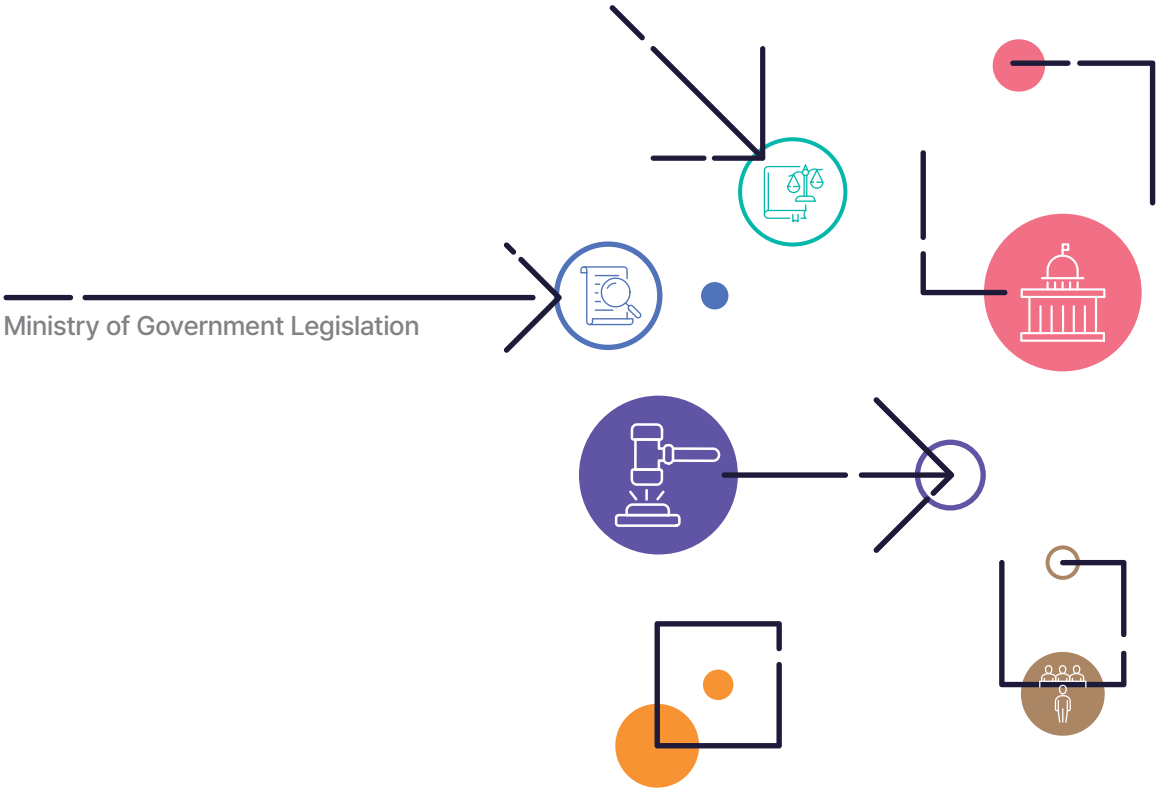
발 간 등 록 번 호
11-1170000-100028-10

2024
법령해석 사례집 상



Ministry of Government Legislation

법제처

CONTENTS

[상권]

제1장 기획재정·금융·공정거래

제1절 기획재정·금융 ····· 3

1. 「소득세법 시행령」 제155조 제8항 및 제16항 등 관련(23-0932) ····· 3
2. 법률 제12152호 「지방세기본법」 부칙 제3조 등 관련(23-0976) ····· 10
3. 「국가재정법」 제96조 등 관련(23-1091) ····· 15
4. 「조세특례제한법」 제97조제1항 등 관련(24-0009) ····· 18
5. 「관세법」제175조제2호 등 관련(24-0169, 24-0436) ····· 22
6. 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호 등 관련(24-0206, 24-0588) ····· 26
7. 「지방세특례제한법」 제177조의2 등 관련(24-0294) ····· 33
8. 「조세특례제한법」 제6조 등 관련(24-0620) ····· 36
9. 「세무사법」 제5조의2제1항제4호 등 관련(24-0655) ····· 40
10. 「지방세법 시행령」 제28조의4제6항제1호가목 등(24-0772) ····· 43
11. 「공유재산 및 물품 관리법」 제8조 등(24-0818) ····· 48
12. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 등 관련(24-0870) ····· 52

제2절 공정거래 ····· 58

1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제47조 등 관련(24-0239, 24-0240) ····· 58
2. 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령」 제9조제4항 등 관련(24-0795) ····· 64
3. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제18조제3항제1호 등 관련(24-0836) ····· 69
4. 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조제3항 등 관련(24-0867) ····· 76

제2장 산업통상자원·중소기업

제1절 산업통상자원 ····· 83

1. 「전기안전관리법 시행규칙」 제29조제3항 등 관련(23-0820) ····· 83
2. 「고압가스 안전관리법」 제22조의2 제4항 등 관련(23-1144, 23-1001, 23-1002) ····· 87

3. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의5 등 관련(24-0008, 23-1144) ····· 92
4. 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 별표 등 관련(24-0008) ····· 95
5. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제59조의2 등 관련(24-0141, 24-0540) ····· 100
6. 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 제2조 본문 관련(24-0246) ····· 109
7. 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 등 관련(24-0323) ····· 112
8. 「대외무역법」 제33조제4항제1호 등 관련(24-0476) ····· 115
9. 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 및 제13조의3제1항 관련(24-0622) ····· 119
10. 「산업안전보건법」 제17조 등 관련(24-0701) ····· 123
11. 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조 등 관련(24-0724, 24-0800) ····· 127
12. 「고압가스 안전관리법 시행령」 제5조의4제1항 제5호 등 관련(24-0851) ····· 133

제2절 중소기업 ····· 138

1. 「중소기업창업 지원법 시행령」 제2조제1항제5호 등 관련(23-0838) ····· 138
2. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제5조제1항 등 관련(24-0077) ····· 142
3. 「지역신용 보증재단법」 제40조제3항 등 관련(24-0552) ····· 146

제3장 교육·여성가족·문화체육관광

제1절 교육 ····· 151

1. 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 등(23-0938) ····· 151
2. 「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항 단서 등 관련(23-1130) ····· 156
3. 「폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법」 제10조 등 관련(24-0059, 24-0160) ····· 161
4. 「계약학과 설치·운영 규정」 제26조제4항 등 관련(24-0099) ····· 165
5. 「교육공무원법」 제41조 등 관련(24-0374, 24-0467) ····· 170
6. 「지방공무원법」 제30조의4제1항 등 관련(24-0384) ····· 174
7. 「사립학교법」 제70조의4 등 관련(24-0455) ····· 178
8. 「사립학교법」 제25조제4항 등 관련(24-0474) ····· 182
9. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제2조제3호 등 관련(24-0600) ····· 186

Ministry of Government Legislation

CONTENTS

제2절 여성가족·청소년 ····· 190

1. 「청소년활동 진흥법」 제16조제1항 등 관련(23-0786, 24-0161) ····· 190
2. 「청소년활동 진흥법 시행규칙」 제7조제4호 등 관련(24-0078) ····· 194
3. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제7조의3제1항 등 관련(24-0460, 24-0564) ·· 198

제3절 문화체육관광 ····· 201

1. 「관광진흥법 시행령」 제13조제1항제3호나목 등 관련(23-0916) ····· 201
2. 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제18조제1항 등 관련(24-0016, 24-0145) ····· 205
3. 「관광진흥법」 제32조 등 관련(24-0062, 24-0456, 24-0457) ····· 208
4. 「관광진흥법」 제7조제1항 관련(24-0155, 24-0435) ····· 214
5. 「근로자퇴직급여 보장법」 제9조제1항 등 관련(24-0211) ····· 219
6. 「관광진흥법 시행령」 별표 1 등 관련(24-0692) ····· 222
7. 대통령령 제18800호 관광진흥법 시행령 일부개정령 부칙 제4조 등 관련(24-0809) ····· 226
8. 「관광진흥법 시행령」 제4조 등 관련(24-0819) ····· 230
9. 「관광진흥법」 제48조의3 제6항 등 관련(24-0822) ····· 235
10. 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조 등 관련(24-0854) ····· 239

제4장 국방·국가보훈

제1절 국방 ····· 245

1. 「병역법」 제77조의2제1항제2호 등 관련(24-0279) ····· 245
2. 「군수품관리법」 제4조 등 관련(24-0631, 24-0686, 24-0687) ····· 250
3. 「병역법 시행령」 제59조제1항 등 관련(24-0668) ····· 256
4. 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제13조제1항제1호 등 관련(24-0740) ····· 260

제2절 국가보훈 ····· 265

1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제25조 등 관련(24-0214) ····· 265
2. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제79조제3항 등 관련(24-0561) ····· 269

제5장 행정자치·인사·안전

제1절 행정일반·지방자치 ····· 277

1. 「공직자의 이해충돌 방지법」 제25조제2항 등 관련(23-0747) ····· 277
2. 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조 등 관련(23-0748, 24-0057) ····· 281
3. 「지방재정법」 제9조제3항 등 관련(23-1005) ····· 285
4. 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제8조제1항 및 「지방교부세법 시행규칙」 별표 2 등 관련(23-1104, 23-1135, 24-0179, 24-0180, 24-0215, 24-0216) ····· 289
5. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제11조제1항제2호 등 관련(23-1177) ····· 294
6. 「지방재정법」 제29조제1항 등 관련(23-1178) ····· 298
7. 「지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제8호사목 등(24-0018) · 303
8. 「행정조사기본법」 제22조 등 관련(24-0051) ····· 308
9. 「공유재산 및 물품 관리법」 제33조 등 관련(24-0123) ····· 313
10. 「공유재산 및 물품관리법」 제16조제2항제5호 등 관련(24-0134) ····· 317
11. 「행정대집행법」 제6조제1항 등 관련(24-0173) ····· 323
12. 「지방자치법」 제33조 등 관련(24-0357) ····· 326
13. 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제17조제6항제3호 등 관련(24-0404) ····· 329
14. 「공유재산 및 물품관리법」 제16조제2항제5호 등 관련(24-0411) ····· 334
15. 「지방자치법」 제35조 등 관련(24-0463) ····· 340
16. 「이북5도 및 미수복 시·군의 명예시장·군수 등 위촉에 관한 규정」 제6조제3항 등 관련(24-0501) ····· 344
17. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(24-0537) ····· 347
18. 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조제2항 등 관련(24-0637) · 351
19. 「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ 제2호 등 관련(24-0659, 24-0820, 24-0857, 24-0858) ····· 355
20. 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 등 관련(24-0673, 24-0757) ····· 358
21. 「자원봉사활동 기본법 시행령」 제15조 등 관련(24-0735, 24-0796) ····· 364
22. 「행정사법」 제2조제1항제1호·제4호 등 관련(24-0770, 24-0915) ····· 370
23. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제2조제4호 등 관련(24-0804, 24-0978) ····· 375
24. 「민원 처리에 관한 법률」 제2조 등 관련(24-0869) ····· 380
25. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(24-0902) ····· 384

Ministry of Government Legislation

CONTENTS

제2절 공무원 ····· 389

1. 「지방공무원법」 제67조의2제1항 등 관련(23-1025) ····· 389
2. 「국가공무원법」 제73조의4제1항 등 관련(23-1094) ····· 393
3. 「공무원 임용령」 제45조의2 등 관련(24-0131, 24-0219) ····· 397
4. 「지방공무원법」 제63조제1항 등 관련(24-0375) ····· 401
5. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2 등 관련(24-0423) ····· 404
6. 「지방공무원법」 제40조 등 관련(24-0495) ····· 407
7. 「국가공무원 복무규정」 제9조 등 관련(24-0519) ····· 410
8. 「국가공무원법」 제2조제3항 등 관련(24-0543, 24-0662) ····· 413
9. 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호 등 관련 (24-0579, 24-0734, 24-0749, 24-0751, 24-0752, 24-0753, 24-0754, 24-0755) ··· 417
10. 「공무원임용령」 제31조제2항 제2호가목1) 등 관련(24-0745) ····· 425
11. 「국가공무원법」 제26조의5 등 관련(24-0769, 24-0919) ····· 429
12. 「국가공무원법」 제26조의5 등 관련(24-0771) ····· 432

제3절 경찰·소방·국민안전 ····· 435

1. 「도로교통법」 제35조제1항·제2항 등(23-1015, 23-1090) ····· 435
2. 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 등 관련(23-1125, 24-0280) ····· 439
3. 「도로교통법」 제5조제1항 등 관련(23-1140) ····· 443
4. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제1호가목 등(23-1156) ····· 447
5. 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행규칙」 제2조제2항제3호 등 관련 (24-0082) ····· 450
6. 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 등 관련(24-0304, 24-0503, 24-0504) ····· 453
7. 「청원경찰법 시행령」 별표 1 등 관련(24-0344) ····· 458
8. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조제3항 등 관련(24-0421, 24-0664, 24-0665) ····· 461
9. 「소하천정비법」 제14조 제1항 등 관련(24-0541, 24-0607, 24-0608) ····· 469
10. 「경비업법」 제4조제3항제5호 등 관련(24-0548) ····· 473
11. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항 등 관련(24-0803) ····· 477
12. 「청원경찰법」 제10조의6제3호 등 관련(24-0903) ····· 482

제6장 농림축산·산림·해양수산

제1절 농림축산 ····· 487

1. 「농어촌정비법」 제86조 등 관련(23-1022) ····· 487
2. 「농지법 시행령」 제24조제1항 제5호 등(23-1083) ····· 492
3. 「농지법 시행령」 제28조제1항 등 관련(24-0247) ····· 495
4. 「농지법」 제56조 등 관련(24-0258) ····· 498
5. 「농지법」 제32조제1항 등 관련(24-0314) ····· 502
6. 「농지법 시행규칙」 제6조제1항 등 관련(24-0410) ····· 506
7. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제19조제2항 등 관련(24-0525) ····· 510
8. 「농지법」 제23조제1항제6호 등 관련(24-0577) ····· 514
9. 「개간촉진법」(1967. 1. 16. 법률 제1872호로 폐지되기 전의 것을 말함) 제23조제1항 등 관련 (24-0628, 24-0940) ····· 517
10. 「농지법」 제63조 등 관련(24-0783) ····· 526

제2절 산림 ····· 530

1. 「산지관리법 시행령」 별표 2 등 관련(23-0644) ····· 530
2. 「산지관리법」 제14조 등 관련(23-1164) ····· 534
3. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제24조 등 관련(23-1175) ····· 537
4. 「산지관리법」 제14조 등 관련(24-0012) ····· 541
5. 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」 제21조제1항제1호 등 관련(24-0091) ····· 546
6. 「산지관리법」 제51조제1항 등 관련(24-0209) ····· 550
7. 「소나무재선충병 방제특별법」 제10조제2항 등 관련(24-0475) ····· 554
8. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제4조제1호 등 관련(24-0690) ····· 558
9. 「산지관리법」 제25조제1항 등 관련(24-0840) ····· 563

제3절 해양수산 ····· 567

1. 「수산업법」 제15조 등 관련(23-0925) ····· 567
2. 「낚시 관리 및 육성법」 제25조 등 관련(23-1114) ····· 572
3. 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제3조 등 관련(24-0511, 24-0688) ····· 576
4. 「항만법」 제9조제4항 등 관련(24-0517) ····· 580

Ministry of Government Legislation

CONTENTS

5. 법률 제12545호 항만법 일부개정법률 부칙 제6조 등 관련(24-0684) ····· 583
6. 「항만법」 제3조제1항 등 관련(24-0713, 24-0777) ····· 588
7. 「연안사고 예방에 관한 법률」 제11조 등 관련(24-0890, 24-0979) ····· 594

제7장 보건복지·식품의약품

제1절 보건복지 ····· 603

1. 「의료법」 제17조제3항 등 관련(23-0913) ····· 603
2. 「장애인복지법」 제63조제2항 등 관련(23-1050) ····· 606
3. 「응급의료에 관한 법률」 제44조제1항 및 제45조제1항 등 관련(24-0003) ····· 610
4. 「응급의료에 관한 법률」 제51조 등 관련(24-0048) ····· 614
5. 「재난적의료비 지원에 관한 법률 시행령」 제7조제1항 등 관련(24-0250) ····· 618
6. 「의료법 시행규칙」 제36조제4항 등 관련(24-0277) ····· 622
7. 「노인복지법 시행규칙」 별표 9 제1호나목 등 관련(24-0325, 24-0563) ····· 626
8. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제12조 등 관련 (24-0558, 24-0685) ····· 630
9. 「사회복지사업법」 제33조제2항 등 관련(24-0606, 24-0733) ····· 634
10. 「공중위생관리법 시행규칙」 제3조 제1항제1호의2 관련(24-0654) ····· 638
11. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제65조 등 관련(24-0679) ····· 642
12. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제50조제1항 등 관련 (24-0682) ····· 647
13. 「의료법」 제21조제1항 등 관련(24-0712) ····· 650
14. 「국민기초생활 보장법」 제16조제2항 등 관련(24-0828) ····· 654

제2절 식품의약품 ····· 657

1. 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 등 관련(23-1079, 24-0176) ····· 657
2. 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제4조 및 「식품위생법」 제44조 등 관련(24-0015) ····· 660
3. 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제4호 등 관련(24-0281) ····· 666
4. 「위생용품 관리법 시행규칙」 별표 1 등 관련(24-0349) ····· 669
5. 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제3호 등 관련(24-0652, 24-0797, 24-0798) ····· 673

[하권]

제8장 환경·고용노동

제1절 환경 ····· 679

1. 「환경영향평가법」 제33조제1항 등 관련(23-0389) ····· 679
2. 「수도법」 제21조의4 등 관련(23-1105) ····· 684
3. 「대기환경보전법」 제79조 등 관련(24-0115) ····· 688
4. 「하천법」 제25조제5항 등 관련(24-0208) ····· 691
5. 「환경영향평가법」 제41조제1항 등 관련(24-0292) ····· 695
6. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제15조제1항 등 관(24-0296) ····· 699
7. 「수도법」 제7조제3항제2호 등 관련(24-0307) ····· 703
8. 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제10조제1항 등 관련(24-0326) ····· 707
9. 「폐기물관리법」 제25조제1항 등 관련(24-0355) ····· 712
10. 법률 제8014호 「하수도법」 부칙 제6조제1항 등 관련(24-0367) ····· 717
11. 「실내공기질 관리법」 제9조제1항 등 관련(24-0465) ····· 721
12. 「환경영향평가법 시행령」 제13조제1항 등 관련(24-0492, 24-0587) ····· 725
13. 「폐기물관리법」 제27조제2항제3호 등 관련(24-0523, 24-0589) ····· 731
14. 「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목 등 관련(24-0567) ····· 737
15. 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목 등 관련(24-0627, 24-0706) ····· 741
16. 「환경영향평가법」 제46조의2 제1항 등 관련(24-0656, 24-0779) ····· 745
17. 「소음·진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제1호 등 관련(24-0694) ····· 751
18. 「대기환경보전법」 제39조 등 관련(24-0698) ····· 756
19. 「상수원 관리규칙」 제15조제1호가목 등 관련(24-0718) ····· 761
20. 「국민건강보험법」 제54조제2호 등 관련(24-0725, 24-0763, 24-0938, 24-0939) ····· 766
21. 대통령령 제22506호 수도법 시행령 일부개정령 부칙 제5조제1호 등 관련(24-0786) ····· 772
22. 「물환경보전법」 제61조의2제1항 등 관련(24-0792) ····· 777

제2절 고용노동 ····· 782

1. 「근로기준법」 제52조제1항 및 제74조제5항 등 관련(24-0033) ····· 782
2. 「근로기준법」 제74조제1항 등 관련(24-0050) ····· 786

Ministry of Government Legislation

CONTENTS

3. 「근로기준법」 제60조제2항 등 관련(24-0114) ····· 789
4. 「근로기준법」 제60조 등 관련(24-0345) ····· 792
5. 「근로기준법 시행령」 제30조제1항 등 관련(24-0586, 24-0732) ····· 795
6. 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙」 제15조제5항 등 관련(24-0605) ····· 798
7. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제33조 등 관련(24-0660) ····· 801
8. 「근로기준법」 제60조 등 관련(24-0674, 24-0778) ····· 806
9. 「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항 등 관련(24-0700) ····· 811
10. 「근로기준법」 제60조제5항 등 관련(24-0775) ····· 814
11. 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령」 제44조제3호 등 관련 (24-0794) ····· 817

제9장 국토교통

제1절 국토개발·건축·건설 ····· 823

1. 「건축법 시행령」 제12조제3항제1호 등 관련(23-0751) ····· 823
2. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목 등 관련(23-0770) ····· 827
3. 「경관법 시행령」 별표 제1호자목 등 관련(23-0782, 24-0056) ····· 832
4. 「건설산업기본법 시행령」 제13조제1항제1호 및 별표 2 등 관련(23-0835) ····· 836
5. 법률 제18828호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부 개정법률 부칙 제2조제1항 등 관련(23-0841) ····· 841
6. 「건축사법」 제19조 등 관련(23-0935) ····· 846
7. 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조 등 관련(23-0956) ····· 850
8. 「주택법」 제15조 등(23-0982) ····· 854
9. 「도시 및 주거환경정비법」 제35조 제5항 단서 등 관련(23-0983, 23-1093) ····· 859
10. 「도시개발법」 제11조제1항제9호 등 관련(23-1067) ····· 862
11. 「지하 안전관리에 관한 특별법」 제24조 등(23-1132) ····· 866
12. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항제2호·제3호의2 등 관련 (23-1153, 23-1154) ····· 870
13. 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제11조제1항제3호 등 관련(23-1160) ····· 878
14. 법률 제18386호 「공익사업을 위한 토지의 취득 및 보상에 관한 법률」 부칙 제3조 등 (23-1168) ····· 881

15. 「산지관리법」 제8조제1항 등 관련(23-1172) ····· 885
16. 「건축법 시행령」 제12조제3항제2호 관련(24-0004) ····· 892
17. 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」 제7조제1항제6호 등 관련(24-0019) ····· 896
18. 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조제1항 등 관련(24-0023, 24-0244) ····· 900
19. 「건축법 시행령」 제86조제2항 등(24-0032, 24-0242, 24-0243) ····· 904
20. 「건설산업기본법」 제49조제1항 등 관련(24-0053) ····· 909
21. 「건축법 시행규칙」 제16조 등 관련(24-0109) ····· 914
22. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제93조제1항 등 관련(24-0241) ····· 919
23. 「건축법」 제83조제1항 등 관련(24-0249, 24-0340) ····· 923
24. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 별표 2 등 관련(24-0269) ····· 927
25. 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호 등 관련(24-0271) ····· 931
26. 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호나목·너목 등 관련(24-0286) ····· 935
27. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제46조제1항 등 관련(24-0302) ····· 940
28. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제26조제1항 등 관련(24-0333, 24-0539) ····· 944
29. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제19조의2 등 관련(24-0343) ····· 948
30. 「건축법」 제2조제1항제11호 등 관련(24-0348, 24-0369) ····· 951
31. 「건설산업기본법」 제2조제12호 관련(24-0353) ····· 956
32. 「건축법 시행령」 제12조제3항제1호 등 관련(24-0356) ····· 959
33. 국토교통부령 제641호 「건축물의 피난·방화구조의 기준 등에 관한 규칙」 부칙 제2조 등 관련 (24-0378, 24-0472) ····· 963
34. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제99조 등 관련(24-0408) ····· 968
35. 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조 등(24-0424) ····· 971
36. 「주차장법 시행령」 제6조제2항 등 관련(24-0428) ····· 975
37. 법률 제16138호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제3조 등 관련(24-0432) ····· 980
38. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제56조제1항 등 관련(24-0433) ····· 985
39. 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제25조제1항 관련(24-0486, 24-0565) ····· 990
40. 「주택법」 제14조의2 제2항 등 관련(24-0488) ····· 993
41. 「지적재조사에 관한 특별법」 제21조제6항 등(24-0524) ····· 997
42. 「건축법」 제11조제1항 및 제21조제1항 등 관련(24-0527, 24-0667) ····· 1001
43. 「건축법 시행령」 제8조제1항 등 관련(24-0533) ····· 1006
44. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항제3호의2 등 관련(24-0544) 1009
45. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 별표 1 제5호사목 관련(24-0550) · 1013

Ministry of Government Legislation

CONTENTS

46. 「건축법 시행령」 제35조 등 관련(24-0551, 24-0801) ····· 1017
47. 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제9조제2항제1호 및 제3호 등 관련 (24-0557) ····· 1024
48. 법률 제18631호 주택법 일부개정법률 부칙 제2조 등 관련(24-0571) ····· 1028
49. 「건축법」 제43조제1항 등(24-0592, 24-0663) ····· 1032
50. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조 등(24-0614) ····· 1036
51. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 별표 1 등 관련 (24-0616, 24-0916, 24-0917) ····· 1041
52. 「개발이익 환수에 관한 법률」 제12조 등(24-0629) ····· 1052
53. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제12조제1호바목 등 관련(24-0638) ····· 1057
54. 「건축법 시행령」 제118조제1항제11호 등 관련(24-0644) ····· 1061
55. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제93조 등 관련(24-0646, 24-0780) ····· 1064
56. 「건축법 시행령」 제119조제1항 등 관련(24-0647) ····· 1070
57. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제21조제3항 등(24-0680) ····· 1073
58. 「건축법 시행령」 제119조제1항제2호다목8) 등(24-0696, 24-0729) ····· 1078
59. 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」 제2조제1호라목 등 관련 (24-0743) ····· 1081
60. 「건축법」 제19조 등(24-0764, 24-0947) ····· 1086
61. 「건설산업기본법」 제88조 등 관련(24-0835) ····· 1091
62. 「건축법 시행령」 별표 15 제13호 등 관련(24-0844) ····· 1095
63. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제84조제1항 등 관련(24-0879) ····· 1099
64. 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호 등 관련(24-0887) ····· 1105

제2절 주택관리·부동산 ····· 1108

1. 「공동주택관리법 시행령」 제14조제3항 등 관련(23-0847) ····· 1108
2. 「공공주택 특별법」 제50조의3제5항 본문 등 관련(23-0888) ····· 1112
3. 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항 제11호 등 관련(23-0905) ····· 1116
4. 「공동주택관리법」 제93조제5항 등 관련(23-0926) ····· 1120
5. 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제23조 등(23-0946) ····· 1124
6. 「주택법」 제57조의2제3항 등 관련(23-1056) ····· 1127
7. 「주택법 시행령」 제60조의2제2항제3호 등 관련(23-1095, 23-1136) ····· 1131
8. 「민간임대 주택에 관한 특별법」 제23조제1항제1호 등 관련(23-1096, 24-0144) ····· 1135
9. 「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항 등 관련(23-1161) ····· 1140

10. 「공동주택관리법」 제14조제3항 등 관련(24-0005) ····· 1144
11. 「공인중개사법」 제33조제1항제3호 등 관련(24-0011) ····· 1149
12. 「공공주택 특별법」 제50조의3제1항 등 관련(24-0087) ····· 1153
13. 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 시행령」 제7조제1항제1호 등 관련(24-0088) 1158
14. 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제9조제2항 등 관련(24-0201) ····· 1161
15. 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조제1항 등 관련(24-0253) ····· 1165
16. 「도시 및 주거환경정비법」 제56조 등 관련(24-0318) ····· 1169
17. 「공동주택관리법」 제30조 등 관련(24-0319) ····· 1172
18. 「도시 및 주거환경정비법」 제124조 등 관련(24-0327) ····· 1177
19. 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제16조의2제1항 등 관련(24-0339) ····· 1180
20. 「도시 및 주거환경정비법」 제124조제4항 등 관련(24-0347) ····· 1183
21. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제25조제1항 등 관련(24-0390) ····· 1187
22. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제46조제1항 등 관련(24-0418) ····· 1192
23. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제45조제1항 등 관련(24-0437) ····· 1196
24. 「도시 및 주거환경정비법」 제50조제4항 등 관련(24-0450, 24-0610) ····· 1202
25. 「공동주택관리법」 제35조제1항제4호 등 관련(24-0451) ····· 1209
26. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제2호 등 관련(24-0477) ····· 1213
27. 「주택법 시행규칙」 제13조제1항 등 관련(24-0480, 24-0536, 24-0562) ····· 1217
28. 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제9조 등 관련(24-0489, 24-0707) ··· 1221
29. 「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제6호 등 관련(24-0506) ····· 1225
30. 「공동주택관리법」 제64조제5항 등 관련(24-0508) ····· 1229
31. 「공공주택 특별법」 제18조 등(24-0545) ····· 1233
32. 「공동주택관리법」 제35조제1항 등 관련(24-0556, 24-0666) ····· 1236
33. 「건축법 시행령」 제19조제1항제1호 등 관련(24-0569) ····· 1239
34. 「주택법」 제21조제1항제1호 등(24-0570) ····· 1243
35. 「공동주택관리법」 제29조제2항 등(24-0602) ····· 1247
36. 「공동주택관리법」 제38조제1항 등 관련(24-0611) ····· 1250
37. 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제9조제2항 등 관련(24-0618) ····· 1254
38. 「도시 및 주거환경정비법」 제29조제5항 등 관련(24-0632) ····· 1258
39. 「공공주택 특별법」 제49조의3 등(24-0639, 24-0704, 24-0705) ····· 1262
40. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제51조제2항 등 관련(24-0695) ····· 1267
41. 구 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제6호 등(24-0711, 24-0799) ····· 1272
42. 「공동주택관리법 시행령」 제11조제4항제5호 등 관련(24-0759) ····· 1277

Ministry of Government Legislation

CONTENTS

43. 「공동주택관리법」 제14조제4항 등 관련(24-0848, 24-0918) ····· 1280
44. 「건축물의 분양에 관한 법률」 제6조 제4항 등 관련(24-0905, 24-0960) ····· 1285

제3절 도로·교통 ····· 1289

1. 「도로법」 제37조 등 관련(23-0858, 24-0055) ····· 1289
2. 「여객자동차 운수사업법」 제5조 등 관련(23-0984, 24-0090) ····· 1293
3. 노면표시)에 해당하는지 여부(「도로교통법」 제74조 등 관련(24-0238) ····· 1298
4. 「주차장법」 제19조의3 제2항 등 관련(24-0362) ····· 1302
5. 법률 제7715호 「토지이용규제 기본법」 부칙 제4조제2항 등 관련(24-0368) ····· 1305
6. 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호 등 관련(24-0385) ····· 1309
7. 「주차장법 시행규칙」 제6조제1항제5호 등 관련(24-0568) ····· 1313
8. 「여객자동차 운수사업법」 제25조 등 관련(24-0635, 24-0756) ····· 1317
9. 「자동차관리법 시행령」 제14조의4제1항 등 관련(24-0731) ····· 1324
10. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 등 관련(24-0741) ····· 1329
11. 「주차장법」 제19조의4제2항 등 관련(24-0814) ····· 1333
12. 「주차장법」 제10조 등 관련(24-0815) ····· 1336

제10장 기타

1. 「공중화장실 등에 관한 법률」 제3조제16호 등 관련(23-0910) ····· 1343
2. 「정보통신공사업법」 제8조제3항 등 관련(24-0217, 24-0218) ····· 1348
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조제1항 등 관련(24-0311) ····· 1354
4. 대통령령 제34309호 「개인정보 보호법 시행령」 부칙 제2조 제1항 등 관련(24-0445) ····· 1358
5. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제3조 단서 등 관련(24-0547) ····· 1362
6. 「지능정보화 기본법」 제2조제16호다목 등 관련(24-0582) ····· 1366



기획재정·금융·공정거래

제1절 기획재정·금융
제2절 공정거래

제1절 기획재정·금융

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0932

민원인 – 「소득세법 시행령」 제155조제16항의 '수도권에 소재한 공공기관이 수도권 밖의 지역으로 이전'하는 경우가 같은 조 제8항의 '근무상의 형편'에 포함되는지 여부(「소득세법 시행령」 제155조 제8항 및 제16항 등 관련)

01 질의요지

「소득세법 시행령」 제155조제1항 전단에서는 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택을 양도하기 전에 다른 주택을 취득함으로써 일시적으로 2주택이 된 경우 '종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 신규 주택을 취득'하고 신규 주택을 취득한 날부터 '3년' 이내에 종전의 주택을 양도하는 경우[1]에는 이를 1세대1주택으로 보아 같은 영 제154조제1항을 적용한다고 규정하고 있고, 같은 영 제155조제16항에서는 같은 조 제1항을 적용[2]할 때 '수도권[3]에 소재한 공공기관[4]이 수도권 밖의 지역으로 이전'하는 경우로서 공공기관의 종사자가 구성하는 1세대가 취득하는 다른 주택이 해당 공공기관이 이전한 시[5]·군 또는 이와 연접한 시·군의 지역에 소재하는 경우에는 같은 조 제1항 중 "3년"을 "5년"으로 보고, 이 경우 해당 1세대에 대해서는 '종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 다른 주택을 취득'하는 요건을 적용하지 아니한다고 규정하고 있는 한편,

---

1) 「소득세법 시행령」 제155조제18항에 따른 사유에 해당하는 경우를 포함하며, 이하 같음.

2) 수도권에 1주택을 소유한 경우에 한정하며, 이하 같음.

3) 「수도권정비계획법」 제2조제1호 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 서울특별시·인천광역시·경기도를 말하며, 이하 같음.

4) 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제2조제14호에 따른 공공기관으로, 중앙행정기관과 그 소속 기관, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 기획재정부장관이 지정한 공공기관, 공공단체 중 법률에 따른 정부출자대상 법인으로서 정부로부터 출자를 받았거나 받고 있는 법인 등을 말하며, 이하 같음.

5) 특별자치시·광역시 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따라 설치된 행정시를 포함하며, 이하 같음.

「소득세법 시행령」 제155조제8항에서는 기획재정부령으로 정하는 취학, ‘근무상의 형편’, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유로 취득한 수도권 밖에 소재하는 주택과 그 밖의 주택(이하 “일반주택”이라 함)을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 같은 영 제154조제1항을 적용한다고 규정하고 있는바,

수도권에 1주택을 소유하고 있는 수도권에 소재한 공공기관 종사자가 해당 기관이 수도권 밖의 지역으로 이전함에 따라 수도권 밖의 지역 소재 주택을 취득한 경우[6]가 「소득세법 시행령」 제155조제8항의 ‘근무상의 형편’에 포함된다고 보아 같은 항을 적용할 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「소득세법 시행령」 제155조제8항의 ‘근무상의 형편’에 포함된다고 보아 같은 항을 적용할 수는 없습니다.

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 해야 하는바[7], 수도권에 1주택을 소유하고 있는 수도권에 소재한 공공기관 종사자가 해당 기관이 수도권 밖의 지역으로 이전함에 따라 수도권 밖의 지역 소재 주택을 취득한 경우가 「소득세법 시행령」 제155조제16항 외에 같은 조 제8항의 ‘근무상의 형편’으로 수도권 밖에 소재하는 주택을 취득한 경우에 포함된다고 보아 같은 항을 적용할 수 있는지 여부는 문언의 형식적인 표현 외에도 해당 규정의 체계, 입법연혁 및 취지 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다.

---

6) 수도권 밖의 지역 소재 주택을 취득한 날부터 5년이 도과한 후 수도권 소재 주택을 양도하려는 경우로서, 「소득세법 시행령」 제155조제16항을 근거로 같은 영 제154조제1항의 1세대1주택 비과세 특례 규정을 적용할 수 없는 경우를 전제함.

7) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다 81035 판결례 참조

먼저 「소득세법」 제94조제1항제1호에서는 '건물'의 양도로 발생하는 소득을 과세 대상 양도소득으로 규정하고 있는 한편, 같은 법 제89조제1항제3호에서는 과세하지 않는 양도소득의 하나로 '1세대가 1주택을 보유하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 주택'(가목) 또는 '1세대가 1주택을 양도하기 전에 다른 주택을 대체취득하거나 상속, 동거봉양, 혼인 등으로 인하여 2주택 이상을 보유하는 경우로서 대통령령으로 정하는 주택'(나목)의 양도로 발생하는 소득을 규정하고 있으며, 같은 호 나목의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제154조제11항에서는 '같은 법 제89조제1항제3호나목에서 "대통령령으로 정하는 주택"이란 같은 법 시행령 제155조에 따른 1세대1주택의 특례에 해당하여 같은 영 제154조를 적용하는 주택을 말한다'고 규정하고 있고, 같은 영 제155조 각 항에서는 2주택 이상을 보유하고 있음에도 1주택을 보유하는 경우로 보아 같은 영 제154조제1항을 적용할 수 있는 특례 요건 등을 규정하고 있습니다.

이와 같은 소득세법령의 문언과 규정체계에 비추어 볼 때, 소득세법령에 따른 양도소득세는 건물 등 자산의 양도로 인하여 발생하는 소득에 대하여 부과하는 세금으로, 주택의 양도로 소득이 발생하였다면 원칙적으로 그 소득에 대하여 양도소득세가 과세되고[8], 예외적으로 ① 1세대가 실제로 1주택을 보유하는 경우로서 「소득세법 시행령」 제154조의 요건을 충족하는 경우(「소득세법」 제89조제1항제3호가목) 또는 ② 1세대가 2주택 이상을 보유하지만 「소득세법 시행령」 제155조에 따른 1세대1주택의 특례에 해당하는 경우로서 같은 영 제154조의 요건을 충족하는 경우(「소득세법」 제89조제1항제3호나목)에 대해서는 양도소득세가 과세되지 아니하는바, 같은 영 제155조는 부득이한 사정으로 2주택을 보유할 수밖에 없는 상황에 대한 배려로 1세대1주택의 외연을 예외적으로 확장하여 실제로는 1세대1주택의 양도가 아님에도 1세대1주택의 양도로 의제[9]하는 특례적 성격의 예외규정이라 할 것인바, 조세나 부담금에 관한 법률의 해석에 관하여는 그 부과요건 또는 감면요건을 막론하고 특별한 사정이 없는 한 법문대로 해석할 것이고 합리적 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 아니하고, 특히 감면요건 규정 가운데에 명백히 특혜규정이라고 볼 수 있는 것은 엄격하게 해석하는 것이 공평원칙에도 부합하므로[10] 합리적인 이유 없이 같은 조 각 항에 따른 비과세 요건을 확장해석해서는 안된다고 할 것입니다.

그런데 「소득세법 시행령」 제155조에서는 1세대1주택의 특례 사유로 '근무상의 형편'과 '수도권 소재 공공기관의 수도권 밖 지역으로 이전'을 각각 제8항과 제16항으로 구분하여

8) 대법원 1983. 12. 13. 선고 83누307 판결례 참조

9) 서울행정법원 2023. 7. 26. 선고 2022구단71793 판결례 참조

10) 법제처 2010. 6. 14. 회신 10-0161 해석례 및 법제처 2013. 4. 26. 회신 13-0101 해석례 참조

별개의 특례 사유로 규정하고 있는 한편, 같은 조 제16항에서는 같은 조 "제1항을 적용할 때" 수도권에 소재한 공공기관이 수도권 밖의 지역으로 이전하는 경우로서 일정 요건을 충족하는 경우에는 같은 조 제1항에 따른 종전의 주택의 양도 기한을 "3년"이 아닌 "5년"으로 보고, '종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 다른 주택을 취득하는 요건'을 적용하지 않도록 하는 규정으로서, 일시적 2주택에 대한 특례를 규정하고 있는 같은 조 제1항에 대한 특례규정인 반면, 같은 조 제8항에서는 '취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유'로 취득한 수도권 밖에 소재하는 주택과 일반주택을 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 '부득이한 사유'가 해소된 날부터 3년 이내에 일반주택을 양도하는 경우 1주택을 소유한 것으로 인정하여 '부득이한 사유'가 지속되는 동안에는 기간 제한 없이 2주택을 보유할 수 있도록 하는 특례라는 점을 고려하면, 같은 조 제8항의 비과세 요건인 '근무상 형편'을 확장하여 같은 조 제16항의 '수도권에 소재한 공공기관의 수도권 밖의 지역으로의 이전'도 포함된다고 보아 같은 조 제16항의 비과세 요건을 충족하지 못하더라도 같은 조 제8항을 근거로 양도소득세 비과세 혜택을 받을 수 있다고 보는 것은 위와 같은 엄격해석 원칙에 반한다고 할 것입니다.

더욱이 「소득세법 시행령」 제155조제8항 및 제16항의 입법연혁을 살펴보면, 2006년 2월 9일 대통령령 제19327호로 구 「소득세법 시행령」을 일부개정하면서 국가균형발전을 위한 '공공기관과 기업의 지방이전 촉진을 지원'하기 위해 공공기관 등 이전에 따른 주택 취득으로 일시적 2주택이 된 종사자에 대해 1세대1주택으로 인정하는 중복보유 허용기간을 같은 영 제155조제1항에 따른 기간보다 연장해 주는 내용으로[11] 같은 조에 제16항이 먼저 신설된 후, 2008년 11월 28일 대통령령 제21138호로 구 「소득세법 시행령」을 일부개정하면서 '지방의 부동산·건설경기 활성화[12]'를 위한 목적으로 취학, '근무상의 형편' 등 부득이한 사유로 2주택을 보유하는 경우에 대해 비과세 특례를 부여하기 위하여 같은 영 제155조에 제8항이 신설되었는바, 「소득세법 시행령」 제155조제16항은 1세대가 '수도권 소재 공공기관이 수도권 밖의 지역으로 이전'하게 되면서 신규 주택을 취득하게 된 경우 단기간에 거래가 이루어지지 않는 주택의 특성상 '일시적으로 2주택을 보유'할 수밖에 없기 때문에 같은 조 제1항에 대한 특례로서 신규 주택을 취득한 날부터 5년 이내에 종전 주택을 양도하는 경우 양도소득세를 부과하지 않으려는 것인 반면, 같은 조 제8항은 1세대가 '근무상의 형편' 등의 부득이한 사유로 수도권 밖 주택을 취득하고 그 부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내에

11) 소득세법시행령 개정요강(2006. 1.) 참조

12) 2008년 11월 28일 대통령령 제21138호로 일부개정되어 2008년 11월 28일 시행된 소득세법 시행령 일부개정령 개정이유 참조

일반주택을 양도하는 경우를 지방 부동산·건설경기의 활성화에 기여한다고 보아 양도소득세를 부과하지 않으려는 것으로서, 그 취지와 대상이 다를 뿐만 아니라, 각 항이 신설된 이후 현재까지 그 특례 인정 요건을 완화(제16항)[13] 또는 강화(제8항)[14]하는 방향으로 각각 개정되어 왔는바, 이러한 입법연혁 및 취지에 비추어 볼 때에도 「소득세법 시행령」 제155조 제8항 및 제16항은 서로 구분되는 별개의 특례규정으로서 '수도권에 소재한 공공기관의 수도권 밖의 지역으로의 이전'이 '근무상의 형편'에도 포함된다고 보아 각 항에 따른 특례를 선택적으로 적용할 수는 없습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「소득세법 시행령」 제155조제8항의 '근무상의 형편'에 포함된다고 보아 같은 항을 적용할 수는 없습니다.

관계법령

소득세법

제89조(비과세 양도소득) ① 다음 각 호의 소득에 대해서는 양도소득에 대한 소득세(이하 "양도소득세"라 한다)를 과세하지 아니한다.

1.·2. (생 략)

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택(주택 및 이에 딸린 토지의 양도 당시 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 고가주택은 제외한다)과 이에 딸린 토지로서 건물이 정착된 면적에 지역별로 대통령령으로 정하는 배율을 곱하여 산정한 면적 이내의 토지(이하 이 조에서 "주택부수토지"라 한다)의 양도로 발생하는 소득

가. 1세대가 1주택을 보유하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 주택

나. 1세대가 1주택을 양도하기 전에 다른 주택을 대체취득하거나 상속, 동거봉양, 혼인 등으로 인하여 2주택 이상을 보유하는 경우로서 대통령령으로 정하는 주택

5. (생 략)

②·③ (생 략)

소득세법 시행령

제154조(1세대1주택의 범위) ① 법 제89조제1항제3호가목에서 "대통령령으로 정하는 요건"이란

13) 2008. 2. 22. 대통령령 제20618호로 종전의 주택 처분기간을 2년에서 5년으로 연장하는 내용으로 개정되었고, 2012. 6. 29. 대통령령 제23887호로 종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 신규 주택을 취득하는 요건을 적용하지 않는 내용으로 개정되어 비과세 요건이 완화됨.

14) 2012. 2. 2. 대통령령 제23588호로 처분기간의 제한 없이 비과세하던 것을 "부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내"에 일반주택을 양도하는 경우에만 양도소득세를 비과세하는 내용으로 개정되어 비과세 요건이 강화됨.

1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 해당 주택의 보유기간이 2년(제8항제2호에 해당하는 거주자의 주택인 경우는 3년) 이상인 것[취득 당시에 「주택법」 제63조의2제1항제1호에 따른 조정대상지역(이하 "조정대상지역"이라 한다)에 있는 주택의 경우에는 해당 주택의 보유기간이 2년(제8항제2호에 해당하는 거주자의 주택인 경우에는 3년) 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 것]을 말한다. 다만, 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 보유기간 및 거주기간의 제한을 받지 않으며 제5호에 해당하는 경우에는 거주기간의 제한을 받지 않는다.

1. ~ 5. (생 략)

② ~ ⑫ (생 략)

제155조(1세대1주택의 특례) ① 국내에 1주택을 소유한 1세대가 그 주택(이하 이 항에서 "종전의 주택"이라 한다)을 양도하기 전에 다른 주택(이하 이 조에서 "신규 주택"이라 한다)을 취득(자기가 건설하여 취득한 경우를 포함한다)함으로써 일시적으로 2주택이 된 경우 종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 신규 주택을 취득하고 신규 주택을 취득한 날부터 3년 이내에 종전의 주택을 양도하는 경우(제18항에 따른 사유에 해당하는 경우를 포함한다)에는 이를 1세대1주택으로 보아 제154조제1항을 적용한다.

② ~ ⑦ (생 략)

⑧ 기획재정부령으로 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유(이하 이 항에서 "부득이한 사유"라 한다)로 취득한 수도권 밖에 소재하는 주택과 그 밖의 주택(이하 이 항에서 "일반주택"이라 한다)을 국내에 각각 1개씩 소유하고 있는 1세대가 부득이한 사유가 해소된 날부터 3년 이내에 일반주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 제154조제1항을 적용한다.

⑨ ~ ⑮ (생 략)

(16) 제1항을 적용(수도권에 1주택을 소유한 경우에 한정한다)할 때 수도권에 소재한 법인 또는 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제2조제14호에 따른 공공기관이 수도권 밖의 지역으로 이전하는 경우로서 법인의 임원과 사용인 및 공공기관의 종사자가 구성하는 1세대가 취득하는 다른 주택이 해당 공공기관 또는 법인이 이전한 시(특별자치시·광역시 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따라 설치된 행정시를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)·군 또는 이와 연접한 시·군의 지역에 소재하는 경우에는 제1항 중 "3년"을 "5년"으로 본다. 이 경우 해당 1세대에 대해서는 종전의 주택을 취득한 날부터 1년 이상이 지난 후 다른 주택을 취득하는 요건을 적용하지 아니한다.

(17) ~ ㉕ (생 략)

소득세법 시행규칙

제71조(1세대1주택의 범위) ①·② (생 략)

③ 영 제154조제1항제1호 및 제3호에서 "기획재정부령으로 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그 밖에 부득이한 사유"란 세대의 구성원 중 일부(영 제154조제1항제1호의 경우를 말한다) 또는 세대전원(영 제154조제1항제3호의 경우를 말한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

사유로 다른 시(특별시, 광역시, 특별자치시 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따라 설치된 행정시를 포함한다. 이하 이 조, 제72조 및 제75조의2에서 같다)·군으로 주거를 이전하는 경우(광역시지역 안에서 구지역과 읍·면지역 간에 주거를 이전하는 경우와 특별자치시, 「지방자치법」 제7조제2항에 따라 설치된 도농복합형태의 시지역 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따라 설치된 행정시 안에서 동지역과 읍·면지역 간에 주거를 이전하는 경우를 포함한다. 이하 이 조, 제72조 및 제75조의2에서 같다)를 말한다.

1. 「초·중등교육법」에 따른 학교(초등학교 및 중학교를 제외한다) 및 「고등교육법」에 따른 학교에의 취학
2. 직장의 변경이나 전근등 근무상의 형편
3. 1년이상의 치료나 요양을 필요로 하는 질병의 치료 또는 요양
4. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력으로 인한 전학(같은 법에 따른 학교폭력대책자치위원회가 피해학생에게 전학이 필요하다고 인정하는 경우에 한한다)

제72조(1세대1주택의 특례) ① ~ ⑥ (생 략)

⑦ 영 제155조제8항 및 같은 조 제10항제5호에서 "기획재정부령으로 정하는 취학, 근무상의 형편, 질병의 요양, 그밖에 부득이한 사유"란 세대의 구성원 중 일부(영 제155조제10항제5호의 경우를 말한다) 또는 세대전원(영 제155조제8항의 경우를 말한다)이 제71조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 다른 시·군으로 주거를 이전하는 경우를 말한다.

⑧·⑨ (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-0976

민원인 – 상속인이 2013년 7월에 상속을 원인으로 취득세 과세물건을 취득한 경우 그 취득세에 대하여 법률 제12152호 지방세기본법 제38조제1항제1호의2에 따라 10년의 부과제척기간이 적용되는지 여부(법률 제12152호 「지방세기본법」 부칙 제3조 등 관련)

01 질의요지

구 「지방세기본법」(2014. 1. 1. 법률 제12152호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 "구 지방세기본법"이라 함) 제38조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 지방세는 대통령령으로 정하는 바에 따라 부과할 수 있는 날부터 같은 항 각 호에서 정하는 기간이 만료되는 날까지 부과하지 아니한 경우에는 부과할 수 없다고 규정하면서, 같은 항 제3호에서 '그 밖의 경우[15]에는 5년'을 규정하고 있었는데,

2014년 1월 1일 법률 제12152호로 일부개정되어 같은 날 시행된 「지방세기본법」(이하 "개정 지방세기본법"이라 함)에서는 제38조제1항에 제1호의2를 신설하여 "상속을 원인으로 취득하는 경우"에는 지방세 부과의 제척기간(이하 "부과제척기간"이라 함)을 10년으로 규정함으로써 상속을 원인으로 취득하는 경우에 대한 지방세 부과제척기간을 종전의 5년에서 10년으로 연장하면서, 같은 법 부칙 제3조에서 "제38조제1항제1호의2의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 해당 지방세를 부과할 수 있는 날이 개시되는 경우부터 적용한다"는 내용의 적용례를 두었는바,

상속인이 개정 지방세기본법 시행일 전인 2013년 7월에 피상속인의 사망에 따라 상속을 원인으로 취득세[16] 과세물건[17]을 취득한 경우, 그 취득세에 대해서는 구 지방세기본법 제38조제1항제3호에 따라 5년의 부과제척기간이 적용되는지, 아니면 개정 지방세기본법 제38조제1항제1호의2에 따라 10년의 부과제척기간이 적용되는지?[18]

---

15) 구 지방세기본법 제38조 제1항에 따라 납세자가 사기나 그 밖의 부정한 행위로 지방세를 포탈하거나 환급 또는 경감받은 경우(제1호)나 납세자가 법정신고기한까지 소득세, 법인세 또는 지방소비세의 과세표준신고서를 제출하지 아니하여 해당 지방소득세 소득분 또는 지방소비세를 부과할 수 없는 경우(제2호) 외의 경우를 의미함.

16) 「지방세기본법」 제7조제2항제1호에 따른 취득세를 말하며, 이하 같음.

17) 「지방세기본법」 제34조제1항제1호에 따른 과세물건으로서, 과세의 대상이 되는 것을 말하며, 이하 같음.

18) 구 지방세기본법 제38조제1항제1호 및 개정 지방세기본법 제38조제1항제1호에는 해당하지 않는 경우를 전제함.

02 회답

상속인이 개정 지방세기본법 시행일 전인 2013년 7월에 피상속인의 사망에 따라 상속을 원인으로 취득세 과세물건을 취득한 경우 그 취득세에 대해서는 개정 지방세기본법 제38조제1항제1호의2에 따라 10년의 부과제척기간이 적용됩니다.

03 이유

일반적으로 부칙의 적용례 규정은 새로운 법령의 시행에 있어서 최초 적용시기 및 대상 등에 관한 사항을 구체적으로 규정함으로써 집행상의 논란을 방지하기 위하여 두는 것인데[19], 개정 지방세기본법 제38조제1항제1호의2에서 지방세는 대통령령으로 정하는 바에 따라 부과할 수 있는 날부터 상속을 원인으로 과세물건을 취득하는 경우에는 10년의 기간이 만료되는 날까지 부과하지 아니한 경우에는 부과할 수 없다고 규정하면서, 같은 법 부칙 제1조 본문에서는 "이 법은 2014년 1월 1일부터 시행한다"고 규정하고 있고, 같은 법 부칙 제3조에서는 "부과의 제척기간 연장에 관한 적용례"라는 제목 하에 "제38조제1항제1호의2의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 해당 지방세를 부과할 수 있는 날이 개시되는 경우부터 적용한다"고 규정하여 같은 법 제38조제1항제1호의2의 개정규정의 적용 관계를 별도로 규정하고 있는바, 이에 따라 최초로 해당 지방세를 부과할 수 있는 날이 개정 지방세기본법의 시행일인 2014년 1월 1일 전인 경우에는 구 지방세기본법 제38조제1항제3호에 따른 5년의 부과제척기간이, 2014년 1월 1일 이후인 경우에는 개정 지방세기본법 제38조제1항제1호의2에 따른 10년의 부과제척기간이 적용될 것입니다.

그리고 구 지방세기본법 제38조제1항 각 호 외의 부분 본문의 위임에 따라 마련된 구 「지방세기본법 시행령」(2013. 3. 23. 대통령령 제24425호로 타법개정되어 같은 날 시행된 것을 말함) 제18조제1항제1호 본문에서는 '같은 법 또는 지방세관계법에서 신고납부하도록 규정된 지방세의 경우에는 해당 지방세에 대한 신고기한의 다음 날'을 같은 법 제38조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 지방세를 부과할 수 있는 날로 규정하고 있고, 구 「지방세법」(2013. 6. 7. 법률 제11873호로 타법개정되어 2013. 7. 1. 시행된 것을 말함) 제20조제1항에서는 취득세 과세물건을 취득한 자는 상속으로 인한 경우는 상속개시일이 속하는 달의

19) 법제처 2013. 1. 7. 회신 12-0688 해석례 참조

말일부터 6개월 이내에 산출한 세액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하고 납부해야 한다고 규정하고 있으며, 「민법」 제997조에서는 상속은 사망으로 인하여 개시 된다고 규정하고 있는바, 상속을 원인으로 과세물건을 취득하는 경우 최초로 취득세를 부과할 수 있는 날은 피상속인이 사망한 날이 속하는 달의 말일부터 6개월이 되는 날의 다음 날이라고 할 것입니다.

그렇다면 이 사안과 같이 2013년 7월 중 피상속인이 사망하면서 상속을 원인으로 취득세 과세물건을 취득한 경우, 피상속인이 사망한 날이 속하는 달의 말일인 2013년 7월 31일부터 6개월 이내인 2014년 2월 3일[20]까지 취득세를 신고해야 하고, 그 신고기한의 다음 날인 2014년 2월 4일부터 취득세를 부과할 수 있으므로, 이 사안의 경우 '최초로 취득세를 부과할 수 있는 날'은 개정 지방세기본법이 시행된 2014년 1월 1일 이후로서, 그 취득세에 대해서는 개정 지방세기본법 부칙 제3조에 따라 같은 법 제38조제1항제1호의2의 개정규정에 따른 10년의 부과제척기간이 적용된다고 할 것입니다.

한편 이 사안과 같이 개정 지방세기본법 시행 전에 취득세 과세물건을 취득함으로써 취득세 납세의무가 이미 성립한 경우에 대하여 같은 법 부칙 제3조에 따라 개정 지방세기본법 제38조제1항제1호의2를 적용하는 것은 「대한민국헌법」 제13조제2항 및 「지방세기본법」 제20조제2항에 따른 소급과세금지 원칙에 반하는 것으로서 허용될 수 없다는 의견이 있습니다.

그러나 소급과세금지 원칙은 조세법령을 그 시행 전에 종결된 사실에 소급하여 '조세부과의 요건[21]'으로 삼지 못한다는 것을 의미하는 것인데, 개정 지방세기본법 제38조제1항제1호의2의 개정규정은 지방세 납부의무가 성립된 이후 지방세부과의 요건을 변경하는 것이 아니라 지방세 부과권의 제척기간만을 연장하는 것으로서[22] 소급과세금지 원칙에 위배되지 않으며[23], 개정 지방세기본법 부칙 제3조는 같은 법 제38조제1항제1호의2 개정규정을 그 시행 후 최초로 취득세를 부과할 수 있는 날이 개시되는 경우, 즉 그 부과제척기간의 진행이 시작되는 경우부터 적용한다는 것이지 부과제척기간이 이미 경과된 경우에 적용한다는 것은 아니므로, 소급입법에 해당하지도 않는바[24], 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다[25].

---

20) 2014년 1월 30일부터 2014년 2월 1일까지는 설 연휴에 해당하고, 2014년 2월 2일은 일요일로 공휴일에 해당하므로, 신고기한은 2014년 2월 3일에 만료됨(구 지방세기본법 제24조제1항 및 대법원 1991. 2. 8. 선고 90후1680 판결례 참조)

21) 납세의무자, 과세물건, 과세물건의 귀속, 과세표준, 세율 등 납세의무의 성립요건을 의미함(임승순, 조세법, 박영사, 2021, 106면 참조).

22) 헌법재판소 2012. 12. 27. 선고 2011헌바132 전원재판부 결정례 참조

23) 헌법재판소 2003. 6. 26. 선고 2000헌바82 전원재판부 결정례

따라서 상속인이 개정 지방세기본법 시행일 전인 2013년 7월에 피상속인의 사망에 따라 상속을 원인으로 취득세 과세물건을 취득한 경우 그 취득세에 대해서는 개정 지방세기본법 제38조제1항제1호의2에 따라 10년의 부과제척기간이 적용됩니다.

관계법령

지방세기본법(2014. 1. 1. 법률 제12152호로 일부개정되기 전의 것)

제38조(부과의 제척기간) ① 지방세는 대통령령으로 정하는 바에 따라 부과할 수 있는 날부터 다음 각 호에서 정하는 기간이 만료되는 날까지 부과하지 아니한 경우에는 부과할 수 없다. 다만, 조세의 이중과세방지를 위하여 체결한 조약(이하 "조세조약"이라 한다)에 따라 상호합의절차가 진행 중인 경우에는 「국제조세조정에 관한 법률」 제25조에서 정하는 바에 따른다.

1. 납세자가 사기나 그 밖의 부정한 행위로 지방세를 포탈하거나 환급 또는 경감받은 경우에는 10년
2. 납세자가 법정신고기한까지 소득세, 법인세 또는 지방소비세의 과세표준신고서를 제출하지 아니하여 해당 지방소득세 소득분 또는 지방소비세를 부과할 수 없는 경우에는 7년
3. 그 밖의 경우에는 5년

② ~ ⑤ (생 략)

지방세기본법 시행령(2013. 3. 23. 대통령령 제24425호로 타법개정되어 같은 날 시행된 것)

제18조(제척기간의 기산일) ① 법 제38조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 지방세를 부과할 수 있는 날은 다음 각 호에 해당하는 날로 한다.

1. 법 또는 지방세관계법에서 신고납부하도록 규정된 지방세의 경우에는 해당 지방세에 대한 신고기한의 다음 날. 이 경우 예정신고기한, 중간예납기한 및 수정신고기한은 신고기한에 포함되지 아니한다.
2. 제1호에 따른 지방세 외의 지방세의 경우에는 해당 지방세의 납세의무성립일

지방세기본법(2014. 1. 1. 법률 제12152호로 일부개정되어 2014. 1. 1. 시행된 것)

제38조(부과의 제척기간) ① 지방세는 대통령령으로 정하는 바에 따라 부과할 수 있는 날부터 다음 각 호에서 정하는 기간이 만료되는 날까지 부과하지 아니한 경우에는 부과할 수 없다. 다만, 조세의 이중과세를 방지하기 위하여 체결한 조약(이하 "조세조약"이라 한다)에 따라 상호합의절차가 진행 중인 경우에는 「국제조세조정에 관한 법률」 제25조에서 정하는 바에 따른다.

1. 납세자가 사기나 그 밖의 부정한 행위로 지방세를 포탈하거나 환급 또는 경감받은 경우에는 10년
1의2. 상속을 원인으로 취득하는 경우에는 10년

24) 대법원 1999. 9. 3. 선고 98두7060 판결례 참조

25) 헌법재판소 2003. 6. 26. 선고 2000헌바82 전원재판부 결정례 참조

2. 납세자가 법정신고기한까지 소득세, 법인세 또는 지방소비세의 과세표준신고서를 제출하지 아니하여 해당 지방소득세 또는 지방소비세를 부과할 수 없는 경우에는 7년
3. 그 밖의 경우에는 5년

② ~ ⑤ (생 략)

법률 제12152호 지방세기본법 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2014년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 제142조제3항제1호의2마목의 개정규정은 2014년 8월 7일부터 시행한다.

제2조(일반적 적용례) 이 법은 이 법 시행 후 최초로 납세의무가 성립하는 분부터 적용한다.

제3조(부과의 제척기간 연장에 관한 적용례) 제38조제1항제1호의2의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 해당 지방세를 부과할 수 있는 날이 개시되는 경우부터 적용한다.

질의제목 3 ▶ 안건번호 23-1091

민원인 – 국가가 소속 공무원에게 보수를 과다하게 지급하여 그 과다 지급된 보수의 반환을 구하는 경우 그 과다지급 보수 반환청구권의 소멸시효 기간(「국가재정법」 제96조 등 관련)

01 질의요지

「국가재정법」 제96조제1항에서는 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리로서 시효에 관하여 다른 법률에 규정이 없는 것은 5년 동안 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다고 규정하고 있는 한편,

「민법」 제163조제1호에서는 이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 한 채권은 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다고 규정하고 있는바,

국가가 소속 공무원에게 보수를 과다하게 지급하여 그 과다 지급된 보수의 반환을 구하는 경우, 그 과다지급된 보수의 반환을 청구할 수 있는 권리의 소멸시효 기간은 「국가재정법」 제96조제1항에 따라 5년인지, 아니면 「민법」 제163조제1호에 따라 3년인지?

02 회답

국가가 소속 공무원에게 보수를 과다하게 지급하여 그 과다 지급된 보수의 반환을 구하는 경우, 그 과다지급된 보수의 반환을 청구할 수 있는 권리의 소멸시효 기간은 「국가재정법」 제96조제1항에 따라 5년입니다.

03 이유

「국가재정법」 제96조제1항에서는 "금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리"로서 시효에 관하여 다른 법률에 규정이 없는 것은 5년 동안 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다고

규정하면서, 금전 급부의 발생원인에 관하여는 아무런 제한을 두고 있지 않고 있으므로, 이 사안과 같이 '국가'가 소속 공무원에게 '보수'를 과다하게 지급하여 그 과다 지급된 '보수'의 반환을 청구하는 권리는 법률상 원인 없이 지급된 금전, 즉 부당이득의 반환을 구하는 것을 내용으로 하는 "금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리"에 해당하므로, 「국가재정법」 제96조제1항에 따라 5년의 소멸시효 기간이 적용된다고 보아야 합니다.

한편 「국가재정법」 제96조제1항에서는 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리로서 시효에 관하여 "다른 법률에 규정이 없는 것"은 5년 동안 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다고 규정하고 있고, 「민법」 제163조제1호에서 이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 한 채권은 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다고 규정하고 있는바, 「민법」 제163조제1호는 「국가재정법」 제96조제1항에 따른 다른 법률의 규정에 해당하여, 국가가 과다지급된 보수의 반환을 청구할 수 있는 권리에 대해서는 「국가재정법」 제96조제1항이 아닌 「민법」 제163조제1호에 따라 3년의 소멸시효 기간이 적용된다는 의견이 있습니다.

그러나 「민법」 제163조제1호가 적용되기 위해서는 해당 채권이 "이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 하는 채권"에 해당해야 할 것인데, 이 때 '1년 이내의 기간으로 정한 채권'이란 1년 이내의 정기로 지급되는 채권을 말하는 것으로서[26], 이 사안의 채권은 보수의 지급을 목적으로 하는 채권이 아닌, 국가가 법률상 원인 없이 과다하게 지급된 보수에 대한 반환을 구하는 권리로서 일종의 부당이득 반환청구권에 해당하는바, 같은 호에 따른 급료채권 등 1년 이내의 정기로 지급되는 채권에 해당하지 않으므로, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 국가가 소속 공무원에게 보수를 과다하게 지급하여 그 과다 지급된 보수의 반환을 구하는 경우, 그 과다지급된 보수의 반환을 청구할 수 있는 권리의 소멸시효 기간은 「국가재정법」 제96조제1항에 따라 5년입니다.

26) 대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다65821 판결례 참조

관계법령

국가재정법

제96조(금전채권·채무의 소멸시효) ① 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리로서 시효에 관하여 다른 법률에 규정이 없는 것은 5년 동안 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.

② 국가에 대한 권리로서 금전의 급부를 목적으로 하는 것도 또한 제1항과 같다.

③ 금전의 급부를 목적으로 하는 국가의 권리의 경우 소멸시효의 중단·정지 그 밖의 사항에 관하여 다른 법률의 규정이 없는 때에는 「민법」의 규정을 적용한다. 국가에 대한 권리로서 금전의 급부를 목적으로 하는 것도 또한 같다.

④ 법령의 규정에 따라 국가가 행하는 납입의 고지는 시효중단의 효력이 있다.

민법

제162조(채권, 재산권의 소멸시효) ① 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 채권 및 소유권 이외의 재산권은 20년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

제163조(3년의 단기소멸시효) 다음 각호의 채권은 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

1. 이자, 부양료, 급료, 사용료 기타 1년 이내의 기간으로 정한 금전 또는 물건의 지급을 목적으로 한 채권
2. ~ 7. (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0009

민원인 – 「조세특례제한법」 제97조제1항 본문의 “2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시”하였을 것이라는 요건이 같은 항 단서에도 적용되는지 여부(「조세특례제한법」 제97조제1항 등 관련)

01 질의요지

「조세특례제한법」 제97조제1항 본문에서는 대통령령으로 정하는 거주자가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 국민주택[27]을 2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시하여 5년 이상 임대한 후 양도하는 경우에는 그 주택(이하 “임대주택”이라 함)을 양도함으로써 발생하는 소득에 대한 양도소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면한다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 “다만, 「민간임대주택에 관한 특별법」 또는 「공공주택 특별법」에 따른 건설임대주택 중 5년 이상 임대한 임대주택과 같은 법에 따른 매입임대주택 중 1995년 1월 1일 이후 취득 및 임대를 개시하여 5년 이상 임대한 임대주택(취득 당시 입주된 사실이 없는 주택만 해당한다) 및 10년 이상 임대한 임대주택의 경우에는 양도소득세를 면제한다”고 규정하고 있는바,

「조세특례제한법」 제97조제1항 본문의 “2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시”하였을 것이라는 요건이 같은 항 단서에도 적용되어, 2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시한 경우에만 같은 항 단서에 따라 양도소득세를 면제받을 수 있는지?

02 회답

「조세특례제한법」 제97조제1항 본문의 “2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시”하였을 것이라는 요건은 같은 항 단서에도 적용되어, 2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시한 경우에만 같은 항 단서에 따라 양도소득세를 면제받을 수 있습니다.

27) 「주택법」에 따른 국민주택 규모 이하의 주택을 의미하고(「조세특례제한법」 제55조의2제4항 및 같은 법 시행령 제51조의2 제3항 참조), 이에 딸린 해당 건물 연면적의 2배 이내의 토지를 포함하며, 이하 같음.

03 이유

먼저 「조세특례제한법」 제97조제1항 본문에서는 대통령령으로 정하는 거주자가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 국민주택을 "2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시"하여 5년 이상 임대한 후 양도하는 경우에는 그 임대주택을 양도함으로써 발생하는 소득에 대한 양도소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 "감면"한다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 ① 「민간임대주택에 관한 특별법」 또는 「공공주택 특별법」에 따른 건설임대주택 중 5년 이상 임대한 임대주택과 ② 같은 법에 따른 매입임대주택 중 1995년 1월 1일 이후 취득 및 임대를 개시하여 5년 이상 임대한 임대주택(취득 당시 입주된 사실이 없는 주택만 해당함) 및 ③ 10년 이상 임대한 임대주택의 경우에는 양도소득세를 "면제"한다고 규정하고 있는데, 일반적으로 법령의 단서는 본문의 규정을 전제[28]로 본문의 주된 내용에 대한 예외를 인정하거나 규율 대상 중 일부에 대해 달리 정할 필요가 있을 때 두는 것으로서, 「조세특례 제한법」 제97조제1항 단서는 양도소득세 "감면" 대상 임대주택의 요건을 정하고 있는 같은 항 본문과는 달리 양도소득세 "면제" 대상 임대주택의 요건을 정하면서, ②에서 매입임대주택에 대해서는 그 임대 개시 시점을 '1995년 1월 1일 이후'로 한정[29]하고 있을 뿐, 임대주택의 임대 개시 기한에 관한 같은 항 본문의 "2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시"하였을 것이라는 요건의 적용을 배제하거나 그 기한을 달리 정한 것으로 볼만한 명문의 규정을 두지 않았으므로, 같은 항 본문의 "2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시"하였을 것이라는 요건은 같은 항 단서의 경우에도 그대로 적용된다 할 것입니다.

그리고 임대주택에 대한 양도소득세 감면제도의 입법연혁을 살펴보면, 「조세특례제한법」 제97조제1항 본문의 "2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시"하였을 것이라는 요건은 해당 특례가 신설될 당시에는 없었다가[30], 2000년 12월 29일 법률 제6297호로 구 「조세특례제한법」[31]을 일부개정하면서 신설된 것인데, 이는 1999년 12월 28일 법률 제6045호로 「조세특례제한법」을 일부개정할 당시 주택 경기를 활성화하고 주택 전세값을 안정시키기 위해[32] '1999년 8월 20일부터 2001년 12월 31일 사이에 신축되는 국민주택 등'을 취득하여 5년간 임대한 후 이를 양도하는 경우에는 양도소득세를 면제하는 내용의 '신축 주택' 임대에

28) 법제처 2011. 9. 1. 회신 11-0444 해석례, 법제처 2012. 6. 8. 회신 12-0255 해석례, 대법원 2016. 6. 9. 선고 2015다78536 판결례 및 대구지방법원 2023. 8. 16. 선고 2023구합124 판결례 참조

29) 매입임대주택의 경우 1995년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 임대를 개시한 경우 양도소득세 면제 가능

30) 1986. 12. 26. 법률 제3865호로 일부개정되어 1987. 1. 1. 시행된 조세특례제한법 제67조의4제1항 참조

31) 2000. 12. 29. 법률 제6297호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음.

32) 1999. 12. 28. 법률 제6045호로 일부개정되어 2000. 1. 1. 시행된 조세특례제한법 일부개정법률 개정이유 참조

대한 양도소득세 감면 특례가 제97조의2로 신설됨에 따라 '이미 건축된 주택'을 5년 이상 임대하는 자 등에 대하여 양도소득세 감면 및 면제 혜택을 부여하는 구「조세특례제한법」 제97조제1항의 '본문과 단서'를 그대로 둘 경우 같은 법 제97조의2에 따른 주택 신축 및 신축 주택의 임대에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려하여, 같은 법 제97조제1항에 따른 기존 특례에 일종의 '적용 시한'을 둔 것인바,[33] "2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시"하였을 것이라는 요건이 같은 항 단서에는 적용되지 않아 이미 건축된 주택에 대하여 임대 개시 시기와 관계없이 양도소득세가 면제된다고 해석하는 것은 그 입법연혁 및 취지에 부합하지 않습니다.

더욱이「조세특례제한법」 제97조제1항 본문은 장기 임대주택에 대한 양도소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면하는 특례를, 같은 항 단서는 장기 임대주택에 대한 양도소득세를 완전히 면제하는 특례를 둔 것으로서, 특정 요건을 만족하는 장기 임대주택에 대하여 같은 항 본문보다 더 큰 세제 혜택을 부여하는 같은 항 단서의 요건은 보다 엄격하게 해석하는 것이 타당하다 할 것인데[34], 만약 같은 항 본문의 "2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시"하였을 것이라는 요건이 같은 항 단서에는 적용되지 않는다고 해석한다면, 같은 항 본문에 따른 양도소득세의 100분의 50 상당액 감면 특례는 "2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시"한 임대주택에 한정하여 적용되는 반면, 같은 항 단서에 따른 양도소득세 면제 특례는 그러한 제한 없이 적용됨으로써, '감면적용 시한'에 관하여는 같은 항 본문에 따른 '양도소득세 일부 감면의 요건'보다 같은 항 단서에 따른 '양도소득세 면제의 요건'이 완화되는 결과에 도달하므로, 이는 양도소득세의 일부 감면과 면제의 특례를 정하고 있는 같은 항 본문과 단서의 관계에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서「조세특례제한법」 제97조제1항 본문의 "2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시"하였을 것이라는 요건은 같은 항 단서에도 적용되어, 2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시한 경우에만 같은 항 단서에 따라 양도소득세를 면제받을 수 있습니다.

33) 서울행정법원 2016. 10. 28. 선고 2016구단55028 판결례, 서울중앙지방법원 2008. 9. 24. 선고 2008가단61118 판결례 참조

34) 대구지방법원 2023. 8. 16. 선고 2023구합124 판결례 참조

관계법령

조세특례제한법

제97조(장기임대주택에 대한 양도소득세의 감면) ① 대통령령으로 정하는 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국민주택(이에 딸린 해당 건물 연면적의 2배 이내의 토지를 포함한다)을 2000년 12월 31일 이전에 임대를 개시하여 5년 이상 임대한 후 양도하는 경우에는 그 주택(이하 "임대주택"이라 한다)을 양도함으로써 발생하는 소득에 대한 양도소득세의 100분의 50에 상당하는 세액을 감면한다. 다만, 「민간임대주택에 관한 특별법」 또는 「공공주택 특별법」에 따른 건설임대주택 중 5년 이상 임대한 임대주택과 같은 법에 따른 매입임대주택 중 1995년 1월 1일 이후 취득 및 임대를 개시하여 5년 이상 임대한 임대주택(취득 당시 입주된 사실이 없는 주택만 해당한다) 및 10년 이상 임대한 임대주택의 경우에는 양도소득세를 면제한다.

1. 1986년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지의 기간 중 신축된 주택
2. 1985년 12월 31일 이전에 신축된 공동주택으로서 1986년 1월 1일 현재 입주된 사실이 없는 주택

② ~ ④ (생 략)

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0169, 24-0436

민원인 - 「관세법」 제175조제2호 및 제3호에 따른 특허보세구역 운영인의 결격사유의 의미 (「관세법」제175조제2호 등 관련)

01 질의요지

「관세법」 제174조제1항 전단에서는 특허보세구역을 설치·운영하려는 자는 세관장의 특허를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제175조 각 호 외의 부분 본문에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 특허보세구역을 설치·운영할 수 없다고 규정하면서 같은 조 제2호에서는 피성년후견인과 피한정후견인을, 제3호에서는 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자를 규정하고 있는바,

「관세법」 제175조제2호에 따른 피성년후견인과 피한정후견인, 같은 조 제3호에 따른 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자가 국내법에 따른 피성년후견인과 피한정후견인, 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자만을 의미하는지 아니면 국내에 거주하는 외국인으로서 그의 국적국(國籍國) 법령에 따라 이와 동일하거나 유사한 사유에 해당하는 자를 포함하는지?

02 회답

「관세법」 제175조제2호에 따른 피성년후견인과 피한정후견인, 같은 조 제3호에 따른 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자에는 국내에 거주하는 외국인으로서 그의 국적국 법령에 따라 이와 동일하거나 유사한 사유에 해당하는 자가 포함됩니다.

03 이유

먼저 「관세법」 제174조제1항 전단에서는 특허보세구역을 설치·운영하려는 자(이하 "특허보세구역 운영인"이라 함)는 세관장의 특허를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법

제175조 각 호 외의 부분 본문에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 특허보세구역을 설치·운영할 수 없다고 규정하면서, 구체적인 결격사유로 피성년후견인과 피한정후견인(제2호), 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자(제3호)를 규정하고 있으나, 그 결격사유에 대한 정의나 근거 규정에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 우리나라 법체계에서는 피성년후견·피한정후견에 관한 사항을 「민법」에서, 파산선고·복권에 관한 사항을 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」(이하 "채무자회생법"이라 함)에서 각각 규정하고 있고, 이와 동일하거나 유사한 제도를 외국법 체계에서도 규정하고 있다면, 관세법령에서 국내법에 따른 결격사유에 해당하는 자만으로 한정하고 있지 않은 이상 국내에 거주하는 외국인에 대하여 그의 국적국 법령에 따라 이와 동일하거나 유사한 사유에 해당하는 자가 반드시 제외된다고 보기는 어렵습니다.

그리고 「민법」에 따르면 피성년후견인은 질병 등의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 지속적으로 결여되어 가정법원에서 성년후견개시의 심판을 받은 자로서(제9조제1항) 피성년후견인의 법률행위는 원칙적으로 취소할 수 있다고(제10조제1항) 규정하고 있고, 피한정후견인은 질병 등의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족하여 가정법원에서 한정후견개시의 심판을 받은 자로서(제12조제1항) 가정법원은 피한정후견인이 한정후견인의 동의를 받아야 하는 행위의 범위를 정할 수 있다고 (제13조제1항) 규정하고 있는바, 「관세법」 제175조제2호에서 피성년후견인과 피한정 후견인을 특허보세구역 운영인의 결격사유로 규정한 것은 행위능력에 일정한 제한이 있는 자들이 특허보세구역을 설치·운영하는 것을 배제하여 거래의 안전과 제3자를 보호하기 위한 취지로 볼 수 있으므로 행위능력에 제한이 있는 자라면 외국인이라 하더라도 결격사유에 해당한다고 보는 것이 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

특히 외국인의 행위능력에 대해 정하고 있는 「국제사법」을 살펴보면, 같은 법 제28조제1항 전단에서는 "사람의 행위능력은 그의 본국법에 따른다"고 규정하고 있고, 같은 법 제75조제1항에서는 "후견은 피후견인의 본국법에 따른다"고 규정하고 있는바, 외국인이 그의 국적국 법령에 따른 후견개시 심판을 받거나 이와 유사한 사유가 있는 경우 국내 법률관계에 있어서도 외국인의 국적국의 법령에서 정한 행위능력의 제한을 받게 되므로 「관세법」 제175조제2호에 따른 결격사유에 해당한다고 보는 것이 「국제사법」의 규정 체계에 비추어 봤을 때 합리적입니다.

또한 「관세법」 제175조제3호에서 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자를 특허보세구역 운영인의 결격사유로 규정한 취지는 특허보세구역의 설치·운영에서의 거래상 신뢰나 재산상의

신용 확보를 위하여 법원으로부터 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자가 특허보세구역을 설치·운영하지 못하도록 하려는 것인데, 국내에 거주하는 외국인이 그의 국적국 법령에 따라 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 또는 이와 유사한 사유가 있는 자에 해당한다면 국내에서 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자와 동일하게 거래상의 신뢰나 재산상의 신용 측면에서 부적합하다고 볼 수 있을 것인바, 같은 법 제175조제3호에 따른 특허보세구역 운영인의 결격사유는 국내법에 따라 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 뿐만 아니라 국내에 거주하는 외국인의 경우에는 그의 국적국 법령에 따라 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자 또는 이와 유사한 사유가 있는 자도 해당한다고 보는 것이 결격사유를 규정한 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 ①「관세법」 제175조제2호 및 제3호에 따른 결격사유를 국내법에 따른 결격사유로 한정하여 해석한다면, 국내에 거주하는 외국인으로서 그의 국적국 법령에 따라 같은 조 제2호 및 제3호와 동일하거나 유사한 자에 해당하여 국내법에 따른 피성년후견인과 피한정후견인, 국내법에 따른 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자에 해당하는 내국인과 본질적으로 동일하거나 유사한 사유에 해당함에도 불구하고 이를 달리 취급하는 불합리한 결과가 초래되는 점, ②「관세법」 제174조에 따라 특허보세구역의 유형별로 설치·운영의 특허를 받은 자는 10년 이내의 기간 동안 관세의 부과가 유보된 상태의 물품을 장치, 제조·가공, 전시, 판매 등을 할 수 있는 권리인 '특허[35]'를 부여받게 되고, 보세구역에 물품 반입·반출시 신고 의무(제157조), 자율관리보세구역[36]으로 지정한 보세구역은 보세사를 채용하여 해당 보세구역에 장치된 물품을 자율적으로 관리할 의무(제164조), 특허보세구역 운영인의 명의 대여 금지(제177조의2) 등 각종 책임과 의무를 가지게 되는 바, 특허보세구역 운영인은 중요한 경제활동의 주체로서 해당 분야의 건전한 경제질서를 유지할 공익상 필요성을 고려하면, 같은 법 제175조제2항 및 제3항의 결격사유의 범위를 국내에 거주하는 외국인의 경우에는 그의 국적국의 법령에 따른 결격사유를 포함하는 것으로 해석하여 규율할 필요가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「관세법」 제175조제2호에 따른 피성년후견인과 피한정후견인, 같은 조 제3호에 따른 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자에는 국내에 거주하는 외국인으로서 그의 국적국 법령에 따라 이와 동일하거나 유사한 사유에 해당하는 자가 포함됩니다.

---

35) 대법원 1989. 5. 9. 선고 88누4188 판결례 참조.

36) 보세구역 중 물품의 관리 및 세관감시에 지장이 없다고 인정하여 관세청장이 정하는 바에 따라 세관장이 지정하는 보세구역을 말하며, 이하 같음,(「관세법」 제164조제1항 참조.)

법령정비 권고사항

국내에 거주하는 외국인에 대하여 그의 국적국 법령에 따라 「관세법」 제175조제2호 및 제3호와 동일하거나 유사한 사유에 해당하는 자가 특허보세구역 운영인의 결격사유에 포함되는지 여부 또는 그 결격사유에 해당하지 않음을 확인하는 방법 및 절차를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

관세법

제174조(특허보세구역의 설치·운영에 관한 특허) ① 특허보세구역을 설치·운영하려는 자는 세관장의 특허를 받아야 한다. 기존의 특허를 갱신하려는 경우에도 또한 같다.
②·③ (생 략)

제175조(운영인의 결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 특허보세구역을 설치·운영할 수 없다. 다만, 제6호에 해당하는 자의 경우에는 같은 호 각 목의 사유가 발생한 해당 특허보세구역을 제외한 기존의 다른 특허를 받은 특허보세구역에 한정하여 설치·운영할 수 있다.
1. (생 략)
2. 피성년후견인과 피한정후견인
3. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
4. ~ 8. (생 략)

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0206, 24-0588

민원인 -「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호에 따라 거주기간의 제한을 받지 아니하고 양도소득이 비과세되는 1세대 1주택의 범위 등(「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「소득세법」 제89조제1항제3호가목에서는 1세대가 1주택을 보유하는 경우로서 "대통령령으로 정하는 요건"을 충족하는 주택(주택 및 이에 딸린 토지의 양도 당시 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 고가주택은 제외함)과 주택부수토지[37]의 양도로 발생하는 소득에 대해서는 양도소득에 대한 소득세(이하 "양도소득세"라 함)를 과세하지 아니한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「소득세법 시행령」 제154조제1항 각 호 외의 부분에서는 "대통령령으로 정하는 요건"이란 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 해당 주택의 보유기간이 2년[38] 이상인 것[취득 당시에 조정대상지역[39]에 있는 주택의 경우에는 해당 주택의 보유기간이 2년[40] 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 것]을 말하며(본문), 다만 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 같은 항 제5호에 해당하는 경우에는 거주기간의 제한을 받지 않는다고 규정하고 있고(단서), 같은 항 제5호에서는 거주자[41]가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 "매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실"이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 계약금 지급일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우를 규정하고 있는바,

거주자가 「주택법」에 따른 지역주택조합[42]의 조합원으로서 지역주택조합 사업을 통해 취득한 조정대상지역에 있는 주택[43]에 대한 양도소득세 비과세 요건과 관련하여,

---

37) 주택에 딸린 토지로서 건물이 정착된 면적에 지역별로 대통령령으로 정하는 배율을 곱하여 산정한 면적 이내의 토지를 의미하며, 이하 같음

38) 「소득세법 시행령」 제154조제8항제2호에 해당하는 거주자의 주택인 경우는 3년

39) 「주택법」 제63조의2제1항제1호에 따른 조정대상지역을 말하며, 이하 같음

40) 「소득세법 시행령」 제154조제8항제2호에 해당하는 거주자의 주택인 경우에는 3년

41) 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소(居所)를 둔 개인을 말하며(「소득세법」 제1조의2제1항제1호 참조), 이하 같음

42) 일정한 구분에 따른 지역에 거주하는 주민이 주택을 마련하기 위하여 설립한 조합을 의미하며, 이하 같음

43) 2017. 9. 19. 대통령령 제28293호로 일부개정된 「소득세법 시행령」 부칙 제2조제2항에 따라 종전의 규정에 따르는 주택에 해당하지 않음을 전제함

가. 거주자가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 '「주택법」 제2조제11호가목에 따른 지역주택조합 가입에 관한 계약[44](이하 "조합원 가입계약"이라 함)을 체결한 사실'이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 조합원 가입계약 체결일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우, 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호가 적용되어 거주기간의 제한을 받지 않는지?

나. 거주자가 가입한 지역주택조합이 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 '「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획승인(이하 "사업계획승인"이라 함)을 받은 사실'이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 사업계획승인일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우, 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호가 적용되어 거주기간의 제한을 받지 않는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

거주자가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 '조합원 가입계약을 체결한 사실'이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 조합원 가입계약 체결일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우, 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호가 적용되지 아니하여 거주기간의 제한을 받습니다.

나. 질의 나에 대해

거주자가 가입한 지역주택조합이 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 '사업계획승인을 받은 사실'이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 사업계획승인일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우, 「소득세법 시행령」 제154조제1항 제5호가 적용되지 아니하여 거주기간의 제한을 받습니다.

44) 「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획승인이 있기 전, 같은 법 제11조의3제8항에 따른 계약서에 따라 지역주택조합의 조합원으로 가입하는 것을 내용으로 하는 계약을 의미하고, 이하 같음

03 이유

가. 질의 가 및 나의 공통사항

조세법률주의 원칙상 조세법규의 해석은 그 부과요건 또는 감면요건을 막론하고 특별한 사정이 없는 한 법문대로 해석할 것이고 합리적 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 아니하고, 특히 감면요건 규정 가운데에 명백히 특혜규정이라고 볼 수 있는 것은 엄격하게 해석하는 것이 공평원칙에도 부합한다고 할 것입니다.[45]

「소득세법」 제94조제1항에서는 건물의 양도로 발생하는 소득(제1호) 등을 과세대상이 되는 양도소득으로 규정하고 있는데, 같은 법 제89조제1항제3호에서는 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택[46]의 양도로 발생하는 소득에 대해서는 양도소득세를 과세하지 아니한다고 규정하면서, 같은 호 가목에서는 1세대가 1주택을 보유하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 주택을 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제154조제1항 본문에서는 같은 법 제89조제1항제3호가목에서 대통령령으로 정하는 요건이란 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 취득 당시에 조정대상지역에 있는 주택의 경우에는 해당 주택의 보유기간이 2년 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상인 것을 말하나, 같은 영 제154조제1항 단서 및 제5호에서는 거주자가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 “매매계약을 체결하고 계약금을 지급”한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 계약금 지급일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우에는 거주기간의 제한을 받지 않는다고 규정하고 있습니다.

이와 같은 소득세법령의 문언과 규정체계에 비추어 볼 때, 주택의 양도로 소득이 발생하였다면 원칙적으로 그 소득에 대하여 양도소득세가 과세되나, 취득 당시 조정대상지역에 있는 주택의 경우 예외적으로 「소득세법」 제89조제1항제3호가목 및 같은 법 시행령 제154조제1항 본문에 따라 1세대가 1주택을 보유하는 경우로서 해당 주택의 보유기간이 2년 이상이고 그 보유기간 중 거주기간이 2년 이상일 경우 양도소득세가 과세되지 아니하고, 같은 항 단서 및 제5호에 따라 거주자가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 ‘매매계약을 체결하고 계약금을 지급’한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 계약금 지급일 현재 주택을 보유하지 아니한다면 위 거주기간의 제한을 받지 않게

45) 대법원 2004. 5. 28. 선고 2003두7392 판결례, 법제처 2013. 4. 26. 회신 13-0101 해석례 등 참조

46) 허가 여부나 공부(公簿)상의 용도구분과 관계없이 세대의 구성원이 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로서 사실상 주거용으로 사용하는 건물을 말하며 (「소득세법」 제88조제7호 참조), 이하 같음

되는바, 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호는 양도소득세 비과세 요건을 완화하는 특례적 성격의 예외규정으로 법문대로 해석해야할 것이고, 납세자에게 유리하다고 하여 합리적인 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 않는다 할 것이므로[47], 그 문언에 따라 거주자가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 '매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 경우'에 예외적으로 비과세 요건인 거주기간이 배제된다 할 것이고, 합리적 이유 없이 법령에서 규정하고 있지 아니한 다른 사유를 들어 거주기간 요건이 배제된다고 해석할 수는 없다 할 것입니다.

나. 질의 가에 대해

그런데 「주택법」에 따른 지역주택조합제도는 소형주택 소유자 및 무주택 서민의 내집 마련의 기회를 확대하고 공동주택공급 촉진을 위해 일정한 자격을 가진 사람들이 청약저축과 관계없이 일정한 지역을 단위로 설립해서 주택을 공급할 수 있도록 하는 제도[48]로서, 일반적으로 지역주택조합사업은 조합설립 준비단계에서부터 사업부지의 확보, 조합의 설립과 사업계획승인, 아파트 등 주택의 건축에 이르기까지 일련의 절차를 진행하여 시행되고[49], 그 중 거주자가 조합원 가입계약을 체결하는 것은 「주택법」 제11조의3제8항에 따른 주택조합의 사업개요, 조합원의 자격기준 등이 포함된 계약서에 따라 지역주택조합의 조합원으로 가입하는 것으로서 장래에 주택을 취득할 것을 기대할 수는 있으나, 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정하는 매매계약[50]을 체결하고 계약금을 지급하는 것과는 구분되는 별개의 행위이므로, 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 조합원 가입계약을 체결하였다는 사실만으로 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호에 따라 거주기간의 제한을 받지 않는다고 해석하는 것은 특례적 성격에 대한 예외규정을 확대해석하여 양도소득세 비과세요건의 범위를 확대하는 것으로서 타당하지 않습니다.

또한 「소득세법 시행령」 제154조제1항 본문은 실수요 목적의 주택 구입을 유도하고 부동산투기를 억제하기 위하여 주택 분양 등이 과열되어 있거나 과열될 우려가 있는 조정대상지역에 소재하는 주택의 경우 2년 이상 보유하고 그 보유기간 중 2년 이상 거주할 것을 1세대 1주택 양도소득세 비과세 요건으로 정하고 있고, 예외적으로 같은 항 제5호에

47) 대법원 2004. 5. 28. 선고 2003두7392 판결례, 2006. 5. 25. 선고 2005다19163 판결례 등 참조
48) 김동근·정동근, 주택법, 진원사, 2016, 597면 참조
49) 대법원 2022. 7. 14. 선고 2021다281999, 282008 판결례 참조
50) 「민법」 제563조 참조

해당하는 경우에는 거주기간의 제한을 받지 않도록 규정하고 있는바[51], 합리적 이유 없이 같은 항 제5호에 해당하는 경우를 확장하여 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 조합원 가입계약을 체결한 경우에도 거주기간의 제한을 배제하는 것은 실수요 목적의 주택 구입을 유도하고 부동산투기를 억제하기 위한 「소득세법 시행령」 제154조제1항의 취지에 부합한다고 보기 어렵습니다.

따라서 거주자가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 '조합원 가입계약을 체결한 사실'이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 조합원 가입계약 체결일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우, 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호가 적용되지 아니하여 거주기간의 제한을 받습니다.

다. 질의 나에 대해

한편, 「주택법」에 따른 지역주택조합제도는 소형주택 소유자 및 무주택 서민의 내집 마련의 기회를 확대하고 공동주택공급 촉진을 위해 일정한 자격을 가진 사람들이 청약저축과 관계없이 일정한 지역을 단위로 설립해서 주택을 공급할 수 있도록 하는 제도로서, 일반적으로 지역주택조합사업은 조합설립 준비단계에서부터 사업부지의 확보, 조합의 설립과 사업계획승인, 아파트 등 주택의 건축에 이르기까지 일련의 절차를 진행하여 시행되고, 지역주택조합이 「주택법」 제15조제1항에 따라 사업계획승인을 받는 것은 일정 호수 이상의 주택건설사업을 시행하거나 일정 면적 이상의 대지조성사업을 시행하기 위한 것으로 사업계획승인을 통해 장래에 주택이 건축된다면 이를 취득할 것을 기대할 수는 있으나, 당사자 일방이 재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정하는 매매계약을 체결하고 계약금을 지급하는 것과는 구분되는 별개의 행위로서, 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 거주자가 가입한 지역주택조합이 사업계획승인을 받았다는 사실만으로 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호에 따라 거주기간의 제한을 받지 않는다고 해석하는 것은 특례적 성격에 대한 예외규정을 확대해석하여 양도소득세 비과세요건의 범위를 확대하는 것으로서 타당하지 않습니다.

또한 「소득세법 시행령」 제154조제1항 본문은 실수요 목적의 주택 구입을 유도하고 부동산투기를 억제하기 위하여 주택 분양 등이 과열되어 있거나 과열될 우려가 있는 조정대상지역에 소재하는 주택의 경우 2년 이상 보유하고 그 보유기간 중 2년 이상 거주할

51) 2017. 9. 19. 대통령령 제28293호로 일부개정된 「소득세법 시행령」 개정이유 및 부산지방법원 2012. 2. 9. 선고 2011구합3846 판결례 참조

것을 1세대 1주택 양도소득세 비과세 요건으로 정하고 있고, 예외적으로 같은 항 제5호에 해당하는 경우에는 거주기간의 제한을 받지 않도록 규정하고 있는바, 합리적 이유 없이 같은 항 제5호에 해당하는 경우를 확장하여 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 거주자가 가입한 지역주택조합이 사업계획승인을 받은 경우에도 거주기간의 제한을 배제하는 것은 실수요 목적의 주택 구입을 유도하고 부동산투기를 억제하기 위한 「소득세법 시행령」 제154조제1항의 취지에 부합한다고 보기 어렵습니다.

따라서 거주자가 가입한 지역주택조합이 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 '사업계획승인을 받은 사실'이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 사업계획승인일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우, 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호가 적용되지 아니하여 거주기간의 제한을 받습니다.

관계법령

소득세법

제89조(비과세 양도소득) ① 다음 각 호의 소득에 대해서는 양도소득에 대한 소득세(이하 "양도소득세"라 한다)를 과세하지 아니한다.

1. ~ 2. (생 략)
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택(주택 및 이에 딸린 토지의 양도 당시 실지거래가액의 합계액이 12억원을 초과하는 고가주택은 제외한다)과 이에 딸린 토지로서 건물이 정착된 면적에 지역별로 대통령령으로 정하는 배율을 곱하여 산정한 면적 이내의 토지(이하 이 조에서 "주택부수토지"라 한다)의 양도로 발생하는 소득
   가. 1세대가 1주택을 보유하는 경우로서 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 주택
   나. 1세대가 1주택을 양도하기 전에 다른 주택을 대체취득하거나 상속, 동거봉양, 혼인 등으로 인하여 2주택 이상을 보유하는 경우로서 대통령령으로 정하는 주택
5. (생 략)

② · ③ (생 략)

소득세법 시행령

제154조(1세대1주택의 범위) ① 법 제89조제1항제3호가목에서 "대통령령으로 정하는 요건"이란 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 해당 주택의 보유기간이 2년(제8항제2호에 해당하는 거주자의 주택인 경우는 3년) 이상인 것[취득 당시에 「주택법」 제63조의2제1항제1호에 따른 조정대상지역(이하 "조정대상지역"이라 한다)에 있는 주택의 경우에는 해당 주택의 보유기간이 2년(제8항제2호에 해당하는 거주자의 주택인 경우에는 3년) 이상이고 그 보유기간 중

거주기간이 2년 이상인 것]을 말한다. 다만, 1세대가 양도일 현재 국내에 1주택을 보유하고 있는 경우로서 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 보유기간 및 거주기간의 제한을 받지 않으며 제5호에 해당하는 경우에는 거주기간의 제한을 받지 않는다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 거주자가 조정대상지역의 공고가 있은 날 이전에 매매계약을 체결하고 계약금을 지급한 사실이 증빙서류에 의하여 확인되는 경우로서 해당 거주자가 속한 1세대가 계약금 지급일 현재 주택을 보유하지 아니하는 경우

② ~ ⑫ (생 략)

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0294

민원인 – 「대외무역법」에 따른 무역을 하는 자가 수출용으로 취득하는 중고자동차의 경우, 「지방세법」에 따라 산출한 취득세액에 관계없이 취득세가 전액 면제되는지 여부(「지방세특례제한법」 제177조의2 등 관련)

01 질의요지

「지방세특례제한법」 제68조제3항에서 「대외무역법」에 따른 무역을 하는 자가 수출용으로 취득하는 중고자동차에 대해서는 취득세를 2024년 12월 31일까지 면제한다고 규정하고 있고, 같은 법 제177조의2제1항에서 같은 법에 따라 취득세가 면제[52]되는 경우에는 같은 법에 따른 취득세의 면제규정에도 불구하고 100분의 85에 해당하는 감면율[53]을 적용하되(본문), 「지방세법」에 따라 산출한 취득세의 세액이 200만원 이하인 경우(제1호가목) 등에는 그러하지 아니하다(단서)고 규정하고 있는바,

「대외무역법」에 따른 무역을 하는 자가 수출용으로 취득하는 중고자동차의 경우, 「지방세법」에 따라 산출한 취득세의 세액에 관계없이 「지방세특례제한법」 제68조제3항에 따라 취득세가 전액 면제되는지?[54]

02 회답

이 사안의 경우, 「지방세법」에 따라 산출한 취득세의 세액이 200만원 이하인 경우 「지방세특례제한법」 제177조의2제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 항 제1호가목에 따라 취득세가 전액 면제되고, 취득세의 세액이 200만원을 초과하는 경우 같은 법 제177조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 100분의 85에 해당하는 감면율이 적용됩니다.

52) 지방세 특례 중에서 세액감면율이 100분의 100인 경우와 세율경감률이 「지방세법」에 따른 해당 과세대상에 대한 세율 전부를 감면하는 것을 말하며, 이하 같음

53) 「지방세법」 제13조제1항부터 제4항까지의 세율은 적용하지 아니한 감면율을 말하며, 이하 같음

54) 「지방세특례제한법」 제68조제3항, 같은 법 제177조의2 외의 다른 법령에 의하여 취득세가 비과세 또는 감면되지 않는 경우를 전제로 함

03 이유

조세법규의 해석은 특별한 사정이 없는 한 법문대로 해석할 것이고 합리적 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 아니하며, 특히 감면요건 규정 가운데에 명백히 특혜규정이라고 볼 수 있는 것은 엄격하게 해석하는 것이 조세공평의 원칙에도 부합한다 할 것인데[55], 「지방세특례제한법」 제68조제3항에서 「대외무역법」에 따른 무역을 하는 자가 수출용으로 취득하는 중고자동차에 대해서는 취득세를 2024년 12월 31일까지 면제한다고 규정하고 있으나, 같은 법 제177조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에서 '같은 법에 따라 취득세가 면제되는 경우'에는 같은 법에 따른 취득세의 면제규정에도 불구하고 100분의 85에 해당하는 감면율을 적용한다고 규정하고 있고, 이에 대한 예외규정으로서 같은 항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 항 제1호가목에서 「지방세법」에 따라 산출한 취득세의 세액이 200만원 이하인 경우 취득세가 전액 면제된다고 규정하고 있으므로, 문언상 「대외무역법」에 따른 무역을 하는 자가 수출용으로 취득하는 중고자동차의 경우 「지방세법」 제68조제3항에 따라 취득세가 면제되는 규정에도 불구하고 같은 법에 따라 산출한 취득세의 세액이 200만원을 초과하는 경우에는 「지방세특례제한법」 제177조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 100분의 85에 해당하는 감면율이 적용되고, 그 취득세의 세액이 200만원 이하인 경우 같은 법 제177조의2제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 항 제1호가목에 따라 취득세가 전액 면제된다 할 것입니다.

그리고 지방세 감면 특례의 제한에 관해 규정하고 있는 「지방세특례제한법」의 입법연혁을 살펴보면, 2014년 12월 31일 법률 제12955호로 일부개정된 「지방세특례제한법」에 제177조의2를 신설하여 수익자가 최소한의 비용을 지불하는 조세부담의 형평성을 증진하기 위하여 「지방세법」에 따라 납부하여야 하는 취득세가 200만원을 초과하는 경우 「지방세특례제한법」에 따른 취득세의 면제 규정에도 불구하고 100분의 85에 해당하는 감면율을 적용하도록 하였고[56], 취약계층 등 보호를 위해 다시 예외를 두어 같은 조 제1항 단서에서는 「지방세법」에 따라 산출한 취득세의 세액이 200만원 이하인 경우 등에 대하여 그 세액을 면제하였는바[57], 「대외무역법」에 따른 무역을 하는 자가 수출용으로 취득하는 중고자동차에 대하여도 「지방세특례제한법」 제68조제3항에 따른 취득세 면제규정에도 불구하고 그

55) 대법원 2002. 4. 12. 선고 2001두731 판결례 참조

56) 2014. 12. 31. 법률 제12955호로 일부개정된 「지방세특례제한법」 개정이유 및 2014. 12. 4. 의안번호 제13329호로 발의된 「지방세특례제한법」 일부개정법률안(대안) 참조

57) 헌법재판소 2024. 2. 28. 선고 2021헌바64 결정례 참고

취득세의 세액에 따라 같은 법 제177조의2의 적용을 받는다고 보는 것이 입법연혁 및 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 「지방세법」에 따라 산출한 취득세의 세액이 200만원 이하인 경우 「지방세특례제한법」 제177조의2제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 항 제1호가목에 따라 취득세가 전액 면제되고, 취득세의 세액이 200만원을 초과하는 경우 같은 법 제177조의2 제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 100분의 85에 해당하는 감면율이 적용됩니다.

관계법령

지방세특례제한법

제68조(매매용 및 수출용 중고자동차 등에 대한 감면)

① ~ ② (생 략)

③ 「대외무역법」에 따른 무역을 하는 자가 수출용으로 취득하는 중고선박, 중고기계장비 및 중고항공기에 대해서는 「지방세법」 제12조제1항제1호·제3호 및 제4호의 세율에서 각각 1천분의 20을 경감하여 취득세를 2024년 12월 31일까지 과세하고, 「대외무역법」에 따른 무역을 하는 자가 수출용으로 취득하는 중고자동차에 대해서는 취득세를 2024년 12월 31일까지 면제한다.

④ (생 략)

제177조의2(지방세 감면 특례의 제한) ① 이 법에 따라 취득세 또는 재산세가 면제(지방세 특례 중에서 세액감면율이 100분의 100인 경우와 세율경감률이 「지방세법」에 따른 해당 과세대상에 대한 세율 전부를 감면하는 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)되는 경우에는 이 법에 따른 취득세 또는 재산세의 면제규정에도 불구하고 100분의 85에 해당하는 감면율(「지방세법」 제13조제1항부터 제4항까지의 세율은 적용하지 아니한 감면율을 말한다)을 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「지방세법」에 따라 산출한 취득세의 세액(연부로 부동산을 취득하는 경우 매회 세액을 합산한 것을 말하며, 1년 이내에 동일한 소유자로부터 부동산을 취득하는 경우 또는 1년 이내에 연접한 부동산을 취득하는 경우에는 각각의 부동산에 대하여 산출한 취득세의 세액을 합산한 것을 말한다) 및 재산세의 세액이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 취득세: 200만원 이하
   나. 재산세: 50만원 이하(「지방세법」 제122조에 따른 세 부담의 상한을 적용하기 이전의 산출액을 말한다)
2. (생 략)

② ~ ③ (생 략)

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0620

민원인 – 「조세특례제한법」 제6조제1항에 따라 세액을 감면받을 수 있는 기간(「조세특례제한법」 제6조 등 관련)

01 질의요지

「조세특례제한법」 제6조제1항에서는 대통령령으로 정하는 중소기업(이하 "중소기업"이라 함) 중 2024년 12월 31일 이전에 광업, 제조업, 음식점업 등 같은 조 제3항 각 호에 따른 업종으로 창업한 중소기업(이하 "창업중소기업"이라 함)에 대해서는 해당 사업에서 최초로 소득이 발생한 과세연도[58](사업 개시일부터 5년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 해당 사업에서 소득이 발생하지 아니하는 경우에는 5년이 되는 날이 속하는 과세연도를 말함)와 그 다음 과세연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 과세연도(이하 "감면기간"이라 함)까지 해당 사업에서 발생한 소득에 대한 소득세 또는 법인세에 같은 조 제1항 각 호의 구분에 따른 비율을 곱한 금액에 상당하는 세액을 감면한다고 규정하고 있고, 같은 조 제10항제3호에서는 같은 조 제1항을 적용할 때 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우는 창업으로 보지 아니한다고 규정하고 있는바,

「조세특례제한법」 제6조제1항에 따라 세액감면을 받던 내국인[59]이 폐업 후 종전 감면기간이 지나기 전에 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우, 사업을 다시 개시한 때부터 종전 감면기간이 종료하는 때까지 같은 항에 따라 세액을 감면받을 수 있는지?

02 회답

「조세특례제한법」 제6조제1항에 따라 세액감면을 받던 내국인이 폐업 후 종전 감면기간이

58) 「소득세법」에 따른 과세기간 또는 「법인세법」에 따른 사업연도를 말하며(「조세특례제한법」 제2조제1항제2호 참조), 이하 같음

59) 「소득세법」에 따른 거주자 및 「법인세법」에 따른 내국법인을 말하며(「조세특례제한법」 제2조제1항제1호 참조), 이하 같음

지나기 전에 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우, 사업을 다시 개시한 때부터 종전 감면기간이 종료하는 때까지 같은 항에 따라 세액을 감면받을 수 없습니다.

03 이유

「조세특례제한법」 제6조제1항 각 호 외의 부분에서 대통령령으로 정하는 중소기업 중 2024년 12월 31일 이전에 같은 조 제3항 각 호에 따른 업종으로 창업한 중소기업에 대해서는 해당 사업에서 최초로 소득이 발생한 과세연도와 그 다음 과세연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 과세연도까지 해당 사업에서 발생한 소득에 대한 소득세 또는 법인세에 같은 조 제1항 각 호의 구분에 따른 비율을 곱한 금액에 상당하는 세액을 감면한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제2조제1항에서 "대통령령으로 정하는 중소기업"이란 매출액이 업종별로 일정 규모 기준 이내일 것(제1호), 같은 법 시행령 제29조제3항에 따른 소비성서비스업을 주된 사업으로 영위하지 아니할 것(제4호) 등의 요건을 모두 갖춘 기업을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제6조제3항에서 창업중소기업의 범위는 광업, 제조업, 음식점업 등의 업종을 경영하는 중소기업으로 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제10항제3호에서 같은 조 제1항의 규정을 적용할 때 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우는 창업으로 보지 아니한다고 규정하고 있는 등 「조세특례제한법」 제6조에서는 '창업중소기업' 등에 대한 소득세 또는 법인세의 감면에 관한 사항과 그 예외 등에 관하여 규정하고 있습니다.

먼저 조세법률주의의 원칙상 과세요건이거나 비과세요건 또는 조세감면요건을 막론하고 조세법규의 해석은 특별한 사정이 없는 한 법문대로 해석할 것이고, 납세자에게 유리하다고 하여 합리적 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 아니하며, 특히 감면요건 가운데 명백히 특혜규정이라고 볼 수 있는 것은 엄격하게 해석하는 것이 조세공평의 원칙에도 부합한다고 할 것인데,[60] 앞서 살펴본 바와 같이 「조세특례제한법」 제6조는 '창업중소기업'에 대한 세액의 감면에 관하여 규정하고 있으므로 법문대로 엄격하게 해석해야 할 것인바, 같은 조 제1항에 따른 '창업중소기업'은 같은 조 제3항에서 규정하고 있는 업종을 경영하되, 소비성서비스업을 주된 사업으로 영위하지 아니하면서 매출액이 일정 규모 기준 이내인 기업을 의미하고, 같은 조 제1항은 원칙적으로 위와 같은 '창업중소기업'이 감면기간 동안

60) 대법원 2004. 5. 28. 선고 2003두7392 판결례 등 참조

같은 조 제3항에 따른 업종을 영위하여 그에 따른 소득이 발생하는 것을 전제로 그 소득에 대한 소득세 또는 법인세를 감면하는 규정이라 할 것입니다.

그런데 내국인이 과거 창업중소기업으로서 「조세특례제한법」 제6조제1항에 따른 세액감면을 받았다고 하더라도 폐업하여 같은 조 제3항에 따른 업종을 영위하지 않게 되었다면 더 이상 창업중소기업이라고 할 수 없으므로, 종전에 창업중소기업으로서 같은 조 제3항에 따른 업종을 영위하는 것을 전제로 받았던 세액감면 혜택은 유지되지 않는다고 할 것인바, 종전 감면기간이 끝나기 전에 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하더라도 종전 세액감면 혜택을 이어서 받을 수 없을 뿐만 아니라, 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우는 같은 조 제10항제3호에 따라 '창업'한 중소기업에도 해당하지 않으므로 다시 개시한 사업에서 최초로 소득이 발생한 과세연도부터 다시 세액을 감면받을 수도 없다고 할 것입니다.

그리고 「조세특례제한법」제6조제1항에서는 창업중소기업에 대하여 해당 사업에서 최초로 소득이 발생한 과세연도와 그 다음 과세연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 과세연도까지 세액감면 혜택을 부여하고 있고, 같은 조 제10항에서는 합병·분할·현물출자 또는 사업의 양수를 통하여 종전의 사업을 승계하거나 종전의 사업에 사용되던 자산을 인수 또는 매입하여 같은 종류의 사업을 하는 경우(제1호), 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우(3호) 등은 창업으로 보지 아니하여 제1항에 따른 세액감면 혜택을 주고 있지 않은데, 이는 새로운 사업을 최초로 개시함으로써 원시적인 사업창출의 효과가 있는 경우에만 소득세 또는 법인세의 감면혜택을 주려는 취지인바[61], 이 사안과 같이 내국인이 같은 법 제6조제1항에 따라 세액감면을 받은 바 있더라도 폐업하여 사업을 영위하지 않고 있다가 종전 감면기간이 끝나기 전에 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 영위하는 것은 원시적인 사업창출의 효과가 있다고 보기 어려우므로 같은 조 제1항에 따라 세액을 감면받을 수 없다고 보는 것이 해당 규정의 취지에도 부합합니다.

따라서 「조세특례제한법」 제6조제1항에 따라 세액감면을 받던 내국인이 폐업 후 종전 감면기간이 지나기 전에 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우, 사업을 다시 개시한 때부터 종전 감면기간이 종료하는 때까지 같은 항에 따라 세액을 감면받을 수 없습니다.

61) 대법원 2014. 3. 27. 선고 2011두11549 판결례 참조

관계법령

조세특례제한법

제6조(창업중소기업 등에 대한 세액감면) ① 대통령령으로 정하는 중소기업(이하 "중소기업"이라 한다) 중 2024년 12월 31일 이전에 제3항 각 호에 따른 업종으로 창업한 중소기업(이하 이 조에서 "창업중소기업"이라 한다)과 「중소기업창업 지원법」 제53조제1항에 따라 창업보육센터사업자로 지정받은 내국인(이하 이 조에서 "창업보육센터사업자"라 한다)에 대해서는 해당 사업에서 최초로 소득이 발생한 과세연도(사업 개시일부터 5년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 해당 사업에서 소득이 발생하지 아니하는 경우에는 5년이 되는 날이 속하는 과세연도를 말한다. 이하 제6항에서 같다)와 그 다음 과세연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 과세연도까지 해당 사업에서 발생한 소득에 대한 소득세 또는 법인세에 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 곱한 금액에 상당하는 세액을 감면한다.

1.·2. (생 략)

② ~ ⑨ (생 략)

⑩ 제1항부터 제9항까지의 규정을 적용할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 창업으로 보지 아니한다.

1. 합병·분할·현물출자 또는 사업의 양수를 통하여 종전의 사업을 승계하거나 종전의 사업에 사용되던 자산을 인수 또는 매입하여 같은 종류의 사업을 하는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

가. ~ 나. (생 략)

2. 거주자가 하던 사업을 법인으로 전환하여 새로운 법인을 설립하는 경우
3. 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우
4. 사업을 확장하거나 다른 업종을 추가하는 경우 등 새로운 사업을 최초로 개시하는 것으로 보기 곤란한 경우

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0655

민원인 – 「세무사법」 제5조의2제1항제4호에서 규정하고 있는 “대위 이상의 재정병과 장교로서 10년 이상 군의 재정 업무를 담당한 경력이 있는 사람”의 의미(「세무사법」 제5조의2제1항제4호 등 관련)

01 질의요지

「세무사법」 제5조의2제1항제4호에서는 대위 이상의 재정병과(財政兵科) 장교로서 10년 이상 군의 재정 업무를 담당한 경력이 있는 사람은 세무사 자격시험의 제1차 시험을 면제한다고 규정하고 있는바,

「세무사법」 제5조의2제1항제4호에 따른 경력은 대위 이상의 재정병과 장교의 직에서의 경력으로 한정되는지, 아니면 대위 이상의 재정병과장교가 되기 전의 경력도 포함되는지?

02 회답

「세무사법」 제5조의2제1항제4호에 따른 경력은 대위 이상의 재정병과 장교의 직에서의 경력으로 한정됩니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[62], 「세무사법」 제5조의2제1항제4호에서는 세무사 자격시험의 제1차 시험을 면제하는 대상 중 하나로 대위 이상의 재정병과 장교로서 10년 이상 군의 재정 업무를 담당한 경력이 있는 사람을 규정하고 있고, 여기에서 “~로서”는 지위나 신분 또는 자격을 나타내는 격(格)조사[63]이므로, 이를 달리

62) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

63) 국립국어원 표준국어대사전 참조

해석하여야 할 특별한 사정이 없다면 같은 호에서 규정하고 있는 사람은 대위 이상의 재정병과 장교에 재직 중인 상태에서 군의 재정 업무를 담당한 경력이 10년 이상인 사람을 의미한다고 보는 것이 문언의 통상적인 의미에 부합하는 해석[64]이라고 할 것입니다.

그리고 「세무사법」 제3조제1호에서 같은 법 제5조의 세무사 자격시험에 합격한 사람은 세무사의 자격이 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제5조제1항에서 세무사 자격시험은 기획재정부장관이 실시하는 제1차 시험과 제2차 시험으로 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제5조의2제1항에서 제1차 시험을 면제하는 대상을 각 호로 규정하면서, 같은 항 제4호에서 대위 이상의 재정병과 장교로서 10년 이상 군의 재정 업무를 담당한 경력이 있는 사람을 규정하고 있는바, 원칙적으로 세무사 자격시험의 제1차 시험과 제2차 시험에 각각 응시하여 합격한 사람이 세무사 자격을 취득하게 되나, 예외적으로 같은 법 제5조의2제1항에 따라 제1차 시험을 면제받고 제2차 시험에 합격한 사람도 세무사 자격을 취득할 수 있게 되는 것이므로, 같은 항은 제1차 시험을 면제하는 예외규정으로 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 된다 할 것이고[65], 이에 따라 같은 항 제4호는 문언에 따라 대위 이상의 재정병과 장교에 재직 중인 상태에서 군의 재정 업무를 담당한 경력이 10년 이상인 사람으로 해석해야 할 것이며, 계급과 관계 없이 10년 이상 군의 재정 업무를 담당한 경력이 있는 대위 이상의 재정병과 장교에 대하여도 제1차 시험이 면제된다고 해석한다면 이는 예외적으로 1차 시험 면제의 대상이 되는 같은 항 제4호를 확대해석하는 것이므로 타당하지 않습니다.

따라서 「세무사법」 제5조의2제1항제4호에 따른 경력은 대위 이상의 재정병과 장교의 직에서의 경력으로 한정된다고 할 것입니다.

법령정비 권고사항

「세무사법」 제5조의2제1항제4호에 따른 직급과 실무경력 사이의 선후관계를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

64) 법제처 2023. 4. 3. 회신 23-0132 해석례, 법제처 2017. 3. 6. 회신 17-0046 해석례, 2015. 9. 30. 회신 15-0533 해석례 등 참조

65) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

관계법령

세무사법

제5조의2(시험의 일부 면제) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제1차 시험을 면제한다.

1. 국세(관세는 제외한다. 이하 같다)에 관한 행정사무에 종사한 경력이 10년 이상인 사람
2. 지방세에 관한 행정사무에 종사한 경력이 10년 이상인 사람으로서 5급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람
3. 지방세에 관한 행정사무에 종사한 경력이 20년 이상인 사람
4. 대위 이상의 재정병과(財政兵科) 장교로서 10년 이상 군의 재정 업무를 담당한 경력이 있는 사람

② ~ ④ (생 략)

질의제목 10 ▶ 안건번호 24-0772

민원인 – 전체 주택의 시가표준액이 1억원을 초과하지만 부속토지를 제외한 주거용 건축물의 시가표준액이 1억원 이하인 경우로서 주거용 건축물만 소유한 경우 해당 주거용 건축물이 취득세 중과를 위한 소유주택 수에 포함되는지(「지방세법 시행령」 제28조의4제6항제1호가목 등)

01 질의요지

「지방세법」 제11조제1항에서는 부동산에 대한 취득세는 과세표준[66]에 같은 항 각 호에 해당하는 표준세율을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다고 규정하면서, 같은 항 제8호에서는 유상거래를 원인으로 주택(「주택법」 제2조제1호의 주택으로서 「건축법」에 따른 건축물대장·사용승인서·임시사용승인서나 「부동산등기법」에 따른 등기부에 주택으로 기재된 주거용 건축물과 그 부속토지를 말하며, 이하 같음)을 취득하는 경우에는 「지방세법」 제11조제1항제8호 각 목의 구분에 따른 세율을 적용한다고 규정하고 있는 한편,

「지방세법」 제13조의2제1항에서는 주택[67]을 유상거래를 원인으로 취득하는 경우로서 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 법 제11조제1항제8호에도 불구하고 같은 항 각 호에 따른 세율을 적용한다고 하여, 1세대 3주택 취득 등에 대한 취득세 중과에 관하여 규정하면서, 같은 법 제13조의2제5항에서는 같은 조 제1항부터 제4항까지를 적용할 때 주택의 범위 포함 여부, 주택 수의 산정방법 등 필요한 세부 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 주택 수의 산정방법을 정한 「지방세법 시행령」 제28조의4제6항제1호가목에서는 1세대의 주택 수를 산정할 때 같은 영 제28조의2제1호에 해당하는 주택으로서 주택 수 산정일 현재 같은 호에 따른 해당 주택의 시가표준액 기준을 충족하는 주택을 소유주택[68] 수에서 제외하도록 규정하고 있고, 같은 영 제28조의2제1호 본문에서는 「지방세법」 제4조에 따른 시가표준액(이하 "시가표준액"이라 함)이 1억원 이하인 주택을 규정하면서, 시가표준액 다음에 괄호를 두어 지분이나 부속토지만을 취득한 경우에는 전체 주택의 시가표준액을 말한다고 규정하고 있는바,

---

66) 「지방세법」 제10조의2부터 제10조의6까지의 규정에 따른 과세표준을 말함

67) 「지방세법」 제11조제1항제8호에 따른 주택을 말함

68) 주택 취득일 현재 취득하는 주택을 포함하지 아니한 소유주택을 말하며, 이하 같음

주택 수 산정일 현재 주거용 건축물과 그 부속토지, 즉 전체 주택의 시가표준액은 1억원을 초과하지만 주거용 건축물만의 시가표준액은 1억원 이하인 주택의 주거용 건축물[69](이하 "이 사안의 주거용 건축물"이라 함)을 소유한 경우, 이 사안의 주거용 건축물은 「지방세법 시행령」 제28조의4제6항제1호가목에 따라 취득세 중과를 위한 1세대의 소유주택 수 산정에서 제외되는지?

02 회답

이 사안의 주거용 건축물은 「지방세법 시행령」 제28조의4제6항제1호가목에 따라 취득세 중과를 위한 1세대의 소유주택 수 산정에서 제외되지 않습니다.

03 이유

먼저 「지방세법 시행령」 제28조의4제6항제1호가목에서는 같은 영 제28조의2제1호에 해당하는 주택으로서 주택 수 산정일 현재 같은 호에 따른 해당 주택의 시가표준액 기준을 충족하는 주택을 같은 법 제13조의2에 따른 취득세 중과 시 소유주택 수 산정에서 제외하도록 규정하고 있고, 같은 영 제28조의2제1호 본문에서는 시가표준액이 1억원 이하인 주택을 규정하면서 시가표준액 다음에 괄호 규정을 두어 지분이나 부속토지만을 취득한 경우에는 전체 주택의 시가표준액을 말한다고 규정하고 있으며, 「지방세법」 제11조제1항제8호 및 제13조의2제1항에 따르면 주택은 주거용 건축물 및 그 부속토지를 의미하는바, 해당 규정 및 문언을 종합하여 보면 주거용 건축물과 그 부속토지, 즉 전체 주택 중 일부를 자기의 몫으로 소유한 경우에도 전체 주택의 시가표준액을 기준으로 1억원 이하인지 여부를 판단해야 한다고 할 것인데, 이 사안과 같이 주거용 건축물만을 소유한 것은 전체 주택 중 일부를 소유한 것으로서 전체 주택의 일정 지분을 가진 것이라고 볼 수 있으므로, 같은 법 시행령 제28조의2제1호에 따라 전체 주택의 시가표준액을 기준으로 소유주택 수에서 제외할지 여부를 판단하는 것이 문언상 명확하다고 할 것이어서, 이 사안에서와 같이 주거용 건축물과 그 부속토지를 포함한 전체 주택의 시가표준액이 1억원을 초과한다면 해당 주거용 건축물은 「지방세법 시행령」 제28조의4제6항 제1호가목에 따라 취득세 중과를 위한 1세대의 소유주택 수에 포함된다고 할 것입니다.

69) 재산세를 부과할 때와 같이 시가표준액에 대하여 주거용 건축물 가격과 토지 가격을 감정평가한 결과에 따라 안분하면 주거용 건축물에 대한 시가표준액이 1억원 이하인 것으로 전제함

그리고 「지방세법」 제13조의2, 같은 법 시행령 제28조의2 및 제28조의4 등을 신설하여 주택 취득에 대한 중과세 규정을 둔 이유는 주택 실수요자를 보호하고 투기수요를 근절하기 위하여 1세대가 3주택 이상을 취득하는 등의 경우에는 주택 취득에 따른 취득세율을 상향함으로써 실수요자 중심의 주택보유를 유도하여 서민의 주거안정을 도모하려는 것인데,[70] 이 때 「지방세법」 제28조의4제6항은 소유주택 수의 산정 시 제외되는 대상을 규정하여 결과적으로 중과세율 대신 기존 취득세율을 적용할 수 있도록 하려는 내용의 규정인바, 만일 취득세 중과 여부와 관련하여 이 사안의 주거용 건축물의 경우에도 소유주택 수에서 제외할 수 있도록 소유주택 수 산정 방식을 완화하여 해석한다면, 1세대 다주택자 중에서 취득세 중과를 적용받는 대상이 감소하는 결과를 가져올 수 있어, 실수요자 중심의 주택보유를 유도하고 투기수요를 근절하고자 하는 규정의 도입 취지에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

한편, 「지방세법 시행령」 제28조의2제1호 및 제28조의4제6항제1호가목은 주거용 건축물의 일부 지분 또는 부속토지의 일부 지분을 가지고 있거나, 그 부속토지만을 소유한 경우에만 전체 주택의 시가표준액을 기준으로 1억원 이상인지 여부를 판단하도록 한 것이라고 보는 의견이 있는데, 이러한 의견에 따르면 시가표준액이 1억원 이하인지 여부를 판단할 때 실제 거주에 사용할 수 없는 부속토지만을 가진 경우에는 전체 주택의 시가표준액을 기준으로 해야 하지만, 거주에 사용할 수 있는 주거용 건축물 전체만을 소유한 경우에는 주거용 건축물의 시가표준액만을 기준으로 하게 되어 결과적으로 조세 형평에 어긋날 수 있는 점, 나아가 주거용 건축물과 그 부속토지의 소유자를 달리 함으로써 「지방세법」 제13조의2에 따른 취득세 중과 규정의 적용을 회피할 여지가 발생할 수 있는 점 등을 고려할 때 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 주거용 건축물은 「지방세법 시행령」 제28조의4제6항제1호가목에 따라 취득세 중과를 위한 1세대의 소유주택 수 산정에서 제외되지 않습니다.

70) 2020. 8. 12. 법률 제17473호로 일부개정된 「지방세법」 개정이유 참조

관계법령

지방세법

제11조(부동산 취득의 세율) ① 부동산에 대한 취득세는 제10조의2부터 제10조의6까지의 규정에 따른 과세표준에 다음 각 호에 해당하는 표준세율을 적용하여 계산한 금액을 그 세액으로 한다.

1. ~ 7. (생 략)

8. 제7호나목에도 불구하고 유상거래를 원인으로 주택{「주택법」 제2조제1호의 주택으로서 「건축법」에 따른 건축물대장·사용승인서·임시사용승인서나 「부동산등기법」에 따른 등기부에 주택으로 기재[「건축법」(법률 제7696호로 개정되기 전의 것을 말한다)에 따라 건축허가 또는 건축신고 없이 건축이 가능하였던 주택(법률 제7696호 건축법 일부개정법률 부칙 제3조에 따라 건축허가를 받거나 건축신고가 있는 것으로 보는 경우를 포함한다)으로서 건축물대장에 기재되어 있지 아니한 주택의 경우에도 건축물대장에 주택으로 기재된 것으로 본다]된 주거용 건축물과 그 부속토지를 말한다. 이하 이 조에서 같다}을 취득하는 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 세율을 적용한다. 이 경우 지분으로 취득한 주택의 취득당시가액(제10조의3 및 제10조의5제3항에서 정하는 취득당시가액으로 한정한다. 이하 이 호에서 같다)은 다음 계산식에 따라 산출한 전체 주택의 취득당시가액으로 한다.

$$\text{전체 주택의 취득당시가액} = \text{취득 지분의 취득당시가액} \times \frac{\text{전체 주택의 시가표준액}}{\text{취득 지분의 시가표준액}}$$

가. ~ 다. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

제13조의2(법인의 주택 취득 등 중과) ① 주택(제11조제1항제8호에 따른 주택을 말한다. 이 경우 주택의 공유지분이나 부속토지만을 소유하거나 취득하는 경우에도 주택을 소유하거나 취득한 것으로 본다. 이하 이 조 및 제13조의3에서 같다)을 유상거래를 원인으로 취득하는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제11조제1항제8호에도 불구하고 다음 각 호에 따른 세율을 적용한다.

1.·2. (생 략)

3. 1세대 3주택 이상에 해당하는 주택으로서 조정대상지역에 있는 주택을 취득하는 경우 또는 1세대 4주택 이상에 해당하는 주택으로서 조정대상지역 외의 지역에 있는 주택을 취득하는 경우: 제11조제1항제7호나목의 세율을 표준세율로 하여 해당 세율에 중과기준세율의 100분의 400을 합한 세율

② ~ ④ (생 략)

⑤ 제1항부터 제4항까지 및 제13조의3을 적용할 때 주택의 범위 포함 여부, 세대의 기준, 주택 수의 산정방법 등 필요한 세부 사항은 대통령령으로 정한다.

지방세법 시행령

제28조의2(주택 유상거래 취득 중과세의 예외) 법 제13조의2제1항을 적용할 때 같은 항 각 호 외의 부분에 따른 주택(이하 이 조 및 제28조의3부터 제28조의6까지에서 "주택"이라 한다)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택은 중과세 대상으로 보지 않는다.

1. 법 제4조에 따른 시가표준액(지분이나 부속토지만을 취득한 경우에는 전체 주택의 시가표준액을 말한다)이 1억원 이하인 주택. 다만, 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제1호에 따른 정비구역(종전의 「주택건설촉진법」에 따라 설립인가를 받은 재건축조합의 사업부지를 포함한다)으로 지정·고시된 지역 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제2조제1항제4호에 따른 사업시행구역에 소재하는 주택은 제외한다.
2. ~ 16. (생 략)

제28조의4(주택 수의 산정방법) ① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 1세대의 주택 수를 산정할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택, 조합원입주권, 주택분양권 또는 오피스텔은 소유주택(주택 취득일 현재 취득하는 주택을 포함하지 아니한 소유주택을 말한다) 수에서 제외한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택
   가. 제28조의2제1호에 해당하는 주택으로서 주택 수 산정일 현재 같은 호에 따른 해당 주택의 시가표준액 기준을 충족하는 주택
   나. ~ 마. (생 략)
2. ~ 9. (생 략)

질의제목 11 ▶ 안건번호 24-0818

민원인 – 지상권이 설정된 부동산을 지방자치단체에 기부채납할 수 있는지(「공유재산 및 물품 관리법」 제8조 등)

01 질의요지

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 "개발제한구역법"이라 함) 제4조의2제2항 본문에서는 같은 조 제1항에 따라 훼손지[71]의 정비사업을 시행하는 자는 해당 정비사업 구역 면적의 100분의 30 이상에 해당하는 정비사업 부지에 도시공원등[72]을 조성하여 공원관리청[73]에 기부채납(寄附採納)하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

「공유재산 및 물품 관리법」(이하 "공유재산법"이라 함) 제8조에서는 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸되기 전에는 공유재산으로 취득하지 못한다고 규정하고 있는바,

개발제한구역법 제4조의2제2항 본문에 따라 기부채납하기 위하여 도시공원등을 조성한 경우로서 해당 도시공원등의 부지에 지상권[74]이 설정되어 있는 경우, 훼손지의 정비사업을 시행하는 자는 지상권이 설정된 도시공원등을 공유재산법 제8조에도 불구하고 공원관리청에 기부채납할 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 훼손지의 정비사업을 시행하는 자는 지상권이 설정된 도시공원등을 공유재산법 제8조에 따라 공원관리청에 기부채납할 수 없습니다.

---

71) 개발제한구역 내 건축물 또는 공작물 등 각종 시설물이 밀집되어 있거나 다수 산재되어 녹지로서의 기능을 충분히 발휘하기 곤란한 곳 등 개발제한구역법 제4조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 훼손된 지역을 말하며(개발제한구역법 제4조제4항 참조), 이하 같음

72) 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조에 따른 도시공원 및 녹지를 말하며, 이하 같음

73) 도시공원을 관리하는 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수를 말하며(「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제19조의2 참조), 이하 같음

74) 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 물권을 말하며(「민법」 제279조 참조), 이하 같음

03 이유

개발제한구역법 제4조의2제2항 본문에서는 훼손지의 정비사업을 시행하는 자는 해당 정비사업 구역 면적의 100분의 30 이상에 해당하는 정비사업 부지에 도시공원등을 조성하여 공원관리청에 기부채납하여야 한다고 규정하고 있을 뿐, 이 사안과 같이 지상권이 설정된 도시공원등의 기부채납 등에 관하여는 별도의 규정을 두고 있지 않은 한편, 공유재산법은 공유재산 및 물품에 관한 기본적인 사항을 정한 법률로서(제1조), 같은 법 제2조의2에서는 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 공유재산법을 따르도록 규정하고 있고, 같은 법 제8조에서는 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸되기 전에는 공유재산으로 취득하지 못하지만(본문), 법원의 판결에 따라 취득하는 경우에는 같은 조를 적용하지 아니한다고 규정(단서)하고 있습니다.

먼저 지방자치단체 소유로 된 공유재산에 관하여 규정하고 있는 공유재산법 제2조 제3호에서는 "기부채납"이란 지방자치단체 외의 자가 부동산과 그 종물, 선박, 주식 등 같은 법 제4조제1항 각 호에 해당하는 공유재산의 소유권을 무상으로 지방자치단체에 이전하여 지방자치단체가 이를 취득하는 것을 말한다고 규정하고 있는데, 같은 법 제8조에서는 공유재산의 취득과 관련하여 지방자치단체가 사권이 설정된 재산은 그 사권이 소멸되기 전에는 공유재산으로 취득하지 못한다고 규정하고 있고, 같은 법 제94조의2제1항에서는 행정안전부장관은 지방자치단체가 공유재산과 물품의 관리·처분·수입 및 지출을 통일적으로 운영할 수 있게 하기 위하여 공유재산 및 물품의 운영기준을 정할 수 있다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 행정안전부 고시인 「지방자치단체 공유재산 운영기준」(이하 "운영기준"이라 함) 별표 1 제1호라목에서는 지방자치단체의 장은 사권이 설정되어 있는 재산을 기부받지 않도록 명확하게 규정하고 있는바, 이 사안의 도시공원등에 설정된 지상권이 사권이라면 공유재산법 제8조에 따라 그 사권이 소멸되기 전에는 해당 도시공원등을 기부채납할 수 없다는 것이 문언상 명확하다고 할 것입니다.

이 경우 공유재산법 제8조에 따른 "사권"은 그 사권의 내용에 따라 해당 재산의 사용·수익·처분권이 그 권리자에게 귀속됨으로써 소유자의 사용·수익· 처분권이 제한되는 사법상 일체의 권리[75]를 의미하는바, 이 사안에서와 같이 도시공원등에 설정된 지상권은 「민법」 제279조에 따르면 타인의 토지에 건물 기타 공작물이나 수목을 소유하기 위하여 그 토지를 사용하는 권리로서 부동산의 사용가치를 독점적으로 지배하는 것을 내용으로 하는 용익물권[76]이고[77],

75) 부산고등법원 2022. 12. 14. 선고 2021나56056 판결례 참조

76) 타인의 토지나 건물 등 부동산을 일정의 목적에 사용·수익하는 권리 중 물권에 관한 것임

이에 따라 지상권이 설정된 부동산의 사용권은 지상권자에게 귀속되어 대지의 소유권자도 그 사용이 제한되며, 대세적(對世的) 효력을 가진 물권으로서 누구에게라도 그 권리를 주장할 수 있어 대지의 소유자로부터 대지의 사용승낙을 받은 자가 있더라도 그에 대하여 지상권자는 지상권을 주장할 수 있어 결국 지상권자의 동의를 받지 못한 부동산의 경우에는 해당 부동산을 사용할 수 있는 권원을 확보했다고 보기 어려운 점[78] 등을 종합하여 보면, 도시공원등에 설정된 지상권은 공유재산의 사용 등에 있어서 제한을 발생시킬 수 있으므로, 이 사안의 도시공원등은 공유재산법 제8조에 따라 그 지상권이 소멸되기 전에는 기부채납할 수 있는 대상이 아니라고 할 것입니다.

그리고 공유재산법 제8조에서 사권이 설정된 재산을 공유재산으로 취득하지 못하도록 한 것은 사권으로 인하여 해당 재산의 사용·처분이 제한될 수 있는 가능성과 사권으로 인한 분쟁의 여지를 미연에 차단함으로써 공유재산의 적정한 보호와 효율적인 관리·처분이라는 입법목적을 달성하기 위한 것인데[79], 이 사안과 같이 명확하게 지상권이라는 사권이 설정되어 있는 도시공원등의 경우에는 기부채납을 할 수 없다고 해석하는 것이 공유재산의 효율적인 관리를 도모하려는 공유재산법 제8조의 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

또한 개발제한구역법 제4조의2에 따라 훼손지의 정비사업을 시행하는 자는 같은 조 제2항에 따라 정비사업 부지에 도시공원등을 조성하여 기부채납하는 것이 의무로 부여되어 있으나, 그 부지의 규모를 정비사업 구역 면적의 100분의 30 이상에 해당하는 정비사업 부지로만 규정하고 있어 도시공원등을 조성하는 위치를 자율적으로 조정할 수 있는 점, 같은 조 제3항에서는 정비사업 구역 내에 도시공원등을 조성하기 어려운 경우 다른 도시공원 부지를 기부채납할 수 있다고 규정하고 있어 같은 조 제2항에 따라 훼손지의 정비사업을 시행하는 자가 반드시 정비사업 부지에 도시공원등을 조성하여 기부채납해야만 하는 것은 아니므로, 같은 조 제2항에 따른 기부채납을 할 수 없다고 하더라도 기부채납에 관한 법령상 의무를 이행할 수 있는 점 등을 고려할 때, 개발제한구역법 제4조의2제2항에 따라 기부채납하려는 경우 그 기부채납의 대상에 대해서는 공유재산법 제8조에 따라 사권이 설정되지 않은 것으로 한정하여 해석하는 것이 개발제한구역법 제4조의2의 규정 체계에도 부합한다고 할 것입니다.

한편, 공유재산법에서는 공유재산에 대해서도 사권 설정이 가능하도록 하고 있는 점을 고려할 때 이 사안의 도시공원등과 같이 사권이 설정된 재산이더라도 공유재산법 제8조에도

77) 법제처 2020. 5. 11. 회신 20-0111 해석례 참조

78) 법제처 2014. 8. 29. 회신 14-0454 해석례 참조

79) 법제처 2013. 11. 4. 회신 13-0494 해석례, 부산고등법원 2022. 12. 14. 선고 2021나56056 판결례 등 참조

불구하고 기부채납할 수 있다는 의견이 있으나, 사권이 설정된 재산을 공유재산으로 취득하는 것과 이미 취득한 공유재산에 사권을 설정하는 등 일정한 관리나 처분을 하는 것은 각각 구분되는 것으로, 취득한 공유재산에 사권을 설정하는 것에 관하여는 공유재산법 제19조 및 제28조에서 별도의 규정을 두고 있으나 사권이 설정된 재산을 공유재산으로 취득하는 것에 관하여는 같은 법 제8조에서 명시적으로 금지하고 있으므로, 규정 체계상 공유재산에 대한 사권 설정이 금지되고 있지 않다는 것이 사권이 설정된 재산을 공유재산으로 취득할 수 있는 근거로 보기는 어렵다는 점에서 이러한 의견은 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 훼손지의 정비사업을 시행하는 자는 지상권이 설정된 도시공원등을 공유재산법 제8조에 따라 공원관리청에 기부채납할 수 없습니다.

관계법령

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법

제4조의2(토지소유자 등의 훼손지 정비사업) ① (생 략)

② 제1항에 따라 정비사업을 시행하는 자는 해당 정비사업 구역 면적의 100분의 30 이상에 해당하는 정비사업 부지에 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조에 따른 도시공원 또는 녹지를 조성하여 같은 법 제20조에 따른 공원관리청(이하 "공원관리청"이라 한다)에 기부채납(寄附採納)하여야 한다. 다만, 정비사업 시행을 위하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따라 도시·군관리계획으로 결정된 도로의 개설이 필요한 경우, 정비사업 구역 면적의 100분의 5 이내에서 공원·녹지로 조성하여 기부채납해야 하는 면적을 도로의 면적으로 대체할 수 있다.

③ ~ ⑧ (생 략)

법률 제13670호 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 일부개정법률 부칙

제2조(유효기간) ① 제4조의2, 제11조제1항제5호의2 및 제12조제1항제1호의2의 개정규정은 2020년 12월 31일까지 효력을 가진다.

② 제1항에 따른 유효기간 중 제4조의2의 개정규정에 따라 개발제한구역관리계획의 수립·변경을 요청한 경우에 대해서는 해당 유효기간이 경과한 후에도 같은 조, 제11조제1항제5호의2 및 제12조제1항제1호의2의 개정규정을 적용한다.

공유재산 및 물품 관리법

제7조(기부채납) ① 지방자치단체의 장은 제4조제1항 각 호의 재산을 지방자치단체에 기부하려는 자가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 받을 수 있다.

② (생 략)

제8조(사권설정 재산의 취득 제한) 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸되기 전에는 공유재산으로 취득하지 못한다. 다만, 법원의 판결에 따라 취득하는 경우에는 이 조를 적용하지 아니한다.

질의제목 12 ▶ 안건번호 24-0870

민원인 – 입찰참가자격 제한처분에 대한 집행정지결정이 있은 후 그 집행정지기간 중에 당초 제한처분 전에 발생한 위반행위가 적발된 경우 적용되는 입찰참가자격 제한기준(「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 등 관련)

01 질의요지

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 "국가계약법"이라 함) 제27조제1항 전단에서는 각 중앙관서의 장[80]은 계약을 이행할 때에 부실·조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "부정당업자"라 함)에게는 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰 참가자격을 제한하여야 하며, 그 제한사실을 즉시 다른 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제76조제3항 본문에서는 각 중앙관서의 장은 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 즉시 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가자격을 제한해야 한다고 규정하면서, 같은 조 제4항에서는 같은 조 제3항에 따른 입찰참가자격 제한의 기간에 관한 사항은 같은 법 제27조제1항 각 호에 해당하는 행위별로 부실벌점, 하자비율, 부정행위 유형, 고의·과실 여부, 뇌물 액수 및 국가에 손해를 끼친 정도 등을 고려하여 기획재정부령으로 정한다고 규정하고 있으며,

그 위임에 따라 마련된 국가계약법 시행규칙 제76조에서는 국가계약법 시행령 제76조제4항에 따른 부정당업자의 입찰참가자격제한의 세부기준은 별표 2와 같다고 규정하면서, 같은 규칙 별표 2 제1호라목에서는 각 중앙관서의 장이 같은 호 나목에 따라 입찰참가자격 제한을 한 후 그 처분 이전에 발생한 위반행위를 적발한 경우에는, 만일 그 처분 전에 해당 위반행위를 적발했더라면 당초의 입찰참가자격 제한기간보다 긴 기간으로 처분했을 것으로 판단되는 경우에 한정하여 당초의 입찰참가자격 제한기간을 초과하는 기간만큼 추가로 입찰참가자격을 제한할 수 있다고 규정하고 있는바,

국가계약법 제27조제1항제1호에 따른 중앙관서의 장의 입찰참가자격 제한처분[81]에 대한

80) 「국가재정법」 제6조에 따른 중앙관서의 장을 말하며, 이하 같음.

81) 국가계약법 시행규칙 별표 2의 '1. 일반기준' 나목에 따라 입찰참가자격 제한처분을 한 경우임을 전제로 함.

법원의 집행정지결정이 있은 후, 중앙관서의 장이 그 집행정지기간 중에 다시 당초의 입찰참가자격 제한처분 전에 발생한 위반행위를 적발한 경우, 이는 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목의 "입찰참가자격 제한을 한 후 그 처분 이전에 발생한 위반행위를 적발한 경우"에 해당하여 같은 목에 따른 입찰참가자격 제한기준이 적용되는지?

02 회답

이 사안의 경우, 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목의 "입찰참가자격 제한을 한 후 그 처분 이전에 발생한 위반행위를 적발한 경우"에 해당하여 같은 목에 따른 입찰참가자격 제한기준이 적용됩니다.

03 이유

국가계약법 제27조제1항 및 같은 법 시행령 제76조제4항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제76조에서는 부정당업자의 입찰참가자격제한의 세부기준은 별표 2와 같다고 규정하고 있고, 같은 규칙 별표 2 제1호라목에서는 당초의 입찰참가자격 제한처분에 대해 법원의 집행정지결정이 있는 경우에 관해서는 별도의 규정을 두고 있지 않은바, 이 사안과 같이 같은 법 제27조제1항제1호에 따른 중앙관서의 장의 입찰참가자격 제한처분에 대한 법원의 집행정지결정이 있은 후, 중앙관서의 장이 그 집행정지기간 중에 당초의 입찰참가자격 제한처분 이전에 발생한 위반행위를 다시 적발한 경우, 같은 시행규칙 별표 2 제1호라목이 적용되는지 여부가 문제됩니다.

먼저 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목에서는 "각 중앙관서의 장이 나목에 따라 입찰참가자격 제한을 한 후"라고 규정하여 각 중앙관서의 장이 당초의 입찰참가자격 제한처분을 한 사실 자체에 대해서만 규정하고 있을 뿐, 그 제한처분의 효력이 반드시 유지되고 있는 상태일 것까지 요구하고 있지 않은 점, 「행정소송법」 제23조제2항에 따른 집행정지 제도는 취소소송이 제기된 경우 본안이 계속되고 있는 법원에서 판결을 하기 전에 처분등[82]이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의

82) 「행정소송법」 제2조제1항제1호에 따른 "처분등"을 말하며, 이하 같음

정지를 결정하는 잠정적이고 일시적인 성격을 갖는 가구제(假救濟) 제도로서[83], 처분등에 관하여 집행정지결정이 있었다고 하더라도 이미 그 처분등이 이루어졌다는 사실 자체에 영향을 미치는 것은 아니라는 점[84] 등을 고려하면, 이 사안과 같이 당초의 입찰참가자격 제한처분에 대한 법원의 집행정지결정이 있더라도 부정당업자의 위반행위에 대한 당초 제한처분 자체의 존재 여부까지 영향을 미치는 것은 아니므로, 그 집행정지기간 중에 당초 제한처분 전에 발생한 위반행위가 적발된 경우에도 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목이 적용된다고 보아야 할 것입니다.

그리고 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목은 2023년 11월 2일 기획재정부령 제1022호로 국가계약법 시행규칙이 일부개정되면서 신설되었는데, 같은 목의 취지는 여러 개의 위반행위가 있는 경우 행정청의 부정행위 인지여부에 따라 같은 위반행위에 대해서도 제재처분의 결과가 달라질 수 있는 등 「행정기본법」상 비례의 원칙과 신뢰보호의 원칙에 배치될 수 있는 문제점이 있어 중앙관서의 장이 어떠한 위반행위에 대하여 입찰참가자격 제한처분을 한 후 그 처분 전의 위반행위를 알게 되어 추가로 제한처분을 하는 경우에는 해당 위반행위들에 대하여 한 번에 제재처분을 할 경우와의 형평성을 고려하도록 한 데에 있는 점에 비추어 볼 때[85], 만약 당초의 입찰참가자격 제한처분에 대해 법원의 집행정지결정이 있었다는 이유로 그 집행정지기간 동안에는 같은 목이 적용되지 않는다고 해석하게 되면, 당초 제한처분에 대한 집행정지신청의 인용 여부, 위반사실이 집행정지기간 만료일을 전후하여 언제 적발되었는지 여부 등 집행정지와 관련된 여러 사정에 따라 같은 목의 적용 여부가 달라질 수 있어 형평에 맞지 않을 수 있는바, 그와 같은 해석은 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목의 입법취지에 부합한다고 보기 어렵습니다.

또한 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다고 할 것인데,[86] 만약 이 사안과 같이 입찰참가자격 제한처분에 대한 집행정지결정이 있은 후 그 집행정지기간 중에 당초 제한처분 전에 발생한 위반행위를 추가로 적발한 경우, 당초 제한처분의 효력이 정지되어 그 처분이 없었던 것과 같은 상태가 되어 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목이 적용되지 않는다고 해석하게 되면, 처분의 상대방인 국민의

83) 헌법재판소 2018. 1. 25. 선고 2016헌바208 결정례 및 법제처 2020. 3. 20. 회신 19-0669 해석례 참조

84) 서울고등법원 2018. 5. 31. 선고 2018나2010683 판결례(상고기각) 및 법제처 2020. 3. 20. 회신 19-0669 해석례 참조

85) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두18964 판결례 및 2023. 11. 2. 기획재정부령 제1022호로 개정된 국가계약법 시행규칙 개정이유 및 주요내용 참조

86) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

입장에서는 당초 제한처분의 위법 여부를 다투기 위해 소송을 제기하는 과정에서 권리구제 수단의 일환으로 신청한 집행정지가 법원에서 인용되었다는 이유로 오히려 더 불리한 입찰참가자격 제한처분을 추가하여 받게 될 가능성이 있는바, 그러한 해석은 타당하지 않다고 할 것입니다.

아울러 이 사안과 같이 당초의 입찰참가자격 제한처분에 대한 법원의 집행정지결정이 있은 후 그 집행정지기간 중에 적발한 당초 제한처분 전의 위반행위에 대하여, ① 만약 당초 제한처분의 효력이 집행정지결정으로 인해 유지되고 있지 않음을 전제하여 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목이 적용되지 않는다고 보면, 추후 당초 제한처분에 대한 본안소송의 확정판결에 따라 집행정지결정의 효력이 소멸되어 당초 제한처분의 효력이 회복되는 경우에는, '효력이 있는 상태의 당초 제한처분'과 '효력이 없는 상태의 당초 제한처분을 전제로 행한 추가 제한처분'이 동시에 존재하게 되는 모순이 발생하는 점, ② 만약 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목이 적용되어 당초의 입찰참가자격 제한기간을 초과하는 기간만큼 추가로 제한처분을 하는 경우에도, 추후 당초 제한처분에 대한 본안소송의 확정판결에 따라 당초 제한처분의 효력이 상실하게 되는 경우에는 중앙관서의 장이 이러한 사정을 반영하여 추가 제한처분의 기간을 변경하는 등의 방식을 통해 제한처분에 대한 합리적 조정이 가능하다는 점[87]도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목의 "입찰참가자격 제한을 한 후 그 처분 이전에 발생한 위반행위를 적발한 경우"에 해당하여 같은 목에 따른 입찰참가자격 제한기준이 적용됩니다.

87) 반대로 당초 제한처분에 대한 본안소송의 확정판결에 따라 당초 제한처분의 효력이 회복되는 경우에는 중앙관서의 장은 이미 국가계약법 시행규칙 별표 2 제1호라목을 적용하여 부과한 추가 제한처분을 그대로 유지하면 됨

관계법령

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) ① 각 중앙관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "부정당업자"라 한다)에게는 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰참가자격을 제한하여야 하며, 그 제한사실을 즉시 다른 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다. 이 경우 통보를 받은 다른 중앙관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 부정당업자의 입찰 참가자격을 제한하여야 한다.

1. 계약을 이행할 때에 부실·조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자
2. ~ 9. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) ① · ② (생 략)

③ 각 중앙관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "부정당업자"라 한다)에 대해서는 즉시 1개월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가자격을 제한해야 한다. 다만, 부정당업자의 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인이 법 제27조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 입찰참가자격 제한 사유가 발생한 경우로서 부정당업자가 대리인, 지배인 또는 그 밖의 사용인의 그 행위를 방지하기 위해 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 부정당업자에 대한 입찰참가자격을 제한하지 않는다.

1. 계약상대자, 입찰자 또는 제30조제2항에 따라 전자조달시스템을 이용해 견적서를 제출하는 자로서 법 제27조제1항제1호부터 제4호까지 및 제7호부터 제9호까지의 규정 중의 어느 하나에 해당하는 자
2. 법 제27조제1항제5호 또는 제6호에 해당하는 자

④ 제3항에 따른 입찰참가자격 제한의 기간에 관한 사항은 법 제27조제1항 각 호에 해당하는 행위별로 부실벌점, 하자비율, 부정행위 유형, 고의·과실 여부, 뇌물 액수 및 국가에 손해를 끼친 정도 등을 고려하여 기획재정부령으로 정한다.

⑤ ~ ⑮ (생 략)

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙

제76조(부정당업자의 입찰참가자격 제한기준 등) 영 제76조제4항에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한의 세부기준은 별표 2와 같다.

[별표 2]

부정당업자의 입찰참가자격 제한기준(제76조 관련)

1. 일반기준

가. 각 중앙관서의 장은 입찰참가자격의 제한을 받은 자에게 그 처분일부터 입찰참가자격제한기간 종료 후 6개월이 경과하는 날까지의 기간 중 다시 부정당업자에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 그 위반행위의 동기·내용 및 횟수 등을 고려하여 제2호에 따른 해당 제재기간의 2분의 1의 범위에서 자격제한기간을 늘릴 수 있다. 이 경우 가중한 기간을 합산한 기간은 2년을 넘을 수 없다.

나. 각 중앙관서의 장은 부정당업자가 위반한 여러 개의 행위에 대하여 입찰참가자격 제한을 하는 경우 입찰참가자격 제한기간은 제2호에 규정된 해당 위반행위에 대한 제한기준 중 제한기간을 가장 길게 규정한 제한기준에 따른다.

다. 각 중앙관서의 장은 부정당업자에 대한 입찰참가자격을 제한하는 경우 자격제한 기간을 그 위반행위의 동기·내용 및 횟수 등을 고려해 제2호에서 정한 기간의 2분의 1의 범위에서 줄일 수 있으며, 이 경우 감경 후의 제한기간은 1개월 이상이어야 한다. 다만, 법 제27조제1항제7호에 해당하는 자에 대해서는 입찰참가자격 제한기간을 줄여서는 안 된다.

라. 각 중앙관서의 장이 나목에 따라 입찰참가자격 제한을 한 후 그 처분 이전에 발생한 위반행위를 적발한 경우에는, 만일 그 처분 전에 해당 위반행위를 적발했더라면 당초의 입찰참가자격 제한기간보다 긴 기간으로 처분했을 것으로 판단되는 경우에 한정하여 당초의 입찰참가자격 제한기간을 초과하는 기간만큼 추가로 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

2. 개별기준

제2절 공정거래

질의제목 1 ▶ 안건번호 24-0239, 24-0240

민원인 – 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제47조제1항에 따라 금지되는 행위의 범위(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제47조 등 관련)

01 질의요지

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법"이라 함) 제47조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 공시대상기업집단[88](동일인[89]이 자연인인 기업집단으로 한정하며, 이하 같음)에 속하는 국내 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족[90]으로 한정하며, 이하 같음), 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사 또는 그 계열회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사와 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 "각 호의 이익제공행위"라 함)를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있는바,

특정 공시대상기업집단에 속하는 계열회사로서 '동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사 A'가 'A가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사[91]'를 대상으로 하는 각 호의 이익제공행위가 공정거래법 제47조제1항에 따라 금지되는 행위에 포함될 수 있는지?

---

88) 공정거래법 제31조제1항 전단에 따라 지정된 자산총액이 5조원 이상인 기업집단을 말하며, 이하 같음.

89) 공정거래법에 별도의 정의규정을 두고 있지 않으나, 기업의 실질적 지배자인 자연인 또는 법인을 말하며, 이하 같음.

90) 공정거래법 시행령 제4조제1항제1호가목에 따른 배우자, 4촌 이내의 혈족, 3촌 이내의 인척, 동일인이 지배하는 국내 회사 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유하고 있는 5촌·6촌인 혈족이나 4촌인 인척, 동일인이 「민법」에 따라 인지한 혼인 외 출생자의 생부나 생모를 말하며, 이하 같음.

91) 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 미만의 지분을 소유한 국내회사를 전제함.

02 회답

이 사안의 경우, 특정 공시대상기업집단에 속하는 계열회사로서 '동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사 A'가 'A가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사'를 대상으로 하는 각 호의 이익제공행위는 공정거래법 제47조제1항에 따라 금지되는 행위에 포함될 수 있습니다.

03 이유

먼저 공정거래법 제47조제1항 각 호 외의 부분 전단에서는 '공시대상기업집단에 속하는 국내 회사'는 ① '특수관계인', ② '동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사' 또는 ③ '그 계열회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사'와 각 호의 이익제공행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있는바, 이에 따라 '공시대상기업집단에 속하는 국내 회사'가 위 ①, ②, ③의 어느 하나에 해당하는 자와 각 호의 이익제공행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하는 것이 금지된다는 점은 그 문언상 명확합니다.

그런데 이 때 공정거래법 제47조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 각 호의 이익제공행위의 주체로 규정하고 있는 '공시대상기업집단에 속하는 국내 회사'가 지칭하는 대상을 살펴보면, 같은 법 제31조제1항에서는 자산총액이 5조원 이상인 '기업집단'을 일정 기준에 따라 '공시대상기업집단'으로 지정하도록 규정하고 있고, 같은 법 제2조제11호나목에서는 "기업집단"이란 동일인이 회사가 아닌 경우에는 그 동일인이 지배하는 둘 이상의 회사의 집단으로서 동일인이 대통령령으로 정하는 기준[92]에 따라 사실상 그 사업내용을 지배하는 회사의 집단을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제12호에서는 "계열회사"란 둘 이상의 회사가 '동일한 기업집단에 속하는 경우에 이들 각각의 회사'를 서로 상대방의 계열회사라 한다고 규정하고 있는바, "공시대상기업집단에 속하는 국내 회사"는 같은 법 제31조제1항에

92) ① 동일인이 단독으로 또는 동일인 관련자와 합하여 해당 회사의 발행주식총수의 100분의 30 이상을 소유하는 경우로서 최다출자자인 회사, ② 동일인이 해당 회사의 경영에 대해 지배적인 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 회사(공정거래법 시행령 제4조 참조)

따라 지정된 '공시대상기업집단에 속하는 모든 계열회사'로서 해당 동일인이 지배하는 회사를 의미한다고 할 것입니다.

그렇다면 공정거래법 제47조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "공시대상기업집단에 속하는 국내 회사"가 각 호의 이익제공행위를 하는 대상 중 하나로 규정하고 있는 ② '동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사'는 '공시대상기업집단에 속하는 계열회사'에 당연히 포함되므로, 같은 규정에 따른 "공시대상기업집단에 속하는 국내회사"로서 각 호의 이익제공행위를 하는 주체가 될 수 있다고 할 것인 한편, 같은 조를 비롯한 공정거래법령에서는 각 호의 이익제공행위의 대상 중 하나인 ③ '그 계열회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사'의 범위를 해당 행위를 하는 주체인 '공시대상기업집단에 속하는 국내 회사(이 사안의 A)'와는 '다른 계열회사(B)'가 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 경우로 제한하고 있지도 않은바, 이 사안과 같이 특정 공시대상기업집단에 속하는 계열회사로서 '동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사 A'가 'A가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사'와 각 호의 이익제공행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하는 것은 공정거래법 제47조제1항에 따라 금지된다고 보는 것이 관련 규정의 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

더욱이 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규정은 기존 부당지원행위에 대한 규제[93]의 경우 공정한 거래를 해칠 우려가 있을 것을 요건으로 함에 따라 사업자가 아닌 특수관계인 개인에 대한 지원이 이루어지는 경우에는 해당 요건을 입증하는 것이 곤란한 문제를 해결하기 위해 2013년 8월 13일 법률 제12095호로 공정거래법을 일부개정하면서 제23조의2를 신설하여 공정한 거래를 저해하는지 여부가 아닌 '특수관계인에게 부당한 이익을 제공하였는지 여부'를 기준으로 위법성을 판단하여 규제하는 제도를 둔 것으로, 그 '부당성'의 판단에 있어서는 행위주체와 행위객체 및 특수관계인의 관계, 행위의 목적과 의도, 행위의 경위와 그 당시 행위객체가 처한 경제적 상황, 거래의 규모, 특수관계인에게 귀속되는 이익의 규모, 이익제공행위의 기간 등을 종합적으로 고려하여 변칙적인 부의 이전 등을 통하여 대기업집단의 특수관계인을 중심으로 경제력 집중이 유지·심화될 우려가 있는지에 따라

93) 사업자가 부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금·대여금·인력·부동산·유가증권·상품·용역·무체재산권 등을 제공하거나 현저히 유리한 조건으로 거래하여 특수관계인 또는 다른 회사를 지원하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하는 것을 말함(구 공정거래법 제23조제1항 제7호).

판단해야 하는바[94], 공정거래법 제47조제1항은 해당 규정에서 상정하고 있는 행위주체와 행위객체 사이에 일어날 수 있는 다양한 각 호의 이익제공행위 중에서 행위의 구체적인 상황을 개별적으로 살펴 "특수관계인에게 부당한 이익이 귀속되는 경우"를 규제하려는 것으로서, 이익을 제공한 주체인 '동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사 A'와 이익을 제공받은 객체인 'A가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사'가 공정거래법 제47조제1항에 따른 행위주체와 행위객체의 요건에 각각 해당될 수 있다면 해당 행위는 공정거래법 제47조제1항 각 호 외의 부분 전단의 규율 대상이라 할 것이고, 해당 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익 귀속되는지 여부에 따라 금지 여부가 결정된다고 할 것입니다.

한편 이 사안은 「상법」상의 모회사(다른 회사의 발행주식의 총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 가진 회사)에 해당[95]하는 A가 그 자회사(그 다른 회사)를 대상으로 각 호의 이익제공행위를 하는 경우로서, 특수관계인의 주식소유 비율이 높은 계열회사에서 낮은 계열회사로 이익을 제공하는 행위가 이루어지기 때문에 특수관계인에게 부당한 이익이 귀속된다고 보기 어렵고, 모회사와 자회사는 경제적 이해관계를 같이 한다고 볼 수 있으므로, 모회사의 자회사에 대한 각 호의 이익제공행위를 규제하는 것은 특수관계인에게 부당한 이익이 귀속되는 것을 규제하려는 공정거래법 제47조제1항의 취지에 부합하지 않을 뿐만 아니라, 모회사와 자회사 간의 자유로운 거래활동을 위축시킬 우려가 있다는 의견이 있습니다.

그러나 ① 공정거래법 제47조제1항은 부당한 이익제공행위의 주체를 "공시대상기업 집단에 속하는 국내 회사"로만 규정하고 있을 뿐, 해당 주체에 대한 특수관계인의 주식소유 요건은 별도로 규정하고 있지 않은바, 반드시 특수관계인의 주식소유 비율이 낮은 회사에서 높은 회사로 이익을 제공하는 행위만을 규제대상으로 하고 있지 않다는 점, ② 특수관계인의 지분이 높은 계열회사에서 낮은 계열회사로, 또는 모회사에서 자회사로 이익제공이 이루어지는 경우에도 특수관계인에게 이익이 귀속될 가능성이 없다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 공정거래법 제47조제1항은 모회사와 자회사 간의 거래를 원천적으로 차단하는 것이 아니라 해당 거래를 통하여 특수관계인에게 '부당한 이익이 귀속되는 것으로 판단되는 경우에만' 규제 대상으로 한다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 특정 공시대상기업집단에 속하는 계열회사로서 '동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내

94) 대법원 2022. 11. 10. 선고 2021두35759 판결례 참조
95) 「상법」 제342조의2 참조

계열회사 A'가 'A가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사'를 대상으로 하는 각 호의 이익제공행위는 공정거래법 제47조제1항에 따라 금지되는 행위에 포함될 수 있습니다.



관계법령

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 10. (생 략)

11. "기업집단"이란 동일인이 다음 각 목의 구분에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사실상 그 사업내용을 지배하는 회사의 집단을 말한다.

가. 동일인이 회사인 경우: 그 동일인과 그 동일인이 지배하는 하나 이상의 회사의 집단

나. 동일인이 회사가 아닌 경우: 그 동일인이 지배하는 둘 이상의 회사의 집단

12. "계열회사"란 둘 이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우에 이들 각각의 회사를 서로 상대방의 계열회사라 한다.

13. ~ 20. (생 략)

제47조(특수관계인에 대한 부당한 이익제공 등 금지) ① 공시대상기업집단(동일인이 자연인인 기업집단으로 한정한다)에 속하는 국내 회사는 특수관계인(동일인 및 그 친족으로 한정한다. 이하 이 조에서 같다), 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 국내 계열회사 또는 그 계열회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 국내 계열회사와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 통하여 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위를 하여서는 아니 된다. 이 경우 다음 각 호에 해당하는 행위의 유형 및 기준은 대통령령으로 정한다.

1. 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 조건보다 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위
2. 회사가 직접 또는 자신이 지배하고 있는 회사를 통하여 수행할 경우 회사에 상당한 이익이 될 사업기회를 제공하는 행위
3. 특수관계인과 현금이나 그 밖의 금융상품을 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위
4. 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격 또는 거래조건 등에 대한 합리적인 고려나 다른 사업자와의 비교 없이 상당한 규모로 거래하는 행위

② 기업의 효율성 증대, 보안성, 긴급성 등 거래의 목적을 달성하기 위하여 불가피한 경우로서 대통령령으로 정하는 거래에는 제1항제4호를 적용하지 아니한다.

③ 제1항에 따른 거래 또는 사업기회 제공의 상대방은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 우려가 있음에도 불구하고 해당 거래를 하거나 사업기회를 제공받는 행위를 하여서는 아니 된다.

④ 특수관계인은 누구에게든지 제1항 또는 제3항에 해당하는 행위를 하도록 지시하거나 해당 행위에 관여해서는 아니 된다.

상법

제342조의2(자회사에 의한 모회사주식의 취득) ① 다른 회사의 발행주식의 총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 가진 회사(이하 "母會社"라 한다)의 주식은 다음의 경우를 제외하고는 그 다른 회사(이하 "子會社"라 한다)가 이를 취득할 수 없다

1. 주식의 포괄적 교환, 주식의 포괄적 이전, 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 때
2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 때

② 제1항 각호의 경우 자회사는 그 주식을 취득한 날로부터 6월 이내에 모회사의 주식을 처분하여야 한다.

③ 다른 회사의 발행주식의 총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 모회사 및 자회사 또는 자회사가 가지고 있는 경우 그 다른 회사는 이 법의 적용에 있어 그 모회사의 자회사로 본다

질의제목 2 ▶ 안건번호 24-0795

민원인 – 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령」 제9조제4항에 따른 예상매출액 범위 산정 적용 대상인 "해당 가맹본부의 가맹점이 5개 이상 있는 경우"의 의미(「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령」 제9조제4항 등 관련)

01 질의요지

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(이하 "가맹사업법"이라 함) 제9조제5항에서는 중소기업자[96]가 아닌 가맹본부(제1호) 또는 직전 사업연도 말 기준으로 가맹본부와 계약을 체결·유지하고 있는 가맹점사업자의 수가 일정한 수 이상인 가맹본부(제2호)는 가맹계약을 체결할 때 가맹희망자에게 대통령령으로 정하는 예상매출액의 범위 및 그 산출 근거를 서면(이하 "예상매출액 산정서"라 함)으로 제공하여야 한다고 규정하고 있고,

그 위임에 따라 마련된 가맹사업법 시행령 제9조제3항에서는 가맹사업법 제9조제5항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 예상매출액의 범위"란 가맹희망자의 점포 예정지에서 영업개시일부터 1년간 발생할 것으로 예상되는 매출액의 최저액과 최고액으로 획정된 범위를 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제9조제4항에서는 같은 조 제3항에도 불구하고 가맹희망자의 점포 예정지가 속한 해당 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 함)에 해당 가맹본부의 가맹점(직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상인 가맹점으로 한정하며, 이하 이 항에서 같음)이 5개 이상 있는 경우에는 그 점포 예정지에서 가장 인접한 가맹점 5개 중 별표 1의3에 따른 직전 사업연도 매출환산액이 가장 작은 가맹점과 가장 큰 가맹점을 제외한 나머지 3개 가맹점의 같은 표에 따른 직전 사업연도 매출환산액 중 최저액과 최고액으로 획정된 범위로 같은 조 제3항에 따른 범위를 갈음할 수 있다고 규정하고 있는바,

가맹사업법 시행령 제9조제4항에 따른 "가맹희망자의 점포 예정지가 속한 해당 시·도에 해당 가맹본부의 가맹점이 5개 이상 있는 경우"에 해당하는지를 판단하는 경우, 예상매출액 산정서 제공 시점에 폐업 등으로 가맹본부와의 가맹사업거래가 종료된 가맹점[97]도 포함되는지?

96) 「중소기업기본법」 제2조제1항 또는 제3항에 따른 자를 말하며, 이하 같음

97) 직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상인 경우로서 직전 사업 연도 말 기준으로 가맹본부와 계약을 체결·유지한 가맹점을 전제로 함

02 회답

이 사안의 경우, 예상매출액 산정서 제공 시점에 폐업 등으로 가맹본부와의 가맹사업거래가 종료된 가맹점도 포함됩니다.

03 이유

가맹사업법 시행령 제9조제4항에서는 가맹사업법 제9조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 가맹본부가 가맹희망자에게 제공해야 하는 예상매출액 산정서의 작성을 위한 "예상매출액의 범위"의 산정 기준에 대하여 규정하면서, 가맹희망자의 점포 예정지가 속한 해당 시·도에 해당 가맹본부의 가맹점이 5개 이상 있는 경우에는 같은 법 시행령 제9조제3항에 따른 일반적인 산정 기준과 다른 기준으로 예상매출액의 범위를 갈음할 수 있다고 규정하고 있는데, "해당 가맹본부의 가맹점이 5개 이상 있는 경우"의 의미에 대해서는 명확히 규정하고 있지 않는바, 이를 해석할 때에는 같은 규정의 문언 외에도 해당 법령의 체계, 입법연혁 및 취지 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다.

먼저 가맹사업법 시행령 제9조제4항에서는 같은 조 제3항에도 불구하고 가맹희망자의 점포 예정지가 속한 해당 시·도에 "해당 가맹본부의 가맹점"이 5개 이상 있는 경우에는 그 점포 예정지에서 가장 인접한 가맹점 5개 중 별표 1의3에 따른 직전 사업연도 매출환산액이 가장 작은 가맹점과 가장 큰 가맹점을 제외한 나머지 3개 가맹점의 같은 표에 따른 직전 사업연도 매출환산액 중 최저액과 최고액으로 획정된 범위로 같은 영 제9조제3항에 따른 범위를 갈음할 수 있다고 규정하고 있는데, "해당 가맹본부의 가맹점" 뒤에 괄호를 두어 "직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상인 가맹점으로 한정한다"고 규정하여, 그 "가맹점"에 대해 직전 사업연도의 영업기간에 대해서 규정하고 있고, 예상매출액 산정서 제공 시점에 가맹본부와 가맹사업거래가 유지되고 있는지 여부에 대해서는 규정하고 있지 않습니다.

그런데 가맹사업법 제9조제4항·제5항 및 같은 법 시행령 제9조에서 가맹본부로 하여금 가맹희망자에게 예상수익상황에 관한 정보(예상매출액의 범위 및 그 산출 근거)를 서면으로 제공하도록 한 취지는 가맹본부에 정보가 편재되어 있는 상황에서 가맹본부로 하여금 정확한 정보를 제공하게 하여 가맹희망자의 합리적 판단을 방해하지 않도록 하고, 제공받은 정보에 기초하여 가맹계약을 체결함으로써 가맹희망자나 가맹점사업자를 두텁게 보호하려는 데

있다고 할 것입니다.[98]

그리고 가맹희망자의 점포 예정지 인근에 다수의 가맹점이 있는 경우에는 인근 가맹점의 매출 통계가 점포 예정지 예상수익상황에 대한 의미 있는 추정치가 될 수 있다는 점에서 가맹사업법 시행령 제9조제4항에서는 같은 조 제3항과 다른 기준으로 예상매출액의 범위를 산정할 수 있도록 규정한 것인데[99], 이 사안과 같이 직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상이고 직전 사업 연도 말 기준으로 가맹본부와 계약을 체결·유지한 가맹점으로서 예상매출액 산정서 제공 시점에는 폐업 등으로 가맹본부와의 가맹사업거래가 종료된 가맹점(이하 "이 사안 폐업등 가맹점"이라 함) 중에는 매출액이 낮아 폐업을 한 가맹점이 포함될 가능성이 있는바, 만약 이를 제외하고 예상매출액의 범위를 산정할 경우 점포 예정지의 정확한 예상수익상황을 가맹희망자에게 제공하기 어려울 수 있다는 점을 고려하면, 예상매출액 산정의 기준이 되는 "해당 가맹본부의 가맹점"에 이 사안 폐업등 가맹점이 포함된다고 해석하는 것이 예상수익상황에 대한 정확한 정보제공이라는 해당 규정의 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

또한 가맹사업법 제7조제2항에서는 가맹본부가 같은 조 제1항에 따라 가맹희망자에게 정보공개서를 제공할 경우에는 가맹희망자의 장래 점포 예정지에서 가장 인접한 가맹점 10개(정보공개서 제공시점에 가맹희망자의 장래 점포 예정지가 속한 광역지방자치단체에서 "영업 중인 가맹점"의 수가 10개 미만인 경우에는 해당 광역지방자치단체 내의 가맹점 전체)의 상호, 소재지 및 전화번호가 적힌 문서를 함께 제공하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제9조제5항제2호에서는 "직전 사업연도 말 기준으로 가맹본부와 계약을 체결·유지하고 있는 가맹점사업자"의 수가 일정 수 이상인 가맹본부는 가맹계약을 체결할 때 가맹희망자에게 예상매출액 산정서를 제공하여야 한다고 규정하고 있는 등 "가맹점"의 영업 여부나 가맹계약 유지 여부에 대해서 별도로 규정하고 있는 것과 달리, 가맹사업법 시행령 제9조제4항에서는 예상매출액 산정의 기준이 되는 "가맹점"에 대하여 "직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상인 가맹점"이라는 요건만을 규정하고 있고, 가맹사업거래 유지에 대하여는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이러한 해당 규정의 문언과 가맹사업법령의 체계를 고려하면, 가맹사업법 시행령 제9조제4항에 따른 "해당 가맹본부의 가맹점이 5개 이상 있는 경우"에 해당하는지를 판단할 때 이 사안 폐업등 가맹점이 포함된다고 보는 것이 합리적인 해석이라고 할 것입니다.

98) 대법원 2022. 5. 26. 선고 2021다300791 판결례 참조

99) 2014. 2. 11. 대통령령 제25175호로 일부개정된 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령」에 대한 조문별 개정이유서 참조

따라서 이 사안의 경우, 예상매출액 산정서 제공 시점에 폐업 등으로 가맹본부와의 가맹사업거래가 종료된 가맹점도 포함됩니다.

법령정비 권고사항

가맹사업법 시행령 제9조제4항에 따른 "해당 가맹본부의 가맹점이 5개 이상 있는 경우"의 "가맹점"에 이 사안 폐업등 가맹점이 포함되는지를 법령에 명확하게 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률

제9조(허위·과장된 정보제공 등의 금지) ①·② (생 략)

③ 가맹본부는 가맹희망자나 가맹점사업자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 제공하는 경우에는 서면으로 하여야 한다.

1. 가맹희망자의 예상매출액·수익·매출총이익·순이익 등 장래의 예상수익상황에 관한 정보
2. 가맹점사업자의 매출액·수익·매출총이익·순이익 등 과거의 수익상황이나 장래의 예상수익상황에 관한 정보

④ (생 략)

⑤ 제3항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 가맹본부는 가맹계약을 체결할 때 가맹희망자에게 대통령령으로 정하는 예상매출액의 범위 및 그 산출 근거를 서면(이하 "예상매출액 산정서"라 한다)으로 제공하여야 한다.

1. 중소기업자(「중소기업기본법」 제2조제1항 또는 제3항에 따른 자를 말한다)가 아닌 가맹본부
2. 직전 사업연도 말 기준으로 가맹본부와 계약을 체결·유지하고 있는 가맹점사업자(가맹본부가 복수의 영업표지를 보유하고 있는 경우에는 동일 영업표지를 사용하는 가맹점사업자에 한정한다)의 수가 대통령령으로 정하는 수 이상인 가맹본부

⑥·⑦ (생 략)

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령

제9조(예상수익상황에 대한 정보제공 등) ①·② (생 략)

③ 법 제9조제5항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 예상매출액의 범위"란 가맹희망자의 점포 예정지에서 영업개시일부터 1년간 발생할 것으로 예상되는 매출액의 최저액과 최고액으로 획정된 범위를 말한다. 이 경우 그 매출액의 최고액은 그 매출액의 최저액의 1.7배를 초과해서는 아니 된다.

④ 제3항에도 불구하고 가맹희망자의 점포 예정지가 속한 해당 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)에 해당 가맹본부의 가맹점(직전 사업연도의 영업기간이 6개월 이상인 가맹점으로 한정한다. 이하 이 항에서 같다)이 5개 이상 있는 경우에는 그 점포 예정지에서 가장 인접한 가맹점 5개 중 별표 1의3에 따른 직전 사업연도 매출환산액이 가장 작은 가맹점과 가장 큰 가맹점을 제외한 나머지 3개 가맹점의 같은 표에 따른 직전 사업연도 매출환산액 중 최저액과 최고액으로 획정된 범위로 제3항에 따른 범위를 갈음할 수 있다.
⑤ (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0836

민원인 – 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제18조제3항제1호바목에서 규정하고 있는 "손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우"의 의미(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제18조제3항제1호 등 관련)

01 질의요지

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법"이라 함) 제18조제3항 각 호 외의 부분에서는 일반지주회사[100]의 자회사[101]는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 항 제1호 본문에서는 손자회사[102]의 주식을 그 손자회사 발행주식총수의 100분의 50(이하 "손자회사주식보유기준"이라 함) 미만으로 소유하는 행위를 규정하면서, 같은 호 단서에서는 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 손자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우는 예외로 한다고 규정하고 있으며, 같은 호 바목에서는 손자회사를 손자회사에 해당하지 아니하게 하는 과정에서 손자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우로서 그 미달하게 된 날부터 1년 이내인 경우(같은 기간 내에 손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우로 한정함)를 규정하고 있는 한편,

공정거래법 시행령 제5조제2항 각 호 외의 부분 본문에서는 공정거래위원회는 같은 영 제4조제1항에도 불구하고 같은 영 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사에 대해서는 이해관계자의 요청에 따라 동일인이 지배하는 기업집단의 범위에서 제외할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 항 제3호 본문에서는 같은 항 제2호나목에 해당하는 회사로서 해당 회사의 최다출자자가 임원의 구성이나 사업운용 등에 지배적인 영향력을 행사하지 않는다고 인정될 것(제3호가목) 등 각 목의 요건을 모두 갖춘 회사를 규정하고 있는바,

어느 손자회사가 공정거래법 시행령 제5조제2항제3호 각 목의 요건을 충족하여 공정거래위원회가 동일인이 지배하는 기업집단의 범위에서 제외하는 결정을 하고 이를 통지한 경우,

100) 금융지주회사 외의 지주회사를 의미하며(공정거래법 제18조제2항제5호 참조), 이하 같음

101) 지주회사로부터 대통령령으로 정하는 기준에 따라 그 사업내용을 지배받는 국내 회사를 말하며(공정거래법 제2조제8호 참조), 이하 같음

102) 자회사로부터 대통령령으로 정하는 기준에 따라 그 사업내용을 지배받는 국내 회사를 말하며(공정거래법 제2조제9호 참조), 이하 같음

공정거래법 제18조제3항제1호바목에서 규정하고 있는 “손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우”는 해당 회사가 같은 법 시행령 제5조제2항제3호 각 목의 요건을 충족하는 경우를 의미하는지, 아니면 같은 항에 따른 공정거래위원회의 기업집단 범위 제외 결정이 해당 회사에 통지되는 경우를 의미하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 공정거래법 제18조제3항제1호바목에서 규정하고 있는 “손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우”는 같은 법 시행령 제5조제2항에 따른 공정거래위원회의 기업집단 범위 제외 결정이 해당 회사에 통지되는 경우를 의미합니다.

03 이유

공정거래법 제18조제3항제1호 본문에서는 일반지주회사의 자회사는 손자회사의 주식을 그 손자회사 발행주식총수의 100분의 50 미만으로 소유하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하면서, 같은 호 단서 및 바목에서는 손자회사를 손자회사에 해당하지 아니하게 하는 과정에서 손자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우로서 그 미달하게 된 날부터 1년 이내인 경우(같은 기간 내에 손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우로 한정함)는 예외로 한다고 규정하고 있는 한편, 같은 법 제2조제9호에서는 “손자회사”란 자회사의 계열회사일 것 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 자회사로부터 그 사업내용을 지배받는 국내 회사를 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조제12호에서는 “계열회사”란 둘 이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우에 이들 각각의 회사를 서로 상대방의 계열회사라 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제5조제2항 각 호 외의 부분 본문에서는 공정거래위원회는 같은 영 제4조제1항에도 불구하고 같은 영 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사에 대해서는 이해관계자의 요청에 따라 동일인이 지배하는 기업집단의 범위에서 제외할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제3호 본문에서는 같은 항 제2호나목에 해당하는 회사[103]로서 해당 회사의 최다출자자가 임원의 구성이나 사업운용 등에 지배적인 영향력을 행사하지 않는다고 인정될 것(제3호가목) 등 각 목의 요건을 모두 갖춘 회사를 규정하고 있습니다.

103) 민간투자사업법인으로서 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조제1호부터 제4호까지의 방식으로 민간투자사업을 추진하는 회사

위와 같은 공정거래법령의 규정체계를 종합해 보면, 자회사의 계열회사인 손자회사가 공정거래법 시행령 제5조제2항제3호에 따라 기업집단의 범위에서 제외된다면, 같은 영 제3조제4항제1호에 따른 자회사의 계열회사일 것이라는 손자회사 기준을 충족하지 못하여 더 이상 손자회사가 아니라고 할 것인데, 이 경우에 공정거래법 제18조제3항제1호바목에서 규정하고 있는 "손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우"가 손자회사가 같은 법 시행령 제5조제2항제3호 각 목의 요건을 충족하는 경우를 의미하는지, 아니면 같은 항에 따른 공정거래위원회의 기업집단 범위 제외 결정이 손자회사에 통지되는 경우를 의미하는지가 문제됩니다.

먼저 공정거래법령의 문언과 규정체계상 손자회사가 공정거래법 시행령 제5조제2항제3호에 따라 기업집단의 범위에서 제외되는 경우는 공정거래법 제18조제3항제1호바목에서 규정하고 있는 "손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우"에 해당한다 할 것인데, 공정거래위원회가 공정거래법 시행령 제5조제2항에 따라 어느 회사를 동일인이 지배하는 기업집단의 범위에서 제외하는 경우 해당 회사는 지주회사 등의 행위제한(법 제18조) 등 규제대상에서 제외될 수 있고, 그에 따라 공정거래위원회로부터 시정조치(법 제37조), 과징금(법 제38조) 등 제재처분대상에서도 제외될 수 있으므로, 위와 같은 공정거래위원회의 제외 결정은 해당 회사의 권리의무에 직접 관계가 있는 행위로 상대방이 있는 행정처분에 해당한다 할 것이고[104], 상대방이 있는 행정처분의 경우에는 특별한 규정이 없는 한 의사표시의 일반적 법리에 따라 그 행정처분이 상대방에게 고지되어야 효력을 발생하게 되므로[105], 원칙적으로 위 공정거래위원회의 제외 결정이 해당 회사에 통지되어야 비로소 기업집단의 범위에서 제외되는 효력이 발생합니다.

그리고 공정거래법 시행령 제4조제1항에서는 기업집단의 범위에 대하여 규정하고 있고, 같은 영 제5조제2항 본문에서는 공정거래위원회는 같은 영 제4조제1항에도 불구하고 같은 영 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사에 대해서는 이해관계자의 요청에 따라 동일인이 지배하는 기업집단의 범위에서 제외할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 항 제3호 가목에서 "해당 회사의 최다출자자가 임원의 구성이나 사업운용 등에 지배적인 영향력을 행사하지 않는다고 인정될 것"과 같은 불확정 개념을 사용하고 있고[106], 같은 조 제3항에서는 공정거래위원회가 동일인이 지배하는 기업집단의 범위에서 제외된 회사가 그 제외 요건에

104) 대법원 2015. 3. 20. 선고 2012두27176 판결례 참조

105) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2009두 11706 판결례, 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011두31635 판결례, 서울행정법원 2021. 9. 24. 선고 2020구단64609 판결례 등 참조

106) 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011두29205 판결례 참조

해당하지 않게 된 경우 직권 또는 이해관계자의 요청에 따라 그 제외 결정을 취소할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항 및 제5항에서는 기업집단으로부터의 제외를 요청하려는 자가 일정한 경우 특정 서류 등을 공정거래위원회에 제출할 것을 규정하고 있는바, 같은 영 제5조의 문언과 체계를 고려하면, 같은 영 제4조제1항에 따라 기업집단의 범위에 속하는 어느 회사가 같은 영 제5조제2항제3호에 따라 예외적으로 기업집단 범위에서 제외되기 위해서는 그 회사가 같은 항 제3호 각 목의 요건을 충족하기만 하면 당연히 기업집단의 범위에서 제외되는 것은 아니고, 이해관계자의 요청에 따라 공정거래위원회가 같은 호 각 목의 요건을 충족하는지 여부 등을 판단한 후 기업집단 범위 제외 여부에 대하여 결정하고 통지하는 행위가 있어야 하며[107], 그에 따라 해당 회사가 손자회사에 해당하지 아니하게 된다 할 것입니다.

또한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데[108], 공정거래법 제18조제3항제1호바목에서는 일반지주회사의 자회사가 손자회사의 주식을 손자회사 발행주식총수의 100분의 50 미만으로 소유하는 행위를 원칙적으로 제한하면서, 손자회사를 손자회사에 해당하지 아니하게 하는 과정에서 손자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우로서 그 미달하게 된 날부터 1년 이내에 "손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우"에 한정하여 예외로 하고 있는바, 그 문언에 따라 "손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우"는 같은 법 시행령 제5조제2항에 따른 공정거래위원회의 기업집단 범위 제외 결정이 손자회사에 통지되어 해당 회사가 더 이상 손자회사에 해당하지 않게 된 경우를 의미한다 할 것이고, 같은 법 시행령 제5조제2항제3호 각 목의 요건을 충족할 수 있는 사유가 존재하여 장차 손자회사에 해당하지 아니하게 될 가능성이 있는 경우까지 포함된다고 보기는 어렵습니다.

한편 공정거래법 시행령 제26조제4항 및 지주회사 관련 규정에 관한 해석지침[109](이하 "해석지침"이라 함) 등에서는 지주회사 관련 규제의 적용 여부는 사유 발생을 기준으로 하므로, 공정거래법 제18조제3항제1호바목에서 규정하고 있는 "손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우"도 그 사유가 발생한 "손자회사가 같은 법 시행령 제5조제2항제3호 각 목의 요건을 충족하는 경우"를 의미한다는 의견이 있으나, 해석지침에서는 지주회사 등의 행위제한규정 적용시점을 주로 설립등기일, 합병등기일 등 특정 시점으로 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제26조제4항에서도 지주회사가 같은 영 제3조제1항 또는 제2항의 기준에 해당하지 않게 된

107) 서울고등법원 2015. 7. 23. 선고 2014누3640 판결례 및 임영철·조성국, 공정거래법 이론과 실무 제3판, 박영사(2023) 334p 등 참조

108) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례, 대법원 2020. 2. 6. 선고 2019두43474 판결례 참조

109) 공정거래위원회예규 제410호

사실을 공정거래위원회에 알린 경우에는 해당 사유가 발생한 날부터 지주회사로 보지 않는다고 정하고 있을 뿐, 손자회사가 같은 법 시행령 제5조제2항에 따라서 기업집단의 범위에서 제외되어 손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우에 대하여는 규정하고 있지 않으므로, 공정거래법 시행령 제26조제4항 및 해석지침 등을 근거로 손자회사가 같은 법 시행령 제5조제2항제3호 각 호의 요건을 충족하기만 하면, 공정거래위원회의 결정 및 통지 없이도 당연히 기업집단의 범위에서 제외되어 손자회사에 해당하지 않는다고 보기는 어렵다 할 것이고, 그와 같이 해석한다면 오히려 기업집단의 범위에서 제외되는 시점이 불분명하여 관련 규정 준수 여부와 관련된 행정제재 및 형사처벌 여부에 대한 예측가능성을 저해할 우려가 있다는 점에서, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 공정거래법 제18조제3항제1호바목에서 규정하고 있는 "손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우"는 같은 법 시행령 제5조제2항에 따른 공정거래위원회의 기업집단 범위 제외 결정이 해당 회사에 통지되는 경우를 의미합니다.

관계법령

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 8. (생 략)
9. "손자회사"란 자회사로부터 대통령령으로 정하는 기준에 따라 그 사업내용을 지배받는 국내 회사를 말한다.
10.·11. (생 략)
12. "계열회사"란 둘 이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우에 이들 각각의 회사를 서로 상대방의 계열회사라 한다.
13. ~ 20. (생 략)

제18조(지주회사 등의 행위제한 등) ①·② (생 략)

③ 일반지주회사의 자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 손자회사의 주식을 그 손자회사 발행주식총수의 100분의 50[그 손자회사가 상장법인 또는 국외상장법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사(일반지주회사의 자회사인 벤처지주회사로 한정한다)의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다. 이하 이 조에서 "손자회사주식보유기준"이라 한다] 미만으로 소유하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 손자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우는 예외로 한다.

가. ~ 마. (생 략)

바. 손자회사를 손자회사에 해당하지 아니하게 하는 과정에서 손자회사주식보유기준에 미달하게

된 경우로서 그 미달하게 된 날부터 1년 이내인 경우(같은 기간 내에 손자회사에 해당하지 아니하게 된 경우로 한정한다)

사. (생 략)

④ ~ ⑦ (생 략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제3조(지주회사의 기준) ① ~ ③ (생 략)

④ 법 제2조제9호에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 다음 각 호의 기준을 말한다.

1. 자회사의 계열회사일 것
2. 자회사가 소유하는 주식수가 제14조제1항제1호 또는 제2호의 자 중 최다출자자가 소유하는 주식수와 같거나 그 보다 많을 것. 다만, 자회사가 소유하는 주식수가 다음 각 목의 자가 소유하는 주식수와 같은 경우는 제외한다.

가.·나. (생 략)

제5조(기업집단으로부터의 제외) ① (생 략)

② 공정거래위원회는 제4조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사에 대해서는 이해관계자의 요청에 따라 동일인이 지배하는 기업집단의 범위에서 제외할 수 있다. 다만, 제3호 또는 제5호의 회사에 대해 법 제47조를 적용하는 경우와 제5호의 회사 중 벤처지주회사가 주식을 소유한 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업에 대해 제3조제3항을 적용하는 경우에는 기업집단의 범위에 속하는 것으로 본다.

1. (생 략)
2. (생 략)

가. (생 략)

나. 민간투자사업법인으로서 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조제1호부터 제4호까지의 방식으로 민간투자사업을 추진하는 회사

3. 제2호나목에 해당하는 회사로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 회사. 다만, 해당 회사는 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제13조에 따라 사업시행자로 지정된 날부터 같은 법 제15조제1항에 따라 주무관청의 승인을 받아 같은 조 제2항에 따라 고시된 실시계획에 따른 사업(같은 법 제21조제7항에 따라 고시된 부대사업은 제외한다)을 완료하여 같은 법 제22조제1항에 따른 준공확인을 받기 전까지의 기간까지만 기업집단 범위에서 제외할 수 있다.

가. 해당 회사의 최다출자자가 임원의 구성이나 사업운용 등에 지배적인 영향력을 행사하지 않는다고 인정될 것. 이 경우 최다출자자가 소유한 주식을 산정하는 때에는 동일인 또는 동일인관련자가 소유한 해당 회사의 주식을 포함한다.

나. 해당 회사(해당 회사가 그 사업내용을 지배하는 회사를 포함한다)가 동일인이 지배하는 회사(동일인이 회사인 경우에는 동일인을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)에 출자하고 있지 않을 것

다. 해당 회사(해당 회사가 그 사업내용을 지배하는 회사를 포함한다)와 동일인이 지배하는 회사 간에 채무보증 관계가 없을 것. 다만, 해당 회사(해당 회사가 그 사업내용을 지배하는 회사는

제외한다. 이하 이 목에서 같다)에 출자한 동일인이 지배하는 회사가 해당 회사에 대해 채무보증을 제공하는 경우는 제외한다.

라. 동일인 또는 동일인관련자가 해당 회사의 주식을 취득하거나 소유하여 제4조제1항의 요건에 해당하게 된 날 이후 해당 회사(해당 회사가 그 사업내용을 지배하는 회사를 포함한다. 이하 이 목에서 같다)와 동일인(그 친족을 포함한다) 간 또는 해당 회사와 동일인이 지배하는 회사 간에 법 제45조제1항제9호, 같은 조 제2항 또는 법 제47조를 위반하여 해당 회사, 동일인(그 친족을 포함한다) 또는 동일인이 지배하는 회사가 공정거래위원회로부터 시정조치(시정권고 또는 경고를 포함한다)를 받거나 과징금을 부과받은 사실이 없을 것

4.·5. (생 략)

③ ~ ⑦ (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0867

민원인 – 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조제3항에 따른 “청약철회등”에 교환이 포함되는지 여부(「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조제3항 등 관련)

01 질의요지

「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」(이하 “전자상거래법”이라 함) 제17조에서는 통신판매에 있어서의 소비자의 청약철회권 등에 대하여 규정하면서, 같은 조 제1항에서는 통신판매업자와 재화 또는 용역(이하 “재화등”이라 함)의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 같은 법 제13조제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일(제1호) 등 같은 법 제17조제1항 각 호의 기간 이내에 해당 계약에 관한 청약철회등을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화등이 멸실되거나 훼손된 경우(제1호) 등에 해당하는 경우에는 소비자는 통신판매업자의 의사에 반하여 같은 조 제1항에 따른 청약철회등을 할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 소비자는 같은 조 제1항 및 제2항에도 불구하고 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 그 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회등을 할 수 있다고 규정하고 있는바,

소비자가 통신판매업자와 재화등의 구매에 관한 계약을 체결하여 공급받은 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우, 소비자가 공급받은 재화등을 통신판매업자에게 반환하고, 반환한 재화등과는 다른 재화등을 통신판매업자로부터 다시 공급받는 것(이하 “교환”이라 함)이 전자상거래법 제17조제3항에 따른 “청약철회등”에 포함되는지?

02 회답

이 사안의 경우, 교환은 전자상거래법 제17조제3항에 따른 “청약철회등”에 포함되지 않습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[110], 전자상거래법 제17조제3항에서는 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우 같은 조 제1항 및 제2항에도 불구하고 일정한 기간 이내에 "청약철회등"을 할 수 있다고 규정하고 있고, 여기서 "청약철회등"은 같은 법 제13조제2항제5호에서 "청약의 철회 및 계약의 해제"를 약칭한 것으로서, 청약의 철회는 계약이 체결되기 전에 청약이 없었던 것으로 하는 것이고, 계약의 해제는 유효하게 성립한 계약의 효력을 당사자 일방의 의사표시에 의하여 소급적으로 소멸케 하여, 계약이 처음부터 성립하지 않은 것과 같은 상태로 복귀시키는 것[111]인 반면, "교환"은 계약이 체결된 이후 공급받은 재화등을 통신판매업자에게 반환하고, 반환한 재화등과는 다른 재화등을 다시 공급받는 것을 의미하므로 청약의 철회나 계약의 해제와는 다른 개념이라고 할 것인바, 전자상거래법 제17조제3항에 따른 "청약철회등"에 "교환"이 포함되지 않는다는 것이 문언상 명확합니다.

그리고 전자상거래법 제13조제2항에서는 통신판매업자의 소비자에 대한 거래조건에 대한 정보제공 사항에 대하여 규정하면서, 같은 조 제5호에서는 청약의 철회 및 계약의 해제의 기한·행사방법 및 효과에 관한 사항을, 같은 항 제6호에서는 재화등의 교환·반품·보증과 그 대금 환불 및 환불의 지연에 따른 배상금 지급의 조건·절차를 각각 규정하고 있는바, 전자상거래법에서는 청약의 철회, 계약의 해제 및 교환을 각각 별도의 개념으로 구분하여 사용하고 있다고 할 것이고, 같은 법 제18조제1항에서는 소비자는 같은 법 제17조제3항 등에 따라 청약철회등을 한 경우에는 이미 공급받은 재화등을 반환하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제18조제2항에 따라 통신판매업자는 청약철회등이 있는 경우 일정한 기간 이내에 이미 지급받은 재화등의 대금을 환급할 의무를 부담하는 등 전자상거래법 제18조에서는 "청약철회등"의 효과에 대하여 규정하고 있는데, 해당 조항에서 청약철회등이 있는 경우 통신판매업자가 반환받은 재화와는 다른 재화를 다시 공급하도록 하는 내용은 규정하고 있지 않은바, 전자상거래법 제17조제3항에 따른 "청약철회등"에 "교환"은 포함되지 않는다고 해석하는 것이 전자상거래법의 규정체계에도 부합합니다.

아울러 전자상거래법 제17조제3항의 "청약철회등"이라는 표현은 구 전자상거래법(2002년

110) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

111) 지원림, 민법강의 제18판, 홍문사 1399p 참조

3월 30일 법률 제6687호로 제정되어 2002년 7월 1일 시행된 것을 말함) 제정 당시부터 규정되어 있었는데, 이는 당초 의안번호 제160722호로 발의된 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한법률안에서는 "청약 철회"로만 규정되어 있던 것을, 청약의 철회와 계약의 해제의 개념을 구분하여 명확하게 하기 위하여 현행 전자상거래법과 같이 청약의 철회 및 계약의 해제(이하 "청약철회등"이라 한다)로 규정하게 된 것인바, 이러한 입법연혁을 살펴보면 "청약철회등"에 청약의 철회와 계약의 해제의 개념을 구분하여 명확히 하려는 내용[112] 외에 전자상거래법 제17조의 적용 대상으로 교환까지 포함하려는 취지가 있었다고 보기는 어렵다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편 전자상거래법 제17조제3항에서 규정하고 있는 "청약철회등"에서의 "등"은 그 밖에 같은 종류의 것이 더 있음을 나타내는 의존명사[113]로서 "교환"이 포함된다는 의견이 있으나, 전자상거래법 제17조제3항에 따른 "청약철회등"은 법령에서 반복하여 사용되는 문구나 단어군을 맨 처음 나오는 조항에서 그 문구나 단어군을 대표할 수 있는 문구나 단어로 줄여 간단하게 표시하는 방법인 "약칭"[114]에 해당하는 것으로, 전자상거래법 제13조제2항 제5호에서 청약의 철회 및 계약의 해제 뒤에 괄호를 두어 이하 "청약철회등"이라 한다고 약칭하고 있어, "청약청회등"은 "청약의 철회 및 계약의 해제"를 의미하는 것이 분명한바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 교환은 전자상거래법 제17조제3항에 따른 "청약철회등"에 포함되지 않습니다.

112) 2001. 4. 17. 의안번호 제160722호로 발의된 전자상거래등에서의소비자보호에관한법률안에 대한 국회 정무위원회 심사보고서 참조

113) 국립국어원 표준국어대사전 참조

114) 법제처 법령입안·심사기준(2023) P.792 참조

관계법령

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률

제13조(신원 및 거래조건에 대한 정보의 제공) ① (생 략)

② 통신판매업자는 소비자가 계약체결 전에 재화등에 대한 거래조건을 정확하게 이해하고 실수나 착오 없이 거래할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 적절한 방법으로 표시·광고하거나 고지하여야 하며, 계약이 체결되면 계약자에게 다음 각 호의 사항이 기재된 계약내용에 관한 서면을 재화등을 공급할 때까지 교부하여야 한다. 다만, 계약자의 권리를 침해하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 계약자를 갈음하여 재화등을 공급받는 자에게 계약내용에 관한 서면을 교부할 수 있다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 청약의 철회 및 계약의 해제(이하 "청약철회등"이라 한다)의 기한·행사방법 및 효과에 관한 사항(청약철회등의 권리를 행사하는 데에 필요한 서식을 포함한다)
6. ~ 11. (생 략)

제17조(청약철회등) ① 통신판매업자와 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 다음 각 호의 기간(거래당사자가 다음 각 호의 기간보다 긴 기간으로 약정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 해당 계약에 관한 청약철회등을 할 수 있다.

1. 제13조제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일. 다만, 그 서면을 받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일
2. 제13조제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받지 아니한 경우, 통신판매업자의 주소 등이 적혀 있지 아니한 서면을 받은 경우 또는 통신판매업자의 주소 변경 등의 사유로 제1호의 기간에 청약철회등을 할 수 없는 경우에는 통신판매업자의 주소를 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 7일
3. 제21조제1항제1호 또는 제2호의 청약철회등에 대한 방해 행위가 있는 경우에는 그 방해 행위가 종료한 날부터 7일

② 소비자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 통신판매업자의 의사에 반하여 제1항에 따른 청약철회등을 할 수 없다. 다만, 통신판매업자가 제6항에 따른 조치를 하지 아니하는 경우에는 제2호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 경우에도 청약철회등을 할 수 있다.

1. ~ 6 (생 략)

③ 소비자는 제1항 및 제2항에도 불구하고 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 그 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회등을 할 수 있다.

④ ~ ⑥ (생 략)



산업통상자원·중소기업

제1절 산업통상자원
제2절 중소기업

제1절 산업통상자원

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0820

민원인 – 전기안전관리자의 직무대행자 지정 기준을 내부 규정으로 정한 사업장 등에서 전기안전관리자의 부재로 직무대행자를 지정한 경우 반드시 직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰두어야 하는지 여부(「전기안전관리법 시행규칙」 제29조제3항 등 관련)

01 질의요지

「전기안전관리법」 제22조제1항부터 제4항까지에서는 전기사업자나 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자의 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 전기안전관리업무를 수행하는 전기안전관리자의 선임에 관한 사항을 규정하고 있고, 같은 조 제5항에서는 같은 조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 전기안전관리자를 선임한 자는 전기안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 그 기간 동안 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 대행자(이하 "직무대행자"라 함)를 지정해야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제29조제3항에서는 같은 법 제22조제5항에 따라 직무대행자를 지정한 자는 같은 규칙 별지 제14호서식의 전기안전관리자의 직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰두어야 한다고 규정하고 있는바,

「전기안전관리법」 제22조제5항에 따른 직무대행자를 지정하는 기준을 내부 규정[1]으로 정하고 있는 사업장등[2]의 전기안전관리자가 상당 기간의 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없어 그 기간 동안 내부 규정에 따라 직무대행자를 지정한 경우, 같은 법 시행규칙 제29조제3항에 따라 직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰두어야 하는지?

---

1) 전기안전관리자 부재 시 그 직무대행자를 지정하는 기준을 두고 있으나, 직무대행자의 인적사항, 직무대행기간 등 직무대행자 지정서에 포함되어야 하는 사항이 모두 규정되어 있지는 않은 경우를 전제함.

2) 「전기안전관리법」 제2조제3호에 따른 전기사업자의 사업장 및 같은 조 제9호에 따른 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자의 전기설비가 설치된 장소를 의미하며, 이하 같음.

02 회답

이 사안의 경우, 직무대행자를 지정한 자는 「전기안전관리법 시행규칙」 제29조제3항에 따라 직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰두어야 합니다.

03 이유

먼저 일반적으로 법령에서 "~을 할 수 있다"고 규정하고 있는 경우는 그 행위주체에 대하여 일정한 권리나 권한 또는 자격을 부여하는 것으로, "~을 하여야 한다"고 규정하고 있는 경우는 그 행위주체에 대하여 일정한 의무나 책임을 부과하는 것으로 각각 해석하는 것이 합리적이라고 할 것인데[3], 「전기안전관리법 시행규칙」 제29조제3항에서 「전기안전관리법」 제22조제5항에 따라 직무대행자를 지정한 자는 '직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰두어야 한다'고 규정하고 있는바, 해당 규정의 문언상 전기안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없어 직무대행자를 지정한 자에게는 "직무대행자 지정서"를 작성·비치할 의무가 있다고 할 것입니다.

그리고 ① 「전기안전관리법」은 전기재해의 예방과 전기설비 안전관리에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명과 재산을 보호하고 공공의 안전을 확보함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제22조제1항부터 제5항까지에서는 상시적인 전기설비의 공사·유지·관리 및 운용에 필요한 조치[4]를 위하여 전기사업자나 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자에게 전기안전관리자의 선임 및 전기안전관리자의 직무대행자 지정 의무를 부여하고 있고, ② 같은 법 제24조에서는 전기안전관리자에게 전기안전관리 기록에 대한 작성·보전 및 제출의무(제3항)와 기술기준에 적합하지 아니한 전기설비의 수리·개조·이전 등 필요한 조치 요구의무(제4항)를 부여하면서, 해당 의무를 위반한 경우에 대하여 각각 300만원 이하 및 100만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정(같은 법 제52조제1항제5호 및 같은 조 제2항제6호)하고 있는데, 전기안전관리자 또는 그 직무대행자가 전기안전관리업무를 소홀히 수행하는 등 법적 의무를 위반한 경우에는 그 책임의 소재가 명확하게 밝혀질 필요가 있다고 할 것인바, 전기안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우 같은 법 시행규칙 제29조제1항에 따른 지정요건을 갖춘 직무대행자가 그 대행 기간 동안

3) 법제처 2017. 8. 2. 회신 17-0330 해석례 참조

4) 「전기안전관리법」 제2조제1호에 따른 "전기안전관리"의 정의 참조

직무를 제대로 수행했는지를 확인하기 위한 목적 등으로 같은 조 제3항에서 직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰둘 의무를 부여한 것이라 할 것입니다.

한편 「전기안전관리법 시행규칙」 별지 제14호서식의 "직무대행자 지정서"에서는 지정인, 전기설비의 용량·전압, 전기안전관리자 및 직무대행자의 성명·소속·직책·기술자격사항·근무연수, 직무대행기간, 직무대행사유, 지정연월일을 작성하도록 규정하고 있는바, 같은 규칙 제29조제3항에 따라 직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰두는 경우에는 같은 서식의 직무대행자 지정서와 형식적으로 완전히 동일한 양식의 직무대행자 지정서 서식을 사용하지는 않더라도 그 내용은 같은 서식의 내용에 부합해야 할 것[5]인데, 이 사안과 같이 사업장등의 내부 규정에서 직무대행자의 지정기준을 규정하고 있으나, 전기안전관리자의 직무대행 사유가 발생하여 직무대행자를 지정한 경우 실제로 지정되는 직무대행자의 인적사항이나 직무대행기간, 직무대행사유 등 직무대행자 지정서에 포함되어야 하는 내용을 작성하여 갖춰두지 않은 경우에는 같은 규칙 제29조제3항에 따라 전기안전관리자의 직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰둔 것으로 보기 어렵다 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 직무대행자를 지정한 자는 「전기안전관리법 시행규칙」 제29조 제3항에 따라 직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰두어야 합니다.

관계법령

전기안전관리법

제22조(전기안전관리자의 선임 등) ① 전기사업자나 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 전기설비(휴지 중인 전기설비는 제외한다)의 공사·유지 및 운용에 관한 전기안전관리업무를 수행하게 하기 위하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 「국가기술자격법」에 따른 전기·기계·토목 분야의 기술자격을 취득한 사람 중에서 각 분야별로 전기안전관리자를 선임하여야 한다.

② ~ ④ (생 략)

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 전기안전관리자를 선임한 자는 전기안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우에는 그 기간 동안, 전기안전관리자를 해임한 경우에는 다른 전기안전관리자를 선임하기 전까지 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 대행자를 각각 지정하여야 한다.

⑥ ~ ⑧ (생 략)

5) 법제처 2023. 9. 7. 회신 23-0427 해석례 참조

전기안전관리법 시행규칙

제29조(전기안전관리자의 직무대행자의 지정요건) ① 법 제22조제5항에 따라 지정되는 전기안전관리자의 직무대행자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 「국가기술자격법」에 따른 전기·토목·기계 분야 기능사 이상의 자격소지자
2. 「초·중등교육법」 제2조제3호에 따른 고등학교의 전기·토목·기계 관련 학과 졸업 이상의 학력을 갖춘 후 해당 분야에서 1년 이상의 실무경력이 있는 사람
3. 해당 전기설비의 일상적인 운용을 위한 운전·조작 또는 이에 대한 업무의 감독이 가능한 사람

② 법 제22조제5항에 따라 전기안전관리자의 직무대행자로 지정된 사람은 전기설비의 안전관리를 위한 확인과 전기설비의 일상적인 운용을 위한 운전·조작 또는 이에 대한 감독업무를 수행한다.

③ 법 제22조제5항에 따라 전기안전관리자의 직무대행자를 지정한 자는 별지 제14호서식의 전기안전관리자의 직무대행자 지정서를 작성하여 갖춰두어야 한다.

④ 법 제22조제5항에 따라 지정된 전기안전관리자의 직무대행자의 직무대행기간은 30일을 초과할 수 없다.

[별지 제14호서식]

전기안전관리자의 직무대행자 지정서

접수번호		접수일자		처리기간	3일
지정인	대표자 성명		전화번호		
	회사명 또는 상호				
	주소 또는 소재지				

전기설비					
	수전설비	용량	㎾	전압	V
	발전설비	상용	㎾	전압	V
		비상용	㎾	전압	V

구 분	성명	소속 및 직책	기술자격사항	근무연수	비 고
전기안전관리자					
직무대행자					
직무대행기간					
직무대행사유					

「전기안전관리법」제22조제5항 및 같은 법 시행규칙 제29조제3항에 따라 전기안전관리자의 직무를 대행하는 자를 위와 같이 지정합니다.

년 월 일

지정인 (서명 또는 인)

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-1144, 23-1001, 23-1002

민원인 – 고압가스 “접합 또는 납붙임용기”의 상세기준에 적합하면 “재충전 금지용기”의 제조에 필요한 시설 및 기술기준에 적합한 것으로 볼 수 있는지 여부(「고압가스 안전관리법」 제22조의2 제4항 등 관련)

01 질의요지

「고압가스 안전관리법」(이하 “고압가스법”이라 함) 제22조의2제1항제2호에서는 같은 법 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회(이하 “가스기술기준위원회”라 함)는 같은 법 제5조제2항에 따른 용기등[6]의 제조에 필요한 시설기준과 기술기준의 범위에서 그 기준을 충족하는 상세한 규격, 특정한 수치 및 특정한 시험방법 등을 세부적으로 규정한 기준(이하 “상세기준”이라 함)을 정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 상세기준에 적합하면 같은 조 제1항 각 호의 기준 중 그 상세기준이 해당하는 기준에 적합한 것으로 본다고 규정하고 있는바,

고압가스법 시행규칙 제2조제1항제26호에 따른 접합 또는 납붙임용기의 상세기준[KGS AC311(고압가스용 납붙임 또는 접합용기 제조의 시설·기술·검사 기준)을 말하며, 이하 “접합 또는 납붙임용기 상세기준”이라 함]에 적합하게 제조된 용기인 경우, 해당 용기는 고압가스법 제5조제2항에 따른 용기등의 제조에 필요한 시설기준과 기술기준 중 재충전 금지용기(같은 규칙 별표 10 제2호카목에 따른 재충전 금지용기를 말하며, 이하 “재충전 금지용기”라 함)의 제조에 필요한 ①시설기준 및 ②기술기준에도 적합한 것으로 볼 수 있는지?

02 회답

접합 또는 납붙임용기 상세기준에 적합하게 제조된 용기라도 고압가스법 제5조제2항에 따른 재충전 금지용기의 제조에 필요한 시설기준 및 기술기준에 적합한 것으로 볼 수는 없습니다.

6) 고압가스법 제3조제2호에 따른 용기, 제4호에 따른 냉동기 및 제5호에 따른 특정설비를 말하며, 이하 같음.

03 이유

먼저 고압가스법 제5조제2항에서는 용기등의 제조에 필요한 시설기준과 기술기준은 산업통상자원부령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제9조제1호에서는 “용기 제조의 시설기준과 기술기준”은 별표 10과 같다고 규정하고 있으며, 같은 규칙 별표 10 제1호에서는 용기를 제조하려는 자에게 적용되는 시설기준을 규정하고 있고, 같은 표 제2호에서는 가목부터 아목까지에서는 모든 용기의 제조에 필요한 기술기준을, 같은 호 자목(복합재료용기), 차목(아세틸렌충전용 용기), 카목(재충전 금지용기) 및 타목(이동식 부탄연소기용 접합용기)에서는 각각 특정 용기의 제조에 필요한 기술기준을 정하고 있는 한편, 같은 법 제22조의2제1항제2호에 따라 가스기술기준위원회는 고압가스법 시행규칙 제2조제1항제26호에 따른 “접합 또는 납붙임용기”에 대한 상세기준과 “재충전 금지용기”에 대한 상세기준[KGS AC216(고압가스용 재충전 금지 용기 제조의 시설·기술·검사 기준)을 말하며, 이하 “재충전 금지용기 상세기준”이라 함]을 별도로 구분하여 정하면서, 각각의 상세기준에서 제조설비 및 검사설비 등 해당 용기의 “제조시설 기준”과 용기의 설계, 재료, 두께, 구조 및 치수 등 해당 용기의 “제조기술 기준”을 구체적으로 규정하고 있는바, 각각의 상세기준에서는 접합 또는 납붙임용기의 상세기준에 적합하면 재충전 금지용기의 상세기준에 적합한 것으로 본다는 등의 규정이 없고, 접합 또는 납붙임용기의 상세기준에 적합하면 법 제22조의2제4항에 따라 접합 또는 납붙임용기의 상세기준에 해당하는 시설기준 및 기술기준에 적합한 것으로 보아야 하는바, 각 용기의 종류별로 그 용기에 관한 상세기준에 적합한 경우에는 해당 용기의 제조에 필요한 시설기준 및 기술기준에만 적합하다고 보는 것이 고압가스법령의 문언 및 규정체계에 부합하는 해석입니다.

한편 고압가스법 시행규칙 제2조제1항제26호에서 “접합 또는 납붙임용기”는 동판 및 경판을 각각 성형하여 심(Seam)용접이나 그 밖의 방법으로 접합하거나 납붙임하여 만든 내용적(內容積) 1리터 이하인 1회용 용기를 말한다고 규정하고 있고, “재충전 금지용기 상세기준” 1.4.1에서 “재충전 금지용기”는 최초 충전 후 1회 사용으로 내용 연한이 끝나 파기해야 하는 용기(부속품과 일체로 제조된 것을 말함)를 말한다고 규정하고 있는데, 두 용기 모두 1회용 용기라는 성질이 유사하므로 접합 또는 납붙임용기의 상세기준에 적합하면 재충전 금지용기의 제조에 필요한 시설기준 및 기술기준에도 적합한 것으로 보아야 한다는 의견이 있습니다.

그러나 “재충전 금지용기 상세기준” 3.6.1.에서 알루미늄 합금제 이음매 없는 구조의 재충전

금지용기는 밑면 접합으로 제조하지 않도록 규정하고 있고, 같은 상세기준 3.6.2.에서 알루미늄 합금제 재충전 금지용기는 납붙임을 사용하지 않는다고 규정하고 있는 등 재충전 금지용기와 접합 또는 납붙임용기는 제조방법이 서로 구분되며, "접합 또는 납붙임용기 상세기준" 1.4.1.에 따르면 "접합 또는 납붙임용기"는 내용적이 1리터 이하로 제한되고 에어졸 제조용, 라이터 충전용, 연료용 가스용, 절단용 또는 용접용으로 사용목적이 정해져 있는 용기이고, "재충전 금지용기"는 고압가스법 시행규칙 별표 10 제2호카목에 따라 내용적 25리터까지 제조가 가능하고 특별한 사용목적이 규정되지 않은 용기로서, "접합 또는 납붙임용기"와 "재충전 금지용기"는 제조방법, 최대 용량 등이 서로 다른 별개의 용기라고 할 것이므로, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 접합 또는 납붙임용기 상세기준에 적합하게 제조된 용기라도 고압가스법 제5조 제2항에 따른 재충전 금지용기의 제조에 필요한 시설기준 및 기술기준에 적합한 것으로 볼 수는 없습니다.

관계법령

고압가스 안전관리법

제5조(용기·냉동기 및 특정설비의 제조등록 등) ① 용기·냉동기 또는 특정설비(이하 "용기등"이라 한다)를 제조하려는 자는 시장·군수 또는 구청장에게 등록하여야 한다. 등록한 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따른 등록의 기준과 대상범위는 대통령령으로 정하고, 용기등의 제조에 필요한 시설기준과 기술기준은 산업통상자원부령으로 정한다.

③ ~ ⑥ (생 략)

제22조의2(상세기준) ① 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기준의 범위에서 그 기준을 충족하는 상세한 규격, 특정한 수치 및 특정한 시험방법 등을 세부적으로 규정한 기준(이하 "상세기준"이라 한다)을 정할 수 있다.

1. (생 략)
2. 제5조제2항에 따른 용기등의 제조에 필요한 시설기준과 기술기준
3. ~ 14. (생 략)

② 상세기준은 제1항에 따른 가스기술기준위원회의 심의·의결을 거쳐 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다.

③ 제1항에 따른 가스기술기준위원회는 제2항에 따라 승인을 받은 경우 그 상세기준의 내용을 지체 없이 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 일반인에게 알려야 하고, 산업통상자원부장관은 그 승인사실을 관보에 공고하여야 한다.

④ 상세기준에 적합하면 제1항 각 호의 기준 중 그 상세기준이 해당하는 기준에 적합한 것으로 본다.
⑤ (생 략)

고압가스 안전관리법 시행규칙

제2조(정의) ① 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. ~ 11. (생 략)
12. "초저온용기"란 섭씨 영하 50도 이하의 액화가스를 충전하기 위한 용기로서 단열재를 씌우거나 냉동설비로 냉각시키는 등의 방법으로 용기 내의 가스온도가 상용 온도를 초과하지 아니하도록 한 것을 말한다.
13. ~ 23. (생 략)
24. "용접용기"란 동판 및 경판(동체의 양 끝부분에 부착하는 판을 말한다. 이하 같다)을 각각 성형하고 용접하여 제조한 용기를 말한다.
25. "이음매 없는 용기"란 동판 및 경판을 일체(一體)로 성형하여 이음매가 없이 제조한 용기를 말한다.
26. "접합 또는 납붙임용기"란 동판 및 경판을 각각 성형하여 심(Seam)용접이나 그 밖의 방법으로 접합하거나 납붙임하여 만든 내용적(內容積) 1리터 이하인 일회용 용기를 말한다.
27. ~ 29. (생 략)
② ~ ⑤ (생 략)

제9조(용기등의 제조시설기준 및 제조기술기준) 법 제5조제2항 및 법 제5조의2제3항에 따른 용기 등의 제조에 필요한 시설기준 및 기술기준은 다음 각 호와 같다.
1. 용기 제조의 시설기준과 기술기준 : 별표 10
2. ~ 4. (생 략)

[별표 10]

용기 제조의 시설·기술·검사기준과 용기의 재검사기준

(제9조제1호, 제9조의2제3항, 제28조제4항제6호, 제43조제1항제1호 및 제44조제2항 관련)

1. 시설기준

가. 용기를 제조하려는 자는 이 별표의 기술기준에 따라 용기를 제조하기 위하여 필요한 제조설비를 갖출 것. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토 결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 않을 수 있다.
나. 용기를 제조하려는 자는 이 별표의 검사기준에 따라 용기를 검사하기 위하여 필요한 검사설비를 갖출 것

2. 기술기준

가. 용기의 재료는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 충전하는 고압가스의 종류·압력·온도 및

사용환경에 적절한 것일 것

나. 용기의 두께는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 그 용기에 사용한 재료, 충전하는 고압가스의 종류·압력·온도 및 사용환경에 적합한 것일 것

다. 용기의 구조는 그 용기의 안전성 및 편리성을 확보하기 위하여 충전하는 고압가스의 종류·압력·온도 및 사용환경에 적절한 것일 것

라. 용기의 치수는 그 용기의 안전성 및 호환성을 확보하기 위하여 필요한 경우 그 용기의 재료, 충전하는 고압가스의 종류·충전압력·온도 및 사용환경에 적절한 것일 것

마. 용기의 용접은 그 용기 이음매의 기계적 강도를 확보하기 위하여 필요한 경우 그 용기의 재료 및 구조에 따라 적절한 방법으로 할 것

바. 용기의 열처리는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 필요한 경우 그 용기의 재료 및 두께에 따라 적절한 방법으로 할 것

사. 용기에는 그 용기의 부식을 방지하기 위하여 필요한 경우 적절한 부식방지 조치를 할 것

아. 용기에는 그 용기의 부속품을 보호하기 위하여 적절한 부속장치를 부착할 것

자. 복합재료용기는 그 용기의 안전을 확보하기 위하여 그 용기에 충전하는 고압가스의 종류 및 압력을 다음과 같이 할 것

1) 충전하는 고압가스는 가연성인 액화가스가 아닐 것

2) 최고충전압력은 35㎫(산소용은 20㎫) 이하일 것

차. 아세틸렌충전용 용기는 그 용기의 안전을 확보하기 위하여 그 용기에 충전하는 다공질물 및 용해제는 아세틸렌의 분해폭발을 방지할 수 있도록 적절한 품질·충전량 및 다공도를 갖는 것일 것

카. 재충전 금지용기는 그 용기의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합하게 할 것

1) 용기와 용기부속품을 분리할 수 없는 구조일 것

2) 최고충전압력(㎫)의 수치와 내용적(L)의 수치를 곱한 값이 100 이하일 것

3) 최고충전압력이 22.5㎫ 이하이고 내용적이 25L 이하일 것

4) 최고충전압력이 3.5㎫ 이상인 경우에는 내용적이 5L 이하일 것

5) 가연성가스 및 독성가스를 충전하는 것이 아닐 것

타. 이동식 부탄연소기용 접합용기는 그 용기의 안전을 확보하기 위하여 압력방출기능을 갖는 구조일 것

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0008, 23-1144

경기도 포천시 – 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의5제3호에 따른 "공장설립등의 승인을 받은 후 4년이 지난 날"의 기산점(「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의5 등 관련)

01 질의요지

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 "산업집적법") 제13조제1항 본문에서는 공장건축면적이 500제곱미터 이상인 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 "공장설립등"이라 함)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장(이하 "시장등"이라 함)의 승인을 받아야 하며, 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다고 규정하고 있는 한편,

산업집적법 제13조의5 각 호 외의 부분 본문 및 같은 조 제3호에서는 시장등은 같은 법 제13조에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자가 공장설립등의 승인을 받은 후 4년이 지난 날까지 같은 법 제15조제1항에 따른 완료신고(이하 "공장설립등완료신고"라 함)를 하지 아니한 사유로 사업시행이 곤란하다고 인정하는 경우에는 그 공장설립등의 승인의 취소를 명할 수 있다고 규정하고 있는바,

산업집적법 제13조제1항 본문에 따라 최초로 공장설립등의 승인(이하 "최초승인"이라 함)을 받은 후 그 승인을 받은 사항을 변경하기 위한 승인(이하 "변경승인"이라 함)을 받은 경우, 같은 법 제13조의5제3호에 따른 '공장설립등의 승인을 받은 후 4년이 지난 날'은 '최초승인을 받은 후 4년이 지난 날'로 보아야 하는지, 아니면 '변경승인을 받은 후 4년이 지난 날'로 보아야 하는지?

02 회답

산업집적법 제13조제1항 본문에 따라 최초승인을 받은 후 변경승인을 받은 경우, 같은 법 제13조의5제3호에 따른 '공장설립등의 승인을 받은 후 4년이 지난 날'은 '변경승인을 받은 후 4년이 지난 날'로 보아야 합니다.

03 이유

먼저 산업집적법 제13조제1항 본문에서는 공장설립등을 하려는 경우와 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우 모두 시장등의 '승인'을 받아야 한다고 규정하고 있을 뿐, '최초승인'과 '변경승인'의 개념을 별도로 구분하여 규정하고 있지 아니하고, 같은 법 제13조의2제1항에서는 "제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인"을 할 때 시장등이 관계 행정기관의 장과 협의한 사항에 대하여는 해당 인·허가등[7]을 받은 것으로 본다고 규정하고 있는데, 이러한 인·허가등의 의제는 공장설립등의 '최초승인' 시뿐만 아니라, 그 승인받은 사항을 변경하는 '변경승인' 시에도 적용되는 규정이라는 점[8], 같은 법 제15조제1항에서는 "제13조제1항에 따른 공장설립등의 승인"을 받은 자가 공장건설을 완료하였을 때에는 공장설립등완료신고를 해야 한다고 규정하고 있는데, 이 사안과 같이 '최초승인' 후 '변경승인'을 받은 경우라면 '공장건설을 완료하였을 때'는 '변경승인'을 받은 내용대로 공장건설을 완료하였을 때를 의미한다는 점 등을 고려하면, 같은 법 제13조의5제3호에 따른 "공장설립등의 승인"에는 '변경승인'이 포함된다고 보는 것이 그 문언 및 산업집적법의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

그리고 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용해야 하고, 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다고 할 것[9]인데, 침익적 행정행위로서 공장설립등의 승인의 취소 요건을 규정하고 있는 산업집적법 제13조의5 각 호 외의 부분 본문에서는 공장설립등의 승인을 취소할 수 있는 경우를 "제13조에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 사업시행이 곤란하다고 인정하는 경우"로 규정하고 있을 뿐, "공장설립등"의 의미를 '최초승인'으로 한정하고 있지 않으므로, 이 사안과 같이 최초승인을 받은 후에 변경승인을 받은 경우라면 같은 법 제13조의5제3호에 따른 '공장설립등의 승인을 받은 후 4년이 지난 날'은 처분 상대방에게 불리한 '최초승인을 받은 후 4년이 지난 날'이 아닌 '변경승인을 받은 후 4년이 지난 날'로 보는 것이 타당할 것입니다.

또한 산업집적법 시행규칙 제7조제1항에서는 산업집적법 제13조제1항 본문에서 "승인을 받은 사항을 변경하려는 경우"란 공장부지면적의 변경(제1호), 공장건축면적의 변경(제2호), 부대시설면적의 변경(제3호)을 하려는 경우를 말한다고 규정하면서, 각각 승인받은 면적이

7) 산업집적법 제13조의2제1항 각 호의 어느 하에 해당하는 허가·신고·면허·승인·해제 또는 용도폐지 등을 말함.

8) 「행정기본법」 제26조제2항에서는 인허가의제의 사후관리 등과 관련하여 주된 인허가가 있은 후 이를 변경하는 경우에는 같은 법 제24조·제25조 및 제26조제1항을 준용하도록 규정하여 주된 인허가를 변경하는 경우에도 인허가의제의 절차와 효과 등이 준용되도록 규정하고 있음.

9) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

감소하거나 기준공장면적률[10]에 적합한 범위에서의 변경 등은 제외한다고 규정하여, 같은 법 제13조제1항 본문에 따른 '변경승인'을 받게 되면 공장부지면적, 공장건축면적 등이 증가될 가능성이 크다고 할 것인데, 이 사안과 같이 산업집적법 제13조제1항 본문에 따라 최초승인을 받은 후 변경승인을 받은 경우에 대해서도 같은 법 제13조의5제3호의 '공장 설립등의 승인을 받은 후 4년이 지난 날'을 '최초승인을 받은 후 4년이 지난 날'로 해석하게 되면, 변경승인을 통해 공장건축면적 등이 증가되어 공장 설립에 소요되는 기간이 불가피하게 증가되는 경우에도 변경승인을 받지 않은 경우와 동일하게 최초승인일을 기준으로 4년이 지난 날까지 공장설립등완료신고를 하지 아니하였다는 사유로 공장설립등의 승인을 취소할 수 있게 되는 불합리한 결과가 초래됩니다.

따라서 산업집적법 제13조제1항 본문에 따라 최초승인을 받은 후 변경승인을 받은 경우, 같은 법 제13조의5제3호에 따른 '공장설립등의 승인을 받은 후 4년이 지난 날'은 '변경승인을 받은 후 4년이 지난 날'로 보아야 합니다.

관계법령

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률

제13조(공장설립등의 승인) ① 공장건축면적이 500제곱미터 이상인 공장의 신설·증설 또는 업종변경(이하 "공장설립등"이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 승인을 받아야 하며, 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 승인을 받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여야 한다.

② ~ ⑦ (생 략)

제13조의5(공장설립등의 승인의 취소) 시장·군수 또는 구청장은 제13조에 따라 공장설립등의 승인을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 사업시행이 곤란하다고 인정하는 경우에는 그 공장설립등의 승인의 취소 및 해당 토지의 원상회복을 명할 수 있으며, 이 경우 원상회복에 관하여는 「농지법」 제42조 및 「산지관리법」 제39조를 준용한다. 다만, 제3호에 따른 기간을 초과하는 것이 부득이하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1.·2. (생 략)

3. 공장설립등의 승인 및 제14조의3에 따른 제조시설의 설치승인을 받은 후 4년이 지난 날까지 제15조제1항에 따른 완료신고를 하지 아니하거나 공장착공 후 1년 이상 공사를 중단한 경우

4.·5. (생 략)

10) 산업집적법 제8조에 따른 기준공장면적률(제조업종별 공장부지면적에 대한 같은 법 시행령 제12조제3항에 따른 공장건축물등의 면적의 비율)을 말함

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0008

민원인 – 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 별표 제1호다목에 따른 과태료 부과 예외 대상에 오피스텔도 포함되는지 여부(「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 별표 등 관련)

01 질의요지

「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」(이하 "친환경자동차법 시행령"이라 함) 별표 제1호다목1) 및 2) 외의 부분에서 "부과권자는 아파트에 설치된 전용 주차구역[11]의 수량이 해당 아파트의 입주자등[12]의 전기자동차 및 외부충전식 하이브리드 자동차(이하 "전기자동차등"이라 함)의 수량과 동일하거나 초과하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 규정에서 정한 과태료를 부과하지 않을 수 있다"고 규정하고 있고, 같은 목 1)에서는 "아파트 관리주체 등(「공동주택관리법」에 따른 관리주체, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제23조에 따른 관리단 및 같은 법 제24조에 따른 관리인을 말한다. 이하 "관리주체등"이라 한다)이 초과수량의 범위에서 전기자동차등이 아닌 자동차의 주차가 가능한 것으로 표시한 구역에 주차한 경우 제2호가목의 과태료"를, 같은 목 2)에서는 "아파트 관리주체등이 입주자등의 전기자동차 및 외부충전식하이브리드자동차의 수량의 범위에서 제18조의8제1항제6호 또는 제7호에 따른 산업통상자원부장관이 고시한 시간이 지난 후에도 전기자동차 또는 외부충전식하이브리드자동차를 주차할 수 있다고 표시한 구역에 계속 주차한 경우 제2호나목의 과태료"를 각각 규정하고 있는바,

「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」(이하 "집합건물법"이라 함) 제23조에 따른 관리단 또는 같은 법 제24조에 따른 관리인을 통해 관리되는 집합건물로서 오피스텔[13]의 경우 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목에 따라 과태료를 부과하지 않을 수 있는 대상 시설에 포함되는지?

---

11) 환경친화적 자동차 충전시설이 설치된 것으로 한정하며, 이하 같음.

12) 「공동주택관리법」에 따른 입주자등을 말하며, 이하 같음.

13) 「건축법 시행령」 별표 1 제14호에 따른 업무시설 중 같은 호 나목2)에 따른 오피스텔을 말하며, 이하 같음.

02 회답

이 사안 오피스텔의 경우 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목에 따라 과태료를 부과하지 않을 수 있는 대상 시설에 포함되지 않습니다.

03 이유

먼저 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」(이하 "친환경자동차법"이라 함) 제16조에서는 같은 법 제11조의2제9항을 위반하여 충전 방해행위를 하거나(제1항) 같은 법 제11조의2제7항 및 제8항을 위반하여 환경친화적 자동차 충전시설의 충전구역 및 전용주차구역에 주차를 한 자(제2항)(이하 "충전방해행위등을 한 자"라 함)에 대해 과태료를 부과한다고 규정하고 있고, 같은 법 제16조제3항의 위임에 따라 과태료의 부과기준을 정하고 있는 같은 법 시행령 별표에서는 과태료 부과의 개별기준으로서 위반행위에 따른 과태료의 금액(제2호)과 이를 가중·감경할 수 있는 일반기준(제1호)을 정하면서, 같은 표 제1호다목1) 및 2) 외의 부분에서 부과권자는 '아파트에 설치된 전용주차구역의 수량이 해당 아파트의 입주자등의 전기자동차등의 수량과 동일하거나 초과하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우'에는 같은 표 제2호에서 정하는 과태료를 부과하지 않을 수 있다고 규정하여 과태료를 부과하지 않을 수 있는 대상 시설을 '아파트'로 명시하고 있는데, 이 때 '아파트'의 의미나 범위에 대해 해당 규정에서 별도로 규정하고 있지는 않습니다.

그런데 친환경자동차법 제11조의2제1항의 위임에 따라 '환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역을 의무적으로 설치해야 하는 시설'을 규정하고 있는 같은 법 시행령 제18조의5 제1호 및 제2호에서는 '「건축법 시행령」 제3조의5 및 별표 1에 따른 용도별 건축물'의 구분에 따라 각 시설을 열거하여 규정하면서, '「건축법 시행령」 제3조의5 및 별표 1에 따른 용도별 건축물 중 업무시설(제1호자목)'과 '「건축법 시행령」 제3조의5 및 별표 1 제2호에 따른 공동주택 중 100세대 이상의 아파트(제2호가목)'를 각각 구분하여 규정하고 있는 체계에 비추어 볼 때, 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목1) 및 2) 외의 부분의 "아파트"는 '「건축법 시행령」 제3조의5 및 별표 1에 따른 용도별 건축물'의 구분에 따른 아파트를 의미한다고 보아야 할 것이고, 그에 따라 같은 목 1) 및 2)에서 규정하고 있는 '아파트 관리주체등'의 의미도 '아파트의 관리주체등'으로 한정되는 것으로 해석되며, "오피스텔"의 경우에는 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 용도별 건축물 구분상 아파트와는 구분되는 업무시설에 해당[같은 표

제14호나목2)]하므로, "오피스텔"은 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목에 따라 과태료를 부과하지 않을 수 있는 대상 시설에 해당하지 않는다고 할 것입니다.

더욱이 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목에서 일정 요건을 갖춘 아파트에 설치된 전용주차구역인 경우에 대해서만 충전방해행위등을 한 자에 대해 과태료를 부과하지 않을 수 있도록 규정한 취지는, 아파트의 경우 충전시설이 입주자 등의 전기차등의 총수보다 많은 경우 입주민 간의 주차분쟁의 우려가 제기[14]되어 아파트에 설치된 충전시설 보유 전용주차구역의 수가 입주자 등의 전기자동차등의 수량을 초과하는 경우로서 아파트의 관리주체 등이 그 초과수량의 범위에서 전기자동차등이 아닌 자동차의 주차가 가능한 것으로 표시한 구역에 주차한 경우 등에는 과태료를 부과하지 않을 수 있도록 하여 환경친화적 자동차 보급 현황과 연계하여 과태료 부과 여부를 결정할 수 있도록 하기 위한 것[15]인바, 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목의 규정은 전용주차구역 설치 대상 시설이 아파트인 경우로 한정하여 적용된다고 보는 것이 이러한 입법취지에 부합하는 해석입니다.

한편 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목1) 및 2)에서는 충전방해행위등을 한 자에 대하여 과태료를 부과하지 않을 수 있는 요건으로 '아파트 관리주체등'이 일정한 표시를 한 전용주차구역에 주차한 경우를 규정하면서, '아파트 관리주체등'을 「공동주택관리법」에 따른 관리주체, 집합건물법 제23조에 따른 관리단 및 같은 법 제24조에 따른 관리인으로 규정하고 있는바, 오피스텔이 집합건물로서 집합건물법 제23조에 따른 관리단 또는 같은 법 제24조에 따른 관리인을 통해 관리되는 경우 그 관리단 및 관리인은 '아파트 관리주체등'에 포함되므로, 오피스텔도 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목에 따라 과태료를 부과하지 않을 수 있는 대상 시설에 해당한다는 의견이 있습니다.

그러나 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목의 규정체계상 같은 목 1) 및 2)에 규정된 '아파트 관리주체등'의 의미는 같은 목 1) 및 2) 외의 부분에서 과태료를 부과하지 않을 수 있는 대상 시설로 규정하고 있는 '아파트의 관리주체등'을 의미하는 것으로 해석해야 할 것인 점, 같은 목 1)에서 "관리주체 등" 뒤에 괄호를 두어 '「공동주택관리법」에 따른 관리주체, 집합건물법 제23조에 따른 관리단 및 같은 법 제24조에 따른 관리인'을 말한다고 규정한 것은, 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트 중 「공동주택관리법」에 따른 의무관리대상 공동주택으로서의 아파트[16]와 의무관리대상 공동주택이 아닌 아파트로서 집합건물법이

14) 구 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령(2022. 1. 25. 대통령령 제32361호로 개정되어 2022. 1. 28. 시행된 것을 말함) 조문별 개정이유서 참조.

15) 구 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령(2022. 1. 25. 대통령령 제32361호로 개정되어 2022. 1. 28. 시행된 것을 말함) 개정이유 참조.

적용되는 아파트[17]의 관리주체를 포괄하기 위해 관련 근거 규정을 모두 명시한 것[18]이지, 집합건물법에 따른 오피스텔 등 관리단 또는 관리인을 통해 관리되는 모든 집합건물에 대하여 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목을 적용하기 위한 것은 아니라고 할 것인바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안 오피스텔의 경우 친환경자동차법 시행령 별표 제1호다목에 따라 과태료를 부과하지 않을 수 있는 대상 시설에 포함되지 않습니다.

관계법령

환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령

제21조(과태료의 부과기준) 법 제16조제1항 및 제2항에 따른 과태료의 부과기준은 별표와 같다.

[별표]

과태료의 부과기준(제21조 관련)

1. 일반기준

가.·나. (생 략)

다. 부과권자는 아파트에 설치된 전용주차구역(환경친화적 자동차 충전시설이 설치된 것으로 한정한다)의 수량이 해당 아파트의 입주자등(「공동주택관리법」에 따른 입주자등을 말한다. 이하 같다)의 전기자동차 및 외부충전식하이브리드자동차의 수량과 동일하거나 초과하는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 규정에서 정한 과태료를 부과하지 않을 수 있다.

1) 아파트 관리주체 등(「공동주택관리법」에 따른 관리주체, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제23조에 따른 관리단 및 같은 법 제24조에 따른 관리인을 말한다. 이하 "관리주체등"이라 한다)이 초과수량의 범위에서 전기자동차 또는 외부충전식하이브리드자동차가 아닌 자동차의 주차가 가능한 것으로 표시한 구역에 주차한 경우: 제2호가목의 과태료

2) 아파트 관리주체등이 입주자등의 전기자동차 및 외부충전식하이브리드자동차의 수량의 범위에서 제18조의8제1항제6호 또는 제7호에 따른 산업통상자원부장관이 고시한 시간이

16) 「공동주택관리법」 제2조제1항제1호가목, 같은 항 제2호, 「주택법」 제2조제3호 및 같은 법 시행령 제3조제1항제1호 등 참조

17) 아파트 건물에 대하여 구분소유 관계가 성립되면 집합건물법 제23조제1항에 따른 관리단이 설립되고, 구분소유자가 10인 이상일 때에는 같은 법 제24조제1항에 따른 관리인을 선임하여야 하며, 아파트가 의무관리대상 공동주택으로 전환하기 전에도 관리인이 집합건물의 관리에 관한 업무를 수행함.

18) 서울고등법원 2019. 4. 17. 선고 2018나2059428 판결례 참조

지난 후에도 전기자동차 또는 외부충전식하이브리드자동차를 주차할 수 있다고 표시한 구역에 계속 주차한 경우: 제2호나목의 과태료

2. (생 략)

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0141, 24-0540

국토교통부 – 일반물류단지개발사업의 시행자를 변경하기 위하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」에 따라 수립·승인한 물류단지계획을 같은 법에 따라 변경하려는 경우, 주민 등 의견청취를 반드시 거쳐야 하는지 여부 등(「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제59조의2 등 관련)

01 질의요지

「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」(이하 "물류시설법"이라 함) 제59조의2에 따라 준용되는 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」(이하 "산단절차간소화법"이라 함)[19] 제8조제2항에 따라 '물류단지를 지정하는 자[20] 외의 자'가 물류단지계획을 수립하고 시·도지사에게 승인을 신청하여 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조제1항에 따라 물류단지계획이 승인된 경우[21]로서, 시·도지사가 일반물류단지개발사업의 시행자를 변경하기 위하여 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2에 따라 물류단지계획을 변경하려는 경우[22],

가. 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제1항 단서에 따라 주민 등의 의견청취 절차를 생략할 수 있는지?

나. 물류시설법 제22조제3항에 따른 지역물류정책위원회의 심의를 거치지 않고 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제2항에 따라 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제14조에 따른 심의위원회인 지방물류단지계획심의위원회[23]의 심의를 거칠 수 있는지?

---

19) 물류시설법 제59조의2제2항에서 물류단지 지정 및 개발절차에 대하여 산단절차간소화법을 준용하는 경우, "산업단지"는 "물류단지"로, "산업단지계획"은 "물류단지계획"으로, "산업입지정책심의위원회"는 "「물류정책기본법」 제20조에 따른 지역물류정책위원회"로 본다고 규정하고 있는바, 이하 산단절차간소화법의 규정을 기재할 때에는 물류시설법 제59조의2에 따라 물류시설법에 따른 용어로 대체하여 기재함

20) 물류시설법 제22조 또는 제22조의2에 따라 물류단지를 지정하는 자를 말함.

21) 산단절차간소화법 제3조 단서 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 규모 이상의 물류단지를 제외한 경우를 전제함

22) 이 사안의 경우, 산단절차간소화법에 따라 수립된 물류단지계획을 산단절차간소화법에 따라 변경하려는 경우임을 전제함

23) 물류시설법 제59조의2제2항에서 물류단지 지정 및 개발절차에 대하여 산단절차간소화법을 준용하는 경우, "산업단지계획"은 "물류단지계획"으로 본다고 규정하고 있는바, 산단절차간소화법 제14조에 따른 "지방산업단지계획심의위원회"는 "지방물류단지계획심의위원회"로 봄

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제1항 단서에 따라 주민 등의 의견청취 절차를 생략할 수 있습니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 물류시설법 제22조제3항에 따른 지역물류정책위원회의 심의를 거치지 않고 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제2항에 따라 지방물류단지계획심의위원회의 심의를 거칠 수 있습니다.

03 이유

가. 질의 가 및 질의 나의 공통사항

물류시설법 제22조제3항 전단에서는 시·도지사는 일반물류단지를 지정하려는 때에는 일반물류단지개발계획을 수립하여 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지역물류정책위원회의 심의를 거쳐야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 후단 및 같은 법 시행령 제13조제2항제4호에서는 일반물류단지개발계획 중 중요 사항인 '일반물류단지개발사업 시행자를 변경'하려는 때에도 또한 같다고 규정하고 있으며, 같은 법 제24조제1항 본문에서는 물류단지지정권자는 물류단지를 지정하려는 때에는 주민 및 관계 전문가의 의견을 들어야 하고 타당하다고 인정하는 때에는 그 의견을 반영하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 단서 및 같은 법 시행령 제17조제4항에서는 국방상 기밀사항이거나 물류단지지정 면적의 변경(10분의 1 미만의 면적을 변경하는 경우만 해당함), 물류단지시설용지 면적의 변경(10분의 1 미만의 면적을 변경하는 경우만 해당함) 또는 물류단지시설용지의 용도변경, 기반시설의 부지 면적의 변경(10분의 1 미만의 면적을 변경하는 경우만 해당함) 또는 그 시설의 위치 변경 등 경미한 사항인 경우에는 의견 청취를 생략할 수 있다고 규정하고 있는바, 물류시설법령에 따르면 "일반물류단지개발사업 시행자의 변경"은 주민 등 의견청취를 생략할 수 있는 경미한 사항에 포함되지 않습니다.

한편 물류시설법 제59조의2에서는 물류단지 지정 및 개발절차에 관하여 산단절차간 소화법을 준용한다고 규정하면서(제1항), 산단절차간소화법을 준용하는 경우 "산업단지"는 "물류단지"로, "산업단지계획"은 "물류단지계획"으로, "지방산업단지계획심의위원회"는 "지방물류단지계획심의위원회"로, "산업입지정책심의위원회"는 "「물류정책기본법」 제20조에 따른 지역물류정책위원회" 등으로 본다고 규정하고 있는데(제2항), 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제8조제1항에서는 지정권자는 '사업시행자의 주소 및 성명' 등이 포함된 물류단지계획을 수립하여야 하며, 물류단지계획이 수립된 경우 물류시설법에 따른 개발계획 및 실시계획이 모두 수립된 것으로 본다고 규정하고 있어, 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법에 따르면 일반물류단지의 시행자를 변경하기 위해서는 물류단지계획을 변경하도록 하고 있습니다.

그리고 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제9조에서는 지정권자는 물류단지계획을 수립하려고 하거나 물류단지계획의 승인신청을 받은 경우에는 일간신문 및 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하고, 공고일부터 20일 이상 일반인이 열람하도록 하여야 하는 등 주민 등의 의견청취에 관하여 규정하고 있고, 같은 법 제14조제1항에서는 같은 법 제8조에 따른 물류단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 시·도지사는 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제15조의2제1항 본문에서는 지정권자[24]가 수립·승인된 물류단지계획을 변경하는 경우에는 같은 법 제9조 및 제14조 등을 준용한다고 규정하면서, 같은 법 제15조의2제1항 단서 및 같은 법 시행령 제10조에서는 '물류단지면적의 100분의 10 이상의 면적변경, 주요 유치업종의 변경, 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경을 제외한 사항을 변경하려는 경우'에는 같은 법 제9조에 따른 주민 등의 의견청취를 생략할 수 있으며, 같은 법 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거치지 아니한다고 규정하고 있는바, 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법에 따르면 "일반물류단지개발사업 시행자의 변경"은 물류단지계획의 경미한 사항을 변경하려는 경우에 해당합니다.

나. 질의 가에 대해

먼저 물류시설법 제59조의2에 따라 물류단지 개발절차에 산단절차간소화법이 준용되고, 산단절차간소화법 제4조제1항 본문에서는 산단절차간소화법은 물류단지의 지정 및 개발에 적용되는 규제에 관한 특례에 대하여 다른 법률에 우선하여 적용한다고 규정하면서 단서

24) 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조·제7조·제7조의2 및 제8조에 따라 산업단지를 지정하는 자를 말함.

에서는 다른 법률에서 산단절차간소화법의 규제에 관한 특례보다 완화되는 규정이 있으면 그 법률로 정하는 바에 따른다고 규정하고 있는바, 산단절차간소화법은 같은 법보다 규제가 완화되는 경우를 제외하고는 다른 법에 우선 적용되는 특별법의 지위를 가지고 있으므로 물류시설법에 대해서도 우선 적용된다고 할 것이므로, 산단절차간소화법에 따라 수립·승인된 물류단지계획을 같은 법에 따라 변경하려는 경우 주민 등 의견청취를 생략할 수 있다고 규정하여 절차를 간소화하고 있다면, 그러한 경우가 물류시설법에 따르면 주민의견청취를 생략할 수 있는 경우에 해당하지 않더라도 산단절차간소화법이 우선 적용되어 주민 등 의견청취를 생략할 수 있다고 해석하는 것이 산단절차간소화법 및 산단절차간소화법을 준용하고 있는 물류시설법의 입법취지 및 규정체계에 부합하는 해석입니다.

그런데 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제1항 본문에서 같은 법에 따라 수립·승인된 물류단지계획을 변경하려는 경우에는 같은 법 제9조에 따른 주민 등 의견청취를 준용하도록 규정하면서 같은 법 제15조의2제1항 단서 및 같은 법 시행령 제10조에서는 물류단지계획의 변경 중 '일반물류단지개발사업 시행자의 변경' 등 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 같은 법 제9조에 따른 주민 등 의견청취를 생략할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법에 따라 수립·승인된 물류단지계획 중 일반물류단지개발사업의 시행자를 변경하기 위하여 그 계획을 변경하려는 경우에는 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제1항 단서가 우선 적용되어 주민 등 의견청취 절차를 생략할 수 있다고 해석하는 것이 타당합니다.

또한 산단절차간소화법의 입법연혁을 살펴보면, 산업단지계획의 수립·변경과 관련하여 주민의견 청취를 위해서는 공고, 열람 등의 절차를 거쳐야 하므로 통상 2~3개월의 시간이 소요되어 사업시행자에게 부담이 된다는 문제가 있어 2015년 8월 11일 법률 제13481호로 일부개정된 산단절차간소화법에서 제15조제3항 단서를 개정하여 산업단지계획의 경미한 변경 시 주민 등의 의견청취 절차를 생략할 수 있도록 한 것인바[25], "일반물류단지개발사업의 시행자 변경"이 산단절차간소화법령에서 정한 "경미한 사항의 변경"에 해당한다면 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제1항 단서에 따라 주민 등의 의견청취를 생략할 수 있다고 해석하는 것이 이러한 입법연혁에 부합하는 해석입니다.

아울러 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제1항 단서

25) 2014. 8. 26. 의안번호 제1911466호로 발의된 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 일부개정법률안에 대한 국토교통위원회 검토보고서(대안폐기) 참조

에서는 주민 등 의견청취를 “생략할 수 있다”고 규정하여 의견청취의 생략을 재량 사항으로 정하고 있는바, 물류단지계획의 경미한 사항이 변경되는 경우라도 지정권자가 특정 사안에 대해서 주민 등 의견청취가 필요하다고 판단하는 경우에는 해당 절차를 거칠 수 있으므로 물류시설법에 따른 주민 등 의견청취 절차가 반드시 생략되는 것은 아니라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제1항 단서에 따라 주민 등의 의견청취 절차를 생략할 수 있습니다.

다. 질의 나에 대해

먼저 물류시설법 제59조의2에 따라 물류단지 개발절차에 산단절차간소화법이 준용되고, 산단절차간소화법 제4조제1항 본문에서는 산단절차간소화법은 물류단지의 지정 및 개발에 적용되는 규제에 관한 특례에 대하여 다른 법률에 우선하여 적용한다고 규정하면서 단서에서는 다른 법률에서 산단절차간소화법의 규제에 관한 특례보다 완화되는 규정이 있으면 그 법률로 정하는 바에 따른다고 규정하고 있는바, 산단절차간소화법은 같은 법보다 규제가 완화되는 경우를 제외하고는 다른 법에 우선 적용되는 특별법의 지위를 가지고 있으므로, 이 사안과 같이 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제8조에 따라 물류단지계획이 수립·승인된 후 시·도지사가 “일반물류단지개발사업 시행자의 변경”을 위해 물류단지계획을 변경하려는 경우 그 변경 절차에 관해서도 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2에 따라 물류단지계획을 변경하여야 할 것인데, 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제1항 본문에서는 같은 법 제15조에 따라 심의위원회의 심의를 거쳐 수립·승인된 산업단지계획을 변경하는 경우에는 같은 법 제14조에 따른 심의위원회의 심의에 관한 규정을 준용하도록 규정하고 있고, 같은 법 제15조의2제1항 단서 및 같은 법 시행령 제10조에 따르면 “일반물류단지개발사업 시행자의 변경”은 같은 법 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거치지 않아도 되는 경미한 사항의 변경에 해당합니다.

그런데 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제2항에서는 같은 조 제1항 단서에 따른 경미한 사항이 같은 법 제14조제3항 각 호의 심의회 및 위원회의 심의 대상인 경우에는 같은 법 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거칠 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제14조제3항제1호에서는 「물류정책기본법」 제20조에 따른 지역물류정책위원회를 규정[26]하고 있는바, “일반물류단지개발사업 시행자의 변경”은 물류시설법

26) 물류시설법 제59조의2제2항에서 물류단지 지정 및 개발절차에 대하여 산단절차간소화법을 준용하는 경우, “산업입지정책

제59조의2에 따라 준용되는 산산단절차간소화법 제15조의2제1항 단서 및 같은 법 시행령 제10조에 따르면 경미한 사항이나, 물류시설법 제22조제3항 후단 및 같은 법 시행령 제13조제2항제4호에 따르면 일반물류단지개발계획 중 중요 사항의 변경으로서 지역물류정책위원회의 심의대상이 되므로, 문언상 일반물류단지개발사업의 시행자를 변경하기 위하여 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법에 따라 수립·승인된 물류단지계획을 변경하려는 경우에는 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차 간소화법 제15조의2제2항에 따라 같은 법 제14조에 따른 심의위원회를 거칠 수 있는 것으로 해석하는 것이 명확합니다.

그리고 심의위원회 심의에 관한 입법연혁을 살펴보면, 산업단지계획 변경 시 산업단지계획심의위원회를 거치지 않는 경미한 변경이 산단절차간소화법 제14조제3항 각 호의 심의회 또는 위원회의 심의를 거쳐야 하는 중요한 변경인 경우에 어떻게 처리하는지에 대해서 명확하게 규정하고 있지 않다는 문제가 있어[27] 2018년 6월 12일 법률 제15678호로 일부 개정된 산단절차간소화법에서는 제15조의2를 신설하여 개별법에 따른 위원회 대신 산업단지계획심의위원회 심의를 거칠 수 있도록 하여 '심의 절차'를 간소화하려는 취지였던바[28], 이러한 산단절차간소화법 제15조의2의 입법취지에 비추어보면 이 사안의 경우는 산단절차간소화법령에 따르면 경미한 사항의 변경에 해당하나 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제14조제3항제1호에 따른 지역물류 정책위원회의 심의 대상인 경우에 해당하여 같은 법 제15조의2제2항에 따라 같은 법 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거칠 수 있다고 해석하는 것이 이러한 입법취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 이 사안의 경우, 물류시설법 제59조의2에 따라 준용되는 산단절차간소화법 제15조의2제2항에 따라 지방물류단지계획심의위원회의 심의를 거칠 수 있습니다.

심의위원회"는 "「물류정책기본법」 제20조에 따른 지역물류정책위원회"로 본다고 규정하고 있음

27) 2017. 12. 18. 의안번호 2010891호로 발의된 산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 일부개정법률안에 대한 국토교통위원회 검토보고서 참조

28) 2018. 6. 12. 법률 제15678호로 일부개정된 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 개정이유 참조

관계법령

물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률

제22조(일반물류단지의 지정) ① ~ ② (생 략)

③ 시·도지사는 일반물류단지를 지정하려는 때에는 일반물류단지개발계획을 수립하여 관계 행정기관의 장과 협의한 후 「물류정책기본법」 제20조의 지역물류정책위원회의 심의를 거쳐야 한다. 일반물류단지개발계획 중 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

④ ~ ⑤ (생 략)

제24조(주민 등의 의견청취) ① 물류단지지정권자는 물류단지를 지정하려는 때에는 주민 및 관계 전문가의 의견을 들어야 하고 타당하다고 인정하는 때에는 그 의견을 반영하여야 한다. 다만, 국방상 기밀(機密)사항이거나 대통령령으로 정하는 경미한 사항인 경우에는 의견 청취를 생략할 수 있다.

② (생 략)

제59조의2(「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」의 준용) ① 물류단지 지정 및 개발절차에 관하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」을 준용한다. 다만, 같은 법 제17조 및 제18조는 준용하지 아니한다.

② 제1항에 따라 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」을 준용하는 경우 "산업단지"는 "제2조제6호에 따른 물류단지"로, "국가산업단지"는 "제22조제1항제1호 또는 제22조의2에 따라 국토교통부장관이 지정한 물류단지"로, "산업단지개발지원센터"는 "물류단지개발지원센터"로, "산업단지계획심의위원회"는 "물류단지계획심의위원회"로, "중앙산업단지계획심의위원회"는 "중앙물류단지계획심의위원회"로, "지방산업단지계획심의위원회"는 "지방물류단지계획심의위원회"로, "산업단지계획"은 "물류단지계획"으로, "민간기업등"은 "제22조 또는 제22조의2에 따라 물류단지를 지정하는 자 외의 자"로, "산업입지정책심의위원회"는 "「물류정책기본법」 제19조제1항제2호에 따른 물류시설분과위원회 또는 같은 법 제20조에 따른 지역물류정책위원회"로, "산업단지계획 통합기준"은 "물류단지계획 통합기준"으로 본다.

③ (생 략)

물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 시행령

제13조(일반물류단지의 지정) ① 삭제

② 법 제22조제2항 후단 및 같은 조 제3항 후단에서 "대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 때"란 각각 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 변경을 하려는 때를 말한다.

1. 일반물류단지지정 면적의 변경(10분의 1 이상의 면적을 변경하는 경우만 해당한다)
2. 일반물류단지시설용지 면적의 변경(10분의 1 이상의 면적을 변경하는 경우만 해당한다) 또는 일반물류단지시설용지의 용도변경
3. 기반시설(구거를 포함한다)의 부지 면적의 변경(10분의 1 이상의 면적을 변경하는 경우만 해당한다) 또는 그 시설의 위치 변경
4. 일반물류단지개발사업 시행자의 변경

제17조(주민 등의 의견청취) ① 물류단지지정권자는 법 제24조제1항에 따라 물류단지의 지정에 관하여 주민 및 관계 전문가의 의견을 들으려는 경우에는 물류단지개발계획안의 내용을 해당 물류단지의 소재지를 관할하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)에게 보내야 하며, 이를 받은 시장·군수·구청장은 그 주요 내용을 해당 지방에서 발간되는 일간신문, 공보, 인터넷 홈페이지 또는 방송 등을 통하여 공고하고 14일 이상 일반에게 열람하게 해야 한다.

② ~ ③ (생 략)

④ 법 제24조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 물류단지지정 면적의 변경(10분의 1 미만의 면적을 변경하는 경우만 해당한다)
2. 물류단지시설용지 면적의 변경(10분의 1 미만의 면적을 변경하는 경우만 해당한다) 또는 물류단지시설용지의 용도변경
3. 기반시설(구거를 포함한다)의 부지 면적의 변경(10분의 1 미만의 면적을 변경하는 경우만 해당한다) 또는 그 시설의 위치 변경

⑤ (생 략)

산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법

제4조(다른 법률과의 관계) ① 이 법은 산업단지의 지정 및 개발에 적용되는 규제에 관한 특례에 대하여 다른 법률에 우선하여 적용한다. 다만, 다른 법률에서 이 법의 규제에 관한 특례보다 완화되는 규정이 있으면 그 법률로 정하는 바에 따른다.

② (생 략)

제9조(주민 등의 의견청취) ① 지정권자는 산업단지계획을 수립하려고 하거나 산업단지계획의 승인 신청을 받은 경우에는 해당 지역을 주된 보급지역으로 하는 일간신문 및 해당 기관의 인터넷 홈페이지에 공고하고, 공고일부터 20일 이상 일반인이 열람하도록 하여야 한다. 이 경우 산업단지계획의 승인신청을 받은 때에는 특별한 사유가 없으면 승인신청을 받은 날부터 3일(근무일 기준) 이내에 공고하여야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

제14조(심의위원회의 심의) ① 제8조에 따른 산업단지계획을 수립 또는 승인하기 위하여 국토교통부장관은 중앙산업단지계획심의위원회, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 지방산업단지계획심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

② (생 략)

③ 심의위원회의 심의를 거친 경우에는 다음 각 호에서 정한 심의회 및 위원회의 심의를 받거나 거친 것으로 본다.

1. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업입지정책심의회
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 도시계획위원회
3. 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가심의위원회

3의2. 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가심의위원회

4. 「에너지이용 합리화법」에 따른 에너지사용계획에 대하여 심의권한을 가진 위원회
5. 「국가통합교통체계효율화법」에 따른 국가교통위원회

6. 「산지관리법」에 따른 산지관리위원회
7. 「경관법」에 따른 경관위원회

제15조(산업단지계획의 승인 고시 등) ① 지정권자는 심의위원회의 심의를 거쳐 산업단지계획을 수립 또는 승인하고, 그 결과를 관보 또는 공보에 고시하여야 한다. 이 경우 필요한 조건을 붙일 수 있다.
② ~ ④ (생 략)

제15조의2(산업단지계획의 변경) ① 제15조에 따라 수립·승인된 산업단지계획을 변경하는 경우에는 제8조부터 제15조까지, 제16조, 제17조, 제20조부터 제27조까지 및 제27조의2를 준용한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 제9조에 따른 주민 등의 의견청취를 생략할 수 있고, 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거치지 아니한다.
② 제1항 단서에 따른 경미한 사항이 제14조제3항 각 호의 심의회 및 위원회의 심의대상인 경우에는 제1항 단서에도 불구하고 제14조에 따른 심의위원회의 심의를 거칠 수 있다.
③ (생 략)

산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법 시행령

제10조(경미한 사항의 변경) 법 제15조의2제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우"란 다음 각 호의 경우를 제외한 사항을 말한다.

1. 산업단지면적의 100분의 10 이상의 면적변경
2. 주요 유치업종의 변경(도로를 제외한 기반시설의 용량이나 면적의 증가가 수반되는 경우로 한정한다)
3. 국토교통부장관이 정하는 토지이용계획 및 주요기반시설계획의 변경

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0246

민원인 – 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 “주변지역”의 범위(「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 제2조 본문 관련)

01 질의요지

「발전소주변지역 지원에 관한 법률」(이하 “발전소주변지역법”이라 함) 제2조 본문에서는 “주변지역”이란 「전기사업법」 제2조제4호에 따른 발전사업자가 가동·건설 중이거나 건설할 예정인 발전소[29]의 발전기가 설치되어 있거나 설치될 지점(이하 “발전기설치지점”이라 함)으로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역이 속하는 읍·면·동의 지역으로 규정하고 있는바,

읍·면·동의 관할 구역 중 일부가 발전기설치지점으로부터 5킬로미터 이내에 있는 경우, 해당 읍·면·동의 관할 구역 중 발전기설치지점으로부터 5킬로미터 밖에 있는 지역도 발전소주변지역법 제2조 본문에 따른 “주변지역”에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 해당 읍·면·동의 관할 구역 중 발전기설치지점으로부터 5킬로미터 밖에 있는 지역도 발전소주변지역법 제2조 본문에 따른 “주변지역”에 해당합니다.

03 이유

발전소주변지역법 제2조 본문에서는 같은 법에 따른 지원사업의 지역적 대상인 “주변지역”을 발전기설치지점으로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역이 속하는

29) 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에 따른 다목적댐 발전소와 발전소주변지역법 시행령 제2조제2항에 따른 발전소는 제외하며(발전소주변지역법 제2조 본문 참조), 이하 같음.

읍·면·동의 지역으로 정의하고 있는바, 읍·면·동의 관할 구역 중 일부만이 발전기설치지점으로부터 5킬로미터 이내에 있는 경우 해당 읍·면·동의 관할 구역 전체가 주변지역에 해당하는지, 아니면 발전기설치지점으로부터 5킬로미터 이내에 해당하는 지역만이 주변지역에 해당하는지가 문제됩니다.

먼저 발전소주변지역법 제2조 본문에서는 "주변지역"이란 '발전기설치지점으로부터 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역이 속하는 읍·면·동의 지역'이라고 규정하고 있는데, '속하다'라는 것은 관계되어 딸려있다는 의미[30]이므로, 같은 법 제2조 본문에 따른 주변지역은 발전기설치지점으로부터 5킬로미터 이내의 '육지 및 섬지역'으로 한정되는 것이 아니라, 발전기설치지점으로부터 5킬로미터 이내의 '육지 및 섬지역이 딸려있는 읍·면·동의 관할 구역 전체'를 의미한다고 보는 것이 해당 규정의 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 구 발전소주변지역법[31] 제2조제1호 각 목 외의 부분 본문에서는 "주변지역"을 발전기설치지점 등으로부터 반경 5킬로미터 이내의 '육지 및 도서지역'으로 규정하고 있었으나, 2000년 12월 23일 법률 제6284호로 일부개정되어 2001년 2월 24일 시행된 발전소주변지역법에서 발전소로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 도서지역의 경계를 물리적으로 명확하게 구분하여 확정하는 것이 어렵고, 주변지역이 속하는 읍·면·동까지 지원이 이루어질 수밖에 없는 현실적인 사정을 고려하여 현재와 같이 '육지 및 섬지역이 속하는 읍·면·동의 지역'까지 확대하여 개정[32]한 것에 비추어 보면, 같은 법에 따른 지원사업의 적용 대상이 되는 "주변지역"에는 읍·면·동의 관할 구역 중 일부만이 발전기설치지점으로부터 5킬로미터 이내에 있는 경우에도 해당 읍·면·동의 관할 구역 전체가 해당한다고 보는 것이 입법 연혁 및 취지를 고려할 때 타당한 해석입니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 읍·면·동의 관할 구역 중 발전기설치지점으로부터 5킬로미터 밖에 있는 지역도 발전소주변지역법 제2조 본문에 따른 "주변지역"에 해당합니다.

---

30) 국립국어원 표준국어대사전 참조

31) 2000. 12. 23. 법률 제6284호로 일부개정되어 2001. 2. 24. 시행되기 전의 것을 말함

32) 2000. 6. 30. 의안번호 제160050호로 발의된 발전소주변지역지원에관한법률중개정법률안에 대한 국회 산업자원위원회 검토보고서 및 법제처 2017. 7. 11. 회신 17-0266 해석례 참조

관계법령

발전소주변지역 지원에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 "주변지역"이란 「전기사업법」 제2조제4호에 따른 발전사업자(이하 "발전사업자"라 한다)가 가동·건설 중이거나 건설할 예정인 발전소{「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」에 따른 다목적댐 발전소와 발전원(發電源)의 종류별로 대통령령으로 정하는 시설용량 이하의 발전소는 제외한다. 이하 같다}의 발전기가 설치되어 있거나 설치될 지점으로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역이 속하는 읍·면·동의 지역을 말한다. 다만, 수력발전소, 조력발전소 또는 해상풍력발전소의 경우에는 발전(發電)과 관련이 있는 수계(水系)나 저수지 또는 바다의 인근지역으로서 대통령령으로 정하는 범위의 지역을 말한다.

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0323

산업통상자원부 – '엔지니어링사업자의 전문분야 추가'에 대한 신고의 성격(「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 등 관련)

01 질의요지

「엔지니어링산업 진흥법」(이하 "엔지니어링산업법"이라 함) 제21조제1항 전단에서는 '엔지니어링활동[33]을 영업의 수단으로 하려는 자는 기술인력 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다'고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 '엔지니어링사업자는 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하거나 휴업 또는 폐업하려는 때에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 산업통상자원부장관에게 그 사실을 신고하여야 한다'고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제33조제2항에서는 "대통령령으로 정하는 중요 사항"이란 '상호 또는 명칭'(제1호), '엔지니어링사업의 전문분야'(제5호), '법 제21조제1항 전단에 따라 신고한 기술인력'(제6호) 등을 말한다고 규정하고 있는바,

'엔지니어링사업자[34]가 엔지니어링사업[35]의 전문분야를 추가하려는 때[36]에는 엔지니어링산업법 제21조제1항에 따라 신고해야 하는지 아니면 같은 조 제2항에 따라 변경신고를 해야 하는지?

02 회답

엔지니어링사업자가 엔지니어링사업의 전문분야를 추가하려는 때에는 엔지니어링산업법 제21조제2항에 따라 변경신고를 해야 합니다.

33) 엔지니어링산업법 제2조제1호에 따른 "엔지니어링활동"을 말하며, 이하 같음.
34) 엔지니어링산업법 제2조제4호에 따른 "엔지니어링사업자"를 말하며, 이하 같음.
35) 엔지니어링산업법 제2조제3호에 따른 "엔지니어링사업"을 말하며, 이하 같음.
36) 엔지니어링사업의 종류(엔지니어링업, 엔지니어링컨설팅업)에는 변동이 없는 경우로 전제하며, 이하 같음.

03 이유

먼저 엔지니어링사업자의 신고와 관련된 엔지니어링산업법령의 문언을 살펴보면, 엔지니어링산업법 제21조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제2항제5호에서는 변경신고 대상의 하나로 엔지니어링사업의 전문분야를 '변경'하려는 경우를 규정하고 있는데, 일반적으로 "변경"이란 '다르게 바꾸어 새롭게 고침'을 의미[37]하는 것으로서, '전문분야의 변경'에는 ①기존의 전문분야 중 일부를 삭제하는 것, ②새로운 전문분야를 추가하는 것, ③기존의 전문분야를 삭제하는 동시에 새로운 전문분야를 추가하는 것이 모두 포함된다고 보아야 할 것이고, 같은 법 제21조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제2항에서 변경신고의 대상에 '전문분야의 추가'가 포함되지 않는다고 별도로 명시하고 있지도 않으므로, 엔지니어링사업자가 엔지니어링사업의 전문분야를 추가하는 신고는 같은 법 제21조제2항에 따른 변경신고의 대상에 포함된다고 보는 것이 엔지니어링산업법령의 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 엔지니어링산업법 제21조제1항 전단에서는 '엔지니어링활동을 영업의 수단으로 하려는 자는 기술인력 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다'고 규정하여 '엔지니어링활동을 영업의 수단으로 하려는 자'를 같은 조 제1항에 따른 신고 대상으로 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 '엔지니어링사업자는 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 때에는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 산업통상자원부장관에게 그 사실을 신고하여야 한다'고 규정하여 '대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 엔지니어링사업자'를 같은 조 제2항에 따른 변경신고 대상으로 규정하고 있는바, 이와 같이 '새롭게 엔지니어링사업을 하려는 자'는 같은 법 제21조제1항에 따른 신고를, '이미 엔지니어링사업자에 해당하는 자'가 기존의 신고 사항을 변경하려는 경우는 같은 조 제2항에 따른 변경신고를 각각 구분하여 규정하고 있는 점을 고려하면, 이미 엔지니어링사업자에 해당하는 자가 엔지니어링사업의 전문분야를 추가하려는 때에는 엔지니어링산업법 제21조제2항에 따라 변경신고를 해야 한다는 것이 같은 법 제21조의 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 엔지니어링산업법 시행규칙 제7조제2항에서는 같은 법 제21조제1항에 따라 엔지니어링사업자 신고를 한 자에게 같은 법 시행규칙 별지 제9호서식의 엔지니어링사업자 신고증을 발급하도록 규정하고 있는데, 같은 서식에 따르면 엔지니어링사업자 신고증에는 명칭, 대표자성명, 소재지, 신고번호, 전문분야(…등 ○개 분야) 등을 기재하도록 되어 있어,

37) 국립국어원 표준국어대사전 참조

하나의 엔지니어링사업자가 여러 개의 '전문분야' 를 보유하는 경우에도 '전문분야'별로 별개의 신고증을 발급하는 것이 아니라 '사업자'별로 하나의 신고증을 발급하되 신고증에 ○개의 전문분야를 보유하고 있다는 것이 기재되는 점을 고려하면, 전문분야별로 별도의 엔지니어링사업자 신고가 이루어진다고 보기는 어려우므로, '엔지니어링사업의 전문분야를 추가하는 신고'는 같은 법 제21조제1항에 따른 '새로운 엔지니어링사업의 신고'가 아니라 같은 조 제2항에 따라 '기존에 신고된 사항을 변경하는 신고'에 해당한다고 보는 것이 합리적입니다.

따라서 엔지니어링사업자가 엔지니어링사업의 전문분야를 추가하려는 때에는 엔지니어링산업법 제21조제2항에 따라 변경신고를 해야 합니다.

관계법령

엔지니어링산업 진흥법

제21조(엔지니어링사업자의 신고 등) ① 엔지니어링활동을 영업의 수단으로 하려는 자는 기술인력 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖추고 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다. 이 경우 산업통상자원부장관은 신고한 자에게 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 신고증을 교부하여야 한다.
② 엔지니어링사업자는 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하거나 휴업 또는 폐업하려는 때에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 산업통상자원부장관에게 그 사실을 신고하여야 한다.
③ 산업통상자원부장관은 제1항 및 제2항에 따른 신고를 받은 경우 그 신고 사항에 대하여 보완이 필요하다고 인정할 때에는 3개월 이내에서 기간을 정하여 이를 보완하게 할 수 있다.
④·⑤ (생 략)
⑥ 엔지니어링사업자의 신고 절차 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

엔지니어링산업 진흥법 시행령

제33조(엔지니어링사업자의 신고 등) ① 법 제21조제1항 전단에 따른 엔지니어링사업자의 신고 요건은 별표 3과 같다.
② 법 제21조제2항에서 "대통령령으로 정하는 중요 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.
1. 상호 또는 명칭
2. 영업소 소재지
3. 대표자
4. 엔지니어링사업의 종류
5. 엔지니어링사업의 전문분야
6. 법 제21조제1항 전단에 따라 신고한 기술인력

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0476

산업통상자원부 – 국내생산물품등의 판매자가 「대외무역관리규정」 제86조제1항 각 호의 원산지 판정기준 적용 제외물품의 원산지를 우리나라로 표시하는 것이 「대외무역법」제33조제4항제1호의 금지행위에 해당되는지 여부(「대외무역법」 제33조제4항제1호 등 관련)

01 질의요지

「대외무역법」 제35조제1항 본문에서는 산업통상자원부장관은 공정한 거래질서의 확립과 생산자 및 소비자 보호를 위하여 필요하다고 인정하면 수입원료를 사용하여 국내에서 생산되어 국내에서 유통되거나 판매되는 물품등[38](이하 "국내생산물품등"이라 함)에 대한 원산지 판정에 관한 기준을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 전단에서는 국내생산물품등의 판매자에 대해서는 같은 법 제33조제4항제1호 및 제4호를 준용한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제33조제4항제1호에서는 물품등의 판매업자는 같은 법 제35조에 따른 국내생산물품등에 대하여 원산지를 거짓으로 표시하거나 원산지를 오인하게 하는 표시를 하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있는 한편,

「대외무역법」의 위임에 따라 국내생산물품등의 원산지 판정 기준 등을 규정하고 있는 「대외무역관리규정」(산업통상자원부 고시) 제86조제1항에서는 「대외무역법」 제35조에 따른 수입원료를 사용한 국내생산물품등에서 원산지 판정 기준 적용 대상물품은 「대외무역관리규정」 제86조제1항 각 호의 어느 하나[39]에도 해당되지 않는 물품이라고 규정하고 있는바,

국내생산물품등의 판매자가 국내생산물품등 중에서 「대외무역관리규정」 제86조제1항 각 호에 따른 물품(이하 "원산지 판정기준 적용 제외물품"이라 함)의 원산지를 우리나라로 표시하는 행위가 「대외무역법」 제33조제4항제1호의 금지행위에 해당되는지?[40]

38) 「대외무역법」 제2조제1호에 따른 물품, 용역, 전자적 형태의 무체물을 말하며, 이하 같음

39) 국내수입후 제85조제8항의 단순한 가공활동을 거친 물품, 1류 ~ 24류(농수산물·식품), 30류(의료용품) 등을 말함

40) 「대외무역법」 및 「대외무역관리규정」 외에 다른 법령에서 국내생산물품등에 대하여 다른 기준을 규정하지 않은 경우를 전제함

02 회답

국내생산물품등의 판매자가 국내생산물품등 중에서 원산지 판정기준 적용 제외물품의 원산지를 우리나라로 표시하는 행위는 「대외무역법」 제33조제4항제1호의 금지행위에 해당됩니다.

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[41], 「대외무역법」 제33조제4항제1호에서는 국내생산물품등에 대하여 원산지를 거짓으로 표시하거나 원산지를 오인(誤認)하게 하는 표시를 하는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 법 제35조제3항에서는 국내생산물품등의 판매자에 대하여 같은 법 제33조제4항제1호 및 제4호를 준용한다고 규정하고 있으며, 같은 법에서는 국내생산물품등 중 원산지 판정 기준 적용 대상물품인지 여부에 따라 같은 법 제33조제4항제1호의 적용대상인지 여부가 달라진다는 규정도 두고 있지 않은바, 결국 같은 법 제33조제4항제1호 및 제35조제3항에 따라 모든 국내생산물품등의 원산지를 거짓으로 표시하거나 오인하게 하는 표시를 하는 것은 금지된다고 보아야 할 것이므로, 국내생산물품등 중 원산지 판정기준 적용 제외물품에 대해 원산지를 우리나라로 표시하는 것은 「대외무역법」 제33조제4항제1호의 금지행위인 원산지를 거짓으로 표시하거나 원산지를 오인하게 하는 표시를 하는 경우에 해당한다고 할 것입니다.

그리고 「대외무역법」 제33조 등에서 규정하고 있는 원산지 표시제도는 수입물품의 원산지를 국산으로 허위 표시하여 판매함으로써 소비자에게 피해를 주는 사례가 빈번하게 발생함에 따라 국내 소비자보호 및 공정 무역거래질서를 확립하기 위하여 도입된 제도[42]이고, 2022년 6월 10일 법률 제18885호로 「대외무역법」을 일부개정하면서 제35조제3항을 신설하여 수입원료를 사용한 국내생산물품등의 거래 질서를 정립하기 위하여 “국내생산물품등”의 원산지 표시 위반 여부에 대한 단속 근거를 명시적으로 규정[43]하게 된 것이므로, 국내

41) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

42) 1992. 10. 22. 의안번호 140094호로 발의된 대외무역법중개정법률안에 대한 국회 상공위원회 심사보고서 참조

43) 2021. 4. 7. 의안번호 2109345호로 발의된 대외무역법 일부개정법률안에 대한 산업통상자원중소벤처기업위원회 검토보고서 및 2022. 6. 10. 법률 제18885호로 일부개정되어 2022. 12. 11. 시행된 대외무역법 개정이유 참조

생산물품등 중 원산지 판정기준 적용 제외물품의 원산지를 우리나라로 표시한 경우에는 「대외무역법」 제33조제4항제1호의 적용대상이 된다고 해석하는 것이 입법연혁 및 취지에 부합한다고 할 것입니다.

또한 「대외무역법」 제35조제1항의 위임에 따라 수입원료를 사용한 국내생산물품등의 원산지 판정 기준을 정하고 있는 「대외무역관리규정」 제86조제1항에서는 「대외무역법」 제35조에 따른 수입원료를 사용한 국내생산물품등에서 원산지 판정 기준 적용 대상물품에 대하여 규정하고 있고, 「대외무역관리규정」 제86조제2항 전단에서는 원산지 판정 기준 적용 대상물품 중에서 '우리나라'를 원산지로 하는 물품에 대하여 규정하고 있으며, 같은 조 제5항에서는 「대외무역법」 제35조에 따른 수입원료를 사용한 국내생산물품 중 「대외무역관리규정」 제86조제2항의 원산지 규정을 충족하지 않은 물품의 원산지 표시에 대하여 규정하고 있는바, 위 규정에 따르면 원산지를 우리나라로 표시할 수 있는 물품은 '원산지 판정기준 적용 대상물품'인 것이 전제되는데, 이러한 전제 요건에 충족되지 않는 원산지 판정기준 적용 제외물품의 경우에는 그 원산지를 우리나라로 표시할 수 없다고 할 것입니다.

따라서 국내생산물품등의 판매자가 국내생산물품등 중에서 원산지 판정기준 적용 제외물품의 원산지를 우리나라로 표시하는 행위는 「대외무역법」 제33조제4항제1호의 금지행위에 해당됩니다.

관계법령

대외무역법

제33조(수출입 물품등의 원산지의 표시) ①산업통상자원부장관이 공정한 거래 질서의 확립과 생산자 및 소비자 보호를 위하여 원산지를 표시하여야 하는 대상으로 공고한 물품등(이하 "원산지표시대상물품"이라 한다)을 수출하거나 수입하려는 자는 그 물품등에 대하여 원산지를 표시하여야 한다.
② 수입된 원산지표시대상물품에 대하여 대통령령으로 정하는 단순한 가공활동을 거침으로써 해당 물품등의 원산지 표시를 손상하거나 변형한 자(무역거래자 또는 물품등의 판매업자에 대하여 제4항이 적용되는 경우는 제외한다)는 그 단순 가공한 물품등에 당초의 원산지를 표시하여야 한다. 이 경우 다른 법령에서 단순한 가공활동을 거친 수입 물품등에 대하여 다른 기준을 규정하고 있으면 그 기준에 따른다.
③ (생 략)
④ 무역거래자 또는 물품등의 판매업자는 수출 또는 수입 물품등 및 제35조에 따른 국내생산물품등에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 제2호 및 제3호에 따른 금지행위는 수입 물품등에 한정한다.

1. 원산지를 거짓으로 표시하거나 원산지를 오인(誤認)하게 하는 표시를 하는 행위
2. 원산지의 표시를 손상하거나 변경하는 행위
3. 원산지표시대상물품에 대하여 원산지 표시를 하지 아니하는 행위
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 위반되는 원산지표시대상물품을 국내에서 거래하는 행위

⑤ (생 략)

제35조(수입원료를 사용한 국내생산 물품등의 원산지 판정 기준 등) ①산업통상자원부장관은 공정한 거래질서의 확립과 생산자 및 소비자 보호를 위하여 필요하다고 인정하면 수입원료를 사용하여 국내에서 생산되어 국내에서 유통되거나 판매되는 물품등(이하 "국내생산물품등"이라 한다)에 대한 원산지 판정에 관한 기준을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정할 수 있다. 다만, 다른 법령에서 국내생산물품등에 대하여 다른 기준을 규정하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② (생 략)

③ 국내생산물품등의 판매자에 대해서는 제33조제4항제1호 및 제4호를 준용한다. 이 경우 "제1호부터 제3호"는 "제1호"로, "원산지표시대상물품"은 "국내생산물품등"으로 본다.

대외무역관리규정

제86조(수입원료를 사용한 국내생산물품등의 원산지 판정 기준) ① 법 제35조에 따른 수입원료를 사용한 국내생산물품 등에서, 원산지 판정 기준 적용 대상물품은 다음 각 호의 어느 하나에도 해당되지 않는 물품이다.

1. 국내수입후 제85조제8항의 단순한 가공활동을 거친 물품
2. 1류~24류(농수산물·식품), 30류(의료용품), 33류(향료·화장품), 48류(지와 판지), 49류(서적·신문·인쇄물), 50류~58류(섬유), 70류(유리), 72류(철강), 87류(8701~8708의 일반차량), 89류(선박)

② 제1항의 원산지 판정 기준 적용 대상물품중에서, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 우리나라를 원산지로 하는 물품으로 본다. 이 경우 제조원가란, 일반적으로 물품의 공장도 공급가액에서 이윤과 판매·관리비를 제외한 금액이 되나, 정확한 계산이 곤란한 경우 등, 예외적인 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제9조에 따른 공인원가계산용역기관이 계산한 원가로 대체할 수 있다.

1.·2. (생 략)

③·④ (생 략)

⑤ 법 제35조에 따른 수입원료를 사용한 국내생산물품중 제2항의 원산지 규정을 충족하지 아니한 물품의 원산지 표시는 다음 각 호의 방법에 따라 표시할 수 있다.

1. 우리나라를 "가공국" 또는 "조립국" 등으로 표시하되 원료 또는 부품의 원산지를 동일한 크기와 방법으로 병행하여 표시
2. 제1호의 원료나 부품이 1개국의 생산품인 경우에는 "원료(또는 부품)의 원산지 : 국명"을 표시
3. 제1호의 원료나 부품이 2개국 이상(우리나라를 포함한다)에서 생산된 경우에는 완성품의 제조원가의 재료비에서 차지하는 구성비율이 높은 순으로 2개 이상의 원산지를 각각의 구성비율과 함께 표시(예: "원료 (또는 부품)의 원산지 : 국명(○%), 국명(○%)")

⑥ 제2항에 따른 판정 시, 원산지를 우리나라로 입증할 수 없는 원료는 수입원료로 본다.

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0622

산업통상자원부 – 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 등에 따라 수의계약을 체결할 수 있는 자의 범위(「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 및 제13조의3제1항 관련)

01 질의요지

「외국인투자 촉진법」 제13조제1항에서는 기획재정부장관, 국유재산을 관리하는 중앙관서의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공기업[44]의 장은 국가·지방자치단체·공공기관 또는 지방공기업(이하 "국가등"이라 함)이 소유하는 토지·공장 또는 그 밖의 재산(이하 "토지등"이라 함)을 「도시개발법」(제4호) 등의 관련 규정에도 불구하고 수의계약으로 외국인투자기업등[45]에게 사용·수익 또는 대부(이하 "임대"라 함)할 수 있다고 규정하고 있고, 「외국인투자 촉진법」 제13조의3제1항에서는 국가등은 소유하는 토지등을 「도시개발법」 등의 관련 규정에도 불구하고 수의계약으로 외국인투자기업등에 매각할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「도시개발법」 제11조제1항에서는 도시개발사업의 시행자(이하 "도시개발사업시행자"라 함)로 지정받을 수 있는 자로 국가나 지방자치단체(제1호), 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사(제4호), 국가·지방자치단체나 지방공사 등이 도시개발사업을 시행할 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인(제11호)(이하 "도시개발사업특수목적법인"이라 함) 등을 규정하고 있는바,

도시개발사업자인 도시개발사업특수목적법인은 도시개발사업으로 취득한 조성토지등[46]을 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 또는 제13조의3제1항에 따라 수의계약으로 외국인투자기업등에게 임대 또는 매각할 수 있는지?

---

44) 지방직영기업은 제외하며, 이하 같음

45) 외국인투자기업 또는 외국인투자환경 개선시설 운영자를 말하며(「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 참조), 이하 같음

46) 도시개발사업으로 조성된 토지·건축물 또는 공작물 등을 말하며, 이하 같음

02 회답

도시개발사업자인 도시개발사업특수목적법인은 도시개발사업으로 취득한 조성토지등을 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 또는 제13조의3제1항에 따라 수의계약으로 외국인투자기업등에게 임대 또는 매각할 수 없습니다.

03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미를 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[47], 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 또는 제13조의3제1항 에서는 외국인투자기업등에게 수의계약으로 국가등이 소유하는 토지등을 임대 또는 매각할 수 있는 주체로 "기획재정부장관, 국유재산을 관리하는 중앙관서의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 장"을 제한적으로 열거하고 있고, 도시개발사업특수목적법인은 이에 해당하지 않으므로, 도시개발사업특수목적법인은 「외국인투자촉진법」에 따라 외국인투자기업등에게 수의계약으로 임대 또는 매각할 수 있는 주체가 아니라는 것이 문언상 명확합니다.

또한 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」, 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「도시개발법」 또는 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 등은 국·공유재산과 그에 준하는 공익성을 가지고 있는 공공기관·지방공기업 소유의 토지등을 보호하고 그 취득·유지·보존 및 운용과 처분의 적정을 기하기 위하여 국·공유재산의 처분 등에 대하여 엄격히 제한하고 있음에도 불구하고, 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 및 제13조의3제1항은 외국인투자를 촉진하기 위하여 예외적으로 이러한 제한을 완화하여 외국인투자기업 등에게는 국·공유재산과 토지등을 수의계약의 방법에 의하여 임대 또는 매각할 수 있도록 특례를 정한 것으로서, 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 및 제13조의3제1항에 따라 수의계약을 할 수 있는지 여부는 엄격하게 해석해야 할 것이므로[48], 명문의 규정 없이 도시개발사업 특수목적법인이 「외국인투자 촉진법」에 따라 외국인투자기업등에게 수의계약으로 임대 또는 매각할 수 있다고 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

47) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

48) 법제처 2013. 6. 12. 회신 13-0169 해석례 참조

한편 「도시개발법 시행령」 제18조제8항에 따르면 도시개발사업특수목적법인 중 공공기관 또는 지방공기업이 아니더라도 국가 또는 지방자치단체가 100분의 50 이상 출자한 법인인 경우가 있을 수 있고, 이 경우 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제3호에 따라 정부가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있는 공공기관이나 「지방공기업법」 제53조제2항에 따라 지방자치단체가 100분의 50 이상의 지분을 가지고 있는 지방공사와 마찬가지로 상당한 공익성을 가지고 있다고 볼 수 있으므로, 이러한 도시개발사업특수목적법인의 경우에는 공공기관 또는 지방공사 등과 동일하게 도시개발사업으로 취득한 조성토지등을 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 또는 제13조의3제1항에 따라 수의계약으로 임대 또는 매각할 수 있다고 해석해야 한다는 의견이 있습니다.

그러나 공공기관 및 지방공사의 경우 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조부터 제6조까지에 따라 기획재정부장관의 지정을 받거나 「지방공기업법」 제49조제2항에 따라 지방자치단체가 그 설립, 업무 및 운영에 관한 기본적인 사항을 조례로 정하여 설립하여야 하고, 경영 등에 관하여 「공공기관의 운영에 관한 법률」 또는 「지방공기업법」에 따른 각종 규율을 받게 되는데 반해, 설립 및 경영에 관하여 「공공기관의 운영에 관한 법률」 또는 「지방공기업법」의 적용을 받지 않는 도시개발사업특수목적법인을 공공기관이나 지방공사와 마찬가지의 공익성을 가지고 있다고 보기 어렵고, 단순히 국가 또는 지방자치단체의 출자 또는 지분소유 비율이 유사하다는 사실만으로 명시적 규정 없이 도시개발사업특수목적법인을 공공기관이나 지방공사와 동일하게 볼 수 없다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 도시개발사업자인 도시개발사업특수목적법인은 도시개발사업으로 취득한 조성토지등을 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 또는 제13조의3제1항에 따라 수의계약으로 외국인투자기업등에게 임대 또는 매각할 수 없습니다.

관계법령

외국인투자 촉진법

제13조(국유·공유재산의 임대) ① 기획재정부장관, 국유재산을 관리하는 중앙관서의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공기업(지방직영기업은 제외하며, 이하 이 조에서 "지방공기업"이라 한다)의 장은 국가·지방자치단체·공공기관 또는 지방공기업(이하 "국가등"이라 한다)이 소유하는 토지·공장 또는 그 밖의 재산(이하 "토지등"이라 한다)을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률의 관련 규정에도 불구하고 수의계약으로 외국인투자기업 또는 외국인투자환경 개선시설 운영자(이하 이 조, 제13조의2부터 제13조의4까지 및 제14조에서 "외국인투자기업등"이라 한다)에게 사용·수익 또는 대부(이하 "임대"라 한다)할 수 있다. 다만, 토지등이 제18조제1항제1호에 해당하는 경우에는 비수도권 국내복귀기업에도 임대할 수 있다.

1. ~ 3. (생 략)
4. 「도시개발법」
5. ~ 7. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

제13조의3(국유·공유재산의 매각) ① 국가등은 소유하는 토지등을 제13조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률의 관련 규정에도 불구하고 수의계약으로 외국인투자기업등에 매각할 수 있다.

② ~ ③ (생 략)

도시개발법

제11조(시행자 등) ① 도시개발사업의 시행자(이하 "시행자"라 한다)는 다음 각 호의 자 중에서 지정권자가 지정한다. 다만, 도시개발구역의 전부를 환지 방식으로 시행하는 경우에는 제5호의 토지소유자나 제6호의 조합을 시행자로 지정한다.

1. 국가나 지방자치단체
2. 대통령령으로 정하는 공공기관
3. 대통령령으로 정하는 정부출연기관
4. 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사
5. ~ 10. (생 략)
11. 제1호부터 제9호까지, 제9호의2 및 제10호에 해당하는 자(제6호에 따른 조합은 제외한다)가 도시개발사업을 시행할 목적으로 출자에 참여하여 설립한 법인으로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 법인

질의제목 10 ▶ 안건번호 24-0701

민원인 – 상시근로자 300명 미만의 사업장에 선임된 안전관리자의 업무 전담 여부(「산업안전보건법」 제17조 등 관련)

01 질의요지

「산업안전보건법」 제17조제1항에서는 사업주[49]는 사업장에 같은 법 제15조제1항 각 호의 사항 중 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 안전보건관리책임자[50]를 보좌하고 관리감독자[51]에게 지도·조언하는 업무를 수행하는 사람(이하 "안전관리자"라 함)을 두어야 한다고 규정하면서, 같은 법 제17조제2항에서는 안전관리자를 두어야 하는 사업의 종류와 사업장의 상시근로자 수, 안전관리자의 수·자격·업무·권한·선임방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 대통령령으로 정하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수에 해당하는 사업장의 사업주는 안전관리자 에게 그 업무만을 전담하도록 하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제16조제2항에서는 같은 법 제17조제3항에서 "대통령령으로 정하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수에 해당하는 사업장"이란 같은 조 제1항에 따른 사업 중 상시근로자 300명 이상을 사용하는 사업장[52]을 말한다고 규정하고 있고, 같은 영 제18조제1항에서는 안전관리자의 업무를 각 호로 규정하고 있는바,

상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장[53]의 사업주는 해당 사업장에 선임된 안전관리자에게 반드시 「산업안전보건법」 제17조제2항 및 같은 법 시행령 제18조제1항 각 호에 따른 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하여야 하는지?[54]

---

49) 「산업안전보건법」 제2조제4호에 따른 "사업주"를 말함

50) 「산업안전보건법」 제15조에 따른 "안전보건관리책임자"를 말함

51) 「산업안전보건법」 제16조에 따른 "관리감독자"를 말함.

52) 건설업의 경우에는 공사금액이 120억원(「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호에 따른 토목공사업의 경우에는 150억원) 이상인 사업장을 말함

53) 「산업안전보건법」 제17조제1항·제2항 및 같은 법 시행령 제16조제1항·별표 3에 따라 안전관리자를 두어야 하는 사업 중 건설업을 제외한 사업의 사업장을 전제로 함

54) 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장의 사업주가 해당 사업장에 선임된 안전관리자에게 산업안전보건법령에 따른 안전관리자의 업무 외에 별도로 겸직하게 하는 업무의 구체적인 내용 및 업무량 등은 별론으로 함

02 회답

상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장의 사업주는 해당 사업장에 선임된 안전관리자에게 반드시 「산업안전보건법」 제17조제2항 및 같은 법 시행령 제18조제1항 각 호에 따른 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하여야 하는 것은 아닙니다.

03 이유

우선 「산업안전보건법」 제17조제2항에서는 안전관리자를 두어야 하는 사업의 종류와 사업장의 상시근로자 수 및 안전관리자의 업무 등의 사항을 대통령령으로 정하도록 규정하면서, 같은 조 제3항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제16조제2항에서는 사업주로 하여금 안전관리자에게 그 업무만을 전담하도록 하여야 하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수에 관하여 안전관리자를 두어야 하는 사업 중 "상시근로자 300명 이상을 사용하는 사업장"으로 그 범위를 한정하여 규정하고 있는바, 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장의 사업주의 경우에는 해당 사업장에 선임된 안전관리자에게 반드시 그 업무만을 전담하도록 하여야 할 의무가 있는 것은 아니라는 것이 문언상 분명합니다.

더욱이 2021년 5월 18일 법률 제18180호로 일부개정된 「산업안전보건법」에서는 제17조제3항을 신설하여 안전관리자의 업무 전담 규정을 기존 시행령에서 법률로 상향하여 규정하면서, 전담하는 안전관리자를 두어야 하는 사업장의 범위를 대통령령으로 정하도록 위임하였고[55], 이에 따라 2021년 11월 19일 대통령령 제32132호로 일부개정된 「산업안전보건법 시행령」 제16조에서는 전담하는 안전관리자를 두어야 하는 사업장의 구체적인 범위를 "안전관리자를 두어야 하는 사업 중 상시근로자 300명 이상을 사용하는 사업장"으로 규정한 것인바, 일정 규모 이상에 해당하는 사업장의 경우 안전관리자가 전담 업무를 수행하도록 하여 산업재해 예방에 기여하려는 입법 목적에 비추어 보면[56], 사업장의 규모를 나타내는 상시근로자 수가 같은 영 제16조제2항에서 정한 기준인 300명에 이르지 않은 사업장에 대해서는 그 규율 대상에 포함시키지 않은 것으로 보는 것이 타당하다고 할 것입니다.

또한 「산업안전보건법」 제17조제3항 및 같은 법 시행령 제16조제2항에 따라 일정 규모

55) 2021. 4. 29. 의안번호 제2109808호로 발의된 산업안전보건법 일부개정법률안 의안원문 참조

56) 2021. 11. 19. 대통령령 제32132호로 일부개정된 산업안전보건법 시행령 일부개정령안에 대한 조문별 개정이유서 참조

이상의 사업장에는 산업안전보건법령에 규정된 업무만을 전담하는 안전관리자를 두도록 한 것은, 일반적으로 안전관리자는 안전관리자로서의 업무 외에 다른 업무도 수행할 수 있다고 할 것이나, 일정 규모 이상의 사업장에는 산업안전보건법령에 규정된 업무만 전담하는 전담 안전관리자를 두어 근로자의 안전에 더욱 주의를 기울이려는 데에 그 취지가 있다고 할 것이므로[57], 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장의 사업주의 경우에는 안전관리자에게 반드시 그 업무만을 전담하도록 하여야 하는 것은 아니라고 해석하는 것이 입법 취지에도 부합합니다.

따라서 상시근로자 300명 미만을 사용하는 사업장의 사업주는 해당 사업장에 선임된 안전관리자에게 반드시 「산업안전보건법」 제17조제2항 및 같은 법 시행령 제18조제1항 각 호에 따른 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하여야 하는 것은 아닙니다.

관계법령

산업안전보건법

제17조(안전관리자) ① 사업주는 사업장에 제15조제1항 각 호의 사항 중 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 업무를 수행하는 사람(이하 "안전관리자"라 한다)을 두어야 한다.
② 안전관리자를 두어야 하는 사업의 종류와 사업장의 상시근로자 수, 안전관리자의 수·자격·업무·권한·선임방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
③ 대통령령으로 정하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수에 해당하는 사업장의 사업주는 안전관리자에게 그 업무만을 전담하도록 하여야 한다.
④·⑤ (생 략)

산업안전보건법 시행령

제16조(안전관리자의 선임 등) ① 법 제17조제1항에 따라 안전관리자를 두어야 하는 사업의 종류와 사업장의 상시근로자 수, 안전관리자의 수 및 선임방법은 별표 3과 같다.
② 법 제17조제3항에서 "대통령령으로 정하는 사업의 종류 및 사업장의 상시근로자 수에 해당하는 사업장"이란 제1항에 따른 사업 중 상시근로자 300명 이상을 사용하는 사업장[건설업의 경우에는 공사금액이 120억원(「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호에 따른 토목공사업의 경우에는 150억원) 이상인 사업장]을 말한다.
③ ~ ⑥ (생 략)

57) 법제처 2012. 3. 2. 회신 12-0069 해석례 참조

제18조(안전관리자의 업무 등) ① 안전관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제24조제1항에 따른 산업안전보건위원회(이하 "산업안전보건위원회"라 한다) 또는 법 제75조제1항에 따른 안전 및 보건에 관한 노사협의체(이하 "노사협의체"라 한다)에서 심의·의결한 업무와 해당 사업장의 법 제25조제1항에 따른 안전보건관리규정(이하 "안전보건관리규정"이라 한다) 및 취업규칙에서 정한 업무
2. 법 제36조에 따른 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언
3. ~ 10. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

질의제목 11 ▶ 안건번호 24-0724, 24-0800

민원인 – 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조에 따른 가스사용시설 안전관리업무 대행자의 자격 요건 충족 여부(「도시가스사업법 시행규칙」 제47조 등 관련)

01 질의요지

「도시가스사업법」 제28조제1항에서는 일반도시가스사업자는 같은 법 제26조의 안전관리 규정(이하 "안전관리규정"이라 함)에 따른 가스사용시설의 안전관리업무를 효율적으로 수행하기 위하여 그 업무의 일부를 대행하게 할 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 자격을 갖춘 자로 하여금 그 업무를 대행하게 하여야 한다고 규정하고 있고,

그 위임에 따라 마련된 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조에서는 「도시가스사업법」 제28조제1항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 자격을 갖춘 자"란 같은 규칙 제47조 각 호의 요건을 모두 갖춘 자를 말하고, 이 경우 같은 조 각 호에 따른 안전관리 책임자, 사용시설점검원, 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자를 각각 갖추어야 한다고 규정하면서, 각 호로 안전관리 책임자가 1명 이상일 것(제1호), 사용시설점검원이 가스사용시설 안전관리 수요자 3천 가구 또는 사업체마다 1명 이상일 것(제2호), 「건설산업기본법 시행령」 제13조에 따른 제1종 또는 제2종 가스시설시공업에 등록한 자일 것(제3호)을 규정하고 있는바,

가. 「도시가스사업법」 제28조제1항 및 같은 법 시행규칙 제47조에 따라 가스사용시설의 안전관리업무를 대행하려는 자가 안전관리 책임자의 자격과 사용시설점검원의 자격을 모두 소지하고 있는 자를 선임한 경우, 같은 조 제1호 및 제2호의 요건을 모두 갖추었다고 볼 수 있는지?[58]

나. 「건설산업기본법 시행령」 제13조에 따른 제1종 또는 제2종 가스시설시공업에 등록한 자가 「도시가스사업법」 제28조제1항 및 같은 법 시행규칙 제47조에 따라 가스사용시설의 안전관리업무를 대행하려고 할 때, 위 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자가 사용시설점검원의 자격을 소지하고 있는 경우, 같은 조 제2호 및 제3호의 요건을 모두 갖추었다고 볼 수 있는지?[59]

58) 가스사용시설 안전관리업무를 대행하기 위하여 사용시설점검원이 1명 이상일 것이 요구되는 경우를 전제함

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조제1호 및 제2호의 요건을 모두 갖추었다고 볼 수 없습니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조제2호 및 제3호의 요건을 모두 갖추었다고 볼 수 없습니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

먼저 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조에서는 「도시가스사업법」 제28조제1항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 자격을 갖춘 자"란 같은 법 시행규칙 제47조 각 호의 요건을 모두 갖춘 자를 말하고, 이 경우 같은 조 각 호에 따른 안전관리 책임자, 사용시설점검원, 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자를 "각각" 갖추어야 한다고 규정하고 있는데, 여기에서 "각각"이란 사람이나 물건의 하나하나를 의미하는바[60], 결국 산업통상자원부령으로 정하는 자격을 갖춘 자는 같은 법 시행규칙 제47조 각 호에서 규정하고 있는 안전관리 책임자(제1호), 사용시설점검원(제2호), 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자(제3호)를 하나하나 별도로 모두 갖추어야 한다는 의미이므로, 안전관리 책임자와 사용시설점검원을 별도로 선임하지 않은 이 사안의 경우에는 같은 조 제1호 및 제2호의 요건을 모두 갖추었다고 보기 어렵습니다.

그리고 구 「도시가스사업법 시행규칙」(1999년 7월 1일 산업자원부령 제75호로 일부개정되기 전의 것을 말함) 제47조제5항 전단에서는 같은 항 제1호부터 제3호까지의 요건을 모두 갖춘 자가 일반도시가스사업자의 안전조치에 관한 업무를 대행할 수 있다고

59) 가스사용시설 안전관리업무를 대행하기 위하여 사용시설점검원이 1명 이상일 것이 요구되는 경우를 전제함
60) 국립국어원 표준국어대사전 참조

규정하면서, 같은 항 후단에서는 같은 항 제1호 및 제2호에 의한 기술인력의 자격요건이 공통된다 하더라도 각 호의 기술인력을 "각각" 갖추도록 규정하고 있었고, 같은 항 제3호 후단에서는 제1호 및 제2호의 규정에 의해 채용된 자로 하여금 안전관리업무를 수행하게 하는 경우에는 그 수만큼 같은 항 제3호 전단의 요건을 갖춘 자를 "채용한 것으로 본다"고 규정하고 있어, 하나하나 별도로 채용하여야 하는 기술인력(제1호 및 제2호)과 채용한 것으로 간주될 수 있는 기술인력(제3호)을 구분하여 규정하고 있었으나, 현행 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조에서는 같은 조 각 호에 따른 안전관리 책임자, 사용시설점검원, 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자를 각각 갖추어야 한다고 규정하고 있을 뿐, 구 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조제5항제3호와 같이 채용한 것으로 간주하는 규정을 두고 있지 않고 있으므로, 가스사용시설 안전관리업무를 대행하려는 자는 안전관리 책임자, 사용시설점검원, 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자를 별도로 선임하여야 할 것입니다.

또한 「도시가스사업법」에서 일정한 자격을 갖춘 자로 하여금 가스사용시설 안전관리업무의 일부를 대행할 수 있도록 한 것은 일반도시가스사업자가 안전관리업무를 효율적으로 수행하게 함으로써 도시가스사고의 예방과 통일된 가스안전관리체계를 구축하려는 취지이고[61], 이에 따라 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조에서는 가스사용시설 안전관리업무에 필요한 자격인 같은 조 각 호의 자격을 "각각" 갖추어야 그 업무를 대행할 수 있도록 규정하여 효율적이고 전문적인 안전관리업무 수행을 도모하려는 것인바, 만약 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조 각 호에서 요구되는 자격 등을 중복으로 소지하고 있는 자를 선임한 자가 같은 조 각 호의 요건을 모두 갖춘 것으로 보아 가스사용시설 안전관리업무를 대행할 수 있게 된다면, 동일인에게 과중한 업무를 부담시키게 되어 24시간 누설신고 긴급출동, 노후시설 개선권고, 사고예방 계도 등[62]과 같은 가스사용시설 안전관리업무의 안정성과 효율성을 저해할 수 있는 결과를 초래할 수 있는 점[63]에서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조제1호 및 제2호의 요건을 모두 갖추었다고 볼 수 없습니다.

---

61) 2004. 12. 31. 법률 제7282호로 일부개정된 「도시가스사업법」 개정이유 참조

62) 2004. 11. 3. 의안번호 제170716호로 발의된 도시가스사업법중개정법률안에 대한 국회 산업자원위원회 심사보고서 참조

63) 법제처 2014. 5. 16. 회신 14-0072 해석례 등 참조

나. 질의 나에 대해

먼저 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조에서는 「도시가스사업법」 제28조제1항에서 “산업통상자원부령으로 정하는 자격을 갖춘 자”란 같은 법 시행규칙 제47조 각 호의 요건을 모두 갖춘 자를 말하고, 이 경우 같은 조 각 호에 따른 안전관리 책임자, 사용시설점검원, 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자를 “각각” 갖추어야 한다고 규정하고 있는데, 여기에서 “각각”이란 사람이나 물건의 하나하나를 의미하는바[64], 결국 산업통상자원부령으로 정하는 자격을 갖춘 자는 같은 법 시행규칙 제47조 각 호에서 규정하고 있는 안전관리 책임자(제1호), 사용시설점검원(제2호), 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자(제3호)를 하나하나 별도로 모두 갖추어야 한다는 의미이므로, 사용시설점검원과 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자를 별도로 선임하지 않은 이 사안의 경우에는 같은 조 제2호 및 제3호의 요건을 모두 갖추었다고 보기 어렵습니다.

그리고 구 「도시가스사업법 시행규칙」(1999년 7월 1일 산업자원부령 제75호로 일부 개정되기 전의 것을 말함) 제47조제5항 전단에서는 같은 항 제1호부터 제3호까지의 요건을 모두 갖춘 자가 일반도시가스사업자의 안전조치에 관한 업무를 대행할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 후단에서는 같은 항 제1호 및 제2호에 의한 기술인력의 자격요건이 공통된다 하더라도 각 호의 기술인력을 “각각” 갖추도록 규정하고 있었고, 같은 항 제3호 후단에서는 제1호 및 제2호의 규정에 의해 채용된 자로 하여금 안전관리업무를 수행하게 하는 경우에는 그 수만큼 같은 항 제3호 전단의 요건을 갖춘 자를 “채용한 것으로 본다”고 규정하고 있어, 하나하나 별도로 채용하여야 하는 기술인력(제1호 및 제2호)과 채용한 것으로 간주될 수 있는 기술인력(제3호)을 구분하여 규정하고 있었으나, 현행 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조에서는 같은 조 각 호에 따른 안전관리 책임자, 사용시설점검원, 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자를 각각 갖추어야 한다고 규정하고 있을 뿐, 구 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조제5항제3호와 같이 채용한 것으로 간주하는 규정을 두고 있지 않고 있으므로, 가스사용시설 안전관리업무를 대행하려는 자는 안전관리 책임자, 사용시설점검원, 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자를 별도로 선임해야 할 것입니다.

또한 「도시가스사업법」에서 일정한 자격을 갖춘 자로 하여금 가스사용시설 안전관리업무의 일부를 대행할 수 있도록 한 것은 일반도시가스사업자가 안전관리업무를 효율적으로 수행하게 함으로써 도시가스사고의 예방과 통일된 가스안전관리체계를 구축하려는 취지이고[65], 이에 따라 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조에서는 가스사용시설 안전관리

64) 국립국어원 표준국어대사전 참조

업무에 필요한 자격인 같은 조 각 호의 자격을 "각각" 갖추어야 그 업무를 대행할 수 있도록 규정하여 효율적이고 전문적인 안전관리업무 수행을 도모하려는 것인바, 만약 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조 각 호에서 요구되는 자격 등을 중복으로 소지하고 있는 자를 선임한 자가 같은 조 각 호의 요건을 모두 갖춘 것으로 보아 가스사용시설 안전관리업무를 대행할 수 있게 된다면, 동일인에게 과중한 업무를 부담시키게 되어 24시간 누설신고 긴급출동, 노후시설 개선권고, 사고예방 계도 등[66]과 같은 가스사용시설 안전관리업무의 안정성과 효율성을 저해할 수 있는 결과를 초래할 수 있는 점[67]에서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조제2호 및 제3호의 요건을 모두 갖추었다고 볼 수 없습니다.

관계법령

도시가스사업법

제28조(가스사용시설의 안전관리업무 대행) ① 일반도시가스사업자는 제26조의 안전관리규정에 따른 가스사용시설의 안전관리업무를 효율적으로 수행하기 위하여 그 업무의 일부를 대행하게 할 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 자격을 갖춘 자(이하 "가스사용시설 안전관리업무 대행자"라 한다)로 하여금 그 업무를 대행하게 하여야 한다.

② 가스사용시설 안전관리업무 대행자는 가스사용시설 중 도시가스를 연료로 사용하는 보일러를 시공하여서는 아니 된다.

③ 산업통상자원부장관 또는 시·도지사는 가스사용시설 안전관리업무 대행자에 대하여 가스사용자에게 부담시키는 가스사용시설의 설치비용에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 가스사용자의 보호 및 공공의 이익증진을 위하여 필요하다고 인정하면 그 내용의 전부 또는 일부를 공표할 수 있다.

도시가스사업법 시행규칙

제47조(가스사용시설 안전관리업무 대행자의 자격) 법 제28조제1항에서 "산업통상자원부령으로 정하는 자격을 갖춘 자"란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자를 말한다. 이 경우 다음 각 호에 따른 안전관리 책임자, 사용시설점검원, 제1종 또는 제2종 가스시설시공업 등록을 위한 자격소지자를 각각 갖추어야 한다.

---

65) 2004. 12. 31. 법률 제7282호로 일부개정된 「도시가스사업법」 개정이유 참조

66) 2004. 11. 3. 의안번호 제170716호로 발의된 도시가스사업법중개정법률안에 대한 국회 산업자원위원회 심사보고서 참조

67) 법제처 2014. 5. 16. 회신 14-0072 해석례 등 참조

1. 안전관리 책임자(「국가기술자격법」에 따른 가스기능사 이상의 기술자격을 소지하거나 별표 14 제4호다목1)의 교육을 이수한 자를 말한다)가 1명 이상일 것
2. 사용시설점검원(별표 14 제4호나목2) 또는 같은 호 다목2)의 교육을 이수한 자를 말한다)이 가스사용시설 안전관리 수요자 3천 가구 또는 사업체마다 1명 이상일 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 가구 또는 사업체를 기준으로 할 수 있다.
   가. ~ 나. (생 략)
3. 「건설산업기본법 시행령」 제13조에 따른 제1종 또는 제2종 가스시설시공업에 등록한 자일 것

질의제목 12 ▶ 안건번호 24-0851

경상남도 창원시 – 「고압가스 안전관리법 시행령」 제5조의4제1항제5호의 "수요자"에 액화석유가스 충전사업자 또는 판매사업자가 포함되는지 여부(「고압가스 안전관리법 시행령」 제5조의4제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「고압가스 안전관리법」(이하 "고압가스법"이라 함) 제5조의4제1항 전단에서는 고압가스 운반차량을 이용하여 고압가스를 운반하려는 자는 시장·군수 또는 구청장에게 등록하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 등록의 기준과 대상범위는 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제5조의4제1항에서는 같은 법 제5조의4제2항에 따른 고압가스 운반자의 등록 대상범위를 정하면서, 같은 항 제5호에서는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제3조제1항 제1호가목에 따른 용기 충전사업자(가목) 등에 해당하는 자가 수요자에게 용기로 액화석유 가스를 운반하는 차량으로 고압가스를 운반하는 것을 규정하고 있는 한편,

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 "액화석유가스법"이라 함) 제5조제1항에서는 액화석유가스 충전사업 등을 하려는 자는 그 사업소마다 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 함)의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 전단에서는 액화석유가스 판매사업을 하려는 자는 판매소마다 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제3조 제1항에서는 액화석유가스 충전사업 허가, 액화석유가스 판매사업 허가 등의 종류 및 대상 범위를 정하면서, 같은 항 제1호가목에서는 액화석유가스 충전사업 중 하나로 액화석유가스를 용기[68]에 충전하여 공급하는 사업[69]을 '용기 충전사업'으로 규정하고 있고, 같은 항 제4호에서는 용기에 충전된 액화석유가스를 판매하는 사업(가목)인 용기 판매사업 등을 '액화석유가스 판매사업'으로 규정하고 있는바,

고압가스법 시행령 제5조의4제1항제5호 각 목 외의 부분 본문의 "수요자"에 액화석유

68) 자동차에 고정된 용기, 내용적(內容積) 1리터 미만의 용기 및 용기내장형 가스난방기용 용기는 제외함
69) 자동차에 고정된 탱크를 이용하여 산업통상자원부령으로 정하는 탱크에 공급하는 것을 포함함

가스법 시행령 제3조제1항제1호가목에 따른 용기 충전사업자 또는 같은 항 제4호에 따른 액화석유가스 판매사업자(이하 “용기충전사업자등”이라 함)가 포함되는지[70][71]?

02 회답

고압가스법 시행령 제5조의4제1항제5호 각 목 외의 부분 본문의 “수요자”에 용기충전사업자등은 포함되지 않습니다.

03 이유

먼저 고압가스법 시행령 제5조의4제1항제5호가목에서는 같은 법 제5조의4제2항에 따른 고압가스 운반자의 등록 대상 중 하나로 액화석유가스법 시행령 제3조제1항제1호가목에 따른 용기 충전사업자가 “수요자”에게 용기로 액화석유가스를 운반하는 차량으로 고압가스를 운반하는 경우를 규정하고 있고, 액화석유가스법 제2조제4호에서는 “액화석유가스 충전사업”이란 저장시설에 저장된 액화석유가스를 용기(容器)에 충전하거나 자동차에 고정된 탱크에 충전하여 “공급”하는 사업을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제8호에서는 “액화석유가스 판매사업”이란 용기에 충전된 액화석유가스를 “판매”하거나 자동차에 고정된 탱크에 충전된 액화석유가스를 산업통상자원부령으로 정하는 규모 이하의 저장 설비에 “공급”하는 사업을 말한다고 규정하고 있는데, 일반적으로 “수요자”란 필요해서 사거나 얻고자 하는 사람을 의미하고, “판매자”는 상품 따위를 파는 사람이나 그 기관을 의미하는 것으로[72], 고압가스법 시행령 제5조의4제1항제5호 각 목 외의 부분 본문에 따른 “수요자”는 액화석유가스의 소비 등을 목적으로 이를 구입하는 자로서, 액화석유가스를 공급하는 사업을 하는 자인 액화석유가스 충전사업자나 판매사업자와는 구별되는 개념이라고 할 것인바, 같은 규정에 따른 “수요자”의 범위에 용기충전사업자등은 포함되지 않는다고 보는 것이 문언의 통상적인 의미에 부합하는 해석입니다.

---

70) 충전사업자가 최종 수요자(액화석유가스법 시행령 제3조제1항제1호가목에 따른 용기 충전사업자 또는 같은 항 제4호에 따른 판매사업자가 아닌 액화석유가스를 최종적으로 소비 등을 하기 위하여 액화석유가스를 구입하는 자를 말함)에게 용기로 액화석유가스를 운반하는 차량으로 고압가스를 운반하지 않는 경우를 전제로 함

71) 충전사업자가 「자동차관리법」 제3조제1항제5호에 따른 이륜자동차를 이용하여 액화석유가스를 운반하는 경우는 제외함

72) 국립국어원 표준국어대사전 참조

그리고 고압가스법 시행령 제5조의4제1항제5호의 규정은 구 고압가스법 시행령(2014년 7월 21일 대통령령 제25491호로 일부개정된 것을 말함)에서 처음 도입되었는데, 구 고압가스법 시행령 입법예고 공고문[73]에 따르면 당초 액화석유가스사업법 시행령에 따른 액화석유가스 충전사업자 또는 같은 법 시행령에 따른 액화석유가스 판매사업자가 용기로 액화석유가스를 운반하는 차량으로 고압가스를 운반하는 경우를 고압가스 운반자의 등록 대상으로 하였으나, 용기충전사업자등 상호 간에 용기로 액화석유가스를 운반하는 경우는 등록 대상에서 제외하기 위하여, 구 고압가스법 시행령에서는 고압가스 운반자의 등록 대상범위 중 하나로 용기 충전사업자가 "수요자"에게 용기로 액화석유가스를 운반하는 경우로 규정하게 된 것인바, 이러한 법령의 개정 과정에 비추어 보면, 고압가스법 시행령 제5조의4 제1항제5호 각 목 외의 부분 본문의 "수요자"에 용기충전사업자등은 포함되지 않는다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다고 할 것인데[74], 고압가스법 제39조제5호에서는 같은 법 제5조의4제1항 전단에 따른 등록을 하지 아니하고 고압가스를 운반한 자에 대하여 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있는바, 고압가스법 시행령 제5조의4제1항제5호 본문의 "수요자"에 용기충전사업자등이 포함된다고 해석하는 것은 명시적인 규정이나 합리적인 근거 없이 규제의 범위 및 처벌 대상을 확대하는 해석으로서 타당하지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 고압가스법 시행령 제5조의4제1항제5호 각 목 외의 부분 본문의 "수요자"에 용기충전사업자등은 포함되지 않습니다.

73) 산업통상자원부 공고 제2014-180호 참조

74) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

관계법령

고압가스 안전관리법

제5조의4(고압가스 운반자의 등록) ① 고압가스 운반차량을 이용하여 고압가스를 운반하려는 자는 시장·군수 또는 구청장에게 등록하여야 한다. 등록한 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따른 등록의 기준과 대상범위는 대통령령으로 정하고, 고압가스 운반차량에 필요한 시설기준과 기술기준은 산업통상자원부령으로 정한다.

고압가스 안전관리법 시행령

제5조의4(고압가스 운반자의 등록 대상범위 등) ① 법 제5조의4제2항에 따른 고압가스 운반자의 등록 대상범위는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 차량(이하 "고압가스운반차량"이라 한다)으로 고압가스를 운반하는 것으로 한다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 수요자에게 용기로 액화석유가스를 운반하는 차량. 다만, 「자동차관리법」 제3조제1항제5호에 따른 이륜자동차를 이용하여 액화석유가스를 운반하는 경우 해당 이륜자동차는 제외한다.
   가. 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」(이하 이 조에서 "영"이라 한다) 제3조제1항제1호가목에 따른 용기 충전사업자
   나. 영 제3조제1항제1호라목에 따른 가스난방기용기 충전사업자
   다. 영 제3조제1항제4호에 따른 액화석유가스 판매사업자
6. (생 략)

② (생 략)

액화석유가스의 안전관리 및 사업법

제5조(사업의 허가 등) ① 액화석유가스 충전사업, 가스용품 제조사업 또는 액화석유가스 집단공급사업을 하려는 자는 그 사업소마다 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)의 허가를 받아야 한다.

② 액화석유가스 판매사업을 하려는 자는 판매소마다 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. 이 경우 허가를 받은 액화석유가스 판매사업자가 액화석유가스를 용기로 판매하는 경우에는 그 허가를 받은 지역의 특별자치시·특별자치도·시·군·구(구는 자치구를 말하며, 이하 "시·군·구"라 한다)를 관할구역으로 하는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 지역에서만 판매할 수 있다. 다만, 다른 시·도 관할구역에 있는 시·군·구 지역이라도 그 시·군·구가 허가를 받은 지역의 시·군·구와 연접한 경우에는 판매할 수 있다.

③ ~ ⑨ (생 략)

액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령

제3조(액화석유가스사업 허가의 종류 및 대상 범위) ① 법 제5조제1항 및 제2항에 따른 액화석유가스 충전사업 허가, 가스용품 제조사업 허가, 액화석유가스 집단공급사업 허가 및 액화석유가스 판매사업 허가의 종류 및 대상 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 액화석유가스 충전사업: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업. 다만, 용기 또는 저장능력이 3톤 미만인 탱크로 가스라이터에 액화석유가스를 충전하는 경우와 「고압가스 안전관리법」에 따른 고압가스 제조(액화석유가스 제조만 해당한다)허가를 받은 자가 그 허가받은 내용에 따라 액화석유가스를 충전하는 경우는 제외한다.
   가. 용기 충전사업: 액화석유가스를 용기[자동차에 고정된 용기, 내용적(內容積) 1리터 미만의 용기 및 용기내장형 가스난방기용 용기는 제외한다]에 충전하여 공급하는 사업(자동차에 고정된 탱크를 이용하여 산업통상자원부령으로 정하는 탱크에 공급하는 것을 포함한다)
2.·3. (생 략)
4. 액화석유가스 판매사업: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업
   가. 용기 판매사업: 용기에 충전된 액화석유가스를 판매하는 사업
   나. 용기 및 자동차에 고정된 탱크 판매사업: 다음 1) 및 2)의 사업을 함께 하는 사업
      1) 가목의 사업
      2) 자동차에 고정된 탱크(탱크의 규모 등이 산업통상자원부령으로 정하는 기준에 맞는 것으로 한정한다)에 충전된 액화석유가스를 산업통상자원부령으로 정하는 규모 이하의 저장설비에 공급하는 사업

② (생 략)

제2절 중소기업

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0838

민원인 – 법인인 중소기업자의 창업의 범위에서 제외되는 경우가 다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 '기존 사업과 같은 종류의 사업'을 개시하는 것으로 한정되는지 여부(「중소기업창업 지원법 시행령」 제2조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

2020년 4월 7일 법률 제17244호로 일부개정되어 2020년 10월 8일 시행된 「중소기업창업 지원법」(이하 "구 중소기업창업법"이라 함) 제2조제1호에서는 "창업"이란 중소기업을 새로 설립하는 것을 말한다고 규정하면서, 이 경우 창업의 범위는 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 구 중소기업창업법 시행령(2020. 10. 8. 대통령령 제31108호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제2조제1항 각 호 외의 부분에서 "창업"은 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것으로서 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 것을 말한다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서는 "법인인 중소기업자가 의결권 있는 발행주식[75] 총수의 100분의 30 이상[76]을 소유하는 경우로서 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 가장 많은 주식의 지분을 소유하는 다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것"을 규정하고 있는바,

법인인 중소기업자의 "창업"에서 제외되는 구 중소기업창업법 시행령 제2조제1항제5호에 따른 '다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것'이 '다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 기존 사업과 같은 종류의 사업을 개시하는 것'으로 한정되는지?

75) 출자지분을 포함하며, 이하 같음.

76) 해당 법인과 그 임원이 소유하고 있는 주식을 합산하여 산정하며, 이하 같음.

02 회답

구 중소기업창업법 시행령 제2조제1항제5호에 따른 '다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것'은 '다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 같은 종류의 사업을 개시하는 것'으로 한정되지 않습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언이 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[77], 구 중소기업창업법 시행령 제2조제1항제5호에서는 창업에 해당하지 않는 것 중의 하나로 '법인인 중소기업자'가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 30 이상을 소유하는 경우로서 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 가장 많은 주식의 지분을 소유하는 다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 '사업'을 개시하는 것을 규정하고 있는데, 같은 항 제4호에서 '개인인 중소기업자'가 일정한 주식 소유 요건[78]을 갖추어 '기존 사업과 같은 종류의 사업'을 개시하는 것을 창업에 해당하지 않는 것의 하나로 규정한 것과 달리, 법인인 중소기업자의 경우는 기존 사업과 같은 종류의 사업인지 여부에 관계 없이 일정한 주식 소유 요건을 갖추어 "다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것"으로 규정하고 있으므로, 구 중소기업창업법 시행령 제2조제1항제5호에 따라 일정한 주식 소유 요건을 갖추어 다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하면 새로 설립된 다른 법인인 중소기업이 개시하는 사업이 기존 사업과 같은 종류의 사업인지 다른 종류의 사업인지 여부와 상관없이 "창업"에 해당하지 않는다는 점은 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 구 중소기업창업법 시행령 제2조제1항제5호는 2020년 10월 8일 대통령령 제31108호로 종전의 「중소기업창업 지원법 시행령」을 일부개정하면서, 창업에서 제외되는 승계 방식의 사업 개시 형태를 명확히 규정하기 위하여 "창업"에 해당하지 않는 것으로 보는 사업 개시 형태를 상속·증여로 사업을 계속하는 경우(제1호), 개인인 중소기업자가 기존 사업을 계속 영위하면서 단독으로 또는 친족과 합하여 의결권 있는 발행주식 총수의 30퍼센트

77) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

78) 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 30 이상을 소유하거나 의결권 있는 방행주식 총수를 기준으로 가장 많은 주식의 지분을 소유할 것

이상을 소유하거나 가장 많은 주식 지분을 소유하는 법인인 중소기업을 설립하여 기존 사업과 같은 종류의 사업을 개시하는 경우(제4호), 법인인 중소기업자가 의결권 있는 발행주식 총수의 30퍼센트 이상을 소유하는 경우로서 가장 많은 주식 지분을 소유하는 다른 법인인 중소기업을 설립하여 사업을 개시하는 경우(제5호) 등으로 명확하게 규정하면서 신설된 규정으로,[79] 법인인 중소기업자의 경우 자회사 성격의 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 경우에는 사업의 종류와 관계 없이 중소기업창업 지원법령상 각종 지원 대상이 되는 창업으로 인정하지 않으려는 의도를 반영한 것[80]인바, 구 중소기업창업법 시행령 제2조제1항제5호에 따른 '다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것'을 '다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 같은 종류의 사업을 개시하는 것'으로 한정하여 해석함으로써, 다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 다른 종류의 사업을 개시하는 경우도 "창업"의 범위에 포함되는 것으로 해석하는 것은 해당 규정의 입법연혁 및 개정취지에도 부합하지 않습니다.

따라서 구 중소기업창업법 시행령 제2조제1항제5호에 따른 '다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것'은 '다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 같은 종류의 사업을 개시하는 것'으로 한정되지 않습니다.

관계법령

중소기업창업 지원법(2020. 4. 7. 법률 제17244호로 일부개정되어 2020. 10. 8. 시행된 것)

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "창업"이란 중소기업을 새로 설립하는 것을 말한다. 이 경우 창업의 범위는 대통령령으로 정한다.

1의2. ~ 8. (생 략)

중소기업창업 지원법 시행령(2020. 10. 8. 대통령령 제31108호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것)

제2조(창업의 범위) ① 「중소기업창업 지원법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호에 따른 창업은 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 것을 말한다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 개인인 중소기업자가 기존 사업을 계속 영위하면서 단독으로 또는 「중소기업기본법 시행령」

79) 2020. 2. 18. 대통령령 제30436호로 일부개정되어 2020. 2. 21. 시행된 중소기업창업 지원법 시행령 일부개정령 조문별 제·개정이유서 참조

80) '중소기업창업 지원법 시행령 및 시행규칙 개정계획(중소벤처기업부 보고자료)' 참조

제2조제5호에 따른 친족과 합하여 의결권 있는 발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다) 총수의 100분의 30 이상을 소유하거나 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 가장 많은 주식의 지분을 소유하는 법인인 중소기업을 설립하여 기존 사업과 같은 종류의 사업을 개시하는 것

5. 법인인 중소기업자가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 30 이상(해당 법인과 그 임원이 소유하고 있는 주식을 합산한다)을 소유하는 경우로서 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 가장 많은 주식의 지분을 소유하는 다른 법인인 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것
6. (생 략)

② 제1항 각 호에 따른 같은 종류의 사업의 범위는 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 작성·고시하는 한국표준산업분류(이하 "한국표준산업분류"라 한다)상의 세세분류를 기준으로 한다. 이 경우 기존 업종에 다른 업종을 추가하여 사업을 하는 경우에는 추가된 업종의 매출액이 총 매출액의 100분의 50 미만인 경우에만 같은 종류의 사업을 계속하는 것으로 본다.

③ 제2항 후단에 따른 추가된 업종의 매출액 또는 총 매출액은 추가된 날이 속하는 분기의 다음 2분기 동안의 매출액 또는 총 매출액을 말한다.

질의제목 2 ▶ 안건번호 24-0077

민원인 – 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제5조제1항에 따른 중소기업제품의 의미(「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제5조제1항 등 관련)

01 질의요지

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」(이하 "판로지원법"이라 함) 제5조제1항 전단에서는 대통령령으로 정하는 공공기관[81]의 장은 예산과 사업계획을 고려하여 중소기업제품의 구매 증대를 위한 구매계획과 전년도 구매실적을 중소벤처기업부장관에게 통보해야 한다고 규정하고 있는바,

판로지원법 제5조제1항에 따른 중소기업제품의 구매실적 중 물품에 관한 구매실적[82]이 반드시 중소기업자[83]가 '생산'한 물품에 대한 구매실적으로만 한정되는지?

02 회답

판로지원법 제5조제1항에 따른 중소기업제품의 구매실적 중 물품에 관한 구매실적은 반드시 중소기업자가 생산한 물품에 대한 구매실적으로만 한정되는 것은 아닙니다.

03 이유

판로지원법 제4조제1항에서는 공공기관의 장은 물품·용역 및 공사(이하 "제품"이라 함)에 관한 조달계약을 체결하려는 때에는 중소기업자의 수주(受注) 기회가 늘어나도록 해야 한다고

81) 판로지원법 제2조제2호의 공공기관을 말하며, 이하 같음.

82) 판로지원법 시행령 제5조제1항제1호·제2호 및 제6호에 따른 제품의 구매실적 중 물품에 관한 구매실적으로 한정하며, 이하 같음.

83) 판로지원법 제2조제1호의 중소기업자를 말하며, 이하 같음.

규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 공공기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품 및 용역[84]에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결해야 한다고 규정하고 있는 한편, 판로지원법 제5조제1항 전단에서는 대통령령으로 정하는 공공기관의 장은 예산과 사업계획을 고려하여 중소기업제품의 구매 증대를 위한 구매계획과 전년도 '구매실적'을 중소벤처기업부장관에게 통보해야 한다고 규정하고 있는데, 같은 법 시행령 제5조제2항제1호에서는 그 '중소기업제품 구매실적'에 포함되어야 하는 사항으로 같은 조 제1항 각 호에 따른 제품의 구매실적[85]을 규정하고 있습니다.

그런데 판로지원법 시행령 제5조제1항제1호부터 제6호까지에서는 총 구매액에 대한 중소기업제품 구매목표비율과 구매목표액(제1호), 물품별·공사별·용역별 구매목표액(제2호), 판로지원법 제14조제1항에 따른 우선구매 대상 기술개발제품의 우선구매 목표비율과 구매목표액(제3호), 여성기업제품의 구매목표비율과 구매목표액(제4호), 장애인기업제품의 구매목표비율과 구매목표액(제5호) 및 그 밖에 중소벤처기업부장관이 중소기업제품의 구매 증대를 위하여 필요하다고 인정하는 사항(제6호)을 각각 규정하고 있는바, 명시적으로 중소기업자가 '생산'한 제품에 대한 것으로 한정[86]되는 같은 항 제3호부터 제5호까지에 따른 제품의 구매실적과는 달리, 같은 항 제1호·제2호 및 제6호에 따른 제품의 구매실적은 "중소기업제품"의 구매실적이라고 할 것인데, 판로지원법 제4조제1항에서 물품·용역 및 공사를 "제품"으로 약칭하고 있을 뿐, 판로지원법령에서는 "중소기업제품"의 의미나 범위에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안에서는 "중소기업제품" 중 물품에 해당하는 것이 반드시 중소기업자가 '생산'한 물품으로 한정되는지 여부가 문제됩니다.

먼저 판로지원법 제2조제1호에서는 "중소기업자"를 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자(가목) 또는 「중소기업협동조합법」 제3조에 따른 중소기업협동조합(나목)에 해당하는 자로 정의하고 있는데, 「중소기업기본법」 제2조에서는 중소기업자를 매출액·자산총액 등의 요건을 갖추고 영리를 목적으로 사업을 하는 기업 등으로 규정하고 있을 뿐, 물품을 '생산'하는 자로 한정하고 있지 않고, 「중소기업협동조합법」에서도 중소기업협동조합은 조합원 또는 회원의 상호부조를 목적으로 "생산, 가공, 수주, 판매, 구매, 보관, 운송, 환경 개선, 상표, 서비스 등의 공동 사업"을 할 수 있다고 규정하고 있는바(제7조제1항 및

84) 판로지원법 제6조제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품은 제외함.

85) 제품의 구매실적이 처음의 목표에 미달하는 경우에는 그 사유를 포함하며, 이하 같음.

86) 제3호의 경우 판로지원법 제13조, 제4호의 경우 「여성기업지원에 관한 법률」 제9조, 제5호의 경우 「장애인기업활동 촉진법」 제9조의2 참조

제35조제1항제1호), 판로지원법에 따른 중소기업자의 범위에서 물품을 '유통'·'판매'하는 자가 제외된다고 할 수는 없습니다.

그리고 판로지원법 제5조제1항에 따른 공공기관의 구매계획과 구매실적과 관련하여 같은 법 제4조에서는 "구매 증대"라는 제목 하에 제1항에서는 공공기관의 장이 제품에 관한 조달계약을 체결할 때 '중소기업자가 그 계약을 수주'할 수 있도록 해야 한다고 규정하면서 그 계약의 대상을 '제품'이라고만 규정하고 있지, 중소기업자가 직접 '생산'한 제품으로 규정하고 있지 않은 점, 제2항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제2조의2제1항에서는 일정 금액 미만의 물품 및 용역에 대하여 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결해야 한다고 규정하면서, 이 경우 중소기업제품 공공구매 종합정보망을 통해 중소기업자 여부를 확인하도록 하여 '조달계약의 당사자'가 중소기업자인지만을 확인하도록 하고 있을 뿐, 해당 제품이 중소기업자가 생산한 제품인지 확인하도록 규정하고 있지는 않은 점 등에 비추어 볼 때, 구매 증대 대상 중소기업제품이 반드시 중소기업자가 생산하는 제품으로 한정된다고 볼 수는 없을 것이므로, 판로지원법에 따른 중소기업자가 유통·판매하는 물품에 관한 조달계약이라면 그 물품이 중소기업자가 생산한 것인지 여부와 관계 없이 "중소기업제품 구매 증대"를 위한 계약에 해당된다고 할 것입니다.

또한 판로지원법 제6조제1항에서는 중소벤처기업부장관은 "중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품"으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정할 수 있다고 규정하고 있는데, 이와 같이 중소기업자간 경쟁 제품에 대해서는 명시적으로 중소기업자가 "직접 생산·제공하는 제품"이라고 규정하고 있는 것과는 달리, 생산의 주체에 관하여 별도의 제한을 두지 않은 같은 법 제5조제1항에 따른 공공기관의 우선 구매 대상으로서의 중소기업제품은 중소기업이 생산하는 것으로만 한정되지 않는다고 해석하는 것이 판로지원법령의 체계에 부합하는 해석입니다.

따라서 판로지원법 제5조제1항에 따른 중소기업제품의 구매실적 중 물품에 관한 구매실적은 반드시 중소기업자가 생산한 물품에 대한 구매실적으로만 한정되는 것은 아닙니다.

관계법령

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률

제4조(구매 증대) ① 공공기관의 장은 물품·용역 및 공사(이하 "제품"이라 한다)에 관한 조달계약을 체결하려는 때에는 중소기업자의 수주(受注) 기회가 늘어나도록 하여야 한다.

② 공공기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품 및 용역(제6조제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품은 제외한다)에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 한다.

③ (생 략)

제5조(구매계획 및 구매실적의 작성) ① 대통령령으로 정하는 공공기관의 장은 예산과 사업계획을 고려하여 중소기업제품의 구매 증대를 위한 구매계획과 전년도 구매실적을 중소벤처기업부장관에게 통보하여야 한다. 이 경우 구매계획에 대통령령으로 정하는 중소기업제품 구매목표비율을 제시하여야 한다.

② ~ ⑦ (생 략)

중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령

제5조(구매계획과 구매실적에 포함될 사항) ① 법 제5조제1항에 따른 구매계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 총 구매액에 대한 중소기업제품 구매목표비율과 구매목표액
2. 물품별·공사별·용역별 구매목표액
3. 법 제14조제1항에 따른 우선구매 대상 기술개발제품(이하 "우선구매 대상 기술개발제품"이라 한다)의 우선구매 목표비율과 구매목표액
4. 「여성기업지원에 관한 법률」 제9조제3항에 따른 여성기업제품의 구매목표비율과 구매목표액
5. 「장애인기업활동 촉진법」 제9조의2제3항에 따른 장애인기업제품의 구매목표비율과 구매목표액
6. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 중소기업제품의 구매 증대를 위하여 필요하다고 인정하는 사항

② 법 제5조제1항에 따른 중소기업제품 구매실적에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 제1항 각 호에 따른 제품의 구매실적(제품의 구매실적이 처음의 목표에 미달하는 경우에는 그 사유를 포함한다)
2. 전년도 공사의 구매실적이 1천억원 이상인 공공기관은 법 제12조제2항에 따라 중소벤처기업부장관이 선정하여 고시한 제품의 제품별 직접 구매실적

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0552

인천광역시 – 「지역신용보증재단법」 제40조제3항에서 규정하고 있는 "그 업무"의 범위(「지역신용보증재단법」 제40조제3항 등 관련)

01 질의요지

「지역신용보증재단법」 제17조에서 "재단[87]은 다음 각 호의 업무를 수행한다"고 규정하면서 같은 조 제8호에서는 "국가, 지방자치단체, 공공기관 등이 위탁하는 사업 중 소기업등[88] 지원 또는 그에 부수되는 사업으로서 중소벤처기업부장관 또는 시·도지사의 승인을 받은 사업"을 규정하고 있고, 같은 법 제40조제3항에서 "재단은 그 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융회사등[89], 중앙회[90], 한국자산관리공사[91] 또는 신용정보회사[92]에 위탁할 수 있다"고 규정하고 있는바,

「지역신용보증재단법」 제40조제3항에서 규정하고 있는 "그 업무"에 같은 법 제17조제8호에서 규정하고 있는 사업이 모두 포함되는지 아니면 그 중 비금전적 지원 사업은 제외되는지?

02 회답

「지역신용보증재단법」 제40조제3항에서 규정하고 있는 "그 업무"에는 같은 법 제17조제8호에서 규정하고 있는 사업이 모두 포함됩니다.

87) 「지역신용보증재단법」에 따라 설립된 신용보증재단을 말하며, 이하 같음

88) 「지역신용보증재단법」 제2조제4호바목에서 규정하고 있는 소기업등을 의미하며, 이하 같음

89) 「은행법」 제2조제1항제2호에 따른 은행, 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행 등 「지역신용보증재단법」 제2조제4호에 따른 금융회사등을 말하며, 이하 같음

90) 신용보증재단중앙회를 말하며(「지역신용보증재단법」 제35조 등 참조), 이하 같음

91) 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제6조에 따른 한국자산관리공사를 말하며, 이하 같음

92) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 신용정보회사를 말하며, 이하 같음

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것이고[93], 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용되어야 할 것인바[94], 「지역신용보증재단법」 제17조에서 "업무"라는 제목으로 "재단은 다음 각 호의 업무를 수행한다"고 규정하고 있고, 같은 조 각 호에서는 기본재산의 관리(제1호), 신용보증(제2호), 신용조사 및 신용정보의 관리(제3호), 경영지도(제4호), 국가, 지방자치단체, 공공기관 등이 위탁하는 사업 중 소기업등 지원 또는 그에 부수되는 사업으로서 중소 벤처기업부장관 또는 시·도지사의 승인을 받은 사업(제8호) 등 재단의 업무를 규정하고 있으며, 같은 법 제40조제3항에서 재단은 그 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융회사등, 중앙회, 한국자산관리공사 또는 신용정보회사에 위탁할 수 있다고 규정하고 있는데, 문언상 "그 업무"에서 "그"는 바로 앞에 규정된 "재단"을 가리키는 것으로 "그 업무"는 "재단의 업무"를 의미하고[95], 이는 같은 법 제17조 각 호에서 규정하고 있는 재단의 업무와 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 결국 같은 법 제40조제3항의 "그 업무"에는 같은 법 제17조제8호에서 규정하고 있는 사업이 모두 포함된다 할 것입니다.

그리고 행정권한의 위탁이란 법령에 따라 권한의 일부를 다른 행정기관이나 지방자치단체, 민간 기관 등에게 맡기는 것으로서[96] 이처럼 업무의 일부를 위탁하기 위해서는 별도의 법령상 근거가 필요하고, 그 위탁의 근거가 되는 법령에서는 위탁할 수 있는 업무, 수탁기관 등 위탁에 관한 사항을 구체적으로 규정해야 하는데[97], 「지역신용보증재단법」 제40조제1항 및 제2항에서는 중소벤처기업부장관이 시·도지사에게 위임할 수 있는 권한을 같은 법 제17조제6호, 제30조제1항, 제36조에 따른 권한으로 규정하고 있고, 같은 법 제40조제4항에서는 중앙회의 회장이 위탁할 수 있는 중앙회의 업무를 "신용보증 업무"의 전부 또는 일부로 규정하여 각각 위탁하는 업무의 범위를 정하고 있는 것과는 달리, 같은 조 제3항에서는 재단이 금융회사등, 중앙회, 한국자산관리공사, 신용정보회사에 위탁할 수 있는 업무를 한정하지 아니하고 "그 업무"로만 규정하고 있는바, "그 업무"는 같은 법 제17조제8호를 포함하여 같은 조에서

93) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
94) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조
95) 국립국어원 표준국어대사전 및 법제처 2024. 7. 5. 회신 24-0369 해석례 참조
96) 법제처 2015. 11. 24. 회신 15-0730 해석례 참조
97) 법제처 2013. 10. 25. 회신 13-0417 해석례, 법제처 2016. 5. 20. 회신 16-0131 해석례 등 참조

규정하고 있는 재단의 업무를 의미한다고 해석하는 것이 법률의 규정 체계에도 부합합니다.

따라서 「지역신용보증재단법」 제40조제3항에서 규정하고 있는 그 업무에는 같은 법 제17조제8호에서 규정하고 있는 사업이 모두 포함됩니다.

관계법령

지역신용보증재단법

제17조(업무) 재단은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 기본재산의 관리
2. 신용보증
3. 신용조사 및 신용정보의 관리
4. 경영지도
5. 구상권의 행사
6. 제2호 및 제3호의 업무에 부수되는 업무로서 중소벤처기업부장관의 승인을 받은 것
7. 제1호·제4호 및 제5호의 업무에 부수되는 업무로서 시·도지사의 승인을 받은 것
8. 국가, 지방자치단체, 공공기관 등이 위탁하는 사업 중 소기업등 지원 또는 그에 부수되는 사업으로서 중소벤처기업부장관 또는 시·도지사의 승인을 받은 사업
9. 다른 법령에서 재단의 사업으로 정하는 사업

제40조(위임 등) ① 제17조제6호 및 제30조제1항에 따른 중소벤처기업부장관의 권한은 그 전부 또는 일부를 시·도지사에 위임할 수 있다.

② 중소벤처기업부장관은 필요하다고 인정하는 경우에는 제36조에 따른 재단에 대한 감독권의 일부를 시·도지사에게 위임할 수 있다.

③ 재단은 그 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융회사등, 중앙회, 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제6조에 따른 한국자산관리공사 또는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 신용정보회사에 위탁할 수 있다.

④ 중앙회의 회장은 신용보증 업무의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융회사등, 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제6조에 따른 한국자산관리공사 또는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 신용정보회사에 위탁할 수 있다.

⑤ (생 략)



교육·여성가족·문화체육관광

제1절 교육
제2절 여성가족·청소년
제3절 문화체육관광

제1절 교육

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0938

전라남도 담양군 – 「관광진흥법」에 따른 사업계획의 승인으로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위허가가 의제되는 경우의 재해영향평가 협의 대상 판단 기준(「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 등)

01 질의요지

「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호에서는 재해영향평가 협의 대상인 개발사업을 "「관광진흥법」 제15조에 따른 관광사업계획"[아목2)] 및 "「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제56조에 따른 개발행위의 허가"[가목1)] 등으로 규정하면서, 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고 제1호 본문에서는 재해영향평가 협의를 해야 하는 개발사업의 범위를 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터(국토계획법 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위 허가의 규모를 초과하는 경우로 한정[1]함) 이상인 경우 등으로 한다고 규정하고 있고, 국토계획법 시행령 제55조제1항제1호가목에서는 자연녹지지역[2]의 개발행위허가 규모를 1만제곱미터 미만이라고 규정하고 있는 한편,

「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고 제4호에서는 '다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업으로서 개발사업의 대상 규모(부지면적)가 비고 제1호에 따른 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위에 해당하는 경우에는 재해영향평가 협의를 하여야 한다'고 규정하고 있는바,

「관광진흥법」 제15조에 따라 승인받으려는 사업계획(이하 "관광사업계획"이라 함)에 같은

1) 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에는 1만제곱미터를 기준으로 함.
2) 국토계획법 시행령 제30조제1항제4호다목에 따른 자연녹지지역을 말하며, 이하 같음.

법 제16조제1항제8호에 따라 관광사업계획 승인 시 의제되는 국토계획법 제56조에 따른 개발행위허가(이하 “개발행위허가”라 함) 사항이 포함되어 있는 경우로서, 그 관광사업계획 승인 및 개발행위허가 의제 대상 개발사업이 자연녹지지역에서 이루어지는 부지면적 5천제곱미터 이상 1만제곱미터 미만의 개발사업인 경우, 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고 제1호에 따라 재해영향평가 협의 대상 개발사업이 되는지, 아니면 의제되는 개발행위허가에 관한 기준인 같은 비고 제4호만을 적용하여 해당사업은 재해영향평가 협의 대상 개발사업에서 제외되는지?

02 회답

이 사안의 경우, 해당 개발사업은 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호가 비고 제1호에 따라 재해영향평가 협의 대상 개발사업에 해당합니다.

03 이유

「자연재해대책법」 제4조제1항에서는 관계행정기관의 장[3]은 자연재해에 영향을 미치는 개발사업의 허가등[4]을 하려는 경우에는 그 개발사업의 허가등을 하기 전에 행정안전부 장관과 재해영향평가에 관한 협의를 해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제5조제1항에서는 같은 법 제4조에 따라 재해영향평가등의 협의를 해야 하는 개발사업은 같은 항 각 호와 같다고 규정하면서, 제1호에서는 국토·지역 계획 및 도시의 개발을, 같은 항 제8호에서는 관광단지의 개발을 각각 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제6조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 별표 1 제2호에서는 재해영향평가 협의 대상인 개발사업을 “「관광진흥법」 제15조에 따른 관광사업계획”[아목2)] 및 “국토계획법 제56조에 따른 개발행위의 허가”[가목1)] 등으로 규정하고 있고, 같은 법 시행령 별표 1 제2호 비고 제1호 본문에서는 재해영향평가 협의를 해야 하는 개발사업의 범위를 “개발사업의 부지면적이 5천제곱미터 이상”인 경우 등으로 하되, 괄호를 두어 “국토계획법 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우로 한정”한다고 규정하고 있으며, 같은 항 제1호가목에서는 자연녹지지역에 대한 개발행위허가 규모를 1만제곱미터 미만으로

3) 관계 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 특별지방행정기관의 장을 말하며, 이하 같음.

4) 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등을 말하며, 이하 같음.

규정하고 있습니다.

그렇다면 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 및 같은 호 비고 제1호 본문에 따라 개발사업이 「관광진흥법」 제15조에 따른 관광사업계획을 승인 받아 시행하는 사업으로서 부지면적이 5천제곱미터 이상인 개발사업이거나 국토계획법 제56조에 따른 개발행위허가 대상 개발사업으로서 자연녹지지역에서 이루어지는 부지면적 1만제곱미터 이상인 개발사업인 경우에는 재해영향평가 협의 대상이 되는바, 이 사안과 같이 국토계획법령상 자연녹지지역에서 이루어지는 개발사업이라 하더라도 「관광진흥법」 제15조에 따른 관광사업계획 승인 대상 개발사업으로서, 그 부지면적이 5천제곱미터 이상이라면 그 개발사업은 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호아목 및 같은 호 비고 제1호 본문의 괄호 외의 부분에 따라 자연재해대책법령에 따른 재해영향평가 협의 대상 개발사업이라고 보는 것이 타당합니다.

한편 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고 제4호에서는 "다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업으로서 개발사업의 대상 규모(부지면적)가 비고 제1호에 따른 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위에 해당하는 경우에는 재해영향평가 협의를 하여야 한다"고 규정하고 있는데, 이는 '개별 법령에서 정하는 바에 따라 하는 주된 허가등에 관한 사업'(이하 "본 사업"이라 함)에 관한 규정이 아니라, 의제되는 허가등에 관한 사업(이하 "의제되는 사업"이라 함)에 관한 규정으로, 의제되는 사업의 대상 규모가 같은 비고 제1호에 따른 재해영향평가 협의 대상에 해당하면, 의제되는 사업에 대해서도 재해영향평가를 해야 한다[5]는 의미이지, 본 사업의 허가등으로 의제되는 사업이 있는 경우에는 본 사업이 아닌 그 의제되는 사업의 규모로 재해영향평가 협의 대상인지 여부를 판단하려는 규정으로 해석할 수는 없는바, 이 사안과 같이 관광사업계획 승인으로 개발행위허가가 의제되는 경우라도 본 사업의 부지면적이 5천제곱미터 이상인 경우에는 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호아목 및 같은 호 비고 제1호 본문의 괄호 외의 부분에 따라 자연재해대책법령에 따른 재해영향평가 협의 대상 개발사업에 해당된다고 보아야 합니다.

아울러 「자연재해대책법」은 태풍, 홍수 등 자연현상으로 인한 재난으로부터 국토를 보존하고 국민의 생명·신체 및 재산과 주요 기간시설을 보호하기 위하여 자연재해의 예방·복구 및 그 밖의 대책에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적(제1조)으로 마련된 법률로서, "재해영향평가"는 각종 개발사업의 계획수립단계부터 사전 심의기능을 강화하여 무분별한 개발 억제와 재해발생요인을 사전에 차단하기 위해 도입된 제도[6]라는 점을 고려하면,

5) 법제처 2016. 5. 24. 회신 16-0046 해석례 참조

6) 2005. 1. 27. 법률 제7359호로 전부개정되어 같은 해 7. 27. 시행된 「자연재해대책법」에 대한 개정이유서 및 2004. 7. 2.

재해영향평가 협의 대상의 기준이 되는 개발사업 범위를 합리적 이유 없이 축소하여 본 사업의 규모를 기준으로 재해영향평가 협의 대상 개발사업에 해당된다고 보지 않고, 의제되는 사업의 규모만을 기준으로 해당 개발사업이 재해영향평가 협의 대상 개발사업에 해당되는지 여부를 판단하는 것은 자연재해대책법령의 목적 및 취지에 부합하지 않는다는 점도 이 사안을 해석할 때 함께 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 개발사업은 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호가 비고 제1호에 따라 재해영향평가 협의 대상 개발사업에 해당합니다.

관계법령

자연재해대책법 시행령

[별표 1]

재해영향평가등의 협의 대상 행정계획 및 개발사업의 범위 및 협의 시기(제6조제1항 관련)

1. 행정계획 (생 략)
2. 개발사업

구분	대상 개발사업	협의 시기
가. 국토·지역 계획 및 도시의 개발	1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가	개발행위 허가 전
	2) ~ 8) (생 략)	
나. ~ 사. (생 략)		
아. 관광단지 개발 및 체육시설	1) (생 략)	
	2) 「관광진흥법」 제15조에 따른 관광사업계획	사업계획 승인 전
	3) ~ 5) (생 략)	

비고

1. 위 표의 개발사업 중 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우로 한정하며, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에는 1만제곱미터) 이상이거나 길이가 2킬로미터(「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제9조에 따른 임도 설치의 경우에는 4킬로미터) 이상인 경우로 한다. (단서 생략)
2.·3. (생 략)
4. 다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업으로서 개발사업의 대상 규모(부지면적)가 비고 제1호에 따른 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위에 해당하는 경우에는 재해영향평가 협의를 하여야 한다.

의안번호 제170119호로 발의된 자연재해대책법개정법률안에 대한 국회 행정자치위원회 심사보고서 참조

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령

제55조(개발행위허가의 규모) ①법 제58조제1항제1호 본문에서 "대통령령으로 정하는 개발행위의 규모"란 다음 각호에 해당하는 토지의 형질변경면적을 말한다. 다만, 관리지역 및 농림지역에 대하여는 제2호 및 제3호의 규정에 의한 면적의 범위안에서 당해 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례로 따로 정할 수 있다.

1. 도시지역
   가. 주거지역·상업지역·자연녹지지역·생산녹지지역 : 1만제곱미터 미만
   나. 공업지역 : 3만제곱미터 미만
   다. 보전녹지지역 : 5천제곱미터 미만
2. 관리지역 : 3만제곱미터 미만
3. 농림지역 : 3만제곱미터 미만
4. 자연환경보전지역 : 5천제곱미터 미만

②·③ (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-1130

민원인 – 의료인의 양성과 관련되는 재입학의 허가 범위인 '모집단위별 입학정원'의 의미(「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항 단서 등 관련)

01 질의요지

「고등교육법 시행령」 제28조제1항 본문에서는 「고등교육법」 제32조에 따른 대학[7]의 학생정원은 입학정원을 기준으로 하여 학칙이 정하는 모집단위(이하 "모집단위"라 함)별로 학칙으로 정한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분에서는 학칙으로 모집단위별 입학정원을 정함에 있어서 교육부장관이 정하는 같은 항 각 호의 사항에 관하여는 이에 따라야 한다고 규정하면서, 같은 항 제2호가목에서 '「의료법」 제2조제1항에 따른 의료인(이하 "의료인"이라 함)의 양성과 관련되는 모집단위별 정원'을 규정하고 있는 한편,

「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항에서는 대학의 장은 같은 영 제28조제1항에 따라 학칙이 정하는 계열별 학생정원을 포함한 학생정원(이하 "총정원"이라 함)의 범위에서 재입학을 허가할 수 있다고 규정하면서(본문), 의료인의 양성과 관련되는 재입학의 경우에는 같은 영 제28조제3항제2호에 따른 모집단위별 입학정원의 범위에서 재입학을 허가해야 한다(단서)고 규정하고 있는바,

「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항 단서에 따른 의료인의 양성과 관련되는 재입학 허가 범위로서 '같은 영 제28조제3항제2호에 따른 모집단위별 입학정원의 범위'는 '모집단위별 개별 학년도 입학정원의 범위'를 의미하는지, 아니면 '모집단위별 수업연한[8]에 따른 전체 학년의 입학정원의 범위'를 의미하는지?

7) 「고등교육법」 제2조에 따른 산업대학·교육대학·전문대학·기술대학·원격대학 및 각종학교를 포함하되, 대학원 및 대학원대학을 제외하며. 이하 같음.

8) 「고등교육법」 제31조제1항 및 같은 법 시행령 제25조에 따른 수업연한을 의미함.

02 회답

「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항 단서에 따른 의료인의 양성과 관련되는 재입학 허가 범위로서 '같은 영 제28조제3항제2호에 따른 모집단위별 입학정원의 범위'는 '모집단위별 개별 학년도 입학정원의 범위'를 의미합니다.

03 이유

「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항 단서에서는 대학의 장은 의료인의 양성과 관련되는 재입학의 경우에는 같은 영 제28조제3항제2호에 따른 모집단위별 입학정원의 범위에서 재입학을 허가해야 한다고 규정하고 있는데, 고등교육법령에서는 "모집단위별 입학정원"의 구체적인 의미에 관한 별도의 규정을 두고 있지 않은바, 이처럼 해당 법령에서 사용하는 용어의 정의나 포섭의 구체적인 범위가 명확히 규정되어 있지 아니한 경우 법령상 용어의 해석은 그 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 해당 조항의 규정 형식과 내용을 종합적으로 고려하여 해석해야 할 것입니다[9].

먼저 「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항 단서에서는 의료인의 양성과 관련되는 재입학의 경우에는 같은 항 본문에 따른 '총정원의 범위'가 아닌 '같은 영 제28조제3항제2호에 따른 모집단위별 입학정원의 범위'에서 재입학을 허가해야 한다고 규정하고 있는데, 같은 영 제28조제1항 본문에서 「고등교육법」 제32조에 따른 대학의 학생정원은 '입학정원'을 기준으로 하여 '모집단위별'로 학칙으로 정하도록 규정하고 있고, 같은 영 제28조제3항에서는 대학이 학칙으로 '모집단위별 입학정원'을 정함에 있어서는 교육부장관이 정하는 같은 항 제2호 각 목에 해당하는 의료인 등의 인력의 양성과 관련되는 모집단위별 정원에 따라야 한다고 규정하면서, 학칙으로 정하는 '모집단위별 입학정원'이 '모집단위별 개별 학년도의 입학정원'을 의미한다고 명시적으로 규정하고 있지는 않으나, '입학'은 일반적으로 특정 학년으로 학교에 들어가는 것을 전제하는 개념으로서, 매 년 또는 매 학기 단위 일정으로 운영되는 학사 행정에 해당한다는 점을 고려할 때, '입학정원'이라는 용어는 통상적으로 '개별 학년도'를 기준으로 한 개념으로 보아야 할 것입니다.

그리고 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는

9) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2004도7807 판결례 참조

한 동일하게 해석·적용되어야 할 것인데,[10] 「고등교육법」 제34조의5제1항 본문에서 교육부장관은 해당 '입학연도'에 학생이 대학에 지원할 수 있는 총 횟수(제2호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 정하거나 변경할 경우에는 해당 입학연도의 4년 전 학년도[11]가 개시되는 날 전까지 공표해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제28조제1항에 따른 학생정원은 입학정원을 기준으로 하고 있어, 고등교육법령상의 '입학'은 개별 학년도별로 정하여 운영되고 있는 점, 같은 영 제29조제3항에서 대학의 장은 같은 영 제28조제1항에도 불구하고 학칙이 정하는 바에 따라 2학년 이상인 학생이 "같은 학년"의 다른 모집단위로 옮기는 것을 허가할 수 있도록 하되(본문), 같은 영 제28조제3항제2호에 해당하는 모집단위로 옮기는 경우에는 "그 입학정원"의 범위를 초과할 수 없다고 규정하고 있는데(단서), 여기에서 "그 입학정원"은 모집단위를 옮기려고 하는 학생이 속한 학년과 "같은 학년"에 해당하는 의료인 양성 관련 모집단위의 입학정원을 의미하는 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 같은 영 제29조의2제1항 단서를 비롯한 고등교육법령에 따른 "모집단위별 입학정원"이라는 용어는 모집단위별 개별 학년도의 입학정원을 지칭하는 개념으로 보아야 할 것이지, '모집단위별 수업연한에 따른 전체 학년의 입학정원'으로 확대하여 해석할 수는 없다고 할 것입니다.

한편 「고등교육법 시행령」 제29조의2는 2006년 1월 13일 대통령령 제19278호로 구 「고등교육법 시행령」[12]을 일부개정하면서 제적 후 재입학을 원하는 자들에게 고등교육을 받을 수 있는 기회를 폭넓게 제공하여 고등교육에 대한 국민의 수혜 범위를 확대하고, 이와 함께 학사 운영에 대한 대학의 자율성을 강화하려는 취지[13]로 대학의 장이 '총정원의 범위'에서 재입학을 허가하도록 하면서도, 의료인의 양성과 관련되는 재입학의 경우에는 같은 조 제1항에 단서를 두어 같은 영 제28조제1항·제3항·제4항에 따라 교육부장관이 관계 중앙행정기관의 장인 보건복지부장관과 협의하여 정한 '모집단위별 입학정원의 범위'에서만 재입학을 허가하도록 제한하였는바, 이는 국가의 보건 정책, 보건의료 환경의 변화, 보건의료 인력에 대한 사회적 수요 등 제반사정을 고려하여 의과대학 등의 재입학을 허가하는 경우 그 허가의 범위를 제한하도록 함으로써 보건의료 인력의 적정한 수급과 원활하고 적정한 보건서비스를 확보하기 위한 데에 그 취지가 있었던 것으로 보이는 점[14] 등에 비추어 보면,

---

10) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조

11) 「고등교육법」 제20조(학년도 등) ① 학교의 학년도(學年度)는 3월 1일부터 다음 연도 2월 말일까지로 한다. 다만, 학교운영을 위하여 필요한 경우에는 학칙으로 다르게 정할 수 있다.

12) 2006. 1. 13. 대통령령 제19278호로 일부개정되어 같은 날 시행되기 전의 것을 말함.

13) 2006. 1. 13. 대통령령 제19278호로 일부개정된 고등교육법 시행령 개정이유서 및 주요내용 참조

14) 헌법재판소 2020. 7. 16. 선고 2018헌마566 결정례 참조

「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항 본문에서 대학의 일반적인 재입학 허가와 관련하여 계열별 학생정원을 포함한 총정원의 범위에서 재입학을 허가할 수 있도록 규정한 것과 달리, 같은 항 단서에서는 의료인 양성과 관련되는 재입학의 경우에는 그 허가 범위를 '모집단위별 개별 학년도 입학정원의 범위'로 보다 엄격하게 제한한 것으로 보는 것이 같은 항 단서의 입법 취지에 부합합니다.

따라서 「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항 단서에 따른 의료인의 양성과 관련되는 재입학 허가 범위로서 '같은 영 제28조제3항제2호에 따른 모집단위별 입학정원의 범위'는 '모집단위별 개별 학년도 입학정원의 범위'를 의미합니다.

관계법령

고등교육법

제32조(학생의 정원) 대학(산업대학·교육대학·전문대학·원격대학·기술대학 및 각종학교를 포함한다)의 학생 정원에 관한 사항은 대통령령으로 정하는 범위에서 학칙으로 정한다.

고등교육법 시행령

제28조(학생의 정원) ① 법 제32조에 따른 대학(산업대학·교육대학·전문대학·기술대학·원격대학 및 각종학교를 포함하되, 대학원 및 대학원대학을 제외한다)의 학생정원은 입학정원을 기준으로 하여 학칙이 정하는 모집단위(이하 "모집단위"라 한다)별로 학칙으로 정하되, 「대학설립·운영 규정」에 따른 교사, 교지, 교원 및 수익용 기본재산에 따라 정해지는 학생수의 범위에서 정하여야 한다. (단서 생략)

② 삭제

③ 제1항의 규정에 의하여 학칙으로 모집단위별 입학정원을 정함에 있어서 교육부장관이 정하는 다음 각호의 사항에 관하여는 이에 따라야 한다.

1. 교원의 양성과 관련되는 모집단위별 정원
2. 다음 각목에 해당하는 인력의 양성과 관련되는 모집단위별 정원
   가. 「의료법」 제2조제1항의 규정에 의한 의료인
   나. 「의료기사 등에 관한 법률」 제1조의 규정에 의한 의료기사
   다. 「약사법」 제2조제2호에 따른 약사 및 한약사
   라. 「수의사법」 제2조제1호의 규정에 의한 수의사
3. ~ 5. (생 략)

④·⑤ (생 략)

제29조의2(재입학) ① 대학(산업대학·교육대학·전문대학·기술대학·원격대학 및 각종학교를 포함하되, 대학원 및 대학원대학을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 장은 제28조제1항에 따라 학칙이 정하는 계열별 학생정원을 포함한 학생정원(이하 "총정원"이라 한다)의 범위에서 재입학을 허가할 수 있다. 다만, 교원 및 의료인의 양성과 관련되는 재입학의 경우에는 제28조제3항제1호 및 제2호에 따른 모집단위별 입학정원의 범위에서 재입학을 허가하여야 한다.

②·③ (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0059, 24-0160

환경부·민원인 – 상수원보호구역에 있는 폐교재산의 용도변경에 관한 특례의 범위(「폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법」 제10조 등 관련)

01 질의요지

「폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법」(이하 "폐교활용법"이라 함) 제10조에서는 '특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 및 군수(광역시의 군수는 제외하며, 이하 "특별시장등"이라 함)는 「수도법」 제7조제1항에 따른 상수원보호구역(이하 "상수원보호구역"이라 함)에 있는 폐교재산[15]을 교육용시설[16] 등으로 활용하기 위하여 대부받은 자에 대하여는 「수도법」 제7조제6항에 따른 허가의 기준에도 불구하고 대통령령으로 정하는 경우에 용도변경을 허가할 수 있다'고 규정하고 있는데,

「수도법」 제7조제3항제2호에서는 상수원보호구역에서는 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 금지행위를 할 수 없다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조제1항제3호에서는 그러한 금지행위의 하나로 "행락·야영 또는 야외취사행위"를 규정하고 있는 한편, 같은 법 제7조제4항 각 호 외의 부분 본문에서는 상수원보호구역에서 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 관할 시장등[17]의 허가를 받아야 한다고 규정하면서 같은 항 제1호에서는 '건축물의 용도변경' 등을 규정하고 있는바,

폐교활용법 제10조에 따라 상수원보호구역에 있는 폐교재산을 대부받아 교육용시설로 활용하기 위해 폐교재산을 야영장 시설[18]로 용도변경하려는 경우, 야영장 시설에서 이루어지는 '야영행위'가 「수도법」 제7조제3항제2호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조제1항제3호에 따라 상수원보호구역에서 금지되는 행위에 해당하여 폐교활용법 제10조에 따른 용도변경 허가 대상에서 제외되는지?

---

15) 폐교활용법 제2조제2호에 따른 폐교재산을 말하며, 이하 같음.

16) 폐교활용법 제2조제3호에 따른 교육용시설을 말하며, 이하 같음.

17) 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장을 말하며, 이하 같음.

18) 「건축법 시행령」 별표 1 제29호에 따른 야영장 시설[「관광진흥법」에 따른 야영장 시설(「청소년활동 진흥법」 제10조 제1호마목에 따른 청소년야영장이 아닌 시설로 전제함)로서 관리동, 화장실, 샤워실, 대피소, 취사시설 등의 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것]을 말하며, 이하 같음.

02 회답

이 사안의 경우, 야영장 시설에서 이루어지는 '야영행위'가 「수도법」 제7조제3항제2호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조제1항제3호에 따라 상수원보호구역에서 금지되는 행위에 해당하여 폐교활용법 제10조에 따른 용도변경 허가 대상에서 제외됩니다.

03 이유

먼저 「수도법」 제7조제4항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 제1호에서는 상수원보호구역에서 '건축물의 용도변경' 등의 행위를 하려는 자는 관할 시장등의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제6항에서는 "제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 상수원보호구역의 지정절차, 허가의 기준에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다"고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제13조에서는 상수원보호구역에서 건축물의 용도변경 등의 행위허가기준을 정하고 있는 한편, 폐교활용법 제10조에서는 특별시장등은 상수원보호구역에 있는 폐교재산을 교육용시설 등으로 활용하기 위하여 대부받은 자에 대하여는 "「수도법」 제7조제6항에 따른 허가의 기준에도 불구하고" 대통령령으로 정하는 경우에 용도변경을 허가할 수 있다고 규정하고 있는바, 폐교활용법 제10조가 「수도법」 제7조제6항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제13조에서 규정하고 있는 '상수원보호구역에서의 행위에 대한 허가의 기준'에 대한 특례에 해당한다는 점은 명확하다고 할 것입니다.

그리고 「수도법」 제7조제1항에서는 환경부장관은 상수원의 확보와 수질 보전을 위하여 필요하다고 인정되는 지역을 상수원보호구역으로 지정하도록 규정하면서, 같은 조 제3항에서는 상수원보호구역에서 '금지되는 행위'를, 같은 조 제4항에서는 시장등의 '허가를 받아야 할 수 있는 행위'를 각각 규정하고 있는데, 같은 조 제3항제2호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조제1항제3호에서는 "상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위"로서 '행락·야영 또는 야외 취사행위'를 상수원보호구역에서 금지되는 행위로 규정하면서, 이와 관련하여 별도의 예외를 두고 있지 아니하며, 같은 법 제7조제6항의 위임에 따라 '상수원보호구역에서의 행위에 대한 허가의 기준'을 정하고 있는 같은 법 시행령 제13조제1항에서도 시장등은 상수원보호구역에서 같은 법 제7조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 허가할 때에는 상수원보호구역의 지정목적에 지장이 없다고 인정되는 경우에만 허가할 수 있다고 규정하고 있는바, 상수원보호구역 내 일반적인 '건축물의 용도변경' 행위가 「수도법」

제7조제4항제1호에 따라 허가를 받아 할 수 있는 행위에 해당한다고 하더라도, 상수원보호구역 내 '야영행위'를 위해 제공되는 건축물로의 용도변경 행위는 「수도법」 제7조제3항에 따라 허가 대상 행위에서 제외된다고 할 것입니다.

그렇다면 폐교활용법 제10조에 따른 상수원보호구역 내 폐교재산의 용도변경 허가에 관한 특례 역시 「수도법」 제7조제4항에 따라 상수원보호구역에서 허가를 받아 할 수 있는 행위의 허가기준에 대한 특례를 정한 것일 뿐, 같은 조 제3항에 따라 상수원보호구역에서 금지되는 행위까지 할 수 있는 특례를 정한 것은 아니라고 보아야 합니다.

아울러 상수원보호구역은 「수도법」 제7조제1항에 따라 '상수원의 확보와 수질 보전을 위하여' 지정되는 구역으로서, 같은 조 제3항 및 제4항에서는 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위 등 상수원보호구역에서 금지되는 행위(제3항)와 건축물의 용도변경 행위 등 허가를 받아 할 수 있는 행위(제4항)를 구체적으로 정하여 규제하고 있고, 폐교재산법 제10조는 폐교재산 학생수의 감소 및 학교의 통·폐합 등으로 증가하는 폐교재산을 적극 활용[19]하려는 정책적 목적에 따라 상수원보호구역 내 건축물 중 폐교재산에 대해서만 예외적으로 적용되는 특례를 규정한 것으로서, 「수도법」에 따른 상수원보호구역 지정제도의 취지와 특례규정의 성격을 고려할 때, 폐교재산법 제10조에 따른 특례가 적용되는 범위는 엄격하게 해석·적용해야 한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우, 야영장 시설에서 이루어지는 '야영행위'가 「수도법」 제7조제3항제2호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조제1항제3호에 따라 상수원보호구역에서 금지되는 행위에 해당하여 폐교활용법 제10조에 따른 용도변경 허가 대상에서 제외됩니다.

19) 1999. 8. 31. 법률 제6005호로 제정되어 1999. 12. 1. 시행된 폐교재산의활용촉진을위한특별법 제정이유 참조

관계법령

폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법

제10조(용도변경에 관한 특례) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 및 군수(광역시의 군수는 제외한다)는 「수도법」 제7조제1항에 따른 상수원보호구역에 있는 폐교재산을 교육용시설, 사회복지시설 또는 귀농어·귀촌 지원시설로 활용하기 위하여 대부받은 자에 대하여는 「수도법」 제7조제6항에 따른 허가의 기준에도 불구하고 대통령령으로 정하는 경우에 용도변경을 허가할 수 있다.

수도법

제7조(상수원보호구역 지정 등) ①·② (생 략)

③ 제1항과 제2항에 따라 지정·공고된 상수원보호구역에서는 다음 각 호의 행위를 할 수 없다.

1. (생 략)
2. 그 밖에 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 금지행위

④ 제1항과 제2항에 따라 지정·공고된 상수원보호구역에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 관할 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 행위인 경우에는 신고하여야 한다.

1. 건축물, 그 밖의 공작물의 신축·증축·개축·재축(再築)·이전·용도변경 또는 제거
2.·3. (생 략)

⑤ (생 략)

⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 상수원보호구역의 지정절차, 허가의 기준에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

수도법 시행령

제12조(상수원보호구역에서의 금지행위) ① 법 제7조제3항제2호에서 "대통령령으로 정하는 금지행위"란 다음 각 호의 행위를 말한다.

1.·2. (생 략)
3. 행락·야영 또는 야외 취사행위
4. ~ 6. (생 략)

②·③ (생 략)

제13조(상수원보호구역에서의 행위허가기준) ① 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 상수원보호구역에서 법 제7조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 허가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 상수원보호구역의 지정목적에 지장이 없다고 인정되는 경우에만 허가할 수 있다.

1. (생 략)
2. 오염물질의 발생 정도가 종전의 경우보다 높지 아니한 범위에서의 건축물이나 그 밖의 공작물의 용도변경
3. ~ 5. (생 략)

②·③ (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0099

교육부 – 재교육형 계약학과의 학생신분을 유지하기 위한 조건으로서 '취업'의 의미(「계약학과 설치·운영 규정」 제26조제4항 등 관련)

01 질의요지

「계약학과 설치·운영 규정」(교육부 고시) 제26조제1항에서는 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」(이하 "산학협력법"이라 함) 제8조제1항제2호에 따른 계약학과[20](이하 "재교육형 계약학과"라 함)의 학생이 산업체 등에서 본인의 의사에 의하여 퇴직한 경우 등에는 입학의 취소 또는 제적 처리하도록 하면서, 같은 규정 제26조제3항에서는 권고사직 등 본인의 의사와 관계없이 퇴직한 경우에는 필요경비를 학생이 부담하는 조건으로 계약학과 소속의 학생신분을 유지할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 같은 조 제3항 등에 따라 학생신분을 유지하기 위해서는 해당 계약학과 운영 기간 내에 이수해야 할 학점의 100분의 50 이상을 취득하거나, 100분의 50 미만을 이수했을 경우에는 퇴직한 날부터 6개월 이내에 같은 종류 업계[21] 또는 같은 직무[22]에 취업하여야 한다고 규정하고 있는바,

「계약학과 설치·운영 규정」 제26조제3항에 따라 권고사직 등 본인의 의사와 관계없이 퇴직한 재교육형 계약학과의 학생[23]이 해당 재교육형 계약학과 운영 기간 내 이수해야 할 학점의 100분의 50 미만을 이수한 경우로서 퇴직한 날부터 6개월 이내에 같은 종류 업계 또는 같은 직무에 취업한 후 다시 퇴직한 경우에도[24] 재교육형 계약학과의 학생신분이 유지되는지?

---

20) "계약학과"란 산업교육을 실시하는 산학협력법 제2조제2호다목의 산업교육기관이 산업체 등의 계약에 의하여 설치· 운영하는 학부·학과와 산학협력법 시행령 제8조의2에 따른 계약정원을 포함하여 말함(「계약학과 설치·운영 규정」 제2조제1호 참조)

21) 표준산업분류의 중분류 기준으로 하며, 이하 같음

22) 표준직업분류의 중분류 기준으로 하며, 이하 같음

23) 필요경비를 학생이 부담하는 조건임을 전제함

24) 「계약학과 설치·운영 규정」 제26조제3항에 따른 권고사직 등으로 퇴직한 후, 같은 종류 업계 또는 같은 직무에 다시 취업하였으나 해당 계약학과 운영 기간 내 이수해야 할 학점의 100분의 50 이상을 이수하지 못한 상태에서 다시 본인의 의사에 의하여 퇴직한 이후 재취업하지 않고 있는 경우로 전제함

02 회답

이 사안의 경우, 재교육형 계약학과의 학생신분이 유지되지 않습니다.

03 이유

산학협력법 제8조제1항제2호에서는 산업교육기관은 국가, 지방자치단체 또는 산업체등[25]이 그 소속 직원의 재교육이나 직무능력 향상 또는 전직(轉職) 교육을 위하여 그 경비의 전부 또는 일부를 부담하면서 교육을 의뢰하는 경우 국가, 지방자치단체 또는 산업체등과의 계약에 의하여 직업교육훈련 과정 또는 학과 등을 설치·운영할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제6항 및 같은 법 시행령 제8조제12항의 위임에 따라 마련된 「계약학과 설치·운영 규정」 제14조에서는 재교육형 계약학과에 입학하려는 사람은 원칙적으로 기간의 정함이 없는 근로자여야 하되, 기간이 정하여져 있는 근로자인 경우에는 그 근무 기간이 계약학과 운영 기간보다 길어야 하며(제3항), 산업체 등[26]의 소속 직원에 한해 입학 자격이 부여(제5항)된다고 규정하고 있으며, 같은 규정 제26조제1항에서는 재교육형 계약학과의 학생이 산업체 등에서 본인의 의사에 의하여 퇴직한 경우, 징계해고, 근로계약기간 만료로 퇴직한 경우에는 입학의 취소 또는 제적 처리한다고 규정하고 있는바, 재교육형 계약학과의 학생은 "산업교육기관과 계약을 체결한 산업체 등의 소속 근로자 또는 직원"으로서, 원칙적으로 재교육형 계약학과의 학생이 산업체 등에서 퇴직한 경우에는 별도의 규정이 없는 한 재교육형 계약학과의 학생 신분도 유지할 수 없게 됩니다.

그런데 재교육형 계약학과 학생을 보호하기 위하여 퇴직 사유에 따라 학생신분 유지 인정기준을 별도로 마련하여 「계약학과 설치·운영 규정」 제26조제2항 및 제3항에서는 임금체불 등으로 자진퇴사가 불가피하다고 인정되는 경우 또는 권고사직 등 본인의 의사와 관계없이 퇴직한 경우에는 필요경비를 학생이 부담하는 조건으로 계약학과 소속의 학생 신분을 유지할 수 있도록 하면서, 같은 조 제4항에서는 제2항 또는 제3항에 따라 학생신분을 유지하기 위한 추가적인 요건으로 해당 계약학과 운영 기간 내 이수해야 할 학점의 100분의 50 이상을 취득하거나, 100분의 50 미만을 이수했을 경우 퇴직한 날부터 6개월 이내에 같은 종류 업계 또는 같은 직무에 취업하도록 규정하고 있는바, 재교육형 계약학과의 학생이 소속된

25) 산업체, 사업자단체 및 직능단체를 말하며(산학협력법 제2조제4호 참조), 이하 같음

26) 「계약학과 설치·운영 규정」 제3조제1항에 따른 산업체 등을 말하며, 이하 같음

산업체 등에서 자진퇴사가 불가피하거나 비자발적인 사유로 퇴직한 경우에는 기존에 이수한 학점이 100분의 50 이상이거나, 기존에 이수한 학점이 100분의 50 미만이더라도 퇴직한 날부터 6개월 이내에 같은 종류 업계 또는 같은 직무에 취업하면 당초에 취업한 산업체 등의 소속 근로자 또는 직원이라는 지위를 상실했더라도 학생신분을 유지할 수 있도록 예외를 인정하고 있습니다.

이처럼 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것[27]인바, 원칙적으로 재교육형 계약학과의 학생은 산업교육기관과 계약을 체결한 산업체 등의 소속 근로자 또는 직원이어야 학생신분을 유지할 수 있다는 점을 고려할 때, 「계약학과 설치·운영 규정」 제26조제4항의 예외규정은 산업교육기관과 계약을 체결한 산업체 등에서 자진퇴사가 불가피하거나 비자발적인 사유로 근무하지 못하게 되는 상황에서는 해당 재교육형 계약학과 운영 기간 내 이수해야 할 학점의 100분의 50 미만을 이수한 경우에는 퇴직 전 소속했던 산업체 등과 같은 종류 업계 또는 같은 직무라도 취업하여 산업체 등에 소속된 경우에 한정하여 학생신분을 유지할 수 있도록 한 취지로 해석하는 것이 타당하므로, 이 사안과 같이 같은 종류 업계 또는 같은 직무에 취업한 후 자발적으로 퇴직하여 산업체 등에 더 이상 소속되지 않게 된 경우에는 학생신분이 유지되지 않는다고 할 것입니다.

아울러 재교육형 계약학과는 산학연협력(産學硏協力)을 촉진하여 교육과 연구의 연계를 기반으로 산업사회의 요구에 따르는 창의적인 산업인력을 양성하기 위하여(산학협력법 제1조) 산업교육기관이 산업체등과의 계약에 따라 학생을 선발하고 교육과정을 선택하도록 하는 제도로서, 공개경쟁에 의하여 학생을 선발하는 학과 등의 예외로 규정된 특례이므로 이러한 계약학과 제도는 그 문언상의 의미나 입법취지를 확대하여 적용하는 것이 제한된다고 할 것[28]인데, 「계약학과 설치·운영 규정」 제26조제3항에 따라 퇴직한 사람이 해당 재교육형 계약학과 운영 기간 내 이수해야 할 학점의 100분의 50 미만을 이수한 경우 같은 조 제4항에서 학생신분을 유지하기 위해서는 같은 종류 업계 또는 같은 직무에 '취업'하여야 한다고 규정하고 있는 것을, 같은 종류 업계 또는 같은 직무에 취업한 후 다시 퇴직한 경우에도 학생신분이 유지된다고 해석한다면, 재교육형 계약학과 운영 기간 내 이수해야 할 학점을 전혀 취득하지 못한 자가 취업 후 단기간 근무하고 퇴직한 상태로 있는 경우에도 학생 신분이 유지되는

27) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조

28) 2003. 5. 27. 법률 제6878호로 일부개정되어 2003. 9. 1. 시행된 산학협력법 국회 검토보고서 및 법제처 2016. 1. 12. 회신 15-0810 해석례 참조

불합리한 결과가 초래되므로, 같은 조 제4항에서 학생신분을 유지할 수 있는 조건으로 같은 종류 업계 또는 같은 직무에 "취업"한 경우를 규정하고 있는 취지에 부합하지 않게 된다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 재교육형 계약학과의 학생신분이 유지되지 않습니다.

관계법령

산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률

제8조(계약에 의한 직업교육훈련과정 등의 설치·운영) ① 산업교육기관은 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 국가, 지방자치단체 또는 산업체등과의 계약에 의하여 권역별로, 산업교육기관간 또는 산업교육기관별로 직업교육훈련 과정 또는 학과 등을 설치·운영할 수 있다. 이 경우 새로운 학과·학부를 설치할 필요가 있는 때에는 그에 앞서 이미 설치되어 있는 학과·학부나 유사한 학과·학부를 우선 활용하여야 한다.

1. 국가, 지방자치단체 또는 산업체등이 채용을 조건으로 학자금 지원계약을 체결하고, 특별한 교육과정의 운영을 요구하는 경우
2. 국가, 지방자치단체 또는 산업체등이 그 소속 직원의 재교육이나 직무능력 향상 또는 전직(轉職) 교육을 위하여 그 경비의 전부 또는 일부를 부담하면서 교육을 의뢰하는 경우
3. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ 제1항에 따른 직업교육훈련과정 등의 설치·운영 및 학생선발방법, 정원, 납부금, 제5항에 따른 비용 지원 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 시행령

제8조(계약에 의한 학과 및 학부의 설치·운영 등) ① ~ ⑪ (생 략)

⑫ 제1항부터 제11항까지에서 규정한 사항 외에 계약학과등의 설치·운영에 필요한 사항은 교육부장관이 정하여 고시한다.

계약학과 설치·운영 규정(교육부고시 제2023-17호)

제26조(퇴직 등) ① 법 제8조제1항제2호에 따른 계약학과의 학생이 산업체 등에서 본인의 의사에 의하여 퇴직한 경우, 징계해고, 근로계약기간 만료로 퇴직한 경우에는 입학의 취소 또는 제적 처리한다.

② 제1항에도 불구하고 임금체불, 휴업, 사업장 이전, 통근이 불가능한 지역으로의 전근 등으로 인한 자진퇴사가 불가피하다고 인정되는 경우에는 필요경비를 학생이 부담하는 조건으로 계약학과 소속의 학생신분을 유지할 수 있으며 남은 기간의 교육은 계약학과에서 맡는다.

③ 산업체 등의 도산, 구조조정, 권고사직 등 본인의 의사와 관계없이 퇴직한 경우에는 필요경비를 학생이 부담하는 조건으로 계약학과 소속의 학생신분을 유지할 수 있으며 남은 기간의 교육은 계약학과에서 맡는다.
④ 제2항 또는 제3항에 따라 학생신분을 유지하기 위해서는 해당 계약학과 운영 기간 내 이수해야할 학점의 100분의 50 이상을 취득하거나, 100분의 50 미만을 이수했을 경우에는 퇴직한 날부터 6개월 이내에 같은 종류 업계(표준산업분류의 중분류 기준) 또는 같은 직무(표준직업분류의 중분류 기준)에 취업하여야 한다.
⑤ ~ ⑦ (생 략)

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0374, 24-0467

민원인 – 「교육공무원법」 제41조의 교원의 범위(「교육공무원법」 제41조 등 관련)

01 질의요지

「교육공무원법」 제41조에서는 교원은 수업에 지장을 주지 아니하는 범위에서 소속 기관의 장의 승인을 받아 연수기관이나 근무장소 외의 시설 또는 장소에서 연수(이하 "근무지외연수"라 함)를 받을 수 있다고 규정하고 있는바,

「초·중등교육법」 제3조제1호의 국립학교 또는 같은 조 제2호의 공립학교(이하 "국공립학교"라 함)에서 근무하는 교장, 교감, 사서교사, 영양교사는 「교육공무원법」 제41조에 따라 근무지외연수를 받을 수 있는 대상인 '교원'에 해당하는지?

02 회답

국공립학교에서 근무하는 교장, 교감, 사서교사, 영양교사는 「교육공무원법」 제41조에 따라 근무지외연수를 받을 수 있는 대상인 '교원'에 해당합니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[29], 「교육공무원법」 제2조제1항제1호에서는 교육공무원 중 하나로 교육기관에 근무하는 '교원'을 규정하고 있고, 같은 조 제3항제1호에서는 교육기관 중 하나로 「초·중등교육법」 제2조의 학교에 해당하는 국립 또는 공립의 학교를 규정하고 있으나 교원의 구체적인 내용에 관하여 별도로 규정하고

29) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

있지는 않은데, 「초·중등교육법」 제19조제1항에서는 학교에는 같은 항 각 호의 '교원'을 둔다고 규정하면서, 같은 항 제1호 본문에서 초등학교·중학교·고등학교·공민학교·고등기술학교 및 특수학교에는 교장·교감·수석교사 및 교사를 둔다고 규정하고 있고, 같은 법 제21조에서는 교원의 자격을 규정하면서 같은 조 제2항에서 '교사'를 정교사, 준교사, 전문상담교사, 사서교사, 실기교사, 보건교사 및 영양교사로 구분하여 규정하고 있는바, 사서교사, 영양교사는 '교사'에 해당하고, 같은 법 제19조에 따라 국공립학교에 있는 교장, 교감, 교사 모두 '교원'에 포함된다고 할 것인바, 이러한 교육 관계 법령의 규정을 종합하면 이 사안과 같이 국공립학교에서 근무하는 교장, 교감, 사서교사, 영양교사는 '교원'에 포함되어 「교육공무원법」 제41조에 따른 근무지외연수를 받을 수 있는 대상에 해당한다고 보는 것이 문언에 부합하는 해석입니다.

또한 「교육공무원법」 제41조에서 교원으로 하여금 '수업에 지장을 주지 아니하는 범위에서' 근무지외연수를 받을 수 있도록 규정한 것은 상시적으로 학교에 배치되어 학생을 교육하고 지도하는 교원을 대상으로 방학 등 학교에서 학생들에 대한 교육이 이루어지지 않는 기간이나 그 밖에 학교에서의 교육에 특별한 지장을 초래하지 않는 기간 동안 학교에 출근하지 않는 대신 연수기관이나 근무장소 외의 시설이나 장소에서 연수를 받을 수 있도록 허용하려는 취지로서[30] 교장, 교감, 사서교사, 영양교사는 상시적으로 학교에 배치되어 학생들을 교육하고 지도하는 업무를 수행하고 있고, 이러한 교육·지도업무를 효과적으로 수행하기 위해서는 다양한 형태의 연수를 통해 직무수행능력을 향상할 필요성이 있다는 점에서 같은 법 제41조에 따른 교원에 해당하여 근무지외연수를 받을 수 있다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법취지에도 부합합니다.

아울러 「교원 등의 연수에 관한 규정」 제6조제1항에서는 교원 등의 연수를 직무수행능력 향상 등을 위한 직무연수(제1호)와 교원의 자격을 취득하기 위한 자격연수(제2호)로 구분하고 있는데, 같은 조 제3항에서는 자격연수의 연수과정을 정교사(1·2급)과정, 전문상담교사(1급)과정, 사서교사(1급)과정, 영양교사(1급)과정, 교감과정, 교장과정 등으로 구분하고 있어 교장, 교감, 사서교사, 영양교사를 자격연수의 대상으로 규정하고 있는 점, 「교육공무원법」 및 「교원 등의 연수에 관한 규정」 등 교육 관련 법령에서 교장, 교감, 사서교사, 영양교사에 대하여 「교육공무원법」 제41조의 적용을 배제하는 규정을 두고 있지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편 「교육공무원법」 제41조에서는 교원은 '수업에 지장을 주지 아니하는 범위에서' 연수를

30) 법제처 2013. 4. 3. 회신 13-0069 해석례 참조

받을 수 있다고 규정하고 있으므로, 교무를 총괄·관리하여 수업시간을 거의 배정받지 않는 교장, 교감이나 교과[31] 과목 담당이 아닌 사서교사, 영양교사의 경우 교과 과목 담당교원에 비하여 상대적으로 담당하는 수업시간이 적어 같은 법 제41조에 따른 연수대상인 '교원'에 해당하지 않는다는 의견이 있으나, 교장은 수업운영방법 결정[32] 등 학교운영에 관한 사항 및 소속 교직원 지도·감독, 학생 교육 등의 업무를 총괄하고[33], 교감은 교장을 보좌하여 교무 관리 및 학생 교육업무를[34], 사서교사는 정보해득력 강화를 위한 도서관 이용지도교육 및 독서교육[35] 등을, 영양교사는 올바른 식생활 습관 형성 등 식생활 관련 교육 및 지도[36] 등의 업무를 수행하고 있는바, 학교에서 상시적으로 이루어지는 교장, 교감, 사서교사, 영양교사의 교육·지도업무에 대한 고려 없이 '수업에 지장을 주지 아니하는 범위'를 수업시간에 이루어지는 학습활동에 지장을 주지 아니하는 범위만으로 한정하여 해석하는 것은 근무지외연수의 대상이 되는 교원의 범위를 지나치게 제한할 수 있다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 국공립학교에서 근무하는 교장, 교감, 사서교사, 영양교사는 「교육공무원법」 제41조에 따라 근무지외연수를 받을 수 있는 대상인 '교원'에 해당합니다.

관계법령

교육공무원법

제41조(연수기관 및 근무장소 외에서의 연수) 교원은 수업에 지장을 주지 아니하는 범위에서 소속 기관의 장의 승인을 받아 연수기관이나 근무장소 외의 시설 또는 장소에서 연수를 받을 수 있다.

초·중등교육법

제19조(교직원의 구분) ① 학교에는 다음 각 호의 교원을 둔다.
1. 초등학교·중학교·고등학교·고등공민학교·고등기술학교 및 특수학교에는 교장·교감·수석교사

31) 「초·중등교육법」 제23조, 같은 법 시행령 제43조 및 그 위임에 따라 마련된 교육부 고시인 「초·중등학교 교육과정」에서 정하고 있는 교과를 말함
32) 「초·중등교육법」 제24조제3항 및 같은 법 시행령 제48조 참조
33) 「초·중등교육법」 제20조제1항 등 참조
34) 「초·중등교육법」 제20조제2항 등 참조
35) 「도서관법」 제3조제3호 및 제45조제1항 참조
36) 「학교급식법」 제13조 참조

및 교사를 둔다. 다만, 학생 수가 100명 이하인 학교나 학급 수가 5학급 이하인 학교 중 대통령령으로 정하는 규모 이하의 학교에는 교감을 두지 아니할 수 있다.

2. 각종학교에는 제1호에 준하여 필요한 교원을 둔다.

② ~ ④ (생 략)

제21조(교원의 자격) ① 교장과 교감은 별표 1의 자격 기준에 해당하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관이 검정(檢定)·수여하는 자격증을 받은 사람이어야 한다.

② 교사는 정교사(1급·2급), 준교사, 전문상담교사(1급·2급), 사서교사(1급·2급), 실기교사, 보건교사(1급·2급) 및 영양교사(1급·2급)로 나누되, 별표 2의 자격 기준에 해당하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관이 검정·수여하는 자격증을 받은 사람이어야 한다.

③ (생 략)

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0384

경기도교육청 - 교육전문직원이 담당하는 특수업무의 지원을 위해 교육감이 지방자치단체 외의 기관·단체의 임직원을 파견받아 교육청에서 근무하게 하려는 경우 「지방공무원법」 제7조에 따른 인사위원회의 의결을 거쳐야 하는지 여부(「지방공무원법」 제30조의4제1항 등 관련)

01 질의요지

「지방공무원법」 제7조에서는 지방자치단체에 임용권자[37]별로 인사위원회를 둔다고 규정하고 있고, 같은 법 제30조의4제1항에서는 임용권자는 전문성이 특히 요구되는 특수업무의 효율적 수행 등을 위하여 필요하면 인사위원회의 의결을 거쳐 지방자치단체 외의 기관·단체(이하 "민간기관"이라 함)의 임직원을 파견받아 근무하게 할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「교육공무원법」 제59조에서는 교육감 소속 교육전문직원[38]의 인사에 관한 중요 사항에 대하여 교육감이 자문할 수 있도록 교육감 소속으로 지방교육전문직원 인사위원회(이하 "지방교육인사위원회"라 함)를 둔다고 규정하고 있는바,

교육감 소속 교육전문직원이 담당하는 특수업무의 지원을 위해[39] 교육감이 민간기관의 임직원(이하 "민간교육전문가"라 함)을 파견받아 교육청에서 근무하게 하려는 경우, 「지방공무원법」 제7조에 따른 인사위원회(이하 "지방인사위원회"라 함)의 의결을 반드시 거쳐야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 지방인사위원회의 의결을 반드시 거쳐야 합니다.

37) 지방자치단체의 장(특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의 교육감을 포함한다) 및 지방의회의 의장[특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도 의회의 의장 및 시·군·구(자치구를 말함)의회의 의장을 말한다]을 말하며(「지방공무원법」 제6조제1항), 이하 같음.

38) 「교육공무원법」 제1항제2호 및 제3호에 따른 교육공무원을 말하며(「교육공무원법」 제2조제2항 참조), 이하 같음.

39) 해당 업무가 교육감 소속 교육전문직원이 담당하는 특수업무의 효율적 수행 등을 위한 업무임을 전제함.

03 이유

먼저 지방인사위원회에 관하여 규정하고 있는「지방공무원법」 및「지방공무원 임용령」의 규정을 살펴보면,「지방공무원법」 제6조제1항에서는 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 "시·도"라 함)의 교육감을 포함하는 지방자치단체의 장 등은 같은 법에서 정하는 바에 따라 그 소속 공무원의 임명·휴직·면직과 징계를 하는 권한(이하 "임용권"이라 함)을 가진다고 규정하고 있고, 같은 법 제7조제1항에서는 지방자치단체에 임용권자별로 인사위원회를 둔다고 규정하고 있으므로, 임용권자인 시·도의 교육감은 그 소속 공무원의 임용 등에 관한 사무를 관장하는 "지방인사위원회"를 두고 있습니다.

그리고「지방공무원법」 제30조의4제1항에서는 임용권자는 특수업무의 효율적 수행 등을 위하여 필요하면 '인사위원회'의 의결을 거쳐 민간기관의 임직원을 파견받아 근무하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된「지방공무원 임용령」 제27조의4제4항에서는 교육감 등 지방자치단체의 장은 민간기관의 임직원을 파견받아 근무하게 하거나 파견기간을 연장할 때에는 미리 해당 인사위원회의 의결을 거쳐야 한다고 규정하고 있는데,「지방공무원법」 및「지방공무원 임용령」 상 민간교육전문가의 파견을 받기 위하여 지방인사위원회 외의 다른 인사위원회의 심의나 의결을 거치도록 규정하고 있지 않으므로 같은 법 제30조의4 제1항에 따른 "인사위원회"는 교육감 소속의 "지방인사위원회"를 의미한다고 보아야 하고, 이 사안과 같이 교육감이 민간교육전문가를 파견받아 교육청에서 근무하게 하려는 경우에는 같은 법 제30조의4제1항에 따라 "지방인사위원회"의 의결을 반드시 거쳐야 한다고 해석하는 것이 문언에 부합하는 해석입니다.

또한「교육공무원법」은 교육을 통하여 국민 전체에게 봉사하는 교육공무원에 대하여 그 직무와 책임의 특수성을 반영하여 그 자격·임용·보수·연수 및 신분보장 등에 관하여 '교육공무원'에게 적용할「국가공무원법」 및「지방공무원법」에 대한 특례를 규정함을 목적으로 하는 법률(제1조)인데, 이 사안의 민간교육전문가는 그 담당업무가 교육감 소속 교육전문직원이 담당하는 특수업무의 지원업무라고 하더라도「지방공무원법」 제30조의4제1항에 따라 파견되는 민간기관의 임직원으로서「교육공무원법」 제2조제1항에 따른 교육공무원[40]으로 임용되는 것은 아니므로「교육공무원법」의 적용대상으로 보기는 어렵다는 점,「교육공무원법」

40) "교육공무원"이란 교육기관에 근무하는 교원 및 조교(제1호), 교육행정기관에 근무하는 장학관 및 장학사(제2호) 및 교육기관, 교육행정기관 또는 교육연구기관에 근무하는 교육연구관 및 교육연구사(제3호)을 말하며(「교육공무원법」 제2조제1항), 이하 같음.

에서는 민간기관의 임직원 파견에 대한 별도의 규정을 두고 있지 않고, 특히 같은 법 제59조제1항에서는 교육감 소속 교육전문직원의 인사에 관한 중요 사항에 대하여 교육감이 자문할 수 있도록 교육감 소속으로 지방교육인사위원회를 둔다고 규정하고 있을 뿐 교육전문직원이 담당하는 특수업무의 지원을 위해 민간교육전문가를 파견받아 근무하게 하려는 경우, 민간교육전문가 파견 등에 대해 다른 위원회의 사전심의를 거치도록 별도의 규정을 두고 있지 않다는 점 등에 비추어 볼 때 민간교육전문가는 「지방공무원법」의 적용을 받아 같은 법 제30조의4제1항에 따라 파견되는 민간기관의 임직원으로서 지방인사위원회의 의결을 거쳐야 한다고 해석하는 것이 관련 규정의 체계에 부합합니다.

따라서 이 사안의 경우, 지방인사위원회의 의결을 반드시 거쳐야 합니다.

관계법령

지방공무원법

제7조(인사위원회의 설치) ① 지방자치단체에 임용권자(임용권을 위임받은 자는 제외하되, 그중 시의 구청장과 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정하는 소속 기관의 장을 포함한다)별로 인사위원회를 두되, 시·도에 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 교육감 소속으로 인사위원회를 두는 경우에는 필요하면 제1인사위원회와 제2인사위원회를 둘 수 있다.

② ~ ⑪ (생 략)

제8조(인사위원회의 기능 등) ① 인사위원회는 다음 각 호의 사무를 관장한다.

1. ~ 6. (생 략)
7. 그 밖에 법령 또는 조례에 따라 인사위원회 관장에 속하는 사항

② ~ ④ (생 략)

제30조의4(파견근무) ① 임용권자는 그 업무수행과 관련된 행정 지원이나 연수, 그 밖에 능력개발 등을 위하여 필요하면 소속 공무원을 지방자치단체의 다른 기관, 다른 지방자치단체, 국가기관, 공공단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항 각 호에 해당하는 기관(「지방공기업법」에 따른 지방직영기업, 지방공사 및 지방공단을 포함한다), 국내외의 교육기관·연구기관, 그 밖의 기관에 일정 기간 파견근무하게 할 수 있으며, 전문성이 특히 요구되는 특수업무의 효율적 수행 등을 위하여 필요하면 인사위원회의 의결을 거쳐 지방자치단체 외의 기관·단체의 임직원을 파견받아 근무하게 할 수 있다.

②·③ (생 략)

④ 공무원을 파견근무하게 하거나 지방자치단체 외의 기관·단체의 임직원을 파견받아 근무하게 하는 경우 파견 사유·기간·절차와 파견기간 중의 복무, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

지방공무원 임용령

제27조의4(민간전문가의 파견근무) ① ~ ③ (생 략)
④ 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 제1항에 따라 민간기관의 임직원을 파견받아 근무하게 하거나 제3항에 따라 파견기간을 연장할 때에는 미리 해당 인사위원회의 의결을 거쳐야 한다.
⑤·⑥(생 략)

교육공무원법

제59조(지방교육전문직원 인사위원회) ① 교육감 소속 교육전문직원의 인사에 관한 중요 사항에 대하여 교육감이 자문할 수 있도록 교육감 소속으로 지방교육전문직원 인사위원회를 둔다.
② ~ ④ (생 략)

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0455

민원인 – 「사립학교법」에 따른 학교법인 등의 사무직원이 재직기간 중 직무와 관련하여 횡령죄 등을 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 경우 당연퇴직 사유에 해당하는지 여부(「사립학교법」 제70조의4 등 관련)

01 질의요지

「사립학교법」 제70조의2제1항에서는 학교법인 또는 사립학교경영자는 그의 사무와 그가 설치·경영하는 학교의 사무를 처리하기 위하여 필요한 사무기구를 두되, 그 설치·운영과 사무직원의 정원·임용·보수·복무 및 신분보장에 관하여는 학교법인 또는 법인인 사립학교경영자의 경우에는 정관으로 정하고, 사인인 사립학교경영자의 경우에는 규칙으로 정한다고 규정하면서, 같은 법 제70조의4에서는 같은 법 제70조의2제1항에도 불구하고 같은 조에 따라 임명된 사무직원의 당연퇴직에 관하여는 「지방공무원법」 제61조제1호를 준용하고, 이 경우 "공무원"은 "사무직원"으로 본다고 규정하고 있는 한편,

「지방공무원법」 제61조제1호 본문에서는 공무원이 같은 법 제31조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연히 퇴직한다고 규정하고 있고, 같은 법 제31조제6호의2에서는 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄(이하 "횡령·배임죄"라 함)를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람은 공무원이 될 수 없다고 규정하고 있는바,

「사립학교법」 제70조의2제1항에 따라 학교법인 또는 사립학교경영자가 두는 사무기구의 사무직원(이하 "학교법인등사무직원"이라 함)이 재직기간 중 직무와 관련하여 횡령·배임죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 경우 「사립학교법」 제70조의4에 따른 당연퇴직 사유에 해당하는지?

02 회답

학교법인등사무직원이 재직기간 중 직무와 관련하여 횡령·배임죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 경우 「사립학교법」 제70조의4에 따른 당연퇴직 사유에 해당합니다.

03 이유

「사립학교법」 제70조의4에서는 학교법인등사무직원의 당연퇴직에 관하여는 「지방공무원법」 제61조제1호를 준용하고 이 경우 "공무원"은 "사무직원"으로 본다고 규정하고 있는데, "준용"은 특정 조문을 그와 성질이 유사한 규율 대상에 대해 그 성질에 따라 다소 수정하여 적용하는 입법기술[41]로서, 학교법인등사무직원의 당연퇴직에 대해서 「지방공무원법」상 지방공무원[42]의 당연퇴직 규정인 같은 법 제61조제1호를 준용하되 그 문언 중 "공무원"은 "사무직원"으로 바꾸어 읽도록 명시하고 있습니다.

그리고 「사립학교법」 제70조의4에 따라 학교법인등사무직원의 당연퇴직에 관하여 준용되는 「지방공무원법」 제61조제1호에서는 공무원이 같은 법 제31조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당연히 퇴직한다고 규정하고 있어, 「지방공무원법」 제61조제1호는 같은 법 제31조 각 호의 결격사유가 적용되는 것을 규정하고 있는바, 이러한 「사립학교법」 및 「지방공무원법」의 규정 체계를 종합하면 학교법인등사무직원이 「지방공무원법」 제31조제6호의2의 결격사유에 해당하는 '재직기간 중 직무와 관련하여 횡령·배임죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 경우'에는 「사립학교법」 제70조의4에 따라 「지방공무원법」 제61조제1호가 준용되어 당연퇴직 사유에 해당하는 것이 문언상 명확하다고 할 것입니다.

또한 사립학교는 국·공립학교와 설립주체는 다르지만 국·공립학교와 동일한 교과과정의 운영 등을 통해 학교교육의 일부를 담당하고 있어 국가·사회적으로 미치는 영향력과 공공성이 상당하므로[43] 사립학교 운영의 공공성을 강화하고 학교법인등사무직원의 인사·채용의

41) 법령 입안·심사 기준(2023) p. 796 참조
42) 지방자치단체의 공무원을 말하며(「지방공무원법」 제2조제1항 참조), 이하 같음
43) 헌법재판소 2012. 2. 23. 선고 2011헌바14 결정례 참조

투명성을 제고하기 위하여 「사립학교법」 제70조의4에서 지방공무원의 당연퇴직 사유를 학교법인등사무직원에게도 준용하는 규정을 둔 것인바, 이러한 취지에 비추어보면 지방공무원의 당연퇴직에 관한 규정을 학교법인등사무직원에게도 준용하도록 한 「사립학교법」 제70조의4에 따라 학교법인등사무직원이 재직기간 중 직무와 관련하여 횡령·배임죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 경우 당연퇴직 사유에 해당한다고 해석하는 것이 규정의 입법취지에도 부합합니다.

따라서 학교법인등사무직원이 재직기간 중 직무와 관련하여 횡령·배임죄를 범하여 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 경우 「사립학교법」 제70조의4에 따른 당연퇴직 사유에 해당합니다.

관계법령

사립학교법

제70조의2(사무기구 및 직원) ① 학교법인 또는 사립학교경영자는 그의 사무와 그가 설치·경영하는 학교의 사무를 처리하기 위하여 필요한 사무기구를 두되, 그 설치·운영과 사무직원의 정원·임용·보수·복무 및 신분보장에 관하여는 학교법인 또는 법인인 사립학교경영자의 경우에는 정관으로 정하고, 사인인 사립학교경영자의 경우에는 규칙으로 정한다.

② 각급 학교 소속 사무직원은 학교의 장의 제청으로 학교법인 또는 사립학교경영자가 임용한다.

제70조의4(사무직원의 당연퇴직) 제70조의2제1항에도 불구하고 같은 조에 따라 임명된 사무직원의 당연퇴직에 관하여는 「지방공무원법」 제61조제1호를 준용한다. 이 경우 "공무원"은 "사무직원"으로 본다.

지방공무원법

제31조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 공무원이 될 수 없다.

1. ~ 6. (생 략)

6의2. 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 사람

6의3.~ 8. (생 략)

제61조(당연퇴직) 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 당연히 퇴직한다.

1. 제31조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우. 〈단서 생략〉
2. 임기제공무원의 근무기간이 만료된 경우

형법

제355조(횡령, 배임) ①타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.

② 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가한 때에도 전항의 형과 같다.

제356조(업무상의 횡령과 배임) 업무상의 임무에 위배하여 제355조의 죄를 범한 자는 10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0474

교육부 – 「사립학교법」 제25조제4항의 적용 범위(「사립학교법」 제25조제4항 등 관련)

01 질의요지

「사립학교법」 제20조제1항에서 임원[44]은 정관으로 정하는 바에 따라 이사회에서 선임한다고 규정하고 있고, 같은 법 제25조제1항에서 관할청[45]은 학교법인[46]이 이사의 결원을 보충하지 아니하여 학교법인의 정상적 운영이 어렵다고 판단되는 경우(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이해관계인의 청구에 의하여 또는 직권으로 조정위원회[47]의 심의를 거쳐 임시이사를 선임하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서 임시이사는 같은 법 제20조에 따른 임원으로 선임될 수 없다고 규정하고 있는바,

관할청이 「사립학교법」 제25조제1항에 따라 임시이사를 선임한 후, 그 임시이사의 선임 사유가 해소되어 같은 법 제25조의3제1항에 따라 임시이사를 해임하고 이사를 선임하여 학교법인이 정상화된 다음, 해당 학교법인이 그 이사의 임기만료로 새로운 이사를 선임하려는 경우, 같은 법 제25조제4항이 적용되어 정상화 전 해당 학교법인의 임시이사로 선임되었던 사람(이하 "임시이사였던 사람"이라 함)은 같은 법 제20조에 따른 이사로 선임될 수 없는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「사립학교법」 제25조제4항이 적용되지 아니하여 임시이사였던 사람은 같은 법 제20조에 따른 이사로 선임될 수 있습니다.

---

44) 이사장, 이사 및 감사를 말하며(「사립학교법」 제14조제1항 및 제2항 참조), 이하 같음

45) 「사립학교법」 제4조에 따른 관할청(그 주소지를 관할하는 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도 교육감 또는 교육부장관)을 말하며, 이하 같음

46) 사립학교만을 설치·경영할 목적으로 「사립학교법」에 따라 설립되는 법인을 의미하며(「사립학교법」 제2조제2호 참조), 이하 같음

47) 「사립학교법」 제24조의2제1항에 따라 교육부장관 소속으로 두는 사학분쟁조정위원회를 말하며, 이하 같음

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 합니다[48].

먼저 「사립학교법」 제25조에서는 '임시이사의 선임'에 대하여 규정하면서 제1항에서는 학교법인이 이사의 결원을 보충하지 아니하여 학교법인의 정상적 운영이 어렵다고 판단되는 경우나 임시이사를 해임한 경우 등 임시이사의 선임사유를, 제2항에서는 조속한 시일 내에 임시이사 선임사유가 해소될 수 있도록 노력해야 하는 임시이사의 의무를, 제3항에서는 임시이사의 재임기간을, 제4항에서는 정식이사로 선임되지 못하는 임시이사의 임원 선임 제한을 각각 규정하고 있고[49], 같은 법 제25조의2에서는 '임시이사의 해임'에 대하여 규정하고 있으며, 같은 법 제25조의3에서는 '임시이사가 선임된 학교법인의 정상화'에 대하여 각각 규정하고 있는바, 같은 법 제25조부터 제25조의3까지의 규정은 임시이사 선임 사유가 발생하여 관할청이 같은 법 제25조제1항에 따라 임시이사를 선임해야 하는 때부터 그 선임 사유가 해소되어 학교법인이 같은 법 제25조의3에 따라 통상적인 정식이사 체제로 전환될 때까지를 규율하는 것으로서, 「사립학교법」의 규정체계와 문언상 임시이사가 임원으로 선임될 수 없음을 규정하고 있는 같은 법 제25조제4항은 임시이사 선임 사유가 발생한 때부터 그 선임 사유가 해소되어 정식이사 체제로 전환되는 경우 적용될 수 있는 규정으로, 학교법인이 임시이사 체제[50]에서 정식이사 체제[51]로 전환된 후 정상적으로 운영되고 있는 경우에는 적용되지 않는다고 보아야 할 것인바, 이 사안의 경우 같은 법 제25조제4항이 적용되지 아니하여 임시이사였던 사람은 같은 법 제20조에 따른 이사로 선임될 수 있다고 할 것입니다.

그리고 「사립학교법」 제25조제4항의 연혁을 살펴보면, 1999년 8월 19일 법률 제6004호로 일부개정된 「사립학교법」에서 분규가 발생한 학교법인이 정상화되는 경우 그 다음 단계의

48) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

49) 헌법재판소 2013. 11. 28. 선고 2007헌마1189 전원재판부 결정례 참조

50) 「사립학교법」 제25조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로, 같은 항에 따라 임시이사가 선임되어 학교법인이 운영되는 체제를 의미하며, 이하 같음

51) 「사립학교법」 제25조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경우로, 정식이사가 선임되어 학교법인이 운영되는 체제를 의미하며, 이하 같음

절차가 갖추어져 있지 않은 점을 보완하여, 교육부장관이 선임하는 임시이사는 추후 '학교법인이 정상화되는 때' 정식이사로 선임될 수 없도록 하는 규정을 신설하였고[52], 2005년 12월 29일 법률 제7802호로 일부개정된 「사립학교법」 제25조의3으로 임시이사가 선임된 학교법인의 정상화에 관한 규정이 신설되었으며, 이후 운영 실무에 맞추어 의미를 명확히 하기 위하여 임시이사가 선임된 학교법인의 정상화에 따른 정식이사 선임 시 그 정식이사로 선임될 수 없다는 취지로 제25조제4항의 규정을 개정하려고 한 점[53]에 비추어 볼 때, 같은 법 제25조제4항은 임시이사 선임 사유가 발생한 때부터 그 선임 사유가 해소되어 정식이사 체제로 전환되는 경우 적용되는 규정이라 할 것이고, 이 사안과 같이 학교법인이 이미 정식이사 체제로 전환되어 정상적으로 운영되는 경우에는 적용되지 않는 것으로 보아야 할 것입니다.

또한 「사립학교법」 제25조제4항은 '임시이사 체제가 통상적인 학교법인 이사회 체제로 전환될 때' 관할청의 개입을 최소화하고 학교법인의 설립목적 및 독립성을 보장하기 위한 취지에서 규정된 것으로서[54], 임시이사 체제에서 정식이사 체제로 전환되고 난 후 학교법인의 이사는 관할청에 의하여 선임되는 것이 아니라 같은 법 제20조제1항에 따라 정관으로 정하는 바에 따라 해당 학교법인의 이사회에서 선임되므로, 이 사안의 경우 임시이사였던 사람이 같은 법 제20조에 따른 이사로 선임되더라도 관할청이 개입할 여지가 있다거나, 학교법인의 설립목적 및 독립성이 침해될 것이라고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

아울러 「사립학교법」 제22조에서는 이사의 결격사유로 '학교 운영에 중대한 장애를 일으켜 임원 취임의 승인이 취소된 후 10년이 지나지 아니한 사람'(제2호)이나 '교육 관계 법령을 위반하여 해임된 후 6년이 지나지 아니한 사람'(제3호) 등을 별도로 규정하고 있는데, 만약 이 사안의 경우에 「사립학교법」 제25조제4항이 적용되어 '임시이사였던 사람'은 같은 법 제20조에 따른 이사로 선임될 수 없다고 해석하게 된다면, 학교법인의 이사회는 어느 경우에서든 '임시이사였던 사람'을 이사로 선임할 수 없게 되는바, 결격사유로 규정되어 있지 않은 사유인 임시이사직에 있었다는 사정만으로 '임시이사였던 사람'은 정식이사로 선임되는 것 자체가 사실상 불가능하게 되는 결과를 초래하는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「사립학교법」 제25조제4항이 적용되지 아니하여 임시이사였던 사람은 같은 법 제20조에 따른 이사로 선임될 수 있습니다.

---

52) 1998. 12. 2. 의안번호 제151530호로 발의된 사립학교법중개정법률안에 대한 교육위원회 심사보고서 참조

53) 2017. 8. 17. 의안번호 제2008568호로 발의된 사립학교법 일부개정법률안에 대한 교육문화체육관광위원회 검토보고서 참조

54) 법제처 2019. 12. 24. 회신 19-0261 해석례 참조

관계법령

사립학교법

제20조(임원의 선임과 임기) ① 임원은 정관으로 정하는 바에 따라 이사회에서 선임한다.
② 임원은 관할청의 승인을 받아 취임한다. 이 경우 교육부장관이 정하는 바에 따라 인적사항을 공개하여야 한다.
③ 이사장·이사 및 감사의 임기는 정관으로 정하되, 이사는 5년을 초과할 수 없고 중임(重任)할 수 있으며, 감사는 3년을 초과할 수 없고 한 차례만 중임할 수 있다.

제25조(임시이사의 선임) ① 관할청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이해관계인의 청구에 의하여 또는 직권으로 조정위원회의 심의를 거쳐 임시이사를 선임하여야 한다.
1. 학교법인이 이사의 결원을 보충하지 아니하여 학교법인의 정상적 운영이 어렵다고 판단되는 경우
2. 제20조의2에 따라 학교법인의 임원 취임 승인을 취소한 경우. 다만, 임원 취임 승인이 취소되어 제18조제1항에 따른 이사회 의결정족수를 충족하지 못하는 경우로 한정한다.
3. 제25조의2에 따라 임시이사를 해임한 경우

② 임시이사는 조속한 시일 내에 제1항에 따른 사유를 해소할 수 있도록 노력하여야 한다.
③ 임시이사는 제1항에 따른 사유가 해소될 때까지 재임하되, 그 임기는 선임된 날부터 3년을 초과할 수 없다.
④ 임시이사는 제20조에 따른 임원으로 선임될 수 없다.
⑤·⑥ (생 략)

제25조의3(임시이사가 선임된 학교법인의 정상화) ① 관할청은 제20조에도 불구하고 제25조에 따라 선임된 임시이사의 선임 사유가 해소되었다고 인정할 때에는 조정위원회의 심의를 거쳐 지체 없이 임시이사를 해임하고 이사를 선임하여야 한다.
②·③ (생 략)

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0600

민원인 – 「초·중등교육법 시행령」 제29조제1항에 따라 정원 외로 학적이 관리되는 자가 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제2조제3호 등의 "학생"에 포함되는지 여부(「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제2조제3호 등 관련)

01 질의요지

「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」(이하 "학교폭력예방법"이라 함) 제2조제3호에서 "가해학생"이란 가해자 중에서 학교폭력을 행사하거나 그 행위에 가담한 학생을 말한다고 정의하고 있고, 같은 조 제4호에서는 "피해학생"이란 학교폭력으로 인하여 피해를 입은 학생을 말한다고 정의하고 있는 한편,

「초·중등교육법 시행령」 제29조제1항에서는 초등학교 및 중학교의 장(이하 "초등학교장 등"이라 함)은 입학 이후 취학 의무를 유예받은 학생(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 학생에 대하여 학칙이 정하는 바에 따라 정원 외로 학적을 관리할 수 있다고 규정하고 있는바,

학교폭력예방법 제2조제3호에 따른 "가해학생" 및 같은 조 제4호에 따른 "피해학생"의 정의에서 규정된 "학생"에 「초·중등교육법 시행령」 제29조제1항에 따라 정원 외로 학적이 관리되는 자(이하 "정원외학적관리자"라 함)[55]가 포함되는지?

02 회답

학교폭력예방법 제2조제3호에 따른 "가해학생" 및 같은 조 제4호에 따른 "피해학생"의 정의에서 규정된 "학생"에는 정원외학적관리자가 포함됩니다.

55) 초등학교 및 중학교에서 학적이 관리되는 자를 대상으로 하는 것을 전제함

03 이유

법령에서 사용되는 용어의 의미를 별도로 정의하거나 의미와 내용을 제한·확대하여야 할 특별한 규정을 두고 있지 않는 등 그 용어의 의미가 불명확한 경우에는 그 법령의 규정 내용과 입법 취지는 물론 입법 취지가 유사한 다른 법령과의 관계, 사회에서 일반적으로 통용되는 의미 등을 종합적으로 고려하여 해석할 수 있다고 할 것인데[56], 학교폭력예방법 제2조제3호에서는 "가해학생"이란 가해자 중에서 학교폭력을 행사하거나 그 행위에 가담한 "학생"을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4호에서는 "피해학생"이란 학교폭력으로 인하여 피해를 입은 "학생"을 말한다고 규정하면서, 같은 법령에서는 "학생"의 의미에 대해서 별도로 정의하거나 그 범위 등에 관하여 규정하고 있지는 않은바, 같은 법 제2조제3호·제4호에서 규정된 각각의 "학생"에 정원외학적관리자가 포함되는지 여부는 학교폭력예방법령의 규정 및 입법 취지, 다른 교육관계 법령과의 체계적 조화 등을 종합적으로 고려해서 판단해야 할 것입니다.

먼저 학교폭력예방법 제2조제2호에서는 "학교"를 「초·중등교육법」 제2조에 따른 초등학교·중학교·고등학교·특수학교 등으로 정의하고 있어 학교폭력예방법의 적용대상은 「초·중등교육법」에 따른 학교라고 할 것인데, 초·중등교육법령에서는 "학생"에 대하여 별도로 정의하고 있지 않으나 「초·중등교육법 시행령」 제29조제1항에서 초등학교장등은 '입학 이후 취학의무를 유예받은 학생'(제1호), '정당한 사유 없이 해당 학년도 수업일수의 3분의 1 이상 장기결석한 학생'(제2호), '초등학교장등이 같은 항 제2호에 따른 장기결석 학생이 학교에 출석할 수 있도록 해당 학생의 보호자에게 취학 통보를 하였으나[57] 학년도가 시작된 후에도 계속하여 출석하지 않은 학생'(제3호)에 대하여 학칙이 정하는 바에 따라 정원 외로 학적을 관리할 수 있다고 규정하여 문언상 정원외학적관리자는 초·중등교육법령상 "학생"임을 전제하고 있고, 「초·중등교육법」 제25조제1항 및 같은 법 시행규칙 제25조의 위임에 따라 마련된 교육부훈령인 「학교생활기록 작성 및 관리지침」(이하 "학교생활 기록지침"이라 함) 별표 7에서는 "재학"의 정의를 '당해 학교의 학생 신분(학적)을 보유하는 것'이라고 하여 학적을 학생 신분을 나타내는 것으로 규정하고 있으므로, 초·중등교육법령상 "정원외학적관리자"는 "학생"에 해당한다고 할 것입니다.

그렇다면 앞서 살펴본 바와 같이 학교폭력예방법의 적용대상은 「초·중등교육법」상의 학교이고, 그 학교의 "학생" 또한 초·중등교육법령상의 학생으로 보아야 할 것이므로,

56) 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0572 해석례 참조

57) 학교폭력예방법 제25조제5항제2호에 따른 통보를 말함.

학교폭력예방법 제2조제3호에 따른 “가해학생” 및 같은 조 제4호에 따른 “피해학생”의 정의에서 규정된 “학생”에는 정원외학적관리자가 포함된다고 할 것입니다.

그리고 학교폭력예방법은 학교폭력의 예방과 대책에 필요한 사항을 규정함으로써 피해학생의 보호, 가해학생의 선도·교육 및 피해학생과 가해학생 간의 분쟁조정을 통하여 학생의 인권을 보호하고 학생을 건전한 사회구성원으로 육성함을 목적으로 하는 법률(제1조)인데, 만약 학교폭력으로 인한 충격이나 학교폭력을 피하기 위해 장기결석 등을 하여 “정원외학적관리자”로 분류된 학생을 “피해학생”에 해당하지 않는 것으로 해석할 경우, 해당 정원외학적관리자는 학교폭력예방법에 따른 학교폭력 조사·상담(제11조의2), 피해학생의 보호(제16조), 장애학생의 보호(제16조의2), 사이버폭력의 피해자 지원(제16조의4), 가해학생에 대한 조치(제17조) 등의 적용 대상에서 제외되어 적절한 보호 및 지원을 받지 못하게 되고, “정원외학적관리자”를 “가해학생”에 해당하지 않는 것으로 해석할 경우, 학교폭력예방법 제17조에 따른 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위의 금지(제2호), 사회봉사(제4호), 학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료(제5호) 등의 조치를 하지 못하는 불합리한 결과가 초래되어 피해학생의 보호와 가해학생의 선도·교육이라는 입법목적에도 부합하지 않게 됩니다.

아울러 「교육기본법」 제8조제1항에 따라 6년의 초등교육과 3년의 중등교육은 의무교육에 해당하므로, 의무교육대상자는 「초·중등교육법」 제13조에 따라 초등학교(제1항·제2항) 및 중학교(제3항)에 입학하여 졸업할 때까지 다녀야 하고 초등학교 또는 중학교에 입학함으로써 학생 신분을 취득한다고 할 것인데, 의무교육대상자는 같은 법 제18조제1항 단서에 따라 퇴학이 불가능하며, 학교생활기록지침 별표 7에 따르면 학칙에 따라 재학생 자격이 소멸되어 학적에서 제외되는 제적이나(제17호), 학생의 바람으로 재학생의 신분을 포기하는 자퇴(제18호)가 허용되지 않는다는 점에서 특별한 경우를 제외하고는 학생 신분의 상실 또는 포기 등이 인정되지 않고, 「초·중등교육법」 제28조제1항에서는 학업을 중단하거나 학업 중단 위기에 있는 학생을 위하여 교육상 시책을 마련하도록 하는 등 의무교육대상자의 경우 취학의무를 유예하거나 학업을 중단한다고 하더라도 곧바로 “학생”의 신분이 상실되는 것이 아니고 “정원외학적관리자”로 분류하여 학적을 작성·관리하고 출석을 독려하며 학업을 지속할 수 있도록 하고 있는바, 정원 외로 학적이 관리된다는 것만으로 학생 신분이 상실된다고 볼 수 없다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 학교폭력예방법 제2조제3호에 따른 “가해학생” 및 같은 조 제4호에 따른 “피해학생”의 정의에서 규정된 “학생”에는 정원외학적관리자가 포함된다고 할 것입니다.

관계법령

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "학교폭력"이란 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취·유인, 명예훼손·모욕, 공갈, 강요·강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버폭력 등에 의하여 신체·정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위를 말한다.

1의2.·1의3. (생 략)

2. "학교"란 「초·중등교육법」 제2조에 따른 초등학교·중학교·고등학교·특수학교 및 각종학교와 같은 법 제61조에 따라 운영하는 학교를 말한다.
3. "가해학생"이란 가해자 중에서 학교폭력을 행사하거나 그 행위에 가담한 학생을 말한다.
4. "피해학생"이란 학교폭력으로 인하여 피해를 입은 학생을 말한다.
5. (생 략)

초·중등교육법 시행령

제29조(유예자의 학적관리 등) ① 초등학교 및 중학교의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 학생에 대하여 학칙이 정하는 바에 따라 정원 외로 학적을 관리할 수 있다.

1. 입학 이후 취학 의무를 유예받은 학생
2. 정당한 사유 없이 해당 학년도 수업일수의 3분의 1 이상 장기 결석한 학생
3. 초등학교 및 중학교의 장이 제25조제5항제2호에 따라 이 항 제2호의 장기결석 학생이 학교에 출석할 수 있도록 해당 학생의 보호자에게 통보했으나 학년도가 시작된 후에도 계속하여 출석하지 않은 학생

② (생 략)

제2절 여성가족·청소년

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0786, 24-0161

경기도 파주시 -「청소년활동 진흥법」 제16조제1항에 따라 청소년수련관의 운영을 위탁받은 청소년단체가 그 청소년수련관의 운영을 같은 항에 따라 다른 청소년단체에 재위탁할 수 있는지 여부 등(「청소년활동 진흥법」 제16조제1항 등 관련)

01 질의요지

「청소년활동 진흥법」(이하 "청소년활동법"이라 함) 제11조제1항 각 호 외의 부분에서는 국가 및 지방자치단체는 「청소년기본법」 제18조제1항에 따라 청소년활동법 제11조제1항 각 호와 같은 수련시설[58]을 설치·운영해야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 제2호에서는 시·도지사[59] 및 시장·군수·구청장[60]은 각각 같은 법 제10조제1호가목에 따른 청소년수련관을 1개소 이상 설치·운영해야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제16조제1항에서는 국가 또는 지방자치단체, 같은 법 제11조제3항에 따라 허가를 받은 수련시설 설치·운영자는 수련시설의 효율적 운영을 위하여 청소년단체[61]에 그 운영을 위탁할 수 있다고 규정하고 있는바,

가. 시장이 청소년활동법 제11조제1항제2호에 따라 설치한 청소년수련관(이하 '이 사안 청소년수련관'이라 함)의 운영을 같은 법 제16조제1항에 따라 청소년단체 A[62]에 위탁한 경우, 청소년단체 A(수탁기관)는 이 사안 청소년수련관의 운영을 같은 항에 따라 다른 청소년단체에 다시 위탁(이하 "재위탁"이라 함)할 수 있는지?[63]

58) 청소년활동법 제10조제1호의 청소년수련시설을 말하며(청소년활동법 제4조제1항 참조), 이하 같음.
59) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 말하며, 이하 같음.
60) 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음.
61) 「청소년기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체를 말하며(청소년활동법 제8조제2항 참조), 이하 같음.
62) 청소년활동법 제11조제3항에 따라 허가를 받은 수련시설 설치·운영자가 아닌 경우를 전제함.

나. 이 사안 청소년수련관의 운영을 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제21조제1항에 따라 출연기관[64] B[65]가 대행하는 경우, 출연기관 B(대행기관)는 이 사안 청소년수련관의 운영을 청소년활동법 제16조제1항에 따라 청소년단체에 위탁할 수 있는지?[66]

02 회답

가. 질의 가에 대해

청소년단체 A(수탁기관)는 이 사안 청소년수련관의 운영을 청소년활동법 제16조제1항에 따라 다른 청소년단체에 재위탁할 수 없습니다.

나. 질의 나에 대해

출연기관 B(대행기관)는 이 사안 청소년수련관의 운영을 청소년활동법 제16조제1항에 따라 청소년단체에 위탁할 수 없습니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

먼저 행정업무의 '민간위탁'이란 법률에 규정된 행정기관의 사무 중 일부를 국가나 지방자치단체가 아닌 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 맡겨 그의 명의로 그의 책임 아래 행사하도록 하는 것으로서, 법률에 따라 정해진 직무범위 및 행위주체를 대·내외적으로 변경하는 효과가 있으므로 특정 행정사무에 관한 법령상의 권한 주체를 변경하려면 법령에 개별적이고 명시적인 근거를 두어야 하고[67], 위탁받은 사무(수탁사무)를 다시 재위탁하는

63) 청소년단체 A가 자신의 명의와 책임으로 다른 청소년단체에 위탁하려는 경우를 전제하며, 청소년활동법 제16조제1항 외에 다른 법령의 규정을 근거로 재위탁할 수 있는지 여부는 별론으로 함.

64) 지방자치단체가 설립하고 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따라 지정·고시된 출연기관을 말하며(같은 법 제2조제1항 참조), 이하 같음.

65) 청소년활동법 제11조제3항에 따라 허가를 받은 수련시설 설치·운영자가 아닌 경우를 전제함.

66) 출연기관 B가 자신의 명의와 책임으로 청소년단체에 위탁하려는 경우를 전제함.

67) 법제처 2011. 2. 17. 회신 11-0005 해석례, 법제처 2016. 2. 24. 회신 16-0006 해석례 참조

경우에도 별도의 법령상 근거가 있어야 합니다[68].

그런데 청소년의 권리 및 책임과 가정·사회·국가·지방자치단체의 청소년에 대한 책임을 정하고 청소년정책에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적[69]으로 하는 법률인 「청소년 기본법」 제18조제1항에서는 국가 및 지방자치단체는 청소년시설을 설치·운영해야 한다고 규정하고 있고, 이에 따라 청소년활동법 제11조제1항제2호에서는 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 각각 같은 법 제10조제1호가목에 따른 '청소년수련관을 1개소 이상 설치·운영해야 한다'고 규정하고 있는바, 같은 법 제11조제1항제2호에 따라 설치된 '이 사안 청소년수련관'은 이를 설치한 '시장'이 직접 '운영'해야 하는 법률상 의무가 있다고 할 것입니다.

그렇다면 이 사안 청소년수련관을 시장이 직접 운영하는 대신 다른 자에게 위탁하여 운영하거나 그 수탁기관이 이를 다시 재위탁하기 위해서는 청소년활동법령상 근거가 있어야 할 것인데, 청소년활동법 제16조제1항에서는 시장이 수련시설의 운영을 청소년단체에 위탁할 수 있는 근거 규정을 두고 있을 뿐, 재위탁에 관한 근거 규정은 두고 있지 않으므로, 청소년활동법령상 근거 없는 재위탁은 할 수 없는 것으로 보아야 합니다.

따라서 청소년단체 A(수탁기관)는 이 사안 청소년수련관의 운영을 청소년활동법 제16조제1항에 따라 다른 청소년단체에 재위탁할 수 없습니다.

나. 질의 나에 대해

먼저 행정업무의 '민간위탁'이란 법률에 규정된 행정기관의 사무 중 일부를 국가나 지방자치단체가 아닌 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 맡겨 그의 명의로 그의 책임 아래 행사하도록 하는 것으로서, 법률에 따라 정해진 직무범위 및 행위주체를 대·내외적으로 변경하는 효과가 있으므로 행정기관이 그 업무를 민간에 위탁하려면 법률에 개별적이고 명시적인 위탁 근거가 있어야 합니다[70].

이와 관련하여 청소년활동법 제16조제1항에서는 '국가 또는 지방자치단체', 같은 법 제11조제3항에 따라 허가를 받은 '수련시설 설치·운영자'는 수련시설의 효율적 운영을 위하여 청소년단체에 그 운영을 위탁할 수 있다고 규정하고 있는바, 같은 법 제16조제1항을 근거로 수련시설의 운영을 청소년단체에 위탁할 수 있는 주체는 행정청인 '국가, 지방자치

68) 대법원 2000. 11. 10. 선고 2000추36 판결례, 법제처 2016. 2. 24. 회신 16-0006 해석례 및 법제처 2016. 5. 20. 회신 16-0131 해석례 참조

69) 「청소년 기본법」 제1조 참조.

70) 법제처 2016. 2. 24. 회신 16-0006 해석례 참조

단체'와 '수련시설 설치·운영자'로 한정되어 있으므로, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제21조제1항에 따라 이 사안 청소년수련관의 운영을 대행하고 있는 출연기관 B는 청소년수련관의 운영을 청소년활동법 제16조제1항에 따라 다른 청소년단체에 위탁할 수 없다고 보는 것이 타당합니다.

또한 일반적으로 '행정사무의 대행'은 행정권한이 이전되는 위임·위탁'과는 달리 '행정청의 명의와 책임'으로 권한을 행사하되, 실제적인 업무는 대행기관이 수행하도록 하는 것으로서 법적인 권한의 귀속 자체가 변경되는 것이 아닌바[71], 이 사안과 같이 지방자치단체가 청소년수련관을 직접 운영하거나 청소년활동법 제16조제1항에 따라 청소년단체로 하여금 위탁 운영하게 하는 대신, 출연기관 B로 하여금 운영을 '대행'하도록 한 경우에는 출연기관 B는 청소년수련관의 운영에 관한 실질적인 업무를 대행하는 자에 불과하며, 이 사안 청소년수련관은 여전히 '지방자치단체의 명의와 책임'으로 운영되는 것이므로, 출연기관 B는 대행 중인 청소년수련관의 운영을 같은 항에 따라 자신의 명의와 책임으로 청소년단체에게 위탁할 '권한'이 없다고 보아야 합니다.

따라서 출연기관 B(대행기관)는 이 사안 청소년수련관의 운영을 청소년활동법 제16조제1항에 따라 청소년단체에 위탁할 수 없습니다.

관계법령

청소년활동 진흥법

제11조(수련시설의 설치·운영 등) ① 국가 및 지방자치단체는 「청소년기본법」 제18조제1항에 따라 다음 각 호와 같은 수련시설을 설치·운영하여야 한다.

1. (생 략)
2. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 시장·군수·구청장은 각각 제10조제1호가목에 따른 청소년수련관을 1개소 이상 설치·운영하여야 한다.

3·4. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

제16조(수련시설 운영의 위탁) ① 국가 또는 지방자치단체, 제11조제3항에 따라 허가를 받은 수련시설 설치·운영자는 수련시설의 효율적 운영을 위하여 청소년단체에 그 운영을 위탁할 수 있다.

② ~ ④ (생 략)

71) 법제처 2008. 12. 24. 회신 08-0388 해석례 및 법제처 2017. 3. 6. 회신 17-0034 해석례 참조

질의제목 2 ▶ 안건번호 24-0078

광주광역시 광산구 – 청소년수련시설 운영대표자의 자격요건으로서 청소년육성업무에 종사한 경력으로 인정되는 '청소년단체활동 지도교사로 종사한 경력'의 의미(「청소년활동 진흥법 시행규칙」 제7조제4호 등 관련)

01 질의요지

「청소년활동 진흥법」(이하 "청소년활동법"이라 함) 제14조제1항 본문의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제8조에서는 같은 법 제10조제1호의 청소년수련시설(이하 "수련시설"이라 함)의 설치·운영자 등이 선임해야 하는 운영대표자의 자격 요건으로 '2급 청소년지도사 자격증 취득 후 청소년육성업무에 3년 이상 종사한 사람'(제2호) 등을 규정(제1항)하면서, 그 '청소년육성업무에 종사한 경력'에 관하여는 여성가족부령으로 정하도록 규정(제2항)하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제7조 제4호에서는 "「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교에서 청소년단체활동 지도교사로 종사한 경력"을 청소년육성업무에 종사한 경력으로 규정하고 있는바,

「청소년활동 진흥법 시행규칙」(이하 "청소년활동법 시행규칙"이라 함) 제7조제4호에 따른 경력에 '「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교에서 「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체 관련 활동에 해당하지 않는 청소년 관련 단체 활동[72]의 지도교사로 종사한 경력'이 포함되는지?

02 회답

청소년활동법 시행규칙 제7조제4호에 따른 경력에 '「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교에서 「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체 관련 활동에 해당하지 않는 청소년 관련 단체 활동의 지도교사로 종사한 경력'은 포함되지 않습니다.

72) 동아리, 방과 후 클래스 등 청소년활동, 청소년복지, 청소년보호를 주요 목적 등으로 각급 학교 내·외부에서 주관하여 운영하는 단체 활동임을 전제함.

03 이유

청소년활동법 제14조제1항 본문에서는 수련시설 설치·운영자 또는 위탁운영단체는 '대통령령으로 정하는 자격을 갖춘 사람'을 그 수련시설의 운영대표자로 선임해야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제8조에서는 수련시설 운영대표자의 자격을 갖춘 사람으로 2급 청소년지도사 자격증 취득 후 청소년육성업무에 3년 이상 종사한 사람(제2호), 「초·중등교육법」 제21조에 따른 정교사 자격증 소지자 중 청소년육성업무에 5년 이상 종사한 사람(제4호), 청소년육성업무에 8년 이상 종사한 사람(제5호) 등을 규정(제1항)하면서, 그 청소년육성업무에 종사한 경력에 관하여는 여성가족부령으로 정한다고 규정(제2항)하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제7조제4호에서는 수련시설 운영대표자의 청소년육성업무 종사경력을 "「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교에서 청소년단체활동 지도교사로 종사한 경력"으로 규정하고 있습니다.

그런데 청소년활동법 제8조제2항에서는 '「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체'를 '청소년단체'로 약칭하여 그 이하에서 '청소년단체'라는 용어가 사용되는 경우 '「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체'를 의미하도록 규정하고 있는바, 이 사안에서는 청소년활동법 시행규칙 제7조제4호에 규정된 '청소년단체활동'의 범위가 '「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체 관련 활동'으로 한정되는지 여부가 문제됩니다.

먼저 청소년활동법 제10조제1호에 따른 '수련시설'은 청소년이 청소년활동에 자발적으로 참여하여 청소년 시기에 필요한 기량과 품성을 함양하는 교육적 활동으로서 「청소년기본법」 제3조제7호에 따른 청소년지도자와 함께 청소년수련거리[73]에 참여하여 배움을 실천하는 체험활동인 '청소년수련활동' 등이 전문적으로 이루어지는 시설로서, 청소년활동법 제14조제1항 본문에서는 이러한 수련시설의 설치·운영자 또는 위탁운영단체로 하여금 대통령령으로 정하는 일정한 자격을 갖춘 자를 해당 수련시설의 '운영대표자'로 선임하도록 하고 있고, 이에 따라 선임된 운영대표자는 수련시설을 운영하면서 같은 법에 따라 수련시설의 안전점검(제18조), 그 종사자에 대한 운영·안전·위생 교육(제19조) 등을 실시해야 하는바, 이처럼 수련시설의 운영은 청소년에 대한 전반적인 이해와 관련 분야의 전문적인 지식이 함께 요구되는 업무로서 해당 수련시설을 이용하는 청소년의 안전과도 직결된다는 점을 고려할 때, 수련시설 운영업무의 단순 수행을 넘어 수련시설의 전반적인 운영을 책임지게 되는 '운영대표자'의 자격에 관한 사항은 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것입니다.

73) 청소년수련활동에 필요한 프로그램과 이와 관련되는 사업을 말함(청소년활동법 제2조제6호 참조).

그런데 청소년활동법은 청소년의 권리 및 책임과 가정·사회·국가·지방자치단체의 청소년에 대한 책임을 정하고 청소년정책에 관한 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 하는 법률인 「청소년 기본법」 제47조제2항에 따라 다양한 청소년활동을 적극적으로 진흥하기 위하여 필요한 사항을 정하기 위한 목적 하에 별도로 제정된 법률(제1조)로서, 청소년 활동법에서는 "청소년활동"을 「청소년 기본법」 제3조제3호에 따른 청소년활동을 말한다고 규정(제2조제1호)하고 있는 등 전반적으로 「청소년 기본법」에서 규정하고 있는 청소년 관련 개념을 차용하고 있고, 청소년활동법 제8조제2항에서는 '「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체'를 '청소년단체'로 약칭하고, 그 이하에서 수련시설 운영의 위탁(제16조), 수련시설 이용 요청(제31조), 교포청소년교류활동의 국가 지원(제56조제2항), 청소년교류 센터의 운영 위탁(제58조제2항) 등의 대상을 앞서 약칭한 '청소년단체'로 규정하고 있는바, 청소년활동법 시행규칙 제7조제4호에 규정된 '청소년단체' 역시 같은 규칙 제7조제2호 및 제15조의3에서 규정하고 있는 '청소년단체'와 마찬가지로 「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체만을 의미하는 것으로서, 청소년활동법 시행규칙 제7조제4호의 '청소년 단체활동 지도교사로 종사한 경력'에는 '「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체에 해당하지 않는 청소년 관련 단체의 활동 지도교사로 종사한 경력'은 포함되지 않는다고 보는 것이 청소년활동법의 입법목적 및 청소년활동법령의 규정체계에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

또한 청소년활동법 시행규칙 제7조제4호는 2008년 1월 28일 총리령 제872호로 청소년활동법 시행규칙을 일부개정하면서 신설된 규정으로, 같은 규칙 제7조제2호에 따른 청소년 육성업무 종사경력이 "청소년단체에서 청소년지도·연구업무에 종사한 경력"으로 한정되어 있어, 청소년단체에 종사하지 않는 교사의 학교 내 청소년단체 관련 지도 업무 경력이 청소년 육성업무 종사경력으로 인정되기 어려운 문제를 개선하기 위해 신설된 것이라는 점[74]에 비추어 보더라도, 청소년활동법 시행규칙 제7조제4호에 따른 경력은 같은 조 제2호와 마찬가지로 '「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체'와 관련된 경력으로 보아야 할 것인바, 청소년활동법 시행규칙 제7조제4호에 따른 "청소년단체활동"은 청소년단체의 회원인 학교 내 학생들을 대상으로 이루어지는 활동으로 보는 것이 해당 규정의 입법연혁에도 부합하는 해석입니다.

아울러 만약 「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체에 해당하지 않는 단체의 활동 지도교사로 종사한 경력까지 청소년활동법 시행규칙 제7조제4호에 따른 '청소년단체활동 지도교사로 종사한 경력'으로 인정하게 될 경우, 수련시설 운영대표자의 자격 요건과 관련하여

74) 2008. 1. 28. 총리령 872호로 일부개정되어 같은 날 시행된 청소년활동진흥법 시행규칙 일부개정령 제·개정 설명자료 등 참조

청소년육성업무 경력으로 인정되는 '청소년단체활동'의 판단기준이 불분명해지게 되는 등 운영대표자 자격 요건 충족 여부에 관한 객관적인 판단이 곤란해지는 문제가 발생할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 청소년활동법 시행규칙 제7조제4호에 따른 경력에 '「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교에서 「청소년 기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체 관련 활동에 해당하지 않는 청소년 관련 단체 활동의 지도교사로 종사한 경력'은 포함되지 않습니다.

법령정비 권고사항

청소년활동법 시행규칙 제7조제4호에 따른 '청소년단체활동'의 의미를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

청소년활동 진흥법 시행규칙

제7조(수련시설 운영대표자의 청소년육성업무 종사경력) 영 제8조제2항에 따른 청소년육성업무 종사경력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경력을 말한다.

1. ~ 3. (생 략)
4. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교에서 청소년단체활동 지도교사로 종사한 경력

청소년 기본법

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 7. (생 략)
8. "청소년단체"란 청소년육성을 주된 목적으로 설립된 법인이나 대통령령으로 정하는 단체를 말한다.

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0460, 24-0564

민원인 – 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제7조의3제1항 및 제5항에 따른 “국가”에 지방자치단체가 포함되는지 여부(「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제7조의3제1항 등 관련)

01 질의요지

「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」(이하 “성폭력방지법”이라 함) 제7조의3제1항에서 ‘국가는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 촬영물 또는 복제물 등(이하 “촬영물등”이라 함)이 정보통신망(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호의 정보통신망을 말하며, 이하 같음)에 유포되어 피해(촬영물등의 대상자로 등장하여 입은 피해를 말함)를 입은 사람에 대하여 촬영물등의 삭제를 위한 지원을 할 수 있다’고 규정하면서, 성폭력방지법 제7조의3제5항에서는 ‘국가가 같은 조 제1항에 따라 촬영물등 삭제 지원에 소요되는 비용을 지출한 경우 같은 조 제4항의 성폭력행위자 또는 아동·청소년대상 성범죄행위자에 대하여 구상권(求償權)을 행사할 수 있다’고 규정하고 있는바,

성폭력방지법 제7조의3제1항 및 제5항에 따른 “국가”에 지방자치단체가 포함되는지?

02 회답

성폭력방지법 제7조의3제1항 및 제5항에 따른 “국가”에 지방자치단체는 포함되지 않습니다.

03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미를 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될

수밖에 없다고 할 것이고[75], 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용되어야 할 것인데[76], 성폭력방지법 제3조(국가 등의 책무)제1항·제2항, 제7조(피해자등에 대한 취학 및 취업 지원)제1항·제3항, 제10조(상담소의 설치·운영)제1항 등에서는 "국가와 지방자치단체" 또는 "국가 또는 지방자치 단체"로 규정하여 '국가'와 '지방자치단체'라는 용어를 함께 나열하면서 서로 구분되는 개념으로 사용하고 있으므로, 성폭력방지법 제7조의3제1항 및 제5항에 따른 "국가"도 지방자치단체와는 구분되는 개념으로서 같은 조 제1항 및 제5항에 따른 "국가"에 '지방자치단체'는 포함되지 않는다고 보는 것[77]이 그 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 성폭력방지법 제7조의3에서는 불법촬영물등으로 인한 피해자에 대한 지원 등을 하는 주체를 같은 조 제1항, 제3항 및 제5항에서 '국가'로 명시하면서, 같은 조 제6항에서는 같은 조 제1항 및 제2항에 따른 촬영물등 삭제지원의 내용·방법, 제3항 후단에 따른 자료 보관의 방법·기간 및 제5항에 따른 구상권 행사의 절차·방법 등에 필요한 사항은 여성가족부령으로 정한다고 규정하고 있고, 같은 조 제6항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제2조의6을 살펴보면, 같은 법 제7조의3과 관련된 구체적인 업무를 "여성가족부장관"이 수행하도록 명시하고 있을 뿐이고, "특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장"은 함께 규정하고 있지 않은바, 같은 법 제7조의3제1항에 따른 촬영물등의 삭제지원과 같은 조 제5항에 따른 구상권 행사의 주체에 '지방자치단체'가 포함된다고 보기는 어렵습니다.

따라서 성폭력방지법 제7조의3제1항 및 제5항에 따른 "국가"에 지방자치단체는 포함되지 않습니다.

법령정비 권고사항

성폭력방지법 제7조의3제1항에 따른 촬영물등의 삭제지원과 같은 조 제5항에 따른 구상권 행사의 주체에 지방자치단체도 포함할 필요가 있는지 정책적으로 검토하여 그 결과에 따라 관련 규정을 개정할 필요가 있습니다.

75) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
76) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조
77) 법제처 2024. 3. 28. 회신 23-1160 해석례 참조



관계법령

성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

제7조의3(불법촬영물등으로 인한 피해자에 대한 지원 등) ① 국가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 촬영물 또는 복제물 등(이하 이 조에서 "촬영물등"이라 한다)이 정보통신망(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호의 정보통신망을 말한다. 이하 같다)에 유포되어 피해(촬영물등의 대상자로 등장하여 입은 피해를 말한다)를 입은 사람에 대하여 촬영물등의 삭제를 위한 지원을 할 수 있다.

1. ~ 3. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

⑤ 국가가 제1항에 따라 촬영물등 삭제지원에 소요되는 비용을 지출한 경우 제4항의 성폭력행위자 또는 아동·청소년대상 성범죄행위자에 대하여 구상권(求償權)을 행사할 수 있다.

⑥ (생 략)

제3절 문화체육관광

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0916

민원인 – 「관광진흥법 시행령」 제13조제1항제3호나목의 "건축물 각 부분의 높이"의 의미(「관광진흥법 시행령」 제13조제1항제3호나목 등 관련)

01 질의요지

「관광진흥법」 제15조제1항에서 관광숙박업을 경영하려는 자는 그 사업에 대한 사업계획(이하 "사업계획"이라 함)을 작성하여 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수· 구청장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항의 위임에 따라 사업계획의 승인 및 변경승인의 기준을 정하고 있는 같은 법 시행령 제13조제1항제3호나목에서는 일반 주거지역의 관광숙박시설이 설치되는 '건축물(관광숙박시설이 설치되는 건축물 전부를 말함) 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 인접대지를 조망할 수 있는 창이나 문 등의 개구부(이하 "개구부"라 함)가 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접된 대지의 경계선[78]까지의 수평거리의 두 배를 초과하지 아니할 것'을 규정하고 있는바,

관광숙박시설이 여러 층으로 이루어진 건축물에 설치되는 경우로서, 해당 건축물의 일부 층에 개구부가 설치된 경우, 「관광진흥법 시행령」 제13조제1항제3호나목의 "건축물 각 부분의 높이"는 해당 '건축물 각 부분[79]의 전체 높이[80]'를 의미하는지, 아니면 해당 '건축물의 각 부분에서 가장 높은 개구부가 있는 층까지의 높이'를 의미하는지?

78) 대지와 대지 사이가 공원·광장·도로·하천이나 그 밖의 건축이 허용되지 아니하는 공지(空地)인 경우에는 그 인접된 대지의 반대편 경계선을 말하며, 이하 같음.

79) 개구부가 설치된 부분을 전제로 하며, 이하 같음.

80) 「건축법 시행령」 제119조제1항제5호에 따라 산정된 높이를 말하며, 이하 같음.

02 회답

이 사안의 경우, 「관광진흥법 시행령」 제13조제1항제3호나목의 "건축물 각 부분의 높이"는 건축물 각 부분의 전체 높이를 의미합니다.

03 이유

「관광진흥법 시행령」 제13조제1항제3호나목에서는 「관광진흥법」 제15조제1항에 따른 사업계획의 승인 및 변경승인 기준의 하나로 일반 주거지역에 관광숙박시설을 설치하려는 경우 관광숙박시설이 설치되는 '건축물 각 부분의 높이'는 그 '건축물 각 부분으로부터 개구부가 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접된 대지의 경계선까지의 수평거리의 두 배'를 초과하지 아니할 것을 요구하고 있는데, 이 사안에서는 '개구부가 있는 벽면'의 의미와 관련하여 '건축물 각 부분의 높이'가 해당 '건축물 각 부분의 전체 높이'를 의미하는지, 아니면 '건축물의 각 부분에서 개구부가 있는 벽면의 층까지의 높이'를 의미하는지가 문제됩니다.

먼저 「관광진흥법」 제16조제5항에서는 '같은 법 제15조제1항에 따른 사업계획의 승인 또는 변경승인을 받은 경우 그 사업계획에 따른 관광숙박시설 및 그 시설 안의 위락시설로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함)에 따라 지정된 상업지역(제1호) 및 주거지역·공업지역 및 녹지지역 중 대통령령으로 정하는 지역(제2호)에 대하여는 같은 법 제76조제1항을 적용하지 아니한다'고 규정하면서(본문), 주거지역에서는 주거환경의 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 '사업계획승인기준'에 맞는 경우에 한정한다고 규정(단서)하고 있는바, 이는 관광객 수용을 위한 관광숙박시설이 부족한 실정을 고려하여 관광숙박시설에 대한 건축 규제를 완화하기 위해 국토계획법에 따른 용도지역 및 용도 지구에서의 건축물의 건축제한에 대한 특례[81]를 규정하여 일반주거지역에서도 관광 숙박시설을 설치할 수 있도록 하면서도, 관광숙박시설이 일반주거지역의 쾌적한 주거환경을 훼손할 우려를 방지하기 위하여 주거지역의 경우에는 주거환경 보호를 위하여 정해진 '사업계획승인기준'에 맞는 경우에 한정하여 특례를 적용하도록 함으로써, 주거환경 보호와 조화를 이루려는 입법취지를 가졌다고 할 것[82]입니다.

81) 국토계획법 제76조 및 같은 법 시행령 제71조제1항, 같은 영 별표 4부터 별표 6까지에 따라 일반주거지역에는 관광숙박시설을 건축할 수 없음.

82) 법제처 2013. 5. 28. 회신 13-0134 해석례 참조

그렇다면 이러한 사업계획승인기준의 하나인 「관광진흥법 시행령」 제13조제1항제3호나목은 주변 주택 등의 채광이나 일조 등의 보호뿐만 아니라 일반주거지역에서 무분별하게 관광숙박시설이 설치되어 쾌적한 주거환경이 훼손되지 않도록 주거환경 보호라는 관점에서 엄격하게 해석해야 할 것[83]인바, 같은 목에서 '개구부가 있는 벽면'을 기준으로 인접된 대지의 경계선까지의 수평거리를 측정하도록 하고 있다는 이유로 이 사안에 따른 "건축물의 각 부분의 높이"를 '건축물의 각 부분에서 가장 높은 개구부가 있는 층까지의 높이'로 완화하여 해석하는 것은 해당 규정의 취지에 부합하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「관광진흥법 시행령」 제13조제1항제3호나목의 "건축물 각 부분의 높이"는 건축물 각 부분의 전체 높이를 의미합니다.

관계법령

관광진흥법

제15조(사업계획의 승인) ①관광숙박업을 경영하려는 자는 제4조제1항에 따른 등록을 하기 전에 그 사업에 대한 사업계획을 작성하여 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 승인을 받아야 한다. 승인을 받은 사업계획 중 부지, 대지 면적, 건축 연면적의 일정 규모 이상의 변경 등 대통령령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② 대통령령으로 정하는 관광객 이용시설업이나 국제회의업을 경영하려는 자는 제4조제1항에 따른 등록을 하기 전에 그 사업에 대한 사업계획을 작성하여 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 승인을 받을 수 있다. 승인을 받은 사업계획 중 부지, 대지 면적, 건축 연면적의 일정 규모 이상의 변경 등 대통령령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

③ 제1항과 제2항에 따른 사업계획의 승인 또는 변경승인의 기준·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

관광진흥법 시행령

제13조(사업계획 승인기준) ① 법 제15조에 따른 사업계획의 승인 및 변경승인의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 사업계획의 내용이 관계 법령의 규정에 적합할 것
2. 사업계획의 시행에 필요한 자금을 조달할 능력 및 방안이 있을 것
3. 일반 주거지역의 관광숙박시설 및 그 시설 안의 위락시설은 주거환경을 보호하기 위하여 다음 각 목의 기준에 맞아야 하고, 준주거지역의 경우에는 다목의 기준에 맞을 것. 다만, 일반 주거지역

83) 법제처 2013. 5. 28. 회신 13-0134 해석례 참조

에서의 사업계획의 변경승인(신축 또는 기존 건축물 전부를 철거하고 다시 축조하는 개축을 하는 경우는 포함하지 아니한다)의 경우에는 가목의 기준을 적용하지 아니하고, 일반 주거지역의 호스텔업의 시설의 경우에는 라목의 기준을 적용하지 아니한다.

가. 다음의 구분에 따라 사람 또는 차량의 통행이 가능하도록 대지가 도로에 연접할 것. 다만, 특별자치시·특별자치도·시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)는 주거환경을 보호하기 위하여 필요하면 지역 특성을 고려하여 조례로 이 기준을 강화할 수 있다.

1) 관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업, 의료관광호텔업 및 휴양콘도미니엄업: 대지가 폭 12미터 이상의 도로에 4미터 이상 연접할 것

2) 호스텔업 및 소형호텔업: 대지가 폭 8미터(관광객의 수, 관광특구와의 거리 등을 고려하여 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 지정하여 고시하는 지역에서 20실 이하의 객실을 갖추어 경영하는 호스텔업의 경우에는 4미터) 이상의 도로에 4미터 이상 연접할 것

나. 건축물(관광숙박시설이 설치되는 건축물 전부를 말한다) 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 인접대지를 조망할 수 있는 창이나 문 등의 개구부가 있는 벽면에서 직각 방향으로 인접된 대지의 경계선[대지와 대지 사이가 공원·광장·도로·하천이나 그 밖의 건축이 허용되지 아니하는 공지(空地)인 경우에는 그 인접된 대지의 반대편 경계선을 말한다]까지의 수평거리의 두 배를 초과하지 아니할 것

다. 소음 공해를 유발하는 시설은 지하층에 설치하거나 그 밖의 방법으로 주변의 주거환경을 해치지 아니하도록 할 것

라. 대지 안의 조경은 대지면적의 15퍼센트 이상으로 하되, 대지 경계선 주위에는 다 자란 나무를 심어 인접 대지와 차단하는 수림대(樹林帶)를 조성할 것

4. 연간 내국인 투숙객 수가 객실의 연간 수용가능 총인원의 40퍼센트를 초과하지 아니할 것 (의료관광호텔업만 해당한다)

② (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 24-0016, 24-0145

문화체육관광부·민원인 – 일반일간신문을 경영하는 법인이 발행한 주식 중 대기업과 그 계열회사의 취득 또는 소유가 제한되는 주식의 범위(「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제18조제1항 등 관련)

01 질의요지

「신문 등의 진흥에 관한 법률」(이하 "신문법"이라 함) 제18조제1항에서는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법"이라 함) 제2조제11호에 따른 기업집단 중 자산총액 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업집단에 속하는 회사(이하 "대기업"이라 함)와 그 계열회사(대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자를 포함함)는 일반일간신문을 경영하는 법인(이하 "일반일간신문법인"이라 함)이 발행한 주식 또는 지분(이하 "주식등"이라 함)의 2분의 1을 초과하여 취득 또는 소유할 수 없다고 규정하고 있는바,

일반일간신문법인 A가 대기업과 그 계열회사(이하 "대기업등"이라 함) B에 속하는 경우, 신문법 제18조제1항에 따라 대기업등 B가 일반일간신문법인 A가 발행한 주식등의 2분의 1을 초과하여 소유하는지 여부를 판단할 때, '일반일간신문법인 A가 소유한 자기주식[84]'이 '대기업등 B가 소유하는 일반일간신문법인 A의 발행 주식'에 포함되는지?[85]

02 회답

이 사안의 경우, 신문법 제18조제1항에 따라 대기업등 B가 일반일간신문법인 A가 발행한 주식등의 2분의 1을 초과하여 소유하는지 여부를 판단할 때 '일반일간신문법인 A가 소유한 자기주식'은 '대기업등 B가 소유하는 일반일간신문법인 A의 발행 주식'에 포함됩니다.

---

84) 자기주식의 소유란 주식을 발행한 회사 자신이 그 발행주식을 취득하여 주주가 되는 것을 말함(「상법」 제341조 및 제341조의2 참조)

85) '일반일간신문법인이 소유한 자기주식'이 신문법 제18조제1항에 따른 '일반일간신문법인이 발행한 주식'에 포함됨을 전제로 함.

03 이유

먼저 신문법 제18조제1항에서는 대기업등은 일반일간신문법인이 발행한 주식등의 2분의 1을 초과하여 취득 또는 소유할 수 없다고 규정하고 있을 뿐, 일반일간신문법인이 발행한 주식등의 2분의 1을 초과하여 취득 또는 소유할 수 없는 '대기업등'의 범위에서 해당 대기업등에 속하는 '일반일간신문법인'을 제외하고 있지 않고, 주식을 발행한 회사 자신이 주주가 되는 '자기주식'도 의결권이 없는[86] 등의 특수성이 있을 뿐 '주식'에 해당하며, 달리 신문법령에서 '대기업등이 소유하는 일반일간신문법인의 발행 주식등'이 일반일간신문법인이 발행한 주식등의 2분의 1을 초과하는지를 산정할 때 '일반일간신문법인 소유의 자기주식'이나 '의결권 없는 주식'을 제외한다는 내용을 명시하고 있지도 않으므로, 이 사안의 경우 '일반일간신문법인 A가 소유한 자기주식'도 '대기업등 B가 소유하는 일반일간신문법인 A의 발행 주식'에 포함되는 것으로 보는 것이 신문법 제18조제1항의 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 신문법 제18조제1항에서 대기업등이 일반일간신문법인이 발행한 주식 또는 지분을 취득하거나 소유하는 것을 제한하고 있는 취지는 대기업등이 일반일간신문법인에 대한 지배적인 소유권을 획득함으로써 자본의 이익에 따라 언론의 공공성이 훼손되거나 여론의 다양성이 저해되는 것을 방지하기 위한 것이라 할 것[87]인데, 자기주식의 경우 의결권이 없어 대기업등에 속하는 일반일간신문법인이 소유한 자기주식으로는 해당 일간신문법인의 의사결정에 직접적으로 참여할 수는 없다고 할 것이나, 대기업등에 속하는 일반일간 신문법인이 자기주식을 소유하는 경우 그렇지 않은 경우에 비해 '일반일간신문법인이 발행한 주식 중 의결권이 있는 전체 주식' 대비 '대기업등이 소유한 의결권 있는 주식'의 비율이 상승함으로써 일반일간신문법인에 대한 대기업등의 영향력이 커질 수 있는바, 이 사안과 같이 일반일간신문법인 A가 대기업등 B에 속하는 경우에 '일반일간신문법인 A가 소유한 자기주식'은 '대기업등 B가 소유하는 일반일간신문법인 A의 발행 주식'에서 제외된다고 해석하는 것은 신문법 제18조제1항의 입법 취지에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 신문법 제18조제1항에 따라 대기업등 B가 일반일간신문법인 A가 발행한 주식등의 2분의 1을 초과하여 소유하는지 여부를 판단할 때 '일반일간신문법인 A가 소유한 자기주식'은 '대기업등 B가 소유하는 일반일간신문법인 A의 발행 주식'에 포함됩니다.

---

86) 「상법」 제369조제2항 참조

87) 2008. 12. 26. 의안번호 제1803214호로 발의된 신문등의자유와기능보장에관한법률 전부개정법률안에 대한 국회 문화체육관광방송통신위원회 검토보고서 참조

관계법령

신문 등의 진흥에 관한 법률

제18조(대기업의 일반일간신문 소유제한 등) ① 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 기업집단 중 자산총액 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 기업집단에 속하는 회사(이하 "대기업"이라 한다)와 그 계열회사(대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자를 포함한다)는 일반일간신문을 경영하는 법인이 발행한 주식 또는 지분의 2분의 1을 초과하여 취득 또는 소유할 수 없다.

② (생 략)

제19조(소유제한 위반 시 조치 등) ① 제18조를 위반하여 주식 또는 지분을 취득 또는 소유한 자는 그 초과분에 대한 의결권을 행사할 수 없다.

② 시·도지사는 제18조를 위반하여 주식 또는 지분을 취득 또는 소유한 자에 대하여 6개월 이내의 기간을 정하여 이를 시정할 것을 명하여야 한다.

③ (생 략)

상법

제369조(의결권) ① 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② 회사가 가진 자기주식은 의결권이 없다.

③ (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0062, 24-0456, 24-0457

문화체육관광부 – 「관광진흥법」 제32조 및 같은 법 시행규칙 별표 10의2에 따라 안전·위생기준을 지켜야 하는 대상 시설인 '물놀이형 유기시설 또는 유기기구'의 범위(「관광진흥법」 제32조 등 관련)

01 질의요지

「관광진흥법」 제32조에서는 같은 법 제5조제2항 또는 제4항에 따라 유원시설업[88]의 허가를 받거나 신고를 한 자 중 물놀이형 '유기시설 또는 유기기구를 설치한 자는 문화체육관광부령으로 정하는 안전·위생기준을 지켜야 한다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 별표 10의2에서는 '물놀이형 유원시설업자의 안전·위생기준'(이하 "안전·위생기준"이라 함)을 구체적으로 규정하고 있는바,

「관광진흥법 시행령」 제2조제5호다목의 기타유원시설업[89] 신고를 한 자(이하 "기타유원시설업자"라 함)가 같은 법 시행규칙 별표 11 제2호나목1)라)에서 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구로 규정하고 있는 '미니슬라이드', '미니수중모험놀이', '미니워터에어바운스'(이하 "이 사안 유기시설등"이라 함)를 설치한 경우[90] 같은 법 제32조 및 같은 법 시행규칙 별표 10의2에 따른 안전·위생기준을 지켜야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 기타유원시설업자는 「관광진흥법」 제32조 및 같은 법 시행규칙 별표 10의2에 따른 안전·위생기준을 지켜야 합니다.

88) 「관광진흥법」 제3조제1항제6호의 "유원시설업"을 말하며, 이하 같음.

89) 유기시설이나 유기기구를 갖추어 관광객에게 이용하게 하는 유원시설업의 한 종류로서 「관광진흥법」 제33조에 따른 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구를 설치하여 운영하는 업을 말하며, 이하 같음.

90) 불특정 다수를 대상으로 상시로 영업하기 위하여 일정한 영업장소에 이 사안 유기시설등의 전부 또는 일부를 설치한 경우를 전제함.

03 이유

「관광진흥법」 제3조제1항제6호에서는 '유원시설업'을 유기시설이나 유기기구를 갖추어 이를 관광객에게 이용하게 하는 업으로 규정하면서, 같은 법 시행령 제2조제1항제5호에서는 유원시설업의 세부 종류를 '종합유원시설업', '일반유원시설업', '기타유원시설업'으로 구분하고 있고, 같은 법 제5조제4항에서 '기타유원시설업'을 신고 대상 업종으로 규정[91]하고 있으며, 같은 법 제32조에서는 '같은 법 제5조제2항 또는 제4항에 따라 유원시설업의 허가를 받거나 신고를 한 자'(이하 "유원시설업자"라 함) 중 '물놀이형 유기시설 또는 유기기구'를 설치한 자는 문화체육관광부령으로 정하는 물놀이형 안전·위생기준을 지켜야 한다고 규정하고 있습니다.

그리고 같은 법 제33조제1항 전단에서는 유원시설업자 및 유원시설업의 허가 또는 변경허가를 받으려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구에 대하여는 특별자치시장·특별자치도시자·시장·군수·구청장이 실시하는 안전성검사를, 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구에 대하여는 안전성검사 대상에 해당되지 아니함을 확인하는 검사를 받도록 규정하고 있고, 그 위임에 따른 같은 법 시행규칙 제40조제1항 및 별표 11에서는 유기시설 또는 유기기구를 시설 자체가 갖는 위험요소의 정도에 따라 '안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구'와 '안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구'로 구분하면서, 같은 별표 제2호나목1)라)에서 미니슬라이드를 비롯한 이 사안 유기시설등을 '안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구'로 구분하여 규정하고 있는바, 이 사안에서는 기타유원시설업자가 설치한 안전성검사 대상이 아닌 이 사안 유기시설등이 같은 법 제32조 및 같은 법 시행규칙 별표 10의2에 따른 안전·위생기준을 지켜야 하는 시설인 '물놀이형 유기시설 또는 유기기구'에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

먼저 「관광진흥법 시행규칙」 별표 11 제2호나목1)라)에서는 이 사안 유기시설등을 '놀이형'의 한 종류로 분류하면서 '일정한 시설(기계·기구·공간 등) 내에서 이용자 스스로가 참여하여 물놀이(수심 1미터 이하)를 체험하는 유기시설 또는 유기기구'라고 설명하고 있는바, '물놀이'는 일반적으로 '물가나 물속에서 하는 놀이'[92]를 의미하고, 이 사안 유기시설등에 해당하는 '미니슬라이드', '미니수중모험놀이', '미니워터에어바운스'는 같은 별표

91) 종합유원시설업 및 일반유원시설업은 같은 법 제5조제2항 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 허가 대상 업종으로 규정하고 있음.

92) 국립국어원 표준국어대사전 참조

제1호나목1)라)에 따라 '안전성검사 대상 물놀이형 유기시설 또는 유기기구'에 해당하는 '바디슬라이드', '수중모험놀이', '워터에어바운스' 등에 비해 길이나 탑승높이, 면적 등 규모에 있어 차이가 있을 뿐, 실제 물을 매개체로 하는 놀이활동에 이용되는 것을 전제로 설계되어 설치·운용된다는 점에 비추어 보면, 이 사안 유기시설등은 같은 법 제32조에 따른 '물놀이형 유기시설 또는 유기기구'에 해당한다고 보아야 할 것입니다.

그리고 같은 법 제33조에 따라 재질·구조 등 '유기시설 또는 유기기구' 자체의 안전성을 제고하기 위하여 실시하는 안전성검사와 같은 법 제32조에 따라 수질관리, 안전요원 배치 등 해당 시설의 설치·운영 과정에서의 이용자의 안전 및 위생을 확보하고자 '유원시설업자'에 대한 준수사항을 규율하고 있는 안전·위생기준은 그 입법 경위 및 취지, 근거 법률과 규율 대상 등을 달리하는 별개의 제도이고, 관광진흥법령에서는 '안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구'에 해당하는 경우 같은 법 제32조의 안전·위생기준의 적용 대상에서 제외한다는 취지의 규정을 별도로 두고 있지도 않다는 점을 고려하면, 특정 유기시설 또는 유기기구가 같은 법 제33조에 따른 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구에 해당한다고 하여 곧바로 같은 법 제32조에 따른 '유원시설업자'가 준수하여야 하는 안전·위생기준의 적용 대상에서 제외될 수 있는 사유나 요건이 되는 것은 아닌바, 안전성검사 대상이 아닌 이 사안 유기시설등을 설치한 기타유원시설업자에 대해서도 같은 법 제32조에 따라 같은 법 시행규칙 별표 10의2의 안전·위생기준을 지켜야 한다고 보는 것이 유기시설 또는 유기기구에 대한 관광진흥법령의 규정 체계 및 제도의 목적에 부합합니다.

또한 「관광진흥법」 제32조에서 물놀이형 유기시설 또는 유기기구를 설치한 유원시설업자에게 별도의 안전·위생기준을 마련하여 준수하도록 한 취지는 물놀이형 유기시설 또는 유기기구의 경우 그 운영 과정에서 안전사고의 빈도가 높고 각종 질병의 감염 통로가 될 수 있다는 점에서 다른 유기시설 또는 유기기구에 비해 보다 엄격히 관리할 필요가 있으므로 별도의 안전·위생기준 마련 및 준수를 통해 물놀이형 유기시설 및 유기기구의 운영 과정에서의 수중안전 및 위생이 확보될 수 있도록 하려는 것인바[93], 같은 법 제32조에 따른 안전·위생기준을 준수하여야 하는 '물놀이형 유기시설 또는 유기기구'의 범위는 그 이용자들을 충분히 보호할 수 있는 방향으로 해석해야 할 것이고, 이 사안 유기시설등이 같은 법 제33조에 따른 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구에 해당하지 않는다는 것만으로 해당 시설의 안전·위생 관리의 필요성이 없다거나 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구와 차별을 둘 만큼 그 필요성이 적다고 볼 수도 없으므로 안전성검사 대상이 아닌 이 사안 유기시설등도

93) 2008. 8. 21. 의안번호 1800689호로 발의된 관광진흥법 일부개정법률안 의안원문 및 국회 문화체육관광방송통신위원회 전문위원 검토보고서 참조

같은 법 제32조의 '물놀이형 유기시설 또는 유기기구'에 해당된다고 보는 것이 관광진흥법령의 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 이 사안 유기시설등의 경우 2009년 3월 25일 법률 제9527호로 관광진흥법을 일부개정하여 같은 법 제32조를 신설한 당시에는 같은 법 시행규칙[94] 별표 11에서 해당 시설의 규모와는 관계없이 '안전성검사 대상인 물놀이형 유기시설 또는 유기기구'에 포함되어 있었다가, 유기시설 또는 유기기구의 안전성검사 체계 및 규제를 개선하기 위한 취지로 2016년 12월 30일 문화체육관광부령 제276호로 관광진흥법 시행규칙을 일부개정하여 기존 안전성검사 대상이었던 '물놀이형 유기시설 또는 유기기구' 중 비교적 위험요소가 적은 일정 규모 미만의 유기시설 또는 유기기구를 '미니슬라이드', '미니수중모험놀이', '미니워터에어바운스'로 명명(命名)하여 안전성검사를 받지 않아도 되는 대상 시설로 재분류[95]하게 된 것인 반면, 안전·위생기준을 준수하여야 하는 같은 법 제32조 등의 '물놀이형 유기시설 또는 유기기구'의 적용 범위에 대해서는 해당 규정의 신설 당시부터 현행 규정에 이르기까지 별도의 법령 개정 없이 그대로 유지되어 온 점을 종합하면, 같은 법 제32조에 따른 '물놀이형 유기시설 또는 유기기구'에 이 사안 유기시설등도 계속 포함되어 있다고 해석하는 것이 관계 규정의 입법연혁에도 부합한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 기타유원시설업자는 「관광진흥법」 제32조 및 같은 법 시행규칙 별표 10의2에 따른 안전·위생기준을 지켜야 합니다.

법령정비 권고사항

「관광진흥법」 제32조 및 같은 법 시행규칙 별표 10의2에 따른 안전·위생기준의 내용이 이 사안 유기시설등을 설치·운영하는 기타유원시설업자에 적용될 경우의 입법적 효과 등을 정책적으로 검토하여 유원시설업장 및 유기시설·유기기구의 규모·특성 등을 고려한 합리적인 규제가 설정될 수 있도록 관련 법령을 정비할 필요성이 있는지 검토할 필요가 있습니다.

94) 2008. 8. 26. 문화체육관광부령 제13호로 일부개정되어 같은 날 시행된 관광진흥법 시행규칙을 말함

95) 2016. 12. 30. 문화체육관광부령 제276호로 일부개정되어 2017. 1. 1. 시행된 관광진흥법 시행규칙 개정이유 및 조문별 제·개정이유서 참조

관계법령

관광진흥법

제32조(물놀이형 유원시설업자의 준수사항) 제5조제2항 또는 제4항에 따라 유원시설업의 허가를 받거나 신고를 한 자(이하 "유원시설업자"라 한다)중 물놀이형 유기시설 또는 유기기구를 설치한 자는 문화체육관광부령으로 정하는 안전·위생기준을 지켜야 한다.

제33조(안전성검사 등) ① 유원시설업자 및 유원시설업의 허가 또는 변경허가를 받으려는 자(조건부 영업허가를 받은 자로서 그 조건을 이행한 후 영업을 시작하려는 경우를 포함한다)는 문화체육관광부령으로 정하는 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구에 대하여 문화체육관광부령에서 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 실시하는 안전성검사를 받아야 하고, 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구에 대하여는 안전성검사 대상에 해당되지 아니함을 확인하는 검사를 받아야 한다. 이 경우 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 성수기 등을 고려하여 검사시기를 지정할 수 있다.

② ~ ⑤ (생 략)

관광진흥법 시행규칙

제39조의2(물놀이형 유원시설업자의 안전·위생기준) 법 제32조에 따라 유원시설업자 중 물놀이형 유기시설 또는 유기기구를 설치한 자가 지켜야 하는 안전·위생기준은 별표 10의2와 같다.

제40조(유기시설 또는 유기기구의 안전성검사 등) ① 법 제33조제1항에 따른 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구와 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 및 유기기구는 별표 11과 같다.

② ~ ⑨ (생 략)

■ 관광진흥법 시행규칙 [별표 11]

안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구와
안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구(제40조제1항 관련)

1. 안전성검사 대상 유기시설 또는 유기기구

(중 략)

2. 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구
   가. (생 략)
   나. 구 분
      1) 안전성검사 대상이 아닌 유기시설 또는 유기기구는 다음과 같이 구분한다.

유 형	내용	유기시설 또는 유기기구
가) ~ 다) (생 략)		
라) 놀이형	일정한 시설(기계·기구·공간 등) 내에서 보조기구 또는 장치를 이용하거나 기구에 포함된 구성물을 작동하여 이용자 스스로가 이용하거나 체험할 수 있는 기구로서 누구나 이용할 수 있고 사행성이 없는 유기시설 또는 유기기구	붕붕뜀틀, 미니모험놀이(플레이스페이스 포함, 탑승높이가 3미터 이하이며, 설치 면적이 120제곱미터 이하), 미니에어바운스(탑승높이가 3미터 이하이며, 설치면적이 120제곱미터 이하), 미니사격, 공쏘기, 광선총, 공굴리기, 표적맞추기, 물쏘기, 미니볼링, 미니농구, 공던지기, 공차기, 에어하키, 망치치기, 펀치, 미니야구, 스키타기, 팔씨름, 오토바이타기, 자동차경주, 자전거타기, 보트타기, 말타기, 뮤직댄스, 수상기구타기, 건슈팅 등
	일정한 시설(기계·기구·공간 등) 내에서 이용자 스스로가 참여하여 물놀이(수심 1미터 이하)를 체험하는 유기시설 또는 유기기구	미니슬라이드(슬라이드 길이 10미터 이하이며, 탑승높이 2미터 이하), 미니수중모험놀이(물버켓이 설치되지 않고 슬라이드 전체길이가 10미터 이하이며, 탑승높이 2미터 이하), 미니워터에어바운스(탑승높이가 3미터 이하이며, 설치 면적이 120제곱미터 이하) 등

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0155, 24-0435

문화체육관광부 – 국제회의업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 「관광진흥법」제7조제1항제3호 본문의 결격사유에 해당하여 다른 종류의 관광사업인 여행업의 등록을 받을 수 없는지 여부 등(「관광진흥법」 제7조제1항 관련)

01 질의요지

「관광진흥법」 제7조제1항 각 호 외의 부분 전단에서는 '다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 관광사업[96]의 등록등[97]을 받을 수 없다'고 규정하면서, 같은 항 제3호 본문에서 결격사유의 하나로 '같은 법에 따라 등록등이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자'를 규정하고 있는바,

가. 국제회의업[98]의 등록[99]이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 「관광진흥법」 제7조제1항제3호 본문의 결격사유에 해당하여 다른 종류의 관광사업인 여행업[100]의 등록을 받을 수 없는지?

나. 여행업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 「관광진흥법」 제7조제1항제3호 본문의 결격사유에 해당하여 취소된 여행업 등록을 했던 관할 등록기관등의 장[101]이 아닌 다른 관할 등록기관등의 장(이하 "다른 관할 등록기관등의 장"이라 함)에게 여행업의 등록을 받을 수 없는지?

96) "관광사업"이란 관광객을 위하여 운송·숙박·음식·운동·오락·휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 딸린 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 업(業)을 말하며(「관광진흥법」 제2조제1호), 이하 같음.

97) 관광사업을 경영하기 위한 등록·허가 또는 지정을 말하며(「관광진흥법」 제2조제2호), 이하 같음.

98) 「관광진흥법」 제3조제1항제4호에 따른 국제회의업을 말하며, 이하 같음.

99) 「관광진흥법」 제4조제1항에 따른 등록을 말하며, 이하 같음

100) 「관광진흥법」 제3조제1항제1호에 따른 여행업을 말하며, 이하 같음.

101) 문화체육관광부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하며(「관광진흥법」 제7조제2항), 이하 같음

02 회답

가. 질의 가에 대해

국제회의업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는「관광진흥법」제7조제1항제3호 본문의 결격사유에 해당하여 다른 종류의 관광사업인 여행업의 등록을 받을 수 없습니다.

나. 질의 나에 대해

여행업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는「관광진흥법」제7조제1항제3호 본문의 결격사유에 해당하여 다른 관할 등록기관등의 장에게 여행업의 등록을 받을 수 없습니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미를 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[102],「관광진흥법」제3조제1항에 따라 관광사업은 여행업(제1호), 관광숙박업(제2호), 관광객 이용시설업(제3호), 국제회의업(제4호), 카지노업(제5호), 유원시설업(제6호), 관광 편의시설업(제7호)을 모두 포함하는 것이고, 같은 법 제7조제1항 전단 및 같은 항 제3호 본문에서는 같은 법에 따라 '등록'이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 '관광사업의 등록'을 받을 수 없다고 규정하여, 관광사업의 한 종류에서 결격사유에 해당하였다면 관광사업의 범위 안에서는 다른 종류의 관광사업 등록에도 결격사유에 해당하는 것으로 보아야 하고, 새로 등록하려는 관광사업을 등록이 취소된 관광사업과 '같은 종류의 관광사업'으로 한정하고 있지도 않으므로 같은 법 제7조제1항 각 호 외의 부분 전단의 '관광사업'에는 등록이 취소된 관광사업과 다른 종류의 관광사업도 포함되는 것이 문언상 분명합니다.

그리고「행정기본법」제16조제1항에서 결격사유를 '자격이나 신분 등을 취득 또는 부여할

102) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

수 없거나 인가, 허가, 지정, 승인, 영업등록, 신고 수리 등을 필요로 하는 영업 또는 사업 등을 할 수 없는 사유'라고 규정하고 있는데, 「관광진흥법」 제4조제1항 및 제3항에 따르면 여행업을 경영하려는 자는 대통령령으로 정하는 자본금[103]·시설 및 설비 등을 갖추어 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음)에게 등록해야 하고, 같은 법 제7조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 같은 항 각 호의 결격사유 중 어느 하나에 해당하는 자는 관광사업의 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항 본문에서는 관광사업의 등록을 받은 자가 같은 조 제1항 각 호의 결격사유 중 어느 하나에 해당하면 등록기관등의 장은 3개월 이내에 그 등록을 취소하여야 한다고 규정하고 있는바, 이를 종합하면 같은 법 제7조는 관광사업의 전 과정에 걸쳐 같은 조 제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것을 요구함으로써 관광사업을 영위하는 자의 자질을 일정 수준 이상으로 지속적으로 유지하고 이를 충족하지 못하는 경우 '관광사업'의 영역에 진입하거나 '관광사업'을 영위하는 것을 방지하려는 취지의 규정으로 보아야 하므로[104], 국제회의업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니하여 같은 조 제1항제3호 본문의 결격사유에 해당하는 자는 같은 종류의 관광사업 뿐만 아니라 다른 종류의 관광사업인 여행업의 등록도 받을 수 없다고 보는 것이 같은 조에서 결격사유를 규정한 취지에도 부합하는 해석입니다.

아울러 국제회의업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자가 다른 종류의 관광사업인 여행업의 등록은 받을 수 있다고 해석하면, 한 종류의 관광사업의 등록이 취소된 직후에도 업종을 바꾸어 다른 종류의 관광사업의 요건을 갖추면 다시 관광사업을 영위할 수 있게 되어 「관광진흥법」 제7조에서 관광사업의 결격사유를 규정한 취지가 형해화될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 국제회의업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 「관광진흥법」 제7조제1항제3호 본문의 결격사유에 해당하여 다른 종류의 관광사업인 여행업의 등록을 받을 수 없습니다.

나. 질의 나에 대해

「관광진흥법」 제7조제1항 전단 및 같은 항 제3호 본문에서는 이 법에 따라 '등록'이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 '관광사업의 등록'을 받을 수 없다고 규정하여, 결격사유에 해당하는 자의 관광사업 등록과 관련하여 관할 등록기관등의 장에 대해 별도로 규정하거나,

103) 법인인 경우에는 납입자본금을 말하고, 개인인 경우에는 등록하려는 사업에 제공되는 자산의 평가액을 말하며(「관광진흥법」 제4조제3항 참조), 이하 같음

104) 법제처 2023. 6. 7. 회신 23-0233 해석례 및 법제처 법령입안·심사기준(2022) p.182-183 참조

당초 등록을 취소한 관광사업 관할 등록기관등의 장과 동일해야 한다고 제한하고 있지 않은바, 같은 법 제7조제1항 전단은 관광사업 관할 등록기관등의 장에 따라 달리 적용되는 것이 아니므로, 다른 관할 등록기관등의 장에게 새로운 관광사업을 등록하려는 경우에도 적용[105] 된다고 보는 것이 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 「행정기본법」 제16조제1항에서 결격사유를 '자격이나 신분 등을 취득 또는 부여할 수 없거나 인가, 허가, 지정, 승인, 영업등록, 신고 수리 등을 필요로 하는 영업 또는 사업 등을 할 수 없는 사유'라고 규정하고 있는데, 「관광진흥법」 제4조제1항 및 제3항에 따르면 여행업을 경영하려는 자는 대통령령으로 정하는 자본금·시설 및 설비 등을 갖추어 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 등록해야 하고, 같은 법 제7조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 같은 항 각 호의 결격사유 중 어느 하나에 해당하는 자는 관광사업의 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항 본문에서는 관광사업의 등록을 받은 자가 같은 조 제1항 각 호의 결격사유 중 어느 하나에 해당하면 등록기관등의 장은 3개월 이내에 그 등록을 취소하여야 한다고 규정하고 있는바, 이를 종합하면 같은 법 제7조는 관광사업의 전 과정에 걸쳐 같은 조 제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것을 요구함으로써 관광사업을 영위하는 자의 자질을 일정 수준 이상으로 지속적으로 유지하고 이를 충족하지 못하는 경우 '관광사업'의 영역에 진입하거나 '관광사업'을 영위하는 것을 철저히 방지하려는 취지의 규정으로 보아야 하므로[106], 여행업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 같은 조 제1항제3호 본문의 결격사유에 해당하여 다른 관할 등록기관등의 장에게도 여행업의 등록을 받을 수 없다고 보는 것이 같은 조에서 결격사유를 규정한 취지에도 부합합니다.

아울러 여행업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자가 다른 관할 등록기관등의 장에게는 여행업의 등록을 받을 수 있다고 해석하면, 관광사업의 등록이 취소된 직후에도 다른 관할 등록기관등의 장에게 등록을 받으면 다시 관광사업을 영위할 수 있게 되어 「관광진흥법」 제7조에서 관광사업의 결격사유를 규정한 취지가 형해화될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 여행업의 등록이 취소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 「관광진흥법」 제7조제1항제3호 본문의 결격사유에 해당하여 다른 관할 등록기관등의 장에게 여행업의 등록을 받을 수 없습니다.

---

105) 법제처 2007. 7. 13. 회신 07-0197 해석례 참조

106) 법제처 2023. 6. 7. 회신 23-0233 해석례 및 법제처 법령입안·심사기준(2022) p.182-183 참조

관계법령

관광진흥법

제4조(등록) ① 제3조제1항제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업 및 국제회의업을 경영하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 등록하여야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

제7조(결격사유) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 관광사업의 등록등을 받거나 신고를 할 수 없고, 제15조제1항 및 제2항에 따른 사업계획의 승인을 받을 수 없다. 법인의 경우 그 임원 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 경우에도 또한 같다.

1. 피성년후견인·피한정후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
3. 이 법에 따라 등록등 또는 사업계획의 승인이 취소되거나 제36조제1항에 따라 영업소가 폐쇄된 후 2년이 지나지 아니한 자. 다만, 제1호 또는 제2호에 해당하여 제2항에 따라 등록등 또는 사업계획의 승인이 취소되거나 영업소가 폐쇄된 경우는 제외한다.
4. (생 략)

② 관광사업의 등록등을 받거나 신고를 한 자 또는 사업계획의 승인을 받은 자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하면 문화체육관광부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 "등록기관등의 장"이라 한다)은 3개월 이내에 그 등록등 또는 사업계획의 승인을 취소하거나 영업소를 폐쇄하여야 한다. 다만, 법인의 임원 중 그 사유에 해당하는 자가 있는 경우 3개월 이내에 그 임원을 바꾸어 임명한 때에는 그러하지 아니하다.

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0211

민원인 – 사용자가 「근로자퇴직급여 보장법」 제9조제1항 본문에 따라 퇴직금을 지급해야 하는 기간의 만료의 의미(「근로자퇴직급여 보장법」 제9조제1항 등 관련)

01 질의요지

「근로자퇴직급여 보장법」(이하 "퇴직급여법"이라 함) 제9조제1항 본문에서는 "사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다"고 규정하고 있는바,

사용자가 퇴직급여법 제9조제1항 본문에 따라 퇴직금을 지급해야 하는 14일의 기간은 기간말일의 종료로 만료하는지 아니면 기간말일의 금융기관 영업시간의 종료로 만료하는지[107]?

02 회답

사용자가 퇴직급여법 제9조제1항 본문에 따라 퇴직금을 지급해야 하는 14일의 기간은 기간말일의 종료로 만료합니다.

03 이유

퇴직급여법 제9조제1항 본문에서는 "사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다"고 규정하고 있는데, 기간의 계산에 관하여 퇴직급여법령에서 특별한 규정을 두고 있지는 않습니다.

이와 관련하여 행정의 원칙과 기본사항을 규정하고 있는「행정기본법」 제6조제1항에서는 '행정에 관한 기간의 계산에 관하여는 같은 법 또는 다른 법령등[108]에 특별한 규정이 있는

107) 기간말일이 토요일 또는 공휴일이 아닌 경우를 전제함.

경우를 제외하고는 「민법」을 준용한다'고 규정하여 행정에 관한 기간 계산에 있어서는 다른 법령등에 특별한 규정이 없다면 원칙적으로 「민법」을 준용하도록 하고 있고, 「민법」 제155조에서는 '기간의 계산은 법령, 재판상의 처분 또는 법률행위에 다른 정한 바가 없으면 같은 법 제1편제6장(같은 법 제155조부터 제161조까지)의 규정에 의한다'고 규정하고 있는바, 「행정기본법」이나 퇴직급여법령에서 기간의 계산에 관하여 금융기관 영업시간 종료로 기간이 만료한다는 등으로 달리 정하고 있지 않으므로 퇴직금 지급기간의 계산에 관하여 「민법」의 규정을 준용해야 할 것[109]인데, 같은 법 제159조에서는 기간의 만료점에 대하여 '기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다'고 규정하고 있고, 퇴직급여법 제9조제1항 본문에서는 퇴직금 지급기간에 대하여 14일 이내로 규정하여 기간을 '일'로 정한 경우이므로, 사용자가 같은 항 본문에 따라 퇴직금을 지급해야 하는 기간은 기간말일이 종료하는 기간말일의 24시에 만료한다고 보아야 합니다[110].

따라서 사용자가 퇴직급여법 제9조제1항 본문에 따라 퇴직금을 지급해야 하는 14일의 기간은 기간말일의 종료로 만료합니다.

관계법령

근로자퇴직급여 보장법

제9조(퇴직금의 지급 등) ① 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급사유 가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장할 수 있다.
②·③ (생 략)

행정기본법

제6조(행정에 관한 기간의 계산) ① 행정에 관한 기간의 계산에 관하여는 이 법 또는 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「민법」을 준용한다.
② 법령등 또는 처분에서 국민의 권익을 제한하거나 의무를 부과하는 경우 권익이 제한되거나 의무가 지속되는 기간의 계산은 다음 각 호의 기준에 따른다. 다만, 다음 각 호의 기준에 따르는 것이 국민에게 불리한 경우에는 그러하지 아니하다.

108) 「행정기본법」 제2조제1호에 따른 법령등을 말하며, 이하 같음

109) 대법원 2009. 11. 26. 선고 2009두12907 판결례, 서울행정법원 2023. 6. 8. 선고 2022구단64146 판결례 참조

110) 대법원 1993. 11. 23. 선고 93도662 판결례, 법제처 2017. 3. 20. 회신 17-0063 해석례, 법제처 2021. 9. 8. 회신 21-0320 해석례 참조

1. 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 경우에는 기간의 첫날을 산입한다.
2. 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일인 경우에도 기간은 그 날로 만료한다.

민법

제155조(본장의 적용범위) 기간의 계산은 법령, 재판상의 처분 또는 법률행위에 다른 정한 바가 없으면 본장의 규정에 의한다.
제159조(기간의 만료점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다.

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0692

문화체육관광부 – 「관광진흥법 시행령」 별표 1 제2호마목에 따른 호스텔업의 등록기준(「관광진흥법 시행령」 별표 1 등 관련)

01 질의요지

「관광진흥법」 제4조제1항에서는 관광숙박업[111] 등을 경영하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함)에게 등록하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제1항에 따른 등록을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 자본금·시설 및 설비 등을 갖추어야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 별표 1 제2호마목1)에서는 관광숙박업 중 호텔업 종류의 하나인 호스텔업[112]의 등록기준으로 배낭여행객 등 개별 관광객의 숙박에 적합한 객실을 갖추고 있을 것을 규정하고 있는바,

호스텔업을 등록하려는 자가 「관광진흥법 시행령」 별표 1 제2호마목1)에 따라 갖추어야 하는 객실은 개별 관광객별로 분리하여 숙박하기에 적합한 형태의 객실(이하 “단독객실”이라 함)로 한정되는지, 아니면 일행이 아닌 다른 개별 관광객과 함께 숙박할 수 있는 형태의 객실(이하 “공동객실”이라 함)도 포함되는지?

02 회답

호스텔업을 등록하려는 자가 「관광진흥법 시행령」 별표 1 제2호마목1)에 따라 갖추어야 하는 객실은 단독객실로 한정되지 않고, 공동객실도 포함됩니다.

---

111) 「관광진흥법」 제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업을 말하며, 이하 같음

112) 배낭여행객 등 개별 관광객의 숙박에 적합한 시설로서 샤워장, 취사장 등의 편의시설과 외국인 및 내국인 관광객을 위한 문화·정보 교류시설 등을 함께 갖추어 이용하게 하는 업을 말하며(「관광진흥법 시행령」 제2조제1항제2호마목 참조), 이하 같음

03 이유

먼저 「관광진흥법 시행령」 별표 1 제2호에 따른 호텔업에 대한 등록기준을 살펴보면, 관광호텔업[가목(1)], 수상관광호텔업[나목(2)], 소형호텔업[바목(1)]은 욕실이나 샤워시설을 갖춘 객실을 일정한 수 이상 갖추도록 규정하고 있고, 가족호텔업[라목(1) 및 (2)] 및 의료관광호텔업[사목(1) 및 (2)]은 욕실이나 샤워시설 외에 추가적으로 가족단위 관광객 및 의료관광객이 각각 이용할 수 있는 취사시설을 객실별 또는 층별 공동취사장으로 설치하도록 규정하고 있는 반면, 호스텔업[마목 1) 및 2)]에 대해서는 배낭여행객 등 개별 관광객의 숙박에 적합한 객실을 갖추도록 하면서, 화장실, 샤워장, 취사장 등의 편의시설을 공동으로 이용하게 할 수 있다고 규정하고 있는바, 호스텔업의 경우에는 ① 관광호텔업, 수상관광호텔업 등과는 달리 배낭여행객 등 개별 관광객의 숙박에 적합한 객실일 것만을 등록요건으로 하고 있는 점, ② 관광호텔업, 수상관광호텔업 등에서는 객실별로 설치하도록 하고 있는 화장실, 샤워장 등의 편의시설에 대해서도 호스텔업에서는 공동으로 이용할 수 있도록 하고 있는 점에 비추어 볼 때, 호스텔업을 등록하려는 자가 갖추어야 하는 객실을 반드시 단독객실로 한정하여야 한다고 보기는 어렵습니다.

또한 규제의 대상 등은 그 근거가 되는 법령에 구체적이고 명확하게 규정되어야 할 것이므로[113], 「관광진흥법 시행령」 별표 1에 따른 관광사업의 등록기준도 그 문언에 따라 엄격하게 해석해야 할 것인데, 「관광진흥법 시행령」 별표 1 제2호마목1)에서는 호스텔업의 등록기준을 배낭여행객 등 개별 관광객의 숙박에 적합한 객실을 갖추고 있을 것으로 규정하고 있을 뿐이고, 개별 관광객별로 구분하여 숙박하기에 적합한 객실을 갖추도록 규정하거나, 객실을 일행이 아닌 다른 개별 관광객과 함께 이용할 수 없도록 규정하고 있지 않은바, 호스텔업을 등록하려는 자가 「관광진흥법 시행령」 별표 1 제2호마목1)에 따라 갖추어야 하는 객실이 단독객실로 한정된다고 해석하는 것은 명시적인 근거 없이 호스텔업의 등록기준을 강화하는 해석으로서 타당하지 않습니다.

더욱이 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 되는데[114], 「관광진흥법」 제35조제1항제1호에서는 관광사업의 등록등[115]을 받거나 신고를

113) 「행정규제기본법」 제4조 참조.

114) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

115) 관광사업을 경영하기 위한 등록·허가 또는 지정을 말하며(「관광진흥법」 제2조제2호 참조), 이하 같음

한 자 또는 사업계획의 승인을 받은 자가 같은 법 제4조에 따른 등록기준에 적합하지 아니하게 된 경우에 해당하면 그 등록등 또는 사업계획의 승인을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 사업의 전부 또는 일부의 정지를 명하거나 시설·운영의 개선을 명할 수 있도록 규정하고 있는바, 명시적 규정 없이 호스텔업의 등록을 위해서는 모든 객실을 단독객실로만 갖추어야 한다고 보는 것은 호스텔업을 등록하려는 자에게 불리한 방향으로 유추 해석하는 것으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

그리고 호스텔업은 배낭여행객 등 개별 관광객이 주로 이용하는 숙박시설인 호스텔업이 증가하는 현실을 반영하기 위하여 2009년 10월 7일 대통령령 제21768호로 일부개정된 「관광진흥법 시행령」 제2조제1항제2호에 마목을 신설하여 호텔업의 하나로 추가된 것으로서[116], 전세계적으로 배낭여행객이 대폭 증가함에 따라 숙박가격이 저렴하면서 다양한 국적의 사람이 문화와 정보를 교류하고 어울릴 수 있는 숙박시설인 호스텔업에 수요가 증가함에 따라 국제적으로 통용되고 국제기준에 적합한 호스텔업을 관광진흥법령에 따른 관광사업의 종류로 규율할 필요가 있어 호스텔업을 신설하게 된 것인데[117], 만약 「관광진흥법 시행령」 별표 1 제2호마목1)의 호스텔업의 등록기준을 모든 객실을 단독객실로 갖추어야 하는 것으로 본다면, 공동객실에 비하여 숙박가격이 상승하게 되고, 관광객이 다른 국적의 사람과 문화와 정보를 교류할 기회가 줄어들 수 있게 되는바, 이는 숙박가격이 저렴하면서 다양한 국적의 사람이 문화와 정보를 교류할 수 있도록 하기 위하여 호스텔업을 관광사업의 종류의 하나로 추가한 취지에 부합하지 않는 해석이라 할 것입니다.

따라서 호스텔업을 등록하려는 자가 「관광진흥법 시행령」 별표 1 제2호마목1)에 따라 갖추어야 하는 객실은 단독객실로 한정되지 않고, 공동객실도 포함됩니다.

관계법령

관광진흥법 시행령

제5조(등록기준) 법 제4조제3항에 따른 관광사업의 등록기준은 별표 1과 같다. 다만, 휴양 콘도미니엄업과 전문휴양업 중 온천장 및 농어촌휴양시설을 2012년 11월 1일부터 2014년 10월 31일까지 제3조 제1항에 따라 등록 신청하면 다음 각 호의 기준에 따른다.

1. ~ 3. (생 략)

116) 2009. 10. 7. 대통령령 제21768호로 일부개정되어 같은 날 시행된 「관광진흥법 시행령」 개정이유 참조

117) 대통령령 제21768호 관광진흥법 시행령 일부개정령(안)에 대한 입법예고(2009. 5. 21. ~ 6. 10.) 참조

[별표 1]

관광사업의 등록기준(제5조 관련)

1. (생 략)
2. 호텔업
   가. ~ 라. (생 략)
   마. 호스텔업
      1) 배낭여행객 등 개별 관광객의 숙박에 적합한 객실을 갖추고 있을 것
      2) 이용자의 불편이 없도록 화장실, 샤워장, 취사장 등의 편의시설을 갖추고 있을 것. 다만, 이러한 편의시설은 공동으로 이용하게 할 수 있다.
      3) 외국인 및 내국인 관광객에게 서비스를 제공할 수 있는 문화·정보 교류시설을 갖추고 있을 것
      4) 대지 및 건물의 소유권 또는 사용권을 확보하고 있을 것
   바.·사. (생 략)
3. ~ 5. (생 략)

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0809

문화체육관광부 - 「관광진흥법 시행령」이 전부개정된 이후에도 구 「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조가 계속 적용되는 것으로 볼 수 있는지(대통령령 제18800호 관광진흥법 시행령 일부개정령 부칙 제4조 등 관련)

01 질의요지

구 「관광진흥법」(2004. 10. 16. 법률 제7232호로 일부개정되어 2005. 4. 17. 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제67조제1항에서 관광특구[118]는 대통령령이 정하는 요건에 적합한 지역 중에서 시장·군수·구청장의 신청에 의하여 시·도지사가 지정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 구 「관광진흥법 시행령」(2005. 4. 22. 대통령령 제18800호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제56조의2에서는 관광특구로 지정될 수 있는 지역의 요건을 규정하면서, 같은 영 부칙 제4조에서는 제56조의2의 개정규정은 같은 영 시행 후 지정되는 관광특구부터 적용한다고 적용례를 규정하고 있는 한편,

일부개정 「관광진흥법」(2007. 7. 19. 법률 제8531호로 일부개정되어 2007. 10. 20. 시행된 것을 말하며, 이하 같음)에서는 구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2 각 호에서 규정하고 있던 관광특구의 지정 요건을 일부개정 「관광진흥법」 제70조제1항 각 호로 상향하여 규정하면서, 해당 규정에 대한 경과규정을 두지 않았고, 그 위임된 사항을 정하는 전부개정 「관광진흥법 시행령」(2007. 11. 13. 대통령령 제20374호로 전부개정된 것을 말하며, 이하 같음)에서도 구 「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조의 효력에 관하여 별도로 규정하고 있지 않은바,

구 「관광진흥법 시행령」의 시행일(2005년 4월 22일) 전에 관광특구로 지정받아 구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2에 따른 관광특구의 지정요건을 적용받지 않던 지역[119]이 일부개정 「관광진흥법」 제70조에 따른 관광특구의 지정요건의 적용을 받는지?

---

118) 외국인 관광객의 유치 촉진 등을 위하여 관광 활동과 관련된 관계 법령의 적용이 배제되거나 완화되고, 관광 활동과 관련된 서비스·안내 체계 및 홍보 등 관광 여건을 집중적으로 조성할 필요가 있는 지역으로 「관광진흥법」에 따라 지정된 곳을 말하며(「관광진흥법」 제2조제11호 참조), 이하 같음

119) 2005년 4월 22일 전에 관광특구로 지정받은 후 관광특구 지정취소가 없었던 지역을 전제함

02 회답

구 「관광진흥법 시행령」의 시행일(2005년 4월 22일) 전에 관광특구로 지정받아 구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2에 따른 관광특구의 지정요건을 적용받지 않던 지역은 일부개정 「관광진흥법」 제70조에 따른 관광특구의 지정요건의 적용을 받지 않습니다.

03 이유

구 「관광진흥법」 제67조제1항에서 관광특구는 대통령령이 정하는 요건에 적합한 지역 중에서 시장·군수·구청장의 신청에 의하여 시·도지사가 지정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2에서는 관광특구로 지정될 수 있는 지역의 요건을 규정하면서, 같은 영 부칙 제4조에서는 제56조의2의 개정규정은 같은 영 시행 후 지정되는 관광특구부터 적용한다고 규정하고 있습니다.

이후 ① 일부개정 「관광진흥법」에서는 대통령령인 구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2에서 규정하고 있던 관광특구의 지정 요건을 일부개정 「관광진흥법」 제70조제1항 각 호로 내용 변경 없이 상향하여 규정하면서, 그에 대한 경과규정을 두지 않았고, ② 전부개정 「관광진흥법 시행령」에서도 종전 부칙의 적용범위[120]나 구 「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조의 효력에 관하여 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안에서는 구 「관광진흥법 시행령」의 시행일(2005년 4월 22일) 전에 관광특구로 지정받은 지역에 대하여 구 「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조의 효력이 실효되지 않고 계속 적용된다고 볼 것인지가 문제됩니다.

먼저 대통령령인 구 「관광진흥법 시행령」에서 규정하고 있던 관광특구의 지정 요건을 법률인 일부개정 「관광진흥법」 제70조제1항 각 호로 상향하여 규정하면서, 해당 규정에 대한 경과규정을 두지 않은 것에 대하여 살펴보면, 일부개정 「관광진흥법」 제70조제1항은 "관광특구의 지정에 관한 사항은 법률에 규정하여야 할 중요한 사항인 점을 고려하여 대통령령에 위임하고 있는 관광특구의 지정요건을 법률에 규정"하기 위하여 개정된 것이고[121], 구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2의 각 호에서 규정하고 있던 관광특구의 지정요건 4가지를 그대로 일부개정 「관광진흥법」 제70조제1항 각 호로 상향하여 규정함으로써 관광특구의

120) 법제처 법령·입안심사기준(2023) p.708 및 p.709 참조
121) 2007. 7. 19. 법률 제8531호로 일부개정되어 2007. 10. 20. 시행된 「관광진흥법」 개정이유 참조

지정요건은 실질적인 내용 변경이 없었으며, 이처럼 종전과 내용이 동일하여 법령 적용에 혼선이 야기될 우려가 없는 경우[122] 일반적으로 법령에서 경과규정을 두지 않는 것인바, 이 사안과 같이 구「관광진흥법 시행령」의 시행일(2005년 4월 22일) 전에 관광특구로 지정받아 구「관광진흥법 시행령」 제56조의2에 따른 관광특구의 지정요건을 적용받지 않던 지역에 대해서 일부개정「관광진흥법」 제70조에 따른 관광특구의 지정요건을 적용하려는 입법취지가 있었다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

다음으로 전부개정「관광진흥법 시행령」 부칙에서 구「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조의 효력에 관하여 별도의 규정을 두지 않은 것에 대하여 살펴보면, 법령을 전부개정하는 경우에는 법령의 내용 전부를 새로 고쳐 쓰므로 종전의 본칙은 물론 부칙 규정도 모두 소멸한다고 해석하는 것이 원칙이겠지만, 그 경우에도 종전 경과규정의 입법 경위와 취지, 개정 전후 법령의 전반적인 체계나 내용 등에 비추어 신법의 효력발생 이후에도 종전의 경과규정을 계속 적용하는 것이 입법자의 의사에 부합하고, 그 결과가 수범자인 국민에게 예측할 수 없는 부담을 지우는 것이 아니라면 별도의 규정이 없더라도 종전의 경과규정이 실효되지 않고 계속 적용된다고 해석할 수 있습니다[123].

① 우선 구「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조에서는 제56조의2의 개정규정은 같은 영 시행(2005년 4월 22일) 후 지정되는 관광특구부터 적용한다고 규정하고 있는데, 이는 구「관광진흥법 시행령」 제56조의2에서 관광특구의 지정요건이 신설됨에 따라, 집행상의 논란을 방지하기 위하여 신설된 관광특구의 지정요건을 적용하는 시기 및 대상에 대하여 구체적으로 규정한 것으로써[124], 구「관광진흥법 시행령」의 시행일(2005년 4월 22일) 전에 관광특구로 이미 지정받은 지역에 대해서는 강화된 관광특구의 지정요건이 적용되지 않도록 한 것이고, ② 전부개정「관광진흥법 시행령」의 입법 취지를 살펴보면, 해당 대통령령의 개정방식을 전부개정 방식으로 한 이유는 어려운 용어와 표현 등을 이해하기 쉽게 고치고, 복잡한 문장 등은 체계를 정리하여 쉽고 간결하게 정비하기 위한 것으로[125], 실질적인 내용 변경을 위하여 전부개정한 것이 아니며, 이 사안에서 문제되는 관광특구의 지정요건과 관련된 개정은 일부개정「관광진흥법」 제70조제1항으로 상향하여 규정된 것을 반영하는 것이라는 점 등에 비추어 볼 때, 전부개정「관광진흥법 시행령」에서 구「관광진흥법 시행령」 부칙

122) 법제처 법령·입안심사기준(2023) p. 658 참조

123) 대법원 2008. 11. 27. 선고 2006두19419 판결례, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2012재두299 판결례 및 법제처 2010. 4. 2. 회신 10-0045 해석례 참조

124) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.641 참조

125) 2007. 11. 13. 대통령령 제20374호로 전부개정되어 같은 날 시행된「관광진흥법 시행령」 개정이유 참조

제4조에 따른 적용례의 효력을 상실시키려는 의도나 구 「관광진흥법 시행령」과 전부개정 「관광진흥법 시행령」 사이에 관광특구 지정요건의 본질적인 변경 사항은 없다고 보아야 할 것이므로, 구 「관광진흥법 시행령」 부칙 제4조에 따른 적용례가 실효되지 않고 계속 적용된다고 보는 것이 타당하다고 할 것입니다.

따라서 구 「관광진흥법 시행령」의 시행일(2005년 4월 22일) 전에 관광특구로 지정받아 구 「관광진흥법 시행령」 제56조의2에 따른 관광특구의 지정요건을 적용받지 않던 지역은 일부개정 「관광진흥법」 제70조에 따른 관광특구의 지정요건의 적용을 받지 않습니다.

관계법령

구 관광진흥법 시행령(2005. 4. 22. 대통령령 제18800호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것)

제56조의2(관광특구의 지정요건) 법 제67조의 규정에 의하여 관광특구로 지정될 수 있는 지역은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 지역으로 한다.

1. 문화관광부령이 정하는 바에 따라 접객시설, 상가시설, 휴양·오락시설, 숙박시설, 공공편익시설 및 관광안내시설이 분포되어 있어 외국인 관광객의 관광수요를 충족시킬 수 있는 지역일 것
2. 문화관광부장관이 고시하는 기준을 갖춘 통계전문기관의 통계 결과 당해 지역의 최근 1년간 외국인 관광객이 10만명(서울특별시는 50만명) 이상일 것
3. 임야·농지·공업용지 또는 택지 등 관광활동과 직접적인 관련성이 없는 토지가 관광특구 전체 면적의 10퍼센트를 초과하지 아니할 것
4. 제1호 내지 제3호의 요건을 갖춘 지역이 서로 분리되어 있지 아니할 것

제68조의3(관광특구에 대한 평가 등) ① (생 략)

② 시·도지사는 제1항의 규정에 의한 평가의 결과 제67조의 규정에 의한 관광특구지정요건에 적합하지 아니하거나 추진실적이 미흡한 관광특구에 대하여는 대통령령이 정하는 바에 따라 관광특구의 지정취소·면적조정·개선권고 등 필요한 조치를 할 수 있다.

대통령령 제18800호 관광진흥법 시행령 일부개정령 부칙

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제4조(관광특구의 지정요건에 관한 적용례) 제56조의2의 개정규정은 이 영 시행 후 지정되는 관광특구부터 적용한다.

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0819

문화체육관광부 – 등록권자는 한옥체험업 등록신청이 등록기준에 맞는 경우에도 관할지역 내 등록된 한옥체험업의 총량을 관리하기 위하여 일정기간 동안 등록을 거부할 수 있는지 여부(「관광진흥법 시행령」 제4조 등 관련)

01 질의요지

「관광진흥법」 제4조제1항에서는 관광객 이용시설업[126] 등을 경영하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 등록하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제1항에 따른 등록을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 자본금·시설 및 설비 등을 갖추어야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 별표 1 제4호사목에서는 관광객 이용시설업의 종류 중 하나인 한옥체험업의 등록기준을 규정하고 있는 한편,

「관광진흥법 시행령」 제3조제1항에서는 「관광진흥법」 제4조제1항에 따라 등록을 하려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 관광사업 등록신청서를 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제4조제1항에서는 같은 영 제3조에 따라 등록신청을 받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 신청한 사항이 같은 영 제5조에 따른 등록기준에 맞으면 문화체육관광부령으로 정하는 등록증을 신청인에게 발급하여야 한다고 규정하고 있는바,

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 "등록권자"라 함)은 「관광진흥법」 제4조제1항 및 같은 법 시행령 제3조제1항에 따른 한옥체험업 등록신청이 같은 영 제5조에 따른 등록기준에 맞는 경우[127]에도 관할지역 내 등록된 한옥체험업의 총량을 관리하기 위하여 법령에 근거 없이 일정기간 동안 등록을 거부할 수 있는지?

126) 「관광진흥법」 제3조제1항제3호에 따른 관광객 이용시설업을 말하며, 이하 같음

127) 한옥체험업 등록에 필요한 법령상 모든 요건을 갖춘 경우를 전제함.

02 회답

등록권자는「관광진흥법」제4조제1항 및 같은 법 시행령 제3조제1항에 따른 한옥체험업 등록신청이 같은 영 제5조에 따른 등록기준에 맞는 경우에는 관할지역 내 등록된 한옥체험업의 총량을 관리하기 위하여 법령에 근거 없이 일정기간 동안 등록을 거부할 수는 없습니다.

03 이유

먼저「관광진흥법」제4조제1항에서는 관광객 이용시설업 등을 경영하려는 자는 등록권자에게 등록하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제1항에 따른 등록을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 자본금·시설 및 설비 등을 갖추어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제3조제1항에서는 같은 법 제4조제1항에 따라 등록을 하려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 관광사업 등록신청서를 등록권자에게 제출하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제4조제1항에서는 같은 영 제3조에 따라 등록신청을 받은 등록권자는 신청한 사항이 같은 영 제5조에 따른 등록기준에 맞으면 문화체육관광부령으로 정하는 등록증을 신청인에게 발급하여야 한다고 규정하면서, 등록을 거부하거나 일정기간 동안 제한할 수 있는 별도의 규정은 두고 있지 않습니다.

그런데「관광진흥법 시행령」제5조에 따른 등록기준을 갖추어 한옥체험업을 하려는 자의 등록신청에 대하여 일정기간 동안 등록을 거부하는 것은 국민의 권리를 제한하는 것[128]이고, 국민의 권리를 제한하려는 경우에는 법률에 근거를 두어야 할 것인바[129], 등록권자는 등록기준을 갖추고 한옥체험업을 하려는 자에 대하여 법령에 근거 없이 일정기간 동안 등록을 거부할 수는 없다고 해석하여야 할 것입니다.

또한 규제의 대상 등은 그 근거가 되는 법령에 구체적이고 명확하게 규정되어야 할 것이고[130], 관광사업의 등록과 그 등록기준은 그 문언에 따라 엄격하게 해석해야 할 것인데,「관광진흥법」제4조제3항에서는 같은 조 제1항에 따른 등록을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 자본금·시설 및 설비 등을 갖추어야 한다고 규정하고 있을 뿐이고, 그 위임에 따라

128) 법제처 2008. 6. 5. 회신 08-0103 해석례 참조
129)「행정기본법」제8조 참조
130)「행정규제기본법」제4조 참조.

마련된 같은 법 시행령 별표 1 제4호사목에서는 관광객 이용시설업의 종류 중 하나인 한옥체험업의 등록기준을 (1)부터 (12)까지 나열하여 규정하고 있는바, 한옥체험업을 경영하려는 자가 해당 업의 등록을 위하여 같은 표 제4호사목에서 규정하고 있는 등록기준을 모두 갖추어 한옥체험업의 등록을 신청하였음에도 불구하고, 관할지역 내 등록된 한옥체험업의 총량을 관리하기 위한 경우 등록권자가 법령에 근거 없이 일정기간 동안 등록을 거부할 수 있다고 해석하는 것은 명시적인 근거 없이 한옥체험업의 등록기준을 강화(신설)하는 해석으로서 타당하지 않습니다.

그리고 구 「관광진흥법 시행령」(2020년 4월 28일 대통령령 제30639호로 일부개정되기 전의 것을 말함)에서 한옥체험업은 관광 편의시설업의 한 종류로서 지정제로 운영되었으나, 한옥체험업을 보다 효율적으로 운영·관리할 수 있도록 하기 위하여 2020년 4월 28일 대통령령 제30639호로 「관광진흥법 시행령」을 일부개정하면서 현행과 같이 등록제로 운영되는 관광객 이용시설업의 한 종류로 재분류된 것인데[131], 영업에 대한 등록제는 일정한 기준을 마련해 두고 그 기준에 맞으면 바로 장부에 등재하도록 하여 거의 자동적으로 영업을 허용하기 위하여 도입하는 제도로써 신청인이 등록기준을 모두 갖추었으면 등록권자는 등록신청을 받아 주어야 할 것인바[132], 신청인이 한옥체험업의 등록기준을 모두 갖추었다면 등록권자는 등록신청을 받아 주어야 하고, 법령에 근거 없이 일정기간 동안 등록을 거부할 수는 없다고 해석하는 것이 한옥체험업을 지정제에서 등록제로 개정한 입법연혁 및 개정취지에도 부합하는 해석입니다.

따라서 등록권자는 「관광진흥법」 제4조제1항 및 같은 법 시행령 제3조제1항에 따른 한옥체험업 등록신청이 같은 영 제5조에 따른 등록기준에 맞는 경우에는 관할지역 내 등록된 한옥체험업의 총량을 관리하기 위하여 법령에 근거 없이 일정기간 동안 등록을 거부할 수는 없습니다.

131) 2020. 4. 28. 대통령령 제30639호로 일부개정된 「관광진흥법 시행령」 개정이유 참조

132) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.145 및 p.149 참조

관계법령

관광진흥법

제4조(등록) ① 제3조제1항제1호부터 제4호까지의 규정에 따른 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업 및 국제회의업을 경영하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 등록하여야 한다.
② 삭제
③ 제1항에 따른 등록을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 자본금(법인인 경우에는 납입자본금을 말하고, 개인인 경우에는 등록하려는 사업에 제공되는 자산의 평가액을 말한다)·시설 및 설비 등을 갖추어야 한다.
④·⑤ (생 략)

관광진흥법 시행령

제4조(등록증의 발급) ① 제3조에 따라 등록신청을 받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 신청한 사항이 제5조에 따른 등록기준에 맞으면 문화체육관광부령으로 정하는 등록증을 신청인에게 발급하여야 한다.
② ~ ④ (생 략)
제5조(등록기준) 법 제4조제3항에 따른 관광사업의 등록기준은 별표 1과 같다. 다만, 휴양 콘도미니엄업과 전문휴양업 중 온천장 및 농어촌휴양시설을 2012년 11월 1일부터 2014년 10월 31일까지 제3조제1항에 따라 등록 신청하면 다음 각 호의 기준에 따른다.
1. ~ 3. (생 략)

[별표 1]

관광사업의 등록기준(제5조 관련)

1. ~ 3. (생 략)
4. 관광객이용시설업
가. ~ 바. (생 략)
사. 한옥체험업
(1) 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 제27조에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 기준에 적합한 한옥일 것. 다만, 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」, 「근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 문화유산 또는 자연유산으로 지정·등록된 한옥 및 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 제10조에 따라 우수건축자산으로 등록된 한옥의 경우에는 그렇지 않다.
(2) 객실 및 편의시설 등 숙박 체험에 이용되는 공간의 연면적이 230제곱미터 미만일 것. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 한옥의 경우에는 그렇지 않다.

(가) 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」, 「근현대문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 또는 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」에 따라 문화유산 또는 자연유산으로 지정·등록된 한옥

(나) 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 제10조에 따라 우수건축자산으로 등록된 한옥

(다) 한옥마을의 한옥, 고택 등 특별자치시·특별자치도·시·군·구의 조례로 정하는 한옥

(3) 숙박 체험을 제공하는 경우에는 이용자의 불편이 없도록 욕실이나 샤워시설 등 편의시설을 갖출 것

(4) 객실 내부 또는 주변에 소화기를 1개 이상 비치하고, 숙박 체험을 제공하는 경우에는 객실마다 단독경보형 감지기 및 일산화탄소 경보기(난방설비를 개별난방 방식으로 설치한 경우만 해당한다)를 설치할 것

(5) 취사시설을 설치하는 경우에는 「도시가스사업법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 그 밖의 관계 법령에서 정하는 기준에 적합하게 설치·관리할 것

(6) 수돗물(「수도법」 제3조제5호에 따른 수도 및 같은 조 제14호에 따른 소규모급수시설에서 공급되는 물을 말한다) 또는 「먹는물관리법」 제5조제3항에 따른 먹는물의 수질 기준에 적합한 먹는물 등을 공급할 수 있는 시설을 갖출 것

(7) 월 1회 이상 객실·접수대·로비시설·복도·계단·욕실·샤워시설·세면시설 및 화장실 등을 소독할 수 있는 체제를 갖출 것

(8) 객실 및 욕실 등을 수시로 청소하고, 침구류를 정기적으로 세탁할 수 있는 여건을 갖출 것

(9) 환기를 위한 시설을 갖출 것. 다만, 창문이 있어 자연적으로 환기가 가능한 경우에는 그렇지 않다.

(10) 욕실의 원수(原水)는 「공중위생관리법」 제4조제2항에 따른 목욕물의 수질기준에 적합할 것

(11) 한옥을 관리할 수 있는 관리자를 영업시간 동안 배치할 것

(12) 숙박 체험을 제공하는 경우에는 접수대 또는 홈페이지 등에 요금표를 게시하고, 게시된 요금을 준수할 것

5. (생 략)

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0822

문화체육관광부 – 「관광진흥법」 제48조의3제6항에 따른 특별관리지역에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 시·도지사나 시장·군수·구청장이 할 수 있는 “필요한 조치”의 범위(「관광진흥법」 제48조의3 제6항 등 관련)

01 질의요지

「관광진흥법」 제48조의3제2항에서 시·도지사나 시장·군수·구청장[133]은 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 조례로 정하는 바에 따라 특별관리지역으로 지정할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 수용 범위를 초과한 관광객의 방문으로 자연환경이 훼손되거나 주민의 평온한 생활환경을 해칠 우려가 있어 관리할 필요가 있다고 인정되는 지역을 규정하고 있고, 같은 조 제6항에서 시·도지사나 시장·군수·구청장은 특별관리지역에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 관광객 방문시간 제한, 편의시설 설치, 이용수칙 고지, 이용료 징수, 차량·관광객 통행 제한 등 필요한 조치를 할 수 있다고 규정하고 있는바,

「관광진흥법」 제48조의3제6항에 따라 특별관리지역[134]에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 시·도지사나 시장·군수·구청장이 할 수 있는 “필요한 조치”에 한옥체험업의 등록을 일정기간 제한하는 조치가 포함될 수 있는지?

02 회답

「관광진흥법」 제48조의3제6항에 따라 특별관리지역에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 시·도지사나 시장·군수·구청장이 할 수 있는 “필요한 조치”에 한옥체험업의 등록을 일정기간 제한하는 조치는 포함되지 않습니다.

133) 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음

134) 「관광진흥법」 제48조의3제2항제1호에 따라 지정된 특별관리지역을 전제함

03 이유

「관광진흥법」 제48조의3제2항에서 시·도지사나 시장·군수·구청장은 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 조례로 정하는 바에 따라 특별관리지역으로 지정할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 수용 범위를 초과한 관광객의 방문으로 자연환경이 훼손되거나 주민의 평온한 생활환경을 해칠 우려가 있어 관리할 필요가 있다고 인정되는 지역을 규정하고 있고, 같은 조 제6항에서 시·도지사나 시장·군수·구청장은 특별관리지역에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 관광객 방문시간 제한, 편의시설 설치, 이용수칙 고지, 이용료 징수, 차량·관광객 통행 제한 등 필요한 조치를 할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 한옥체험업의 등록을 일정기간 제한하는 조치가 "관광객 방문시간 제한, 편의시설 설치, 이용수칙 고지, 이용료 징수, 차량·관광객 통행 제한 등 필요한 조치"에 포함될 수 있는지가 문제됩니다.

먼저 일반적으로 법령에서 하나 또는 수개의 사항을 열거하고 그 뒤에 "등"을 사용한 경우 열거된 사항은 예시사항이라 할 것이고, 별도로 해석해야 할 특별한 이유가 없는 한 그 "등"에는 열거된 예시사항과 규범적 가치가 동일하거나 그에 준하는 성질을 가지는 사항이 포함되는 것으로 해석함이 상당하다 할 것인데[135], 「관광진흥법」 제48조의3제6항에서 특별관리지역에 필요한 조치로 열거된 예시사항을 살펴보면, "관광객 방문시간 제한, 편의시설 설치, 이용수칙 고지, 이용료 징수, 차량·관광객 통행 제한"으로, 이러한 조치사항은 특별관리지역을 방문하는 관광객을 대상으로 수용 범위를 초과하는 방문을 제한함으로써 주민의 평온한 생활환경을 보장하기 위한 조치 등에 해당하고, 같은 조 제7항에서 같은 조 제6항에 따른 조례를 위반한 사람에게 「지방자치법」에 따라 1천만원 이하의 과태료를 부과·징수할 수 있도록 규정하고 있는 점과 「관광진흥법」 제48조의3제8항에서 특별관리지역의 조치사항을 표시한 안내판을 설치하도록 규정하고 있는 점에 비추어 보더라도 열거된 예시사항은 특별관리지역을 방문하는 관광객을 대상으로 하는 조치로 볼 수 있는 것과 달리, 이 사안과 같이 한옥체험업의 등록을 일정기간 제한하는 조치는 그 대상이 특별관리지역을 방문하는 관광객이 아닌 해당 지역에서 관광사업을 하려는 자이고, 그 조치 사항 또한 관광객의 방문 제한과 같은 방법이 아닌 관광사업의 등록 자체를 제한하는 것으로, 「관광진흥법」 제48조의3 제6항에서 특별관리지역에 필요한 조치의 예시로 열거하고 있는 사항들과 규범적 가치가 동일하거나 그에 준하는 성질을 가지는 사항에 포함된다고 보기 어렵다고 할 것입니다.

135) 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0498 해석례 참조

더욱이 「관광진흥법」 제48조의3제6항에서 특별관리지역에 필요한 조치로 열거된 예시사항의 입법연혁을 살펴보면, 2019년 12월 3일 법률 제16684호로 「관광진흥법」을 일부개정하면서 특별관리지역 지정제도를 도입할 당시에는 "관광객 방문시간 제한 등 필요한 조치"를 할 수 있도록 규정하고 있었는데[136], 특별관리지역 내 주민의 정주권 보호를 위해 이러한 관광객 방문시간 제한뿐만 아니라 다른 침익적 행정행위가 가해질 수 있다는 점에서 그 내용을 구체적으로 명시하는 것이 바람직하므로, 조례에 포괄위임하기보다는 차량·관광객 통행제한, 이용료 징수 사항 등 효율적인 보호 수단을 포함하는 내용으로[137] 2021년 4월 13일 법률 제18009호로 일부개정된 「관광진흥법」 제48조의3제6항에서 필요한 조치의 예시사항을 추가하게 된 것인바[138], 이러한 입법연혁 및 취지를 고려하면, 「관광진흥법」 제48조의3제6항에 따라 특별관리지역에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 할 수 있는 필요한 조치의 범위에는 한옥체험업의 등록을 일정기간 제한하는 조치는 포함되지 않는다고 할 것입니다.

또한 이 사안에서 특별관리지역에 대한 필요한 조치로 하려는 "한옥체험업의 등록의 등록을 일정기간 제한하는 조치"에 대하여 살펴보면, 규제의 대상 등은 그 근거가 되는 법령에 구체적이고 명확하게 규정되어야 할 것인데[139], 한옥체험업과 같은 관광객 이용시설업의 등록에 대하여 규정하고 있는 「관광진흥법」 제4조(등록), 같은 법 시행령 제4조(등록증의 발급)·제5조(등록기준) 등에서는 등록거부나 등록제한에 대하여 명시적인 규정을 두고 있지 않다는 점, 일반적으로 영업에 대한 등록제는 일정한 기준을 마련해 두고 그 기준에 맞으면 바로 장부에 등재하도록 하여 거의 자동적으로 영업을 허용하기 위한 제도인데[140], 등록제로 운영되는 한옥체험업의 등록 자체를 일정기간 동안 제한하는 것은 등록제의 취지에 부합하지 않을 수 있다는 점 등을 종합해 볼 때, 이 사안 특별관리지역에 대한 필요한 조치에 한옥체험업의 등록을 일정기간 제한하는 조치는 포함되지 않는다고 해석하는 것이 일반적인 등록제의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 「관광진흥법」 제48조의3제6항에 따라 특별관리지역에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 시·도지사나 시장·군수·구청장이 할 수 있는 "필요한 조치"에 한옥체험업의 등록을 일정기간 제한하는 조치는 포함되지 않습니다.

---

136) 2019. 12. 3. 법률 제16684호로 일부개정된 「관광진흥법」 개정이유 참조

137) 2020. 11. 18. 의안번호 제2105460호로 발의된 「관광진흥법」 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 문화체육관광위원회 검토보고서 참조

138) 2021. 4. 13. 법률 제18009호로 일부개정된 「관광진흥법」 개정이유 참조

139) 「행정규제기본법」 제4조 참조

140) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.145 및 p.149 참조

관계법령

관광진흥법

제48조의3(지속가능한 관광활성화) ① (생 략)

② 시·도지사나 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 조례로 정하는 바에 따라 특별관리지역으로 지정할 수 있다. 이 경우 특별관리지역이 같은 시·도 내에서 둘 이상의 시·군·구에 걸쳐 있는 경우에는 시·도지사가 지정하고, 둘 이상의 시·도에 걸쳐 있는 경우에는 해당 시·도지사가 공동으로 지정한다.

1. 수용 범위를 초과한 관광객의 방문으로 자연환경이 훼손되거나 주민의 평온한 생활환경을 해칠 우려가 있어 관리할 필요가 있다고 인정되는 지역
2. 차량을 이용한 숙박·취사 등의 행위로 자연환경이 훼손되거나 주민의 평온한 생활환경을 해칠 우려가 있어 관리할 필요가 있다고 인정되는 지역. 다만, 다른 법령에서 출입, 주차, 취사 및 야영 등을 금지하는 지역은 제외한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

⑥ 시·도지사나 시장·군수·구청장은 특별관리지역에 대하여 조례로 정하는 바에 따라 관광객 방문시간 제한, 편의시설 설치, 이용수칙 고지, 이용료 징수, 차량·관광객 통행 제한 등 필요한 조치를 할 수 있다.

⑦ 시·도지사나 시장·군수·구청장은 제6항에 따른 조례를 위반한 사람에게 「지방자치법」 제27조에 따라 1천만원 이하의 과태료를 부과·징수할 수 있다.

⑧ 시·도지사나 시장·군수·구청장은 특별관리지역에 해당 지역의 범위, 조치사항 등을 표시한 안내판을 설치하여야 한다.

⑨·⑩ (생 략)

관광진흥법 시행령

제4조(등록증의 발급) ① 제3조에 따라 등록신청을 받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 신청한 사항이 제5조에 따른 등록기준에 맞으면 문화체육관광부령으로 정하는 등록증을 신청인에게 발급하여야 한다.

② ~ ④ (생 략)

질의제목 10 ▶ 안건번호 24-0854

문화체육관광부 – 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농업협동조합중앙회가 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 공공법인에 해당하는지 여부(「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조 등 관련)

01 질의요지

「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」(이하 "정부광고법"이라 함) 제2조제2호에서는 "공공법인"이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 지정된 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 특별법에 따라 설립된 법인을 말한다고 정의하고 있는바,

「농업협동조합법」에 따라 설립된 농업협동조합중앙회가 정부광고법 제2조제2호에 따른 "특별법에 따라 설립된 법인"에 해당하는지?

02 회답

「농업협동조합법」에 따라 설립된 농업협동조합중앙회는 정부광고법 제2조제2호에 따른 "특별법에 따라 설립된 법인"에 해당합니다.

03 이유

정부광고법에서는 정부기관등[141]의 장은 정부광고의 시행에 필요한 연간 계획을 수립하고(제3조제2항), 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청해야 한다고(제5조) 규정하여, 광고의뢰 의무가 있는 자로 "정부기관" 및 "공공법인"을

141) 정부기관 또는 공공법인을 말하며(정부광고법 제2조제3호 참조), 이하 같음

규정하고 있는데, 같은 법 제2조제2호에서는 "공공법인"으로 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 지정된 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 "특별법에 따라 설립된 법인"을 규정하고 있는바, 정부광고법에 따라 광고의뢰 의무가 있는 "특별법에 따라 설립된 법인"에 해당하는지 여부는 정부광고의 효율성 및 공익성을 향상시키려는 같은 법의 입법 목적과 법인의 설립근거가 되는 법률에서 해당 법인에게 공공적 역할이나 기능을 수행하도록 하고 있는지, 조직구성이나 활동에 대한 행정적 관리·감독 등에서 「민법」이나 「상법」 등에 따라 설립된 일반 법인과 달리 규율하고 있는지, 국가나 지방자치단체의 재정적 지원 등이 있는지, 해당 법인에 대하여 광고의뢰 의무를 부여할 필요성이 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단할 필요가 있습니다[142].

먼저 「농업협동조합법」은 농업인의 자주적인 협동조직을 바탕으로 농업인의 경제적·사회적·문화적 지위를 향상시키고, 농업의 경쟁력 강화를 통하여 농업인의 삶의 질을 높이며, 국민경제의 균형 있는 발전에 이바지함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제3조에서는 농업협동조합중앙회의 독점적 명칭을 보호하는 규정을, 같은 법 제5조에서는 최대봉사의 원칙과 영리목적 업무를 금지하는 규정을, 같은 법 제8조에서는 조세 외의 부과금을 면제하는 규정을 두고 있는데, 이러한 규정들은 농업협동조합중앙회가 국민경제 및 산업에 미치는 영향 및 그 업무의 공공성을 고려한 것이라고 할 것입니다[143].

또한 「농업협동조합법」 제134조제1항제5호는 국가나 공공단체가 위탁하거나 보조하는 사업을 농업협동조합중앙회의 사업 범위로 하는 규정을 두고 있고, 이에 따라 국가는 각종 법률에 근거하여 농업협동조합중앙회를 사업 주관기관 혹은 사업 시행기관으로 하여 각종 사업에 관하여 막대한 자금을 지원하거나 융자하고 있는 등[144] 농업협동조합중앙회는 국가로부터 재정적 지원 등을 받고 있고, 이러한 각종 지원은 농업협동조합중앙회가 국민경제 및 산업에 미치는 영향이 중대하기 때문으로 보아야 할 것입니다[145].

그리고 「농업협동조합법」은 ① 같은 법 제123조에서 농업협동조합중앙회 정관의 변경(제1호), 임원 및 조합감사위원장의 선출과 해임(제3호) 등의 사항을 총회의 의결 사항으로, 같은 법 제125조제4항에서는 농업협동조합중앙회의 경영목표의 설정(제1호), 사업계획 및 자금계획의 종합조정(제2호), 조직·경영 및 임원에 관한 규정의 제정·개정 및 폐지(제3회)

142) 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008두5643 판결례, 법제처 2020. 4. 21. 회신 20-0064 해석례 및 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0333 해석례 참조

143) 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007도6556 판결례 참조

144) 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007도6556 판결례 및 서울고등법원 2016. 4. 12. 선고 2015누53024 판결 참조

145) 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007도6556 판결례 참조

등을 이사회의 의결 사항으로 규정하면서도, 같은 법 제163조에서는 농림축산식품부장관은 농업협동조합중앙회의 총회나 이사회가 의결한 사항이 위법 또는 부당하다고 인정하면 그 전부 또는 일부를 취소하거나 집행을 정지하게 할 수 있다고 규정하고 있고, ② 같은 법 제162조제1항에서 농림축산식품부장관은 같은 법에서 정하는 바에 따라 농업협동조합중앙회를 감독하며 대통령령으로 정하는 바에 따라 감독상 필요한 명령과 조치를 할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 농림축산식품부장관은 같은 조 제1항에 따른 직무를 수행하기 위하여 필요하다고 인정하면 금융위원회에 농업협동조합중앙회에 대한 검사를 요청할 수 있는 있도록 규정하고 있으며, ③ 같은 법 제164조제1항에서는 농림축산식품부장관은 농업협동조합중앙회의 업무와 회계가 법령, 법령에 따른 행정처분 또는 정관에 위반된다고 인정하면 농업협동조합중앙회에 대하여 기간을 정하여 그 시정을 명하고 관련 임직원에게 직무의 정지 등 조치를 하게 할 수 있도록 규정하는 등 국가가 농업협동조합중앙회의 운영 전반에 관하여 광범위하고 다양한 방법으로 지도·감독을 하도록 하고 있습니다[146].

더욱이 「농업협동조합법」 제121조제1항에서는 농업협동조합중앙회를 설립하려면 15개 이상의 조합[147]이 발기인이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거쳐 농림축산식품부장관의 인가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 농업협동조합중앙회의 해산에 관하여는 법률로 정한다고 규정하고 있는데, 이는 같은 법 제89조에서 지역농협[148]의 해산에 관하여는 「민법」 및 「비송사건절차법」을 준용하도록 하고 있는 것과 구별되고[149], 같은 법 제139조제1항 및 같은 법 제160조제4항에서는 농업협동조합중앙회로 하여금 자금 사용내용 등의 공시 및 결산보고서 제출 의무를 부과하고 있는 등 농업협동조합중앙회를 「민법」이나 「상법」 등에 따라 설립된 일반 법인과 달리 규율하고 있다고 할 것입니다.

아울러 정부광고법 제2조제3호에서는 "정부광고"란 정부기관 또는 공공법인이 국내외의 홍보 매체에 광고, 홍보, 계도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위를 말한다고 정의하고 있고, 같은 법에서는 특별법에 따라 설립된 법인을 포함한 "공공법인"에 대하여 같은 법 제5조에 따라 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하도록 의무를 부과하고 있는데, 이러한 의무 부과는 정부광고의 효율성 및 공익성을 향상시키기 위한 것인바[150], 국민경제 및 산업에

146) 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007도6556 판결례 및 서울고등법원 2016. 4. 12. 선고 2015누53024 판결례 참조
147) 지역조합과 품목조합을 말함(「농업협동조합법」 제2조제1호 참조)
148) 지역농업협동조합을 말함(「농업협동조합법」 제13조 참조).
149) 서울고등법원 2016. 4. 12. 선고 2015누53024 판결례 참조
150) 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0333 해석례 참조

중대한 영향을 미치고 있고, 그 업무의 공공성이 있는[151] 농업협동조합중앙회는 정부광고법 제2조제2호에 따른 공공법인에 해당한다고 보아 농업협동조합중앙회가 정부광고를 하려는 경우에도 같은 법 제5조에 따라 미리 문화체육관광부장관에게 광고를 의뢰하도록 하는 것이 정부광고의 효율성 및 공익성 향상에 부합한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「농업협동조합법」에 따라 설립된 농업협동조합중앙회는 정부광고법 제2조제2호에 따른 "특별법에 따라 설립된 법인"에 해당합니다.

관계법령

정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "정부기관"이란 「정부조직법」에 따른 국가기관, 「지방자치법」 제2조제1항 각 호에 따른 지방자치단체 및 같은 조 제3항에 따른 특별지방자치단체, 「지방교육자치에 관한 법률」 제18조에 따른 교육감 및 같은 법 제34조에 따른 하급교육행정기관을 말한다.
2. "공공법인"이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 지정된 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 및 특별법에 따라 설립된 법인을 말한다.
3. "정부광고"란 정부기관 또는 공공법인(이하 "정부기관등"이라 한다)이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 계도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위를 말한다.
4. (생 략)

제5조(광고의뢰) 정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다.

농업협동조합법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "조합"이란 지역조합과 품목조합을 말한다.
2. "지역조합"이란 이 법에 따라 설립된 지역농업협동조합과 지역축산업협동조합을 말한다.
3. "품목조합"이란 이 법에 따라 설립된 품목별·업종별 협동조합을 말한다.
4. "중앙회"란 이 법에 따라 설립된 농업협동조합중앙회를 말한다.

제4조(법인격 등) ① 이 법에 따라 설립되는 조합과 중앙회는 각각 법인으로 한다.
② 조합과 중앙회의 주소는 그 주된 사무소의 소재지로 한다.

151) 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007도6556 판결례 참조



국방·국가보훈

제1절 국방
제2절 국가보훈

제1절 국방

질의제목 1 ▶ 안건번호 24-0279

병무청 – 「병역법」 제65조제1항제1호에 따라 각 군 참모총장으로부터 보충역 편입·전시근로역 편입 또는 병역면제 처분을 받은 사람이 같은 법 제77조의2에 따라 지방병무청장이 실시하는 확인신체검사 대상에 포함되는지 여부(「병역법」 제77조의2제1항제2호 등 관련)

01 질의요지

「병역법」 제65조제1항제1호에서는 '현역병(같은 법 제21조 및 제25조에 따라 복무 중인 사람[1])과 현역병입영 대상자를 포함함), 승선근무예비역 또는 보충역으로서 전상·공상· 질병 또는 심신장애로 인하여 병역을 감당할 수 없는 사람에 대하여는 신체검사를 거쳐 보충역 편입·전시근로역 편입 또는 병역면제 처분(이하 "병역처분변경등"이라 함)을 할 수 있다'고 규정하면서, 같은 법 시행령 제135조에서는 '현역병입영 대상자' 등의 경우에는 '지방병무청장'이, 같은 영 제137조에서는 현역병입영 대상자를 제외한 '같은 법 제65조제1항에 따른 현역병(상근예비역등으로 복무 중인 사람을 포함함)'의 경우에는 '각 군 참모총장'이 각각 병역처분변경등을 하도록 규정하고 있는 한편,

「병역법」 제77조의2제1항제2호에서는 지방병무청장[2]은 같은 법 제65조제1항제1호, 같은 조 제4항 및 같은 법 제65조의2제1항에 따라 병역처분변경등을 받은 사람이 병역의무를 감면받을 목적으로 속임수를 썼다고 인정할 만한 사유 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 진료기록이나 치료내역 등 사실관계를 조사하고 확인신체검사(이하 "확인신체검사"라 함)를 할 수 있다고 규정하고 있는바,

1) 상근예비역(제21조) 및 소방청장, 경찰청장 또는 해양경찰청장의 추천에 의한 전환복무(제25조)로 복무 중인 사람을 말하며, 이하 "상근예비역등으로 복무 중인 사람"이라 함.

2) 병무지청장을 포함하며, 이하 같음.

「병역법」 제77조의2제1항제2호에 따라 지방병무청장이 확인신체검사를 할 수 있는 대상인 '같은 법 제65조제1항제1호에 따라 병역처분변경등을 받은 사람'에 현역병으로 입영[3] 이후 같은 법 시행령 제137조에 따라 각 군 참모총장으로부터 병역처분변경등을 받은 사람이 포함되는지?

02 회답

「병역법」 제77조의2제1항제2호에 따라 지방병무청장이 확인신체검사를 할 수 있는 대상인 '같은 법 제65조제1항제1호에 따라 병역처분변경등을 받은 사람'에는 현역병 입영 이후 같은 법 시행령 제137조에 따라 각 군 참모총장으로부터 병역처분변경등을 받은 사람도 포함됩니다.

03 이유

먼저 「병역법」 제65조제1항제1호에서는 '현역병(상근예비역등으로 복무 중인 사람과 현역병입영 대상자를 포함함), 승선근무예비역 또는 보충역으로서 전상·공상·질병 또는 심신장애로 인하여 병역을 감당할 수 없는 사람에 대하여는 신체검사를 거쳐 병역처분변경등을 할 수 있다'고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제135조 및 제137조에서는 같은 법 제65조제1항제1호에 따른 병역처분변경등의 주체를 "현역병입영 대상자" 등에 대해서는 '지방병무청장'으로, 군부대에 들어간 "현역병(상근예비역등으로 복무 중인 사람을 포함함)"에 대해서는 '각 군 참모총장'으로 규정하고 있는데, 같은 법 제77조의2제1항제2호에서는 '지방병무청장'은 '같은 법 제65조제1항제1호에 따라 병역처분변경등을 받은 사람'이 병역의무를 감면받을 목적으로 속임수를 썼다고 인정할 만한 사유 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 진료기록이나 치료내역 등 사실관계를 조사하고 확인신체검사를 할 수 있다고 규정하여, 지방병무청장이 실시하는 확인신체검사의 대상을 '같은 법 제65조제1항제1호에 따라 병역처분변경등을 받은 사람'으로 규정하고 있는바, 지방병무청장과 각 군 참모총장이 행하는 병역처분변경등을 받은 "현역병입영 대상자" 등과 "현역병(상근예비역등으로 복무 중인 사람을 포함함)" 모두 '같은 법 제65조제1항제1호에 따라 병역처분변경등을 받은 사람'에 해당한다는 점이 명확하므로, '각 군 참모총장으로부터 병역처분변경등'을 받은

3) 「병역법」 제2조제1항제3호에 따른 입영(병역의무자가 징집(徵集)·소집(召集) 또는 지원(志願)에 의하여 군부대에 들어가는 것)을 말하며, 이하 같음.

사람도 같은 법 제77조의2에 따라 지방병무청장이 실시하는 확인신체검사의 대상이 될 수 있다고 보는 것이 관련 규정의 문언에 충실한 해석입니다.

그리고 하위법령을 해석할 때에는 상위법령의 규정이나 입법 취지에 저촉되지 않도록 해석하여야 하는 것이지 그와 반대로 하위법령의 입법 취지에 맞추어 상위법령을 해석하는 것은 타당하지 않다고 할 것[4]인바, 「병역법」 제77조의2제1항제2호에 따라 '같은 법 제65조제1항제1호에 따라 병역처분변경등을 받은 사람'은 그 병역처분변경등의 처분권자가 누구인지와 관계없이 확인신체검사의 대상이 될 수 있다는 점은 그 문언상 분명하므로, 비록 같은 법 시행령 제135조 및 제137조 등에서 '입영 여부'를 기준으로 같은 법 제65조제1항제1호에 따른 병역처분변경등의 처분권자를 '지방병무청장' 및 '각 군 참모총장'으로 구분하여 규정하고 있다고 하더라도, 이러한 대통령령의 규정 내용과 체계를 '병역처분변경등'과는 다른 별개의 법률상 제도인 확인신체검사의 실시 및 그에 따른 병역처분 변경 대상을 판단하는 근거로 삼아 「병역법」 제65조제1항제1호 및 같은 법 제77조의2제1항제2호의 문언에도 불구하고 확인신체검사의 대상이 '지방병무청장'이 직접 병역처분변경등을 한 경우만으로 한정된다고 해석할 수는 없습니다.

또한 「대한민국헌법」 제39조제1항에서는 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국방의 의무를 진다고 규정하고 있고, 이에 「병역법」 제3조제1항 전단에서는 대한민국 국민인 남성은 「대한민국헌법」과 「병역법」에서 정하는 바에 따라 병역의무를 성실히 수행해야 한다고 규정하고 있는바, 국가수호 등을 위해 헌법상 부여된 병역의무의 이행과 직결된 신체등위판정이나 병역처분 등은 예외 없이 공정성과 형평성을 유지해야 할 공익적 필요성이 매우 크다는 점[5], 같은 법 제77조의2에서 병역처분변경등을 받은 사람 등에 대하여 확인신체검사를 실시하도록 규정하고 있는 취지는 징병검사 등 병역처분을 받는 과정에서 허위서류 제출 등 속임수를 쓴 것으로 의심되는 사례가 있는 경우 다시 신체검사를 실시하여 기존 병역처분이 잘못되었다고 판단되는 경우에는 해당 처분을 변경할 수 있도록 함으로써 속임수 등을 통해 병역의무를 적극적으로 기피하려는 시도인 병역면탈 범죄의 예방과 병역처분의 정확성을 제고하기 위한 것[6]인 점에 비추어 보면, 현역병 입영 이후 각 군 참모총장으로부터 병역처분변경등을 받은 사람에 대해 단순히 그 병역변경처분등을 '각 군 참모총장'이 하였다는 이유만으로 지방병무청장이 실시하는 확인신체검사의 대상에서 제외된다고 해석하는 것은 타당하다고 보기 어렵습니다.

---

4) 대법원 1996. 2. 15. 선고 95다38677 전원합의체 판결례(별개의견) 참조

5) 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001두9653 판결례 참조

6) 2010. 9. 6. 의안번호 제1809266호로 제출된 병역법 일부개정법률안에 대한 국회 국방위원회 심사보고서 참조

따라서 「병역법」 제77조의2제1항제2호에 따라 지방병무청장이 확인신체검사를 할 수 있는 대상인 '같은 법 제65조제1항제1호에 따라 병역처분변경등을 받은 사람'에는 현역병 입영 이후 같은 법 시행령 제137조에 따라 각 군 참모총장으로부터 병역처분변경등을 받은 사람도 포함됩니다.

법령정비 권고사항

지방병무청장이 실시하는 확인신체검사 대상에서 현역병 입영 이후 「병역법 시행령」 제137조에 따라 각 군 참모총장이 병역처분변경등을 한 사람에 대한 별도의 조사 제도 등을 마련할 정책적 필요성이 있다면, 이를 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

병역법

제65조(병역처분 변경 등) ① 현역병(제21조 및 제25조에 따라 복무 중인 사람과 현역병입영 대상자를 포함한다), 승선근무예비역 또는 보충역으로서 제1호에 해당하는 사람에 대하여는 신체검사를 거쳐 보충역 편입·전시근로역 편입 또는 병역면제 처분을 할 수 있고, 제2호 및 제3호에 해당하는 사람에 대하여는 보충역 편입 또는 전시근로역 편입을 할 수 있다.

1. 전상·공상·질병 또는 심신장애로 인하여 병역을 감당할 수 없는 사람

2.·3. (생 략)

제77조의2(확인신체검사 등) ① 지방병무청장(병무지청장을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 병역의무를 감면받을 목적으로 속임수를 썼다고 인정할 만한 사유 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 진료기록이나 치료내역 등 사실관계를 조사하고 확인신체검사를 할 수 있다.

1. 제12조제1항에 따른 신체등급 판정에서 질병 또는 심신장애로 4급부터 7급까지로 판정되어 병역처분을 받은 사람
2. 제65조제1항제1호, 같은 조 제4항 및 제65조의2제1항에 따라 병역처분이 변경되거나 병역면제 처분을 받은 사람

② 지방병무청장은 제1항에 따른 확인신체검사 결과 병역처분이 잘못되었다고 판단하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 병역처분을 변경하여야 한다.

③ (생 략)

병역법 시행령

제135조(현역병입영 대상자 등의 병역처분변경) ① 현역병입영 대상자, 승선근무예비역, 의무·법무·군종·수의사관후보생 및 기본병과장교 편입 대상자, 보충역(병력동원소집으로 군복무 중인 사람은 제외한다), 대체역(전시근로소집으로 복무중인 사람은 제외한다), 예비역(상근예비역으로 소집되어 복무 중인 사람과 병력동원소집으로 군에서 복무 중인 사람은 제외한다) 또는 전시근로역(전시근로소집으로 복무 중인 사람은 제외한다)으로서 법 제65조제1항제1호, 같은 조 제4항 및 제65조의2제1항에 따라 공상·질병 또는 심신장애로 병역처분을 변경받으려는 사람은 병역처분변경원서를 지방병무청장에게 제출해야 한다.

② ~ ④ (생 략)

⑤ 지방병무청장은 제1항에 따른 병역처분변경원서를 받은 경우에는 중앙신체검사기관·병역판정검사장 또는 군병원에서 신체검사를 실시하여 다음 각 호와 같이 처리한다. 〈단서 생략〉

1. 신체등급이 5급인 사람은 전시근로역편입·소집해제등, 6급인 사람은 병역면제
2. 현역병입영 대상자, 승선근무예비역, 보충역 또는 대체역으로서 신체등급이 7급인 사람은 제17조제2항 및 제3항을 준용하여 처분
3. 현역병입영 대상자로서 신체등급이 2급부터 4급까지인 사람은 그 해의 병역처분기준에 따라 병역처분을 변경

⑥ ~ ⑫ (생 략)

제137조(현역병 등의 병역처분변경) ① 법 제65조제1항·제2항·제3항 및 제11항에 따른 현역병(법 제21조 및 제25조에 따라 복무 중인 사람을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 병역처분변경은 각 군 참모총장이 다음 각 호의 구분에 따라 한다. 〈후단 생략〉

1. 전상·공상·질병 또는 심신장애인 경우 군병원에서 신체검사를 하여 5급 또는 6급에 해당되는 사람은 심사를 거쳐 신체등급이 5급인 경우에는 전시근로역에 편입하고, 6급인 경우에는 병역면제 처분을 한다. 다만, 신체등급이 5급 또는 6급에 해당하더라도 군복무 중 입원기간이 통틀어 3개월 이내이고 의무복무 만료일 기준으로 남은 복무기간이 6개월 이내인 사람으로서 군복무에 지장이 없고 본인이 원하는 경우에는 국방부령으로 정하는 바에 따라 심사를 거쳐 계속 복무하게 할 수 있다.
2. ~ 6. (생 략)

② ~ ⑦ (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 24-0631, 24-0686, 24-0687

민원인 – 「군수품관리법」 제13조에 따라 불용결정된 군수품을 매각하는 경우 매각의 특례를 규정한 「물품관리법」 제39조가 준용되는지 등(「군수품관리법」 제4조 등 관련)

01 질의요지

「물품관리법」 제3조에서는 군수품의 관리에 관하여는 따로 법률로 정한다고 규정하면서, 같은 법 제36조제1항에서는 물품은 매각을 목적으로 한 물품이거나 불용품이 아니면 매각할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 법 제39조에서는 각 중앙관서의 장이나 조달청장은 매각을 목적으로 한 물품이나 불용품을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 "국가계약법"이라 함)에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 경매 또는 수의계약에 의하여 매각할 수 있다고 규정하고 있으며, 「군수품관리법」 제4조에서는 군수품 관리에 관하여는 이 법에 규정하는 것 외에 「물품관리법」 제9조제3항, 제10조부터 제12조까지, 제26조부터 제28조까지, 제30조, 제32조부터 제34조까지, 제36조, 제42조 및 제44조를 준용한다고 규정하고 있는 한편,

국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목에서는 같은 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우로 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 '①「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인', '②국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목5)가)부터 다)까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 자'와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약[7](같은 목 3)·5)) 등을 규정하고 있는바,

가. 「군수품관리법」 제13조에 따라 불용결정된 군수품(이하 "불용군수품"이라 함)을 매각하는 경우 국가계약법에도 불구하고 불용품을 수의계약에 의하여 매각할 수 있도록 매각의 특례를 규정한 「물품관리법」 제39조가 준용되는지?

7) 국가계약법 시행령 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함함(같은 영 제26조제1항제5호가목3) 단서 참조)

나. 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목3) 및 같은 호 가목5)의 '물품의 제조·구매계약 또는 용역계약'에 '물품의 매각계약'이 포함되는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

불용군수품을 매각하는 경우 국가계약법에도 불구하고 불용품을 수의계약에 의하여 매각할 수 있도록 매각의 특례를 규정한「물품관리법」제39조가 준용되지 않습니다.

나. 질의 나에 대해

국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목3) 및 같은 호 가목5)의 '물품의 제조·구매계약 또는 용역계약'에 '물품의 매각계약'은 포함되지 않습니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

「물품관리법」은 국가 물품의 취득·보관·사용 및 처분에 관한 기본적인 사항을 정한 법률(같은 법 제1조)로서, 물품 중에서도 '군수품'의 관리에 관하여는 따로 법률로 정하도록 규정하여(같은 법 제3조)「군수품관리법」에서 이를 별도로 규율하고 있는데,「군수품관리법」제4조에서는 군수품 관리에 관하여는「군수품관리법」에 규정하는 것 외에「물품관리법」제9조제3항, 제10조부터 제12조까지, 제26조부터 제28조까지, 제30조, 제32조부터 제34조까지, 제36조, 제42조 및 제44조를 준용한다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 불용군수품 매각 시「군수품관리법」제4조에서 준용 대상 조문으로 열거하고 있지 않은「물품관리법」제39조(매각의 특례)도 준용되는지 여부가 문제됩니다.

먼저 "준용"이란 특정 조문을 그와 성질이 유사한 규율 대상에 대해 그 성질에 따라 다소 수정하여 적용하는 입법기술로서 준용 규정을 명시적으로 둔 경우에만 준용이 가능하다 할 것이고, 특정 법령에서 준용의 대상을 구체적으로 특정하여 규정하고 있는 경우에는 그 특정된 규정에 한정하여 준용된다고 보아야 할 것[8]인데, 군수품의 관리에 관하여는「군수품

관리법」에서 규율하도록 하면서 「물품관리법」에서 준용이 필요한 조항은 그 대상을 구체적으로 특정하여 '「물품관리법」 제9조제3항, 제10조부터 제12조까지, 제26조부터 제28조까지, 제30조, 제32조부터 제34조까지, 제36조, 제42조 및 제44조'로 규정하고 있는바, 군수품의 매각과 관련하여서는 '물품은 매각을 목적으로 한 물품이거나 불용품이 아니면 매각할 수 없다'는 내용 등을 규정한 「물품관리법」 제36조가 준용될 뿐, '매각을 목적으로 한 물품이나 불용품을 국가계약법에도 불구하고 「물품관리법 시행령」으로 정하는 바에 따라 경매 또는 수의계약에 의하여 매각할 수 있다'고 규정한 「물품관리법」 제39조까지 준용된다고 보기 어렵습니다.

그리고 「물품관리법」 제39조는 매각을 목적으로 한 물품이나 불용품의 매각에 관한 특례 규정으로, '특례'는 원칙적 규정에 대해 특수하고 예외적인 내용을 규정하는 것인바,[9] 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다는 점[10]에 비추어 볼 때에도, 국가를 당사자로 하는 계약에 대한 일반법인 국가계약법에 대한 예외로서 「물품관리법」 제39조가 적용되는 대상의 범위를 명시적인 준용 규정도 없이 불용군수품까지로 확장하는 것은 타당하지 않다고 할 것입니다.

아울러 군수품 관리에 관한 기본적인 사항과 절차를 규정하고 지침을 제공하여 군수품을 효율적이고 체계적으로 관리하는 것을 목적[11]으로 하는 「군수품 관리 훈령」에서도 제14장에서 불용군수품의 매각에 관한 규정들을 두면서, '불용군수품 매각 계약은 국가계약법에 따라 체결한다'고 규정(같은 훈령 제111조제1항)하고 있을 뿐, 불용군수품 매각 시 「물품관리법」 제39조를 준용하여 국가계약법에도 불구하고 「물품관리법 시행령」으로 정하는 바에 따라 수의계약을 체결할 수 있다는 내용을 규정하고 있지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 불용군수품을 매각하는 경우 국가계약법에도 불구하고 불용품을 수의계약에 의하여 매각할 수 있도록 매각의 특례를 규정한「물품관리법」 제39조가 준용되지 않습니다.

8) 법제처 2023. 9. 12. 회신 법제처 23-0380 해석례 참조

9) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.656 참조

10) 법제처 2023. 5. 11. 회신 23-0187 해석례 참조

11) 「군수품 관리 훈령」 제1조 참조

나. 질의 나에 대해

국가계약법 제7조제1항 본문에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제26조제1항에서는 같은 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우를 각 호로 열거하고 있는바, 이와 같은 국가계약법령의 규정 체계에 비추어 보면, 예외규정에 해당하는 같은 법 제7조제1항 단서 및 같은 법 시행령 제26조제1항에 따른 수의계약 사유는 문언에 따라 엄격하게 해석해야 할 것[12]입니다.

그런데 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목3) 및 같은 호 가목5)의 '물품의 제조·구매계약 또는 용역계약'의 의미를 살펴보면, 물품을 만드는 것에 관한 계약인 '물품의 제조계약', 물품을 사는 것에 관한 계약인 '물품의 구매계약' 및 노무를 제공하는 것에 관한 계약인 '용역계약'에 물품을 파는 것에 관한 계약인 '물품의 매각계약'이 포함되지 않는 것은 해당 용어의 통상적인 의미상 명확하고, 특히 '물품의 구매계약'은 국가가 계약상대방 으로부터 물품을 제공받고 그 대가를 지불하는 경우, 즉 국가가 '구매자'의 지위를 가지면서 비용을 '지출'하는 원인이 되는 계약을 말하는데[13], 국가가 그 소유의 물품을 '공급자'의 지위에서 제공하고 계약상대방으로부터 그 대가를 지불받는 경우로서 '세입'의 원인이 되는 계약이라 할 수 있는 '물품의 매각계약'과는 그 성격이 다르다고 할 것이므로[14], '물품의 제조·구매계약 또는 용역계약'에는 '물품의 매각계약'이 포함되지 않는다고 보는 것이 국가계약법령의 문언에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

또한 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목3) 및 같은 호 가목5)에서 수의계약 사유에 해당하는 계약의 유형을 '물품의 제조·구매계약 또는 용역계약'으로 한정하고 있는 반면, 같은 항 제4호에서는 또다른 수의계약 사유로 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정함)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 '물건을 매각·임대'하는 경우를 규정하여 물품의 '제조·구매 또는 용역계약'과 별개로 물건의 '매각'을 수의계약 사유에 해당하는

12) 법제처 2007. 3. 23. 회신 07-0044 해석례 및 법제처 2015. 11. 11. 회신 15-0578 해석례 참조
13) 법제처 2023. 5. 11. 회신 23-0187 해석례 참조
14) 국가계약법 제15조제1항 및 제16조 참조

계약의 유형으로 규정하고 있는 점에 비추어 보면, '물품의 매각계약'은 같은 항 제5호가목3) 및 같은 호 가목5)의 '물품의 제조·구매계약 또는 용역계약'과 구분되는 개념으로 보는 것이 국가계약법령의 체계에 비추어 볼 때 타당합니다.

따라서 국가계약법 시행령 제26조제1항제5호가목3) 및 같은 호 가목5)의 '물품의 제조·구매계약 또는 용역계약'에 '물품의 매각계약'이 포함되지 않습니다.

관계법령

물품관리법

제3조(군수품관리에 관한 특례) 군수품의 관리에 관하여는 따로 법률로 정한다.

제36조(매각) ① 물품은 매각을 목적으로 한 물품이거나 불용품이 아니면 매각할 수 없다.

② 물품관리관은 제1항의 물품 중 매각을 목적으로 한 물품으로서 물품수급관리계획에 정하여진 물품에 대하여는 그 계획의 범위에서, 그 밖의 물품에 대하여는 필요할 때마다 계약담당공무원에게 매각에 관한 필요한 조치를 할 것을 청구하여야 한다.

제39조(매각의 특례) 각 중앙관서의 장이나 조달청장은 매각을 목적으로 한 물품이나 불용품을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 경매 또는 수의계약에 의하여 매각할 수 있다.

물품관리법 시행령

제43조(매각 방법) ① 각 중앙관서의 장이나 조달청장은 법 제39조에 따라 매각하려는 물품이 2회 이상의 일반경쟁입찰이나 경매에 의하여 매각되지 아니하면 수의계약에 의하여 매각할 수 있다. 다만, 취득단가가 10만원 이하이며 총액이 500만원 이하인 불용품은 처음부터 수의계약에 의하여 매각할 수 있다.

② ~ ④ (생 략)

군수품관리법

제4조(준용규정) 군수품 관리에 관하여는 이 법에 규정하는 것 외에 「물품관리법」 제9조제3항, 제10조부터 제12조까지, 제26조부터 제28조까지, 제30조, 제32조부터 제34조까지, 제36조, 제42조 및 제44조를 준용한다.

국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 법 제7조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. ~ 3. (생 략)
4. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정한다)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우
   가. ~ 마. (생 략)
5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우
   가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약
      1)·2) (생 략)
      3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.
      4) (생 략)
      5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약
         가) ~ 다) (생 략)
      6) (생 략)
   나. ~ 아. (생 략)
② ~ ⑥ (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0668

민원인 – 사회복무요원이 병가를 신청한 경우 복무기관의 장은 해당 병가를 반드시 허가하여야 하는지 여부(「병역법 시행령」 제59조제1항 등 관련)

01 질의요지

「병역법 시행령」 제59조제1항제3호에 따르면 복무기관의 장[15]은 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없는 경우 해당 기간(가목) 또는 공무 외의 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없는 경우 해당 기간(나목) 사회복무요원[16]에게 병가를 허가할 수 있고, 「병역법」 등에 따라 사회복무요원의 복무관리 및 행정처리 절차 등에 필요한 사항을 규정하고 있는 「사회복무요원 복무관리 규정」[17] 제23조제1항에서는 복무기관의 장은 사회복무요원이 병가를 신청할 경우에는 「병역법 시행령」 제59조제1항제3호에 따라 허가할 수 있다고 규정하고 있는바,

사회복무요원이 의료기관의 진단서 등 증빙서류를 구비하여 병가를 신청한 경우, 복무기관의 장은 해당 병가를 반드시 허가해야 하는지, 아니면 사회복무요원의 건강 상태, 직무수행 가능 여부 등을 고려하여 신청한 병가의 전부 또는 일부를 허가하지 않을 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 복무기관의 장은 「병역법 시행령」 제59조제1항에 따라 사회복무요원이 신청한 병가의 전부 또는 일부를 허가하지 않을 수 있습니다.

---

15) 사회복무요원이 배정되어 복무하게 되는 국가기관, 지방자치단체, 공공단체 및 「사회복지사업법」 제2조에 따라 설치된 사회복지시설의 장을 말하며(「병역법」 제2조제10호 참조), 이하 같음

16) 국가기관, 지방자치단체, 공공단체 등의 공익목적 수행에 필요한 사회복지, 보건·의료, 교육·문화, 환경·안전 등의 사회서비스업무 및 행정업무 등의 지원을 위하여 소집되어 공익 분야에 복무하는 사람을 말하며(「병역법」 제2조제10호 참조), 이하 같음

17) 병무청 훈령 제2068호

03 이유

먼저 「병역법」 제31조제1항 전단에서는 사회복무요원을 배정받은 기관의 장은 복무분야를 지정하여 복무하게 하여야 하며, 그 복무에 필요한 사항은 이 법에서 정하는 사항을 제외하고는 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제59조에서는 사회복무요원의 휴가에 관해 규정하고 있는데, 같은 조 제3항에서 복무기관의 장은 사회복무요원이 같은 영 제65조의6제4호 단서에 따른 방송통신에 의한 수업이나 원격수업으로 수학하는 과정에서 출석수업이 필요한 경우에는 특별한 사유가 없으면 같은 영 제59조제1항제1호에 따른 연가를 “허용해야 한다”고 규정하고 있는데 반해, 같은 조 제1항에서는 복무기관의 장은 같은 항 각 호의 구분에 따라 사회복무요원에게 휴가를 “허가할 수 있다”고 문언상 규정하고 있고, 같은 조 제1항제3호가목·나목에서는 복무기관의 장이 병가를 허가할 수 있는 사유를 공무상 질병 또는 부상, 공무 외의 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없는 경우로 규정하면서, 해당 규정 및 그 밖의 병역법령에서는 질병 또는 부상의 종류나 그 정도, 직무를 수행할 수 없는 경우 등에 대해서는 별도의 기준을 규정하고 있지 않은 점을 고려하면, 「병역법 시행령」 제59조제1항제3호는 원칙적으로 사회복무요원의 병가 신청이 있을 경우 복무기관의 장으로 하여금 사회복무요원의 질병·부상 상태 등이 같은 호 각 목에 따른 병가 사유에 해당하는지에 대해 개별적으로 살펴 병가 허가 여부를 판단할 수 있는 것으로 보아야 할 것입니다.

그리고 사회복무요원으로 복무 중인 사람의 복무관리 및 행정처리 절차 등에 관하여 규정하고 있는 「사회복무요원 복무관리 규정」 제23조에 따르면 복무기관의 장은 사회복무요원이 병가를 신청할 경우에는 「병역법 시행령」 제59조제1항제3호에 따라 이를 허가할 수 있고, 예상치 못한 질병으로 인해 출근이 어려운 경우에는 복무기관의 장이 사후에 증빙서류를 제출받아 병가를 허가할 수 있도록 하고 있으며(제1항), 병가기간이 3일 이내인 경우에는 사회복무요원이 진료확인서 · 처방전 등 증빙서류를 제출하면 복무기관의 장이 그 질병상태를 종합 판단하여 병가를 허가할 수 있도록 규정하고 있고(제3항), 병가조퇴 등으로 사회복무요원의 병가기간이 1일 미만이고 증빙서류를 제출할 수 없는 부득이한 경우 복무기관의 장이 질병 상태를 직접 확인하여 이를 생략할 수 있다고(제4항) 규정하고 있어, 사회복무요원은 원칙적으로 사전에 병가를 신청하여야 하되, 복무기관의 장이 사회복무요원의 질병 상태 등에 대해 확인하는 것을 전제로 증빙서류의 제출 시 사후에 병가를 허가하도록 하거나, 증빙서류 제출을 생략할 수 있도록 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 사회복무요원이 진료확인서 등 증빙서류를 구비해 병가를 신청한 경우 복무기관의 장이 질병의 종류나 사회복무요원의 건강

상태 등을 살펴 이를 허가할지 여부를 판단할 수 있다고 할 것입니다.

또한 대한민국 국민의 병역의무에 관하여 규정하고 있는 「병역법」에서 사회복무요원은 국가기관, 지방자치단체 등의 공익목적 수행에 필요한 사회복지, 보건·의료, 교육·문화 등의 사회서비스업무 및 행정업무 등의 지원을 위해 소집된 보충역의 일종으로 규정하고 있고(제2조, 제5조 및 제26조), 사회복무요원의 직무상 행위는 공무수행으로 보고 있으며(제31조제1항), 사회복무요원은 직무상 명령을 준수하고, 성실하게 그 직무를 수행하여야 한다고(제31조의4) 규정하고 있는 등 사회복무요원은 국가안보를 위한 병력 자원이자 병역의무를 이행하고 공무를 수행하는 사람으로서[18], 충실한 병역의무 이행을 통해 국민의 신뢰를 확보해야 할 필요가 있고[19], 사회복무요원의 건강하고 충실한 직무수행을 보장하기 위하여 병역법령에서 사회복무요원의 휴가 제도 등에 대한 허용 요건과 절차를 별도로 규정하고 있는 취지를 고려하면, 사회복무요원의 병가 신청에 대해 해당 복무기관의 장이 신청 내용과 사회복무요원의 건강 상태, 직무 수행 가능 여부 등을 고려하여 신청한 병가의 전부 또는 일부를 허가하지 않을 수도 있다고 보는 것이 병역법령의 취지에도 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 복무기관의 장은 「병역법 시행령」 제59조제1항에 따라 사회복무요원이 신청한 병가의 전부 또는 일부를 허가하지 않을 수 있습니다.

관계법령

병역법

제31조(사회복무요원의 복무 및 보수 등) ① 사회복무요원을 배정받은 기관의 장은 복무분야를 지정하여 복무하게 하여야 하며, 그 복무에 필요한 사항은 이 법에서 정하는 사항을 제외하고는 대통령령으로 정한다. 이 경우 사회복무요원의 직무상 행위는 공무수행으로 본다.
② ~ ⑤ (생 략)

병역법 시행령

제59조(사회복무요원의 휴가) ① 복무기관의 장은 다음 각 호의 구분에 따라 사회복무요원에게 휴가를 허가할 수 있다.
1.·2. (생 략)

18) 헌법재판소 2016. 10. 27. 선고 2016헌마252 전원재판부 결정례 참조
19) 헌법재판소 2021. 6. 24. 선고 2018헌마526 전원재판부 결정례 참조

3. 병가
   가. 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 경우 해당 기간
   나. 공무 외의 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 경우 해당 기간
4.·5. (생 략)
② ~ ⑤ (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0740

민원인 – 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역 안의 기존 건축물을 「건축법」 제19조제3항에 따라 용도변경하려는 경우가 국방부장관 등과의 협의 대상인지 여부(「군사기지 및 군사시설 보호법」 제13조제1항제1호 등 관련)

01 질의요지

「군사기지 및 군사시설 보호법」(이하 "군사기지법"이라 함) 제13조제1항에서는 관계 행정기관의 장은 보호구역[20] 안에서 건축물의 신축·증축 또는 공작물의 설치와 건축물의 용도변경(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 관한 허가나 그 밖의 처분(이하 "허가등"이라 함)을 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 협의절차와 국방부장관이 정하는 협의기준에 따라 국방부장관 등[21]과 협의해야 한다고 규정하면서, 같은 항 단서에서 보호구역의 보호·관리 및 군사작전에 지장이 없는 범위 안에서 대통령령으로 정하는 사항은 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제13조제3항에서는 협의를 하지 않아도 되는 사항으로 「건축법」 제19조제2항에 따른 건축물의 용도변경(제8호) 등을 규정하면서, 군사기지법 시행령 제13조제3항에 단서를 두어 같은 항 제8호 등의 경우 통제보호구역과 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역 안에서는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는 한편,

「건축법」 제19조제3항 본문에서는 같은 조 제4항에 따른 시설군 중 같은 시설군 안에서 용도를 변경하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 "관할행정청"이라 함)에게 건축물대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다고 규정하고 있는바,

군사기지법에 따른 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역 안에서 기존 건축물을 「건축법」 제19조제3항 본문에 따라 용도변경(이하 "이 사안 용도변경"이라 함)하려는 경우가 군사기지법 제13조제1항에 따른 협의 대상에 해당하는지?

20) 군사기지 및 군사시설 보호구역을 말하며(군사기지법 제2조제6호 참조), 이하 같음.

21) 국방부장관, 관할부대장 또는 관리부대장을 말함

02 회답

이 사안 용도변경의 경우, 군사기지법 제13조제1항에 따른 협의 대상에 해당합니다.

03 이유

먼저 「건축법」 제19조제3항 본문에 따른 신청에 따라 관할행정청이 건축물대장 기재내용을 변경하는 행위가 군사기지법 제13조제1항제1호의 "건축물의 용도변경에 관한 허가등"에 해당하는지 살펴보면, 군사기지법에서는 "용도변경"의 의미나 범위에 관하여 별도의 규정을 두고 있지 않으나, 국방부장관 등과의 협의 대상에서 제외되는 행위를 규정한 군사기지법 제13조 단서 및 같은 법 시행령 제13조제3항제7호·제8호 등에서 "「건축법」"을 명시적으로 인용하고 있는 점 등에 비추어 보면, 군사기지법령에서의 용도변경은 특별한 사정이 없는 한 「건축법」에서 규정하고 있는 용어의 의미 및 적용 범위를 따라야 할 것인데[22], 「건축법」 제19조에서는 건축물의 "용도변경"에 관한 사항을 규정하면서, 같은 조 제3항에서 같은 시설군 안에서 건축물의 용도를 변경하려는 자의 신청에 관한 사항을 규정하고 있으므로, 군사기지법 제13조제1항제1호의 "건축물의 용도변경"에는 「건축법」 제19조제3항에 근거한 이 사안 용도변경도 포함된다고 볼 수 있고, 건축물대장에 기재된 건축물의 용도는 건축물의 소유권을 행사하기 위한 전제요건으로서 건축물 소유자의 실체적 권리관계에 밀접하게 관련되어 있는 점[23]을 고려하면, 건축물대장의 관할행정청이 「건축법」 제19조제3항에 따라 용도변경 신청을 받아 건축물대장 기재내용을 변경하는 행위는 군사기지법 제13조제1항제1호의 건축물의 용도변경에 관한 허가등에 해당한다고 할 것입니다.

다음으로 군사기지법 제13조제1항 단서에서는 보호구역의 보호·관리 및 군사작전에 지장이 없는 범위 안에서 대통령령으로 정하는 사항은 국방부장관 등과의 협의를 생략할 수 있도록 규정하고 있는바, 이 사안 용도변경이 국방부장관 등의 협의를 생략할 수 있는 대상 행위에 해당하는지를 살펴보면, 군사기지법 시행령 제13조제3항제8호 본문에서는 건축물의 용도변경과 관련하여 협의를 생략할 수 있는 대상으로 "「건축법」 제19조제2항에 따른 건축물의 용도변경"만을 규정하고 있을 뿐, 군사기지법 시행령 제13조제3항 및 그 밖의 군사기지법령에서 이 사안과 관련된 「건축법」 제19조제3항에 따른 건축물의 용도변경의

22) 법제처 2022. 11. 2. 회신 22-0844 해석례 참조
23) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007두7277 판결례 참조

경우는 협의를 생략할 수 있는 대상 행위로 명시적으로 규정하고 있지 않으므로, 이 사안 용도변경과 같이 같은 시설군 안에서 용도변경을 하려는 경우는 군사기지법 제13조제1항제1호의 적용 대상으로서 국방부장관 등과의 협의 대상 행위에 해당된다고 보는 것이 군사기지법령의 문언 및 체계에 부합한다고 볼 수 있습니다.

그리고 군사기지법 제13조에서 관계 행정기관의 장이 보호구역 안에서 건축물의 신축·증축 또는 용도변경 등에 관한 허가등을 할 때 국방부장관 등과 협의하도록 규정하고 있는 취지는 건축물이 보호구역에 무분별하게 건축되거나 사용되는 경우 군사기지 및 군사시설의 기능 보전과 원활한 군사활동·군사작전에 지장을 초래할 수 있으므로, 국방부장관 등으로 하여금 해당 건축행위 등이 군사기지 및 군사시설의 기능을 보전하거나 군사작전을 원활히 수행하는데 지장을 주는 행위인지를 사전에 검토할 수 있게 하여 보호구역 안에서의 행위를 상호 협의·조정할 수 있도록 하려는 것인 점[24], 군사기지법 제13조제1항 단서 및 같은 법 시행령 제13조제3항은 예외적으로 협의가 생략되는 대상 행위에 대하여 규정한 것이므로, 협의 제도의 규정 취지 등에 비추어 예외적으로 협의를 생략할 수 있는 사유에 관해서는 문언에 따라 엄격하고 제한적으로 해석하는 것이 타당하다는 점[25]에 비추어 볼 때, 같은 법 시행령 제13조제3항제8호 본문에 따른 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경에 해당하지 않는 이 사안 용도변경은 국방부장관 등과의 협의를 생략할 수 없다고 보는 것이 군사기지법령의 취지 등에도 부합합니다.

특히 군사기지법 시행령 제13조제3항 단서에서는 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역 안에서는 기존의 건축물·공작물의 개축·재축·대수선 등과 같이 같은 항 제1호·제2호·제7호 또는 제8호의 행위, 즉 「건축법」에 근거한 행위(이하 "건축행위등"이라 함)와 관련된 협의를 생략할 수 없도록 하여 그 협의 대상 범위에 대해 다른 보호구역에 비해 엄격한 기준을 적용하고 있는데, 이는 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역은 군사적 보호 필요성뿐만 아니라 주민의 생명 및 재산 보호 측면에서도 무분별한 건축행위등을 제한해야 할 필요성이 다른 보호구역에 비해 더 크다는 점을 고려해, 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역 안의 건축행위등과 관련한 허가등에 있어서는 관할행정청이 그 허가등을 하기 전에 국방부장관 등의 전문적·군사적 검토를 거치도록 하려는 취지라고 볼 수 있을 것인바, 군사기지법령에서 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역 안에서 특정 건축행위등에 관한 허가등에 대하여 협의를 생략할 수 있다고 볼 근거 규정이나 그렇게 보아야 할 특별한 사유도 없으므로, 이 사안 용도변경의 경우도 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역 안에서 이루어지는 건축행위등에 해당하는

24) 법제처 2010. 8. 3. 회신 10-0207 해석례 및 2016. 9. 7. 회신 16-0283 해석례 참조

25) 법제처 2009. 12. 31. 회신 09-0357 해석례 참조

이상, 군사기지법 제13조제1항에 따른 협의 대상으로 보아 국방부장관등으로 하여금 해당 용도변경이 보호구역 안의 군사시설의 기능 보전, 주변환경 및 지역주민의 안전에 미치는 영향 등을 사전에 충분히 검토할 수 있도록 보다 엄격히 해석할 필요가 있다고 할 것입니다.

따라서 이 사안 용도변경의 경우, 군사기지법 제13조제1항에 따른 협의 대상에 해당합니다.

법령정비 권고사항

통제보호구역이나 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역이 아닌 보호구역에서 「건축법」 제19조제3항에 따른 용도변경을 하려는 경우가 협의 생략이 가능한 행위에 포함될 필요가 없는지를 정책적으로 검토하여 필요하다면 이를 군사기지법령에 반영할 필요가 있습니다.

관계법령

군사기지 및 군사시설 보호법

제13조(행정기관의 처분에 관한 협의 등) ① 관계 행정기관의 장은 보호구역 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 관한 허가나 그 밖의 처분을 하려는 때에는 대통령령으로 정하는 협의절차와 국방부장관이 정하는 작전성 검토 등 협의기준에 따라 국방부장관 또는 관할부대장등과 협의하여야 한다. 국가기관 또는 지방자치단체가 다음 각 호에 해당하는 행위를 하려는 경우에도 이와 같다. 다만, 보호구역의 보호·관리 및 군사작전에 지장이 없는 범위 안에서 대통령령으로 정하는 사항은 그러하지 아니하다.

1. 건축물의 신축·증축 또는 공작물의 설치와 건축물의 용도변경
2. ~ 13. (생 략)

② ~ ⑪ (생 략)

군사기지 및 군사시설 보호법 시행령

제13조(행정기관의 처분에 관한 협의 등) ① 관계 행정기관의 장이 법 제13조제1항 또는 제2항에 해당하는 사항에 관한 허가나 그 밖의 처분(이하 "허가등"이라 한다)을 하거나 직접 그 행위를 하려는 때에는 중앙행정기관의 장은 국방부장관과, 그 밖의 행정기관의 장은 관할부대장등과 협의하여야 한다. 이 경우 협의절차 및 방법과 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역 안에서의 협의기준은 국방부령으로 정한다.

② (생 략)

③ 법 제13조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느

하나에 해당하는 사항을 말한다. 다만, 제1호, 제2호, 제7호 또는 제8호의 경우 통제보호구역과 폭발물 관련 군사시설이 있는 보호구역 안에서는 그러하지 아니하다.

1. ~ 7. (생 략)

8. 「건축법」 제19조제2항에 따른 건축물의 용도변경. 다만, 「건축법」 제19조제2항제1호에 따른 허가 대상인 건축물의 용도변경 중 같은 법 시행령 제14조제5항제2호라목에 따른 위험물저장 및 처리시설, 같은 항 제3호가목에 따른 방송통신시설 및 같은 호 나목에 따른 발전시설로의 용도변경은 제외한다.

건축법

제19조(용도변경) ① 건축물의 용도변경은 변경하려는 용도의 건축기준에 맞게 하여야 한다.

② 제22조에 따라 사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다.

1. 허가 대상: 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를 상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우
2. 신고 대상: 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군에 속하는 건축물의 용도를 하위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 큰 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

③ 제4항에 따른 시설군 중 같은 시설군 안에서 용도를 변경하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 건축물대장 기재내용의 변경을 신청하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 변경의 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 시설군은 다음 각 호와 같고 각 시설군에 속하는 건축물의 세부 용도는 대통령령으로 정한다.

1. 자동차 관련 시설군
2. 산업 등의 시설군
3. 전기통신시설군
4. 문화 및 집회시설군
5. 영업시설군
6. 교육 및 복지시설군
7. 근린생활시설군
8. 주거업무시설군
9. 그 밖의 시설군

⑤ ~ ⑦ (생 략)

제2절 국가보훈

질의제목 1 ▶ 안건번호 24-0214

민원인 – 교육기관이 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제25조제1항에 따라 교육지원 대상자에 대하여 면제하는 "그 밖의 학비"에 국가자격증 취득을 위한 실습비가 포함되는지 여부(「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제25조 등 관련)

01 질의요지

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」(이하 "국가유공자법"이라 함) 제22조제1항에서는 전상군경, 공상군경, 전몰군경, 순직군경등과 그 사람의 자녀 등 같은 항 각 호의 사람을 교육지원을 받을 수 있는 사람(이하 "교육지원 대상자"라고 함)으로 규정하고 있고, 같은 법 제22조의2제2호에서는 교육지원 대상자에게 교육지원을 실시하는 교육기관(이하 "교육기관"이라 함)의 하나로 「고등교육법」 제2조에 따른 대학[26] 및 그 밖에 이에 준하는 학교를 규정하고 있으며, 같은 법 제25조제1항에서는 교육기관은 교육지원 대상자에 대하여 교육에 필요한 수업료, 입학금 및 그 밖의 학비를 면제한다고 규정하고 있는바,

사립대학[27]이 졸업요건[28]으로 국가자격증의 취득을 요구하는 경우로서 교육지원 대상자가 해당 국가자격증 취득에 필요한 교육을 제공하는 기관으로 지정된 기관[29](이하 "지정교육기관"이라 함)에서 국가자격증의 취득에 필요한 실습을 하고, 지정교육기관이 해당 실습에 필요한 경비(이하 "필수경비"라 함)로 실습비를 부과하는 경우, 그 실습비(이하 "이 사안

26) 산업대학·교육대학·전문대학·원격대학 및 기술대학을 포함함

27) 「고등교육법」 제2조에 따른 대학으로서 「사립학교법」 제2조제1호에 따른 사립학교에 해당하는 학교법인을 말하며, 이하 같음

28) 해당 사립대학의 학칙으로 규정된 경우를 전제함

29) 해당 국가자격증에 관하여 규율하는 법령에 따라 그 국가자격증 취득에 필요한 교육·실습을 제공하는 기관으로 소관부처의 장이 지정한 기관(「항공안전법」 제48조에 따른 전문교육기관 등)을 말함

실습비"라고 함)가 국가유공자법 제25조제1항에 따라 교육기관이 교육지원 대상자에 대하여 면제하는 "그 밖의 학비"에 포함되는지?

02 회답

이 사안 실습비는 국가유공자법 제25조제1항에 따라 교육기관이 교육지원 대상자에 대하여 면제하는 "그 밖의 학비"에 포함되지 않습니다.

03 이유

국가유공자법 제25조제1항에서는 교육기관은 교육지원 대상자에 대하여 교육에 필요한 수업료, 입학금 및 그 밖의 학비(이하 "수업료등"이라 함)를 면제한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제42조제1항에서는 같은 법 제25조제1항에 따른 수업료등에 입학금과 중학교·고등학교의 학교운영지원비를 포함한다고 규정하고 있으나, 국가유공자법 제25조제1항에 따라 교육기관이 교육지원 대상자에게 면제하는 "그 밖의 학비"의 범위에 대해서는 국가유공자법령에서 구체적으로 규정하고 있지 않은바, 이 사안 실습비가 "그 밖의 학비"에 포함되는지에 대해서는 법령의 규정 내용 및 입법 연혁, 입법 취지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 할 것입니다.

먼저 국가유공자법 제25조제1항의 문언을 살펴보면 교육기관은 교육지원 대상자에 대하여 교육에 필요한 "수업료, 입학금 및 그 밖의 학비"를 면제한다고 규정하고 있는데, 법령문에서 "및"은 문장에서 같은 종류의 성분을 연결할 때 쓰는 말로서[30], 국가유공자법 제25조제1항의 "그 밖의 학비"는 그 앞에 열거된 '수업료', '입학금'과 비슷한 성격의 것으로서 해당 교육에 직접적으로 소요되는 필수적인 비용으로 보아야 할 것이고, 특히 같은 법 시행령 제42조제1항에서 수업료등에는 입학금과 중학교·고등학교의 학교운영지원비를 포함한다고 규정하고 있어 수업료등에 포함되는 비용의 종류를 구체적으로 열거하고 있는 점을 고려하면, "이 사안 실습비"를 수업료등에 포함한다는 별도의 규정 없이 "그 밖의 학비"에 포함된다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

30) 국립국어원 표준국어대사전 참조

그리고 국가유공자법 제22조의2 각 호에서는 교육지원 대상자에게 교육지원을 실시하는 교육기관으로 「초·중등교육법」 제2조에 따른 중학교, 고등학교 및 그 밖에 이에 준하는 학교(제1호), 「고등교육법」 제2조에 따른 대학 및 그 밖에 이에 준하는 학교(제2호) 등을 규정하고 있고, 같은 법 제25조제1항에서는 "교육기관"은 교육지원 대상자에 대하여 교육에 필요한 수업료등을 면제한다고 규정하고 있는데, "면제"란 통상적으로 책임이나 의무 따위를 면하여 준다는 뜻[31]이고, 같은 규정에서는 그 면제의 주체를 "교육기관"으로 규정하고 있는바, 국가유공자법 제25조제1항에 따라 교육지원 대상자에게 부과하는 교육 관련 비용을 면제하는 주체는 "교육기관"만 해당된다고 할 것이고, 이 사안 실습비와 같이 지정교육기관에서 부과하는 필수경비는 "교육기관"인 사립대학이 부과하는 것이 아니므로 국가유공자법 제25조제1항에 따라 교육기관이 교육지원 대상자에게 면제하는 "그 밖의 학비"에 포함된다고 볼 수 없습니다.

또한 국가유공자법 제25조의 입법연혁을 살펴보면, 1984년 8월 2일 법률 제3742호로 제정된 국가유공자법 제25조에서는 교육보호대상자의 교육에 필요한 입학금, 수업료 '기타 학비'는 대통령령이 정하는 바에 따라 면제한다고 규정하였고, 1984년 12월 31일 대통령령 제11613호로 제정된 국가유공자법 시행령 제42조에서는 교육보호대상자가 입학금·수업료 및 '기성회비'를 면제받고자 할 때에는 교육보호대상자증명서를 당해 학교의 장에게 제출하여야 한다고 규정하였는바, 교육기관이 교육지원 대상자에게 면제하는 '기타 학비[32]'는 이 법 제정 당시부터 '기성회비'와 같이 교육기관에서 교육지원 대상자에게 부과할 수 있는 것으로 한정하여 규정되어 온 연혁을 고려하면, 국가유공자법 제25조제1항에 따른 면제 대상 수업료등의 하나인 "그 밖의 학비"의 범위를 합리적인 이유 없이 이 사안 실습비와 같이 교육기관이 아닌 기관에서 부과하는 비용까지 포함하는 것으로 확대 해석할 수는 없다고 할 것입니다.

따라서 이 사안 실습비는 국가유공자법 제25조제1항에 따라 교육기관이 교육지원 대상자에 대하여 면제하는 "그 밖의 학비"에 포함되지 않습니다.

31) 국립국어원 표준국어대사전 참조

32) 2002. 1. 26. 법률 제6648호로 일부개정된 국가유공자법에서 제25조의 '기타 학비'를 '그 밖의 학비'로 개정함

관계법령

국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률

제22조(교육지원 대상자 등) ① 교육지원을 받을 수 있는 사람(이하 "교육지원 대상자"라 한다)은 다음 각 호와 같다.

1. 전상군경, 공상군경, 무공수훈자, 보국수훈자, 재일학도의용군인, 4·19혁명부상자, 4·19혁명공로자, 공상공무원, 특별공로상이자 및 특별공로자
2. 전몰군경, 순직군경, 4·19혁명사망자, 순직공무원 및 특별공로순직자의 배우자
3. 제1호에 해당하는 사람의 자녀
4. 전몰군경, 순직군경, 4·19혁명사망자, 순직공무원, 특별공로순직자의 자녀, 미성년 제매 및 제1호에 해당하는 사람이 사망한 경우의 그 미성년 제매

② ~ ④ (생 략)

제22조의2(교육기관) 교육지원 대상자에게 교육지원을 실시하는 교육기관은 다음 각 호와 같다.

1. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 중학교, 고등학교 및 그 밖에 이에 준하는 학교. 다만, 같은 법 제60조의2에 따른 외국인학교는 제외한다.
2. 「고등교육법」 제2조에 따른 대학(산업대학·교육대학·전문대학·원격대학 및 기술대학을 포함한다. 이하 "대학"이라 한다) 및 그 밖에 이에 준하는 학교. 다만, 같은 법 제29조의2의 대학원과 같은 법 제30조의 대학원대학은 제외한다.
3. 「평생교육법」에 따라 학력이 인정되는 평생교육시설
4. 「학점인정 등에 관한 법률」에 따라 평가인정을 받은 학습과정을 운영하는 교육훈련기관

제25조(수업료등의 면제 등) ① 교육기관은 교육지원 대상자에 대하여 교육에 필요한 수업료, 입학금 및 그 밖의 학비(이하 "수업료등"이라 한다)를 면제한다.

② (생 략)

③ 사립인 대학등이 제22조제1항제3호 또는 제4호에 해당하는 교육지원 대상자에 대하여 제1항과 제2항에 따라 수업료등을 면제한 경우 국가는 그 면제금액의 절반을 보조한다.

④ 국가는 교육지원 대상자가 국가유공자, 그 유족 또는 가족으로 등록을 신청한 후 제2항에 따라 수업료등의 면제를 받기 전까지 실제로 부담한 수업료등에 해당하는 금액을 지원할 수 있다. 다만, 다른 법령에 따라 수업료등에 해당하는 금액을 국고보조(國庫補助) 받는 등 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 그에 해당하는 금액은 지원하지 아니한다.

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 교육지원 대상자에게 수업료등을 면제하거나 지원하는 연한(年限), 기준 및 교육지원을 하는 교육기관에 대한 보조 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령

제42조(수업료등의 면제 및 절차 등) ① 법 제22조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 법 제22조의2 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육기관에 재학 중인 경우에는 법 제25조제1항에 따른 수업료등(입학금과 중학교·고등학교의 학교운영지원비를 포함한다. 이하 같다)의 면제를 받는다.

② ~ ⑧ (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 24-0561

민원인 – 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」의 적용 대상에서 제외된 후 다시 적용 대상으로 결정된 사람이 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」의 적용 대상자로 결정되기 위한 절차(「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제79조제3항 등 관련)

01 질의요지

고엽제후유의증환자[33]가 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」(이하 "고엽제법"이라 함) 제28조제1항 각 호의 어느 하나(이하 "고엽제법 적용 제외사유"라 함)에 해당하여 고엽제법의 적용 대상에서 제외[34]된 후, 같은 조 제3항 및 제4항에 따라 보훈심사위원회[35]의 의결(이하 "고엽제법 재등록심사"라 함)을 거쳐 다시 고엽제법의 적용 대상자로 결정(이하 "고엽제법 재등록결정"이라 함)되었고, 이후 같은 법에 따른 고엽제후유증환자[36]에 해당하게 된 자(이하 "이 사안 고엽제후유증환자"라 함)가 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」(이하 "국가유공자법"이라 함) 제6조의4제1항에 따른 상이등급에 해당하는 것으로 판정되어 국가유공자법 제79조제4항에 따라 국가유공자법의 적용 대상자로 결정받으려는 경우[37], 고엽제법의 적용 대상에서 제외된 사유와 동일한 사유에 대하여 고엽제법 재등록심사와 별도로 국가유공자법 제79조제3항 및 제4항에 따른 재등록심사(이하 "국가유공자법 재등록심사"라 함)[38]를 받아야 하는지?

33) 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 고엽제후유의증환자를 말하며, 이하 같음

34) 고엽제법 제28조제1항제2호에 해당하여 고엽제법 적용 대상에서 제외된 경우가 아닌 것을 전제함

35) 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제74조의5에 따른 보훈심사위원회를 말하며, 이하 "보훈심사위원회"라 함

36) 고엽제법 제2조제2호에 따른 고엽제후유증환자를 말하며, 이하 같음

37) 고엽제법에 따른 재등록심사와 국가유공자법에 따른 재등록심사를 동시에 하지 않는 경우로서 고엽제법에 따른 재등록심사 이후 별도의 법 적용 제외사유가 발생하지 않은 경우를 전제함

38) 국가유공자법 제79조제3항에 따라 국가유공자법의 적용 대상에서 제외된 사람이 뉘우친 정도가 현저한지 여부에 대하여 같은 조 제4항에 따라 심사위원회에서 의결하는 것을 말함.

02 회답

이 사안의 경우, 고엽제법의 적용 대상에서 제외된 사유와 동일한 사유에 대하여 고엽제법 재등록심사와 별도로 국가유공자법 재등록심사를 받아야 합니다.

03 이유

고엽제법 제28조제1항에서는 국가보훈부장관은 고엽제법을 적용받거나 적용받을 고엽제 후유의증환자가 고엽제법 적용 제외사유에 해당하면 고엽제법의 적용 대상에서 제외하고 고엽제법에 따라 그가 받을 수 있는 모든 지원을 하지 아니한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제1항에 따라 고엽제법의 적용 대상에서 제외된 사람이 "금고 이상의 실형을 선고받은 경우에는 그 집행이 끝나거나[39] 집행이 면제된 날부터 3년이 지난 경우"(제1호) 또는 "고엽제법의 적용 대상에서 제외된 날부터 2년이 지난 경우"(제2호)에 해당하게 되면 그의 뉘우친 정도가 현저하다고 인정되는 경우만 같은 법 제4조에 따라 등록신청을 받아 고엽제법의 적용 대상으로 결정하여 지원을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서는 고엽제법 재등록결정을 할 때에는 고엽제법 재등록심사를 거친다고 규정하고 있습니다.

한편 국가유공자법 제79조제1항에서는 국가보훈부장관은 국가유공자법을 적용받고 있거나 적용받을 국가유공자가 같은 항 각 호의 어느 하나(이하 "국가유공자법 적용 제외사유"라 함)에 해당하면 국가유공자법의 적용 대상에서 제외한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문에서는 국가보훈부장관은 같은 조 제1항에 따라 국가유공자법의 적용 대상에서 제외된 사람이 "금고 이상의 형을 선고받은 경우에는 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 3년이 지난 경우"(제1호) 또는 "국가유공자법의 적용 대상에서 제외된 날부터 2년이 지난 경우"(제3호)에 해당하면 그 뉘우친 정도가 현저하다고 인정되는 경우에만 국가유공자법 제6조에 따라 등록신청을 받아 국가유공자법의 적용 대상자로 결정하여 보상을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제79조제4항에서는 같은 조 제3항에 따라 국가유공자법의 적용 대상에서 제외된 자를 국가유공자법의 적용 대상자로 결정(이하 "국가유공자법 재등록결정"이라 함)할 때에는 보훈심사위원회의 의결을 거친다고 규정하고

39) 집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함함.

있는바, 이 사안 고엽제후유증환자가 고엽제법의 적용 대상에서 제외된 사유에 대하여 고엽제법 재등록심사를 거쳐 고엽제법 재등록결정이 된 경우, 고엽제법의 적용 대상에서 제외된 사유와 동일한 사유에 대하여 국가유공자법 재등록결정을 위하여 국가유공자법 재등록심사를 거쳐야 하는지 여부가 문제됩니다.

먼저 고엽제법 제6조제1항에서는 고엽제후유증환자로 결정·등록된 사람 중 그 장애정도가 국가보훈부장관이 실시하는 신체검사에서 상이등급에 해당하는 것으로 판정된 사람은 전상군경[40] 등으로 보고 국가유공자법으로 정하는 바에 따라 보상을 한다고 규정하고 있는바, 이 사안 고엽제후유증환자가 국가유공자법에 따른 보상을 받기 위해서는 국가유공자 법에서 그 보상을 받기 위하여 정하고 있는 절차와 요건을 충족하여야 할 것인데, 국가유공자법 제6조에 따르면 전상군경 등 국가유공자가 되려는 사람은 국가보훈부장관에게 등록을 신청해야 하고(제1항), 국가보훈부장관은 등록신청에 대하여 보훈심사위원회의 심의·의결을 거쳐 등록결정을 해야하며(제3항·제4항), 같은 법 제79조에서는 국가유공자법을 적용받고 있거나 적용받을 국가유공자가 국가유공자법 적용 제외사유에 해당하면 같은 법의 적용 대상에서 제외하고 국가유공자법 재등록심사를 거쳐 재등록결정을 하도록 하여 별도의 절차를 규정하고 있고, 고엽제법에 따라 재등록심사를 거친 경우에 국가유공자법에 따른 재등록심사까지 거친 것으로 본다는 규정도 따로 두고 있지 않으므로, 이 사안 고엽제후유증환자가 국가유공자법에 따라 전상군경 등에 해당하게 된 경우에도 국가유공자법 제79조에 따라 별도의 국가유공자법 재등록심사를 거친 경우에만 재등록결정을 할 수 있다고 할 것입니다.

그리고 재등록심사를 둔 취지는 법 적용 대상자가 비난가능성이 큰 범죄를 저지른 경우 해당 법의 적용 대상에서 배제해야 하나, 법 적용 대상자로서의 자격을 박탈하는 것이 아니고 해당 법의 적용대상에서 일시적으로 배제되도록 하려는 것인데[41], 고엽제법 재등록심사를 통해 일정 기간이 지난 후 뉘우침의 정도가 현저하다는 등의 요건을 충족하면 절차를 거쳐 고엽제법의 적용 대상자가 될 수 있는 것이고, 그 '뉘우침의 정도'에 관한 판단은 고엽제법 재등록심사 및 재등록결정 시점의 제반 사정에 비추어 결정된 것인 반면, 이 사안 고엽제후유증환자가 국가유공자법의 적용 대상자로 결정받으려는 경우, 그 뉘우친 정도에 대한 판단은 국가유공자법 재등록심사 및 재등록결정 시점의 기준과 사정에 따라 이루어져야 할 것이고, 고엽제법 재등록결정 이후 그 뉘우친 정도에 대한 판단에 영향을 미칠 수 있는 새로운 사정이 발생하는 등 국가유공자법 재등록심사의 결과가 달라질 가능성도 있는 점을 고려하면,

40) 국가유공자법 제4조제1항제4호에 따른 전상군경을 말하며(고엽제법 제6조제1항 참조), 이하 같음.

41) 1984. 6. 29. 의안번호 110648호로 발의된 국가유공자예우등에관한법률안 국회 보건사회위원회 심사보고서 참조

고엽제법에 따라 재등록결정이 된 사람이 국가유공자법의 적용 대상자로 결정되기 위해서는 국가유공자법에 따라 별도의 재등록심사를 받아야 한다고 해석하는 것이 타당합니다.

아울러 고엽제법과 국가유공자법에 따른 적용 대상자로 신규등록하려는 경우에는 신규등록에 대한 심사를 개별 법령에 따라 각각 거쳐야 한다는 점, 국가유공자의 경우 그 유족 또는 가족도 국가유공자법 제5조제1항 및 같은 법 제6조제1항에 따른 등록 대상으로 규정하여 보상금의 지급 대상이 될 수 있는 반면 고엽제법에서는 고엽제후유의증환자의 유족 또는 가족은 별도의 등록 대상으로 규정하고 있지 않아 보상금의 지급 대상이 될 수 없고, 국가유공자법에서는 각종 수당 외에도 사망일시금의 지급(제17조), 주택의 우선공급(제68조) 등의 지원제도를 규정하고 있는 반면 고엽제법에서는 그러한 지원 제도를 두고 있지 않는 등 국가유공자법과 고엽제법은 그 지원 대상과 내용이 서로 다르다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 고엽제법의 적용 대상에서 제외된 사유와 동일한 사유에 대하여 고엽제법 재등록심사와 별도로 국가유공자법 재등록심사를 받아야 합니다.

관계법령

고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. (생 략)
2. "고엽제후유증환자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
   가. 1964년 7월 18일부터 1973년 3월 23일 사이에 월남전에 참전하여 고엽제 살포지역에서 「병역법」, 「군인사법」 또는 「군무원인사법」에 따른 군인이나 군무원으로서 복무하고 전역(轉役)·퇴직한 자와 정부의 승인을 받아 전투나 군의 작전에 종군(從軍)한 기자(이하 "월남전에 참전하고 전역한 자등"이라 한다)로서 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 질병을 얻은 자
   나. 1967년 10월 9일부터 1972년 1월 31일 사이에 남방한계선 인접지역에서 「병역법」, 「군인사법」 또는 「군무원인사법」에 따른 군인이나 군무원으로서 복무하였거나 고엽제 살포업무에 참가하고 전역·퇴직한 자(이하 "남방한계선 인접지역에서 복무하고 전역한 자등"이라 한다)로서 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 질병을 얻은 자
3. "고엽제후유의증환자"란 월남전에 참전하고 전역한 자등 또는 남방한계선 인접지역에서 복무하고 전역한 자등으로서 제5조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 질병을 얻은 자를 말한다.

제6조(고엽제후유증환자에 대한 보상 등) ① 제4조 및 제7조제5항에 따라 고엽제후유증환자로 결정·등록된 사람 중 그 장애정도가 국가보훈부장관이 실시하는 신체검사에서 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4제1항에 따른 상이등급(이하 "상이등급"이라 한다)에 해당하는 것으로 판정된 사람으로서 월남전에 참전하고 전역한 자등은 같은 법 제4조제1항제4호에 따른 전상군경으로, 남방한계선 인접지역에서 복무하고 전역한 자등은 같은 법 제4조제1항제6호에 따른 공상군경으로 보고 같은 법으로 정하는 바에 따라 보상을 한다.

② ~ ④ (생 략)

제28조(이 법 적용 대상으로부터의 배제) ① 국가보훈부장관은 이 법을 적용받거나 적용받을 고엽제후유의증환자 및 고엽제후유증 2세환자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 이 법의 적용 대상에서 제외하고 이 법에 따라 그가 받을 수 있는 모든 지원(제7조의5 및 제7조의9에 따라 그의 배우자 또는 자녀가 받을 수 있는 지원을 포함한다)을 하지 아니한다.

1. ~ 5. (생 략)

② (생 략)

③ 국가보훈부장관은 제1항에 따라 이 법의 적용 대상에서 제외된 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그의 뉘우친 정도가 현저하다고 인정되는 경우만 제4조에 따라 등록신청을 받아 이 법의 적용 대상으로 결정하여 지원을 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 금고 이상의 형을 선고받은 경우에는 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 3년이 지난 경우
2. 제1호 외의 경우에는 이 법의 적용 대상에서 제외된 날부터 2년이 지난 경우

④ 국가보훈부장관은 제1항제5호에 해당하는 사유로 이 법의 적용 대상에서 제외하거나 제3항에 따라 이 법의 적용 대상에서 제외된 자를 이 법의 적용 대상자로 결정할 때에는 보훈심사위원회의 의결을 거쳐야 한다.

⑤·⑥ (생 략)

국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률

제6조(등록 및 결정) ① 국가유공자, 그 유족 또는 가족이 되려는 사람(이하 이 조에서 "신청 대상자"라 한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가보훈부장관에게 등록을 신청하여야 한다. 다만, 신청 대상자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가보훈부 소속 공무원이 신청 대상자의 동의를 받아 등록을 신청할 수 있고, 그 동의를 받은 경우에는 신청 대상자가 등록을 신청한 것으로 본다.

1. 「국가보훈 기본법」 제23조제1항제3호의2에 따라 발굴된 희생·공헌자의 경우
2. 전투 또는 이에 준하는 직무수행 중 상이를 입거나 사망한 경우
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 직접 등록을 신청할 수 없는 경우

② 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 등록을 신청하는 사람에 대하여는 그 등록신청을 한 날에 제1항에 따른 등록을 신청한 것으로 본다.

③ 국가보훈부장관은 제1항에 따른 등록신청을 받으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 제4조 또는 제5조에 따른 요건을 확인한 후 국가유공자, 그 유족 또는 가족에 해당하는지를 결정한다. 이 경우 제4조제1항제3호부터 제6호까지, 제8호, 제14호 및 제15호의 국가유공자(이하 "전몰군경등"이라 한다)가 되기 위하여 등록을 신청하는 경우에는 그 소속하였던 기관의 장에게 그 요건과 관련된 사실의 확인을 요청하여야 하며, 그 소속하였던 기관의 장은 관련 사실을 조사한 후 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 요건과 관련된 사실을 확인하여 국가보훈부장관에게 통보하여야 한다.

④ 국가보훈부장관은 제3항 전단에 따라 국가유공자, 그 유족 또는 가족에 해당하는 사람으로 결정할 때에는 제74조의5에 따른 보훈심사위원회(이하 "보훈심사위원회"라 한다)의 심의·의결을 거쳐야 한다. 다만, 국가유공자, 그 유족 또는 가족의 요건이 객관적인 사실에 의하여 확인된 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 보훈심사위원회의 심의·의결을 거치지 아니할 수 있다.

⑤·⑥ (생 략)

제79조(이 법 적용 대상으로부터의 배제) ① 국가보훈부장관은 이 법을 적용받고 있거나 적용받을 국가유공자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 이 법의 적용 대상에서 제외하고 이 법 또는 다른 법률에 따라 국가유공자, 그 유족 또는 가족이 받을 수 있는 모든 보상을 하지 아니한다.

1. ~ 5. (생 략)

② (생 략)

③ 국가보훈부장관은 제1항에 따라 이 법의 적용 대상에서 제외된 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 되면 그 뉘우친 정도가 현저하다고 인정되는 경우에만 제6조에 따라 등록신청을 받아 이 법의 적용 대상자로 결정하여 보상을 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 금고 이상의 형을 선고받은 경우에는 그 집행이 끝나거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 날부터 3년이 지난 경우
2. 삭제
3. 제1호 외의 경우에는 이 법의 적용 대상에서 제외된 날부터 2년이 지난 경우

④ 국가보훈부장관은 제1항제5호에 해당하는 사유로 국가유공자, 그 유족 또는 가족을 이 법의 적용 대상에서 제외하거나 제3항에 따라 이 법의 적용 대상에서 제외된 자를 이 법의 적용 대상자로 결정할 때에는 보훈심사위원회의 의결을 거쳐야 한다.

⑤ ~ ⑦ (생 략)

CHAPTER

05

행정자치·인사·안전

제1절 행정일반·지방자치
제2절 공무원
제3절 경찰·소방·국민안전

제1절 행정일반·지방자치

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0747

민원인 – 소속기관장의 사적이해관계자 신고·회피신청 등을 받은 이해충돌방지담당관에게 「공직자의 이해충돌 방지법」 제7조에 따른 조치를 할 수 있는 권한이 부여되는지 여부(「공직자의 이해충돌 방지법」 제25조제2항 등 관련)

01 질의요지

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 "이해충돌방지법"이라 함) 제7조제1항에서는 같은 법 제5조제1항에 따른 신고·회피신청 또는 같은 법 제6조에 따른 부동산 보유·매수 신고를 받은 소속기관장[1]은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 직무수행의 일시 중지 명령(제1호) 등의 조치를 해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제7조제2항 전단에서는 소속기관장은 같은 조 제1항에도 불구하고 직무를 수행하는 공직자를 대체하기가 지극히 어려운 경우(제1호) 등에는 해당 공직자가 계속 그 직무를 수행하도록 할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

이해충돌방지법 제25조제2항에서는 같은 법에 따라 소속기관장에게 신고·신청·제출해야 하는 사람이 소속기관장 자신인 경우에는 해당 신고·신청·제출을 이해충돌방지담당관에게 해야 한다고 규정하고 있는바,

이해충돌방지담당관이 이해충돌방지법 제25조제2항에 따라 소속기관장의 사적이해관계자 신고 및 회피신청(같은 법 제5조제1항), 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고(같은 법 제6조제1항·제2항) 또는 직무관련자와의 거래 신고(같은 법 제9조제1항·제2항)(이하 "신고·회피신청"이라 함)를 받은 경우, 해당 소속기관장에 대하여 같은 법 제7조에 따른 조치를

1) 공직자가 소속된 공공기관의 장을 말하며(이해충돌방지법 제2조제7호 참조), 이하 같음.

할 수 있는 권한이 같은 법 제25조제2항에 따라 이해충돌방지담당관에게 직접 부여 되는지?[2)]

02 회답

이 사안의 경우, 해당 소속기관장에 대하여 같은 법 제7조에 따른 조치를 할 수 있는 권한이 같은 법 제25조제2항에 따라 이해충돌방지담당관에게 직접 부여되는 것은 아닙니다.

03 이유

이해충돌방지법 제25조제1항에서는 공공기관의 장은 소속 공직자 중에서 이해충돌방지담당관을 지정하도록 하고, 같은 항 각 호에서는 이해충돌방지담당관의 담당 업무를 공직자의 이해충돌 방지에 관한 내용의 교육·상담(제1호), 사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청, 부동산 보유·매수 신고 또는 직무관련자와의 거래에 관한 신고의 접수 및 관리(제2호), 같은 법에 따른 위반행위 신고·신청의 접수, 처리 및 내용의 조사(제6호) 등으로 구체적으로 열거하여 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 법에 따라 소속기관장이 신고·신청·제출해야 하는 경우에는 그 신고·신청·제출을 소속기관장 자신이 아닌 '이해충돌방지담당관'에게 하도록 규정하고 있는데, 같은 항에서는 그 신고·신청·제출을 받은 이해충돌방지담당관이 직접 같은 법 제7조에 따른 조치를 할 수 있는지에 관해서는 명시적인 규정을 두고 있지 않습니다.

그런데 이해충돌방지법 제7조제1항·제2항 및 제9조제3항에서는 같은 법 제7조에 따른 조치를 취할 수 있는 권한의 주체를 같은 법 신고·회피신청을 받은 '소속기관장'으로만 규정하고 있고, 이해충돌방지법령에서는 같은 법 제7조에 따른 소속기관장의 조치 권한을 이해충돌방지담당관에게 직접 부여하거나, 위임하는 근거를 별도로 마련해 두고 있지도 않으므로, 이 사안의 경우 이해충돌방지담당관에게 같은 법 제7조에 따른 조치를 할 권한이 부여된다고 해석할 수는 없습니다.

2) 이해충돌방지법 외에 다른 법령이나 공공기관의 규정 등에 따라 해당 조치 권한이 이해충돌방지담당관의 권한으로 규정되어 있거나, 이해충돌방지담당관에게 그 권한이 위임되는지 여부 및 이 사안에서 소속기관장이 이해충돌방지법에 따라 이해충돌방지담당관에게 신고·회피신청을 하는 경우가 「직무대리규정」상의 '사고'에 해당하여 부기관장에게 동 규정에 따른 직무대리를 하게 할 수 있는지 여부는 별론으로 함.

그리고 이해충돌방지법 제25조제2항에서 소속기관장이 신고·신청·제출을 해야하는 경우에는 해당 소속기관장이 아닌 '이해충돌방지담당관'에게 그 신고·신청·제출을 하도록 규정한 것은 소속기관장이 공직자로서 같은 법에 따른 신고·신청·제출을 해야 할 경우 이를 소속기관장인 자신에게 해야 하는 모순이 발생하는 문제를 해소하기 위한 규정으로서, 명문의 규정이 없음에도 불구하고 해당 규정에 따라 이해충돌방지담당관에게 해당 소속기관장의 권한에 속하는 조치를 할 수 있는 권한이 부여된다고 보는 것은 타당하지 않습니다.

아울러 이해충돌방지법 제25조제1항에서 공공기관의 장은 '소속 공직자' 중에서 이해충돌방지담당관을 지정해야 한다고 규정하고 있는바, 일반적으로 소속 공직자에 대해 임용권 및 지휘·감독에 관한 권한을 가지는 소속기관장에 대해 이해충돌방지담당관이 직무수행의 일시중지 명령(같은 법 제7조제1항제1호) 등의 조치를 취하는 것은 현실적으로 어려울 뿐 아니라,[3] 소속기관장에 대해서는 「정부조직법」, 「지방자치법」 등 관계 법령에 따라 지휘·감독 권한을 가진 상급기관이나 법령상의 견제 장치 등을 통해 이해충돌방지법 제7조에 따른 조치에 상응하는 별도의 조치가 이루어질 수 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 소속기관장에 대하여 같은 법 제7조에 따른 조치를 할 수 있는 권한이 이해충돌방지담당관에게 부여되는 것은 아닙니다.

관계법령

공직자의 이해충돌 방지법

제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① 제5조제1항에 따른 신고·회피신청이나 같은 조 제2항에 따른 기피신청 또는 제6조에 따른 부동산 보유·매수 신고를 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하여야 한다.

1. 직무수행의 일시 중지 명령
2. 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정
3. 직무 재배정
4. 전보

② 소속기관장은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 공직자가 계속 그 직무를 수행하도록 할 수 있다. 이 경우 제25조에 따른 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자로 하여금 공정한 직무수행 여부를 확인·점검하게 하여야 한다.

3) 2020. 11. 23. 의안번호 제2105661호로 발의된 공직자의 이해충돌 방지법안(대안반영폐기)에 대한 제386회 제1차 국회 정무위원회 심사보고서 참조

1. 직무를 수행하는 공직자를 대체하기가 지극히 어려운 경우
2. 국가의 안전보장 및 경제발전 등 공익 증진을 위하여 직무수행의 필요성이 더 큰 경우

③ ~ ⑤ (생 략)

제25조(이해충돌방지담당관의 지정) ① 공공기관의 장은 소속 공직자 중에서 다음 각 호의 업무를 담당하는 이해충돌방지담당관을 지정하여야 한다.

1. 공직자의 이해충돌 방지에 관한 내용의 교육·상담
2. 사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청, 부동산 보유·매수 신고 또는 직무관련자와의 거래에 관한 신고의 접수 및 관리
3. 사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청 또는 부동산 보유·매수 신고에도 불구하고 그 직무를 계속 수행하게 된 공직자의 공정한 직무수행 여부의 확인·점검
4. 고위공직자의 업무활동 내역 관리 및 공개
5. 퇴직자 사적 접촉 신고의 접수 및 관리
6. 이 법에 따른 위반행위 신고·신청의 접수, 처리 및 내용의 조사
7. 이 법에 따른 소속기관장의 위반행위를 발견한 경우 법원 또는 수사기관에 그 사실의 통보

② 이 법에 따라 소속기관장에게 신고·신청·제출하여야 하는 사람이 소속기관장 자신인 경우에는 해당 신고·신청·제출을 이해충돌방지담당관에게 하여야 한다.

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-0748, 24-0057

민원인 – 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조에 따른 신고·회피신청 또는 기피신청에 따라 해당 공직자의 직무수행이 당연히 중지되는지 여부(「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조 등 관련)

01 질의요지

「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 "이해충돌방지법"이라 함) 제5조제1항에서는 인가·허가·면허·특허·승인·검사·검정·시험·인증·확인, 지정·등록, 등재·인정·증명, 신고·심사, 보호·감호, 보상 또는 이에 준하는 직무(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자[4](이하 "공직자"라 함)는 직무관련자[5]가 사적이해관계자[6]임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 직무관련자 또는 공직자의 직무수행과 관련하여 직접적인 이해관계가 있는 자(이하 "직무관련자등"이라 함)는 해당 공직자에게 같은 조 제1항에 따른 신고 및 회피 의무가 있거나 그 밖에 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있는 사적 이해관계가 있다고 판단하는 경우에는 그 공직자의 소속기관장에게 기피를 신청할 수 있다고 규정하고 있는데,

공직자가 이해충돌방지법 제5조제1항에 따른 신고·회피신청(이하 "신고·회피신청"이라 함)을 하거나, 직무관련자등이 같은 조 제2항에 따른 기피신청(이하 "기피신청"이라 함)을 한 경우, 그 신고·회피신청 또는 기피신청에 따라 해당 공직자의 직무수행이 당연히 중지되는지?[7][8]

4) 이해충돌방지법 제2조제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말하며, 이하 같음.

5) 이해충돌방지법 제2조제5호에 해당하는 사람으로서 그 대리인을 포함하며, 이하 같음.

6) 이해충돌방지법 제2조제6호에 해당하는 자를 말하며, 이하 같음.

7) 이해충돌방지법령 외 다른 법령 등에 따라 해당 공직자의 직무수행이 중지되는지 여부는 별론으로 함.

8) ① 해당 공직자의 직무수행 중지가 다른 법령에 위반되지 않으며, ② 이해충돌방지법 제5조제3항 각 호에 해당하지 않는 경우를 전제로 함.

02 회답

이 사안의 경우, 신고·회피신청 또는 기피신청에 따라 해당 공직자의 직무수행이 당연히 중지되는 것은 아닙니다.

03 이유

우선 이해충돌방지법 제5조에서는 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 소속기관장에게 신고하고 회피를 신청해야 하고(제1항), 직무관련자등은 해당 공직자에게 신고 및 회피 의무가 있거나 그 밖에 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있는 사적 이해관계가 있다고 판단하는 경우에는 그 공직자의 소속기관장에게 기피를 신청할 수 있다(제2항)고 규정하고 있으며, 같은 법 제7조에서는 신고·회피신청 또는 기피신청을 받은 소속기관장은 '직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우'에 직무수행의 일시 중지 명령(제1항제1호), 직무대리자 또는 직무 공동수행자의 지정(제1항제2호) 등의 조치를 해야 하되, 신고·회피신청이나 기피신청을 받은 경우에도 직무를 수행하는 공직자를 대체하기가 지극히 어려운 경우(제2항제1호), 국가의 안전보장 및 경제발전 등 공익 증진을 위하여 직무수행의 필요성이 더 큰 경우(제2항제2호)에는 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자로 하여금 공정한 직무수행 여부를 확인·점검하게 하는 것을 요건으로 계속 그 직무를 수행하도록 할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 신고·회피신청 또는 기피신청이 있으면 그에 따라 해당 공직자의 직무수행이 중지된다는 규정을 두고 있지는 않습니다.

그리고 이해충돌방지법 제7조제5항의 위임에 따라 신고·회피신청이나 기피신청에 따른 소속기관장의 조치 등에 필요한 사항을 규정하고 있는 같은 법 시행령 제10조에서는 같은 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 조치는 소속기관장이 신고·회피신청 또는 기피신청을 받은 날부터 7일 이내에 해야 한다고 규정하면서(제1항), 소속기관장은 같은 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 조치를 할 때까지 해당 공직자에게 직무수행의 일시 중지를 명할 수 있다고 규정하고 있는데(제2항), 이러한 규정은 신고·회피신청 또는 기피신청이 있으면 그에 따라 해당 공직자의 직무 수행이 당연히 중지되지 않는다는 것을 전제로 하여 필요한 경우 소속기관장이 같은 법 제7조제1항 또는 제2항의 조치를 할 때까지 '직무수행 일시 중지 명령'을 할 수 있도록 한 것으로서, 이러한 법령체계에 비추어 보더라도 신고·회피신청 또는 기피신청이 있다는 그 자체로 해당 공직자의 직무수행이 당연히 중지된다고 보기는 어렵습니다.

또한 이해충돌방지법 제5조 및 제7조는 2021년 5월 18일 법률 제18191호로 같은 법을 제정할 당시 이해충돌 상황에서 공직자가 해당 직무에서 곧바로 제척되도록 할 경우 제척 사유의 설정 범위에 따라 의정활동 및 국가행정업무의 연속성을 저해할 수 있다는 우려 등을 감안하여 제척 제도 대신 구체적인 사안별로 신고·회피신청 또는 기피신청이 있는 경우 소속기관장이 '직무수행에 지장이 있는지 여부'를 판단하여 이해충돌 방지를 위한 직무수행의 일시중지, 직무대리자 등의 지정, 전보 등의 조치를 취하도록 규정한 것으로서[9], 이러한 이해충돌방지법령의 입법연혁 및 취지상으로도 같은 법 제7조에 따른 소속기관장의 조치 결정이 있기 전까지의 기간동안 공직자 또는 직무관련자등의 신고·회피신청 또는 기피신청에 따라 해당 공직자의 직무수행이 당연 중지되는 효과가 발생한다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 신고·회피신청 또는 기피신청에 따라 해당 공직자의 직무수행이 당연히 중지되는 것은 아닙니다.

관계법령

공직자의 이해충돌 방지법

제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

1. 인가·허가·면허·특허·승인·검사·검정·시험·인증·확인, 지정·등록, 등재·인정·증명, 신고·심사, 보호·감호, 보상 또는 이에 준하는 직무
2. ~ 16. (생 략)

② 직무관련자 또는 공직자의 직무수행과 관련하여 직접적인 이해관계가 있는 자는 해당 공직자에게 제1항에 따른 신고 및 회피 의무가 있거나 그 밖에 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있는 사적 이해관계가 있다고 판단하는 경우에는 그 공직자의 소속기관장에게 기피를 신청할 수 있다.

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다.

1. 제1항 각 호에 해당하는 직무와 관련하여 불특정다수를 대상으로 하는 법률이나 대통령령의 제정·개정 또는 폐지를 수반하는 경우

9) 2020. 11. 23. 의안번호 제2105661호로 발의된 공직자의 이해충돌 방지법안(대안반영폐기)에 대한 제386회 제1차 국회 정무위원회 심사보고서 참조

2. 특정한 사실 또는 법률관계에 관한 확인·증명을 신청하는 민원에 따라 해당 서류를 발급하는 경우

④·⑤ (생 략)

제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① 제5조제1항에 따른 신고·회피신청이나 같은 조 제2항에 따른 기피신청 또는 제6조에 따른 부동산 보유·매수 신고를 받은 소속기관장은 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하여야 한다.

1. 직무수행의 일시 중지 명령
2. 직무 대리자 또는 직무 공동수행자의 지정
3. 직무 재배정
4. 전보

② 소속기관장은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 공직자가 계속 그 직무를 수행하도록 할 수 있다. 이 경우 제25조에 따른 이해충돌방지담당관 또는 다른 공직자로 하여금 공정한 직무수행 여부를 확인·점검하게 하여야 한다.

1. 직무를 수행하는 공직자를 대체하기가 지극히 어려운 경우
2. 국가의 안전보장 및 경제발전 등 공익 증진을 위하여 직무수행의 필요성이 더 큰 경우

③ 소속기관장은 제1항 또는 제2항에 따른 조치를 하였을 때에는 그 처리 결과를 해당 공직자와 기피를 신청한 자에게 통보하여야 한다.

④ (생 략)

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 조치·확인·점검·통보, 신고·고발의 기록·관리 및 절차와 방법 등에 필요한 사항은 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정한다.

공직자의 이해충돌 방지법 시행령

제10조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치) ① 법 제7조제1항 또는 제2항에 따른 조치는 법 제5조제1항에 따른 신고·회피신청, 같은 조 제2항에 따른 기피신청이나 법 제6조에 따른 부동산 보유·매수 신고를 받은 날부터 7일 이내에 해야 한다.

② 소속기관장은 제1항에 따라 조치를 할 때까지 해당 공직자에게 직무수행의 일시 중지를 명할 수 있다.

③ ~ ⑤ (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 23-1005

전라남도 영광군 – 지방자치단체가 특별회계를 설치하려는 경우 조례에 존속기한을 명시하지 않을 수 있는 요건(「지방재정법」 제9조제3항 등 관련)

01 질의요지

「지방재정법」 제9조제3항에서는 지방자치단체가 특별회계를 설치하려면 5년 이내의 범위에서 특별회계의 존속기한을 해당 조례에 명시해야 한다고 규정(본문)하면서, "다만, 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계는 그러하지 아니하다"고 규정(단서)하고 있는 한편,

「의료급여법」 제25조제1항에서는 같은 법에 따른 급여비용의 재원에 충당하기 위하여 시·도[10]에 의료급여기금을 설치한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 이 법에서 정한 사항 외에 의료급여기금의 관리·운용에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제28조제1항에서는 시장·군수·구청장[11]은 의료급여사업에 충당하기 위하여 의료급여기금의 교부를 신청하고자 하는 때에는 시·도지사[12]에게 신청해야 한다고 규정하면서, 같은 조 제3항에서는 시장·군수·구청장은 '시·도지사로부터 교부받은 의료급여기금에 대하여는 일반회계와 구분하여 별도의 계정을 설정·운용해야 한다'고 규정하고 있는바,

「의료급여법 시행규칙」 제28조제1항 및 제3항에 따라 시장·군수·구청장이 시·도지사로부터 교부받은 의료급여기금을 일반회계와 구분하여 별도의 계정으로 설정·운용하기 위하여 설치하는 특별회계(이하 "이 사안 특별회계"라 함)가 「지방재정법」 제9조제3항 단서에 따른 "법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계"에 해당하여 시장·군수·구청장은 해당 특별회계의 존속기한을 조례에 명시하지 않아도 되는지?[13]

---

10) 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도를 말하며, 이하 같음.

11) 특별자치시장·특별자치도지사·시장(특별자치도의 행정시장은 제외함)·군수·구청장을 말하며, 이하 같음.

12) 특별시장·특별자치시장·광역시장·도지사·특별자치도지사를 말하며, 이하 같음.

13) 「의료급여법」 제25조 및 제26조에서는 "기금"의 설치 및 그 관리·운용에 관한 사항을 규정하고 있어 해당 규정을 특별회계가

02 회답

이 사안 특별회계는 「지방재정법」 제9조제3항 단서에 따른 “법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계”에 해당하지 않으므로, 시장·군수·구청장은 해당 특별회계의 존속기한을 조례에 명시해야 합니다.

03 이유

먼저 「지방재정법」은 지방자치단체의 재정에 관한 기본원칙을 정함으로써 지방재정의 건전하고 투명한 운용과 자율성을 보장함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제9조제3항 단서는 같은 항 본문에 따른 “지방자치단체가 설치하려는 특별회계는 5년 이내의 범위에서 특별회계의 존속기한을 해당 조례에 명시해야 한다”는 원칙에 대한 예외에 해당하므로, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있는[14] 한편, 같은 법 제9조제3항은 지방자치단체에 특별회계가 과도하게 설치될 경우 지방재정의 구조가 복잡해지고 재정관리의 효율성이 저하되는 문제가 발생할 수 있으므로, 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 예외적인 경우를 제외하고는 특별회계의 존속기한을 조례에 명시하도록 하여 지방자치단체가 특별회계를 남설하는 것을 방지하려는 데[15]에 그 취지가 있다는 점에 비추어 볼 때, 같은 항 단서의 적용 대상이 되는 특별회계의 범위는 해당 특별회계의 설치·운용 근거가 되는 규범이 ‘법률’이어야 하고, 그 규범의 내용이 해당 특별회계를 설치·운용하는 것을 의무 사항으로 명시적으로 규율하고 있는 경우로 제한적이고 엄격하게 해석할 필요가 있습니다.

그런데 「의료급여법」 제25조제1항에서는 같은 법에 따른 급여비용의 재원에 충당하기 위하여 ‘시·도’에 ‘의료급여기금’을 설치한다고 규정하여 그 문언상 해당 기금을 의무적으로 설치해야 하는 주체를 ‘시·도’로 규정하고 있고, 같은 법 제26조제1항에서는 이러한 기금을 일반회계와 구분하여 별도의 ‘계정을 설정하여 관리’해야 한다고 규정하고 있을 뿐 ‘시·군·구에

아닌 기금의 설치 근거로 보아 “기금” 또는 “기금에서 교부된 금액”이 「지방자치단체 기금관리기본법」의 적용 대상인지에 대해서도 해석의 여지가 있을 수 있으나, 현재 해당 규정들을 근거로 하여 시·도 및 시·군·구에서 ‘기금특별회계’를 설치하여 「지방재정법」 등의 특별회계 관련 규정을 적용하여 예산을 집행하고 있는 점 등을 고려하여 본 안건에서는 시장·군수·구청장이 설치하려는 이 사안 특별회계가 「지방재정법」 적용 대상임을 전제하고, 같은 법 제9조제3항 단서 해당 여부를 논의함.

14) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

15) 2013. 11. 15. 의안번호 제1907796호로 정부 발의된 지방재정법 일부개정법률안 국회 안전행정위원회 심사보고서 참조

특별회계를 의무적으로 설치·운용'하도록 하는 명시적인 규정을 두고 있지 않고 있으므로, 시·군·구가 조례로 설치·운용하는 이 사안 특별회계는 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계로 보기는 어렵습니다.

그리고 「의료급여법 시행규칙」 제28조제3항에서 시장·군수·구청장은 시·도지사로부터 교부받은 의료급여기금에 대하여는 일반회계와 구분하여 별도의 계정을 설정·운용해야 한다고 규정하고 있으나, 「의료급여법」 제26조제4항에서는 "같은 법에서 정한 사항 외에 의료급여기금의 '관리·운용'에 관하여 필요한 사항"을 보건복지부령으로 정하도록 위임하였는바, 부령으로 위임된 사항에 시·군·구 특별회계의 '설치'에 관한 사항이 포함된다고 보기 어렵고, 같은 규칙 제28조제3항에서는 시 · 도의 의료급여기금으로부터 교부받은 의료급여 기금을 '일반회계와 구분되는 별도의 계정으로 설정·운영'해야 한다고 규정하고 있을 뿐, 해당 기금에 대하여 반드시 시·군·구에 특별회계를 설치·운용하도록 강제한 것으로 보기도 어려운 점 등을 종합해 보면, 이 사안 특별회계는 「지방재정법」 제9조제3항 단서의 "법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계"에 해당한다고 볼 수 없으므로, 시·도지사로부터 교부받은 의료급여기금에 대하여 시장·군수·구청장이 이 사안 특별회계를 설치하려는 경우에는 같은 항 본문에 따라 해당 시·군·구의 조례에 그 존속기한을 명시해야 합니다.

따라서 이 사안 특별회계는 「지방재정법」 제9조제3항 단서에 따른 "법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계"에 해당하지 않으므로, 시장·군수·구청장은 해당 특별회계의 존속기한을 조례에 명시해야 합니다.

법령정비 권고사항

의료급여법령에 따라 지방자치단체에 설치되는 의료급여기금이 보다 합리적으로 관리·운용될 수 있도록 해당 시·군·구가 설치하는 의료급여기금의 성격 및 그 운용방식에 관한 사항 등을 검토하여 의료급여기금과 관련된 규정을 체계적이고 명확히 정비할 필요가 있습니다.

관계법령

지방재정법

제9조(회계의 구분) ①·② (생 략)

③ 지방자치단체가 특별회계를 설치하려면 5년 이내의 범위에서 특별회계의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 한다. 다만, 법률에 따라 의무적으로 설치·운용되는 특별회계는 그러하지 아니하다.

④ (생 략)

의료급여법

제25조(의료급여기금의 설치 및 조성) ① 이 법에 따른 급여비용의 재원에 충당하기 위하여 시·도에 의료급여기금(이하 "기금"이라 한다)을 설치한다.

② ~ ④ (생 략)

제26조(기금의 관리 및 운용) ① 기금은 일반회계와 구분하여 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 한다.

②·③ (생 략)

④ 이 법에서 정한 사항 외에 기금의 관리·운용에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

의료급여법 시행규칙

제28조(기금의 관리·운용) ① 시장·군수·구청장은 의료급여사업에 충당하기 위하여 기금의 교부를 신청하고자 하는 때에는 별지 제20호서식에 의하여 시·도지사에게 신청하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 신청을 받은 시·도지사는 시장·군수·구청장에게 기금을 교부한 경우 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 교부한 기금의 전부 또는 일부를 반환할 것을 명하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 기금을 목적외의 용도에 사용한 때
2. 법령 또는 시·도의 조례나 규칙에 의한 감독상의 명령을 이행하지 아니한 때
3. 기금운용상 증감조정이 필요한 때

③ 시장·군수·구청장은 시·도지사로부터 교부받은 기금에 대하여는 일반회계와 구분하여 별도의 계정(이하 "기금계정"이라 한다)을 설정·운용하여야 한다.

④ ~ ⑨ (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 23-1104, 23-1135, 24-0179, 24-0180, 24-0215, 24-0216

행정안전부·세종특별자치시·민원인 – 세종특별자치시에 대하여 「지방교부세법 시행규칙」 별표 2에 따라 측정항목별 표준행정수요액을 산정할 때 적용되는 산정방식(「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제8조제1항 및 「지방교부세법 시행규칙」 별표 2 등 관련)

01 질의요지

「지방교부세법」 제7조제1항에 따르면, 기준재정수요액[16]은 각 측정항목[17]별로 측정단위[18]의 수치를 해당 단위비용[19]에 곱하여 얻은 금액을 합산한 금액으로서, 같은 법 시행규칙 제4조제2항 및 별표 2에서는 단위비용을 산정하기 위해 필요한 측정항목별 표준행정수요액의 산정방식을 규정하고 있는데, 같은 표 제8호 및 제9호에서는 각각 측정항목에 해당하는 경비의 종류 중 '아동복지비' 및 '장애인복지비'(이하 "이 사안 경비"라 함)의 표준행정수요액 산정방식을 '시·도' 및 '시·군·구'로 구분하여 규정하고 있는 한편,

「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」(이하 "세종시법"이라 함) 제8조제1항에서는 "다른 법령에서 지방자치단체, 시·도 또는 시·군·구를 인용하고 있는 경우에는 각각 세종특별자치시를 포함하는 것으로 보아 해당 법령을 적용한다"고 규정하고 있는바,

「지방교부세법 시행규칙」 별표 2 제8호 및 제9호에 따라 세종특별자치시에 대한 이 사안 경비의 표준행정수요액을 산정하는 경우, 해당 호의 산정방식란 중 '시·도'의 산정방식과 '시·군·구'의 산정방식이 모두 적용·합산되는지?

16) 「지방교부세법」 제2조제3호에 따른 "기준재정수요액"으로서 각 지방자치단체의 재정수요를 합리적으로 측정하기 위하여 같은 법 제7조에 따라 산정한 금액을 말하며, 이하 같음.

17) 「지방교부세법」 제2조제5호에 따른 "측정항목"으로서 각 지방자치단체의 기준재정수요액을 합리적으로 측정하기 위하여 기능별·성질별로 분류하여 설정한 표준적 경비의 종류를 말하며, 이하 같음.

18) 「지방교부세법」 제2조제6호에 따른 "측정단위"로서, 기준재정수요액을 합리적으로 측정하기 위한 각 측정항목의 단위를 말하며, 이하 같음.

19) 「지방교부세법」 제2조제7호에 따른 "단위비용"으로서 기준재정수요액을 산정하기 위한 각 측정단위의 단위당 금액을 말하며, 이하 같음.

02 회답

「지방교부세법 시행규칙」 별표 2 제8호 및 제9호에 따라 세종특별자치시에 대한 이 사안 경비의 표준행정수요액을 산정하는 경우, '시·도'의 산정방식과 '시·군·구'의 산정방식이 모두 적용·합산되는 것은 아닙니다.

03 이유

「지방교부세법」 제2조제1호에서는 '지방교부세'를 같은 법 제4조에 따라 산정한 금액으로서 같은 법 제6조, 제9조, 제9조의3 및 제9조의4에 따라 국가가 재정적 결함이 있는 지방자치단체에 교부하는 금액을 말한다고 정의하고 있고, 같은 법 제6조제1항 본문에서는 보통교부세는 해마다 기준재정수입액이 기준재정수요액에 못 미치는 지방자치단체에 그 미달액을 기초로 교부한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제7조에서는 기준재정수요액은 각 측정항목별로 측정단위의 수치를 해당 단위비용에 곱하여 얻은 금액을 합산한 금액으로 한다고 규정(제1항)하면서, 단위비용은 대통령령으로 정하는 기준 이내에서 물가변동 등을 고려하여 행정안전부령으로 정한다고 규정(제2항)하고 있고, 같은 조 제2항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제4조제2항 및 별표 2에서는 단위비용을 산정하기 위한 측정항목별 표준행정수요액의 산정방식에 대하여 규정하고 있는 점을 종합해 보면, 같은 표의 '측정항목별 표준행정수요액'은 국가가 지방자치단체에 교부하는 지방교부세 중 '보통교부세'의 교부를 위해 필요한 정보인 측정항목별 '단위비용'을 산정하기 위한 지표에 해당합니다.

그런데 세종시법 제6조제1항 및 제2항에서는 정부의 직할(直轄)로 세종특별자치시를 설치하도록 하면서, 세종특별자치시의 관할구역에는 「지방자치법」 제2조제1항제2호에 해당하는 지방자치단체, 즉 시·군·구를 두지 아니하도록 규정하여 기존 지방자치단체의 유형인 '시·도' 또는 '시·군·구'에 해당하지 않는 '특별자치시'라는 새로운 유형의 지방자치단체를 도입하였는바, 이 사안에서는 세종특별자치시에 대한 이 사안 경비의 표준행정수요액을 산정할 때, 「지방교부세법 시행규칙」 별표 2 제8호 및 제9호의 산정방식란 중 '시·도' 및 '시·군·구'에 세종특별자치시가 각각 포함되는 것으로 보아 '시·도' 및 '시·군·구'의 표준행정수요액 산정방식을 모두 적용·합산해야 하는지 여부가 문제됩니다.

우선 세종시법 제8조제1항은 하나의 행정구역 안에서 시·도 및 시·군·구를 구분하는

지방자치제도를 전제로 하는 '다른 법령'을 세종특별자치시에 대하여 적용함에 있어 발생할 수 있는 법적 공백 보완 등을 위해 마련된 특례로, 특히 같은 항에서 '다른 법령에서 시·군·구를 인용하고 있는 경우'에도 세종특별자치시를 포함하도록 한 것은 세종특별자치시에 기초지방자치단체로서의 시·군·구가 없어 다른 법령에서 기초지방자치단체 소관 사무에 관하여 규정되어 있는 사항을 세종특별자치시에 적용할 수 없게 되는 문제를 방지하기 위한 것[20]이므로, 단순히 어느 특정 법령에서 '시·도' 또는 '시·군·구'를 인용하고 있다는 이유만으로 같은 규정이 일률적으로 적용된다고 할 수는 없고, 대상 법령의 인용방식과 구체적인 규정 내용 및 취지 등을 종합적으로 고려하여 그 적용 여부를 판단해야 할 것입니다.

그런데 「지방교부세법」 제2조제2호에서는 지방자치단체를 「지방자치법」 제2조제1항 및 제2항에 따른 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 및 시·군·자치구와 같은 법 제176조제1항에 따른 지방자치단체조합을 말한다고 규정하고 있고, 「지방교부세법 시행령」 제10조의4제1항에서는 소방안전교부세의 교부 대상을 특별시·광역시·'특별자치시'·도 및 특별자치도로 하면서, 해당 지방자치단체 유형을 '시·도'로 약칭하고 있는 등 지방교부세법령에서는 세종특별자치시를 기본적으로 「지방자치법」 제2조제1항제1호에 따른 특별시, 광역시, 도, 특별자치도와 함께 광역지방자치단체인 '시·도'로 분류하고 있는 것으로 보인다는 점, 「지방교부세법 시행규칙」 별표 2의 ω(비중유지계수)란에서는 '특별자치시'에 대한 비중유지계수를 각 측정항목별로 별도로 규정하고 있으며, 같은 표 제3호·제7호·제10호·제15호 및 제16호에서는 '특별자치시'에 대한 산정방식을 '시·도' 및 '시·군·구' 산정방식과 구분하여 규정하고 있는 등 표준행정수요액 산정과 관련하여 기초지방자치단체의 사무를 수행하는 '특별자치시'의 행정체계상 특수성을 반영한 규정[21]을 두면서도, '특별자치시'의 경우 '시·도' 및 '시·군·구' 산정방식을 모두 중첩하여 적용해야 한다거나 중첩 적용을 전제로 한 표준행정수요액 합산 방식 등에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 같은 표에서 측정항목별로 구분되어 있는 산정방식을 개별 지방자치단체에 적용할 때에는 각각의 지방자치단체별로 하나의 표준행정수요액 산정방식만이 적용된다고 보아야 할 것입니다.

그리고 세종시법 제14조제2항에서는 「지방교부세법」 제6조제1항에도 불구하고 행정안전부장관은 세종시법 제6조에 따른 행정체계의 특수성을 고려하여 2026년까지 세종특별자치시에 교부하는 보통교부세는 '대통령령으로 정하는 바'에 따라 매년 「지방교부세법」 제7조에 따른

20) 광주고등법원(제주재판부) 2010. 7. 7. 선고 2010누25 판결례(상고) 및 대법원 2010. 12. 23. 선고 2010두17021 판결례 참조

21) 2012. 12. 31. 행정안전부령 제331호로 일부개정되어 2013.. 1. 1. 시행된 지방교부세법 시행규칙 일부개정령안 조문별 제·개정이유서 참조

기준재정수요액과 같은 법 제8조에 따른 기준재정수입액의 차액과 그 차액의 100분의 25 이내의 금액을 더한 규모로 산정되도록 기준재정수요액을 보정할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「지방교부세법 시행령」 제7조의2에서는 세종특별자치시의 기준재정수요액을 보정할 때 기준재정수요액에 기준재정수요액과 기준재정수입액의 차액의 100분의 25에 해당하는 금액을 더하여 보정한다고 규정하고 있는 등 광역지방자치단체 및 기초지방자치단체의 사무를 모두 수행하고 있는 세종특별자치시에 대하여 합리적으로 보통교부세가 산정·교부될 수 있도록 별도의 특례를 두고 있는 점에 비추어 볼 때, 세종특별자치시에 대한 기준재정수요액을 보정하기 전 단계에서 이루어지는 이 사안 경비의 표준행정수요액 산정 시, 세종특별자치시의 경우에만 명시적인 근거 없가 없음에도 불구하고 시·도 및 시·군·구의 산정방식을 모두 적용·합산해야 한다고 해석하는 것은 지방교부세 법령의 전반적인 규정 체계에 비추어 허용되기 어렵습니다.

따라서 「지방교부세법 시행규칙」 별표 2 제8호 및 제9호에 따라 세종특별자치시에 대한 이 사안 경비의 표준행정수요액을 산정하는 경우, '시·도'의 산정방식과 '시·군·구'의 산정방식이 모두 적용·합산되는 것은 아닙니다.

관계법령

세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법

제8조(세종특별자치시의 설치에 따른 법령 적용상의 특례) ① 다른 법령에서 지방자치단체, 시·도 또는 시·군·구를 인용하고 있는 경우에는 각각 세종특별자치시를 포함하는 것으로 보아 해당 법령을 적용한다.

② ~ ⑧ (생 략)

지방교부세법 시행규칙

제4조(단위비용) ① 「지방교부세법」(이하 "법"이라 한다) 제7조제2항에 따른 단위비용은 별표 1과 같다.(생 략)

② 제1항의 단위비용을 산정하기 위한 측정항목별 표준행정수요액의 산정방식은 별표 2와 같다.

[별표 2]

측정항목별 표준행정수요액 산정방식(제4조제2항 관련)

경비의 종류	산정방식		ω(비중유지계수)
~ 7. (생 략)			
8. 아동복지비	시·도	lnYi = (1.76148 + 0.84519lnCh) + lnω	특별시(0.9524) 광역시(0.7221) 특별자치시(1.0458) 도·특별자치도(0.4841) 시(0.8810) 군(0.8204) 구(0.8259)
	시·군·구	lnYi = (3.34004 + 0.73462lnCh) + lnω	
	※ Ch: 아동 수		
9. 장애인복지비	시·도	lnYi = (1.3209 + 0.89777lnDp) + lnω	특별시(0.7972) 광역시(0.8234) 특별자치시(0.9734) 도·특별자치도(0.2513) 시(0.8279) 군(0.7933) 구(0.7727)
	시·군·구	Yi = (−196.28436 + 1.58583Dp) × ω	
	※ Dp: 등록장애인 수		
10. ~ 16. (생 략)			

질의제목 5 ▶ 안건번호 23-1177

민원인 – 「도시개발법」 제11조제1항제5호에 따른 도시개발사업의 시행자인 '도시개발구역의 토지 소유자'가 도시개발사업에 필요한 토지 등을 수용하거나 사용하는 경우 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제11조제1항제2호의 '공무수행사인'에 해당되는지 여부(「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제11조제1항제2호 등 관련)

01 질의요지

「도시개발법」 제11조제1항제5호에서는 도시개발사업의 시행자(이하 "시행자"라 함)로 지정될 수 있는 자의 하나로 "도시개발구역의 토지 소유자"를 규정하고 있고, 같은 법 제22조제1항 본문에서는 "시행자는 도시개발사업에 필요한 토지등[22]을 수용하거나 사용할 수 있다"고 규정하고 있는 한편,

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 "청탁금지법"이라 함) 제11조제1항제2호에서는 "법령에 따라 공공기관[23]의 권한을 위임·위탁받은 법인·단체 또는 그 기관이나 개인"(이하 "개인등"이라 함)을 "공무수행사인"으로 규정하고 있는바,

「도시개발법」 제11조제1항제5호에 따라 시행자로 지정된 도시개발구역의 토지 소유자(이하 "토지소유자인 시행자"라 함)가 같은 법 제22조제1항 본문에 따라 도시개발사업에 필요한 토지등을 수용하거나 사용하는 경우 해당 토지소유자인 시행자는 청탁금지법 제11조제1항제2호에 따른 공무수행사인(이하 "공무수행사인"이라 함)에 해당하는지?

02 회답

토지소유자인 시행자가 「도시개발법」 제22조제1항 본문에 따라 도시개발사업에 필요한 토지등을 수용하거나 사용하는 경우 해당 토지소유자인 시행자는 공무수행사인에 해당하지 않습니다.

---

22) 토지·건축물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권, 어업권, 양식업권, 물의 사용에 관한 권리를 말하며(「도시개발법」 제5조제1항제14호 참조), 이하 같음.

23) 청탁금지법 제2조제1호에 따른 "공공기관"을 말하며, 이하 같음.

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인바[24], 청탁금지법 제11조제1항제2호에서는 '법령에 따라 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 개인등'을 "공무수행사인"으로 규정하여, 법령에서 공공기관의 권한을 개인등에 위임 또는 위탁하고 있을 것을 공무수행사인의 요건으로 규정하고 있고, 이 때 '공공기관의 권한을 위임·위탁하는 법령'은 공공기관의 업무를 구체적으로 특정하여 개인등이 수행하도록 위임·위탁하는 내용의 법령을 의미한다고 해석해야 할 것[25]인데, 「도시개발법」 제22조제1항 본문에서는 "시행자는 도시개발사업에 필요한 토지등을 수용하거나 사용할 수 있다"고 규정하여 '토지소유자인 시행자'를 포함한 시행자에게 도시개발사업의 시행에 필요한 토지등을 수용하거나 사용할 수 있는 권한을 '직접 부여'하고 있을 뿐이고, 그 밖에 도시개발법령의 다른 규정에서도 토지등의 수용·사용권을 토지소유자인 시행자에게 위임·위탁하는 규정을 두고 있지 않은바, 이 사안의 '토지소유자인 시행자'가 '법령에 따라 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 개인등'에 해당하지 않는다는 점은 그 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 형벌법규의 해석은 엄격해야 하고 명문규정의 의미를 피고인에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하거나 유추 해석하는 것은 죄형법정주의의 원칙에 어긋나는 것으로서 허용되지 않으며, 이러한 법 해석의 원리는 그 형벌법규의 적용대상이 행정법규가 규정한 사항을 내용으로 하고 있는 경우에 그 행정법규의 규정을 해석하는 데에도 마찬가지로 적용되는데[26], 청탁금지법 제22조에서는 같은 법 제8조제1항 등을 위반한 공직자등에 대한 처벌 규정을 두면서, 같은 법 제11조에 따라 제8조제1항 등이 준용되는 공무수행사인도 공직자등과 같이 처벌 대상에 포함하여 규정하고 있는바, '토지소유자인 시행자'를 공무수행사인으로 보아 청탁금지법을 위반한 행위에 대해 벌칙을 부과할 수 있도록 하는 것은 문언의 범위를 벗어나 처벌 대상을 확대하는 것으로서[27] 타당하지 않습니다.

아울러 청탁금지법 제11조제1항제2호에서 '법령에 따라 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 개인등'을 공무수행사인으로 규정하여 그 공무 수행에 관하여 같은 법 제5조부터 제9조까지를 준용하도록 한 취지는 '법령에 따라 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 개인등'은

24) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
25) 법제처 2022. 9. 22. 회신 22-0322 해석례 참조
26) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90도1516 전원합의체 판결례 참조
27) 대법원 2018. 10. 25. 선고 2018도7041 판결례 참조

비록 공직자등에는 해당하지 않더라도 위임·위탁받은 권한의 행사와 관련한 공정성과 투명성 등을 확보할 필요가 있으므로 법령으로 위임·위탁받은 범위에서는 공직자등으로 보아 부정청탁이나 금품등의 수수에 대하여 청탁금지법에 따라 규율하려는 것인데, 「도시개발법」 제22조제2항에 따라 시행자의 토지등의 수용 또는 사용에 관하여 준용되는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제93조제1항에서는 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보상금을 받은 자 또는 그 사실을 알면서 보상금을 지급한 자는 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하는 규정을 두고 있는 등 '토지소유자인 시행자'가 토지등의 수용 또는 사용 과정에서 행하는 부정행위를 제재할 수 있는 수단이 별도로 마련되어 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 토지소유자인 시행자가 「도시개발법」 제22조제1항 본문에 따라 도시개발사업에 필요한 토지등을 수용하거나 사용하는 경우 해당 토지소유자인 시행자는 공무수행사인에 해당하지 않습니다.

법령정비 권고사항

토지소유자인 시행자를 공무수행사인에 포함하여 청탁금지법에 따라 규율할 필요는 없는지에 대하여 정책적으로 검토하고, 필요하다면 이를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률

제11조(공무수행사인의 공무 수행과 관련된 행위제한 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "공무수행사인"이라 한다)의 공무 수행에 관하여는 제5조부터 제9조까지를 준용한다.

1. (생 략)
2. 법령에 따라 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 법인·단체 또는 그 기관이나 개인
3.·4. (생 략)

② (생 략)

도시개발법

제11조(시행자 등) ① 도시개발사업의 시행자(이하 "시행자"라 한다)는 다음 각 호의 자 중에서

지정권자가 지정한다. 다만, 도시개발구역의 전부를 환지 방식으로 시행하는 경우에는 제5호의 토지 소유자나 제6호의 조합을 시행자로 지정한다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 도시개발구역의 토지 소유자(「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제28조에 따라 면허를 받은 자를 해당 공유수면을 소유한 자로 보고 그 공유수면을 토지로 보며, 제21조에 따른 수용 또는 사용 방식의 경우에는 도시개발구역의 국공유지를 제외한 토지면적의 3분의 2 이상을 소유한 자를 말한다)

6. ~ 9. (생 략)

9의2. (생 략)

10.·11. (생 략)

② ~ ⑪ (생 략)

제22조(토지등의 수용 또는 사용) ① 시행자는 도시개발사업에 필요한 토지등을 수용하거나 사용할 수 있다. 〈단서 생략〉

② 제1항에 따른 토지등의 수용 또는 사용에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

③·④ (생 략)

질의제목 6 ▶ 안건번호 23-1178

경기도 – 시·도지사가 관할 시·군에 배분하는 조정교부금의 재원을 확보할 때 고려되는 요소인 '인구 50만 이상의 시'의 인정기준(「지방재정법」 제29조제1항 등 관련)

01 질의요지

「지방재정법」 제29조제1항제1호에서는 시·도지사[28]는 시·군에서 징수하는 광역시세·도세[29]의 총액의 27퍼센트(인구 50만 이상의 시와 자치구가 아닌 구가 설치되어 있는 시의 경우에는 47퍼센트)에 해당하는 금액을 관할 시·군 간의 재정력 격차를 조정하기 위한 조정교부금의 재원으로 확보해야 한다고 규정하고 있는 한편,

「지방자치법」 제198조제1항에서는 서울특별시·광역시 및 특별자치시를 제외한 '인구 50만 이상 대도시'의 행정, 재정 운영 및 국가의 지도·감독에 대해서는 그 특성을 고려하여 관계 법률로 정하는 바에 따라 특례를 둘 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 '인구 50만 이상 대도시'의 인구 인정기준은 대통령령으로 정한다고 규정함에 따라 같은 법 시행령 제118조제1항에서는 '인구 50만 이상 대도시'의 인구 인정기준(이하 "이 사안 인구인정기준"이라 함)을 규정하고 있는바,

「지방재정법」 제29조제1항에 따른 "인구 50만 이상의 시"에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 시 인구수를 산정하는 경우, 「지방자치법」 제198조제3항 및 같은 법 시행령 제118조제1항에 따른 이 사안 인구인정기준에 따라야 하는지?

02 회답

「지방재정법」 제29조제1항에 따른 "인구 50만 이상의 시"에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 시 인구수를 산정하는 경우, 「지방자치법」 제198조제3항 및 같은 법 시행령 제118조제1항에 따른 이 사안 인구인정기준에 따라야 합니다.

---

28) 광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사를 말하며, 이하 같음.

29) 화력발전·원자력발전에 대한 지역자원시설세, 소방분 지역자원시설세 및 지방교육세는 제외하며, 이하 같음.

03 이유

먼저 지방재정법령에서는 「지방재정법」 제29조제1항에 따라 시·도지사가 시·군에서 징수하는 광역시세·도세의 총액 등 금액의 47퍼센트에 해당하는 금액을 조정교부금의 재원으로 확보해야 하는 "인구 50만 이상의 시"의 의미나 그 인구수 산정기준 등에 관하여 특별히 규정하고 있지 않은바, 법령 자체에 그 법령에서 사용하는 용어의 정의나 포섭의 구체적인 범위가 명확히 규정되어 있지 않은 경우 법령상 용어의 해석은 그 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 해당 조항의 규정 형식과 내용 및 다른 법령과의 관계를 종합적으로 고려하여 해석해야 할 것[30]입니다.

그런데 지방자치단체의 종류와 조직 및 운영, 주민의 지방자치행정 참여에 관한 사항과 국가와 지방자치단체 사이의 기본적인 관계를 규율[31]하고 있는 「지방자치법」에서는 국가와 지방자치단체는 지역 간 재정불균형을 해소하기 위하여 국가와 지방자치단체 간, '지방자치단체 상호 간에 적절한 재정 조정'을 하도록 노력해야 한다고 규정(제136조)하면서, "지방자치단체의 재정에 관하여 이 법에서 정한 것 외에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다"고 규정(제162조)하고 있는바, 「지방재정법」은 이에 따라 '지방자치단체의 재정'에 관한 기본원칙을 별도로 규정하고 있는 법률로서, 같은 법 제29조에서는 '기초지방자치단체 간의 적절한 재정조정'을 목적으로 하는 조정교부금에 관한 사항을 규정하고 있으므로, 이 사안과 같이 「지방재정법」에서 지방재정 운영과 관련된 지방자치단체의 인구수 산정기준을 별도로 규정하고 있지 않은 경우, 특별한 사정이 없는 한 같은 법과의 관계에 있어 일반법 또는 기본법의 지위에 있는 「지방자치법」의 관련 규정을 적용하는 것이 타당하다고 할 것입니다.

더욱이 「지방재정법」에 따른 시·군 조정교부금 제도는 시·도지사가 관할 시·군이 징수하는 광역시·도세의 일정 비율을 재정보전금으로 확보하고, 이를 일정한 기준에 따라 관할 시·군에 배분함으로써 관할 시·군의 재정균형과 안정적 재정운영을 도모[32]하기 위하여 2000년 1월 12일 법률 제6113호로 「지방재정법」을 일부개정하여 같은 법 제24조의2로 신설·도입되어 현행 「지방재정법」 제29조제1항까지 이어지고 있는 제도로서, 같은 항에서 조정교부금의 확보에 있어 '인구 50만 이상의 시'의 경우 인구 50만 미만의 다른 시·군과 차별화된 기준을 적용하고 있는 취지는 '인구 50만 이상의 시'는 광역지방자치단체가 처리하는 사무의 일부를

30) 대법원 2010. 6. 24. 선고 2010두3978 판결례 참조

31) 「지방자치법」 제1조 참조

32) 1999. 10. 11. 의안번호 152149호로 정부 발의된 지방재정법중개정법률안 국회 행정자치위원회 전문위원 검토보고서 참조

직접 처리할 수도 있는 등 그 행정사무 수행 범위가 넓고[33], 더 많은 인구수로 인해 관할구역 내 행정수요가 복잡·다변화되는 특성이 있는 것을 고려하여 조정교부금의 재원을 보다 충분히 확보하게 하려는 것이라는 점에 비추어 보면, 이는 「지방자치법」 제198조제1항에 따라 인구 50만 이상의 시의 재정 운영 등과 관련하여 관계 법률에 둘 수 있는 일종의 특례[34]로 볼 수 있으므로, 「지방재정법」 제29조제1항의 '인구 50만 이상의 시' 해당 여부를 판단할 때에도 「지방자치법」 제198조제1항에 따른 특례 적용 대상 지방자치단체를 구분하는 기준인 이 사안 인구인정기준에 따라야 한다고 보는 것이 그 입법취지 및 다른 법령과의 관계 등에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

또한 이 사안 인구인정기준을 정하고 있는 「지방자치법 시행령」 제118조제1항에서는 해당 지방자치단체의 '관할 구역에 주민등록이 되어 있는 사람'뿐만 아니라 '국내거소신고인 명부에 올라있는 외국국적동포'와 '외국인등록대장에 올라있는 외국인'의 수를 모두 합산하여 인구수를 산정하도록 규정하고 있는데, '국내에 거소를 둔 외국국적동포', '외국인등록대장에 올라 있는 외국인'은 해당 지방자치단체에 거소를 두거나 실제 생활을 영위하면서 등록면허세, 지방소비세 등 광역시세·도세를 직·간접적으로 납부하는 등 해당 지방자치단체의 재정수입에 실질적으로 기여하는 바가 있고, 이러한 주민을 대상으로 하는 기본적인 행정서비스도 예외 없이 충실히 제공될 필요성이 있다는 점에 비추어 볼 때, 「지방재정법」 제29조제1항에 따른 "인구 50만 이상의 시"에 해당하는지 여부를 판단하기 위한 인구수 산정 시 이 사안 인구인정기준을 적용하도록 하는 것이 인구 50만 이상의 시의 경우 많은 인구수로 인해 관할구역 내 행정수요가 복잡·다변화되는 특성이 있다는 점을 고려하여 다른 시·군보다 더 높은 재원 확보 비율을 규정함으로써 조정교부금의 재원을 보다 충분히 확보하도록 하려는 같은 규정의 취지에 반한다고 볼 수도 없습니다.

아울러 「지방재정법」 제29조제1항에서는 모든 시·도지사에게 의무적으로 관할 시·군 간의 재정력 격차를 조정하기 위한 조정교부금의 재원을 확보하도록 하면서, '인구 50만 이상의 시'에 해당하는지 여부에 따라 조정교부금의 재원으로 확보해야 하는 비율을 달리 정하고 있는바, '인구 50만 이상의 시'의 판단기준을 각 시·도마다 달리할 수 있다고 본다면, 특정 시가 어느 광역지방자치단체에 속해 있는지에 따라 적용되는 조정교부금 재원 확보비율이 달라지는 등 「지방재정법」에 따른 조정교부금의 재원 확보 기준이 전국적으로 통일적으로

33) 「지방자치법」 제14조제1항제2호 단서 등 참조

34) 2003. 9. 25. 의안번호 162673호로 의원 발의된 지방자치법 일부개정법률안 국회 행정자치위원회 심사보고서에 따르면, 인구 50만명 이상의 대도시에 관한 특례를 신설할 수 있는 일반적인 근거를 마련하려는 취지로 「지방자치법」 제175조(현행 제198조제1항)를 신설하면서, 기존 인구 50만 이상 대도시에 적용되는 특례의 대표적인 사례로 「지방재정법」 제29조에 따른 시·도 재정보전금 제도(현행 조정교부금 제도)를 언급하고 있음.

적용·집행되지 못하여 혼란과 갈등이 초래될 소지가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「지방재정법」 제29조제1항에 따른 "인구 50만 이상의 시"에 해당하는지 여부를 판단하기 위해 시 인구수를 산정하는 경우, 「지방자치법」 제198조제3항 및 같은 법 시행령 제118조제1항에 따른 이 사안 인구인정기준에 따라야 합니다.

법령정비 권고사항

「지방재정법」 제29조제1항에서의 '인구 50만 이상의 시'에 대해서는 「지방자치법」 제198조제1항에 따른 '인구 50만 이상의 대도시'의 인구 인정기준이 적용된다는 점을 명확히 할 필요가 있습니다.

관계법령

지방재정법

제29조(시·군 조정교부금) ① 시·도지사(특별시장은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)는 다음 각 호의 금액의 27퍼센트(인구 50만 이상의 시와 자치구가 아닌 구가 설치되어 있는 시의 경우에는 47퍼센트)에 해당하는 금액을 관할 시·군 간의 재정력 격차를 조정하기 위한 조정교부금의 재원으로 확보하여야 한다.

1. 시·군에서 징수하는 광역시세·도세(화력발전·원자력발전에 대한 지역자원시설세, 소방분 지역자원시설세 및 지방교육세는 제외한다)의 총액
2. 해당 시·도(특별시는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 지방소비세액(「지방세법」 제71조제3항제3호가목 및 같은 항 제4호가목에 따라 시·도에 배분되는 금액은 해당 지방소비세액에서 제외한다)을 전년도 말의 해당 시·도의 인구로 나눈 금액에 전년도 말의 시·군의 인구를 곱한 금액

② ~ ④ (생 략)

지방자치법

제198조(대도시 등에 대한 특례 인정) ① 서울특별시·광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상 대도시의 행정, 재정 운영 및 국가의 지도·감독에 대해서는 그 특성을 고려하여 관계 법률로 정하는 바에 따라 특례를 둘 수 있다.

② (생 략)

③ 제1항에 따른 인구 50만 이상 대도시와 제2항제1호에 따른 특례시의 인구 인정기준은 대통령령으로 정한다.

지방자치법 시행령

제118조(인구 50만 이상 대도시와 특례시의 인구 인정기준) ① 법 제198조제1항에 따라 특례를 둘 수 있는 인구 50만 이상 대도시는 전년도 말일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 수를 합산한 주민 수가 2년 간 연속하여 50만 이상인 시로 한다.

1. 해당 지방자치단체의 관할 구역에 주민등록이 되어 있는 사람
2. 「재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률」 제6조에 따라 해당 지방자치단체의 국내거소신고인 명부에 올라 있는 외국국적동포
3. 「출입국관리법」 제34조에 따라 해당 지방자치단체의 외국인등록대장에 올라 있는 외국인

②·③ (생 략)

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0018

세종특별자치시 – 「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법 시행령」 제28조의2제3항의 위임에 따라 마련된 조례가 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제8호사목에 따른 “법령”에 해당되는지 여부(「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제8호사목 등 관련)

01 질의요지

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “지방계약법”이라 함) 제9조제1항 단서 및 같은 조 제3항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제25조제1항제8호사목에서는 그 밖에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 “다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우”를 지방자치단체의 장 또는 계약담당자(이하 “지방자치단체의 장등”이라 함)가 수의계약을 할 수 있는 경우로 규정하고 있는 한편,

「신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」(이하 “행복도시법”이라 함) 제54조제3항에서는 행정중심복합도시건설청장, 세종특별자치시장 또는 사업시행자[35]는 행정중심복합도시건설사업으로 인하여 생활기반을 잃어버리게 되는 예정지역[36] 주민에 대하여 소득창출사업 지원 등에 필요한 지원대책(이하 “주민지원대책”이라 함)을 대통령령으로 정하는 바에 따라 수립·시행해야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제28조의2제3항에서는 세종특별자치시장이 수립·시행하는 같은 조 제1항 각 호에 따른 주민지원대책에 관하여 필요한 사항은 세종특별자치시 조례로 정한다고 규정하고 있는바,

행복도시법 시행령 제28조의2제3항의 위임에 따라 마련된 세종특별자치시 조례에서 세종특별자치시장이 주민지원대책의 일환으로 공공기관의 건물 또는 시설의 소독·청소·경비·시설관리 등의 사업(이하 “공공기관 건물등 관리사업”이라 함)을 예정지역 주민으로

35) 행복도시법 제18조제1항에 따라 지정된 행정중심복합도시건설사업의 시행자를 말하며(같은 법 제13조제4항 참조), 이하 같음.

36) 행복도시법 제2조제2호에 따른 예정지역을 말하며, 이하 같음.

구성된 법인 또는 단체(이하 “주민단체”라 함)에 위탁할 수 있도록 규정하는 경우, 해당 조례가 지방계약법 시행령 제25조제1항제8호사목에 따른 “법령”에 해당되는지?

02 회답

행복도시법 시행령 제28조의2제3항의 위임에 따라 마련된 세종특별자치시 조례에서 세종특별자치시장이 주민지원대책의 일환으로 공공기관 건물등 관리사업을 주민단체에 위탁할 수 있도록 규정하는 경우, 해당 조례는 지방계약법 시행령 제25조제1항제8호사목에 따른 “법령”에 해당되지 않습니다.

03 이유

먼저 지방계약법 제9조제1항 본문에서는 지방자치단체의 장등이 계약을 체결하는 경우에는 일반입찰을 원칙으로 하도록 규정하면서 같은 항 단서 및 같은 법 시행령 제25조제1항 각 호에서는 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우로서 예외적으로 수의계약을 할 수 있는 사유를 구체적으로 규정하고 있는바, 이와 같은 계약의 방식에 관한 문언과 체계에 비추어 보면 같은 항 각 호에서 규정하고 있는 수의계약 사유는 엄격하게 한정적으로 해석해야 합니다.

그런데 지방계약법은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 모든 지방자치단체가 체결하는 계약에 대해 공통적으로 적용되어야 할 기본적인 원칙을 정하고 있는 점, 특히 같은 법 제9조제2항은 수의계약의 대상범위 등을 구체화하여 지방자치단체의 자의적인 판단에 따라 수의계약이 양산되는 것을 방지하고 수의계약으로 인한 부패의 소지를 줄이기 위해 마련된 규정[37]이라는 점, 같은 법 제41조에서는 “중앙행정기관의 장은 지방자치단체의 계약에 관한 법령을 입안할 때에는 행정안전부장관과 미리 협의해야 한다고”고 규정하고 있는 등 지방계약법령에서 “법령”이라는 용어가 사용되는 경우 그 범위에 지방자치단체의 자치법규가 포함된다고 볼만한 규정을 찾아볼 수 없는 점 등에 비추어 볼 때, 지방자치단체의 장이

37) 2004. 12. 1. 의안번호 171022호로 제안된 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률안에 대한 국회 행정자치위원회 검토보고서 참조

「지방자치법」 제117조제3항에 따라 특정 단체에 특정 사무를 민간위탁하는 사항을 조례로 정할 수 있는지 여부는 별론으로 하더라도, 지방계약법 제9조제1항에 따른 일반입찰의 예외로서 수의계약 사유를 규정하고 있는 같은 법 시행령 제25조제1항제8호사목에 따른 "다른 법령"에 「지방자치법」 제28조제1항에 따라 지방자치 단체가 법령의 범위에서 그 사무에 관하여 제정하고, 지방자치단체의 의회를 통해 의결하는 자치법규인 "조례"는 포함되지 않는다고 해석하는 것이 지방계약법령의 취지 및 체계에 부합하는 해석입니다.

그렇다면 행복도시법 제54조제3항에서는 세종특별자치시장에게 주민지원대책의 수립·시행 의무를 부과하고 있고, 같은 법 시행령 제28조의2제3항에서는 세종특별자치시장이 수립·시행하는 주민지원대책에 관하여 필요한 사항은 세종특별자치시 "조례"로 정한다고 위임하고 있을 뿐, 세종특별자치시장의 주민지원대책 사업 중 일부를 주민단체에 위탁할 수 있도록 명시적으로 위임하고 있지는 않은바, 행복도시법 시행령 제28조의2제3항의 위임에 따라 마련된 조례를 지방계약법 시행령 제25조제1항제8호사목에 따른 수의계약의 사유로서 "다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우"에서의 "법령"에 해당된다고 볼 수는 없을 것입니다.

또한 수의계약이란 계약상대자를 결정함에 있어 경쟁입찰에 의하지 않고 특정인을 계약상대자로 선정하여 계약을 체결하는 것으로 일반입찰의 원칙에 대한 예외로 인정되는 것으로서, 지방자치단체의 장등이 수의계약을 할 수 있도록 하는 규정은 그 계약상대자 외의 자에 대해서는 영업을 하면서 자유롭게 경쟁하여 지방자치단체의 장등과 계약을 체결할 수 있는 직업수행의 자유를 제한하는 것[38]인바, 그 범위를 넓히는 방향으로 함부로 유추 해석이나 확장해석을 하여서는 안된다고 할 것이므로[39], 지방계약법 시행령 제25조제1항 제8호 사목에서의 "법령"을 지방자치단체가 제정하는 자치규범으로서의 조례까지 포함하는 것으로 넓게 해석하는 것은 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 행복도시법 시행령 제28조의2제3항의 위임에 따라 마련된 세종특별자치시 조례에서 세종특별자치시장이 주민지원대책의 일환으로 공공기관 건물등 관리사업을 주민단체에 위탁할 수 있도록 규정하는 경우, 해당 조례는 지방계약법 시행령 제25조제1항 제8호사목에 따른 "법령"에 해당되지 않습니다.

---

38) 헌법재판소 2023. 10. 26. 선고 2019헌마871 전원재판부 결정례 참고

39) 대법원 2000. 10. 13. 선고 99두3201 판결례 참조.

법령정비 권고사항

입법정책적으로 행복도시법령에 따른 주민지원대책의 일환으로 공공기관 건물등 관리사업을 주민단체에 수의계약으로 위탁할 필요가 있다면, 그 위탁 여부 및 대상을 행복도시법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

제9조(계약의 방법) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 및 지역특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명(指名)하여 입찰에 부치거나 수의계약을 할 수 있다.

② (생 략)

③ 제1항 단서에 따른 지명기준 및 지명절차, 수의계약의 대상범위 및 수의계약상대자의 선정절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④·⑤ (생 략)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따라 수의계약을 할 수 있다.

1. ~ 7의2. (생 략)

8. 그 밖에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. ~ 바. (생 략)

사. 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우

아. ~ 차. (생 략)

②·③ (생 략)

신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법

제54조(관련 대책의 수립) ① · ② (생 략)

③ 건설청장, 세종특별자치시장 또는 사업시행자는 행정중심복합도시건설사업으로 인하여 생활기반을 잃어버리게 되는 예정지역 주민에 대하여 직업전환훈련, 소득창출사업 지원, 그 밖에 주민 재정착과 생활안정에 필요한 지원대책을 대통령령으로 정하는 바에 따라 수립·시행하여야 한다.

신행정수도 후속대책을 위한 연기·공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법 시행령

제28조의2(예정지역 주민에 대한 지원대책) ①법 제54조제3항에 따라 건설청장, 세종특별자치시장 또는 사업시행자가 수립·시행하여야 하는 주민지원대책은 다음 각 호와 같다.

1. (생 략)
2. 예정지역 주민으로 구성된 법인 또는 단체(이하 이 조에서 "주민단체"라 한다)에 대한 소득창출 사업의 지원
3. ·4. (생 략)

② (생 략)

③ 세종특별자치시장이 수립·시행하는 제1항 각 호에 따른 주민지원대책에 관하여 필요한 사항은 세종특별자치시 조례로 정한다.

④·⑤ (생 략)

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0051

민원인 – 「공공감사에 관한 법률」에 따른 자체감사의 감사대상자가 「행정조사기본법」 제22조제1항을 근거로 감사담당자의 교체신청을 할 수 있는지 여부 (「행정조사기본법」 제22조 등 관련)

01 질의요지

「공공감사에 관한 법률」(이하 "공공감사법"이라 함) 제2조제1호에서는 "자체감사"란 중앙행정기관[40], 지방자치단체 및 공공기관[41]의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다고 규정하고 있는 한편,

「행정조사기본법」 제2조제1호에서는 "행정조사"란 행정기관[42]이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등(이하 "현장조사등"이라 함)을 하거나 조사대상자에게 보고요구·자료제출요구 및 출석·진술요구(이하 "보고요구등"이라 함)를 행하는 활동을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제22조제1항에서는 조사대상자는 조사원[43]에게 공정한 행정조사를 기대하기 어려운 사정이 있다고 판단되는 경우에는 행정기관의 장에게 당해 조사원의 교체를 신청할 수 있다고 규정하고 있는바,

중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관 중 공공기관(이하 "소관 공공기관"이라 함) 및 그 공공기관에 속한 자에 대하여 공공감사법 제2조제1호에 따른 자체감사(이하 "공공기관대상자체감사"라 함)를 실시하는 경우, 자체감사를 받는 사람(이하 "감사대상자"라 한다)은 「행정조사기본법」 제22조제1항을 근거로 감사담당자의 교체를 신청할 수 있는지?

---

40) 「정부조직법」 제2조에 따른 부·처·청과 감사원, 국가인권위원회, 공정거래위원회, 금융위원회, 방송통신위원회 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관을 말하며(공공감사법 제2조제2호 참조), 이하 같음.

41) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 지정된 기관(같은 법 제5조제4항에 따른 기타공공기관으로서 직원의 정원이 100명 미만인 기관은 제외한다)과 「감사원법」 제22조제1항 및 제23조에 따른 감사원 감사의 대상기관으로서 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체를 말하며(공공감사법 제2조제4호 참조), 이하 같음.

42) 법령 및 조례·규칙에 따라 행정권한이 있는 기관과 그 권한을 위임 또는 위탁받은 법인·단체 또는 그 기관이나 개인을 말하며(「행정조사기본법」 제2조 참조), 이하 같음.

43) 행정조사업무를 수행하는 행정기관의 공무원·직원 또는 개인을 말하며(「행정조사기본법」 제2조제3호), 이하 같음.

02 회답

중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 공공기관대상자체감사를 실시하는 경우, 감사대상자는「행정조사기본법」제22조제1항을 근거로 감사담당자의 교체를 신청할 수 없습니다.

03 이유

공공감사법 제2조제1호에서는 "자체감사"란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관(이하 "중앙행정기관등"이라 함)의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다고 규정하고 있어, 자체감사는 중앙행정기관등의 감사기구의 장이 '그 소속되어 있는 기관' 뿐만 아니라 '그 소속 기관 및 소관 단체' 및 그 기관에 속한 자에 대하여 실시하는 것도 포함하므로, 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 그 소관 공공기관 및 그 공공기관에 속한 자에 대하여 실시하는 자체감사도 공공감사법 제2조제1호에 따른 자체감사에 해당합니다.

그런데「행정조사기본법」제2조제1호에 따르면 "행정조사"란 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사등을 하거나 조사대상자에게 보고요구등을 행하는 활동이라고 규정하고 있고, 같은 법 제22조제1항에서는 조사대상자는 조사원에게 공정한 행정조사를 기대하기 어려운 사정이 있다고 판단되는 경우에는 행정기관의 장에게 당해 조사원의 교체를 신청할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 공공기관대상자체감사를 실시하는 경우, 공공기관대상자체감사가「행정조사기본법」제2조제1호에 따른 행정조사에 해당하여 감사대상자가 같은 법 제22조제1항을 근거로 감사담당자의 교체를 신청할 수 있는지 여부가 문제됩니다.

먼저 공공감사법은 중앙행정기관등의 자체감사기구의 구성 및 운영 등에 관한 기본적인 사항과 효율적인 감사체계의 확립에 필요한 사항을 정함으로써 중앙행정기관등의 내부통제 제도를 내실화하는 것을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제2조제1호에 따르면 "자체감사"는 중앙행정기관등의 감사기구의 장이 '그 소속되어 있는 기관 및 그 기관에 속한

자'를 대상으로 '모든 업무와 활동 등'을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 제도인 반면, 「행정조사기본법」은 행정조사에 관한 기본원칙·행정조사의 방법 및 절차에 관한 공통적인 사항을 규정함으로써 행정의 공정성·투명성 및 효율성을 높이려는 것을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제2조제1호에 따르면 "행정조사"는 중앙행정기관·지방자치단체 등을 포함하는 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 '법인·단체 또는 그 기관이나 개인'을 대상으로 현장조사등을 하거나 보고요구등을 행하는 제도인바, 이러한 법률의 규정 체계에 비추어 봤을 때 공공감사법에 따른 자체감사와 「행정조사기본법」에 따른 행정조사는 그 목적과 대상을 달리하는 별개의 제도이므로, 공공기관대상자체감사가 「행정조사기본법」 제2조제1호에 따른 "행정조사"에 해당한다고 보기는 어렵습니다.

그리고 공공감사법 제7조제1항에서는 중앙행정기관등의 감사기구의 장은 자체감사 활동에서 독립성이 최대한 보장되어야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제41조제1항에서는 자체감사를 받는 사람으로서 정당한 사유 없이 감사를 거부하거나 자료의 제출요구에 따르지 아니한 사람(제1호) 또는 정당한 사유 없이 자체감사활동을 방해한 사람(제2호)에게는 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하여 자체감사를 받는 사람에게 감사기구의 장 및 감사담당자가 수행하는 감사활동에 협조할 의무를 부과[44]하고 있는 반면, 「행정조사기본법」 제4조에서는 행정조사의 기본원칙을 정하면서 행정조사는 조사목적을 달성하는데 필요한 최소한의 범위 안에서(제1항), 조사목적에 적합하도록 조사대상자를 선정하여(제2항) 실시하여야 하고, 법령등의 위반에 대한 처벌보다는 법령등을 준수하도록 유도하는데 중점을 두어야 한다(제4항)고 규정하고 있고, 같은 법 제25조제1항에서는 행정기관의 장은 법령 등에서 규정하고 있는 조사사항을 조사대상자로 하여금 스스로 신고하도록 하는 자율신고 제도를 운영할 수 있도록 하고 있는 점에 비추어보면, 행정조사의 공정성과 투명성을 확보하여 행정조사의 대상이 되는 기업 등에게 조사에 대한 부담을 덜어주고 국민의 권익을 보호[45]하는 데 중점을 두고 있는바, 공공감사법에 따른 자체감사 및 「행정조사기본법」에 따른 행정조사는 그 대상자가 부담하는 의무가 다르고, 운영 방식도 다른 별개의 제도로서, 공공감사법에 따른 공공기관대상자체감사는 「행정조사기본법」에 따른 행정조사에 해당하지 않고, 공공기관대상자체감사의 감사대상자도 「행정조사기본법」 제22조제1항을 근거로 감사담당자의 교체를 신청할 수 없다고 해석하는 것이 합리적입니다.

또한 「행정조사기본법」 제22조에서 조사원 교체신청 규정을 둔 취지는 '기피' 제도와

44) 대법원 2021. 11. 25. 선고 2019두30270 판결례 참조

45) 2007. 5. 17. 법률 제8482호로 제정되어 2007. 8. 18. 시행된 「행정조사기본법」 제정이유 참조

유사하게 조사대상자가 조사원에게 공정한 행정조사를 기대하기 어려운 사정 등 이해관계가 있는 경우 그 조사원이 아닌 다른 조사원으로 하여금 조사를 할 수 있도록 하여 행정조사 과정의 공정성을 확보하기 위한 것[46]인데, 공공감사법령에서는 자체감사의 객관성과 중립성을 확보하기 위하여 공공감사법 제37조의 위임에 따라 마련된 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」 제6조에서 감사담당자등[47]의 회피 제도를 규정하고 있는바, 제도의 공정성과 객관성을 보장하기 위하여 행정조사기본법령에서는 조사원 교체신청을, 공공감사법령에서는 감사담당자등의 회피를 각각 규정하고 있는 것이므로, 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 공공기관대상자체감사를 실시하는 경우 공공감사법령에서 별도의 기피 제도나 감사담당자의 교체 제도를 규정하고 있지 않은 이상, 그 감사대상자는 「행정조사기본법」 제22조제1항을 근거로 감사담당자의 교체를 신청할 수 없다고 해석하는 것이 각 법령의 입법 취지에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 중앙행정기관 및 지방자치단체의 감사기구의 장이 공공기관대상자체감사를 실시하는 경우, 감사대상자는 「행정조사기본법」 제22조제1항을 근거로 감사담당자의 교체를 신청할 수 없습니다.

관계법령

행정조사기본법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "행정조사"란 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 조사대상자에게 보고요구·자료제출요구 및 출석·진술요구를 행하는 활동을 말한다.
2. "행정기관"이란 법령 및 조례·규칙(이하 "법령등"이라 한다)에 따라 행정권한이 있는 기관과 그 권한을 위임 또는 위탁받은 법인·단체 또는 그 기관이나 개인을 말한다.
3. "조사원"이란 행정조사업무를 수행하는 행정기관의 공무원·직원 또는 개인을 말한다.
4. "조사대상자"란 행정조사의 대상이 되는 법인·단체 또는 그 기관이나 개인을 말한다.

제22조(조사원 교체신청) ① 조사대상자는 조사원에게 공정한 행정조사를 기대하기 어려운 사정이 있다고 판단되는 경우에는 행정기관의 장에게 당해 조사원의 교체를 신청할 수 있다.
②·③ (생 략)

46) 2007. 3. 29. 행정조사기본법안에 대한 제266회국회 법제사법위원회 제1차 회의록 참조

47) 공공감사법 제2조제6호에 따른 감사기구의 장 및 같은 법 제2조제7호에 따른 감사담당자를 말하며(「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」 제2조제1호 참조), 이하 같음.

④ 행정기관의 장은 제1항에 따른 교체신청이 타당하다고 인정되는 경우에는 다른 조사원으로 하여금 행정조사를 하게 하여야 한다.
⑤ (생 략)

공공감사에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "자체감사"란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관의 감사기구의 장이 그 소속되어 있는 기관(그 소속 기관 및 소관 단체를 포함한다) 및 그 기관에 속한 자의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말한다.
2. "중앙행정기관"이란 「정부조직법」 제2조에 따른 부·처·청과 감사원, 국가인권위원회, 국민권익위원회, 공정거래위원회, 금융위원회, 방송통신위원회 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관을 말한다.
3. "지방자치단체"란 특별시·광역시·도(제주특별자치도를 제외한다. 이하 같다)·시·군·자치구 및 특별시·광역시·도의 교육청을 말한다.
4. "공공기관"이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따라 지정된 기관(같은 법 제5조제4항에 따른 기타공공기관으로서 직원의 정원이 100명 미만인 기관은 제외한다)과 「감사원법」 제22조제1항 및 제23조에 따른 감사원 감사의 대상기관으로서 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체를 말한다.
5. "자체감사기구"란 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 설치되어 자체감사를 수행하는 기관 또는 부서를 말한다.
6. "감사기구의 장"이란 자체감사기구의 업무를 총괄하고 감사담당자를 지휘·감독하는 사람 및 제6조제1항에 따른 합의제감사기구를 말한다.
7. "감사담당자"란 자체감사기구에 소속되어 감사활동을 수행하는 사람을 말한다.

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0123

민원인 – 「공유재산 및 물품 관리법」 제33조제1항 및 같은 법 시행령 제34조에서 규정하고 있는 "전년도의 연간 대부료"의 의미(「공유재산 및 물품 관리법」 제33조 등 관련)

01 질의요지

「공유재산 및 물품 관리법」(이하 "공유재산법"이라 함) 제32조제1항 본문에서 일반재산[48]의 대부계약[49]을 체결하였을 때에는 대통령령으로 정하는 요율과 계산방법에 따라 매년 대부료를 징수한다고 규정하고 있고, 같은 법 제33조제1항에서 지방자치단체의 장은 동일인[50]이 같은 일반재산을 1년을 초과하여 계속 대부하는 경우 같은 법 제32조제1항에 따라 산정된 해당 연도의 연간 대부료가 "전년도의 연간 대부료"보다 100분의 5 이상 증가한 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 대부료의 증가분을 감액 조정할 수 있다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제34조에서 같은 법 제33조에 따라 해당 연도의 연간 대부료가 "전년도의 연간 대부료(법 또는 다른 법률에 따라 대부료를 감경받거나 제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료를 말한다)"보다 100분의 5 이상 증가한 부분에 대하여 그 일부 또는 전부를 지방자치단체의 조례로 감액조정할 수 있다고 규정하고 있는바,

공유재산법 제33조제1항 및 같은 법 시행령 제34조에 따라 전년도에 대부료의 증가분이 감액 조정된 경우, 해당 연도 연간 대부료의 조정 기준이 되는 "전년도의 연간 대부료"가 전년도에 같은 법 제32조제1항에 따라 산정된 대부료로서 '감액 조정하기 전의 대부료'를 의미하는지, 아니면 전년도에 같은 법 제33조제1항에 따라 '감액 조정된 대부료'를 의미하는지?

48) 공유재산법 제5조제3항에 따라 행정재산 외의 모든 공유재산을 의미하며, 이하 같음

49) 공유재산법 제2조제9호에 따라 일반재산 또는 물품을 해당 지방자치단체 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용·수익할 수 있도록 체결하는 계약을 의미하며, 이하 같음

50) 상속인과 그 밖의 포괄승계인은 피승계인과 동일인으로 보며, 이하 같음

02 회답

이 사안의 경우, 해당 연도 연간 대부료의 조정 기준이 되는 “전년도의 연간 대부료”는 전년도에 공유재산법 제32조제1항에 따라 산정된 대부료로서 ‘감액 조정하기 전의 대부료’를 의미합니다.

03 이유

먼저 공유재산법 제32조제1항 본문에서 일반재산의 대부계약을 체결하였을 때에는 대통령령으로 정하는 요율과 계산방법에 따라 매년 대부료를 징수한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제31조제1항 본문에서 같은 법 제32조제1항에 따른 일반재산의 대부료는 시가를 반영한 해당 재산 평정가격의 연 1천분의 10 이상의 범위에서 지방자치단체의 조례로 정하되, 월할 또는 일할로 계산할 수 있다고 규정하고 있어 일반재산을 대부받은 자는 원칙적으로 같은 법 제32조제1항 및 같은 법 시행령 제31조에 따라 시가 등을 반영하여 산정된 대부료를 납부하여야 하나, 같은 법 제33조제1항에서 같은 일반재산을 1년을 초과하여 계속 대부하는 경우 ‘같은 법 제32조제1항에 따라 산정된 해당 연도의 연간 대부료’가 “전년도의 연간 대부료”보다 100분의 5 이상 증가한 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 대부료의 증가분을 감액 조정할 수 있다고 규정하면서 같은 법 제32조제1항 및 같은 법 시행령 제31조제1항에 따라 산정된 해당 연도의 연간 대부료를 감액 조정할 수 있는 예외를 정하고 있는바, 같은 법 제33조제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제34조와 같은 예외규정은 엄격하게 해석하여야 하고 합리적 이유 없이 확장하여 해석해서는 아니된다 할 것입니다[51].

그런데 해당 연도 연간 대부료의 감액 조정 기준이 되는 “전년도의 연간 대부료”와 관련하여 공유재산법 시행령 제34조 괄호 부분에서 법 또는 다른 법률에 따라 대부료를 ‘감경’받은 경우에는 변경 전 연간 대부료를 말한다고 규정하고 있으므로, 전년도 대부료에 감액 변경되는 조정이 있었을 경우, “전년도 연간 대부료”는 같은 법 시행령 제34조의 문언에 따라 변경 전 연간 대부료, 즉 조정이 있기 전의 연간 대부료를 의미한다 할 것이고, 만약 같은 법 시행령 제34조 괄호 부분에서의 ‘감경’이 같은 법 제34조제3항에 따른 ‘감경’만을 의미하며 같은 법

51) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 참조

제33조에 따른 '감액 조정'이 포함되지 않는다고 보아, "전년도 연간 대부료"를 변경 후 연간 대부료, 즉 조정이 있은 후의 연간 대부료를 의미한다고 해석하는 것은 감액 조정의 기준이 되는 "전년도의 연간 대부료"를 합리적 이유 없이 낮추어 연간 대부료를 감액 조정할 수 있는 예외를 확장하여 해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

또한 구 공유재산법 시행령[52]에서는 대부료의 조정과 관련하여 제34조에서 같은 법 제33조에 따라 해당 연도의 연간 대부료가 "전년도의 연간 대부료(제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료를 말한다)"보다 100분의 5 이상 증가한 부분에 대하여 감액조정할 수 있다고 규정하고 있었으나, 같은 법 시행령이 2020년 12월 22일 대통령령 제31276호로 일부개정되면서 제34조에서 같은 법 제33조에 따라 해당 연도의 연간 대부료가 "전년도의 연간 대부료(법 또는 다른 법률에 따라 대부료를 감경받거나 제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료를 말한다)"보다 100분의 5 이상 증가한 부분에 대하여 감액조정할 수 있다고 규정됨에 따라 전년도에 공유재산법 또는 다른 법률에 따라 대부료가 감경되어 그 대부료에 변경이 있었더라도 변경 전 연간 대부료를 대부료 조정의 기준으로 한다는 점을 명시하였는바, '감액조정하기 전의 대부료'가 "전년도 연간 대부료"를 의미한다고 해석하는 것이 공유재산법의 입법연혁 및 취지에 부합합니다.

아울러 공유재산법령은 공유재산 및 물품에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 공유재산 및 물품을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리·처분하는 것을 목적으로 하고 있는데(공유재산법 제1조), 공유재산법 제33조제1항 및 같은 법 시행령 제34조의 "전년도의 연간 대부료"가 전년도에 같은 법 제33조제1항 및 같은 법 시행령 제34조에 따라 '감액 조정된 대부료'를 의미한다고 해석한다면, 해당 공유재산의 가격이 지속적으로 상승하는 경우 장기간 공유재산을 대부 받은 자가 실제로 납부하는 대부료와 같은 법 제32조 및 같은 법 시행령 제31조에 따라 원칙적으로 납부하였어야 하는 시가 등이 반영된 대부료와의 차이가 더욱 커지게 되어 공유재산을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리하려는 공유재산법의 입법 취지에 반하는 결과가 초래될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 연도 연간 대부료의 조정 기준이 되는 "전년도의 연간 대부료"는 전년도에 공유재산법 제32조제1항에 따라 산정된 대부료로서 '감액 조정하기 전의 대부료'를 의미합니다.

52) 2020. 12. 22. 대통령령 제31276호로 일부개정되어 2021. 6. 23. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 같음

관계법령

공유재산법

제32조(대부료) ① 일반재산의 대부계약을 체결하였을 때에는 대통령령으로 정하는 요율과 계산방법에 따라 매년 대부료를 징수한다. 다만, 연간 대부료가 대통령령으로 정하는 금액 이하인 경우에는 대부기간의 대부료를 일시에 통합 징수할 수 있다.

② ~ ④ (생 략)

제33조(대부료의 조정) ① 지방자치단체의 장은 동일인(상속인과 그 밖의 포괄승계인은 피승계인과 동일인으로 본다)이 같은 일반재산을 1년을 초과하여 계속 대부하는 경우 제32조제1항에 따라 산정된 해당 연도의 연간 대부료가 전년도의 연간 대부료보다 100분의 5 이상 증가한 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 대부료의 증가분을 감액 조정할 수 있다.

② 다른 법률에 따른 사용료 또는 점용료의 납부대상인 행정재산이 용도 폐지 등의 사유로 이 법에 따른 대부료 납부대상으로 된 경우 그 대부료 산출에 관하여는 제1항을 준용한다.

공유재산법 시행령

제34조(대부료의 조정) 법 제33조에 따라 해당 연도의 연간 대부료가 전년도의 연간 대부료(법 또는 다른 법률에 따라 대부료를 감경받거나 제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료를 말한다)보다 100분의 5 이상 증가한 부분에 대하여 그 일부 또는 전부를 지방자치단체의 조례로 감액조정할 수 있다.

질의제목 10 ▶ 안건번호 24-0134

경기도 고양시 – 법률에서 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하면서 위임 조례에서 그 감면 기준을 정하고 있는 경우가 「공유재산 및 물품관리법」 제16조제2항제5호에 따른 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”에 해당되는지 등(「공유재산 및 물품관리법」 제16조제2항제5호 등 관련)

01 질의요지

「공유재산 및 물품관리법」(이하 “공유재산법”이라 함) 제16조제1항에서는 공유재산의 관리 및 처분에 관하여 지방자치단체의 장이 자문하기 위하여 각 지방자치단체에 공유재산심의회(이하 “심의회”라 함)를 둔다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항제5호에서는 심의회의 심의사항으로 “제24조 또는 제34조 및 그 밖에 다른 법률에 따라 사용료[53] 또는 대부료[54]를 감면하는 경우”를 규정하고 있는 한편,

「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」(이하 “도시재생법”이라 함) 제30조의2제1항에서는 지방자치단체의 장은 도시재생 활성화 등 공익 목적을 위하여 도시재생활성화지역 또는 도시재생 인정사업이 시행되는 지역(이하 “도시재생활성화지역등”이라 함) 내에서 같은 법 제2조제10호나목에 따른 공동이용시설(이하 “공동이용시설”이라 함)에 대한 공유재산법 제20조에 따른 사용허가를 하는 경우 같은 법 제22조에도 불구하고 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하고 있고, 도시재생법 제30조의2제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 공익 목적의 기준, 사용료 면제 대상 및 그 밖에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있는바[55],

가. 도시재생법 제30조의2제1항에서 공동이용시설의 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하면서 같은 조 제2항의 위임에 따라 마련된 조례에서 그 사용료의 면제 또는 경감의 구체적 기준, 감면 대상, 감면 대상별 감면 비율 등(이하 “사용료의 면제·경감 기준등”이라 함)을 정하고 있는 경우가 공유재산법 제16조제2항제5호[56]에 따른 심의회의 심의

53) 공유재산법 제22조에 따른 사용료를 말하며, 이하 같음.

54) 공유재산법 제32조에 따른 대부료를 말하며, 이하 같음.

55) 도시재생법 제30조의2제2항의 위임에 따라 마련된 지방자치단체의 조례에서 공유재산법 제16조에 따른 공유재산심의회의 심의를 거쳐야 한다는 규정을 두지 않은 경우를 전제로 함.

대상인 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”에 해당되는지?

나. 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료를 감면하는 경우”로서 도시재생법 제30조의2제1항에 따라 공동이용시설에 대한 공유재산법 제22조에 따른 사용료(이하 “사용료”라 함)를 면제 또는 경감하는 경우, 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 하는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 심의회의 심의 대상인 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”에 해당됩니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 합니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

도시재생법 제30조의2제1항에서는 지방자치단체의 장은 도시재생 활성화 등 공익 목적을 위하여 도시재생활성화지역등 내에서 공동이용시설에 대한 공유재산법 제20조에 따른 사용허가를 하는 경우 같은 법 제22조에도 불구하고 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 공익 목적의 기준, 사용료 면제 대상 및 그 밖에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있는데, 공유재산법 제16조제2항제5호에서는 심의회의 심의 대상 중 하나로 “제24조 또는 제34조 및 그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”를 규정하고 있을뿐, 법률에서 위임받아 마련된 조례로 사용료의 면제·경감 기준등을 정하고 있는 경우가 심의회의

56) 조례에서 사용료 또는 대부료 감면에 대하여 규정하는 경우가 공유재산법 제16조제2항제6호에 따른 “그 밖에 공유재산의 관리·처분 등에 대하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 경우”에는 해당되지 않음을 전제로 함.

심의 대상인지 여부는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안과 같이 도시재생법 제30조의2제2항의 위임에 따라 마련된 조례에서 공동이용시설에 대한 사용료의 면제·경감 기준등을 정하고 있는 경우가 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 심의회의 심의 대상인 '그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우'에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

먼저 도시재생법 제30조의2제1항에는 지방자치단체의 장이 공동이용시설에 대한 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 그 사용료의 면제 대상 및 그 밖에 필요한 사항은 지방자치단체의 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있는바, 도시재생법 제30조의2제2항의 위임에 따라 마련된 조례에서 사용료의 면제·경감 기준등을 정하고 있다고 하더라도 사용료를 감면할 수 있는 근거 자체는 도시재생법 제30조의2제1항, 즉 법률에 있는 것이고, 공유재산법에서 별도로 '사용료의 면제·경감 기준등을 조례로 정하는 경우' 심의회의 심의 대상에서 제외하도록 하는 명시적인 규정을 두고 있지 않은 이상, 이 사안과 같이 도시재생법에서 공동이용시설의 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하면서 같은 법의 위임에 따라 마련된 조례에서 사용료의 면제·경감 기준등을 정하고 있는 경우는 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 '그 밖에 다른 법률에 따라' 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우에 해당한다고 보아야 할 것입니다.

그리고 공유재산법 제16조제2항제5호에서 또다른 심의회의 심의 대상으로 규정하고 있는 '같은 법 제24조 또는 제34조에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우'를 살펴보면, ①같은 법 제24조제2항에서는 지방자치단체의 장이 지역경제의 활성화를 위하여 필요한 경우 등에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사용료를 감경할 수 있다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제17조제7항에서는 행정재산의 사용료를 일정한 범위[57]에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 감경할 수 있다고 규정하고 있고, ②같은 법 제34조제2항에서는 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 경우에는 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대부료의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다고 규정하고 있어, '같은 법 제24조 또는 제34조에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우'에도 그 사용료 또는 대부료의 구체적 감면 대상 및 기준 등은 조례로 정하도록 하는 것이 전제되어 있는바, 이 사안과 같이 도시재생법 제30조의2제2항의 위임에 따라 공동이용시설 사용료의 면제·경감 기준등을 조례로 정하도록 하고 있는 경우에도 심의회의 심의 대상인 '그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우'에 해당된다고 보는 것이 공유재산법 제16조제2항제5호의 규정 체계에 비추어봤을 때 합리적인 해석입니다.

57) 공유재산법 시행령 제17조제7항 각 호의 구분에 따른 범위를 말함

따라서 이 사안의 경우, 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 심의회의 심의 대상인 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”에 해당됩니다.

나. 질의 나에 대해

공유재산법 제16조제1항에서는 각 지방자치단체에 심의회를 둔다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분에서는 같은 조 제1항에 따른 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다고 규정하면서 같은 항 제5호에서 심의회가 심의하는 사항 중 하나로 “제24조 또는 제34조 및 그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”를 규정하고 있는데, 같은 법 제16조제2항제5호에서 규정한 사항에 대해 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 하는지에 대하여 명시적으로 규정하고 있지 않은바, 이 사안에서는 공유재산법 제16조제2항제5호에 해당하는 경우로서 도시재생법 제30조의2제1항에 따라 공동이용시설에 대한 사용료를 면제 또는 경감하는 경우에 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 하는지가 문제됩니다.

먼저 공유재산법 제16조제1항 및 제2항에서는 심의회의 설치 근거 및 심의사항에 대하여 ‘심의회를 둘 수 있다’, ‘심의할 수 있다’와 같은 가능적 표현을 사용하지 않고 ‘심의회를 둔다’, ‘심의한다’는 단정적 표현을 사용하고 있는바, 이 규정을 그 문언의 통상적 의미로 해석하면 각 지방자치단체는 심의회를 두어야 하고, 그 심의사항으로서 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료를 감면하는 경우”에 대하여 심의회의 심의를 거쳐야 한다는 의미로 해석[58]될 수 있습니다.

그리고 심의회의 심의사항에 관하여 규정하고 있는 공유재산법 제16조제2항의 입법연혁을 살펴보면, ① 구 공유재산법[59] 제16조에서는 심의회의 설치 근거(제1항)를 두면서 그 구성과 운영에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다(제2항)고 규정하고 있었으나, 공유재산의 관리·처분에 대한 심의기능을 강화하고, 심의회 운영의 전국적 통일성을 기하기 위하여[60] 2015년 1월 20일 법률 제13017호로 일부개정된 공유재산법에서 제16조제2항을 신설하여 심의회의 심의사항을 각 호에서 구체적으로 규정하게 된 것이고, ② 종전 공유재산법[61] 제11조에 따르면 ‘지방자치단체의 장은 행정재산의 용도를 변경하거나 폐지하려는 경우(제1호) 등에는 제16조에 따른 공유재산심의회의 심의를 거쳐야 한다’고 규정하고 있었는데, 2021년 4월 20일 법률 제18086호로 일부개정된 공유재산법에서는

58) 대법원 2017. 12. 22. 선고 2014다223025 판결례 참조.

59) 2015. 1. 20. 법률 제13017호로 일부개정되기 전의 것을 말함

60) 공유재산법(2015. 1. 20, 일부개정되어 2015. 7. 21. 시행된 것을 말함) 국회검토보고서 참조.

61) 2021. 4. 20. 법률 제18086호로 일부개정되기 전의 것을 말함

제11조를 '지방자치단체의 장은 공유재산이 각 호의 용도변경 등 사유에 해당하는 경우에는 그 용도를 변경하거나 폐지할 수 있다'고 개정하면서, 제16조제2항에 심의회의 심의사항으로 제2호와 제3호를 신설하여 종전에 반드시 심의를 거쳐야 하는 사항이었던 행정재산의 용도변경 또는 폐지 등을 심의회의 심의사항에 추가한 것인바, 이러한 심의회의 기능과 관련한 입법연혁을 종합적으로 고려하면 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 "그 밖에 다른 법률에 따라 사용료를 감면하는 경우"에 대하여 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 한다고 보는 것이 그 입법연혁 및 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 공유재산법은 공유재산 및 물품을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리·처분하는 것을 목적(제1조)으로 하고 있고, 지방자치단체가 공유재산 관리·처분을 일관성 있게 수행함으로써 지방자치단체의 세외수입을 증대시키고, 공정성과 투명성을 높이기 위하여[62] 공유재산 관리·처분의 기본원칙(같은 법 제3조의2)을 별도로 두고 있는바, 이러한 공유재산법의 규정체계를 고려하면 세외수입과 관련된 공동이용시설의 사용료 감면에 대하여 심의회의 심의를 거쳐 공정하고 전문적인 판단을 하도록 할 필요성이 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 합니다.

관계법령

공유재산 및 물품관리법

제16조(공유재산심의회) ① 공유재산의 관리 및 처분에 관하여 지방자치단체의 장이 자문하기 위하여 각 지방자치단체에 공유재산심의회를 둔다.
② 제1항에 따른 공유재산심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.
1. 제10조 및 제10조의2에 따라 중기공유재산관리계획 또는 공유재산관리계획을 수립하거나 변경하는 경우
2. 제11조에 따라 행정재산의 용도를 변경하거나 폐지하려는 경우
3. 제11조에 따라 일반재산을 행정재산으로 용도를 변경하려는 경우
4. 제12조 단서에 따라 무상으로 회계 간의 재산 이관을 하는 경우
5. 제24조 또는 제34조 및 그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우
6. 그 밖에 공유재산의 관리·처분 등에 대하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 경우
③·④ (생 략)

62) 공유재산법(2010. 2. 4. 법률 제10006호로 일부개정되어 2010. 8. 5. 시행된 것을 말함) 개정이유 및 주요내용 참조.

도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법

제30조의2(공동이용시설 사용료의 감면) ① 지방자치단체의 장은 도시재생 활성화 등 공익 목적을 위하여 다음 각 호에 해당하는 지역 내에서 제2조제10호나목에 따른 공동이용시설에 대한 「공유재산 및 물품 관리법」 제20조에 따른 사용허가를 하는 경우 같은 법 제22조에도 불구하고 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다.

1. 도시재생활성화지역
2. 도시재생 인정사업이 시행되는 지역

② 제1항에 따른 공익 목적의 기준, 사용료 면제 대상 및 그 밖에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

질의제목 11 ▶ 안건번호 24-0173

충청남도 논산시 – 제2차 납세의무자에 해당하는 자에게 행정대집행 비용을 징수할 수 있는지 여부(「행정대집행법」 제6조제1항 등 관련)

01 질의요지

「행정대집행법」 제2조에서는 법률(법률의 위임에 의한 명령, 지방자치단체의 조례를 포함하며, 이하 같음)에 의하여 직접명령되었거나 또는 법률에 의거한 행정청의 명령에 의한 행위로서 타인이 대신하여 행할 수 있는 행위를 의무자가 이행하지 아니하는 경우 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기 곤란하고 또한 그 불이행을 방치함이 심히 공익을 해할 것으로 인정될 때에는 당해 행정청은 스스로 의무자가 하여야 할 행위를 하거나 또는 제삼자로 하여금 이를 하게 하여 그 비용을 의무자로부터 징수할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제6조제1항에서는 대집행에 요한 비용은 「국세징수법」의 예에 의하여 징수할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「국세징수법」 제7조에서는 제2차 납세의무자등[63]에 대한 납부고지에 대해 규정하면서, 같은 조 제1항에서 관할 세무서장은 납세자의 체납액을 제2차 납세의무자등으로부터 징수하는 경우 징수하려는 체납액의 과세기간, 세목, 세액, 산출 근거, 납부하여야 할 기한, 납부장소, 제2차 납세의무자등으로부터 징수할 금액, 그 산출근거, 그 밖에 필요한 사항을 적은 납부고지서를 제2차 납세의무자등에게 발급하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 제1호에서는 납부고지의 대상 중 하나로 제2차 납세의무자[64]를 규정하고 있는바,

「행정대집행법」 제2조에 따른 의무자(이하 “의무자”라 함)가 대집행 비용 납부의무를 이행할 수 없는 경우, 행정청은 같은 법 제6조제1항을 근거로 「국세징수법」 제7조제1항 제1호의 예에 따라 「국세기본법」 제39조제2호에 따른 과점주주(이하 “과점주주”라 함) 등 제2차 납세의무자에 해당하는 자에게 대집행 비용을 징수할 수 있는지[65]?

---

63) 「국세징수법」 제7조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말하며, 이하 같음.

64) 「국세기본법」 제2조제11호에 따른 제2차 납세의무자를 말하며, 이하 같음

65) 개별 법령에서 행정상 의무 불이행자가 아닌 자에게 대집행 비용을 부담시키는 규정이 없는 것을 전제로 함.

02 회답

이 사안의 경우, 행정청은 「행정대집행법」 제6조제1항을 근거로 「국세징수법」 제7조제1항제1호의 예에 따라 과점주주 등 제2차 납세의무자에 해당하는 자에게 대집행 비용을 징수할 수 없습니다.

03 이유

먼저 「행정대집행법」 제6조제1항에서 대집행에 요한 비용은 "「국세징수법」의 예에 의하여 징수할 수 있다"라는 규정의 의미를 살펴보면, 통상 특정 조문을 그와 성질이 유사한 규율 대상에 대하여 그 성질에 따라 다소 수정하여 적용하는 것을 '준용'이라 하고, 이러한 준용형식 중의 하나로 어떠한 법률의 제도나 법령 규정을 포괄적으로 다른 규율 대상에 준용하려는 경우 '예에 따른다'는 표현을 사용하는 데[66], 「행정대집행법」 제6조제1항에서 대집행에 요한 비용은 '「국세징수법」의 예에 의하여 징수할 수 있다'고 규정한 것은 같은 법 제5조에 따른 비용납부 명령의 납기일까지 대집행 비용을 납부하지 않는 경우 그 비용을 징수하기 위해 독촉, 압류·매각 등 '대집행 비용 징수에 관한 일련의 절차'를 「국세징수법」에 따른다는 의미라고 해석하는 것이 문언에 부합하는 해석입니다.

즉, 「국세징수법」은 납부 의무가 확정된 국세의 징수에 필요한 사항을 정하는 법률로서 납세의무자에 대한 국세채권을 가진 국가가 그 채권을 실행하는 절차에 관하여 규정하고 있을 뿐이고 국가에 대하여 국세채무를 부담하는 자의 범위를 규정하고 있지는 않은바, 「행정대집행법」 제6조제1항에서 대집행 비용을 징수하는 절차에 관하여 「국세징수법」의 예에 따른다고 규정하고 있더라도 같은 법에 따라 대집행 비용을 납부할 의무를 부담하는 자가 결정되는 것은 아니므로[67], 이 사안과 같이 의무자가 대집행 비용 납부 의무를 이행할 수 없는 경우에는 행정청이 「행정대집행법」 제6조제1항을 근거로 제2차 납세의무자에 해당하는 자에게 대집행 비용을 징수할 수는 없다고 보는 것이 「국세징수법」 및 「행정대집행법」의 체계에 비추어 보았을 때 타당합니다.

그리고 「행정대집행법」에 의한 대집행 비용의 징수는 침익적 행정처분[68]으로서 그 근거가

66) 법제처 법령입안·심사기준(2023) P.804 참조

67) 수원지방법원 2021. 9. 30. 선고 2021구합63373 판결례 참조

되는 행정법규는 더욱 엄격하게 해석·적용하여야 하고, 행정처분의 상대방에게 지나치게 불리한 방향으로 확대해석하거나 유추해석을 해서는 안 된다고 할 것인데,[69] 「행정대집행법」 제2조에서는 대집행 비용 납부 의무를 부담하는 주체를 의무자로 규정하고 있고, 의무자가 비용 납부 의무를 이행하지 않은 경우 과점주주 등 제2차 납세의무자가 부담한다는 등의 명시적 규정도 두고 있지 않은바, 제2차 납세의무자에 해당하는 자에 대해 대집행 비용을 징수할 수 있다고 해석하는 것은 법령의 명시적인 근거 없이 금전납부 의무 부과 대상을 확대하는 해석으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 행정청은 「행정대집행법」 제6조제1항을 근거로 「국세징수법」 제7조제1항제1호의 예에 따라 과점주주 등 제2차 납세의무자에 해당하는 자에게 대집행 비용을 징수할 수 없습니다.

관계법령

행정대집행법

제6조(비용징수) ① 대집행에 요한 비용은 국세징수법의 예에 의하여 징수할 수 있다.
②·③ (생 략)

국세징수법

제7조(제2차 납세의무자 등에 대한 납부고지) ① 관할 세무서장은 납세자의 체납액을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 이 조에서 "제2차 납세의무자등"이라 한다)로부터 징수하는 경우 징수하려는 체납액의 과세기간, 세목, 세액, 산출 근거, 납부하여야 할 기한(납부고지를 하는 날부터 30일 이내의 범위로 정한다), 납부장소, 제2차 납세의무자등으로부터 징수할 금액, 그 산출 근거, 그 밖에 필요한 사항을 적은 납부고지서를 제2차 납세의무자등에게 발급하여야 한다.
1. 제2차 납세의무자
2. 보증인
3. 「국세기본법」 및 세법에 따라 물적납세의무를 부담하는 자(이하 "물적납세의무를 부담하는 자"라 한다)
② (생 략)

68) 서울행정법원 2020. 9. 18. 선고 2019구합5748 판결례 참조
69) 대법원 2018. 3. 27. 선고 2014두43158 판결례 참조

질의제목 12 ▶ 안건번호 24-0357

민원인 – 「지방자치법」 제33조제1항 본문에 따른 조례와 규칙의 공포 방법(「지방자치법」 제33조 등 관련)

01 질의요지

「지방자치법」 제33조제1항 본문에서는 '조례와 규칙의 공포는 해당 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 한다'고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 '같은 조 제1항에 따른 공보는 종이로 발행되는 공보(이하 "종이공보"라 함) 또는 전자적인 형태로 발행되는 공보(이하 "전자공보"라 함)로 운영한다'고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 '공보의 내용 해석 및 적용 시기 등에 대하여 종이공보와 전자공보는 동일한 효력을 가진다'고 규정하고 있는바,

조례와 규칙의 공포를 '종이공보'에는 게재하지 않고 '전자공보'에만 게재하는 방법으로 한 경우가 「지방자치법」 제33조제1항 본문에 따른 조례와 규칙의 공포에 해당하는지?

02 회답

조례와 규칙의 공포를 '종이공보'에는 게재하지 않고 '전자공보'에만 게재하는 방법으로 한 경우에도 「지방자치법」 제33조제1항 본문에 따른 조례와 규칙의 공포에 해당합니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것[70]인데, 「지방자치법」 제33조제1항 본문에서는 조례와 규칙의 공포는 해당 지방자치단체의 공보에 게재하는

70) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

방법으로 한다고 규정하면서 같은 조 제2항에서는 제1항에 따른 공보는 종이공보 "또는" 전자공보로 운영한다고 규정하고 있는바, "또는"이란 '그렇지 않으면'이라는 뜻으로서 어느 것을 선택해도 될 때에 쓰는 부사[71]라는 점을 고려할 때, 같은 조 제1항에 따른 공보는 종이공보로 발행될 수도 있고, 그렇지 않으면 전자공보로 발행될 수도 있으며, 두 가지 발행 방법을 병행하는 것도 가능하다고 할 것이므로, 조례와 규칙의 공포는 '전자공보'에만 게재하는 방법으로도 가능하다는 것이 같은 조 제1항 및 제2항의 문언상 명확합니다.

그리고 조례와 규칙 등의 공포 방법과 관련된 입법연혁을 살펴보면, 구「지방자치법」(2021. 1. 12. 법률 제17893호로 전부개정되어 2022. 1. 13. 시행되기 전의 것) 제26조제9항에서는 '조례와 규칙의 공포에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다'고 규정하고 있었고, 같은 항의 위임에 따라 마련된 구「지방자치법 시행령」(2021. 12. 16. 대통령령 제32223호로 전부개정되어 2022. 1. 13. 시행되기 전의 것) 제30조제1항 본문에서는 '같은 법 제26조에 따른 조례와 규칙의 공포는 해당 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 한다'고 규정하였을 뿐 구체적인 공보의 운영 방식에 대해서는 규정하지 않았던 반면, 2021년 1월 12일 법률 제17893호로「지방자치법」을 전부개정하면서 현행 규정과 같이 제33조를 두어 '공보는 종이공보 또는 전자공보로 운영한다'는 점(제2항)과, '공보의 내용 해석 및 적용 시기 등에 대하여 종이공보와 전자공보는 동일한 효력을 가진다'는 점(제3항)을 명시하였는바, '전자공보'의 경우 '종이공보'를 보완하는 부차적인 성격이 아니라 '종이공보'와 동일한 효력이 있는 공보 방식이라는 점이 법문언상 명확해졌다는 점에서도 조례와 규칙의 공포를 '종이공보'에는 게재하지 않고 '전자공보'에만 게재하는 방법으로 하는 경우에도「지방자치법」 제33조제1항 본문에 따른 조례와 규칙의 공포 방법에 해당한다고 보는 것이 지방자치법령의 입법연혁에도 부합하는 해석입니다.

따라서 조례와 규칙의 공포를 '종이공보'에는 게재하지 않고 '전자공보'에만 게재하는 방법으로 한 경우에도「지방자치법」 제33조제1항 본문에 따른 조례와 규칙의 공포에 해당합니다.

71) 법제처 알기 쉬운 법령 정비기준(열번째판) p.150 참조

관계법령

지방자치법

제33조(조례와 규칙의 공포 방법 등) ① 조례와 규칙의 공포는 해당 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법으로 한다. 다만, 제32조제6항 후단에 따라 지방의회의 의장이 조례를 공포하는 경우에는 공보나 일간신문에 게재하거나 게시판에 게시한다.

② 제1항에 따른 공보는 종이로 발행되는 공보(이하 이 조에서 “종이공보”라 한다) 또는 전자적인 형태로 발행되는 공보(이하 이 조에서 “전자공보”라 한다)로 운영한다.

③ 공보의 내용 해석 및 적용 시기 등에 대하여 종이공보와 전자공보는 동일한 효력을 가진다.

④ 조례와 규칙의 공포에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

질의제목 13 ▶ 안건번호 24-0404

서울특별시 – 공유재산 사용료 감경 사유 중 "행정재산의 사용에 제한을 받은 경우"의 의미(「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제17조제6항제3호 등 관련)

01 질의요지

「공유재산 및 물품 관리법」(이하 "공유재산법"이라 함) 제22조제1항 본문에서는 지방자치단체의 장은 행정재산을 사용허가한 때에는 대통령령으로 정하는 요율과 계산방법에 따라 매년 사용료를 징수하도록 규정하고 있고, 같은 법 제24조제2항에서는 지방자치단체의 장이 같은 법 제22조에도 불구하고 지역경제의 활성화를 위하여 필요한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사용료를 감경할 수 있다고 규정하면서, 그 위임에 따라 규정된 같은 법 시행령 제17조제6항제3호 본문에서 행정재산 사용료의 감경이 가능한 사유로 "해당 지방자치단체의 귀책사유로 사용허가를 받은 행정재산의 사용에 제한을 받은 경우"를 규정하고 있는바,

「공유재산 및 물품 관리법 시행령」(이하 "공유재산법 시행령"이라 함) 제17조제6항제3호에 따른 행정재산의 사용료 감경 가능 사유인 "행정재산의 사용에 제한을 받은 경우"는 휴업 등으로 사용허가 받은 행정재산의 전부 또는 일부의 사용·수익을 중단하게 된 경우로 한정되는지?[72]

02 회답

공유재산법 시행령 제17조제6항제3호에 따른 "행정재산의 사용에 제한을 받은 경우"는 휴업 등으로 사용허가 받은 행정재산의 전부 또는 일부의 사용·수익을 중단하게 된 경우로 한정되지 않습니다.

---

72) 행정재산의 유상 사용허가를 받은 경우로서 지방자치단체와 사용·수익자 간 체결한 협약 등에 지방자치단체의 귀책사유로 사용허가를 받은 행정재산의 사용 제한을 받은 경우의 처리에 관한 별도의 내용이 없고, 행정재산의 사용이 제한된 것에 대한 지방자치단체의 귀책사유는 존재하나, 사용·수익자의 귀책사유는 없는 경우를 전제함.

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 하는바,[73] 공유재산법 시행령 제17조제6항제3호에서 규정한 "행정재산의 사용에 제한을 받은 경우"의 의미를 해석할 때에도 같은 규정의 문언 및 입법취지, 공유재산법령의 전체적인 체계 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다.

먼저 공유재산법령에서는 '행정재산의 사용 제한'의 의미나 범위에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않으나, 공유재산법 제5조제2항에서는 행정재산을 사용 목적에 따라 공용재산, 공공용재산 등으로 구분하면서, 같은 법 제20조제1항에서는 지방자치단체의 장은 행정재산에 대하여 그 목적 또는 용도에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용허가를 할 수 있다고 규정하고 있고, 일반적으로 '사용'은 '일정한 목적이나 기능에 맞게 쓰는 것'을 의미한다는 점에서 같은 법 시행령 제17조제6항제3호에서의 '행정재산의 사용'이란 '행정재산을 그 정해진 사용 목적에 부합하게 쓰는 것'으로서, 해당 행정재산의 성질 및 종류, 사용을 통해 달성하려는 목적, 일반적인 사용 관행 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 할 것이며, '제한'이란 일반적으로 '일정한 한도를 정하거나 그 한도를 넘지 못하게 막음'을 의미[74]하는데, 구체적인 사안에서 이러한 행정재산의 사용이 제한되는 방식이나 그 범위 및 양태는 다양하여 행정재산의 사용은 하였더라도 지방자치단체의 귀책사유가 원인이 되어 해당 행정재산의 당초 목적대로의 사용을 방해받거나 그 사용에 있어 상당한 지장을 초래하여 실질적으로 사용·수익을 중단하게 된 경우에 준한다고 인정되는 경우에도 '행정재산의 사용 제한'에 해당될 수 있는 점[75]에 비추어 보면, 같은 법 시행령 제17조제6항제3호에서의 '행정재산의 사용에 제한을 받은 경우'의 범위가 사용허가 받은 행정재산의 전부 또는 일부의 사용·수익을 중단하게 된 경우로 한정된다고 볼 수는 없습니다.

그리고 지방자치단체의 장이 공유재산 중 행정재산의 사용·수익을 허가하는 것은 관리청이

73) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

74) 국립국어원 표준국어대사전 참조

75) 서울고등법원 2020. 9. 11. 선고 2019누57017 판결례 참조

'행정처분'을 통해 특정인에게 행정재산을 사용할 수 있는 권리를 특별히 설정하여 주는 강학상 특허에 해당[76]하고, 행정재산의 사용료는 이러한 행정재산의 사용·수익에 대한 대가로 보아야 할 것[77]인데, 사용·수익권자의 귀책사유 없이 행정재산의 정당한 사용을 방해받고 있는 기간까지 온전한 사용·수익에 상응하는 사용료 전부를 징수할 수 있다고 보기는 어렵다는 점[78]에 비추어 볼 때, 행정재산의 전부 또는 일부의 사용·수익을 중단하게 된 경우가 아니더라도 실질적으로 행정재산의 사용·수익자가 행정재산의 사용·수익과 관련해 받은 피해와 지방자치단체의 귀책사유와의 인과관계 등이 인정될 경우에는 지방자치단체의 장은 공유재산법 시행령 제17조제6항제3호에 따라 그 사용료의 감경 여부를 판단할 수 있다고 보아야 할 것입니다.

또한 공유재산법령상 그 부과조건이나 요율 및 계산방법 등이 명확히 규정되어 있는 사용료의 부과와는 달리 그 감경 요건에 관해서는 사용료 부과권자에게 문언의 통상적인 의미를 벗어나지 않는 범위 내에서 일정 부분 재량권을 허용하는 방향으로 해석하여 개별 사안에서의 구체적 타당성을 확보할 수 있도록 하는 것이 합리적이라는 점, 공유재산법 시행령 제17조제6항제3호에서 '사용 제한'에 대한 지방자치단체의 '귀책사유'가 있을 것을 사용료 감경 요건으로 규정하고 있어 해당 규정을 엄격해석의 원칙이 적용되는 명백한 특혜규정이라고 보기도 어려운 점[79]에 비추어 볼 때에도, 같은 규정의 내용은 행정재산 사용허가 대상자의 여건 등을 반영한 효과적인 지원 및 보상이 이루어질 수 있도록 문언의 통상적 의미를 벗어나지 않는 한도 내에서 그 입법 취지와 목적 등에 부합되도록 해석할 필요가 있으므로, "행정재산의 사용 제한"은 휴업 등으로 사용·수익을 중단하게 된 경우만으로 한정되지 않는다고 해석하는 것이 타당합니다.

나아가 공유재산법 시행령 제17조제7항제3호에서 지방자치단체의 장은 같은 조 제6항 제3호에 해당하는 경우 '사용·수익하지 못한 기간에 대한 사용료의 100분의 100 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 감경할 수 있다'고 규정하여 '행정재산 사용의 제한'으로 인한 사용료 감경의 구체적인 대상 및 범위를 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하고 있고, 지방자치단체에 두는 공유재산심의회의 심의사항으로 '같은 법 제24조에 따라 사용료를 감면하는 경우'를 규정하고 있어 이 사안과 같이 공유재산법 제24조제1항 및 같은 법 시행령 제17조제6항제3호에 따라 사용료를 감경하려는 경우에도 공유재산심의회의

76) 대법원 2006. 3. 9. 선고 2004다31074 판결례 참조
77) 대법원 2015. 3. 20. 선고 2012두430 판결례 등 참조
78) 서울고등법원 2020. 11. 13. 선고 2020누31424 판결례 참조
79) 법제처 2010. 6. 14. 회신 10-0161 해석례 참조

심의 대상이 되는 등 개별 사안에서 사용료의 감경에 대해 구체적 타당성 및 공정성을 확보할 수 있는 제도적 장치가 마련되어 있는바, 공유재산법 시행령 제17조제6항제3호에서의 '사용 제한'의 내용 및 범위에 대해서는 지방자치단체의 장이 해당 지방자치단체의 조례에서 정한 구체적인 내용, 해당 행정재산의 용도, 사용 제한으로 인한 피해 정도 및 그 감경 필요성 등에 대한 사항을 종합적으로 판단할 수 있도록 하여 합리적인 범위에서 사용료 감경이 이루어질 수 있도록 하는 것이 규정의 체계 및 취지에 부합한다고 할 것입니다.

아울러 행정재산의 사용료 감경 처분은 그 상대방에게 권리나 이익을 부여하는 수익적 행정처분이자 재량행위[80]로서, 공유재산법 시행령 제17조제6항제3호에 따른 '지방자치단체의 귀책사유'라는 감경 요건에 부합한다고 하더라도 지방자치단체의 장이 지방자치단체의 귀책사유로 인해 발생한 피해의 성격, 귀책사유와의 상당인과관계, 사용료 감경에 따른 효과 등을 비교형량하여 해당 사용료 감경 여부 및 그 감경의 정도를 구체적 사안에 따라 달리 판단할 수 있으므로, 해당 사용료 감경 대상이 지나치게 확대된다거나 자의적인 법 집행으로 인한 수범자의 권익이나 예측가능성을 심각하게 해치는 등의 부당한 결과가 초래된다고 보기 어렵다는 점, 해당 규정에 따른 사용료 감경이 행정재산의 사용과 관련한 지방자치단체와 사용·수익자 간의 법적 분쟁을 조기에 해결하는 기능을 가질 수도 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 공유재산법 시행령 제17조제6항제3호에 따른 "행정재산의 사용에 제한을 받은 경우"는 휴업 등으로 사용허가 받은 행정재산의 전부 또는 일부의 사용·수익을 중단하게 된 경우로 한정되지 않습니다.

관계법령

공유재산 및 물품관리법 시행령

제17조(사용료 감면) ① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 법 제24조제2항에서 "지역경제의 활성화를 위하여 필요한 경우 등 대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 경우를 말한다.

1.·2. (생 략)

3. 해당 지방자치단체의 귀책사유로 사용허가를 받은 행정재산의 사용에 제한을 받은 경우. 다만, 법 제21조제4항제2호에 따라 허가기간을 연장받은 경우는 제외한다.

80) 대법원 1987. 12. 8. 선고 87누861 판결례 참조

4. (생 략)
⑦ 지방자치단체의 장은 법 제24조제2항에 따라 행정재산의 사용료를 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 감경할 수 있다.
1.·2. (생 략)
3. 제6항제3호에 해당하는 경우: 사용·수익하지 못한 기간에 대한 사용료의 100분의 100

질의제목 14 ▶ 안건번호 24-0411

경기도 고양시 – 법률에서 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하면서 위임 조례에서 그 감면 기준을 정하고 있는 경우가 「공유재산 및 물품관리법」 제16조제2항제5호에 따른 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”에 해당되는지 등(「공유재산 및 물품관리법」 제16조제2항제5호 등 관련)

01 질의요지

「공유재산 및 물품관리법」(이하 “공유재산법”이라 함) 제16조제1항에서는 공유재산의 관리 및 처분에 관하여 지방자치단체의 장이 자문하기 위하여 각 지방자치단체에 공유재산심의회(이하 “심의회”라 함)를 둔다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항제5호에서는 심의회의 심의사항으로 “제24조 또는 제34조 및 그 밖에 다른 법률에 따라 사용료[81] 또는 대부료[82]를 감면하는 경우”를 규정하고 있는 한편,

「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」(이하 “도시재생법”이라 함) 제30조의2제1항에서는 지방자치단체의 장은 도시재생 활성화 등 공익 목적을 위하여 도시재생활성화지역 또는 도시재생 인정사업이 시행되는 지역(이하 “도시재생활성화지역등”이라 함) 내에서 같은 법 제2조제10호나목에 따른 공동이용시설(이하 “공동이용시설”이라 함)에 대한 공유재산법 제20조에 따른 사용허가를 하는 경우 같은 법 제22조에도 불구하고 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하고 있고, 도시재생법 제30조의2제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 공익 목적의 기준, 사용료 면제 대상 및 그 밖에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있는바[83],

가. 도시재생법 제30조의2제1항에서 공동이용시설의 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하면서 같은 조 제2항의 위임에 따라 마련된 조례에서 그 사용료의 면제 또는 경감의 구체적 기준, 감면 대상, 감면 대상별 감면 비율 등(이하 “사용료의 면제·경감 기준등”이라 함)을 정하고 있는 경우가 공유재산법 제16조제2항제5호[84]에 따른

81) 공유재산법 제22조에 따른 사용료를 말하며, 이하 같음.

82) 공유재산법 제32조에 따른 대부료를 말하며, 이하 같음.

83) 도시재생법 제30조의2제2항의 위임에 따라 마련된 지방자치단체의 조례에서 공유재산법 제16조에 따른 공유재산심의회의 심의를 거쳐야 한다는 규정을 두지 않은 경우를 전제로 함.

심의회의 심의 대상인 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”에 해당되는지?

나. 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료를 감면하는 경우”로서 도시재생법 제30조의2제1항에 따라 공동이용시설에 대한 공유재산법 제22조에 따른 사용료(이하 “사용료”라 함)를 면제 또는 경감하는 경우, 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 하는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 심의회의 심의 대상인 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”에 해당됩니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 합니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

도시재생법 제30조의2제1항에서는 지방자치단체의 장은 도시재생 활성화 등 공익 목적을 위하여 도시재생활성화지역등 내에서 공동이용시설에 대한 공유재산법 제20조에 따른 사용허가를 하는 경우 같은 법 제22조에도 불구하고 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 따른 공익 목적의 기준, 사용료 면제 대상 및 그 밖에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있는데, 공유재산법 제16조제2항제5호에서는 심의회의 심의 대상 중 하나로 “제24조 또는 제34조 및 그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”를 규정하고 있을뿐,

84) 조례에서 사용료 또는 대부료 감면에 대하여 규정하는 경우가 공유재산법 제16조제2항제6호에 따른 “그 밖에 공유재산의 관리·처분 등에 대하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 경우”에는 해당되지 않음을 전제로 함.

법률에서 위임받아 마련된 조례로 사용료의 면제·경감 기준등을 정하고 있는 경우가 심의회의 심의 대상인지 여부는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안과 같이 도시재생법 제30조의2제2항의 위임에 따라 마련된 조례에서 공동이용시설에 대한 사용료의 면제·경감 기준등을 정하고 있는 경우가 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 심의회의 심의 대상인 '그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우'에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

먼저 도시재생법 제30조의2제1항에는 지방자치단체의 장이 공동이용시설에 대한 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 그 사용료의 면제 대상 및 그 밖에 필요한 사항은 지방자치단체의 조례로 정할 수 있도록 위임하고 있는바, 도시재생법 제30조의2제2항의 위임에 따라 마련된 조례에서 사용료의 면제·경감 기준등을 정하고 있다고 하더라도 사용료를 감면할 수 있는 근거 자체는 도시재생법 제30조의2제1항, 즉 법률에 있는 것이고, 공유재산법에서 별도로 '사용료의 면제·경감 기준등을 조례로 정하는 경우' 심의회의 심의 대상에서 제외하도록 하는 명시적인 규정을 두고 있지 않은 이상, 이 사안과 같이 도시재생법에서 공동이용시설의 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다고 규정하면서 같은 법의 위임에 따라 마련된 조례에서 사용료의 면제·경감 기준등을 정하고 있는 경우는 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 '그 밖에 다른 법률에 따라' 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우에 해당한다고 보아야 할 것입니다.

그리고 공유재산법 제16조제2항제5호에서 또다른 심의회의 심의 대상으로 규정하고 있는 '같은 법 제24조 또는 제34조에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우'를 살펴보면, ①같은 법 제24조제2항에서는 지방자치단체의 장이 지역경제의 활성화를 위하여 필요한 경우 등에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사용료를 감경할 수 있다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제17조제7항에서는 행정재산의 사용료를 일정한 범위[85]에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 감경할 수 있다고 규정하고 있고, ②같은 법 제34조제2항에서는 지방자치단체의 장은 대통령령으로 정하는 경우에는 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대부료의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다고 규정하고 있어, '같은 법 제24조 또는 제34조에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우'에도 그 사용료 또는 대부료의 구체적 감면 대상 및 기준 등은 조례로 정하도록 하는 것이 전제되어 있는바, 이 사안과 같이 도시재생법 제30조의2제2항의 위임에 따라 공동이용시설 사용료의 면제·경감 기준등을 조례로 정하도록 하고 있는 경우에도 심의회의 심의 대상인 '그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우'에 해당된다고 보는 것이 공유재산법 제16조제2항

85) 공유재산법 시행령 제17조제7항 각 호의 구분에 따른 범위를 말함

제5호의 규정 체계에 비추어봤을 때 합리적인 해석입니다.

따라서 이 사안의 경우, 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 심의회의 심의 대상인 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”에 해당됩니다.

나. 질의 나에 대해

공유재산법 제16조제1항에서는 각 지방자치단체에 심의회를 둔다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분에서는 같은 조 제1항에 따른 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다고 규정하면서 같은 항 제5호에서 심의회가 심의하는 사항 중 하나로 “제24조 또는 제34조 및 그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우”를 규정하고 있는데, 같은 법 제16조제2항제5호에서 규정한 사항에 대해 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 하는지에 대하여 명시적으로 규정하고 있지 않은바, 이 사안에서는 공유재산법 제16조제2항제5호에 해당하는 경우로서 도시재생법 제30조의2제1항에 따라 공동이용시설에 대한 사용료를 면제 또는 경감하는 경우에 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 하는지가 문제됩니다.

먼저 공유재산법 제16조제1항 및 제2항에서는 심의회의 설치 근거 및 심의사항에 대하여 ‘심의회를 둘 수 있다’, ‘심의할 수 있다’와 같은 가능적 표현을 사용하지 않고 ‘심의회를 둔다’, ‘심의한다’는 단정적 표현을 사용하고 있는바, 이 규정을 그 문언의 통상적 의미로 해석하면 각 지방자치단체는 심의회를 두어야 하고, 그 심의사항으로서 “그 밖에 다른 법률에 따라 사용료를 감면하는 경우”에 대하여 심의회의 심의를 거쳐야 한다는 의미로 해석[86]될 수 있습니다.

그리고 심의회의 심의사항에 관하여 규정하고 있는 공유재산법 제16조제2항의 입법연혁을 살펴보면, ① 구 공유재산법[87] 제16조에서는 심의회의 설치 근거(제1항)를 두면서 그 구성과 운영에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다(제2항)고 규정하고 있었으나, 공유재산의 관리·처분에 대한 심의기능을 강화하고, 심의회 운영의 전국적 통일성을 기하기 위하여[88] 2015년 1월 20일 법률 제13017호로 일부개정된 공유재산법에서 제16조제2항을 신설하여 심의회의 심의사항을 각 호에서 구체적으로 규정하게 된 것이고, ② 종전 공유재산법[89] 제11조에 따르면 ‘지방자치단체의 장은 행정재산의 용도를 변경하거나

86) 대법원 2017. 12. 22. 선고 2014다223025 판결례 참조.

87) 2015. 1. 20. 법률 제13017호로 일부개정되기 전의 것을 말함

88) 공유재산법(2015. 1. 20, 일부개정되어 2015. 7. 21. 시행된 것을 말함) 국회검토보고서 참조.

89) 2021. 4. 20. 법률 제18086호로 일부개정되기 전의 것을 말함

폐지하려는 경우(제1호) 등에는 제16조에 따른 공유재산심의회의 심의를 거쳐야 한다'고 규정하고 있었는데, 2021년 4월 20일 법률 제18086호로 일부개정된 공유재산법에서는 제11조를 '지방자치단체의 장은 공유재산이 각 호의 용도변경 등 사유에 해당하는 경우에는 그 용도를 변경하거나 폐지할 수 있다'고 개정하면서, 제16조제2항에 심의회의 심의사항으로 제2호와 제3호를 신설하여 종전에 반드시 심의를 거쳐야 하는 사항이었던 행정재산의 용도변경 또는 폐지 등을 심의회의 심의사항에 추가한 것인바, 이러한 심의회의 기능과 관련한 입법연혁을 종합적으로 고려하면 공유재산법 제16조제2항제5호에 따른 "그 밖에 다른 법률에 따라 사용료를 감면하는 경우"에 대하여 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 한다고 보는 것이 그 입법연혁 및 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 공유재산법은 공유재산 및 물품을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리·처분하는 것을 목적(제1조)으로 하고 있고, 지방자치단체가 공유재산 관리·처분을 일관성 있게 수행함으로써 지방자치단체의 세외수입을 증대시키고, 공정성과 투명성을 높이기 위하여[90] 공유재산 관리·처분의 기본원칙(같은 법 제3조의2)을 별도로 두고 있는바, 이러한 공유재산법의 규정체계를 고려하면 세외수입과 관련된 공동이용시설의 사용료 감면에 대하여 심의회의 심의를 거쳐 공정하고 전문적인 판단을 하도록 할 필요성이 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 심의회의 심의를 반드시 거쳐야 합니다.



관계법령

공유재산 및 물품관리법

제16조(공유재산심의회) ① 공유재산의 관리 및 처분에 관하여 지방자치단체의 장이 자문하기 위하여 각 지방자치단체에 공유재산심의회를 둔다.

② 제1항에 따른 공유재산심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 제10조 및 제10조의2에 따라 중기공유재산관리계획 또는 공유재산관리계획을 수립하거나 변경하는 경우
2. 제11조에 따라 행정재산의 용도를 변경하거나 폐지하려는 경우
3. 제11조에 따라 일반재산을 행정재산으로 용도를 변경하려는 경우
4. 제12조 단서에 따라 무상으로 회계 간의 재산 이관을 하는 경우

90) 공유재산법(2010. 2. 4. 법률 제10006호로 일부개정되어 2010. 8. 5. 시행된 것을 말함) 개정이유 및 주요내용 참조.

5. 제24조 또는 제34조 및 그 밖에 다른 법률에 따라 사용료 또는 대부료를 감면하는 경우
6. 그 밖에 공유재산의 관리·처분 등에 대하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 경우
③·④ (생 략)

도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법

제30조의2(공동이용시설 사용료의 감면) ① 지방자치단체의 장은 도시재생 활성화 등 공익 목적을 위하여 다음 각 호에 해당하는 지역 내에서 제2조제10호나목에 따른 공동이용시설에 대한 「공유재산 및 물품 관리법」 제20조에 따른 사용허가를 하는 경우 같은 법 제22조에도 불구하고 사용료를 면제 또는 경감할 수 있다.
1. 도시재생활성화지역
2. 도시재생 인정사업이 시행되는 지역
② 제1항에 따른 공익 목적의 기준, 사용료 면제 대상 및 그 밖에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

질의제목 15 ▶ 안건번호 24-0463

민원인 – 「지방자치법」 제35조에 따른 보고의 대상은 조례·규칙심의회의 심의·의결을 거친 규칙을 의미하는지(「지방자치법」 제35조 등 관련)

01 질의요지

「지방자치법」 제35조에서는 조례나 규칙을 제정하거나 개정하거나 폐지할 경우 조례는 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에, 규칙은 공포 예정일 15일 전에 시·도지사[91]는 행정안전부장관에게, 시장·군수 및 자치구의 구청장은 시·도지사에게 그 전문(全文)을 첨부하여 각각 보고하여야 하며, 보고를 받은 행정안전부장관은 그 내용을 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제28조제1항에서는 지방자치단체의 장이 조례·규칙의 제출·제정·개정·폐지 및 공포 등을 하려는 경우에 지방자치단체의 장이 제정·개정·폐지하려는 규칙안(제3호) 등의 사항을 심의·의결하기 위하여 해당 지방자치단체의 장 소속으로 조례·규칙심의회(이하 "조례·규칙심의회"라 함)를 둔다고 규정하고 있는바,

「지방자치법」 제35조에 따라 행정안전부장관 또는 시·도지사에게 제정하거나 개정하거나 폐지할 규칙을 보고하는 경우, 같은 조에 따른 보고의 대상은 조례·규칙심의회의 심의·의결을 거친 규칙을 의미하는지?[92]

02 회답

이 사안의 경우, 「지방자치법」 제35조에 따른 보고의 대상은 조례·규칙심의회의 심의·의결을 거친 규칙을 의미한다고 할 것입니다.

91) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 의미하며, 이하 같음(「지방자치법」 제8조제2항 참조)
92) 「지방자치법」 제35조에 따라 규칙 공포 예정일 15일 전에 보고하는 경우를 전제함

03 이유

「지방자치법」 제35조에 따라 규칙을 제정하거나 개정하거나 폐지할 경우 그 공포 예정일 15일 전에 시·도지사는 행정안전부장관에게, 시장·군수 및 자치구의 구청장은 시·도지사에게 그 전문(全文)을 첨부하여 각각 보고하여야 하는데, 같은 조에 따른 보고의 대상이 조례·규칙심의회의 심의·의결을 거친 규칙을 의미하는지에 대해서는 지방자치법령에서 규정하고 있지 않으므로, 이에 관해서는 해당 규정의 입법취지와 목적 및 관련 규정의 체계 등을 종합적으로 고려하여 해석해야 합니다.

먼저 「지방자치법」 제35조에서 규칙을 제정하거나 개정하거나 폐지할 경우 시·도지사 또는 시장·군수·구청장[93]으로 하여금 행정안전부장관 또는 시·도지사에게 각각 보고하도록 규정하였는데, 같은 조에서 행정안전부장관 또는 시·도지사에게 제정하거나 개정하거나 폐지할 규칙을 보고할 때 단순히 규칙의 개요나 취지를 첨부하는 것이 아니라 "규칙의 전문(全文)"을 첨부하도록 한 점, 보고를 받은 행정안전부장관이 그 내용을 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하도록 하는 별도의 절차를 규정하고 있는 점, 같은 법 제29조에서 지방자치단체의 장은 법령 또는 조례의 범위에서 그 권한에 속하는 사무에 관하여 규칙을 제정할 수 있다고 규정하면서 같은 법 제30조에서는 시·군 및 자치구의 조례나 규칙은 시·도의 조례나 규칙을 위반해서는 아니 된다고 규정하여 조례와 규칙의 입법한계를 정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 같은 법 제35조에서 보고의무를 규정한 취지는 제정하거나 개정하거나 폐지할 규칙이 공포되기 전에 주무부장관 또는 시·도지사가 법령 위반 여부 등을 검토하기 위한 것으로 보아야 하므로, 같은 조에 따른 보고의 대상은 제정·개정·폐지를 위한 입법절차인 조례·규칙심의회를 거친 규칙을 의미한다고 보는 것이 같은 조의 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

또한 「지방자치법 시행령」 제28조제1항에서는 지방자치단체의 장이 조례·규칙의 제출·제정·개정·폐지 및 공포 등을 하려는 경우에 지방자치단체의 장이 제정·개정·폐지하려는 규칙안 등을 심의·의결하기 위하여 해당 지방자치단체의 장 소속으로 조례·규칙심의회를 둔다고 규정하고 있는데, 「지방자치법 시행령」 제28조에서 조례·규칙심의회를 둔 것은 조례안이나 규칙안의 내용 등이 적정하고 타당한지 여부를 집행기관에서 최종적으로 검토하여 지방자치단체의 장이 조례·규칙심의회의 심의·의결 결과에 따라 조례안이나 규칙안의 지방의회 제출 여부 또는 공포 여부를 결정할 수 있도록 하려는 것인 점을 고려하면[94],

93) 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음

제정·개정·폐지하려는 규칙안은 조례·규칙심의회에서 그 내용의 적정성이나 타당성을 검토하여 수정될 수 있는바, 만약 조례·규칙심의회의 심의·의결을 거치지 않은 규칙도 「지방자치법」 제35조에 따른 보고의 대상이 된다고 본다면, 해당 규칙에 대한 보고 이후에 그 규칙의 내용이 다시 수정될 가능성이 있어 제35조에 따라 주무부장관 또는 시·도지사에게 보고하도록 한 규정의 취지가 사실상 무의미해질 수 있으므로, 같은 법 제35조에 따른 보고의 대상은 조례·규칙심의회에서 심의·의결을 거친 규칙을 의미한다고 해석하는 것이 합리적입니다.

한편 조례·규칙심의회는 「지방자치법」이 아닌 같은 법 시행령 제28조에 근거를 두고 있으므로 「지방자치법」 제35조에 따른 보고의 대상이 되는 규칙을 같은 법 시행령에 근거한 조례·규칙심의회의 심의·의결을 거친 규칙으로 해석하는 것은 타당하지 않다는 의견이 있으나, 「지방자치법」 제35조는 직접 국민을 기속하는 내용이 아니라 지방자치단체의 자치법규 입법절차에 관한 것이고, 이 사안은 지방자치단체에서 규칙의 입법절차 중 어느 단계에서 같은 조에 따라 보고를 해야 하는지와 관련된 문제로 「지방자치법」의 집행을 위하여 필요한 내용으로 볼 수 있고, 같은 법 시행령에서도 규칙에 관한 입법절차를 규정하고 있으므로, 이러한 지방자치법령의 체계를 조화롭게 해석하여 같은 법 제35조에 따라 보고의 대상이 되는 규칙은 조례·규칙심의회의 심의·의결을 거친 것으로 보아야 한다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「지방자치법」 제35조에 따른 보고의 대상은 조례·규칙심의회의 심의·의결을 거친 규칙을 의미한다고 할 것입니다.

관계법령

지방자치법

제35조(보고) 조례나 규칙을 제정하거나 개정하거나 폐지할 경우 조례는 지방의회에서 이송된 날부터 5일 이내에, 규칙은 공포 예정일 15일 전에 시·도지사는 행정안전부장관에게, 시장·군수 및 자치구의 구청장은 시·도지사에게 그 전문(全文)을 첨부하여 각각 보고하여야 하며, 보고를 받은 행정안전부장관은 그 내용을 관계 중앙행정기관의 장에게 통보하여야 한다.

94) 법제처 2017. 9. 29. 회신 17-0485 해석례 참조

지방자치법 시행령

제28조(조례·규칙심의회) ① 지방자치단체의 장이 조례·규칙의 제출·제정·개정·폐지 및 공포 등을 하려는 경우에 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 해당 지방자치단체의 장 소속으로 조례·규칙심의회(이하 이 장에서 "조례·규칙심의회"라 한다)를 둔다.

1. 지방자치단체의 장이 지방의회에 제출하는 조례안
2. 지방의회의 의결을 거친 조례 공포안. 다만, 지방자치단체의 장이 지방의회에 제출하여 원안 의결된 조례 공포안은 제외한다.
3. 지방자치단체의 장이 제정·개정·폐지하려는 규칙안
4. 예산안·결산 등 지방의회에 제출하는 안건 중 지방자치단체의 장이 조례·규칙심의회의 심의·의결이 필요하다고 인정하는 안건

② ~ ④ (생 략)

질의제목 16 ▶ 안건번호 24-0501

민원인 – 「이북5도 및 미수복 시·군의 명예시장·군수 등 위촉에 관한 규정」 제6조제3항의 "연임"의 범위(「이북5도 및 미수복 시·군의 명예시장·군수 등 위촉에 관한 규정」 제6조제3항 등 관련)

01 질의요지

「이북5도 등에 관한 특별조치법」(이하 "이북5도법"이라 함) 제6조에서는 이북5도등[95]의 행정기구는 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 규정된 「이북5도 및 미수복 시·군의 명예시장·군수 등 위촉에 관한 규정」(이하 "이북5도명예시장등위촉규정"이라 함) 제6조제1항에서는 이북5도등 시의 동·리에 명예동장·이장을 두고, 군의 읍·면에는 명예읍장·면장을 둘 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제3항에서는 명예동장·이장·읍장·면장의 임기는 3년으로 하되, 1차에 한하여 연임할 수 있다고 규정하고 있는바,

이북5도등 군 내 A면의 명예면장으로 위촉된 자가 임기만료 후 A면과 같은 군 내 B면의 명예면장으로 위촉되는 경우, 이북5도명예시장등위촉규정 제6조제3항에 따른 "연임"에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 이북5도명예시장등위촉규정 제6조제3항에 따른 "연임"에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 이북5도명예시장등위촉규정 제6조제1항에서는 이북5도등 군의 면에는 명예면장을 둘 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 명예면장은 1945년 8월 15일 현재의 면

95) "이북5도등"이란 이북5도 및 미수복 시·군을 말하며(이북5도법 제4조 참조), 이하 같음

단위로 위촉한다고 규정하여 '행정구역인 면을 기준'으로 면별로 명예면장을 위촉하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 명예면장의 임기는 3년으로 하되, 1차에 한하여 "연임"할 수 있다고 규정하고 있는바, 통상 "연임"은 원래 정해진 임기를 다 마친 뒤에 다시 계속하여 그 직위에 머무르는 것을 의미[96]하고, 여기서의 "그"란 앞에서 이미 이야기한 대상을 가리킬 때 쓰는 말[97]로 "그 직위"란 임기를 다 마친 지역과 같은 행정구역인 면의 명예면장의 직위를 의미한다고 보아야 할 것[98]이므로, 같은 규정 제6조에서 규정하고 있는 문언의 의미를 종합하면 이북5도등 군 내 A면의 명예면장으로 위촉된 자가 임기만료 후 A면과 행정구역을 달리하는 B면의 명예면장으로 위촉되는 것은 "다른 행정구역"의 사무를 관장하는 "다른 직위에 위촉되는 것"으로 "연임"에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 타당합니다.

그리고 이북5도명예시장등위촉규정의 위임에 따라 마련된 「이북5도 등 명예시장·군수 및 명예읍·면·동장 등에 관한 규정」(이하 "이북5도명예면장등규정"이라 한다) 제6조에 따르면 명예면장은 명예시장·군수의 업무를 보좌하고(제2호), 면민의 실태파악 및 계도(제3호), 면민에 대한 애향심 고취 및 친목도모(제4호) 등 관할 행정구역 내 면민에 대한 지원·관리 등의 업무를 수행하는데, 이북5도명예시장등위촉규정 제6조제3항에서 명예면장의 임기는 3년으로 하되, "1차에 한하여 연임할 수 있다"는 규정을 두어 임기가 있는 자의 연임을 제한한 것은 특정인이 같은 지역에서 명예면장으로 장기간 재임하며 특정집단과의 결탁 등을 통해 부정부패가 발생하는 것을 방지하기 위한 취지로 볼 수 있는바,[99] 행정구역을 달리하는 면(B)의 명예면장으로 새롭게 위촉되어 B면의 면민에 대한 명예면장으로서의 업무를 담당하는 경우에는 이러한 문제가 발생할 가능성이 낮아지고, 이북5도명예시장등위촉규정에서는 명예면장으로 위촉되었던 자가 임기만료 후 행정구역을 달리하는 면의 명예면장으로 위촉되는 것을 제한하는 내용을 명시적으로 규정하고 있지도 않으므로, 이북5도등 군 내 A면의 명예면장으로 위촉된 자가 임기만료 후 A면과 행정구역을 달리하는 B면의 명예면장으로 위촉되는 것은 "연임"에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 연임 제한 규정의 취지에 부합하는 해석입니다.

한편 이북5도등 동일한 군 내의 명예면장의 경우 행정구역별로 사무가 다르거나, 그 직위에 차이가 있다고 보기 어려워 이북5도등 군 내 A면의 명예면장으로 위촉된 자가 임기만료 후 A면과 행정구역을 달리하는 B면의 명예면장으로 위촉되는 것은 "연임"에 해당한다는 의견이

96) 국립국어원 표준국어대사전; 법제처 2019. 2. 1. 회신 18-0562 해석례 참조
97) 국립국어원 표준국어대사전; 법제처 2024. 6. 5. 회신 24-0307 해석례 참조
98) 법제처 2019. 5. 29. 회신 19-0183 해석례 참조
99) 법제처 2019. 11. 11. 회신 19-0489 해석례 참조

있으나, 이북5도명예면장등규정 제6조에 따라 명예면장은 명예군수의 업무보좌(제2호)를 비롯하여 면민의 실태파악 및 계도(제3호), 면민에 대한 애향심 고취 및 친목도모(제4호), 기타 이북5도등의 행정에 관한 사항(제5호) 등 해당 행정구역 내 면과 관련된 고유한 업무를 수행한다고 할 것이고, 비록 명예면장이 명예직이라고 하더라도 법령에서 정하고 있는 명예면장으로서의 각 행정구역별 업무에 대한 의무를 면하게 되는 것도 아닌 점[100]을 고려하면, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 이북5도명예시장등위촉규정 제6조제3항에 따른 "연임"에 해당하지 않습니다.

관계법령

이북5도 등에 관한 특별조치법

제6조(행정기구) 이북5도등의 행정기구는 대통령령으로 정한다.

이북5도 및 미수복 시·군의 명예시장·군수 등 위촉에 관한 규정

제6조(명예동장 등) ① 이북5도등 시의 동·리에 명예동장·이장을 두고, 군의 읍·면에는 명예읍장·면장을 둘 수 있다.
② 명예동장·이장·읍장·면장은 이북5도등에 대하여 1945년 8월 15일 현재의 동·리·읍·면 단위로 위촉하되, 명예직으로 한다. 다만, 명예동장·이장은 둘 이상의 동과 리를 통합하여 위촉할 수 있다.
③ 명예동장·이장·읍장·면장의 임기는 3년으로 하되, 1차에 한하여 연임할 수 있다.
④ 명예동장·이장·읍장·면장의 위촉 및 직무 등에 관하여 필요한 세부사항은 법 제7조에 따른 이북5도위원회가 정한다.

100) 대법원 2007. 5. 31. 선고 2007다248 판결례 참조

질의제목 17 ▶ 안건번호 24-0537

민원인 – 「저작권법」 제55조에 따른 저작권 등의 등록 신청 대리 업무가 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지 여부(「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理) 업무를 행정사[101]의 업무로 규정하고 있는 한편, 「저작권법」 제53조 및 제54조에서는 저작자[102]는 저작물[103]의 제호·종류·창작연월일 및 저작자의 실명·이명 등 및 저작재산권의 양도 또는 처분제한 등(이하 "저작권등"이라 함)을 등록할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제55조제1항에서는 같은 법 제53조 및 제54조에 따른 등록은 한국저작권위원회(이하 "위원회"라 함)가 저작권등록부[104]에 기록함으로써 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제26조제1항에서는 같은 법 제53조 및 제54조에 따른 등록을 하려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 등록신청서를 위원회에 제출해야 한다고 규정하고 있는바,

「저작권법」 제55조 및 같은 법 시행령 제26조에 따라 저작권등의 등록 신청을 대리하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 포함되는지?[105]

02 회답

「저작권법」 제55조 및 같은 법 시행령 제26조에 따라 저작권등의 등록 신청을 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 포함됩니다.

---

101) 「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제1호에 따른 일반행정사를 말하며, 이하 같음

102) 「저작권법」 제2조제2호에 따른 저작자를 말하며, 이하 같음.

103) 「저작권법」 제2조제1호에 따른 저작물을 말하며, 이하 같음.

104) 프로그램의 경우에는 프로그램등록부를 말하며, 이하 같음.

105) 본 안건은 「저작권법」에 따른 저작권등의 등록 신청 대리가 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 업무 범위에 해당하는지 여부로 논의를 한정하고, 해당 업무가 같은 법 제3조제1항에 따라 행정사가 아닌 사람이 업(業)으로 수행할 수 있는 '다른 법률에 따라 허용되는 업무'인지는 별도로 논의하지 않음

03 이유

「행정사법」 제2조제1항제5호에서는 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 수행할 수 있는 업무의 하나로 '인가·허가 및 면허 등(이하 "인허가등"이라 함)을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등(이하 "신청등"이라 함)의 대리(代理)' 업무를 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 같은 법 제2조제1항제5호에 따라 행정사가 수행할 수 있는 대리 업무의 내용과 범위를 '다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관의 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일'로 구체화하고 있는바, 「저작권법」에 따라 위원회에 저작권등에 대한 등록 신청을 대리하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 업무 범위에 포함되기 위해서는 ① 위원회가 "행정기관"에 해당하고, ② 위원회에 저작권등의 등록 신청을 하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제5호의 '인허가등'의 '신청등'에 해당해야 할 것입니다.

먼저 위원회가 "행정기관"에 해당하는지를 살펴보면, 행정사법령에서는 행정기관의 정의나 그 범위 및 종류에 대하여 특별히 규정하고 있지 않으나, 일반적으로 "행정기관"은 "국가 또는 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 기관[106]"을 의미하고, 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 행정기관 상대 민원 업무를 대신하거나 도와주는 일을 하는 직역으로서, 행정사의 본래적인 업무는 공적 영역인 행정기관의 업무에 관한 것[107]이므로, 「행정사법」 제2조에서의 "행정기관"은 공적 성격의 업무를 수행하는 공법적 주체[108]로서, 같은 조 제1항제5호에 따라 행정사가 대리할 수 있는 업무 범위는 그 행정기관에 하는 신청·청구 등 행정업무에 관한 사항이여야 할 것입니다.

그런데 「저작권법」상의 저작권등의 등록 제도에 대해 살펴보면, 저작권등의 공정한 이용 및 저작재산권 거래에 있어서의 안전을 도모하기 위하여[109] 법률에서 정한 일정한 사항을 저작권등록부에 기록하게 하여 저작권등을 등록하게 되면 공시효과가 발생하게 되고, 등록된 일정한 사항에 대해서는 추정의 효력이 있으며(법 제53조제3항), 권리 변동 등에 대해 제3자에게 대항할 수 있는 대항력이 발생(법 제54조)하는바, 이러한 효력을 발생하게 하는 저작권등의 등록에 관한 사무는 저작자의 권리 등을 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모하기 위한 공익적 목적으로 수행되는 '공적 성격의 업무'로 보아야 할 것입니다.

106) 국립국어원 표준국어대사전 참조

107) 헌법재판소 2015. 3. 26. 결정, 2013헌마131 결정례 참조

108) 법제처 2016. 10. 24. 회신 16-0262 해석례 및 2022. 10. 28. 회신 22-0483 해석례 참조

109) 오승종, 저작권법 제6판, 박영사(2024) 1199p 참조

그리고 위원회는 저작권에 관한 사항을 심의하고, 저작권 등록에 관한 업무 등을 수행하기 위하여 「저작권법」 제112조제1항에 따라 설립된 공공기관[110]으로서, 같은 법 제55조제1항에서 같은 법 제53조 및 제54조에 따른 등록은 위원회가 저작권등록부에 기록함으로써 한다고 규정하여 저작권등의 등록과 관련된 행정권한을 법률에 의해 부여받았고, 위원회의 저작권등 등록 신청 반려처분에 대해 신청인이 제기한 이의신청의 각하 또는 기각 결정은 행정심판 및 행정소송의 대상(법 제55조제5항)이 되며, 등록처분의 무효확인소송 또는 해당 반려처분 및 이의신청 각하 또는 기각 결정 등에 불복하여 취소소송을 제기하는 경우 위원회가 해당 행정소송의 피고가 되는 점[111] 등을 종합해 보면, 위원회는 저작권등의 등록 업무와 관련하여 「저작권법」에 따라 국민의 권리관계에 영향을 미치는 '행정업무'를 수행하는 '공법적 주체'로서 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 '행정기관'에 해당한다고 보아야 합니다.

다음으로 저작권등의 등록이 '인허가등'에 해당하는지를 살펴보면, 일반적으로 법령에서 하나 또는 수개의 사항을 열거하고 그 뒤에 "등"을 사용한 경우 열거된 사항은 예시사항이라 할 것이고, 별도로 해석해야 할 특별한 이유가 없는 한 그 "등"에는 열거된 예시사항과 규범적 가치가 동일하거나 그에 준하는 성질을 가지는 사항이 포함되는 것으로 해석함이 상당하다 할 것인바[112], 「행정사법」 제2조제1항제5호에서의 '인허가등'은 인가·허가 및 면허에 준하는 것으로서 복수의 대등한 당사자 사이의 사법상 법률관계가 아닌 공법적 효과 발생을 목적으로 하는 공공적 성격의 공법적인 성질에 관한 것을 의미합니다.[113]

통상 강학상의 "등록"은 일정한 사실이나 법률관계를 행정기관에 비치된 장부에 등재하고 이에 따라 일정한 사실이나 법률관계의 존부를 공적으로 증명하는 것으로, 저작권등의 등록 제도는 같은 법 제55조제1항에 따라 위원회가 그 저작권등과 관련된 내용을 저작권등록부에 기록함으로써 그 등록의 효과가 발생하는 점, 앞서 살펴 본 바와 같이 위원회에 일정한 절차를 거쳐 저작권등을 등록하게 되면 그 등록된 내용에 따른 저작자 등의 추정, 저작재산권 등에 대한 대항력의 발생, 저작권 침해자의 침해행위에 대한 과실을 추정할 수 있게 되는 등의 일정한 공법상 효과가 발생한다는 점을 종합해 보면, '저작권등의 등록'은 행정기관에 해당하는 위원회가 일정한 공법적 효과 발생을 목적으로 신청등을 받아 저작권등록부에 저작권등과 관련한 일정한 사항을 기재하는 것으로서 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 '인허가등'에 해당된다고 할 것입니다.

---

110) 한국저작권위원회는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제2호에 따른 기타공공기관으로 분류됨

111) 대법원 2009. 7. 9. 선고 2007두16608 판결례, 서울고등법원 2022. 12. 13. 선고 2022누48044 판결례 등 참조

112) 법제처 2014. 10. 10. 회신, 14-0498 해석례 참조

113) 법제처 2016. 10. 24. 회신 16-0262 해석례 참조

따라서 「저작권법」 제55조 및 같은 법 시행령 제26조에 따라 저작권등의 등록 신청을 대리하는 것은 「행정사법」 제2조제1항제5호에 따른 행정사의 업무에 포함됩니다.

관계법령

행정사법

제2조(업무) ① 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)
6.·7. (생 략)

② 제1항에 따른 업무의 내용과 범위는 대통령령으로 정한다.

저작권법

제53조(저작권의 등록) ① 저작자는 다음 각 호의 사항을 등록할 수 있다.

1. 저작자의 실명·이명(공표 당시에 이명을 사용한 경우로 한정한다)·국적·주소 또는 거소
2. 저작물의 제호·종류·창작연월일
3. 공표의 여부 및 맨 처음 공표된 국가·공표연월일
4. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

②·③ (생 략)

제54조(권리변동 등의 등록·효력) 다음 각 호의 사항은 이를 등록할 수 있으며, 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.

1. 저작재산권의 양도(상속 그 밖의 일반승계의 경우는 제외한다) 또는 처분제한
2. 제57조에 따른 배타적발행권 또는 제63조에 따른 출판권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분제한
3. 저작재산권, 제57조에 따른 배타적발행권 및 제63조에 따른 출판권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분제한

제55조(등록의 절차 등) ①제53조 및 제54조에 따른 등록은 위원회가 저작권등록부(프로그램의 경우에는 프로그램등록부를 말한다. 이하 같다)에 기록함으로써 한다.

② ~ ⑦ (생 략)

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 등록, 등록신청의 반려, 이의신청, 등록공보의 발행 또는 게시, 저작권등록부의 열람 및 사본의 발급 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

저작권법 시행령

제26조(등록신청) ① 법 제53조 및 법 제54조에 따른 등록을 하려는 자는 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 등록신청서를 위원회에 제출해야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

질의제목 18 ▶ 안건번호 24-0637

인천광역시 남동구 – 국가등이 표시·설치하는 공공목적의 광고물등의 기준 적용 방법(「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조제2항 등 관련)

01 질의요지

「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」(이하 "옥외광고물법"이라 함) 제6조제2항 본문에서는 대통령령으로 정하는 광고물등[114]을 제외하고는 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 "국가등"이라 함)가 공공의 목적으로 광고물등을 표시·설치하려는 경우에도 제3조, 제3조의2, 제4조, 제4조의2, 제4조의3 및 제4조의4[115]를 적용한다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 주요 정책 또는 사업의 효율적 홍보·안내 등 공익목적 달성을 위하여 불가피하다고 인정되어 대통령령으로 정하는 표시·설치 기준 등에 맞는 광고물등에 대하여는 그러하지 아니하다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제29조제1항제1호에서는 같은 법 제6조제2항 본문에 따른 "대통령령으로 정하는 광고물등" 중 하나로 국가등의 청사 또는 건물 벽면을 이용하는 간판(면적이 5제곱미터 이상인 간판은 제외한다)을 규정하고 있고, 같은 영 제29조제3항제1호 전단에서는 같은 법 제6조제2항 단서에 따른 "대통령령으로 정하는 표시·설치 기준 등에 맞는 광고물등" 중 하나로 국가등의 청사 또는 건물의 부지 안에 설치하는 홍보용 간판 1개를 규정하고 있는바,

지방자치단체에서 주요 정책 또는 사업의 홍보·안내 등을 위하여 지방자치단체 건물의 벽면을 이용하여 면적이 5제곱미터를 초과하는 홍보용 간판 1개를 설치하려는 경우[116], 옥외광고물법 제6조제2항 본문에 따라 같은 법 제3조 등[117]을 적용해야 하는지, 아니면 옥외광고물법 제6조제2항 단서에 따라 같은 법 제3조 등을 적용하지 않아도 되는지?

---

114) 옥외광고물 또는 게시시설을 의미하며(옥외광고물법 제2조제2호 및 제3조제1항 참조), 이하 같음

115) 제3조(광고물등의 허가 또는 신고), 제3조의2(광역단위 광고물에 관한 허가 등 예외), 제4조(광고물등의 금지 또는 제한 등), 제4조의2(광고물등 자율관리구역), 제4조의3(광고물등 정비시범구역), 제4조의4(광고물등 자유표시구역)

116) 옥외광고물법 제6조제2항 단서에 따라 공익목적 달성을 위하여 불가피하다고 인정되는 경우로 같은 법 시행령 제29조제3항제1호의 국가등의 청사 또는 건물의 부지 안에 설치하는 경우를 전제함

117) 옥외광고물법 제3조, 제3조의2, 제4조, 제4조의2, 제4조의3 및 제4조의4를 의미하며, 이하 같음

02 회답

이 사안의 경우, 옥외광고물법 제6조제2항 단서에 따라 같은 법 제3조 등을 적용하지 않아도 됩니다.

03 이유

먼저 옥외광고물법 제6조제2항 본문에서는 대통령령으로 정하는 광고물등을 제외하고는 국가등이 공공의 목적으로 광고물등을 표시·설치하려는 경우에도 제3조 등을 적용한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제29조제1항에서는 '같은 법 제6조제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 광고물등"이란 국가등이 표시하는 다음 각 호의 광고물등으로서 같은 영에 따른 표시방법에 맞는 광고물등을 말한다'고 규정하면서, 같은 항 제1호에서 '국가등의 청사 또는 건물 벽면을 이용하는 간판(면적이 5제곱미터 이상인 간판은 제외한다)'을 규정하고 있는바, 원칙적으로 국가등이 청사 또는 건물 벽면을 이용하여 설치하는 간판인 경우에도 그 면적이 5제곱미터 이상인 경우에는 옥외광고물법 제6조제2항 본문에 따라 같은 법 제3조 등을 적용해야 할 것입니다.

그런데 옥외광고물법 제6조제2항 단서에서는 주요 정책 또는 사업의 효율적 홍보·안내 등 공익목적 달성을 위하여 불가피하다고 인정되어 대통령령으로 정하는 표시·설치 기준 등에 맞는 광고물등에 대하여는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제29조제3항제1호에서는 같은 법 제6조제2항 단서에서 "대통령령으로 정하는 표시·설치 기준 등에 맞는 광고물등" 중 하나로 '국가등의 청사 또는 건물의 부지 안에 설치하는 홍보용 간판 1개. 이 경우 지주 이용 간판, 옥상간판 또는 건물 등의 벽면을 이용하는 광고물등 중 하나를 선택하여야 한다'고 규정하고 있는바, 옥외광고물법 제6조제2항 단서 및 같은 법 시행령 제29조제3항제1호에서 국가등의 건물의 부지 안에 설치하는 홍보용 간판 1개(건물 등의 벽면을 이용하는 광고물등)에 대해서는 간판의 면적과 관계 없이 같은 법 제3조 등의 적용을 받지 않도록 하여 같은 법 제6조제2항 본문에 대한 예외를 인정하고 있으므로, 지방자치단체가 지방자치단체 건물의 벽면을 이용하여 면적이 5제곱미터를 초과하는 홍보용 간판 1개를 설치하려는 이 사안의 경우 문언상 옥외광고물법 제6조제2항 단서에 따라 같은 법 제3조 등을 적용하지 않아도 된다고 할 것입니다.

또한 옥외광고물법 제6조제2항의 입법연혁을 살펴보면, 종전 옥외광고물법[118]에서는 국가 등이 설치하는 공공목적 광고물등은 허가·신고기준 및 설치 금지지역에 관계없이 설치할 수 있었으나, 공공목적 광고물등의 무분별한 난립을 막기 위하여 2007년 12월 21일 법률 제8737호로 일부개정된 옥외광고물법에서 제6조제2항을 신설하여 공공목적 광고물등에 대해서도 "대통령령이 정하는 설치·표시 기준 등"에 합치되는 경우에만 설치를 허용하도록 한 것으로서[119], 옥외광고물법 제6조제2항 단서의 위임에 따라 같은 법 시행령 제29조제3항에서 "대통령령으로 정하는 표시·설치 기준 등에 맞는 광고물등"을 구체적으로 열거하고 있고, 이 사안의 광고물등은 같은 항 제1호의 기준에 부합하는 홍보용 간판 1개로 대통령령으로 정하는 표시·설치 기준에 합치된다고 할 것이므로, 옥외광고물법 제6조제2항 단서에 따라 같은 법 제3조 등을 적용하지 않아도 된다고 보는 것이 입법연혁 및 취지에도 부합하는 해석입니다.

아울러 옥외광고물법 제6조제2항 단서 및 같은 법 시행령 제29조제3항제1호에서는 같은 법 제3조 등의 적용이 제외되는 광고물등인 "대통령령으로 정하는 표시·설치 기준 등에 맞는 광고물등"으로 국가등의 청사 또는 건물의 부지 안에 설치하는 홍보용 간판 '1개'를 규정하여 설치할 수 있는 수량을 제한하고 있고, 같은 영 제29조제4항에 따라 국가등은 같은 조 제3항 각 호의 광고물등을 표시하려면 관할 시장등[120]과 미리 협의하여야 하며, 같은 조 제7항에 따라 시장등은 광고물등의 안전성 확보, 차량 교통 및 보행안전의 확보, 도시미관 및 쾌적한 생활 환경 조성을 위하여 특히 필요하다고 인정하면 같은 조 제3항에 따른 광고물등의 설치 장소·수량 등을 제한할 수 있는바, 옥외광고물법 제6조제2항 단서에 따라 같은 법 제3조 등을 적용하지 않는다고 하더라도 무분별한 공공목적 광고물등의 설치를 예방할 수 있는 제도가 마련되어 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 옥외광고물법 제6조제2항 단서에 따라 같은 법 제3조 등을 적용하지 않아도 됩니다.

---

118) 2007. 12. 21. 법률 제8737호로 일부개정되기 전의 것을 말함

119) 2007. 12. 21. 법률 제8737호로 일부개정되어 같은 날 시행된 옥외광고물법 관련 국회 행정자치위원회 검토보고서 참조

120) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장을 말하며(옥외광고물법 제3조 참조), 이하 같음

관계법령

옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률

제6조(다른 법령 또는 국가등의 광고물 제한) ① 다른 법령 또는 조례에서 광고물등의 표시·설치에 관하여 제3조제3항·제6항, 제4조제1항·제4항, 제4조의2제2항, 제4조의3제2항 전단 및 제4조의4제2항의 특례를 규정하려는 경우(다른 법령 또는 조례에서 이미 특례 규정이 있을 때에는 그 규정에 따라 광고물등을 표시·설치하는 경우를 포함한다)에는 미리 행정안전부장관과 해당 광고물등의 종류, 수량 및 위치 등을 협의하여야 한다.

② 대통령령으로 정하는 광고물등을 제외하고는 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 "국가등"이라 한다)가 공공의 목적으로 광고물등을 표시·설치하려는 경우에도 제3조, 제3조의2, 제4조, 제4조의2, 제4조의3 및 제4조의4를 적용한다. 다만, 주요 정책 또는 사업의 효율적 홍보·안내 등 공익목적 달성을 위하여 불가피하다고 인정되어 대통령령으로 정하는 표시·설치 기준 등에 맞는 광고물등에 대하여는 그러하지 아니하다.

③ ~ ⑥ (생 략)

옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령

제29조(공공목적 광고물등의 표시방법) ① 법 제6조제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 광고물등"이란 국가등이 표시하는 다음 각 호의 광고물등으로서 이 영에 따른 표시방법에 맞는 광고물등을 말한다.

1. 국가등의 청사 또는 건물 벽면을 이용하는 간판(면적이 5제곱미터 이상인 간판은 제외한다)
2. 국가등의 청사 또는 건물의 부지 안에 설치하는 현수막 게시대와 벽보판 및 그 게시 광고물
3. 시설물 또는 장소 등의 위험·경고·안전의 안내를 위하여 전기를 사용하지 아니하고 설치하는 안내표지판

② (생 략)

③ 법 제6조제2항 단서에서 "대통령령으로 정하는 표시·설치 기준 등에 맞는 광고물등"이란 다음 각 호의 광고물등을 말한다.

1. 국가등의 청사 또는 건물의 부지 안에 설치하는 홍보용 간판 1개. 이 경우 지주 이용 간판, 옥상간판 또는 건물 등의 벽면을 이용하는 광고물등 중 하나를 선택하여야 하며, 홍보용 간판에 전광류를 사용하는 경우에는 제14조제4항제2호에 따른 비율의 범위에서 해당 기관을 제외한 국가등의 공공목적 광고내용을 표출하여야 한다.
2. 국가등의 청사 또는 건물의 부지 밖에 설치하는 현수막 게시대와 벽보판 및 그 게시 광고물
3. ~ 10. (생 략)

④ 국가등은 제3항 각 호의 광고물등을 표시하려면 관할 시장등과 미리 협의하여야 한다.

⑤·⑥ (생 략)

⑦ 시장등은 광고물등의 안전성 확보, 차량 교통 및 보행안전의 확보, 도시미관 및 쾌적한 생활 환경 조성을 위하여 특히 필요하다고 인정하면 제3항에 따른 광고물등의 설치 장소·수량 등을 제한할 수 있다.

질의제목 19 ▶ 안건번호 24-0659, 24-0820, 24-0857, 24-0858

식품의약품안전처·민원인 – 다른 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우 등에 대한 행정처분의 일반기준 적용(「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ 제2호 등 관련)

01 질의요지

「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ 제1호에서는 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 모두 영업정지인 경우에는 가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다고 규정하고 있고, 같은 표 Ⅰ 제2호에서는 같은 날 제조한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항(「식품위생법」 제7조제4항, 「건강기능식품에 관한 법률」 제24조제1항 또는 「축산물 위생관리법」 제4조제6항 위반행위의 경우에는 수입식품등의 기준과 규격에 따른 같은 기준 및 규격의 항목을 위반한 것을 말함)이 적발된 경우에는 같은 위반행위로 본다고 규정하고 있는바,

① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항[121]이 둘 이상 적발된 경우[122]가 「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ 제1호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"에 해당하는지?

02 회답

① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우는 「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ 제1호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"에 해당합니다.

---

121) 「식품위생법」 제7조제4항, 「건강기능식품에 관한 법률」 제24조제1항 및 「축산물 위생관리법」 제4조제6항의 위반행위의 경우에는 수입식품등의 기준과 규격에 따른 같은 기준 및 규격의 항목을 위반한 것을 말하며, 이하 같음

122) 다른 날 제조한 다른 품목, 다른 날 제조한 같은 품목 또는 같은 날 제조한 다른 품목에 대한 둘 이상의 "같은 위반사항"을 행정청이 "하나의 위반사항"으로 보아 1건만 적발할 수 있는지 여부는 별론으로 함

03 이유

먼저 「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ 제2호에서는 “같은 날 제조한 같은 품목”에 대하여 같은 위반사항이 적발된 경우에는 “같은 위반행위”로 본다고 규정하고 있고, 이는 “같은 날 제조한 같은 품목”에 대하여 같은 위반사항이 복수의 제품에서 발생한 경우에도 “하나의 위반행위”로 보아 영업정지 기간을 가중하지 않도록 하여 과도한 제재를 방지하기 위한 취지의 규정인바[123], 같은 호의 문언에 대한 반대해석상 “같은 날 제조한 같은 품목”이 아닌 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우에는 “하나의 위반행위”로 보기 어렵다고 할 것이므로, 이 사안과 같이 ① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우는 하나의 위반행위가 아니라 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우에 해당한다고 할 것입니다.

또한 「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ의 일반기준의 규정체계를 살펴보면, 제1호 및 제2호에서는 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우에 대하여 규정하고 있고, 그중 제2호는 적발된 둘 이상의 위반행위를 예외적으로 하나의 위반행위로 간주하는 경우를 규정하고 있는 것인데[124], 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 엄격하게 해석할 필요가 있으며[125], 이에 따라 제2호의 적용대상이 아니라면 원칙적으로 제1호의 적용대상이 된다고 할 것인데, 같은 표 Ⅰ 제1호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”란 위반행위의 종류와 관계없이 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우를 의미하는바[126], 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우에도 같은 표 Ⅰ 제1호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”에 해당한다는 점에 비추어 보면, 이 사안과 같이 ① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우는 같은 표 Ⅰ 제1호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”에 해당한다고 보는 것이 같은 표 I. 일반기준의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

한편 「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ 제2호에 따른 같은 날 제조한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항이 적발된 경우에 해당하지 않는다는 이유만으로 이 사안의 경우를 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”로 보아 위반행위의 수만큼 행정처분을 한다면, 영업자에 과도한 처분이 될 수 있으므로, 같은 위반사항의 경우에는 이를 하나의 위반행위로

123) 법제처 2015. 2. 17. 회신 15-0016 해석례 참조
124) 법제처 2024. 11. 8. 회신, 24-0652 해석례 참조
125) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조
126) 법제처 2024. 3. 20. 회신 23-1079 해석례 참조

보아야 한다는 의견이 있으나, 행청처분은 그 실효성을 확보하기 위해서 위반행위가 둘 이상이라면 각각의 위반행위에 대해 제재처분을 내릴 필요가 있다고 할 것이고, 그 위반행위의 위반사항이 동일하다고 하여 이를 달리 볼 것은 아니라는 점[127]을 고려하면, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 ① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우는 「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ 제1호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"에 해당합니다.

관계법령

수입식품안전관리 특별법 시행규칙

제46조(행정처분의 기준) 법 제27조부터 제29조까지의 규정에 따른 행정처분의 기준은 별표 13과 같다.

[별표 13]

행정처분의 기준(제46조 및 제47조 관련)

Ⅰ. 일반기준

1. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 모두 영업정지인 경우에는 가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다.
2. 같은 날 제조한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항(「식품위생법」 제7조제4항, 「건강기능식품에 관한 법률」 제24조제1항 또는 「축산물 위생관리법」 제4조제6항 위반행위의 경우에는 수입식품등의 기준과 규격에 따른 같은 기준 및 규격의 항목을 위반한 것을 말한다)이 적발된 경우에는 같은 위반행위로 본다.
3. ~ 11. (생 략)

Ⅱ.·Ⅲ. (생 략)

127) 법제처 2018. 1. 16. 회신 17-0655 해석례 참조

질의제목 20 ▶ 안건번호 24-0673, 24-0757

민원인 – 교육청 또는 공립학교로부터 계약의 대가를 지급받는 경우 보험료의 납부의무자는 「국민건강보험법」 제81조의4제1항에 따라 보험료의 납부사실을 증명하여야 하는지(「국민건강보험법」 제81조의4제1항 등 관련)

01 질의요지

「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문에서는 같은 법 제77조에 따른 보험료의 납부의무자는 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비(이하 "보험료등"이라 함)의 납부사실을 증명하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제47조의3제1항제2호 본문에서는 같은 법 제81조의4제1항 본문에서 규정한 "공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약"으로 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 "지방계약법"이라 함) 제2조에 따른 계약을 규정하고 있는바,

가. 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문 및 같은 법 시행령 제47조의3제1항제2호에 따라 보험료등의 납부사실을 증명하여야 하는 경우인 지방자치단체로부터 지방계약법 제2조에 따른 계약의 대가를 지급받는 경우에 '교육청으로부터 계약[128]의 대가를 지급받는 경우'가 포함되는지?

나. 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문 및 같은 법 시행령 제47조의3제1항제2호에 따라 보험료등의 납부사실을 증명하여야 하는 경우인 지방자치단체로부터 지방계약법 제2조에 따른 계약의 대가를 지급받는 경우에 '공립학교[129]로부터 계약[130]의 대가를 지급받는 경우'가 포함되는지?

128) 교육청이 보험료 납부의무자와 체결하는 수입 및 지출의 원인이 되는 계약을 말하되, 「지방회계법 시행령」 제38조에 따른 일상경비로 그 대가를 지급받는 계약은 제외하는 것으로 전제함

129) 「초·중등교육법」 제3조제2호에 따른 공립학교를 말하며, 이하 같음.

130) 공립학교가 보험료 납부의무자와 체결하는 수입 및 지출의 원인이 되는 계약을 말하되, 「지방회계법 시행령」 제38조에 따른 일상경비로 그 대가를 지급받는 계약은 제외하는 것으로 전제함

02 회답

가. 질의 가에 대해

「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문 및 같은 법 시행령 제47조의3제1항제2호에 따라 보험료등의 납부사실을 증명하여야 하는 경우인 지방자치단체로부터 지방계약법 제2조에 따른 계약의 대가를 지급받는 경우에 '교육청으로부터 계약의 대가를 지급받는 경우'가 포함됩니다.

나. 질의 나에 대해

「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문 및 같은 법 시행령 제47조의3제1항제2호에 따라 보험료등의 납부사실을 증명하여야 하는 경우인 지방자치단체로부터 지방계약법 제2조에 따른 계약의 대가를 지급받는 경우에 '공립학교로부터 계약의 대가를 지급받는 경우'가 포함됩니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문에서는 '국가, 지방자치단체, 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관'으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 보험료등의 납부사실을 증명하여야 한다고 규정하고 있는데, 국민건강보험법령에서 지방자치단체의 개념이나 그 범위를 규정하고 있지 않으므로, '교육청으로부터 대가를 지급받는 경우'가 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문에 따른 지방자치단체로부터 대가를 지급받는 경우에 해당하는지 여부는 해당 규정의 문언 외에도 지방자치 관련 법령의 체계, 「국민건강보험법」 제81조의4의 입법 취지 등을 종합하여 판단하여야 할 것입니다.

먼저 지방자치단체의 종류, 조직 및 운영 등에 관한 사항을 정하고 있는 법령인 「지방자치법」과 「지방교육자치에 관한 법률」(이하 "교육자치법"이라 함) 등에 따르면, 지방자치단체는 법인으로서 '특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도' 및 '시, 군, 구'로 구분되고[131],

지방자치단체의 집행 및 대표기관으로 시·도지사[132] 등 '지방자치단체의 장'을 두고 있는데[133], 교육·학예 분야의 전문성과 특수성을 고려하여 시·도[134]의 교육·학예에 관한 사무의 집행 및 대표기관으로 '교육감'을 두도록 하여[135], 법인격을 갖는 하나의 지방자치단체(시·도)에 사무의 영역에 따라 지방자치단체의 장(시·도지사)과 교육감이 별개의 집행 및 대표기관으로 병존[136]하는 한편, '교육청'은 교육감을 보조하는 기관 및 교육감 소속으로 설치된 기관[137]으로서 별도의 법인격 없이 지방자치단체(시·도)의 기관으로 기능하는바[138], 교육청이 계약의 대가를 지급하는 것은 지방자치단체의 기관으로서 하는 행위이고, 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문에서 '지방자치단체'를 지방자치단체의 사무를 수행하는 기관이 지방자치단체의 장(시·도지사)인 경우로 한정하고 있지 않은바, '교육청으로부터 계약의 대가를 지급받는 경우'도 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문에 따라 보험료등의 납부사실을 증명해야 하는 경우에 포함된다고 보는 것이 지방자치 관련 법령의 체계 및 「국민건강보험법」 제81조의4의 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 「국민건강보험법 시행령」 제47조의3제1항제2호에서는 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문의 위임에 따라 보험료등의 납부사실을 증명해야 하는 경우 중 하나로 '지방계약법 제2조에 따른 계약의 대가를 지급받는 경우'를 규정하고 있고, 지방계약법 제2조에서는 이 법은 지방자치단체가 계약상대자와 체결하는 수입 및 지출의 원인이 되는 계약 등에 대하여 적용한다고 규정하여 지방계약법의 적용 범위를 정하고 있는데, 지방계약법 제3조에서 이 법에서 교육·과학 및 체육에 관한 사항에 관하여는 "지방자치단체의 장" 또는 "특별시장·광역시장·도지사"는 "교육감"으로 본다고 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 지방계약법의 적용 범위에 지방자치단체의 장을 집행 및 대표기관으로 하여 체결되는 계약뿐만 아니라 교육감을 집행 및 대표기관으로 하여 교육청에서 체결되는 계약도 포함되는 것이 명확하므로, '교육청으로부터 계약의 대가를 지급받는 경우'는 지방계약법 제2조에 따른 계약의 대가를 지급받는 경우에 해당하여, 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문 및 같은 법 시행령 제47조의3제1항제2호에 따라 보험료등의 납부사실을 증명해야 하는 경우에 포함된다고 할 것입니다.

---

131) 「지방자치법」 제2조제1항 및 제3조제1항 참조

132) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사를 말하며, 이하 같음.

133) 「지방자치법」 제106조, 제114조 및 제116조 참조

134) 특별시, 광역시, 특별자치시·도 및 특별자치도를 말하며, 이하 같음.

135) 교육자치법 제18조 참조

136) 대법원 2001. 5. 8. 선고 99다69341 판결례 참조

137) 교육자치법 제32조 및 「지방교육행정기관의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제2조제2호 참조

138) 법제처 2020. 9. 17. 회신 20-0356 해석례 및 광주지방법원 목포지원 2021. 4. 27. 선고 2020고단538 판결례 참조

또한「국민건강보험법」제81조의4에 따른 보험료등의 납부증명 제도는 2016년 2월 3일 법률 제13895호로 같은 법이 일부개정되면서 신설된 것으로서, 국가의 사회보장·사회복지 증진 의무라는 공공복리를 효과적으로 달성하기 위하여 납부가 강제되는 금전인 건강보험료의 특성을 고려하여, 납부의무자의 건강보험료 납부를 유도함으로써 보험료 체납을 방지하고 건강보험 재정의 건전성을 유지하고자 건강보험료의 납부를 담보할 수 있는 제도의 하나로 마련된 규정[139]인데, '시·도와 체결된 계약'뿐만 아니라 '시·도 교육청과 체결된 계약'의 경우에도 납부의무자가 계약의 대가를 지급받을 때 보험료등의 완납사실을 증명하도록 하여 보험료등의 납부를 유도할 수 있고, 시·도 교육청과의 계약도 시·도와 체결된 계약과 마찬가지로 지방자치단체의 기관을 통해 체결된 계약이라는 점을 고려할 때,「국민건강보험법」제81조의4제1항 본문의 지방자치단체로부터 계약의 대가를 지급받는 경우에는 '교육청으로부터 계약의 대가를 지급받는 경우'도 포함되는 것으로 보는 것이 같은 규정의 입법 취지에도 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서「국민건강보험법」제81조의4제1항 본문 및 같은 법 시행령 제47조의3제1항 제2호에 따라 보험료등의 납부사실을 증명하여야 하는 경우인 지방자치단체로부터 지방계약법 제2조에 따른 계약의 대가를 지급받는 경우에 '교육청으로부터 계약의 대가를 지급받는 경우'가 포함됩니다.

나. 질의 나에 대해

「국민건강보험법」제81조의4제1항 본문에서는 '국가, 지방자치단체, 또는「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관'으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 보험료등의 납부사실을 증명하여야 한다고 규정하고 있는데, 국민건강보험법령에서 지방자치단체의 개념이나 그 범위를 직접 규정하고 있지 않으므로, '공립학교로부터 대가를 지급받는 경우'가「국민건강보험법」제81조의4 제1항 본문에 따른 지방자치단체로부터 대가를 지급받는 경우에 해당하는지 여부는 해당 규정의 문언 외에도 공립학교 관련 법령의 체계,「국민건강보험법」제81조의4의 입법 취지 등을 종합하여 판단하여야 할 것입니다.

먼저 공립학교는「초·중등교육법」제3조제2호 등에 따라 지방자치단체가 설립·경영하도록 하고 있고 별도의 법인격을 가지고 있지 않아 지방자치단체의 기관으로 기능하는바,

139) 2013. 5. 21. 의안번호 제1905031호로 발의된 국민건강보험법 일부개정법률안에 대한 국회 보건복지위원회 검토보고서 참조

공립학교의 설립·경영에 관한 한 지방자치단체에 법적 효과가 귀속되므로 공립학교의 법률적 행위는 지방자치단체의 법적 행위로 볼 수 있는 점[140], 지방계약법 시행령 제124조제7항에서도 공립학교가 체결하는 계약의 공개에 관한 사항에 대해서는 교육부장관이 따로 정할 수 있다고 규정하여 지방계약법령의 적용 대상에 공립학교가 포함됨을 전제로 하고 있는 점[141], 공립학교의 재산은 지방자치단체의 소유로서 「공유재산 및 물품 관리법」에 따라 관리되는 점[142], 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문에서 '지방자치단체로부터 계약의 대가를 지급받는 경우'를 규정하면서 이를 해당 지방자치단체의 사무를 지방자치단체의 장(시·도지사)이 수행하는 경우로 한정하고 있지 않은 점 등을 종합적으로 고려하면, '공립학교로부터 계약의 대가를 지급받는 경우'도 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문 및 같은 법 시행령 제47조의3제1항제2호에서 규정한 '지방자치단체로부터 지방계약법 제2조에 따른 계약의 대가를 지급받는 경우'에 포함된다고 보는 것이 공립학교 설립·운영 관련 법령 체계 및 「국민건강보험법」 제81조의4의 문언 등에 부합하는 해석입니다.

또한 「국민건강보험법」 제81조의4에 따른 보험료등의 납부증명 제도는 2016년 2월 3일 법률 제13895호로 같은 법이 일부개정되면서 신설된 것으로서, 국가의 사회보장·사회복지 증진 의무라는 공공복리를 효과적으로 달성하기 위하여 납부가 강제되는 금전인 건강보험료의 특성을 고려하여 납부의무자의 건강보험료 납부를 유도함으로써 보험료 체납을 방지하고 건강보험 재정의 건전성을 유지하고자 건강보험료의 납부를 담보할 수 있는 제도의 하나로 마련된 규정인데, '시·도와 체결된 계약'뿐만 아니라 '공립학교와 체결된 계약'의 경우에도 지방자치단체의 하부기관[143]에서 이루어진 공적 영역의 계약으로서 납부의무자가 계약의 대가를 지급받을 때 보험료등의 완납사실을 증명하도록 하여 보험료등의 납부를 유도할 수 있는바, 합리적인 이유 없이 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문의 "지방자치단체"를 좁게 해석하여 공립학교로부터 계약의 대가를 지급받는 경우를 보험료등의 납부사실을 증명해야 하는 경우에서 제외된다고 해석하는 것은 같은 규정의 입법 취지에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 본문 및 같은 법 시행령 제47조의3제1항제2호에 따라 보험료등의 납부사실을 증명하여야 하는 경우인 지방자치단체로부터 지방계약법

140) 대법원 2020. 8. 20. 선고 2018두51201 판결례, 서울행정법원 2021. 5. 13. 선고 2019구합87764 판결례, 인천지법 2006. 1. 12. 선고 2005가합12625 판결례 및 법제처 2012. 5. 25. 회신 12-0225 해석례 등 참조

141) 법제처 2022. 6. 30. 회신 22-0183 해석례 참조

142) 법제처 2022. 6. 30. 회신 22-0183 해석례 참조

143) 대법원 2020. 8. 20. 선고 2018두51201 판결례 참조

제2조에 따른 계약의 대가를 지급받는 경우에 '공립학교로부터 계약의 대가를 지급받는 경우'가 포함됩니다.

관계법령

국민건강보험법

제81조의4(보험료의 납부증명) ① 제77조에 따른 보험료의 납부의무자(이하 이 조에서 "납부의무자"라 한다)는 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 이 조에서 "공공기관"이라 한다)으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부사실을 증명하여야 한다. 다만, 납부의무자가 계약대금의 전부 또는 일부를 체납한 보험료로 납부하려는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② (생 략)

국민건강보험법 시행령

제47조의3(보험료의 납부증명 등) ① 법 제81조의4제1항 본문에서 "공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약을 말한다.

1. (생 략)
2. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제2조에 따른 계약. 다만, 「지방회계법 시행령」 제38조에 따른 일상경비로 그 대가를 지급받는 계약은 제외한다.
3. (생 략)

②·③ (생 략)

질의제목 21 ▶ 안건번호 24-0735, 24-0796

행정안전부 – 「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항에 따라 자원봉사센터를 비영리법인에 위탁하여 운영하는 경우 운영위원회를 두지 않고 비영리법인 이사회로 갈음할 수 있는지 등(「자원봉사활동 기본법 시행령」 제15조 등 관련)

01 질의요지

「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항에서는 국가기관 및 지방자치단체는 자원봉사센터를 설치할 수 있고, 이 경우 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하거나 비영리 법인에 위탁하여 운영하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제15조제2항에서는 자원봉사센터의 원활한 운영을 위한 정책결정기구로서 운영위원회를 둔다고 규정하면서(본문), 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하는 경우에는 이사회를 둔다고 규정하고 있고(단서), 같은 조 제3항에서는 같은 조 제2항에 따른 운영위원회는 20인 이하로 하되 자원봉사단체 대표를 과반수 이상으로 구성하고 대표는 민간인[144]으로 한다고 규정하고 있는바,

가. 「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항에 따라 지방자치단체가 설치한 자원봉사센터를 비영리 법인에 위탁하여 운영하는 경우, 같은 법 시행령 제15조제2항 본문에 따른 운영위원회를 두지 않고 비영리 법인의 이사회로 갈음하여 운영할 수 있는지?

나. 「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항에 따라 지방자치단체가 설치한 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하는 경우, 같은 법 시행령 제15조제2항 단서에 따라 두는 이사회의 대표로 지방자치단체의 장을 선임할 수 있는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항에 따라 설치된 자원봉사센터를 비영리 법인에

144) 민간인에 지방자치단체의 장이 해당하지 않음을 전제함

위탁하여 운영하는 경우, 운영위원회를 두어야 하고 비영리 법인의 이사회로 갈음할 수 없습니다.

나. 질의 나에 대해

「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항에 따라 설치된 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하는 경우, 법인의 이사회의 대표로 지방자치단체의 장을 선임할 수 없습니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항에 따라 국가기관 및 지방자치단체는 자원봉사센터를 설치할 수 있고(전단), 자원봉사센터는 법인으로 하여 운영하거나 비영리 법인에 위탁하여 운영하도록 하면서(후단), 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항 후단에도 불구하고 자원봉사활동을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 국가기관 및 지방자치단체가 운영할 수 있다고 하여, 자원봉사센터를 ①법인으로 하여 운영하는 방식(이하 "법인형"이라 함) ②비영리 법인에 위탁하여 운영하는 방식(이하 "비영리법인 위탁형"이라 함) ③국가기관 및 지방자치단체가 직접 운영하는 방식(이하 "국가기관등 직영형"이라 함)으로 구분하고 있으며, 같은 조 제4항의 위임에 따라 자원봉사센터의 조직 및 운영 등에 필요한 사항을 규정한 같은 법 시행령 제15조제2항 본문에서는 자원봉사센터의 원활한 운영을 위한 정책결정기구로서 운영위원회를 둔다고 하면서, 같은 항에 단서를 두어 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하는 경우에는 이사회를 둔다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 같은 법 제19조제1항 후단에 따른 비영리 법인 위탁형 자원봉사센터의 경우 같은 법 시행령 제15조제2항 본문에 따른 운영위원회를 두지 않고, 비영리법인의 이사회로 갈음하여 운영할 수 있는지가 문제됩니다.

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[145], 「자원봉사활동 기본법 시행령」 제15조제2항 본문에서 자원봉사센터의 원활한 운영을 위한 "정책결정기구로서 운영위원회를 둔다"고 하여 자원봉사센터의 정책결정기구로 운영위원회를 두는 것을

145) 법제처 2022. 6. 10. 회신 22-0137 해석례 등 참조

원칙으로 하되, 같은 항 단서에서 법인형 자원봉사센터의 경우에는 이사회를 둔다고 하여 법인형의 경우 예외적으로 정책결정기구로 이사회를 두도록 한 것으로, 법인형이 아닌 자원봉사센터의 경우에는 같은 항 본문에 따라 정책결정기구로 운영위원회를 두는 것이 문언상 분명하고, 그 밖에 달리 비영리법인 위탁형의 경우 이사회를 두도록 하거나 이사회로 하여금 운영위원회를 갈음할 수 있다고 규정하고 있지 않으므로, 이 사안과 같이 비영리법인 위탁형 자원봉사센터의 경우 운영위원회를 두어야 하고, 비영리 법인의 이사회로 갈음할 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 「자원봉사활동 기본법 시행령」 제15조제2항 본문에 따라 자원봉사센터에 정책결정기구로서 운영위원회를 두는 것이 원칙이고, 같은 항 단서에 따라 예외적으로 법인형 자원봉사센터의 경우에만 정책결정기구로서 이사회를 두도록 한 것인데, 일반적으로 예외 규정은 엄격하게 해석하여야 하는바[146], 특별한 사유 없이 비영리법인 위탁형 자원봉사센터의 경우까지 예외 규정을 적용하여 비영리법인 위탁형의 경우에도 운영위원회를 두지 않고 이사회로 갈음할 수 있다고 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

아울러 「자원봉사활동 기본법 시행령」 제15조제2항 및 제3항에서 자원봉사활동센터의 정책결정기구로 운영위원회를 두고, 운영위원회의 과반수 이상을 자원봉사단체 대표로 구성하며, 그 대표는 민간인으로 하도록 한 것은 자원봉사센터가 수행하는 자원봉사활동의 개발·장려·연계·협력 등 사업의 주요한 정책결정을 전담할 수 있는 별도의 조직을 두어, 주요 사업계획 등에 대하여 독립적이면서도 전문가의 의견이 반영될 수 있는 의사결정체계를 확립하여 자원봉사센터의 효율적이고 원활한 운영을 도모하려는 취지로 보이는데, 만약 비영리법인이 별도의 운영위원회를 두지 않고 이사회가 자원봉사센터의 정책결정기구로서 기능한다면, 자원봉사센터의 업무는 정관 등에서 정한 비영리법인의 다양한 목적사업 중 하나의 업무에 지나지 않아 자원봉사센터의 중요한 정책결정을 적절한 시기에 수행하거나 그 의사결정 과정에서 자원봉사 전문가의 의견이 충분히 반영되기 어려울 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항에 따라 설치된 자원봉사센터를 비영리 법인에 위탁하여 운영하는 경우, 운영위원회를 두어야 하고 비영리 법인의 이사회로 갈음할 수 없습니다.

146) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조

나. 질의 나에 대해

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 하는바[147], 이 사안에서 지방자치단체의 장을 법인의 이사회의 대표로 선임할 수 있는지를 판단하기 위해서는 문언의 형식적인 표현 외에도 해당 규정의 입법취지와 목적, 법질서 전체와의 조화, 법령간의 관계 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다[148].

먼저 「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항 후단 및 같은 조 제2항에 따르면 자원봉사센터는 원칙적으로 법인형이나 비영리법인 위탁형으로 운영하도록 하되, 예외적으로 국가기관등 직영형으로 운영하도록 하고 있는데, 이는 국가기관등 직영형으로는 민간의 경험과 창의성을 활용한 자율적 운영을 담보하는 데에 한계가 있고, 공무원의 잦은 순환보직과 비전문성이 문제됨에 따라 민간운영 방식의 운영을 의무화하려는 취지[149]로서, 같은 법 시행령 제15조 제3항에서는 운영위원회 구성에 있어 자원봉사단체 대표를 과반수 이상으로 하고, 운영위원회 대표를 민간인으로 두도록 규정한 것도, 자원봉사센터 운영 등에 대한 전문적 지식과 경험이 풍부한 전문가로 정책결정기구를 구성하고 대표를 선임함으로써 자원봉사 센터 운영 및 사업 수행이 민간 주도로 자율적으로 이루어지도록 하려는 취지로 볼 수 있고, 법인형 자원봉사센터의 이사회나 비영리법인 위탁형 및 직영형 자원봉사센터의 운영위원회 모두 자원봉사센터의 정책결정기구로서 주요 사안에 대한 의사를 결정한다는 점에서 동일한 기능을 수행하는 것인바, 법인형 자원봉사센터의 경우에도 정책결정기구의 장인 이사회의 대표는 민간인으로 선임하도록 해석하는 것이 자원봉사센터를 원칙적으로 민간이 운영하도록 하면서, 운영위원회를 두도록 한 법령의 취지 및 목적에 부합하는 해석입니다.

그리고 「자원봉사활동 기본법」 제2조제2호에서는 자원봉사활동은 무보수성, 자발성, 공익성, 비영리성, 비정파성(非政派性), 비종파성(非宗派性)의 원칙 아래 수행될 수 있도록 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제5조제1항에서는 같은 법 제14조 등에 따라 지원을 받는 자원봉사센터는 그 명의 또는 그 대표의 명의로 특정 정당이나 특정인의 선거운동을

147) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

148) 법제처 2023. 2. 14. 회신 22-0786 해석례 참조

149) 2016. 10. 20. 의안번호 2002767호로 발의된 자원봉사활동기본법 전부개정법률안에 대한 국회 안전행정위원회 검토보고서 참조

하여서는 아니 된다고 규정하고 있는데, 「지방공무원법」 제2조제3항제1호에 따라 선거로 취임하는 정무직공무원인 지방자치단체의 장이 지원봉사센터를 대표하고 정책결정의 최종적 책임이 있는 법인의 이사회의 대표로 선임되는 경우, 해당 자원봉사센터가 독립된 법인이라 하더라도 자원봉사활동의 비정파성이나 정치활동 등의 금지 의무를 준수하는데 어려움이 있을 수 있다는 점에서, 법인형의 경우 법인의 이사회의 대표로 지방자치단체의 장을 선임할 수 없다고 해석하는 것이 법률에서 정하고 있는 자원봉사활동의 기본 방향에도 부합합니다.

아울러 비영리법인 위탁형 자원봉사센터와 법인형 자원봉사센터는 민간에 의해 운영되고, 「자원봉사활동 기본법 시행령」 제15조제4항 및 제5항에 규정된 업무를 수행한다는 점에서 운영주체의 성격 및 업무 내용이나 범위에 차이가 없는데, 자원봉사센터 운영의 형식적 차이에 따라 법인형의 경우에만 그 정책결정기구의 대표가 민간인뿐만 아니라 지방자치단체의 장도 선임할 수 있다고 보는 것은 불합리한 측면이 있다는 점, 만약 지방자치단체의 장을 법인의 이사회의 대표로 선임할 수 있는 것으로 해석한다면 지방자치단체의 장이 법인형 자원봉사센터의 대표로서 법인의 사무를 총괄하게 되어, 결국 법인형 자원봉사센터가 사실상 국가기관등 직영형 자원봉사센터와 유사하게 운영됨으로써 독립된 법인으로 운영하도록 한 취지가 몰각될 우려가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「자원봉사활동 기본법」 제19조제1항에 따라 설치된 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하는 경우, 법인의 이사회의 대표로 지방자치단체의 장을 선임할 수 없습니다.

관계법령

자원봉사활동 기본법

제19조(자원봉사센터의 설치 및 운영) ① 국가기관 및 지방자치단체는 자원봉사센터를 설치할 수 있다. 이 경우 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하거나 비영리 법인에 위탁하여 운영하여야 한다.

② 제1항 후단에도 불구하고 자원봉사활동을 효율적으로 추진하기 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 국가기관 및 지방자치단체가 운영할 수 있다.

③ 국가는 자원봉사센터의 설치·운영이 활성화될 수 있도록 적극 노력하여야 하며, 지방자치단체는 자원봉사센터의 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.

④ 자원봉사센터 장의 자격요건과 자원봉사센터의 조직 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자원봉사활동 기본법 시행령

제15조(자원봉사센터의 조직 및 운영 등) ①자원봉사센터의 사무를 처리하게 하기 위하여 자원봉사센터에 사무국을 둔다.

② 자원봉사센터의 원활한 운영을 위한 정책결정기구로서 운영위원회를 둔다. 다만, 자원봉사센터를 법인으로 하여 운영하는 경우에는 이사회를 둔다.

③ 제2항의 규정에 의한 운영위원회는 20인 이하로 하되 자원봉사단체 대표를 과반수 이상으로 구성하고 대표는 민간인으로 한다.

④·⑤ (생 략)

⑥지방자치단체는 자원봉사센터의 조직 및 운영 등에 관한 사항은 조례로 정한다.

질의제목 22 ▶ 안건번호 24-0770, 24-0915

민원인 – 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」에 따른 전세사기피해자 등 결정신청서의 작성 및 제출 대행 업무가 행정사의 업무에 해당하는지 여부(「행정사법」 제2조제1항제1호·제4호 등 관련)

01 질의요지

「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」(이하 "전세사기피해자법"이라 함) 제12조제1항에서는 전세사기피해자등[150] 결정을 받으려는 임차인은 국토교통부장관에게 신청하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제29조제1항제1호에서는 이 법에 따른 국토교통부장관의 권한 중 같은 법 제12조에 따른 신청의 접수를 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 함)에 위임한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제3조제1항에서는 같은 법 제12조제1항에 따라 전세사기피해자등 결정을 신청하려는 임차인은 별지 제1호서식의 전세사기피해자등 결정신청서에 임대차계약서 사본 등 관련 서류를 첨부하여 시·도지사에게 제출해야 한다고 규정하고 있는 한편,

「행정사법」 제2조제1항 본문에서는 행정사[151]는 다른 사람의 위임을 받아 같은 항 각 호의 업무를 수행한다고 규정하면서, 같은 항 각 호로 행정기관에 제출하는 서류의 작성(제1호), 같은 항 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 작성된 서류의 제출 대행(代行)(제4호) 등을 규정하고 있는바,

전세사기피해자법 제12조제1항에 따라 전세사기피해자등 결정 신청을 하려는 임차인의 위임을 받아 같은 법 시행규칙 제3조제1항에 따른 전세사기피해자등 결정신청서(이하 "결정신청서"라 함)의 작성 및 그 작성된 서류의 제출을 대행하는 업무가 「행정사법」 제2조제1항제1호·제4호에 따른 행정사의 업무에 해당하는지?[152]

150) 전세사기피해자법 제2조제4호에 따른 '전세사기피해자등'을 말하며, 이하 같음.

151) 「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제1호에 따른 일반행정사를 말하며, 이하 같음.

152) 이 사안에서는 전세사기피해자법에 따른 전세사기피해자등 결정신청서 작성 및 제출 대행 업무가 행정사가 아닌 사람이 업(業)으로 수행할 수 있는 '다른 법률에 따라 허용되는 업무'인지 여부는 별도로 논의하지 않음(「행정사법」 제3조제1항 참조)

02 회답

전세사기피해자법 제12조제1항에 따라 전세사기피해자등 결정 신청을 하려는 임차인의 위임을 받아 결정신청서의 작성 및 그 작성된 서류의 제출을 대행하는 업무는 「행정사법」 제2조제1항제1호·제4호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.

03 이유

「행정사법」 제2조제1항에서는 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 행정기관에 제출하는 서류의 작성(제1호), 작성된 서류의 제출 대행(제4호) 등의 업무를 수행한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제2조에서는 같은 법 제2조제1항에 따른 행정사 업무의 내용과 범위는 같은 항 각 호와 같다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 행정기관에 제출하는 진정·건의·질의·청원 및 이의신청에 관한 서류(가목), 출생·혼인·사망 등 가족관계의 발생 및 변동 사항에 관한 신고 등의 각종 서류(나목)를 작성하는 일을, 같은 항 제4호에서는 다른 사람의 위임에 따라 행정사가 같은 영 제2조제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 작성하거나 번역한 서류를 행정기관 등에 제출하는 일을 규정하고 있는바, 전세사기피해자법 시행규칙 제3조제1항에 따른 전세사기피해자등 결정신청서의 작성 및 그 작성된 서류의 제출을 대행하는 것이 「행정사법」 제2조제1항제1호·제4호에 따른 업무 범위에 포함되기 위해서는 그 결정신청서가 「행정사법 시행령」 제2조제1호에 규정된 행정기관에 제출하는 진정·건의·질의·청원 및 이의신청 등의 각종 서류에 해당해야 할 것인바, 이에 관해서는 행정사법령의 규정 내용과 입법 취지는 물론 입법 취지가 유사한 다른 법령과의 관계, 사회에서 일반적으로 통용되는 의미 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 할 것[153]입니다.

먼저 "행정기관"의 의미에 대해서는 「행정사법」 및 같은 법 시행령에서 별도로 규정하고 있지 않으나, 행정기관은 일반적으로 "국가 또는 지방자치단체의 행정사무를 맡아보는 기관[154]"을 의미하고, 전세사기피해자법 제12조제1항에서는 같은 법 제14조에 따른 전세사기피해자등 결정을 받으려는 임차인은 국토교통부장관에게 신청하여야 한다고 규정하면서, 같은 법 제29조제1항제1호에서는 같은 법에 따른 국토교통부장관의 권한 중 "같은 법 제12조에 따른 신청의 접수에 관한 사항"을 시·도지사에 위임하고 있는바,

153) 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0572 해석례 참조
154) 국립국어원 표준국어대사전 참조

전세사기피해자법령에 따르면 시·도지사는 전세사기피해자등의 결정 신청에 관하여 국토교통부장관의 행정사무를 위임받아 수행하는 행정기관에 해당하고, 같은 법 제12조에 따라 전세사기피해자등 결정 신청을 하려는 임차인은 전세사기피해자등 결정신청서에 임대차계약서 사본 등을 첨부하여 시·도지사에게 제출하도록 하고 있으므로, 해당 결정신청서는 「행정사법」 제2조제1항제1호의 "행정기관에 제출하는 서류"에 해당합니다.

다음으로 결정신청서가 「행정사법 시행령」 제2조제1호에 따라 행정사가 작성할 수 있는 서류에 해당하는지 살펴보면, 같은 호 나목에서는 "출생·혼인·사망 등 가족관계의 발생 및 변동 사항에 관한 신고 등의 각종 서류"를 작성하는 일을 규정하고 있는데, 행정사의 업무는 행정기관을 대상으로 한 공적 업무와 관련된 것으로서[155], 일반적으로 법령에서 하나 또는 수개의 사항을 열거하고 그 뒤에 "등"을 사용한 경우 열거된 사항은 예시사항이라 할 것이고, 별도로 해석해야 할 특별한 이유가 없는 한 그 "등"에는 열거된 예시사항과 규범적 가치가 동일하거나 그에 준하는 성질을 가지는 사항이 포함되는 것으로 해석함이 상당하다 할 것[156]이며, 1999년 8월 19일 대통령령 제16536호로 전부개정된 「행정사법 시행령」 제2조제1호에서 종전에 "진정·건의·질의·청원·이의신청과 호적에 관한 신고 등 민원사무에 관한 각종 서류를 작성하는 일"이라고 규정되어 있던 것을 "진정·건의·질의·청원·이의신청과 호적에 관한 신고 등 각종 서류를 작성하는 일"로 개정하였던 점 등을 고려하면, 「행정사법 시행령」 제2조제1호에 따른 "각종 서류"에는 진정·건의·질의·청원 및 이의신청에 관한 서류, 출생·혼인·사망 등 가족관계의 발생 및 변동 사항 신고에 관한 서류뿐만 아니라 그와 유사하게 민원인이 행정기관에 대하여 특정한 행위를 요구하는 등의 각종 행정사무와 관련된 서류도 포함될 수 있다고 보아야 할 것입니다.

그리고 전세사기피해자법령에 따른 전세사기피해자등 결정에 관한 사무의 성격을 살펴보면, 전세사기피해자법은 전세사기로 피해를 입은 임차인에게 경·공매 절차 및 조세 징수 등에 관한 특례를 부여함으로써 전세사기피해자를 지원하고 주거안정을 도모함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 전세사기피해자등에 해당하는지를 결정받으려는 임차인은 국토교통부령으로 정하는 신청 방법 및 절차 등에 따라 국토교통부장관에게 신청(제12조)하도록 하면서, 국토교통부장관은 신청을 받은 경우 전세사기피해자등 결정 등을 위하여 임차주택의 가격 및 실태, 임차주택의 권리관계 등 필요한 정보나 자료를 조사하고(제13조), 같은 법 제6조에 따른 전세사기피해지원위원회의 심의·의결을 거쳐 전세사기피해자등 결정을 하도록 규정(제14조)하고 있고, 전세사기피해자등으로 결정되면 경매의 유예·정지

155) 헌법재판소 2015. 3. 26. 결정 2013헌마131 결정례 참조

156) 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0498 해석례 참조

(제17조), 경매절차에서의 우선매수권(제20조), 경매 및 공매의 지원(제26조), 금융지원(제27조) 등 전세사기피해자법령상의 각종 지원 및 특례 규정의 적용 대상이 된다는 점에서, 전세사기피해자등 결정에 관한 사무는 전세사기피해자등을 효과적으로 지원하기 위한 공익적 목적으로 수행되는 공공적 성격의 행정사무로 볼 수 있으므로, 이와 관련하여 임차인이 전세사기피해자등의 결정이라는 특정한 행위를 요구하기 위해 행정기관인 시·도지사에 작성·제출하는 서류인 결정신청서는 「행정사법 시행령」 제2조제1호에 따라 행정사가 임차인의 위임을 받아 작성·제출할 수 있는 서류에 포함된다고 보는 것이 타당합니다.

아울러 「행정사법」은 행정사 제도를 확립하여 행정과 관련된 국민의 편익을 도모하고 행정제도의 건전한 발전에 이바지하는 것을 목적으로 하는 법률로서(제1조), 행정사 제도는 행정기관에 제출하는 서류의 작성 및 제출과 같이 일반적인 행정지식만으로 수행할 수 있는 기본적인 민원 행정 사무는 분야별 전문자격자에게 맡기지 않고도 저렴한 비용으로 해당 서비스를 이용할 수 있도록 마련된 별도의 자격제도[157]인바, 임차인이 전세사기피해자등에 해당하는지를 공적으로 결정·확인받기 위하여 결정신청서를 작성하고 이를 제출하는 것은 일반적인 행정지식만으로 수행할 수 있는 기본적인 민원 행정 사무로 볼 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 전세사기피해자법 제12조제1항에 따라 전세사기피해자등 결정 신청을 하려는 임차인의 위임을 받아 결정신청서의 작성 및 그 작성된 서류의 제출을 대행하는 업무는 「행정사법」 제2조제1항제1호·제4호에 따른 행정사의 업무에 해당합니다.

관계법령

행정사법

제2조(업무) ① 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다.

1. 행정기관에 제출하는 서류의 작성
2.·3. (생 략)
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 작성된 서류의 제출 대행(代行)
5. ~ 7. (생 략)

② 제1항에 따른 업무의 내용과 범위는 대통령령으로 정한다.

157) 법제처 2015. 10. 23. 회신 15-0443 해석례 참조

행정사법 시행령

제2조(업무의 내용과 범위) 「행정사법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1항 각 호에 따른 행정사 업무의 내용과 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 법 제2조제1항제1호의 사무: 행정기관에 제출하는 다음 각 목의 서류를 작성하는 일
   가. 진정·건의·질의·청원 및 이의신청에 관한 서류
   나. 출생·혼인·사망 등 가족관계의 발생 및 변동 사항에 관한 신고 등의 각종 서류
2.·3. (생 략)
4. 법 제2조제1항제4호의 사무: 다른 사람의 위임에 따라 행정사가 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 작성하거나 번역한 서류를 행정기관 등에 제출하는 일

전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법

제12조(임차인의 신청) ① 제14조에 따른 전세사기피해자등 결정을 받으려는 임차인은 국토교통부장관에게 신청하여야 한다.

② 그 밖에 전세사기피해자등 결정의 신청 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제29조(권한 등의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 국토교통부장관의 권한 중 다음 각 호의 사항을 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사에게 위임한다.

1. 제12조에 따른 신청의 접수
2.·3. (생 략)

②·③ (생 략)

전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법 시행규칙

제3조(전세사기피해자등 결정신청 등) ① 법 제12조제1항에 따라 전세사기피해자등 결정을 신청하려는 임차인(이하 "신청인"이라 한다)은 별지 제1호서식의 전세사기피해자등 결정신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 제출해야 한다.

1. ~ 5. (생 략)

② (생 략)

③ 신청인은 본인이 직접 신청하기 어려운 사정이 있는 경우에는 다른 사람을 대리인으로 선임할 수 있다.

④ ~ ⑥ (생 략)

질의제목 23 ▶ 안건번호 24-0804, 24-0978

행정안전부·민원인 – 한국예탁결제원이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당하는지 여부(「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제2조제4호 등 관련)

01 질의요지

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 함) 제294조에 따라 설립된 한국예탁결제원이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」(이하 “정보공개법 시행령”이라 함) 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당하는지?

02 회답

자본시장법 제294조에 따라 설립된 한국예탁결제원은 정보공개법 시행령 제2조제4호에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당합니다.

03 이유

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “정보공개법”이라 함) 제2조제3호마목 및 같은 법 시행령 제2조제4호에서는 같은 법에 따라 정보를 공개할 의무가 있는 공공기관의 하나로 “특별법에 따라 설립된 특수법인”을 규정하고 있는바, 이는 문언상 당해 법인의 설립 및 규율을 목적으로 특별히 제정된 법률에 의하여 설립된 법인에 한정할 것은 아니고, 법인의 설립 및 규율 외의 다른 목적을 위하여 제정된 법률 가운데 특정 법인의 설립근거를 둔 법률에 의하여 설립된 법인도 포함된다고 볼 것인데, 한국예탁결제원이 이에 해당하는지는 정보공개법의 입법 목적을 염두에 두고, 해당 법인에게 부여된 업무가 국가행정업무이거나, 이에 해당하지 않더라도 그 업무 수행으로써 추구하는 이익이 해당 법인 내부의 이익에 그치지 않고 공동체 전체의 이익에 해당하는 공익적 성격을 갖는지 여부를 중심으로 판단하되, 해당 법인의

설립근거가 되는 법률이 법인의 조직구성과 활동에 대한 행정적 관리·감독 등에서 「민법」이나 「상법」 등에 의하여 설립된 일반 법인과 달리 규율한 취지, 국가나 지방자치단체의 해당 법인에 대한 재정적 지원·보조의 유무와 그 정도, 해당 법인의 공공적 업무와 관련하여 국가기관·지방자치단체 등 다른 공공기관에 대한 정보공개청구와는 별도로 해당 법인에 대하여 직접 정보공개청구를 구할 필요성이 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여야 합니다[158].

먼저 자본시장법은 자본시장에서의 금융혁신과 공정한 경쟁을 촉진하고 투자자를 보호하며 금융투자업을 건전하게 육성함으로써 자본시장의 공정성·신뢰성 및 효율성을 높여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 제정된 법률(제1조)로, 같은 법 제294조에서는 증권등[159]의 집중예탁과 계좌 간 대체, 매매거래에 따른 결제업무 및 유통의 원활을 위하여 한국예탁결제원을 설립하고, 한국예탁결제원은 법인으로 한다고 규정하여 한국예탁결제원의 설립근거를 자본시장법에 두고 있는바, 한국예탁결제원은 특별법인 자본시장법에 따라 설립된 법인에 해당합니다.

다음으로 한국예탁결제원이 행하는 업무의 내용과 성격에 대해 살펴보면, ① 자본시장법 제296조에서는 한국예탁결제원은 정관으로 정하는 바에 따라 증권등의 집중예탁업무(제1항제1호), 증권등의 계좌 간 대체업무(제1항제2호) 등 같은 조 제1항부터 제3항까지의 규정에서 정하는 업무를 행한다고 규정하여 한국예탁결제원으로 하여금 금융시장에 필요한 예탁·결제 인프라를 제공하도록 하고 있고, ② 같은 법 제298조제1항에서는 한국예탁결제원이 아닌 자는 증권등을 예탁받아 그 증권등의 수수를 갈음하여 계좌 간의 대체로 결제하는 업무를 영위하여서는 아니 된다고 규정하여 한국예탁결제원에 증권등의 예탁·결제 업무에 대한 독점권을 부여하고 있으며, ③ 같은 법 제61조제1항 본문에서는 금융투자업자[160]는 그 고유재산을 운용함에 따라 소유하게 되는 증권을 한국예탁결제원에 지체 없이 예탁하여야 한다고 규정하고, 같은 법 제75조제1항 본문에서는 투자매매업자 또는 투자중개업자는 금융투자상품의 매매, 그 밖의 거래에 따라 보관하게 되는 투자자 소유의 증권을 한국예탁결제원에 지체 없이 예탁하여야 한다고 규정하는 등 같은 법에서는 예탁 업무의 통일성 및 투자자 재산 보호 등을 위해 금융투자업자가 증권을 한국예탁결제원에 의무적으로 예탁해야 하는 경우에 대해 규정하고 있는바, 한국예탁결제원의 업무는 자본시장의 공정성·신뢰성 및 효율성을 높이고 투자자를 보호하는 역할을 하는 등 공익적인 성격을 갖는

158) 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008두5643 판결례 참조

159) 증권, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 말하며(자본시장법 제294조제1항 참조), 이하 같음.

160) 자본시장법 제6조제1항 각 호의 금융투자업에 대하여 금융위원회의 인가를 받거나 금융위원회에 등록하여 이를 영위하는 자를 말하며(자본시장법 제8조 참조), 이하 같음

것으로, 해당 법인의 업무 수행으로써 추구하는 이익이 해당 법인 내부의 이익에 그친다고 보기 어렵습니다.

그리고 한국예탁결제원에 대한 자본시장법상의 행정적 관리·감독 체계에 대해 살펴보면, ① 한국예탁결제원이 정관을 변경하고자 하는 경우 금융위원회 승인을 받아야 하고(같은 법 제299조제2항), ② 같은 법 제302조의 예탁업무규정 및 같은 법 제303조의 결제업무규정 등을 제정·변경하거나 폐지하고자 하는 경우에는 금융위원회의 승인을 받아야 하며(같은 법 제305조제1항), 그 외의 업무에 관한 규정을 제정·변경하거나 폐지한 경우에는 지체 없이 금융위원회에 보고하여야 하고(같은 법 제305조제3항), ③ 금융위원회는 한국예탁결제원 및 그 임직원이 '같은 법 제296조제1항 각 호, 제2항 각 호 및 제3항 각 호 외의 업무를 영위한 경우' 등 처분 사유(같은 법 별표 8 제1호부터 제29호까지)에 해당하는 경우 업무정지, 위법행위의 시정명령 또는 중지명령, 임원 해임요구, 직원 면직요구 등을 할 수 있으며(같은 법 제307조), ④ 한국예탁결제원의 사장은 주주총회에서 선출하되 금융위원회의 승인을 받아야 하는 등 자본시장법에서는 한국예탁결제원에 대한 금융위원회의 적절한 통제가 이루어질 수 있도록 「민법」 또는 「상법」에 따라 설립된 일반적인 법인과 달리 행정적 관리·감독에 관한 사항을 구체적으로 규정하고 있습니다.

아울러 ① 한국예탁결제원은 1974년에 「상법」상 주식회사의 형태로 출범한 후 1994년 1월 5일 법률 제4701호로 「증권거래법」이 일부개정되면서 '예탁기관의 공공성을 높임으로써 유가증권의 집중예탁을 활성화하고 유가증권의 실물거래에 따른 비용과 사고위험을 축소하도록 하는 취지[161]'에서 특수법인의 형태로 개편된 것인 점, ② 한국예탁결제원은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 "전자증권법"이라 함)이 2019년 9월 시행되어 전자증권제도가 한국예탁결제원의 독점 사업의 형태가 아닌 전자등록업 허가제[162]의 형태로 도입됨에 따라 2022년 1월 공공기관운영법에 따른 공공기관에서 지정 해제되었으나, 전자증권법 시행 이후에도 한국예탁결제원에서 자본시장법에 따른 독점 사업인 기존 예탁제도를 병행하여 운영하고 있고 한국예탁결제원 외에 전자증권법에 따른 전자등록업 허가를 받은 기관이 없다면 한국예탁결제원의 경우 여전히 공공기관운영법에 따른 공공기관에 준하는 정도로 공공성이 있다고 할 것인 점, ③ 정보공개법 제2조제3호 및 같은 법 시행령 제2조에서는 국가기관, 지방자치단체, 공공기관운영법에 따른 공공기관과 별개로 "특별법에 따라 설립된 특수법인" 등을 정보공개법 적용 대상 기관으로 규정하고 있는바, 한국예탁결제원이 공공기관운영법에 따른 공공기관에서 지정 해제되었다고 하더라도 국민의

161) 구 「증권거래법」(1994. 1. 5. 법률 제4701호로 일부개정된 것) 개정이유서 참조
162) 전자증권법 제5조 참조

알권리가 충분히 보장될 수 있도록 한국예탁결제원에서 보유·관리하고 있는 정보에 대해 해당 법인에 직접 정보공개를 청구할 수 있다고 해석하는 것이 공공성을 갖는 법인에 대한 국민의 알권리를 보장하려는 정보공개법령의 입법 목적에 부합하는 것이라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 자본시장법 제294조에 따라 설립된 한국예탁결제원은 정보공개법 시행령 제2조제4호에 따른 "특별법에 따라 설립된 특수법인"에 해당합니다.

법령정비 권고사항

정보공개법 시행령 제2조제4호에 따른 "특별법에 따라 설립된 특수법인"의 의미가 명확하지 않으므로, 해당하는 법인의 구체적인 범위 또는 요건 등을 정보공개법령에 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

공공기관의 정보공개에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.·2. (생 략)

3. "공공기관"이란 다음 각 목의 기관을 말한다.

가. 국가기관

1) 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회

2) 중앙행정기관(대통령 소속 기관과 국무총리 소속 기관을 포함한다) 및 그 소속 기관

3) 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」에 따른 위원회

나. 지방자치단체

다. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 공공기관

라. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단

마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관

공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령

제2조(공공기관의 범위) 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제3호마목에서 "대통령령으로 정하는 기관"이란 다음 각 호의 기관 또는 단체를 말한다.

1. 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」에 따른 각급 학교 또는 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 학교

2. 삭제
3. 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 출자기관 및 출연기관
4. 특별법에 따라 설립된 특수법인
5. 「사회복지사업법」 제42조제1항에 따라 국가나 지방자치단체로부터 보조금을 받는 사회복지법인과 사회복지사업을 하는 비영리법인
6. 제5호 외에 「보조금 관리에 관한 법률」 제9조 또는 「지방재정법」 제17조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국가나 지방자치단체로부터 연간 5천만원 이상의 보조금을 받는 기관 또는 단체. 다만, 정보공개 대상 정보는 해당 연도에 보조를 받은 사업으로 한정한다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제294조(설립) ① 증권등(증권, 그 밖에 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 이하 이 장에서 같다)의 집중예탁과 계좌 간 대체, 매매거래에 따른 결제업무 및 유통의 원활을 위하여 한국예탁결제원을 설립한다.

② 예탁결제원은 법인으로 한다.

③ 예탁결제원은 대통령령으로 정하는 바에 따라 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다.

질의제목 24 ▶ 안건번호 24-0869

민원인 – 대한지방행정공제회가 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제3호나목3)에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당하는지 여부(「민원 처리에 관한 법률」 제2조 등 관련)

01 질의요지

「민원 처리에 관한 법률」(이하 “민원처리법”이라 함) 제2조제1호에서는 “민원”이란 민원인이 행정기관에 대하여 처분 등 특정한 행위를 요구하는 것을 말하며, 그 종류는 같은 호 각 목과 같다고 규정하고 있고, 같은 조 제3호에서는 “행정기관”이란 같은 호 각 목의 자를 말한다고 규정하면서, 같은 호 나목에서는 “공공기관”을 규정하고 있으며, 같은 목 3)에서는 공공기관 중 하나로 “특별법에 따라 설립된 특수법인”을 규정하고 있는바,

「대한지방행정공제회법」 제2조제1항에 따른 법인인 대한지방행정공제회(이하 “대한지방행정공제회”라 함)가 민원처리법 제2조제3호나목3)에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당하는지?

02 회답

대한지방행정공제회는 민원처리법 제2조제3호나목3)에 따른 “특별법에 따라 설립된 특수법인”에 해당하지 않습니다.

03 이유

대한지방행정공제회가 민원을 공정하고 적법하게 처리할 의무를 지는[163] 행정기관의 하나인 공공법인으로서 민원처리법 제2조제3호나목3)에 따른 특별법에 따라 설립된

163) 민원처리법은 민원 처리에 관한 기본적인 사항을 규정하여 민원의 공정하고 적법한 처리를 통해 국민의 권익을 보호하는 것을 목적으로 하고 있음(「민원 처리에 관한 법률」 제1조 참조).

특수법인에 해당하는지 여부는 해당 법인에게 부여된 업무 수행으로써 추구하는 이익이 공동체 전체의 이익에 해당하는 공익적 성격을 갖는지, 법인의 설립근거가 되는 법률이 법인의 조직 구성이나 활동에 대한 행정적 관리·감독 등에 관한 사항을 「민법」이나 「상법」 등에 따라 설립된 일반 법인과 달리 규율하고 있는지, 국가 등의 재정적 지원의 유무와 그 정도 및 같은 법의 입법 목적 등을 토대로 해당 법인에 대하여 민원처리법에 따른 의무를 부여할 필요성이 있는지 등을 종합적으로 고려[164]하여 판단할 필요가 있습니다.

먼저 ① 「대한지방행정공제회법」 제7조제1항에 따라 대한지방행정공제회의 회원은 일반회원과 특별회원으로 구분되는데, 같은 조 제2항에 따라 일반회원이 될 수 있는 사람은 지방자치단체에 근무하는 공무원(제1호), 지방행정사무를 담당하는 공무원으로서 정관으로 정하는 사람(제2호) 등 같은 항 각 호에 규정된 사람으로 한정되고, 같은 조 제3항 본문에 따라 특별회원이 될 수 있는 사람은 같은 조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 직에 근무하다가 퇴직한 사람으로 한정되며, 이러한 자격이 있는 사람 중 가입을 희망하는 자의 신청에 의해서 회원이 되는 점, ② 같은 법 제16조제1항에 따르면 대한지방행정공제회는 그 목적을 달성하기 위하여 같은 항 각 호의 사업을 수행하는데, 그중 회원에 대한 급여의 지급 사업(제1호)은 자격을 갖춘 회원이 부담금을 납입하면, 규정에 따른 기간 또는 지급요건에 도달한 때 퇴직급여 등 급여를 지급받는 사업이고, 회원을 위한 복지후생시설의 설치·운영 사업(제2호)은 회원 복리후생시설사업, 퇴직한 회원의 단체에 대한 지원육성사업, 회원 교육, 연수 및 회원 복지서비스사업 등인 점, ③ 「대한지방행정공제회법」의 입법 목적이 지방자치단체의 공무원 또는 지방행정사무에 종사하거나 종사하였던 사람 등에 대한 효율적인 공제제도를 확립·운영함으로써 이들의 생활안정과 복지증진을 도모하기 위한 것이라는 점(제1조) 등을 종합하면, 대한지방행정공제회는 지방공무원 등 일정한 자격을 가진 사람 중에서 회원 가입을 신청한 사람을 회원으로 하고, 주요 사업도 퇴직급여 지급 등 회원을 대상으로 한 공제 성격의 사업이나 회원의 편의를 위한 복지사업이므로 대한지방행정공제회가 수행하는 업무는 국가적인 차원에서 수행되는 행정업무로 보기 어려우며, 수행하는 업무의 성격이나 법인의 활동을 통해 추구하는 이익이 전체 공동체의 이익에 해당하는 공익적 성격을 갖는 것으로 보기도 어렵습니다.

그리고 대한지방행정공제회는 「대한지방행정공제회법」 제8조제1항에 따라 결의기관으로서 대의원회와 운영위원회를 두고, 집행기관으로서 이사장과 이사를 두며, 감사기관으로서 감사를 두고, 같은 법 제13조제1항 및 제2항에 따라 이사장, 이사 및 감사는 대의원회에서

164) 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008두5643 판결례

선출하는데, 이러한 대한지방행정공제회 임직원에 대해 국가공무원에 준하는 결격 사유를 규정하거나 임직원이 직무와 관련하여 뇌물 수뢰 등의 죄를 범한 경우에 공무원으로 의제하여 처벌하도록 하는 등 대한지방행정공제회의 임직원을 공무원에 준하여 규율하는 별도의 규정을 두고 있지 않고 있고, 「대한지방행정공제회법」 제24조에서는 이 법에 규정된 것을 제외하고는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용하도록 하는 점 등 「민법」 등에 따라 설립된 일반 법인과 특별히 다르게 규율하고 있지도 않다고 할 것인바, 앞서 살펴본 대한지방행정공제회의 회원, 사업내용 및 업무에 적용되는 규정 등을 종합하여 볼 때 대한지방행정공제회는 민원처리법 제2조제3호나목3)에 따른 특별법에 따라 설립된 특수법인에 해당한다고 보기 어렵습니다.

따라서 대한지방행정공제회는 민원처리법 제2조제3호나목3)에 따른 "특별법에 따라 설립된 특수법인"에 해당하지 않습니다.

관계법령

민원 처리에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "민원"이란 민원인이 행정기관에 대하여 처분 등 특정한 행위를 요구하는 것을 말하며, 그 종류는 다음 각 목과 같다.
   가. · 나. (생 략)
2. (생 략)
3. "행정기관"이란 다음 각 목의 자를 말한다.
   가. 국회·법원·헌법재판소·중앙선거관리위원회의 행정사무를 처리하는 기관, 중앙행정기관(대통령 소속 기관과 국무총리 소속 기관을 포함한다. 이하 같다)과 그 소속 기관, 지방자치단체와 그 소속 기관
   나. 공공기관
      1) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 법인·단체 또는 기관
      2) 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
      3) 특별법에 따라 설립된 특수법인
      4) 「초·중등교육법」·「고등교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교
      5) 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인·단체 또는 기관
   다. 법령 또는 자치법규에 따라 행정권한이 있거나 행정권한을 위임 또는 위탁받은 법인·단체 또는 그 기관이나 개인

대한지방행정공제회법

제1조(목적) 이 법은 대한지방행정공제회를 설립하여 지방자치단체의 공무원 또는 지방행정사무에 종사하거나 종사하였던 사람 등에 대한 효율적인 공제제도를 확립·운영함으로써 이들의 생활안정과 복지증진을 도모함을 목적으로 한다.

제16조(사업) ① 공제회는 그 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 회원에 대한 급여의 지급
2. 회원을 위한 복지후생시설의 설치·운영
3. 기금 조성을 위한 사업

② 공제회는 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 범위에서 수익사업을 할 수 있다.

질의제목 25 ▶ 안건번호 24-0902

민원인 – 해사행정사가 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제67조제1항에 따른 이의신청 대리를 할 수 있는지 여부(「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련)

01 질의요지

「행정사법」 제2조제1항에서는 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(제5호) 등 같은 항 각 호의 업무를 수행한다고 규정하고 있고, 같은 법 제4조에서는 행정사는 소관 업무에 따라 일반행정사, 해사행정사 및 외국어번역행정사로 구분하고, 종류별 업무의 범위와 내용은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조제2호에서는 해사행정사의 업무 범위와 내용으로 해운 또는 해양안전심판에 관한 같은 법 제2조제1항 각 호(같은 항 제3호는 제외함)의 업무를 규정하고 있는 한편,

「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」(이하 "해양사고심판법"이라 함) 제67조제1항에서는 지방해양안전심판원(이하 "지방심판원"이라 함)에서 결정을 받은 자는 중앙해양안전심판원(이하 "중앙심판원"이라 함)에 이의를 신청할 수 있다고 규정하고 있는바,

「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제2호의 해사행정사[165]가 해양사고심판법 제67조제1항에 따른 이의신청을 대리할 수 있는지?

02 회답

「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제2호의 해사행정사는 해양사고심판법 제67조제1항에 따른 이의신청을 대리할 수 없습니다.

165) 해양사고심판법 제28조에 따른 심판변론인의 자격을 갖추지 못한 경우를 전제함

03 이유

「행정사법」 제2조제1항 본문에서는 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 같은 항 각 호의 업무를 수행한다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서는 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)를 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 행정사가 수행할 수 있는 대리 업무의 범위를 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일(이하 "인허가신청등"이라 함)을 대리하는 일로 규정하고 있고, 같은 법 제4조에서는 행정사를 소관 업무에 따라 일반행정사, 해사행정사 및 외국어번역행정사로 구분하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조제2호에서는 해사행정사의 업무 범위와 내용으로 해운 또는 해양안전심판에 관한 같은 법 제2조제1항 각 호의 업무를 규정하고 있습니다.

한편 해양사고심판법 제3조에서는 해양사고사건을 심판하기 위하여 해양수산부장관 소속으로 해양안전심판원(지방심판원 및 중앙심판원)을 두도록 하면서 해양안전심판원은 제5조제1항에 따른 재결(裁決) 외에 심판관·비상임심판관의 제척·기피·회피(제15조제5항), 심판의 분리·병합(제24조제4항), 이송(제25조제1항), 이해관계인의 심판신청(제39조의2) 등에 관하여 결정을 하도록 규정하고 있고, 지방심판원에서 결정을 받은 자는 그 결정에 이의가 있는 경우에 중앙심판원에 이의를 신청할 수 있으며(제67조제1항), 중앙심판원은 이의신청에 대한 결정을 하도록(제71조제1항) 규정하고 있는바, 해사행정사가 해양사고심판법 제67조제1항에 따른 이의신청 대리업무를 할 수 있는지를 판단하기 위해서는 해당 이의신청이 「행정사법 시행령」 제2조제5호에 따른 인허가신청등에 해당하는지 여부 등을 검토할 필요가 있습니다.

먼저 「행정사법」 제2조제1항 및 같은 법 시행령 제2조 각 호에서는 행정사가 다른 사람의 위임을 받아 수행할 수 있는 업무를 규정하고 있는데, 같은 법 제2조제1항제1호에서는 행정사가 수행할 수 있는 업무로 "행정기관에 제출하는 서류의 작성"을 규정하면서 같은 법 시행령 제2조제1호가목에서는 해당 사무의 내용 및 범위로 "행정기관에 제출하는 이의신청에 관한 서류의 작성"을 명시하고 있는 반면, 같은 법 제2조제1항제5호에서는 행정사가 수행할 수 있는 업무로 "인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리"를 규정하면서 같은 법 시행령 제2조제5호에서는 해당 사무의 내용 및 범위를 "인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는

일을 대리하는 일"로 규정하여, 이의신청 등 행정기관의 처분등의 불복에 관한 신청·청구를 행정사가 대리할 수 있는 행위에 명시적으로 포함하고 있지 않은바,[166] 해사행정사는 해양사고심판법 제67조제1항에 따른 이의신청을 대리할 수는 없다고 해석됩니다.

그리고 「행정사법」 제22조제3호에서는 행정사와 그 사무직원이 하여서는 아니 되는 행위로 "행정사의 업무범위를 벗어나서 타인의 소송이나 그 밖의 권리관계분쟁 또는 민원사무처리과정에 개입하는 행위"를 규정하고 있고, 같은 법 제36조제3항제4호에서는 이를 위반한 경우 100만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있으므로 같은 법 시행령 제2조제5호에 따라 행정사가 대리할 수 있는 "인허가신청등"에는 원칙적으로 타인의 권리관계 분쟁에 개입하는 것은 포함되지 않는다고 할 것인데[167], 해양사고심판법에서의 이의신청 제도는 지방심판원에서 결정을 받은 자가 중앙심판원에 이의를 신청하는 절차로서(제67조제1항) 같은 법에서는 이의신청이 있을 때에 원심조서, 그 밖의 관계 서류 및 증거물(제69조), 심판관계인의 진술(같은 법 시행령 제62조 및 제71조), 조사관의 의견 등을 종합하여 결정(제71조)을 할 수 있도록 하는 등의 규정을 두어 지방심판원의 결정에 대해 적극적으로 다툴 수 있도록 규정하고 있는바, 해양사고심판법 제67조제1항에 따른 이의신청은 「행정사법」 제22조제3호에 따른 소송이나 그 밖의 권리관계분쟁에 해당[168]하여 해사행정사는 해양사고심판법 제67조제1항에 따른 이의신청 대리를 할 수 없다고 해석하는 것이 법률의 체계에도 부합합니다.

아울러 해양사고심판법 제27조제1항에서는 해양사고관련자나 이해관계인은 심판변론인을 선임할 수 있다고 규정하면서 같은 법 제28조제1항에서는 심판변론인의 자격 요건을 심판관 및 조사관으로 근무한 경력이 있는 사람(제2호), 변호사 자격이 있는 사람(제4호) 등 해양사고의 조사·심판 또는 법률사무에 대한 전문성을 갖춘 사람으로 한정하여 규정하고 있고, 같은 법 제29조제1항제1호에서는 심판변론인의 업무로 "해양사고관련자나 이해관계인이 같은 법에 따라 심판원에 대하여 하는 신청·청구·진술 등의 대리 또는 대행"을 규정하여 업무 성격상 상당한 수준의 전문성과 자격을 갖춘 심판변론인으로 하여금 이의신청의 대리 등과 같은 업무를 수행하게 하여 해양사고관련자와 이해관계인의 정당한 권리를 보호하도록 규정[169]하고 있는데, 일반적인 행정지식을 갖춘 사람에게 행정사의 자격을 부여하여 비교적 단순하고 정형화된 업무를 처리할 수 있도록 하여 행정적인 도움을

166) 법제처 2007. 11. 16. 회신 07-0349 해석례; 법제처 2023. 10. 24. 회신 23-0439 해석례 참조

167) 법제처 2022. 10. 28. 회신 22-0327 해석례 참조

168) 법제처 2007. 11. 16. 회신 07-0349 해석례 참조

169) 1987. 10. 21. 의안번호 제120565호로 발의된 해난심판법중개정법률안 소관위원회 심사보고서 참조

필요로 하는 자가 저렴한 비용으로 행정 서비스에 접근할 수 있도록 하려는 행정사 제도의 취지에 비추어 보면[170], 해사행정사가 대리할 수 있는 업무에 해양사고심판법상의 이의신청이 포함된다고 보기는 어렵다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「행정사법」 제4조 및 같은 법 시행령 제3조제2호의 해사행정사는 해양사고심판법 제67조제1항에 따른 이의신청을 대리할 수 없습니다.

관계법령

행정사법

제2조(업무) ① 행정사는 다른 사람의 위임을 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 다른 법률에 따라 제한된 업무는 할 수 없다.
1. 행정기관에 제출하는 서류의 작성
2. 권리·의무나 사실증명에 관한 서류의 작성
3. 행정기관의 업무에 관련된 서류의 번역
4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 작성된 서류의 제출 대행(代行)
5. 인가·허가 및 면허 등을 받기 위하여 행정기관에 하는 신청·청구 및 신고 등의 대리(代理)
6. 행정 관계 법령 및 행정에 대한 상담 또는 자문에 대한 응답
7. 법령에 따라 위탁받은 사무의 사실 조사 및 확인

② 제1항에 따른 업무의 내용과 범위는 대통령령으로 정한다.

제4조(행정사의 종류) 행정사는 소관 업무에 따라 일반행정사, 해사행정사 및 외국어번역행정사로 구분하고, 종류별 업무의 범위와 내용은 대통령령으로 정한다.

행정사법 시행령

제2조(업무의 내용과 범위) 「행정사법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1항 각 호에 따른 행정사 업무의 내용과 범위는 다음 각 호와 같다.
1. 법 제2조제1항제1호의 사무: 행정기관에 제출하는 다음 각 목의 서류를 작성하는 일
   가. 진정·건의·질의·청원 및 이의신청에 관한 서류
   나. 출생·혼인·사망 등 가족관계의 발생 및 변동 사항에 관한 신고 등의 각종 서류
2. ~ 4. (생 략)
5. 법 제2조제1항제5호의 사무: 다른 사람의 위임을 받아 인가·허가·면허 및 승인의 신청·청구 등 행정기관에 일정한 행위를 요구하거나 신고하는 일을 대리하는 일
6.·7. (생 략)

170) 헌법재판소 2024. 8. 29. 선고 전원재판부 2020헌마839 결정례 참조

제3조(행정사의 종류별 업무의 범위와 내용) 법 제4조에 따른 행정사의 종류별 업무의 범위와 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 일반행정사: 법 제2조제1항 각 호(제3호는 제외한다)의 업무(해운 또는 해양안전심판에 관한 업무는 제외한다)
2. 해사행정사: 해운 또는 해양안전심판에 관한 법 제2조제1항 각 호(제3호는 제외한다)의 업무
3. 외국어번역행정사: 법 제2조제1항제3호 및 제4호의 업무

해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률

제67조(결정에 대한 이의신청) ① 지방심판원에서 결정을 받은 자는 중앙심판원에 이의를 신청할 수 있다.

② 이의신청은 제2심 재결이 있을 때까지 할 수 있다.

제2절 공무원

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-1025

민원인 – 지방공무원의 고충심사 청구 등에 대한 조치 의무가 있는 임용권자의 범위(「지방공무원법」 제67조의2제1항 등 관련)

01 질의요지

「지방공무원법」 제67조의2제1항 전단에서 공무원[171]은 누구나 인사·조직·처우 등 각종 근무조건과 그 밖의 신상문제와 관련한 고충에 대하여 상담을 신청하거나 심사를 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 임용권자는 같은 조 제1항에 따라 상담을 신청받은 경우에는 소속 공무원을 지정하여 상담하게 하고, 심사를 청구 받은 경우에는 인사위원회 회의에 부쳐 심사하도록 해야 하며 그 결과에 따라 고충의 해소 등 공정한 처리를 위하여 노력해야 한다고 규정하고 있는바,

「지방공무원법」 제67조의2제1항에 따른 시·군·구(자치구를 말하며, 이하 같음) 또는 시·군·구의회 소속 공무원의 상담 신청이나 심사 청구(이하 "고충심사청구등"이라 함)에 대해 같은 조 제2항에 따른 조치(이하 "고충처리"라 함)를 해야 하는 임용권자에 특별시장·광역시장·도지사(이하 "시·도지사"라 함) 또는 특별시·광역시·도(이하 "시·도"라 함)의회의 의장이 포함되는지[172]?

171) 지방자치단체 또는 지방의회 소속 공무원을 말하며, 이하 같음.

172) 시·도지사가 시장·군수·구청장의 임용권에 대해, 시·도의회의 의장이 시·군·구의회의 의장의 임용권에 대해 관여하지 않은 경우를 전제로 함.

02 회답

이 사안의 경우 「지방공무원법」 제67조의2제1항에 따른 시·군·구 또는 시·군·구의회 소속 공무원의 고충심사청구등에 대해 고충처리를 해야 하는 임용권자에는 시·도지사 또는 시·도의회의 의장은 포함되지 않습니다.

03 이유

먼저 「지방공무원법」 제67조의2제2항에 따르면, 고충심사청구등을 받은 "임용권자"는 소속 공무원을 지정하여 상담하게 하거나 인사위원회 회의에 부쳐 심사하도록 해야 하는 등 고충처리를 해야 하는데, 같은 조에서 "임용권자"의 범위가 시·군·구 또는 시·군·구의회 소속 공무원의 임용권자인 시장·군수·구청장 또는 시·군·구의회의 의장으로 한정되는지에 대해 규정하고 있지는 않으나, 같은 법 제6조에서 "임용권자"라는 조 제목 아래 지방자치단체의 장[173] 및 지방의회의 의장[174]은 같은 법에서 정하는 바에 따라 그 '소속' 공무원의 임명·휴직·면직과 징계를 하는 권한인 '임용권'을 가진다고 규정(제1항)하고 있고, 지방자치단체의 종류와 조직 및 운영 등에 관한 사항을 정하고 있는 「지방자치법」에서는 지방자치단체의 종류를 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도와 시, 군, 구로 구분하여 규정(제2조제1항)하면서, 지방의회의 의장은 지방의회 사무직원을 지휘·감독하고 법령과 조례·의회규칙으로 정하는 바에 따라 그 임면·교육·훈련·복무·징계 등에 관한 사항을 처리(제103조제2항)하고, 지방자치단체의 장은 '소속' 직원을 지휘·감독하고 법령과 조례·규칙으로 정하는 바에 따라 그 임면·교육훈련·복무·징계 등에 관한 사항을 처리한다고 규정(제118조)하고 있는 점 등을 종합하면, 「지방공무원법」 제6조에 따른 임용권자는 그 소속 공무원에 대한 임용권을 갖는 자, 즉 시·군·구 소속 공무원인 경우 시장·군수·구청장을, 시·군·구의회 소속 공무원인 경우 시·군·구의회의 의장을 의미한다 할 것이므로, 이 사안의 경우에 있어서도 같은 법 제67조의2제2항에 따라 시·군·구 또는 시·군·구의회 소속 공무원에 대한 고충처리를 해야 하는 임용권자에 시·도지사 또는 시·도의회의 의장이 포함되는 것으로 보기는 어렵습니다.

그리고 「지방공무원 임용령」(대통령령) 제66조의2제1항에서는 「지방공무원법」 제67조의2제1항 및 같은 법 제67조의3에 따라 공무원이 고충심사를 청구할 때에는 주소, 성명 및

173) 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의 교육감을 포함함.

174) 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의회의 의장 및 시·군·구의회의 의장을 말함.

생년월일(제1호), 소속 기관명 및 직급·직위(제2호) 등을 적은 고충심사청구서를 '임용권자'에게 제출해야 한다고 규정하고 있고, 같은 영 제66조의2제2항에서는 같은 조 제1항에 따라 청구서를 제출받은 임용권자는 지체 없이 해당 인사위원회 회의에 부쳐 이를 심사하도록 해야 한다고 규정하고 있는 한편, 같은 조 제3항에서는 소속 기관을 달리하는 2명 이상의 공무원이 관련된 고충심사의 청구에 대해서는 해당 시·도의 인사위원회에서 심사(전단)하고, 지방자치단체의 장 소속 공무원과 지방의회의 의장 소속 공무원이 관련된 고충심사의 청구에 대해서는 시·도지사가 두는 인사위원회에서 심사(후단)한다고 규정하고 있는 등 임용권자를 달리하는 지방자치단체 및 지방의회에 소속된 공무원과 관련된 고충심사 청구의 처리에 대해서는 특별한 규정을 두고 있는 점에 비추어 보더라도 이러한 특별한 규정이 없는 한 법체계상 시·군·구 또는 시·군·구의회 소속 공무원은 각각 그 임용권자인 시장·군수·구청장 및 시·군·구의회의 의장에게 고충심사청구등을 해야 하고, 그 청구가 있는 경우 해당 임용권자에게 고충처리를 할 책임이 있다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우 「지방공무원법」 제67조의2제1항에 따른 시·군·구 또는 시·군·구의회 소속 공무원의 고충심사청구등에 대해 고충처리를 해야 하는 임용권자에는 시·도지사 또는 시·도의회의 의장은 포함되지 않습니다.

관계법령

지방공무원법

제6조(임용권자) ① 지방자치단체의 장[특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)의 교육감을 포함한다. 이하 같다] 및 지방의회의 의장[시·도의회의 의장 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)의회의 의장을 말한다. 이하 같다]은 이 법에서 정하는 바에 따라 그 소속 공무원의 임명·휴직·면직과 징계를 하는 권한(이하 "임용권"이라 한다)을 가진다.

②·③ (생 략)

제67조의2(고충처리) ① 공무원은 누구나 인사·조직·처우 등 각종 근무조건과 그 밖의 신상문제와 관련한 고충에 대하여 상담을 신청하거나 심사를 청구할 수 있으며, 누구나 기관 내 성폭력 범죄 또는 성희롱을 겪거나 그 발생 사실을 알게 된 경우 이를 신고할 수 있다. 이 경우 상담 신청이나 심사 청구 또는 신고를 이유로 불이익을 주는 처분이나 대우를 받지 아니한다.

② 임용권자는 제1항에 따라 상담을 신청 받은 경우에는 소속 공무원을 지정하여 상담하게 하고, 심사를 청구 받은 경우에는 인사위원회 회의에 부쳐 심사하도록 하여야 하며 그 결과에 따라 고충의 해소 등 공정한 처리를 위하여 노력하여야 한다.

③ 임용권자는 기관 내 성폭력 범죄 또는 성희롱 발생 사실의 신고를 받은 경우에는 지체 없이 사실

확인을 위한 조사를 하고 그에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.
④ 인사위원회는 임용권자로부터 고충심사의 요구를 받으면 지체 없이 이를 심사하고 임용권자에게 보고하거나 알려야 한다.
⑤ 제4항에 따라 고충심사 결과에 대한 보고 또는 통지를 받은 임용권자는 심사결과를 청구인에게 알릴 뿐 아니라 직접 고충 해소를 위한 조치를 하거나 관계 기관의 장에게 시정요청을 할 수 있으며, 요청을 받은 관계 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이를 이행하고 그 처리 결과를 임용권자에게 알려야 한다. 다만, 부득이한 사유로 이행하지 못할 경우에는 그 사유를 알려야 한다.
⑥ 고충상담이나 고충심사의 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-1094

민원인 – 5급 국가공무원이 의원면직 다음 날 다른 국가기관에 다른 직렬의 6급 국가공무원으로 신규채용된 경우가 강임된 경우에 해당하는지 여부(「국가공무원법」 제73조의4제1항 등 관련)

01 질의요지

「국가공무원법」 제73조의4제1항에서는 임용권자는 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐직되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 또는 본인이 동의한 경우에는 소속 공무원(국가공무원을 말하며, 이하 같음)을 강임할 수 있다고 규정하고 있는바,

5급 공무원이 본인의 원(願)에 따라 퇴직(이하 "의원면직"이라 함)한 후 그 다음 날 다른 국가기관[175]에 다른 직렬의 6급 공무원으로 「국가공무원법」 제28조제2항에 따른 경력경쟁채용시험등[176]을 통해 신규채용된 경우가 같은 법 제73조의4제1항에 따라 강임된 경우에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「국가공무원법」 제73조의4제1항에 따라 강임된 경우에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 법령의 정의 규정은 법령에서 쓰고 있는 용어 중 개념상 중요한 용어에 대하여 법령 자체에서 그 의미를 명확하게 할 목적으로 두는 것으로 원칙적으로 법령 전체에 효력을 미친다

175) 의원면직한 국가기관과 임용권자가 다른 국가기관을 전제함.

176) 「국가공무원법」 제28조제2항 각 호 외의 부분 본문에 따른 경력경쟁채용시험(경력 등 응시요건을 정하여 같은 사유에 해당하는 다수인을 대상으로 경쟁의 방법으로 채용하는 시험) 및 같은 항 각 호 외의 부분 단서에 따른 시험을 말하며, 이하 "경력경쟁채용시험등"이라 함.

할 것인데[177], 「국가공무원법」 제5조에서는 같은 법에서 사용하는 용어의 뜻을 규정하면서, 제4호에서 "강임"을 같은 직렬 내에서 하위 직급에 임명하거나 하위 직급이 없어 다른 직렬의 하위 직급으로 임명하거나 고위공무원단에 속하는 일반직공무원을 고위공무원단 직위가 아닌 하위 직위에 임명하는 것으로 정의하고 있는바, 고위공무원단에 속하지 않는 공무원을 임명하는 행위가 같은 법에 따른 "강임"에 해당하기 위해서는 '같은 직렬 내에서 하위 직급에 임명'하거나 '하위 직급이 없어 다른 직렬의 하위 직급으로 임명'하는 임용권자의 행위가 요구된다 할 것입니다.

또한 「공무원임용령」 제2조제1호에서는 "임용"을 신규채용, 승진임용, 전직(轉職), 전보, 겸임, 파견, 강임(降任), 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면으로 열거하여 규정하고 있는 점에 비추어 보면 국가공무원법령상 신규채용, 강임 및 면직은 각각 구별되는 별개의 임용행위로 보아야 할 것이므로, 이 사안과 같이 '의원면직'이라는 임용행위가 있은 후 다시 경력경쟁채용시험등의 절차를 거쳐 '신규채용'된 경우를 국가공무원법령상 "강임"된 경우에 해당하는 것으로 보기는 어렵습니다.

다음으로 「국가공무원법」 제73조의4제1항에서 '임용권자'는 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐직되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 또는 본인이 동의한 경우에는 '소속 공무원'을 강임할 수 있다고 규정하고 있는바, 같은 항에 따른 강임은 같은 기관 내에서 해당 기관의 '임용권자'가 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐직되는 등의 사유로 그 '소속 공무원'을 하위 직급으로 임명하는 행위로서, 이 사안과 같이 원 소속기관의 임용권자가 의원면직하고, 새로운 소속기관의 임용권자가 신규채용한 경우로서 원 소속기관이나 새로운 소속기관의 '임용권자'가 '5급 국가공무원에서 6급 국가공무원으로 임명'한 바가 없는 경우에는 같은 항에 따라 '강임'된 경우에 해당하지 않는다는 점이 문언상 명확합니다.

더욱이 「국가공무원법」 제73조의4제2항 본문에서는 같은 조 제1항에 따라 강임된 공무원은 상위 직급 또는 고위공무원단 직위에 결원이 생기면 같은 법 제40조· 제40조의2·제40조의4 및 제41조에도 불구하고 우선 임용된다고 규정하고 있는바, 이는 같은 법에서 규정하고 있는 공무원의 승진임용 방법 및 절차에도 불구하고 같은 법 제73조의4 제1항에 따라 강임된 공무원에 대해서는 우선 승진임용될 수 있는 예외를 규정한 것으로서, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있는바,[178] 같은 법 제73조의4제1항의 문언을 합리적인 이유 없이 확대해석

177) 법제처 법령입안·심사기준(2021) p. 59 참조

하여 의원면직 후 다른 국가기관에 신규채용된 경우까지 같은 항에 따라 강임된 경우에 포함되는 것으로 볼 수는 없습니다.

한편 공무원연금법령에서는 공무원의 신분이 소멸된 날 또는 그 다음 날에 다시 신분을 취득하고 퇴직급여 및 퇴직수당을 받지 아니한 경우에는 '퇴직'으로 보지 않으므로[179], 이 사안과 같이 의원면직으로 공무원 신분이 소멸된 날의 바로 다음 날 신규채용으로 다시 신분을 취득한 경우에는 '퇴직'한 경우에 해당하지 않아 5급에서 6급으로 '강임'된 것으로 보아야 한다는 의견이 있으나, 동일한 용어라 하더라도 각각의 법령에서 사용하고 있는 용어의 의미는 반드시 같은 의미로 볼 수는 없고 법령의 입법목적과 취지에 따라 개별적으로 검토해야 할 것[180]인바, 「공무원연금법」 제3조제3호 단서에서 같은 법에 따른 "퇴직"의 개념에서 '공무원의 신분이 소멸된 날 또는 그 다음 날에 다시 신분을 취득하고 같은 법에 따른 퇴직급여 및 퇴직수당을 받지 아니한 경우'를 제외하고 있는 것은 연금 수급권의 발생 요건인 퇴직과 퇴직금 산정의 기초가 되는 재직기간을 계산할 때 퇴직급여 등을 받지 않고 퇴직 후 연이어 공무원 신분을 다시 취득한 경우에는 퇴직으로 보지 않는 특례를 둔 취지일 뿐, 국가공무원법령에 따른 임용관계의 발생과 소멸 등의 법적 효과나 취급까지 달리하려는 것으로 볼 수 없으므로[181] 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「국가공무원법」 제73조의4제1항에 따라 강임된 경우에 해당하지 않습니다.

관계법령

국가공무원법

제5조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "직위(職位)"란 1명의 공무원에게 부여할 수 있는 직무와 책임을 말한다.
2. "직급(職級)"이란 직무의 종류·곤란성과 책임도가 상당히 유사한 직위의 군을 말한다.
3. (생 략)
4. "강임(降任)"이란 같은 직렬 내에서 하위 직급에 임명하거나 하위 직급이 없어 다른 직렬의 하위

178) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

179) 「공무원연금법」 제3조제3호 단서

180) 법제처 2021. 3. 3. 회신 20-0727 해석례 참조

181) 법제처 2022. 8. 31. 회신 22-0164 해석례 참조

직급으로 임명하거나 고위공무원단에 속하는 일반직공무원(제4조제2항에 따라 같은 조 제1항의 계급 구분을 적용하지 아니하는 공무원은 제외한다)을 고위공무원단 직위가 아닌 하위 직위에 임명하는 것을 말한다.

5. "전직(轉職)"이란 직렬을 달리하는 임명을 말한다.

6.·7. (생 략)

8. "직렬(職列)"이란 직무의 종류가 유사하고 그 책임과 곤란성의 정도가 서로 다른 직급의 군을 말한다.

9.·10. (생 략)

제73조의4(강임) ① 임용권자는 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐직되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 또는 본인이 동의한 경우에는 소속 공무원을 강임할 수 있다.

② 제1항에 따라 강임된 공무원은 상위 직급 또는 고위공무원단 직위에 결원이 생기면 제40조·제40조의2·제40조의4 및 제41조에도 불구하고 우선 임용된다. 다만, 본인이 동의하여 강임된 공무원은 본인의 경력과 해당 기관의 인력 사정 등을 고려하여 우선 임용될 수 있다.

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0131, 24-0219

민원인 – 동일 소속기관 내 부서의 통폐합 및 승진임용이 「공무원임용령」 제45조의2제3항 단서의 예외사유에 해당되는지 여부(「공무원 임용령」 제45조의2 등 관련)

01 질의요지

「공무원임용령」 제45조의2제3항에서는 「국가공무원법」 제28조제2항제3호에 따라 경력경쟁채용시험[182]을 통하여 채용된 공무원(이하 "제3호경력경쟁채용공무원"이라 함)은 최초 임용일부터 5년의 전출제한기간이 지나야 전출[183]될 수 있되(본문), 기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 전출할 때에는 그렇지 않다(단서)고 규정하고 있는바,

제3호경력경쟁채용공무원이 소속 장관[184]이 같은 기관[185] 내에서 ① 직제의 변경으로 부서가 통폐합되어 해당 직위는 유지한채로 전보된 경우 및 ② 승진임용된 경우가 「공무원임용령」 제45조의2제3항 단서에 따른 전출제한기간의 예외사유에 해당되는지?

02 회답

제3호경력경쟁채용공무원이 소속 장관이 같은 기관 내에서 ① 직제의 변경으로 부서가 통폐합되어 해당 직위는 유지한채로 전보된 경우 및 ② 승진임용된 경우는 「공무원임용령」 제45조의2제3항 단서에 따른 전출제한기간의 예외사유에 해당되지 않습니다.

182) 「국가공무원법」 제28조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 경력 등 응시요건을 정하여 다수인을 대상으로 경쟁의 방법으로 채용하는 시험을 말하며, 이하 같음.

183) 소속 장관이 다른 기관으로 전보되는 것을 말하며(「공무원임용령」 제45조의2제1항 참조), 이하 같음.

184) 「공무원임용령」 제2조제3호에 따른 소속 장관을 말하며, 이하 같음.

185) 해당 공무원이 경력경쟁채용시험을 통하여 최초 임용된 기관을 전제함.

03 이유

법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것[186]인데, 「국가공무원법」 제28조제2항 제3호에서는 임용예정 직급·직위와 같은 직급·직위[187]에서의 근무경력 또는 임용예정 직급·직위에 상응하는 근무기간이나 연구 경력이 대통령령등으로 정하는 기간 이상인 사람을 임용하는 경우에는 경력경쟁채용시험으로 공무원을 채용할 수 있다고 규정하고 있고, 「공무원임용령」 제45조의2제3항에서는 공직의 전문성을 강화하고 해당 기관의 안정적인 인력관리를 도모하기 위해 경력경쟁채용시험 등을 통하여 채용된 공무원의 "전출", 즉 '소속 장관이 다른 기관으로의 전보'를 최초 임용일부터 5년간 제한(본문)하면서, 예외적으로 "기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 전출할 때"에는 그러한 제한의 적용을 배제(단서) 하고 있는바, 같은 항 단서는 같은 항 본문에 따른 전출제한의 필요성에도 불구하고 전출을 허용하는 예외적인 경우로서, 그 예외 사유는 엄격하게 해석해야 할 것입니다.

그런데 「공무원임용령」 제45조의2제3항 단서에서 제3호경력경쟁채용공무원 등의 전출 제한의 예외사유로 규정하고 있는 "기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 전출할 때"의 의미를 살펴보면, "~으로"는 체언(體言) 뒤에 붙어 어떤 일의 원인이나 이유를 나타내는 격(格)조사[188]이고, 전출제한의 예외사유는 엄격하게 해석해야 한다는 점에 비추어 볼 때, 같은 항 단서는 '기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경'이 발생하기만 하면 전출제한기간의 적용이 배제된다는 의미로 볼 수는없고, '기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경'이 '원인'이 되어 불가피하게 해당 공무원을 '소속 장관이 다른 기관으로 전보'해야 하는 경우에는 예외적으로 전출제한기간이 지나지 않은 경우에도 전출할 수 있다는 의미로 보아야 할 것입니다.

그렇다면 「공무원임용령」 제45조의2제3항 단서의 "기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 전출할 때"는 기구개편에 따라 기관이 통폐합되거나 소관 업무의 일부가 소속 장관이 다른 기관으로 이관되는 등의 사유로 불가피하게 경력경쟁채용된 공무원을 전출하는 경우를 의미한다고 할 것인데,[189] 이 사안과 같이 제3호경력경쟁채용공무원이 소속 장관이 같은 기관 내에서 ① 직제의 변경으로 부서가 통폐합되어 원래 직위는 유지한채로 전보된 경우 및 ②

186) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 참조

187) 고위공무원단에 속하는 일반직공무원은 임용예정 직위와 곤란성·책임도가 유사한 직위를 말함.

188) 국립국어원 표준국어대사전 참조

189) 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제26조의2 및 「공무원임용령」 제49조의2 참조

원래 계급보다 높은 계급으로 승진임용된 경우, 그 '전보 또는 승진임용'은 소속 장관이 동일한 기관 내에서 이루어지는 임용행위로서, 「공무원임용령」 제45조제3항제1호·제2호 및 같은 조 제6항 단서에 따라 소속 공무원을 기관 내 다른 직위에 전보할 수 있는 전보제한의 예외사유[190]에 해당하는지는 별론으로 하더라도, 해당 임용행위가 직접적인 원인이 되어 불가피하게 그 공무원을 소속 장관이 다른 기관으로 전보해야 하는 사유가 된다고 볼 수는 없습니다.

따라서 제3호경력경쟁채용공무원이 소속 장관이 같은 기관 내에서 ① 직제의 변경으로 부서가 통폐합되어 해당 직위는 유지한채로 전보된 경우 및 ② 승진임용된 경우는 「공무원임용령」 제45조의2제3항 단서에 따른 전출제한기간의 예외사유에 해당되지 않습니다.

관계법령

국가공무원법

제28조(신규채용) ① (생 략)

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경력 등 응시요건을 정하여 같은 사유에 해당하는 다수인을 대상으로 경쟁의 방법으로 채용하는 시험(이하 "경력경쟁채용시험"이라 한다)으로 공무원을 채용할 수 있다. 다만, 제1호, 제3호, 제4호, 제5호, 제7호, 제11호의 어느 하나에 해당하는 경우 중 다수인을 대상으로 시험을 실시하는 것이 적당하지 아니하여 대통령령등으로 정하는 경우에는 다수인을 대상으로 하지 아니한 시험으로 공무원을 채용할 수 있다.

1.·2. (생 략)

3. 임용예정 직급·직위와 같은 직급·직위(고위공무원단에 속하는 일반직공무원은 임용예정 직위와 곤란성·책임도가 유사한 직위를 말한다)에서의 근무경력 또는 임용예정 직급·직위에 상응하는 근무기간이나 연구 경력이 대통령령등으로 정하는 기간 이상인 사람을 임용하는 경우

4. ~ 13. (생 략)

③ ~ ⑤ (생 략)

제40조(승진) ① 승진임용은 근무성적평정·경력평정, 그 밖에 능력의 실증에 따른다. 다만, 1급부터 3급까지의 공무원으로의 승진임용 및 고위공무원단 직위로의 승진임용의 경우에는 능력과 경력 등을 고려하여 임용하며, 5급 공무원으로의 승진임용의 경우에는 승진시험을 거치도록 하되, 필요하다고 인정하면 대통령령등으로 정하는 바에 따라 승진심사위원회의 심사를 거쳐 임용할 수 있다.

② 6급 이하 공무원으로의 승진임용의 경우 필요하다고 인정하면 대통령령등으로 정하는 바에 따라 승진시험을 병용(竝用)할 수 있다.

190) 「공무원임용령」 제45조제3항 및 제6항에 따르면 기관 내 전보제한기간의 예외사유로 "기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 해당 공무원을 전보하는 경우"를 규정하고 있음

③ 승진에 필요한 계급별 최저 근무연수, 승진 제한, 그 밖에 승진에 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다.

공무원임용령

제2조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "임용"이란 신규채용, 승진임용, 전직(轉職), 전보, 겸임, 파견, 강임(降任), 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면을 말한다.
2. ~ 7. (생 략)

제45조의2(소속 장관이 다른 기관으로의 전보) ① 임용권자 또는 임용제청권자가 소속 공무원을 소속 장관이 다른 기관으로 전보(이하 이 조에서 "전출"이라 한다)하거나 소속 장관이 다른 기관의 공무원을 임용제청 또는 전입시키려고 할 때에는 해당 기관의 장의 동의를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

1. 법 제32조제1항 전단에 따라 소속 장관이 다른 고위공무원단에 속하는 공무원을 임용제청하는 경우
2. 법 제32조의2에 따른 인사교류계획에 따라 전입 또는 전출하는 경우

② (생 략)

③ 법 제28조제2항제2호, 제3호, 제6호부터 제10호까지, 제12호 및 제13호에 따라 경력경쟁채용시험등을 통하여 채용된 공무원은 최초 임용일부터 5년(법 제28조제2항제7호에 따라 채용된 공무원은 3년)의 전출제한기간이 지나야 전출될 수 있다. 다만, 기구의 개편, 직제 또는 정원의 변경으로 전출할 때에는 그렇지 않다.

④·⑤ (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0375

민원인 – 「지방공무원법」 제63조제1항제5호에 따른 휴직 사유의 범위(「지방공무원법」 제63조제1항 등 관련)

01 질의요지

「병역법」에 따라 입영하여 병(兵)으로 복무를 마친 후 공무원으로 재직하는 자가 다시 「군인사법」 제6조제7항제1호에 따라 지원에 의하여 단기복무 부사관으로 복무하려는 경우가 「지방공무원법」 제63조제1항제5호에 따른 휴직 사유인 "법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때"에 해당하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「지방공무원법」 제63조제1항제5호에 따른 휴직 사유인 "법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때"에 해당하지 않습니다.

03 이유

「지방공무원법」 제63조제1항제5호에서는 공무원이 "그 밖에 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때"에는 임용권자는 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명하여야 한다고 규정하고 있는바, "의무"란 규범에 의하여 부과되는 부담이나 구속[191]을 의미하고, "법률에 따른 의무"란 법률에서 이러한 의무를 규정하는 경우를 의미한다고 할 것인데, 「병역법」에 따라 입영하여 병(兵)으로 복무를 마친 공무원이 「군인사법」 제6조제7항제1호에 따라 "지원"에 의하여 단기복무 부사관으로 추가로 복무하려는 것은 자발적인 의사에 따른 것일 뿐 병역법령 등에서 군 복무를 마친 자에게 다시 단기복무 부사관 등으로 군 복무를

191) 국립국어원 표준국어대사전 참조

하여야 한다고 규정하고 있지 않으므로, 이 사안의 경우 「지방공무원법」 제63조제1항제5호에 따른 "법률에 따른 의무"를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때에 해당하지 않는다는 점이 분명합니다.

그리고 「병역법」 제3조제1항 전단에서는 대한민국 국민인 남성은 「대한민국헌법」과 이 법에서 정하는 바에 따라 "병역의무"를 성실히 수행하여야 한다고 규정하고 있고, 「병역법」 제6조제1항에서는 지방병무청장[192]은 "병역의무자"에게 병역의무를 부과하는 통지서를 송달하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제11조제1항 본문에서는 "병역의무자"는 19세가 되는 해에 병역을 감당할 수 있는지를 판정받기 위하여 지방병무청장이 지정하는 일시·장소에서 병역판정검사를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제14조제1항에서 지방병무청장은 병역판정검사를 받은 사람[193] 등에 대하여 신체등급 등에 따라 현역병입영 대상자, 보충역, 전시근로역, 병역면제, 재신체검사라는 병역처분을 하고 있을 뿐만 아니라[194], 같은 법 제88조제1항에서 현역입영 또는 소집 통지서를 받은 사람이 정당한 사유 없이 입영일이나 소집일부터 일정한 기간이 지나도 입영하지 아니하거나 소집에 응하지 아니한 경우에는 3년 이하의 징역에 처하도록 규정하고 있는 병역법령의 체계를 고려하면, 병역법령에 따라 병역의무 부과 통지서 송달, 병역판정 검사 및 병역처분에 따라 병역의무를 수행하는 경우가 아니라, 이미 「병역법」에 따라 입영하여 병(兵)으로 복무를 마친 후 공무원으로 재직하다가 「군인사법」에 따라 지원을 통해 별도의 임용 절차[195]를 거쳐 단기복무 부사관으로 추가로 복무하려는 것은 "법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때"에 해당한다고 볼 수 없습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「지방공무원법」 제63조제1항제5호에 따른 휴직 사유인 "법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때"에 해당하지 않습니다.

192) 병무지청장을 포함함(「병역법」 제6조제1항 참조)

193) 병원에서 신체검사를 받은 사람을 포함함

194) 「병역법」 제20조에서는 병무청장이나 각 군 참모총장은 18세 이상으로서 군에 복무할 것을 지원한 사람에 대하여 현역병으로 선발할 수 있다고 규정하고 있음

195) 「군인사법」 제14조 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 원칙적으로 부사관은 고등학교 이상의 학교를 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 학력을 가진 사람(제2호) 등으로서 '지원'에 의하여 부사관 임용시험에 합격하여 참모총장이 정하는 교육훈련과정을 마친 사람 중에서 임용함

관계법령

지방공무원법

제63조(휴직) ① 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 임용권자는 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체·정신상의 장애로 장기요양이 필요할 때
2. 「병역법」에 따른 병역의무를 마치기 위하여 징집되거나 소집되었을 때
3. 천재지변 또는 전시·사변이나 그 밖의 사유로 생사(生死) 또는 소재(所在)가 불명확하게 되었을 때
4. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제7조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 되었을 때
5. 그 밖에 법률에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 되었을 때

② ~ ⑤ (생 략)

군인사법

제6조(복무의 구분) ① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 장기복무 부사관은 군 교육기관에서 고등학교 교육과정을 마친 사람과 지원에 의하여 전형에 합격한 사람으로 한다.

⑦ 단기복무 부사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 제6항에 따른 장기복무 부사관이 아닌 사람으로서 지원에 의하여 전형에 합격한 사람
2. ~ 6. (생 략)

⑧ (생 략)

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0423

민원인 – 소속 장관은 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2제7항에 따라 장기성과급을 반드시 지급하여야 하는지(「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2 등 관련)

01 질의요지

「공무원수당 등에 관한 규정」(이하 "공무원수당규정"이라 함) 제7조의2제7항에서는 소속 장관은 해당 연도를 포함하여 3년 이상 연속으로 최상위등급의 성과상여금 또는 성과연봉[196]을 받은 국가공무원[197](이하 "공무원"이라 함)에게는 해당 공무원에게 지급되는 성과상여금 또는 성과연봉 지급액의 50퍼센트 이내의 금액을 장기성과급으로 지급할 수 있다고 규정하고 있는바,

소속 장관은 해당 연도를 포함하여 3년 이상 연속으로 최상위등급의 성과상여금 또는 성과연봉을 받은 공무원(이하 "이 사안 공무원"이라 함)에게는 공무원수당규정 제7조의2 제7항에 따라 장기성과급을 반드시 지급해야 하는지?

02 회답

소속 장관은 이 사안 공무원에게는 공무원수당규정 제7조의2제7항에 따라 장기성과급을 반드시 지급해야 하는 것은 아닙니다.

03 이유

먼저 공무원에게 지급하는 성과상여금 등을 규정하고 있는 공무원수당규정 제7조의2의 문언을 살펴보면, 같은 조 제1항에서는 소속 장관은 별표 2의2에 따른 공무원 중 근무성적,

196) 「공무원보수규정」 제4조제7호나목에 따른 성과연봉을 말하며, 이하 같음

197) 그 연속된 기간 중 계급·직급 또는 직무등급이 변동된 공무원을 포함하며, 이하 같음

업무실적 등이 우수한 사람에게는 예산의 범위에서 성과상여금을 “지급한다”고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 본문에서는 소속 장관은 별표 2의3의 지급기준액표에 따라 같은 항 각 호의 어느 하나의 지급방법으로 「공무원보수규정」 제4조의2에 따른 보수성과심의위원회의 심의를 거쳐 성과상여금을 “지급한다”고 규정하고 있는 반면, 같은 조 제7항에서는 이 사안 공무원에게는 해당 공무원에게 지급되는 성과상여금 또는 성과연봉 지급액의 50퍼센트 이내의 금액을 장기성과급으로 “지급할 수 있다”고 규정하고 있는바, 같은 조에서 “지급한다”와 “지급할 수 있다”를 구분하여 규정하고 있는 문언에 비추어 볼 때, 같은 조 제7항에 따른 장기성과급에 대해서는 소속 장관에게 지급 여부를 결정할 수 있는 재량권이 부여되어 있다고 보는 것이 그 문언상 상당하다고 할 것이므로, 소속 장관이 장기성과급을 반드시 지급해야 하는 것은 아니라고 할 것입니다.

그리고 공무원수당규정 제7조의2제7항에 따른 장기성과급 제도는공무원의 장기 성과에 대한 보상이 가능[198]하도록 하기 위해 2023년 9월 19일 대통령령 제33733호로 일부개정된 공무원수당규정에서 신설한 규정으로, 소속 장관이 이 사안 공무원에게 장기성과급을 반드시 지급하도록 하려는 의도였다면 입법기술적인 측면에서 ‘지급한다’ 또는 ‘지급하여야 한다’ 등과 같은 방식으로 그 의미를 보다 명확히 규정하였을 것임에도 불구하고 같은 항에서 장기성과급을 ‘지급할 수 있다’고 규정한 것은, 이 사안 공무원에게 소속 장관이 장기성과급을 지급할 수 있도록 하는 근거 규정을 마련하기 위한 취지였다고 할 것이고, 소속 장관으로 하여금 장기성과급을 반드시 지급하도록 하려는 입법의도까지 있었다고 보기 어렵습니다.

아울러 2016년 1월 8일 대통령령 제26878호로 일부개정된 공무원수당규정에서 신설된 특별성과가산금(제7조의2제6항)의 경우에도 소속 장관은 근무성적이나 업무실적 등이 우수한 상위 2퍼센트 이내의 공무원에게는 해당 공무원에게 지급되는 성과상여금 또는 성과연봉 지급액의 50퍼센트를 특별성과가산금으로 ‘지급할 수 있다’고 규정하여 소속 장관이 그 지급 여부를 결정하도록 하고 있는 점, 특별성과가산금이나 장기성과급은 공무원의 업무실적을 평가하여 그 평가 결과에 따라 최상위등급의 성과상여금 또는 성과연봉을 받은 공무원을 지급대상으로 하는바, 이미 최상위등급의 보상을 받은 공무원에게 추가적인 보상을 제공할 것인지 여부는 소속 장관이 조직의 운영이나 기관의 사정 등을 종합적으로 고려하여 결정할 수 있도록 하는 것이 합리적이라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 소속 장관은 이 사안 공무원에게 공무원수당규정 제7조의2제7항에 따라 장기성과급을 반드시 지급해야 하는 것은 아닙니다.

198) 2023. 9. 19. 대통령령 제33733호로 일부개정되어 같은 날 시행된 공무원수당규정 개정이유 및 주요내용 참조

관계법령

공무원수당 등에 관한 규정

제7조의2(성과상여금 등) ① 소속 장관은 별표 2의2에 따른 공무원 중 근무성적, 업무실적 등이 우수한 사람에게는 예산의 범위에서 성과상여금을 지급한다.

② ~ ⑥ (생 략)

⑦ 소속 장관은 해당 연도를 포함하여 3년 이상 연속으로 최상위등급의 성과상여금 또는 성과연봉을 받은 공무원(그 연속된 기간 중 계급·직급 또는 직무등급이 변동된 공무원을 포함한다)에게는 해당 공무원에게 지급되는 성과상여금 또는 성과연봉 지급액의 50퍼센트 이내의 금액을 장기성과급으로 지급할 수 있다.

⑧ 제6항에 따른 특별성과가산금과 제7항에 따른 장기성과급의 적용대상은 별표 3과 같다.

⑨ 성과상여금 등의 지급기준, 지급범위 및 지급방법 등에 필요한 사항은 인사혁신처장이 정하는 범위에서 소속 장관이 정한다.

⑩ ~ ⑬ (생 략)

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0495

민원인 – 「지방공무원법」 제40조에 따른 국가유공자의 우선 임용의 범위(「지방공무원법」 제40조 등 관련)

01 질의요지

「지방공무원법」 제40조에서는 지방자치단체의 공무원(지방자치단체가 경비를 부담하는 지방공무원을 말하며, 이하 "공무원"이라 함)을 임용할 때 법령에서 정하는 바에 따라 국가유공자를 우선 임용하여야 한다고 규정하고 있는데,

국가유공자[199]가 공무원의 공개경쟁신규임용시험[200]에 합격하여 신규임용후보자 명부에 등재된 경우 임용권자는 신규임용후보자를 공무원으로 임용할 때, 신규임용후보자 중에서 국가유공자를 「지방공무원법」 제40조에 따라 우선 임용해야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 신규임용후보자 중에서 국가유공자를 「지방공무원법」 제40조에 따라 우선 임용해야 하는 것은 아닙니다.

03 이유

먼저 「지방공무원법」 제40조에서는 공무원을 임용할 때 법령에서 정하는 바에 따라 국가유공자를 우선 임용하여야 한다고 규정하고 있는데, 같은 조에서 '법령에서 정하는 바에 따라'라는 부분은 관련 법률 및 명령(대통령령, 총리령, 부령)이 정하는 바에 따라 국가유공자를 우선임용한다는 의미와 아울러 이러한 우선임용의 내용과 방법 및 그 시행에 관하여 필요한

199) 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따라 국가유공자로 등록한 자를 말함
200) 「지방공무원법」 제32조제2항에 따라 실시하는 9급 이하 일반직공무원의 신규임용시험으로 한정함

사항을 관련 법률 및 명령으로 정하도록 위임한다는 의미[201]로 볼 수 있으므로, 이 사안의 경우 임용권자가 신규임용후보자를 공무원으로 임용할 때 신규임용후보자 중에서 국가유공자를 우선 임용하도록 하는 내용과 방법 등을 법률 및 명령에서 정하고 있는지 살펴볼 필요가 있습니다.

그런데 「지방공무원법」의 관련 규정을 살펴보면, 같은 법 제36조제1항에서는 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 각각 해당 인사위원회에서 실시한 신규임용시험에 합격한 사람을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신규임용후보자 명부에 등재(登載)하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「지방공무원 임용령」 제12조제1항에서는 신규임용후보자 명부는 직급별로 시험성적 순위에 따라 작성하되, 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 직류별, 근무희망기관별 및 근무희망지역별로 구분하여 작성할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 영 제13조제1항 본문에서는 임용권자 또는 임용후보자 추천권자는 신규임용후보자를 임용 또는 임용 추천하려는 경우에는 신규임용후보자 명부의 순위가 높은 사람부터 임용예정된 인원 또는 임용 추천 요구된 인원의 3배수 이내에서 임용 또는 임용 추천을 하여야 한다고 규정하고 있는바, 임용권자는 신규임용후보자를 공무원으로 임용할 때 시험성적 순위에 따라 신규임용후보자 명부를 작성하고, 신규임용후보자 명부의 순위에 기반하여 임용하도록 규정하고 있을 뿐, 신규임용후보자 중에서 국가유공자를 우선 임용하도록 하는 내용과 방법은 지방공무원법령 등에서 따로 정하고 있지는 않습니다.

그리고 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」(이하 "국가유공자법"이라 함)은 전상군경, 공상군경, 무공수훈자, 보국수훈자, 재일학도의용군인, 4·19혁명부상자, 4·19혁명공로자, 공상공무원, 특별공로상이자 및 특별공로자 등을 취업지원을 받을 수 있는 사람(이하 "취업지원 대상자"라 함)으로 하고(제29조), 같은 법 제30조에 따라 국가기관, 지방자치단체, 군부대, 국립학교와 공립학교 등의 취업지원 실시기관이 그 직원을 채용하기 위하여 채용시험을 실시하는 경우에는 그 채용시험에 응시한 취업지원 대상자의 점수에 만점의 10퍼센트 또는 5퍼센트를 가점(加點)하도록 하며(제31조), 같은 법 제31조제5항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제48조 및 별표 8에서 채용시험의 가점대상 계급 및 직급은 「국가공무원법」 제2조 및 「지방공무원법」 제2조에 따른 공무원의 일반직공무원 중 6급 이하 공무원 또는 연구사·지도사 등으로 규정하고 있는바, 「지방공무원법」 제40조에 따른 국가유공자에 대한 우선 임용은 국가유공자법령 등에서 정하는 채용시험에 있어서 가산점 부여 등의 방법을 통해 이루어지는 것이고, 나아가 공무원의 모든 임용 절차 및 방법에 있어서

201) 헌법재판소 2003. 7. 24. 선고 2002헌마378 전원재판부 결정례 참조

국가유공자를 우선하여 임용해야 한다고 보기는 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 신규임용후보자 중에서 국가유공자를 「지방공무원법」 제40조에 따라 우선 임용해야 하는 것은 아닙니다.



관계법령

지방공무원법

제36조(신규임용후보자 명부) ① 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 각각 해당 인사위원회에서 실시한 신규임용시험에 합격한 사람을 대통령령으로 정하는 바에 따라 신규임용후보자 명부에 등재(登載)하여야 한다.

② ~ ⑦ (생 략)

제40조(국가유공자의 우선 임용) 공무원을 임용할 때 법령에서 정하는 바에 따라 국가유공자를 우선 임용하여야 한다.

지방공무원 임용령

제12조(신규임용후보자 명부의 작성) ① 신규임용후보자 명부는 직급별로 시험성적 순위에 따라 작성하되, 특히 필요하다고 인정되는 경우에는 직류별, 근무희망기관별 및 근무희망지역별로 구분하여 작성할 수 있다.

② 신규임용후보자 명부의 작성에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

제13조(신규임용방법) ① 임용권자 또는 임용후보자 추천권자는 신규임용후보자를 임용 또는 임용 추천하려는 경우에는 신규임용후보자 명부의 순위가 높은 사람부터 임용예정된 인원 또는 임용 추천 요구된 인원의 3배수 이내에서 임용 또는 임용 추천을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 명부의 순위에 상관없이 임용 또는 임용 추천을 할 수 있다.

1. 임용예정 기관에 근무하고 있는 경우
2. 6개월 이상의 근무경력이 있거나, 임용예정 직위에 관련된 특별한 자격이 있는 경우
3. 임용예정 지역이 도서·벽지 등 특수지역인 경우
4. 임용후보자를 그가 부양할 의무가 있는 가족이 거주하고 있는 지역에 배치하는 경우
5. 규칙으로 정하는 학력, 경력 및 특수자격요건에 해당하는 임용후보자를 추천하도록 임용권자가 요구하는 경우
6. 제6조제3호에 따라 공무원의 직무수행과 관련된 실무수습 중 사망한 시보공무원이 될 사람을 소급하여 임용하는 경우

②·③ (생 략)

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0519

민원인 – 교원의 근무시간의 범위(「국가공무원 복무규정」 제9조 등 관련)

01 질의요지

「국가공무원 복무규정」 제9조제1항에서는 공무원의 1주간 근무시간은 점심시간을 제외하고 40시간으로 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 공무원의 1일 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하며, 점심시간은 낮 12시부터 오후 1시까지로 하되, 행정기관의 장은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 1시간의 범위에서 점심시간을 달리 정하여 운영할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 영 제10조제1항 전단에서는 중앙행정기관의 장은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성에 따라 필요하다고 인정할 때에는 해당 중앙행정기관 또는 그 소속 기관(이하 "소속 행정기관"이라 함)의 공무원에 대하여 같은 영 제9조제1항 및 제2항에 따른 통상의 근무시간 또는 근무일을 변경하여 근무하게 할 수 있다고 규정하고 있는바,

교육부장관이 「국가공무원 복무규정」 제10조제1항에 따라 소속 행정기관의 교원[202]에 대하여 통상의 근무시간을 오전 9시부터 오후 5시까지로 변경한 경우[203], 교원은 같은 영 제9조제2항에 따른 점심시간인 낮 12시부터 오후 1시까지 개인용무를 위하여 외출할 때 해당 시간을 근무시간으로 보아 학교의 장의 승인을 받아야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 교원은 낮 12시부터 오후 1시까지 개인용무를 위하여 외출할 때 해당 시간을 근무시간으로 보아 학교의 장의 승인을 받아야 합니다.

---

202) 「교육공무원법」 제2조제1항제1호에 따른 교육공무원(「국가공무원법」 제2조제2항제2호에 따른 특정직공무원)으로서 「유아교육법」 제2조제2호의 국·공립 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조의 국·공립 학교에 근무하는 교원으로 전제함

203) 「국가공무원 복무규정」 제10조제1항에 따라 통상의 근무시간만 변경하는 것으로 교육부장관과 인사혁신처장 간 협의가 된 경우로서, 협의의 내용에 점심시간에 관한 내용은 없는 경우로 전제함

03 이유

「국가공무원법」 제58조제1항에서는 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 규정된 「국가공무원 복무규정」 제24조의2에서는 「교육공무원법」 제2조제1항제1호에 따른 교원의 휴가에 관하여는 교육부장관이 학사 일정 등을 고려하여 따로 정할 수 있다고 규정하고 있으며, 「국가공무원 복무규정」 제24조의2의 위임에 따라 교원의 휴가에 관하여 규정하고 있는 「교원휴가에 관한 예규」(교육부예규 제83호) 제5조제4항에서는 지각·조퇴·외출을 신청할 때에는 교육정보시스템에 사유를 기재한 후 학교의 장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」(인사혁신처예규 제166호)에 따르면 '외출'은 근무시간 중 개인용무를 위하여 근무장소 외부로 나간 후 근무종료 시간 이전에 돌아오는 것으로 규정하고 있는바, 교원은 근무시간 중 개인용무를 위하여 외출할 때에는 학교의 장의 승인을 받아야 할 것인데, 이 사안의 경우 낮 12시부터 오후 1시까지도 근무시간에 해당하여 교원이 개인용무를 위하여 외출하는 경우에 학교의 장의 승인을 받아야 하는지 여부가 문제됩니다.

먼저 「국가공무원 복무규정」 제9조제1항에서는 공무원의 1주간 근무시간은 점심시간을 제외하고 40시간으로 하며, 토요일은 휴무함을 원칙으로 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 공무원의 1일 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하며, 점심시간은 낮 12시부터 오후 1시까지로 한다고 규정하고 있는바, 공무원의 1주간 근무시간은 점심시간을 제외하고 "40시간"으로 한다는 점이 문언상 분명하므로, 같은 영 제10조제1항에 따라 통상의 근무시간을 변경하는 경우에도 1주간 근무시간은 "40시간"이 되어야 할 것인데, 교육부장관이 소속 행정기관의 교원에 대하여 통상의 근무시간을 오전 9시부터 오후 5시까지로 변경한 경우에 낮 12시부터 오후 1시까지가 근무시간에서 제외된다고 본다면, 교원의 1주간 근무시간은 "40시간"이 아닌 "35시간"이 된다는 점에서 낮 12시부터 오후 1시까지도 근무시간으로 보아야 할 것입니다.

그리고 「국가공무원 복무규정」 제10조제1항 전단에서는 중앙행정기관의 장은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성에 따라 필요하다고 인정할 때에는 소속 행정기관의 공무원에 대하여 제9조제1항 및 제2항에 따른 통상의 근무시간 또는 근무일을 변경하여 근무하게 할 수 있다고 규정하고 있는바, 국·공립 유치원 또는 학교에서 근무하는 교원은 그 기관의 특성상 점심시간에도 급식 지도 및 학생 생활 지도 등[204]을 통해 학생을 보호하고 감독해야 할

204) 교육공무원 인사실무 238p.(교육부, 2016) 및 의정부지방법원 고양지원 2020. 7. 10. 선고 2018가단13373 판결례 참조

필요성이 있으므로, 이러한 교원의 직무의 특수성을 고려하여, 이 사안의 경우 교원의 통상의 근무시간에서 점심시간을 제외하지 않고 오전 9시부터 오후 5시까지(1일 8시간)를 근무시간으로 정한 것으로 보아, 이 경우에는 점심시간이 낮 12시부터 오후 1시까지라고 하더라도 해당 시간은 휴게시간이 아니라 근무시간으로 보는 것이 합리적인 해석이라고 할 것입니다.

그렇다면 「국가공무원 복무규정」 제10조제1항에 따라 교원에 대하여 통상의 근무시간을 오전 9시부터 오후 5시까지로 변경한 이 사안의 경우에는 낮 12시부터 오후 1시까지도 근무시간에 해당한다고 보아야 할 것이므로, 교원이 해당 시간에 개인용무를 위하여 외출하는 것은 근무시간 중 외출에 해당하여 「국가공무원 복무규정」 제24조의2 및 그 위임에 따라 규정된 「교원휴가에 관한 예규」 제5조제4항에 따라 학교의 장의 승인을 받아야 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 교원은 낮 12시부터 오후 1시까지 개인용무를 위하여 외출할 때 해당 시간을 근무시간으로 보아 학교의 장의 승인을 받아야 합니다.

관계법령

국가공무원 복무규정

제9조(근무시간 등) ① 공무원의 1주간 근무시간은 점심시간을 제외하고 40시간으로 하며, 토요일은 휴무함을 원칙으로 한다.

② 공무원의 1일 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하며, 점심시간은 낮 12시부터 오후 1시까지로 한다. 다만, 행정기관의 장은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 1시간의 범위에서 점심시간을 달리 정하여 운영할 수 있다.

③ 1주 40시간 근무에 관하여 필요한 사항은 인사혁신처장이 정한다.

④ (생 략)

제10조(근무시간 등의 변경) ① 중앙행정기관의 장은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성에 따라 필요하다고 인정할 때에는 해당 중앙행정기관 또는 그 소속 기관(이하 이 조에서 "소속 행정기관"이라 한다)의 공무원에 대하여 제9조제1항 및 제2항에 따른 통상의 근무시간 또는 근무일을 변경하여 근무하게 할 수 있다. 이 경우 중앙행정기관의 장은 변경하려는 내용과 이유를 미리 인사혁신처장에게 통보하여야 한다.

② ~ ④ (생 략)

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0543, 24-0662

민원인 – 경찰청장이 「국가공무원법」 제2조제3항에 따른 특수경력직공무원에 해당하는지 여부 (「국가공무원법」 제2조제3항 등 관련)

01 질의요지

「국가공무원법」 제2조제2항에서는 "경력직공무원"이란 실적과 자격에 따라 임용되고 그 신분이 보장되며 평생 동안(근무기간을 정하여 임용하는 공무원의 경우에는 그 기간 동안을 말함) 공무원으로 근무할 것이 예정되는 공무원을 말하며, 그 종류는 다음 각 호와 같다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 특정직공무원으로 경찰공무원 등을 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 "특수경력직공무원"이란 경력직공무원 외의 공무원을 말하며, 그 종류는 다음 각 호와 같다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 정무직공무원으로 선거로 취임하거나 임명할 때 국회의 동의가 필요한 공무원(가목), 고도의 정책결정 업무를 담당하거나 이러한 업무를 보조하는 공무원으로서 법률이나 대통령령(대통령비서실 및 국가안보실의 조직에 관한 대통령령만 해당함)에서 정무직으로 지정하는 공무원(나목)을 규정하고 있으며, 같은 항 제2호에서는 별정직공무원으로 비서관·비서 등 보좌업무 등을 수행하거나 특정한 업무 수행을 위하여 법령에서 별정직으로 지정하는 공무원을 규정하고 있는바,

경찰청장[205]은 「국가공무원법」 제2조제3항에 따른 특수경력직공무원인 정무직공무원(제1호) 또는 별정직공무원(제2호)에 해당하는지?

02 회답

경찰청장은 「국가공무원법」 제2조제3항에 따른 특수경력직공무원인 정무직공무원(제1호) 또는 별정직공무원(제2호)에 해당하지 않습니다.

205) 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제14조에 따른 경찰청장을 의미하며, 이하 같음

03 이유

「국가공무원법」 제2조제1항에서는 국가공무원(이하 “공무원”이라 함)은 경력직공무원과 특수경력직공무원으로 구분한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 “경력직공무원”이란 실적과 자격에 따라 임용되고 그 신분이 보장되며 평생 동안 공무원으로 근무할 것이 예정되는 공무원을 말한다고 하면서, 그 종류로 일반직공무원과 특정직공무원을 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 “특수경력직공무원”이란 “경력직공무원 외의 공무원”을 말한다고 하면서, 그 종류로 정무직공무원과 별정직공무원을 규정하고 있는바, 이 사안의 경우 경찰청장이 같은 조 제2항에 따른 “경력직공무원”에 해당하는지 여부를 우선 살펴볼 필요가 있습니다.

먼저 「국가공무원법」 제2조제2항제2호에서는 경력직공무원의 종류로 법관, 검사, 외무공무원, 경찰공무원, 소방공무원, 교육공무원, 군인, 군무원, 헌법재판소 헌법연구관, 국가정보원의 직원, 경호공무원 등을 특정직공무원으로 규정하고 있고, 경찰의 조직 및 직무범위 등을 정하고 있는 법률인 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」(이하 “경찰법”이라 함) 제14조제1항에서는 경찰청에 경찰청장을 두며, 경찰청장은 치안총감(治安總監)으로 보한다고 규정하고 있으며, 「경찰공무원법」 제3조에서는 경찰공무원의 계급을 치안총감(治安總監), 치안정감(治安正監), 치안감(治安監), 경무관(警務官), 총경(總警) 등으로 구분하고 있는바, 이러한 규정을 종합적으로 고려하면, 경찰청장은 경찰공무원 중 치안총감 계급인 자로서 경찰공무원에 해당한다고 할 것이므로 「국가공무원법」 제2조제2항제2호에 따른 경력직공무원 중 특정직공무원에 해당한다는 점이 문언상 분명합니다.

다음으로 경찰청장이 「국가공무원법」 제2조제3항에 따른 특수경력직공무원 중 정무직공무원에 해당하는지 살펴보면, 같은 항 제1호에서는 정무직공무원을 선거로 취임하거나 임명할 때 국회의 동의가 필요한 공무원(가목), 고도의 정책결정 업무를 담당하거나 이러한 업무를 보조하는 공무원으로서 법률이나 대통령령에서 정무직으로 지정하는 공무원(나목)으로 규정하고 있는데, 경찰법 제14조제2항에서는 경찰청장은 국가경찰위원회의 동의를 받아 행정안전부장관의 제청으로 국무총리를 거쳐 대통령이 임명하되, 이 경우 국회의 인사청문을 거쳐야 한다고 규정하고 있는바, 경찰청장은 선거에 의하여 임용되는 공무원이 아님이 분명하고, 임명 시 국회의 인사청문을 거쳐야 하나 국회의 동의가 필요한 것은 아니며, 다른 법률이나 대통령령에서 별도로 정무직으로 정하고 있는 공무원도 아니므로, 경찰청장이 「국가공무원법」 제2조제3항제1호에 따른 정무직공무원에 해당한다고 보기는 어렵습니다.

그리고 경찰청장이 「국가공무원법」 제2조제3항에 따른 특수경력직공무원 중 별정직

공무원에 해당하는지 살펴보면, 같은 항 제2호에서는 별정직공무원을 비서관·비서 등 보좌업무 등을 수행하거나 특정한 업무 수행을 위하여 법령에서 별정직으로 지정하는 공무원으로 규정하고 있는데, 경찰법 제14조제3항에 따르면 경찰청장은 국가경찰사무를 총괄하고 경찰청 업무를 관장하며 소속 공무원 및 각급 경찰기관의 장을 지휘·감독하는 업무를 수행하는 자로서, 비서관·비서 등 보좌업무를 수행한다고 볼 수 없고, 다른 법령에서 별도로 경찰청장을 별정직공무원으로 지정하고 있지도 않으므로, 경찰청장이 「국가공무원법」 제2조제3항제2호에 따른 별정직공무원에 해당한다고 보기도 어렵습니다.

한편 ① 경찰청장의 임기는 경찰법 제14조제4항에 따라 2년으로 중임할 수 없어 정년까지 근무가 보장되지 않으므로 「국가공무원법」 제2조제2항에 따른 "경력직공무원"의 요건인 평생 동안 공무원으로 근무할 것이 예정되는 공무원에 경찰청장이 해당하는 것으로 볼 수 없고, ② 경찰청장은 정무직공무원에 적용되는 연봉을 받으므로 정무직공무원에 해당한다는 의견이 있으나, ①「국가공무원법」 제2조제2항에서 "평생 동안"에 괄호를 두어 "근무기간을 정하여 임용하는 공무원의 경우에는 그 기간 동안을 말한다"고 규정하고 있으므로 "평생 동안"의 의미가 반드시 정년까지의 근무기간을 의미한다고 보기 어렵고, 경력직공무원의 경우에도 해당 직역의 업무적 특성을 반영하여 임기나 계급정년을 둘 수 있는데 이 경우 임기 또는 계급정년 기간 동안 근속이 보장된다는 점[206]을 고려하면, 경찰청장은 그 임기 동안 근무할 것이 예정되어 있는 공무원으로서 「국가공무원법」 제2조제2항에 따른 "경력직공무원"의 요건에 해당한다고 볼 수 있고, ② 정무직공무원에 적용되는 연봉을 받는 것은 경찰청장의 직책과 계급 등을 고려하여 처우하는 것이므로 이러한 이유만으로 경찰청장을 정무직공무원에 해당한다고 볼 수는 없는바[207], 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 경찰청장은 「국가공무원법」 제2조제3항에 따른 특수경력직공무원인 정무직공무원(제1호) 또는 별정직공무원(제2호)에 해당하지 않습니다.

206) 헌법재판소 2020. 4. 23. 선고 2017헌마321 결정례 참조
207) 법제처 2010. 12. 3. 회신 10-0388 해석례 참조

관계법령

국가공무원법

제2조(공무원의 구분) ① 국가공무원(이하 "공무원"이라 한다)은 경력직공무원과 특수경력직공무원으로 구분한다.

② "경력직공무원"이란 실적과 자격에 따라 임용되고 그 신분이 보장되며 평생 동안(근무기간을 정하여 임용하는 공무원의 경우에는 그 기간 동안을 말한다) 공무원으로 근무할 것이 예정되는 공무원을 말하며, 그 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 일반직공무원: 기술·연구 또는 행정 일반에 대한 업무를 담당하는 공무원
2. 특정직공무원: 법관, 검사, 외무공무원, 경찰공무원, 소방공무원, 교육공무원, 군인, 군무원, 헌법재판소 헌법연구관, 국가정보원의 직원, 경호공무원과 특수 분야의 업무를 담당하는 공무원으로서 다른 법률에서 특정직공무원으로 지정하는 공무원

③ "특수경력직공무원"이란 경력직공무원 외의 공무원을 말하며, 그 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 정무직공무원
   가. 선거로 취임하거나 임명할 때 국회의 동의가 필요한 공무원
   나. 고도의 정책결정 업무를 담당하거나 이러한 업무를 보조하는 공무원으로서 법률이나 대통령령(대통령비서실 및 국가안보실의 조직에 관한 대통령령만 해당한다)에서 정무직으로 지정하는 공무원
2. 별정직공무원: 비서관·비서 등 보좌업무 등을 수행하거나 특정한 업무 수행을 위하여 법령에서 별정직으로 지정하는 공무원

④ (생 략)

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0579, 24-0734, 24-0749, 24-0751, 24-0752, 24-0753, 24-0754, 24-0755

인사혁신처·행정안전부 – 청원경찰 또는 별정우체국 직원이 징계로 파면 또는 해임처분을 받은 경우가 공무원 결격사유에 해당하는지 여부(「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호 등 관련)

01 질의요지

공무원[208]으로 임용될 수 없는 결격사유로서 「국가공무원법」 제33조제7호 및 「지방공무원법」 제31조제7호에서는 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자를, 「국가공무원법」 제33조제8호 및 「지방공무원법」 제31조제8호에서는 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자를 규정하고 있는바,

가. 「청원경찰법」에 따른 청원경찰[209](이하 "청원경찰"이라 함)이 징계로 파면 또는 해임처분을 받은 경우, 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 또는 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에 따른 공무원 결격사유에 각각 해당되는지?

나. 「별정우체국법」에 따른 별정우체국[210]의 직원[211](이하 "별정우체국직원"이라 함)이 징계로 파면 또는 해임처분을 받은 경우, 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 또는 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에 따른 공무원 결격사유에 각각 해당되는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

청원경찰이 징계로 파면 또는 해임처분을 받은 경우, 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호

208) 「국가공무원법」의 적용을 받는 국가공무원 및 「지방공무원법」의 적용을 받는 지방공무원을 말하며, 이하 같음

209) 국가기관 또는 공공단체 등의 기관의 장 등의 경영자가 경비를 부담할 것을 조건으로 경찰의 배치를 신청하는 경우 그 기관 등의 경비를 담당하게 하기 위하여 배치하는 경찰을 말함(「청원경찰법」 제2조 참조)

210) 과학기술정보통신부장관의 지정을 받아 자기의 부담으로 청사와 그 밖의 시설을 갖추고 국가로부터 위임받은 체신(遞信) 업무를 수행하는 우체국을 말함(「별정우체국법」 제2조제1호 참조)

211) 별정우체국장과 「별정우체국법」 제8조에 따라 채용되어 근무하는 사람을 말함(「별정우체국법」 제2조제3호 참조)

또는 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에 따른 공무원 결격사유에 해당됩니다.

나. 질의 나에 대해

별정우체국직원이 징계로 파면 또는 해임처분을 받은 경우, 「국가공무원법」 제33조 제7호·제8호 또는 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에 따른 공무원 결격사유에 해당됩니다.

03 이유

가. 질의 가 및 나의 공통사항

「국가공무원법」 제10장 및 「지방공무원법」 제9장에서는 공무원의 징계에 관한 사항을 구체적으로 규정하면서 「국가공무원법」 제79조 및 「지방공무원법」 제70조에서 징계는 파면·해임·강등·정직·감봉·견책으로 구분한다고 규정하고 있고, 「국가공무원법」 제33조 제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에서는 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년, 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자를 공무원 임용 시의 결격사유로 규정하고 있는데, 국가공무원법령 및 지방공무원법령에서는 위 규정에 따른 '징계'의 구체적인 의미 및 범위에 관하여는 별도로 규정하고 있지 않아, 해당 징계가 「국가공무원법」 제10장 및 「지방공무원법」 제9장에서 규정되어 있는 공무원에 대한 징계로서 파면 또는 해임처분을 받은 경우로 한정되는지, 아니면 「청원경찰법」 등 다른 법률의 징계 규정에 따라 파면 또는 해임처분을 받은 경우까지 포함하는지 여부가 문제되는바, 이처럼 해당 법령 자체에 그 법령에서 사용하는 용어의 정의나 포섭의 구체적인 범위가 명확히 규정되어 있지 아니한 경우에는 그 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 해당 조항의 규정 형식과 내용 및 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 해석하여야 할 것입니다[212].

이와 관련하여 '징계'란 통상적으로 '부정이나 부당한 행위에 대하여 제재를 가하다'라는 의미[213]로서 일반적으로 공무원을 그 대상으로 하는 제재행위만을 의미하는 것은 아니라는 점, 「국가공무원법」 제50조의2제3항[214]에서는 공무원이 적극행정을 추진한 결과에 대하여 해당 공무원의 행위에 고의 또는 중대한 과실이 없다고 인정되는 경우 '이 법' 또는 '다른 공무원

212) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2004도7807 판결례 참조

213) 국립국어원 표준국어대사전 참조

214) 지방공무원의 경우는 「지방공무원법」 제75조의2제3항 참조

인사 관계 법령'에 따른 징계 또는 징계부가금 부과 의결을 하지 아니한다고 규정하고 있고, 「국가공무원법」 제33조제6호의2 및 「지방공무원법」 제31조제6호의2에서는 '공무원'으로 재직기간 중 직무와 관련하여 「형법」 제355조 및 제356조에 규정된 죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자를 공무원 임용 결격사유로 규정하고 있는 등 공무원법령에서는 어떠한 규정 등에 대하여 공무원에게 그 내용을 제한적으로 적용하려는 경우에는 '이 법' 또는 '공무원' 등의 표현을 사용하여 그 적용 범위 또는 대상을 명확하게 규정하고 있는 반면, 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에서는 이러한 별도의 부가적인 수식 없이 '징계'로만 규정하고 있고, 1949년 8월 12일 법률 제44호로 「국가공무원법」 및 1963년 11월 1일 법률 제1427호로 「지방공무원법」을 제정하여 공무원 결격사유 제도를 도입한 이래 해당 규정에서의 '징계'의 근거 규정이나 법령을 별도로 특정하지 않았다는 점에 비추어 볼 때, 같은 규정에 따른 '징계'의 의미가 「국가공무원법」 제10장 및 「지방공무원법」 제9장에서 규정하고 있는 공무원에 대한 징계, 즉 '이 법'에 따른 징계로 한정된다고 보기는 어렵습니다.

그리고 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」은 각각 각급 기관에서 근무하는 국가공무원 및 지방자치단체의 공무원에게 적용할 인사행정의 근본 기준을 확립하여 행정의 민주적이며 능률적인 운영을 기하게 하는 것을 목적으로 하는 법률로서, 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에서 파면 또는 해임의 징계처분을 받은 자를 곧바로 공무원으로 임용할 수 없도록 한 것은 일정 기간 동안은 해당 징계처분을 받은 사람을 공무원에 임용하지 못하도록 함으로써 직무수행에 대한 국민의 신뢰와 공직사회의 질서를 효과적으로 유지하고자 하는 취지[215]라는 점, 징계처분에 따른 파면 또는 해임처분은 그 징계대상자의 의사와 관계없이 직권으로 그 신분을 박탈하는 것이므로 징계의 종류 중에서도 가장 중한 처분으로서[216], 통상 그 징계 대상이 되는 의무위반에 대한 비위의 정도가 심각한바, 이러한 징계처분을 받은 자가 공무원에게 요구되는 준법의식 또는 도덕성 등을 충분히 갖추었다고 보기 어려운 점 등에 비추어보면, 다른 법률에서 정하고 있는 절차에 따른 징계라 하더라도 그 결과가 특정 공적 업무를 수행하는 자의 신분을 박탈하는 파면 또는 해임처분에 이르렀다면, 특별한 사정이 없는 한 해당 징계대상자를 일정 기간 동안 공무원 임용 대상에서도 제외하도록 하는 것이 해당 규정의 취지에 부합한다고 볼 수 있으므로, 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호의 '징계'의 의미가 「국가공무원법」 제10장 및 「지방공무원법」 제9장에서 규정하고 있는 징계로서 파면 또는 해임

215) 대법원 1996. 5. 14. 선고 95누7307 판결례 참조
216) 법제처 2013. 4. 15. 회신 13-0074 해석례 참조

처분을 받은 경우로 한정되지는 않는다고 할 것입니다.

나. 질의 가에 대해

그렇다면 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호의 적용 대상에는 다른 법률에 근거한 징계로 파면 또는 해임처분을 받은 자가 포함될 수 있다고 할 것인데, 청원경찰이 같은 규정의 적용 대상에 포함되려면 청원경찰에 대한 징계가 다른 법률에 근거한 징계에 해당하는지와 청원경찰이 수행하는 업무가 공공성이 있는지 여부 등을 추가적으로 검토할 필요가 있습니다.

이와 관련하여 「청원경찰법」 제5조의2제1항에서는 청원주[217]는 청원경찰이 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때(제1호), 품위를 손상하는 행위를 한 때(제2호)에는 대통령령으로 정하는 징계절차를 거쳐 징계처분을 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 청원경찰에 대한 징계의 종류를 파면, 해임, 정직, 감봉 및 견책으로 구분한다고 규정하고 있는바, 청원경찰을 대상으로 하는 파면 또는 해임의 징계는 「청원경찰법」 제5조의2 및 같은 법 시행령 제8조를 근거로 하여 청원경찰의 신분관계에 불이익을 주는 징계처분으로 볼 수 있습니다.

그리고 「청원경찰법」에 따른 청원경찰은 청원주와의 고용계약에 의한 근로자로서 공무원 신분은 아니라 할 것이나, 청원경찰은 배치된 경비구역만의 경비를 목적으로 필요한 범위에서 「경찰관 직무집행법」에 따른 경찰관의 직무를 수행한다고 규정하고(제3조) 있는 등 청원경찰은 일정한 장소적 한계 내에서는 국가기관 등의 경비 및 공안업무에 대하여 경찰공무원과 동일한 직무수행 권한을 법률상 부여받고 있고, 국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰의 보수는 같은 재직기간에 해당하는 경찰공무원의 보수를 감안하여 정하도록 규정(제6조제2항)하고 있으며, 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나의 결격사유에 해당하는 사람은 청원경찰로 임용될 수 없도록 하고 있고(제5조제2항), 「청원경찰법」 제5조제4항에서는 청원경찰의 복무에 관하여 「국가공무원법」상 복종의 의무(제57조) 등을 준용하도록 하고 있으며, 청원경찰은 형의 선고, 징계처분 또는 신체상·정신상의 이상으로 직무를 감당하지 못할 때를 제외하고는 그 의사에 반하여 면직될 수 없다고 규정(제10조의4 제1항)하고 있는 등 일반 근로자와 달리 청원경찰의 임용·복무·보수 등에 대하여는 공무원과 유사하게 처우하여 신분보장이나 사회보장 측면에서 일반 사기업체의 직원보다 두텁게 보호하면서 그에 부합하는 특별한 책임도 부여하고 습니다[218].

217) 「청원경찰법」 제4조제2항에 따라 청원경찰의 배치 결정을 받은 자를 말하며(「청원경찰법」 제3조 참조), 이하 같음

이처럼 청원경찰은 경찰관에 준하는 공적인 업무를 수행하는 특성상 고도의 준법의식 또는 청렴성 등의 자질이 요구되는데[219], 청원경찰로서의 자질에 심각한 흠결이 생겨 징계처분을 받아 청원경찰직에서 파면·해임된 자의 경우 일정 기간 공무원 임용 대상에서도 배제하여 국민 전체의 신뢰와 공직자의 성실하고 공정한 직무수행을 담보할 필요성이 있다는 점을 고려하면, 청원경찰이 「청원경찰법」 제5조의2 및 같은 법 시행령 제8조에 따라 징계로서 파면·해임처분을 받은 경우도 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에서 각각 정하고 있는 공무원 임용 결격사유에 해당된다고 보는 것이 타당합니다.

따라서 청원경찰이 징계로 파면 또는 해임처분을 받은 경우, 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 또는 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에 따른 공무원 결격사유에 해당됩니다.

다. 질의 나에 대해

먼저 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에서의 '징계'의 범위와 관련하여 앞서 살펴본 바[220]와 같이 다른 특별한 사정이 없는 한 「국가공무원법」 제10장 및 「지방공무원법」 제9장에 규정되어 있는 징계로서 파면·해임 처분을 받은 경우뿐만 아니라, 다른 법률에 근거한 징계로 파면 또는 해임처분을 받은 자가 포함될 수 있다고 할 것인데, 별정우체국직원이 같은 규정의 적용 대상에 포함되려면 별정우체국직원에 대한 징계가 다른 법률에 근거한 징계에 해당하는지와 별정우체국직원이 수행하는 업무가 공공성이 있는지 여부 등을 추가로 살펴볼 필요가 있습니다.

그런데 「별정우체국법」 제10조에서는 직원의 임용, 복무, 보수 및 징계 등에 관하여 필요한 사항은 과학기술정보통신부령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「별정우체국직원 인사규칙」 제36조제1항에서는 별정우체국직원이 직무 관련 여부와 상관없이 공무수탁자로서의 본분을 위반하거나 품위를 손상하는 행위(제3호)를 하는 등의 경우에는 관할 지방우정청장 또는 총괄우체국장이 지방우정청에 설치된 별정우체국징계 위원회에 징계의결을 요구하도록 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 관할 지방우정청장은 같은 조 제1항에 따른 징계위원회의 의결 결과에 따라 별정우체국직원에 대하여 징계처분을 하여야

218) 헌법재판소 2011. 10. 25. 선고 2011헌마85 전원재판부 결정례 참조

219) 청원경찰에게는 「국가공무원법」의 복종의 의무(제57조), 직장이탈금지 의무(제58조), 비밀엄수 의무(제60조) 및 「경찰공무원법」의 거짓보고금지 의무(제24조) 등이 준용됨(「청원경찰법」 제5조제4항)

220) 질의 가 및 나의 공통사항 참조

한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제37조에서는 징계를 중징계와 경징계로 구분하면서, 중징계는 파면·해임·강등 및 정직으로, 경징계는 감봉 및 견책으로 한다고 규정하고 있는 점을 종합해 보면, 별정우체국직원을 대상으로 하는 파면 또는 해임의 징계는 「별정우체국법」 제10조 및 그 위임에 따라 마련된 「별정우체국직원 인사규칙」 제36조 등을 법적 근거로 하여 관할 지방우정청장이 행하게 되는 징계처분으로 볼 수 있습니다.

특히 「별정우체국법」 제10조에서는 별정우체국직원의 임용, 복무, 보수 및 징계 등에 관하여 필요한 사항은 과학기술정보통신부령으로 정한다고 규정하여 징계처분에 대한 법률적 근거를 두면서, 그 징계사유 및 절차에 관한 세부사항을 과학기술정보통신부령으로 위임하고 있는데, 이는 별정우체국직원의 징계에 관한 대부분의 사항이 세부적이고 기술적이라는 것과 그 임용 등에 사인이 관여하는 만큼 징계사유 및 절차의 집행에 있어 자율성을 고려할 필요가 있다는 점에서 법률보다 탄력적으로 대응할 수 있는 행정입법에 징계에 관한 사항을 위임한 것으로 볼 수 있는바[221], 별정우체국직원의 징계에 관한 구체적인 내용 등이 하위법령에 위임되어 있는 경우라 하더라도 그 규정방식만으로 해당 징계가 「국가공무원법」 제33조 제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에 따른 '징계'에 포함되지 않는다고 보기는 어려우므로, 「별정우체국법」 제10조 및 그 위임에 따라 마련된 「별정우체국직원 인사규칙」 제36조 등에 따라 행해지는 징계도 다른 법률에 근거한 징계에 포함된다고 할 것입니다.

그리고 「별정우체국법」에서는 별정우체국직원 중 '국장'은 피지정인 또는 피지정인의 추천을 받은 사람 중에 과학기술정보통신부장관이 임용(제4조)하도록 하고, '국장을 제외한 직원'은 국장이 채용할 수 있도록 규정(제8조)하고 있어 사인(私人)이 그 임용 또는 채용절차에 관여하고 있는 등[222] '별정우체국직원'은 공무원 신분은 아니라 할 것이나, 별정우체국은 지정받은 지역 내에서 국가로부터 위임받은 체신 업무 및 관공서인 우체국의 사무와 동일한 사무를 관장(제2조제1항제1호 및 제6조)하고 있고, 그러한 업무의 공공성에 비추어 별정우체국직원은 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나의 결격사유에 해당하는 사람을 임용할 수 없도록 그 자격요건을 엄격히 규정하고 있으며(제5조 및 제8조제2항), 정년 등 신분보장에 관한 사항을 규정(제8조의2)하면서 직무상 책임에 대하여 공무원으로 의제(제9조)되는 점, 「별정우체국법」 제10조에 따라 별정우체국직원의 복무, 보수 및 징계 등에 관한 사항을 정하는 「별정우체국직원 인사규칙」 제36조제4항에서는 별정우체국직원의 징계 양정에 관한 기준은 우정사업본부 소속 공무원의 예에 따르도록 규정되어 있는 등 별정우체국직원의 업무의

221) 헌법재판소 2023. 7. 20. 선고 2020헌바330 전원재판부 결정례 참조

222) 헌법재판소 2023. 7. 20. 선고 2020헌바330 전원재판부 결정례 참조

내용과 그 업무가 갖는 공적인 성격에 비추어 볼 때, 별정우체국직원은 「국가공무원법」의 적용을 받는 우정사업본부 소속 공무원과 그 업무 내용 등이 유사[223]하다 볼 수 있어 별정우체국직원의 업무를 수행함에 있어 고도의 준법의식 또는 청렴성, 염결성 등의 자질이 요구되는 측면이 있고[224], 그 자질에 심각한 흠결이 생겨 징계처분을 받아 별정우체국직원에서 파면·해임된 자를 일정 기간 공무원 임용 대상에서 배제하여 국민 전체의 신뢰와 공직자의 성실하고 공정한 직무수행을 담보할 필요성이 있으므로[225], 별정우체국직원이 「별정우체국법」 제10조 및 같은 법의 위임에 따라 마련된 「별정우체국직원 인사규칙」 제36조에 따른 징계로서 파면·해임처분을 받은 경우도 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호의 공무원 결격사유에 각각 해당된다고 보는 것이 타당할 것입니다.

따라서 별정우체국직원이 징계로 파면 또는 해임처분을 받은 경우, 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 또는 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호에 따른 공무원 결격사유에 해당됩니다.

관계법령

국가공무원법

제33조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 공무원으로 임용될 수 없다.

1. ~ 6의4. (생 략)
7. 징계로 파면처분을 받은 때부터 5년이 지나지 아니한 자
8. 징계로 해임처분을 받은 때부터 3년이 지나지 아니한 자

지방공무원법

제31조(결격사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 공무원이 될 수 없다.

1. ~ 6의4. (생 략)
7. 징계로 파면처분을 받은 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
8. 징계로 해임처분을 받은 날부터 3년이 지나지 아니한 사람

223) 헌법재판소 2023. 7. 20. 선고 2020헌바330 전원재판부 결정례 참조
224) 부산지방법원 2021. 5. 14. 선고 2021구합20468 판결례 참조
225) 헌법재판소 2011. 10. 25. 선고 2011헌마85 전원재판부 결정례 참조

청원경찰법

제5조의2(청원경찰의 징계) ① 청원주는 청원경찰이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 대통령령으로 정하는 징계절차를 거쳐 징계처분을 하여야 한다.
1. 직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때
2. 품위를 손상하는 행위를 한 때

② 청원경찰에 대한 징계의 종류는 파면, 해임, 정직, 감봉 및 견책으로 구분한다.
③ 청원경찰의 징계에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

별정우체국법

제10조(인사관리) 직원의 임용, 복무, 보수 및 징계 등에 관하여 필요한 사항은 과학기술정보통신부령으로 정한다.

별정우체국 인사규칙

제36조(징계) ① 국장 또는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 관할 지방우정청장 또는 총괄우체국장이 지방우정청에 설치된 별정우체국징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.
1. 법 또는 법에 따른 명령을 위반하였을 때
2. 직무상 의무를 위반하거나 직무를 게을리하였을 때
3. 직무 관련 여부와 상관없이 공무수탁자로서의 본분을 위반하거나 품위를 손상하는 행위를 하였을 때

② 관할 지방우정청장은 제1항에 따른 징계위원회의 의결 결과에 따라 국장 또는 직원에 대하여 징계처분을 하여야 한다.
③ 별정우체국징계위원회의 설치·구성·운영, 징계의 의결 요구·절차 및 그 집행과 그 밖에 징계에 관하여 필요한 사항은 「공무원 징계령」 중 보통징계위원회에 관한 규정을 준용한다.
④ 징계의 양정에 관한 기준은 우정사업본부 소속 공무원의 예에 따른다.

제37조(징계의 종류) 징계는 중징계와 경징계로 구분한다. 이 경우 중징계는 파면·해임·강등 및 정직으로 하며, 경징계는 감봉 및 견책으로 한다.

질의제목 10 ▶ 안건번호 24-0745

민원인 – 「공무원임용령」 제31조제2항제2호가목1)에 따른 해당 공무원에 대한 징계의결 요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우의 의미[「공무원임용령」 제31조제2항제2호가목1) 등 관련]

01 질의요지

「국가공무원법」 제73조의3제1항제3호에서는 임용권자가 직위를 부여하지 아니할 수 있는 자 중 하나로 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 자를 규정하고 있고, 「공무원임용령」 제31조제1항에서는 공무원이 승진하려면 같은 항 각 호의 구분에 따른 기간(이하 "승진소요최저연수"라 함) 동안 해당 계급에 재직해야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항 본문에서는 승진소요최저연수에 직위해제 기간을 포함하지 않도록 하되, 같은 항 단서 및 제2호가목1)에서는 같은 법 제73조의3제1항제3호에 따라 직위해제처분을 받은 사람이 "해당 공무원에 대한 징계의결 요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우"에 해당하는 경우 그 직위해제처분기간을 승진소요최저연수에 포함하도록 규정하고 있는바,

파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계(이하 "중징계"라 함) 의결이 요구되어 「국가공무원법」 제73조의3제1항제3호에 따라 직위해제처분을 받은 공무원에 대하여 관할 징계위원회가 감봉 또는 견책에 해당하는 징계(이하 "경징계"라 함) 의결을 한 경우가 「공무원임용령」 제31조제2항제2호가목1)의 "해당 공무원에 대한 징계의결 요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우"에 해당되는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「공무원임용령」 제31조제2항제2호가목1)의 "해당 공무원에 대한 징계의결 요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우"에 해당되지 않습니다.

03 이유

먼저 「공무원임용령」 제31조제2항제2호가목1)에서는 「국가공무원법」 제73조의3제1항제3호에 따른 직위해제처분기간 중 승진소요최저연수에 포함되는 기간으로 해당 공무원에 대한 징계의결 요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우 그 직위해제처분기간을 규정하고 있는데, 경징계의 의결을 하는 것은 파면·해임·강등·정직·감봉·견책으로 구분되는 징계의 종류[226] 중 감봉 또는 견책에 해당하는 가벼운 수준의 징계를 하기로 의결하는 것이지 징계하지 않기로 의결하는 경우에 해당하지 않는다는 것이 문언상 분명한바, 이 사안과 같이 직위해제처분의 사유가 된 중징계의결 요구에 대해 경징계의결을 한 경우는 같은 영 제31조제2항제2호가목1)에 해당된다고 보기 어렵습니다.

또한 일반적으로 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 엄격하게 해석할 필요가 있는데[227], 「공무원임용령」 제31조제2항 본문에서 직위해제 기간은 원칙적으로 승진소요최저연수에 포함되지 않는 것으로 규정하면서, 같은 항 단서에서 같은 항 각 호에 따른 기간을 예외적으로 승진소요최저연수에 포함시키고 있는 것인바, 예외 규정에 해당하는 같은 영 제31조제2항제2호가목1)은 엄격하게 해석하여야 한다는 점을 고려하면, 같은 규정은 문언에 따라 관할 징계위원회에서 징계하지 아니하기로 의결한 경우를 의미하는 것이지, 관할 징계위원회가 경징계 의결을 한 경우까지 의미하는 것으로 보기는 어렵습니다.

그리고 「공무원임용령」 제31조제1항에서 공무원을 승진임용할 때 승진소요최저연수를 둔 것은 상위 계급의 직무 난이도와 책임 증대를 감당할 능력을 갖추기 위해 최소한의 재직기간이 필요하므로 임용된 후 일정기간 동안 일정한 계급에서 근무한 경력이 인정된 자만을 승진임용 대상으로 삼으려는 데에 그 입법취지가 있다 할 것인데[228], 「국가공무원법」 제73조의3제1항에 따른 직위해제는 해당 공무원이 장래에 계속 직무를 담당하게 될 경우 예상되는 업무상의 장애 등을 예방하기 위하여 일시적으로 해당 공무원에게 직위를 부여하지 아니함으로써 직무에 종사하지 못하도록 하는 것으로서[229], 직위해제처분을 받은 공무원은 직위해제 기간 동안 통상적인 근무를 한다고 보기 어려우므로, 예외적으로 직위해제 기간을 승진소요최저연수에 산입하는 것은 명문에 근거가 있는 경우로 한정해야 할 것이며, 이를

226) 「국가공무원법」 제79조 참조

227) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

228) 법제처 2021. 2. 24. 회신 20-0644 해석례 및 법제처 2015. 3. 31. 회신 15-0095 해석례 참조

229) 대법원 2022. 10. 14. 선고 2022두45623 판결례 참조

확장해석하는 것은 같은 영 제31조제1항의 입법취지에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

한편 「국가공무원법」 제73조의3제1항제3호에 따른 직위해제처분은 중징계의결이 요구 중인 자를 대상으로 하는 것이므로, 관할 징계위원회의 심의 결과 경징계로 의결되었음에도 불구하고 해당 직위해제 기간이 승진소요최저연수에 포함되지 않는 것은 해당 공무원에게는 과도한 불이익이라는 의견이 있으나, 「국가공무원법」 제73조의3제1항에서는 임용권자는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 직위를 부여하지 아니할 수 있다고 규정하여 임용권자가 재량으로 직위해제처분 여부를 판단할 수 있도록 하고 있어, 중징계의결 요구가 있었다는 사실만으로 같은 항 제3호에 따른 직위해제처분이 이루어지는 것이 아니라, 직위해제처분 대상자의 직위·보직·업무의 성격상 그가 계속 직무를 수행함으로 인하여 공정한 공무집행에 구체적인 위험을 초래하는지 여부 등 제반 사정을 고려하여 그 요건이 충족되는 경우에 비로소 직위해제처분을 하게 되는 것인바[230], 이러한 요건을 충족하지 못한 경우에 직위해제처분 자체의 위법·부당성을 다툴 수 있는 점은 별론으로 하더라도, 징계의결 요구에 대해 관할 징계위원회가 경징계로 의결한 경우를 「공무원임용령」 제31조제2항제2호1)에 따른 "관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우"로 볼 수 없다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「공무원임용령」 제31조제2항제2호가목1)의 "해당 공무원에 대한 징계의결 요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우"에 해당되지 않습니다.

관계법령

국가공무원법

제73조의3(직위해제) ① 임용권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 삭제
2. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자
3. 파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 자
4. 형사 사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
5. 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 제70조의2제1항제2호부터 제5호까지의 사유로 적격심사를 요구받은 자

230) 대법원 2022. 10. 14. 선고 2022두45623 판결례 참조

6. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자

② 제1항에 따라 직위를 부여하지 아니한 경우에 그 사유가 소멸되면 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

제79조(징계의 종류) 징계는 파면·해임·강등·정직·감봉·견책(譴責)으로 구분한다.

공무원임용령

제31조(승진소요최저연수) ① 공무원이 승진하려면 다음 각 호의 구분에 따른 기간 동안 해당 계급에 재직해야 한다.

1. 일반직공무원(우정직공무원은 제외한다)
   가. 4급 및 5급: 3년 이상
   나. 6급: 2년 이상
   다. 7급, 8급 및 9급: 1년 이상
2. (생 략)

② 제1항의 기간에는 휴직기간, 직위해제 기간, 징계처분 기간 및 제32조에 따른 승진임용의 제한기간을 포함하지 않는다. 다만, 다음 각 호에 따른 기간은 제1항의 기간에 포함한다.

1. (생 략)
2. 법 제73조의3제1항에 따른 직위해제처분기간 중 다음 각 목의 기간
   가. 법 제73조의3제1항제3호에 따라 직위해제처분을 받은 사람이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 그 직위해제처분기간
      1) 해당 공무원에 대한 징계의결 요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우
      2) 직위해제처분 또는 직위해제처분의 사유가 된 징계의결 요구에 의한 징계처분이 소청심사위원회의 결정이나 법원의 판결에 의하여 무효 또는 취소로 확정된 경우
   나. ~ 라. (생 략)

2의2.·3. (생 략)

③ ~ ⑮ (생 략)

질의제목 11 ▶ 안건번호 24-0769, 24-0919

민원인 – 수사처검사 및 수사처수사관이 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원에 해당하는지 여부(「국가공무원법」 제26조의5 등 관련)

01 질의요지

「국가공무원법」 제26조의5제1항에서는 임용권자는 전문지식·기술이 요구되거나 임용관리에 특수성이 요구되는 업무를 담당하게 하기 위하여 경력직공무원을 임용할 때에 일정기간을 정하여 근무하는 공무원(이하 “임기제공무원”이라 함)을 임용할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 임기제공무원의 임용요건, 임용절차, 근무상한연령 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다고 규정하고 있는 한편,

「고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률」(이하 “공수처법”이라 함) 제4조제2항에서는 고위공직자범죄수사처(이하 “수사처”라 함)에 수사처검사와 수사처수사관 및 그 밖에 필요한 직원을 둔다고 규정하고 있고, 같은 법 제8조제3항에서 수사처검사의 임기는 3년으로 하고, 3회에 한정하여 연임할 수 있으며, 정년은 63세로 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제10조제3항에서 수사처수사관의 임기는 6년으로 하고, 연임할 수 있으며, 정년은 60세로 한다고 규정하고 있는바,

수사처검사 및 수사처수사관이 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원에 해당하는지?

02 회답

수사처검사 및 수사처수사관은 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 「국가공무원법」 제26조의5제1항에서는 임용권자는 전문지식·기술이 요구되거나 임용관리에 특수성이 요구되는 업무를 담당하게 하기 위하여 경력직공무원을 임용할 때에 임기제공무원을 임용할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 임기제공무원의 임용요건, 임용절차, 근무상한연령 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 「공무원임용령」 제22조의4제1항 전단에서는 임용권자 또는 임용제청권자는 정원(일반임기제공무원[231]을 임용하는 경우만 해당함) 및 예산의 범위에서 임기제공무원을 임용할 수 있다고 규정하여, 임용권자가 경력직공무원을 임기제공무원으로 임용할 것인지 여부는 기관의 정원, 예산, 소관 업무의 특성 등을 고려하여 결정할 수 있도록 한 반면, 공수처법에서는 수사처에 수사처검사와 수사처수사관을 두도록 하면서(제4조제2항), 수사처검사는 특정직공무원으로 보하고, 그 임기를 3년으로 하며, 3회에 한정하여 연임할 수 있고, 정년은 63세로 한다고 규정(제8조)하고 있으며, 수사처 수사관은 일반직공무원으로 보하고, 그 임기를 6년으로 하며, 연임할 수 있고, 정년은 60세로 한다고 규정(제10조)하여 법률로써 그 직과 임기 등을 정하고 있을 뿐, 수사처검사와 수사처 수사관을 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원으로 임명한다는 내용을 별도로 규정하고 있지 않은바, 법령의 문언과 체계상 수사처검사와 수사처수사관은 공수처법 제8조 및 제10조에 따라 임명된 공무원임이 분명하고, 「국가공무원법」 제26조의5에 따라 임용된 임기제공무원에 해당하지 않는다고 할 것입니다.

그리고 공수처법 제11조에 따르면 수사처에는 수사처검사와 수사처수사관 외에도 수사처의 행정에 관한 사무처리를 위하여 필요한 직원을 둘 수 있는데, 같은 법 제45조의 위임에 따라 수사처의 조직 및 운영에 필요한 사항을 규정하기 위해 마련된 「고위공직자 범죄수사처 직제」(고위공직자범죄수사처규칙) 제12조제3항에서는 같은 법 제11조제2항에 따라 수사처에 두는 직원의 직급별 정원은 별표 3과 같고, 이 경우 정원 중 1명(서기관 1명)은 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원으로 임용할 수 있다고 규정하여, 수사처검사 및 수사처수사관과 달리 해당 직원에 대해서만 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원에 해당한다는 점을 명시하고 있는바, 수사처검사 및 수사처수사관은 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원과는 구분된다고 할 것입니다.

따라서 수사처검사 및 수사처수사관은 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원에 해당하지 않습니다.

231) 직제 등 법령에 규정된 경력직공무원의 정원에 해당하는 직위에 임용되는 임기제공무원을 말함(「공무원임용령」 제3조의2 참조)

관계법령

국가공무원법

제2조(공무원의 구분) ① 국가공무원(이하 "공무원"이라 한다)은 경력직공무원과 특수경력직공무원으로 구분한다.

② "경력직공무원"이란 실적과 자격에 따라 임용되고 그 신분이 보장되며 평생 동안(근무기간을 정하여 임용하는 공무원의 경우에는 그 기간 동안을 말한다) 공무원으로 근무할 것이 예정되는 공무원을 말하며, 그 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 일반직공무원: 기술·연구 또는 행정 일반에 대한 업무를 담당하는 공무원
2. 특정직공무원: 법관, 검사, 외무공무원, 경찰공무원, 소방공무원, 교육공무원, 군인, 군무원, 헌법재판소 헌법연구관, 국가정보원의 직원, 경호공무원과 특수 분야의 업무를 담당하는 공무원으로서 다른 법률에서 특정직공무원으로 지정하는 공무원
3. 삭제

③·④ (생 략)

제26조의5(근무기간을 정하여 임용하는 공무원) ① 임용권자는 전문지식·기술이 요구되거나 임용관리에 특수성이 요구되는 업무를 담당하게 하기 위하여 경력직공무원을 임용할 때에 일정기간을 정하여 근무하는 공무원(이하 "임기제공무원"이라 한다)을 임용할 수 있다.

② 임기제공무원의 임용요건, 임용절차, 근무상한연령 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다.

고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률

제8조(수사처검사) ① 수사처검사는 7년 이상 변호사의 자격이 있는 사람 중에서 제9조에 따른 인사위원회의 추천을 거쳐 대통령이 임명한다. 이 경우 검사의 직에 있었던 사람은 제2항에 따른 수사처검사 정원의 2분의 1을 넘을 수 없다.

② 수사처검사는 특정직공무원으로 보하고, 처장과 차장을 포함하여 25명 이내로 한다.

③ 수사처검사의 임기는 3년으로 하고, 3회에 한정하여 연임할 수 있으며, 정년은 63세로 한다.

④ (생 략)

제10조(수사처수사관) ① 수사처수사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 처장이 임명한다.

1. 변호사 자격을 보유한 사람
2. 7급 이상 공무원으로서 조사, 수사업무에 종사하였던 사람
3. 수사처규칙으로 정하는 조사업무의 실무를 5년 이상 수행한 경력이 있는 사람

② 수사처수사관은 일반직공무원으로 보하고, 40명 이내로 한다. 다만, 검찰청으로부터 검찰수사관을 파견받은 경우에는 이를 수사처수사관의 정원에 포함한다.

③ 수사처수사관의 임기는 6년으로 하고, 연임할 수 있으며, 정년은 60세로 한다.

질의제목 12 ▶ 안건번호 24-0771

민원인 – 경찰청장이 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제 공무원에 해당하는지 여부 (「국가공무원법」 제26조의5 등 관련)

01 질의요지

「국가공무원법」 제26조의5제1항에서는 임용권자는 전문지식·기술이 요구되거나 임용관리에 특수성이 요구되는 업무를 담당하게 하기 위하여 경력직공무원을 임용할 때에 일정기간을 정하여 근무하는 공무원(이하 “임기제공무원”이라 함)을 임용할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 임기제공무원의 임용요건, 임용절차, 근무상한연령 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다고 규정하고 있는 한편,

「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」(이하 “경찰법”이라 함) 제14조제1항에서는 경찰청에 경찰청장을 두며, 경찰청장은 치안총감(治安總監)으로 보하도록 하면서, 같은 조 제4항에서는 경찰청장의 임기는 2년으로 하고, 중임(重任)할 수 없다고 규정하고 있는바,

경찰청장이 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원에 해당하는지?

02 회답

경찰청장은 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 「국가공무원법」 제26조의5제1항에서는 임용권자는 전문지식·기술이 요구되거나 임용관리에 특수성이 요구되는 업무를 담당하게 하기 위하여 경력직공무원을 임용할 때에 일정기간을 정하여 근무하는 공무원(이하 “임기제공무원”이라 함)을 임용할 수 있다고

규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 임기제공무원의 임용요건, 임용절차, 근무상한연령 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 「공무원임용령」 제22조의4제1항 전단에서는 임용권자 또는 임용제청권자는 정원(일반임기제공무원[232]을 임용하는 경우만 해당함) 및 예산의 범위에서 임기제공무원을 임용할 수 있다고 규정하여, 임용권자가 경력직공무원을 임기제공무원으로 임용할 것인지 여부는 기관의 정원, 예산, 소관 업무의 특성 등을 고려하여 결정할 수 있도록 한 반면, 경찰법 제14조에서는 경찰청에 경찰청장을 두며, 경찰청장은 치안총감(治安總監) 계급의 경찰공무원으로 보하도록 규정(제1항)하고 있고, 경찰청장의 임기는 2년으로 하며 중임할 수 없다고 규정(제4항)하여, 법률로써 그 직과 임기를 정하고 있을 뿐 경찰청장을 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원으로 임명한다는 내용을 별도로 규정하고 있지 않은바, 문언상 경찰청장은 경찰법 제14조에 따라 보하는 공무원임이 분명하고, 「국가공무원법」 제26조의5에 따라 임용된 임기제공무원에는 해당하지 않습니다.

그리고 경찰청과 그 소속기관의 조직과 직무범위에 관한 사항을 규정하기 위하여 마련된 「경찰청과 그 소속기관 직제」 제63조제1항 본문에서는 경찰청에 두는 공무원의 정원을 별표 4로 규정하면서, 같은 항 단서에서는 필요한 경우에는 별표 4에 따른 총정원의 10퍼센트를 넘지 않는 범위에서 행정안전부령으로 정원을 따로 정할 수 있도록 규정하고 있고, 「경찰청과 그 소속기관 직제 시행규칙」 제77조제1항 단서에서는 「경찰청과 그 소속기관 직제」 제63조제1항 단서에 따라 따로 정할 수 있는 공무원의 직급별 정원을 별표 6으로 정하면서, 별표 6의 정원 중 109명은 임기제공무원으로 임용한다고 명시하고 있는데, 109명 뒤에 괄호를 두어 임기제공무원으로 임용하는 109명에 대하여 그 직급과 정원을 열거하고 있는바, 「경찰청과 그 소속기관 직제」에 따르면 임기제공무원으로 임용하는 109명은 「경찰공무원법」 제3조에 따른 경찰공무원이 아닌 「국가공무원법」 제4조에 따른 일반직공무원에 해당하고, 임기제공무원으로 임용하는 경찰공무원에 대하여는 별도로 명시하고 있지 않으므로, 경찰법에 따라 치안총감(治安總監) 계급의 경찰공무원으로 보하는 경찰청장은 임기제 공무원과 구분된다고 할 것입니다.

따라서 경찰청장은 「국가공무원법」 제26조의5에 따른 임기제공무원에 해당하지 않습니다.

232) 직제 등 법령에 규정된 경력직공무원의 정원에 해당하는 직위에 임용되는 임기제공무원을 말함(「공무원임용령」 제3조의2 참조)

관계법령

국가공무원법

제26조의5(근무기간을 정하여 임용하는 공무원) ① 임용권자는 전문지식·기술이 요구되거나 임용관리에 특수성이 요구되는 업무를 담당하게 하기 위하여 경력직공무원을 임용할 때에 일정기간을 정하여 근무하는 공무원(이하 "임기제공무원"이라 한다)을 임용할 수 있다.

② 임기제공무원의 임용요건, 임용절차, 근무상한연령 및 그 밖에 필요한 사항은 대통령령등으로 정한다.

국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률

제12조(경찰의 조직) 치안에 관한 사무를 관장하게 하기 위하여 행정안전부장관 소속으로 경찰청을 둔다.

제14조(경찰청장) ① 경찰청에 경찰청장을 두며, 경찰청장은 치안총감(治安總監)으로 보한다.

② 경찰청장은 국가경찰위원회의 동의를 받아 행정안전부장관의 제청으로 국무총리를 거쳐 대통령이 임명한다. 이 경우 국회의 인사청문을 거쳐야 한다.

③ 경찰청장은 국가경찰사무를 총괄하고 경찰청 업무를 관장하며 소속 공무원 및 각급 경찰기관의 장을 지휘·감독한다.

④ 경찰청장의 임기는 2년으로 하고, 중임(重任)할 수 없다.

⑤ ~ ⑩ (생 략)

제3절 경찰·소방·국민안전

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-1015, 23-1090

전라북도 군산시 – 시 관할구역의 읍·면 일반국도에서 주차위반을 하고 있는 차에 대하여 「도로교통법」 제35조제1항·제2항에 따른 조치를 할 수 있는 자의 범위(「도로교통법」 제35조제1항·제2항 등)

01 질의요지

「도로교통법」 제35조제1항에서는 경찰공무원(제1호), 시장등(특별시장·광역시장[233]·제주특별자치도지사, 시장·군수[234] 또는 도지사를 말하며, 이하 같음)(제2호)이 임명하는 공무원은 같은 법 제32조·제33조 또는 제34조를 위반하여 주차하고 있는 차(이하 "주차위반차"이라 함)가 교통에 위험을 일으키게 하거나 방해될 우려가 있을 때에는 차의 운전자 또는 관리책임이 있는 사람에게 주차 방법을 변경하거나 그 곳으로부터 이동할 것을 명할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제35조제2항에서는 경찰서장이나 시장등은 같은 조 제1항의 경우 차의 운전자나 관리 책임이 있는 사람이 현장에 없을 때에는 필요한 범위에서 그 차의 주차방법을 직접 변경하거나 변경에 필요한 조치를 할 수 있으며, 부득이한 경우 관할 경찰서나 경찰서장 또는 시장등이 지정하는 곳으로 이동하게 할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「도로법」 제23조제1항제1호 및 제2항제3호에서는 시 관할구역의 동(洞) 지역에 있는 일반국도[235]의 도로관리청은 해당 시장으로, 시 관할구역 동 지역이 아닌 일반국도(이하 "시 관할구역의 읍·면 일반국도"라 함)의 도로관리청은 국토교통부장관으로 규정하고 있는바,

시 관할구역의 읍·면 일반국도에 대하여 시장이 임명하는 공무원(이하 "시장임명

233) 「도로교통법」 제147조제2항 및 같은 법 시행령 제86조제2항제2호에 따라 특별시장 또는 광역시장으로부터 같은 법 제35조에 따른 주차위반 차에 대한 조치 권한을 위임받은 구청장 및 군수도 포함하며, 이하 같음.

234) 광역시의 군수는 제외하며, 이하 같음.

235) 우회국도 및 지정국도는 제외하며, 이하 같음.

공무원"이라 함) 및 시장이 해당 도로에 주차된 주차위반 차에 대하여 「도로교통법」 제35조제1항 및 제2항에 따른 조치를 할 수 있는지?

02 회답

시 관할구역의 읍·면 일반국도에 대하여 시장임명공무원 및 시장은 해당 도로에 주차된 주차위반 차에 대하여 「도로교통법」 제35조제1항 및 제2항에 따른 조치를 할 수 있습니다.

03 이유

법률의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[236], 「도로교통법」 제35조제1항제2호에서는 '시장등이 대통령령으로 정하는 바에 따라 임명하는 공무원'은 주차위반 차의 운전자 또는 관리 책임이 있는 사람에게 주차 방법을 변경하거나 그 곳으로부터 이동할 것을 명할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 경찰서장이나 '시장등'은 같은 조 제1항의 경우 차의 운전자나 관리 책임이 있는 사람이 현장에 없을 때에는 필요한 범위에서 그 차의 주차방법을 직접 변경하거나 변경에 필요한 조치를 할 수 있으며, 부득이한 경우에는 관할 경찰서나 경찰서장 또는 시장등이 지정하는 곳으로 이동하게 할 수 있다고 규정하고 있는바, 주차위반 차에 대하여 시장임명공무원 및 시장이 「도로교통법」 제35조제1항 및 제2항에 따른 조치를 할 수 있다는 점은 문언상 명백합니다.

그리고 「도로법」은 도로망의 계획수립, 도로 노선의 지정, 도로공사의 시행과 도로의 시설 기준, 도로의 관리·보전 및 비용 부담 등에 관한 사항을 규정함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제23조제1항제1호 및 제2항제3호에서는 시 관할구역의 읍·면 일반국도의 도로관리청을 국토교통부장관으로 규정하고 있으나, 같은 법에 따른 도로관리청은 도로에 관한 계획, 건설, 관리의 주체가 되는 기관(제2조제5호)으로, 같은 법에 따라 소관 도로에 대하여 도로의 원활한 건설 및 유지·관리를 위한 도로건설·관리계획을 수립하고(제6조), 도로공사와 도로의 유지·관리(제31조) 등을 수행할 권한을 가지는 것이지, 그 소관 도로에 주차된 주차위반 차에 대하여 「도로교통법」 제35조에 따른 단속 권한이 부여되는 것은

236) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

아니고, 교통상 위험과 장해를 발생시킬 우려가 있는 주차위반 차에 대해서는 교통상 위험과 장해의 방지·제거를 목적으로 하는 「도로교통법」의 규율에 따라야 하는바, 이 사안의 경우 「도로법」에 따라 시 관할구역의 읍·면 일반국도의 도로관리청은 국토교통부장관이라 하더라도, 「도로교통법」 제35조에 따른 조치를 할 수는 없고, 같은 조에 따른 단속 권한을 가진 자가 주차단속을 할 수 있으므로, 그에 따라 시장임명공무원 및 시장은 해당 시 관할구역의 읍·면 일반국도의 주차위반 차에 대해 「도로교통법」 제35조제1항·제2항에 따른 조치를 할 수 있습니다.

또한 「도로교통법」에서 '주차위반 차를 조치할 수 있는 자'에 관하여 규정한 입법 연혁을 살펴보면, 1990년 8월 1일 법률 제4243호로 일부개정되기 전의 구 「도로교통법」 제31조에서는 같은 법을 위반하여 주차하고 있는 차가 교통에 위험하거나 방해될 염려가 있을 때에는 경찰공무원이 이동을 명하고(제1항), 경찰서장이 주차위반 차를 이동하게 할 수 있었으나(제2항), 자동차의 급격한 증가로 주차위반 차로 인한 교통난이 심각해짐에 따라 경찰인력만으로는 주차단속이 어려워짐에 따라 1990년 8월 1일 법률 제4243호로 같은 법을 일부개정하여 시·군·구 공무원도 주차위반 차를 단속할 수 있도록 하는 법적 근거를 마련[237][238]한 것인바, 시 관할구역의 도로라면 해당 시장이 도로관리청인지 여부와 상관없이 시장임명공무원 및 시장은 「도로교통법」 제35조제1항·제2항에 따라 주차위반 차에 대한 조치를 할 수 있다고 보는 것이 해당 규정의 입법 취지에도 부합합니다.

따라서 시 관할구역의 읍·면 일반국도에 대하여 시장임명공무원 및 시장은 해당 도로에 주차된 주차위반 차에 대하여 각각 「도로교통법」 제35조제1항 및 제2항에 따른 조치를 할 수 있습니다.

관계법령

도로교통법

제35조(주차위반에 대한 조치) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 제32조·제33조 또는 제34조를 위반하여 주차하고 있는 차가 교통에 위험을 일으키게 하거나 방해될 우려가 있을 때에는 차의 운전자 또는 관리 책임이 있는 사람에게 주차 방법을 변경하거나 그 곳으로부터 이동할 것을 명할 수 있다.

237) 1990. 8. 1. 법률 제4243호로 일부개정된 「도로교통법」 개정이유서 참조

238) 1990. 5. 8. 의안번호 제130842호로 제출된 도로교통법 일부개정법률안에 대한 국회 내무위원회 심사보고서 참조

1. 경찰공무원
2. 시장등(도지사를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)이 대통령령으로 정하는 바에 따라 임명하는 공무원(이하 "시·군공무원"이라 한다)

② 경찰서장이나 시장등은 제1항의 경우 차의 운전자나 관리 책임이 있는 사람이 현장에 없을 때에는 도로에서 일어나는 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요한 범위에서 그 차의 주차방법을 직접 변경하거나 변경에 필요한 조치를 할 수 있으며, 부득이한 경우에는 관할 경찰서나 경찰서장 또는 시장등이 지정하는 곳으로 이동하게 할 수 있다.

③ ~ ⑦ (생 략)

도로법

제23조(도로관리청) ① 도로관리청은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 제11조 및 제12조에 따른 고속국도와 일반국도: 국토교통부장관
2.·3. (생 략)

② 제1항에도 불구하고 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시의 관할구역에 있는 일반국도(우회국도 및 지정국도는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)와 지방도는 각각 다음 각 호의 구분에 따라 해당 시·도지사 또는 시장이 도로관리청이 된다.

1. · 2. (생 략)
3. 시 관할구역의 동 지역에 있는 일반국도 및 지방도: 해당 시장

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-1125, 24-0280

민원인 – 관리지역 및 농림지역에 대한 개발행위허가의 허용 규모를 조례로 정하고 있는 경우 재해영향평가 등의 협의 대상이 되는 개발행위허가의 범위(「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 등 관련)

01 질의요지

「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호가목1)에서는 재해영향평가[239] 협의 대상 개발사업 중 하나로 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제56조[240]에 따른 개발행위의 허가(이하 "개발행위허가"라 함)를 규정하고 있고, 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고란 제1호 본문에서는 재해영향평가 협의를 해야 하는 개발행위허가의 범위를 '국토계획법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우로 한정'한다고 규정하고 있는 한편,

국토계획법 시행령 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 제2호·제3호에서는 각각 관리지역[241] 및 농림지역[242]에서의 개발행위허가가 허용되는 개발행위의 규모를 "3만제곱미터 미만"으로 규정하고 있고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서에서는 관리지역 및 농림지역에 대하여는 같은 항 제2호 및 제3호의 규정에 의한 면적의 범위 안에서 당해 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군(이하 "시·군등"이라 함)의 도시·군계획 조례로 따로 정할 수 있다고 규정하고 있는바,

국토계획법 시행령 제55조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 관리지역 및 농림지역에서 개발행위허가가 허용되는 개발행위의 규모를 시·군등의 도시·군계획조례로 달리 정하고 있는 경우[243], 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고란 제1호 본문에 따른 '용도지역별 개발행위허가의 규모'는 국토계획법 시행령 제55조제1항제2호·제3호에 따른 '3만제곱미터'를

239) 「자연재해대책법」 제2조제5호에 따른 재해영향평가를 말하며, 이하 같음.

240) 국토계획법 제56조제1항제4호 및 제5호는 제외하며, 이하 같음.

241) 국토계획법 제6조제2호의 "관리지역"을 말하며, 이하 같음.

242) 국토계획법 제6조제3호의 "농림지역"을 말하며, 이하 같음.

243) 시·군등의 도시·군계획조례에서 관리지역 및 농림지역에서의 개발행위허가 허용 규모를 국토계획법 시행령 제55조제1항제2호·제3호에 따른 '3만제곱미터' 보다 낮게 규정하고 있는 경우를 전제함.

의미하는지, 아니면 같은 항 각 호 외의 부분 단서에 따라 해당 시·군등의 '도시·군계획조례에서 정한 규모'를 의미하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고란 제1호 본문에 따른 '용도지역별 개발행위허가의 규모'는 해당 시·군등의 '도시·군계획조례에서 정한 규모'를 의미합니다.

03 이유

먼저 국토계획법 시행령 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문 및 각 호에서는 용도지역별 특성에 따라 개발행위허가가 허용되는 개발행위의 규모를 규정하면서, 관리지역(제2호) 및 농림지역(제3호)의 경우에는 각각 '3만제곱미터 미만'으로 규정하고 있는데, 같은 항 각 호 외의 부분 단서에서는 관리지역 및 농림지역에 대하여는 같은 항 제2호 및 제3호에 따른 면적의 범위 안에서 해당 시·군등의 도시군·계획조례로 따로 정할 수 있다고 규정하고 있는바, 이러한 본문과 단서의 내용을 종합하면, 같은 항에 따라 관리지역 및 농림지역에서 개발행위허가가 허용되는 개발행위의 규모는 원칙적으로는 '3만제곱미터 미만'이나, 시·군등의 도시군·계획조례로 별도의 기준을 정하고 있는 경우에는 '3만제곱미터 미만'이 아닌 '도시군·계획조례에서 정한 규모'가 된다고 할 것입니다.

그런데 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고란 제1호 본문에서는 개발행위허가의 경우 재해영향평가 협의를 해야 하는 범위를 "국토계획법 시행령 제55조제1항에 따른" 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우로 한정한다고 규정하여, 국토계획법 시행령 제55조제1항의 본문 또는 단서 어느 한 부분이 아닌 같은 항 전체를 인용하는 규정방식을 취하고 있고, 법률에서 규정의 구체적인 내용을 하위법령에 위임하거나 특정한 조건에서는 조례 등에 별도 규정한 사항에 따르도록 하면서, 하위법령이나 위임조례에서 이를 개별·구체화하고 있다면 법률의 조항과 해당 하위법령 및 조례의 규정은 서로 불가분의 관계를 이루면서 전체적으로 하나의 규율 내용을 형성하고 있는 것으로 보아야 할 것[244]인바, 이

244) 헌법재판소 2012. 8. 23. 선고 2010헌마328 결정례 참조

사안과 같이 관리지역 및 농림지역에서 개발행위허가가 허용되는 개발행위의 규모를 시·군등의 도시·군계획조례로 달리 정하고 있는 경우 재해영향평가의 협의 대상이 되는 기준 규모인 '국토계획법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모'는 해당 시·군등의 '도시군·계획조례에서 정한 규모'를 의미한다고 보는 것이 관련 규정의 문언과 규정체계에 부합하는 해석입니다.

그리고 「자연재해대책법」에 따른 재해영향평가 협의 제도는 각종 개발사업의 계획수립 단계부터 사전 심의기능을 강화하여 '무분별한 개발 억제'와 '재해발생요인'을 사전에 차단하기 위해 도입된 제도[245]로, 같은 법 제7조제1항에서는 관계 행정기관의 장은 재해영향평가 등의 협의 절차가 끝나기 전에 개발사업에 대한 허가등[246]을 하여서는 아니 된다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 개발사업의 허가등을 받으려는 자는 재해영향평가 등의 협의 절차가 끝나기 전에는 개발사업에 대한 공사를 할 수 없도록 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 재해영향평가의 협의는 그 대상 개발사업에 대해 개별 법령에 따른 허가등을 하기 전에 실시하는 절차로서, 자연재해대책법령에 따른 재해영향평가 협의 대상 개발행위허가의 규모 역시 다른 특별한 규정이 없는 한 국토계획법 제58조제1항제1호 본문 및 같은 법 시행령 제55조제1항에 따라 그 건축물이나 사업부지에 직접 적용될 개발행위허가 허용 규모 기준에 따르는 것이 타당하다 할 것[247]이므로, 이 사안과 같이 국토계획법 시행령 제55조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 시·군등의 도시·군계획조례로 관리지역 및 농림지역에서 개발행위허가 허용 규모를 달리 정하고 있는 경우에는 해당 개발행위에 적용될 개발행위허가 허용 규모 기준인 해당 시·군등의 '도시·군계획조례에서 정한 규모'에 따라 재해영향평가 협의 대상 여부를 판단해야 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 비고란 제1호 본문에 따른 '용도지역별 개발행위허가의 규모'는 해당 시·군등의 '도시·군계획조례에서 정한 규모'를 의미합니다.

---

245) 2005. 1. 27. 법률 제7359호로 전부개정되어 2005. 7. 27. 시행된 자연재해대책법 전부개정법률 개정이유서 및 2004. 7. 2. 의안번호 제170119호로 발의된 자연재해대책법개정법률안에 대한 국회 행정자치위원회 심사보고서 참조

246) 각종 개발사업의 근거 법령에 따른 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등 처분을 말하며, 이하 같음.

247) 법제처 2023. 2. 20. 회신 23-0090 해석례 참조

관계법령

자연재해대책법 시행령

[별표 1]

재해영향평가등의 협의 대상 행정계획 및 개발사업의 범위 및 협의 시기

(제6조제1항 관련)

1. (생 략)
2. 개발사업

구분	대상 개발사업	협의 시기
가. 국토·지역 계획 및 도시의 개발	1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조(제1항제4호 및 제5호는 제외한다)에 따른 개발행위의 허가	개발행위 허가 전
	2) ~ 21) (생 략)	
나. ~ 아. (생 략)		

비고

1. 위 표의 개발사업 중 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우로 한정하며, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에는 1만제곱미터) 이상이거나 길이가 2킬로미터(「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제9조에 따른 임도 설치의 경우에는 4킬로미터) 이상인 경우로 한다. 다만, 개발사업 부지의 전부가 법 제12조에 따른 자연재해위험개선지구 또는 법 제25조의3에 따른 해일위험지구에 포함되는 경우에는 모든 대상 개발사업에 대하여 재해영향평가 협의를 하여야 한다.
2. ~ 4. (생 략)

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령

제55조(개발행위허가의 규모) ① 법 제58조제1항제1호 본문에서 "대통령령으로 정하는 개발행위의 규모"란 다음 각호에 해당하는 토지의 형질변경면적을 말한다. 다만, 관리지역 및 농림지역에 대하여는 제2호 및 제3호의 규정에 의한 면적의 범위안에서 당해 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례로 따로 정할 수 있다.

1. (생 략)
2. 관리지역 : 3만제곱미터 미만
3. 농림지역 : 3만제곱미터 미만
4. (생 략)

②·③ (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 23-1140

민원인 – 안전표지인 '정차금지지대표시' 구획 속 노면에 표시된 '정지신호 시 진입금지'가 그 자체로 '정지신호 시 정차금지지대표시 구획으로의 진입금지'를 지시하는 안전표지에 해당하는지 여부(「도로교통법」 제5조제1항 등 관련)

01 질의요지

「도로교통법」 제3조제1항 본문에서는 시장등[248]은 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 신호기[249] 및 안전표지[250](이하 "교통안전시설"이라 함)를 설치·관리해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제4조제1항의 위임에 따라 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준을 규정하고 있는 같은 법 시행규칙 별표 6 Ⅱ 제5호 524란에서는 안전표지의 하나인 노면표시[251]의 종류 중 하나로 '정차금지지대표시'를 규정하고 있으며, 같은 법 제5조제1항에서는 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시를 따라야 한다고 규정하고 있는바,

시장등이 신호기와 정지선표시[252]가 설치된 곳에 「도로교통법」 제3조제1항 본문에 따른 안전표지(노면표시)로서 같은 법 시행규칙 별표 6 Ⅱ 제5호 524란에 따른 '정차금지지대표시'를 설치하면서, 그 '정차금지지대표시' 구획 속 노면에 '정지신호 시 진입금지'라는 문구를 자율적으로 표시한 경우, '정지신호 시 진입금지' 표시가 그 자체로 차마 운전자의 '정지신호 시 정차금지지대표시 구획으로의 진입금지'를 지시하는 안전표지(노면표시)에 해당하는지?

248) 특별시장·광역시장·제주특별자치도지사 또는 시장·군수(광역시의 군수는 제외함)를 말하며, 이하 같음.
249) 「도로교통법」 제2조제15호에 따른 신호기를 말하며, 이하 같음.
250) 「도로교통법」 제2조제16호에 따른 안전표지를 말하며, 이하 같음.
251) 「도로교통법 시행규칙」 제8조제1항제5호에 따른 노면표시를 말하며, 이하 같음.
252) 「도로교통법 시행규칙」 별표 6 Ⅱ 제5호 530란에 따른 정지선표시를 말하며, 이하 같음.

02 회답

이 사안의 경우, '정지신호 시 진입금지' 표시는 그 자체로 차마 운전자의 '정지신호 시 정차금지지대표시 구획으로의 진입금지'를 지시하는 안전표지(노면표시)에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 「도로교통법」 제4조에서는 '교통안전시설의 종류, 교통안전시설의 설치 · 관리기준, 그 밖에 교통안전시설에 관하여 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다'고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제8조제1항제5호에서는 교통안전시설인 안전표지의 종류 중 하나로 '도로교통의 안전을 위하여 각종 주의·규제·지시 등의 내용을 노면에 기호·문자 또는 선으로 도로사용자에게 알리는 표지'인 노면표시를 규정하고 있으며, 같은 규칙 별표 6 Ⅱ 제5호에서는 노면표시를 501부터 548까지의 일련번호로 구분하여 '노면표시의 종류', '만드는 방식', '표시하는 뜻', '설치기준 및 장소'를 각각 구체적으로 규정하고 있는바, 노면 표시의 종류는 같은 호에서 열거하고 있는 것으로 한정된다고 할 것인데, 같은 호에서는 '노면표시의 종류' 중 하나로 '정지신호 시 진입금지'를 규정하고 있지 않고, 같은 호 524란에 따른 '정차금지지대표시'의 '만드는 방식'이나 '표시하는 뜻'에서도 '정지신호 시 진입금지'라는 문구의 표시나 그 표시하는 뜻에 관하여 규정하고 있지 않으므로, 이 사안의 '정차금지지대표시' 구획 속 노면에 표시된 '정지신호 시 진입금지' 그 자체가 차마 운전자에게 '정지신호 시 정차금지지대표시 구획으로의 진입금지'를 지시하는 '안전표지(노면표시)'에 해당한다고 볼 수는 없습니다.

더욱이 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석 · 적용해야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 될 것인데[253], 「도로교통법」 제5조제1항에 따르면 차마의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시를 따라야 하고, 같은 법 제156조제1항제1호에서는 같은 법 제5조를 위반한 차마의 운전자는 20만원 이하의 벌금이나 구류 또는 과료에 처한다고 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 '도로교통법령에 따른 교통안전시설에 해당하는 신호기, 정지선표시 및

253) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

정차금지지대표시'가 동시에 설치된 장소에서 차마의 운전자가 '신호기'의 정지신호에 따라 '정지선표시'가 표시하는 지점에 정지해야 하고, '정차금지지대표시'에 따라 정차금지지대표시 구획 부분에 들어가 정차해서는 안되는 것에서 더 나아가 시장등이 자율적으로 표시한 '정지신호 시 진입금지'에 따라야 하는 것으로 확장 또는 유추 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, '정지신호 시 진입금지' 표시는 그 자체로 차마 운전자의 '정지신호 시 정차금지지대표시 구획으로의 진입금지'를 지시하는 안전표지(노면표시)에 해당하지 않습니다.

관계법령

도로교통법

제4조(교통안전시설의 종류 및 설치·관리기준 등) ① 교통안전시설의 종류, 교통안전시설의 설치·관리기준, 그 밖에 교통안전시설에 관하여 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.
② (생 략)

제5조(신호 또는 지시에 따를 의무) ① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.
1.·2. (생 략)
② (생 략)

도로교통법 시행규칙

제8조(안전표지) ① 법 제4조제1항에 따른 안전표지는 다음 각 호와 같이 구분한다.
1. ~ 4. (생 략)
5. 노면표시
도로교통의 안전을 위하여 각종 주의·규제·지시 등의 내용을 노면에 기호·문자 또는 선으로 도로사용자에게 알리는 표지
② 제1항에 따른 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준은 별표 6과 같다.

[별표 6]

안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준

(제8조제2항 및 제11조제1호관련)

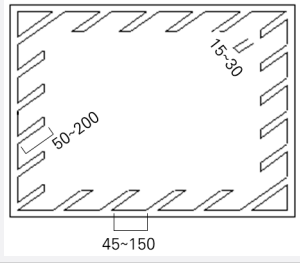
Ⅰ. 일반기준

(생 략)

Ⅱ. 개별기준

1. ~ 4. (생 략)

5. 노면표시

일련번호	종류	만드는 방식 (단위 : 센티미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
501 ~ 523 (생 략)				
524	정차금지 지대표시		·광장이나 교차로 중앙지점 등에 설치된 구획부분에 차가 들어가 정차하는 것을 금지하는 것을 표시하는 것	·광장이나 교차로 중앙지점 등 차가 정차하는 것을 금지하도록 지정된 장소에 노란색으로 설치
525 ~ 548 (생 략)				

질의제목 4 ▶ 안건번호 23-1156

소방청 – 내부계단으로 연결된 복층구조 영업장의 휴게음식점영업 등이 다중이용업에서 제외되는지 여부(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제1호가목 등)

01 질의요지

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」(이하 "다중이용업소법"이라 함) 제2조제1항제1호에서는 "다중이용업"이란 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 영업을 말한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제2조제1호가목에서는 다중이용업의 하나로 「식품위생법 시행령」 제21조제8호에 따른 식품접객업 중 휴게음식점영업 등으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 100제곱미터[254] 이상인 것(본문)을 규정하면서, "다만 영업장(내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장은 제외한다)이 지상 1층이나 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되는 곳에서 하는 영업은 제외한다"(단서)고 규정하고 있는바,

2층 구조의 영업장으로서 한 개 층은 '지상 1층'에, 한 개 층은 '지상에 직접 접하는 층'에 설치되어 있고, 양 층이 내부계단으로 연결되어 있으며, 각 층마다 건축물 외부의 지면과 직접 연결된 주된 출입구가 각각 있는 경우, 해당 영업장에서 하는 휴게음식점영업·제과점영업 또는 일반음식점영업[255](이하 "휴게음식점영업등"이라 함)이 다중이용업소법 시행령 제2조제1호가목 단서에 따라 다중이용업에서 제외되는 영업에 해당하는지?

02 회답

이 사안에 따른 영업장에서 하는 휴게음식점영업등은 다중이용업소법 시행령 제2조제1호가목 단서에 따라 다중이용업에서 제외되는 영업에 해당하지 않습니다.

254) 영업장이 지하층에 설치된 경우에는 66제곱미터를 말하며, 이하 같음.

255) 「식품위생법 시행령」 제21조제8호에 따른 식품접객업 중 휴게음식점영업·제과점영업 또는 일반음식점영업을 말하며, 이하 같음.

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[256], 다중이용업소법 시행령 제2조제1호가목 본문에서는 '휴게음식점영업등으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적의 합계가 100제곱미터 이상인 것'을 "다중이용업"의 하나로 규정하고 있고, 같은 목 단서에서는 '영업장이 지상 1층이나 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되는 곳에서 하는 영업은 제외한다'고 규정하면서, "영업장" 뒤에 괄호를 두어 '내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장을 제외한다'고 규정하여 '내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장에서 하는 영업'을 같은 목 단서에 따라 다중이용업에서 제외되는 영업에서 제외하고 있는바, 같은 목 단서 괄호 부분에 따른 "내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장"에 해당하면, 건축물 외부 지면과 직접 연결되는 주된 출입구의 구조 등과 관계 없이 같은 목 단서에 따라 해당 영업장에서 하는 휴게음식점영업등은 다중이용업에서 제외되는 영업에 해당하지 않는다는 점은 문언상 명백합니다.

그리고 다중이용업소법은 화재 등 재난이나 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 다중이용업소의 안전시설등의 설치·유지 및 안전관리와 화재위험평가, 다중이용업주의 화재배상책임보험에 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리증진에 이바지함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제2조제1항 제1호에서는 다중이용업을 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 "화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것"으로 규정하고 있는바, 일정한 영업장에서 이루어지는 영업이 다중이용업에 해당하는지 여부는 다수인의 재난으로부터 피난의 용이성 뿐만 아니라 화재 발생 및 확산의 위험성 등도 함께 고려하여 판단해야 할 것인데, 같은 법 시행규칙 별표 2 제2호의2에 따르면 다중이용업의 층별 영업장은 다른 영업장 등과 불연재료·준불연재료로 된 차단벽이나 칸막이로 분리되어야 하므로, 내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장이 아닌 경우에는 층간에 화재가 확산될 가능성이 높지 않으나, 내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장인 경우에는 한 층에서 화재 등이 발생한 경우 내부계단 등을 통해 다른 층으로 연기 등이 쉽게 유입되어 화재가 확산될 가능성이 상대적으로 크다는 점 등을 고려할 때, 내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장에 대해서는 다중이용업소법령에 따른 안전 관리에 관한 규제를 적용하는 것이 같은 법의 입법취지 및 다중이용업의 정의에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

256) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

따라서 이 사안에 따른 영업장에서 하는 휴게음식점영업등은 다중이용업소법 시행령 제2조제1호가목 단서에 따라 다중이용업에서 제외되는 영업에 해당하지 않습니다.

관계법령

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "다중이용업"이란 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생 시 생명·신체·재산상의 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는 영업을 말한다.

2. ~ 6. (생 략)

② (생 략)

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령

제2조(다중이용업) 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 영업"이란 다음 각 호의 영업을 말한다. (단서 생략)

1. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호에 따른 식품접객업 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것

가. 휴게음식점영업·제과점영업 또는 일반음식점영업으로서 영업장으로 사용하는 바닥면적(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 산정한 면적을 말한다. 이하 같다)의 합계가 100제곱미터(영업장이 지하층에 설치된 경우에는 그 영업장의 바닥면적 합계가 66제곱미터) 이상인 것. 다만, 영업장(내부계단으로 연결된 복층구조의 영업장을 제외한다)이 다음의 어느 하나에 해당하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되는 곳에서 하는 영업을 제외한다.

1) 지상 1층

2) 지상과 직접 접하는 층

나. (생 략)

1의2. (생 략)

2. ~ 8. (생 략)

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0082

민원인 – 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행규칙」 제2조제2항제3호의 "건축·기계·전기·토목 또는 안전관리 분야 기사로서 재난 및 안전관리에 관한 실무경력이 5년 이상인 사람"의 의미(「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행규칙」 제2조제2항제3호 등 관련)

01 질의요지

「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」(이하 "초고층재난관리법"이라 함) 제12조제1항에서는 초고층 건축물등[257]의 관리주체[258]는 일정한 업무를 총괄·관리하기 위하여 총괄재난관리자[259]를 지정해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5항에서는 총괄재난관리자의 자격은 행정안전부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 같은 항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제2조제2항제3호에서는 총괄재난관리자의 자격요건으로 "「국가기술자격법」에 따른 건축·기계·전기·토목 또는 안전관리 분야 기사(이하 "안전관리등분야기사"라 함)로서 재난 및 안전관리에 관한 실무경력(이하 "재난관리실무경력"이라 함)이 5년 이상인 사람"일 것을 규정하고 있는바,

초고층재난관리법 시행규칙 제2조제2항제3호의 재난관리실무경력은 안전관리등분야기사 자격을 취득한 이후의 경력으로 한정되는지, 아니면 안전관리등분야기사 자격을 취득하기 전의 경력도 포함되는지?

02 회답

초고층재난관리법 시행규칙 제2조제2항제3호의 재난관리실무경력은 안전관리등분야기사 자격을 취득한 이후의 경력으로 한정됩니다.

257) 초고층재난관리법 제2조제3호의 초고층 건축물등을 말하며, 이하 같음.
258) 초고층재난관리법 제2조제5호의 관리주체를 말하며, 이하 같음.
259) 초고층재난관리법 제2조제7호의 총괄재난관리자를 말하며, 이하 같음.

03 이유

먼저 초고층재난법 시행규칙 제2조제2항제3호에서는 총괄재난관리자의 자격요건으로 '안전관리등분야기사로서 재난관리실무경력이 5년 이상인 사람'일 것을 규정하고 있는데, 이 때 '~로서'는 지위나 신분 또는 자격을 나타내는 격조사[260]이므로, 특별한 사정이 없다면 "안전관리등분야기사로서 재난관리실무경력이 5년 이상인 사람"은 안전관리등분야기사의 자격을 취득한 상태에서 5년 이상의 재난관리실무경력을 쌓은 사람을 의미하는 것으로 해석해야 할 것[261]입니다.

그리고 초고층재난법 시행규칙 제2조제2항제1호 및 제2호에서는 각각 「국가기술자격법」에 따른 건축·기계·전기·토목 또는 안전관리 분야 '기술사'(제1호), 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」(이하 "화재예방법 시행령"이라 함) 별표 4 제1호에 따라 '특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 선임될 수 있는 자격을 갖춘 사람'(제2호)을 총괄재난관리자의 자격요건으로 규정하고 있는데, 「국가기술자격법 시행령」 제14조제7항 및 별표 4의2 기술사의 응시자격란 제1호에서는 '기술사'의 응시자격을 "기사 자격을 취득한 후 응시하려는 종목이 속하는 직무분야에서 4년 이상 실무에 종사한 사람"으로 제한하고 있고, 화재예방법 시행령 별표 4 제1호에서는 '특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 선임될 수 있는 자격'을 "소방설비기사의 자격을 취득한 후 5년 이상 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력이 있는 사람" 등으로 규정하고 있는바, 초고층재난법 시행규칙 제2조제2항제1호 및 제2호에 따른 총괄재난관리자의 자격요건도 안전관리 분야와 관련된 자격을 취득한 후 일정 기간의 실무경력을 쌓은 사람일 것을 요구하고 있다는 점에 비추어 볼 때에도, 같은 항 제3호에 따른 재난관리실무경력은 안전관리등분야기사의 자격을 취득한 이후의 경력으로 한정된다고 보는 것이 합리적이라 할 것[262]입니다.

따라서 초고층재난관리법 시행규칙 제2조제2항제3호의 재난관리실무경력은 안전관리등분야기사 자격을 취득한 이후의 경력으로 한정됩니다.

260) 국립국어원 표준국어대사전 참조
261) 법제처 2015. 11. 2. 회신 15-0612 해석례 참조
262) 법제처 2015. 11. 2. 회신 15-0612 해석례 참조

관계법령

초고층재난관리법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "초고층 건축물"이란 층수가 50층 이상 또는 높이가 200미터 이상인 건축물을 말한다(「건축법」 제84조에 따른 높이 및 층수를 말한다. 이하 같다).
2. ~ 4. (생 략)
5. "관리주체"란 초고층 건축물등 또는 일반건축물등의 소유자 또는 관리자(그 건축물등의 소유자와 관리계약 등에 따라 관리책임을 진 자를 포함한다)를 말한다.
6. (생 략)
7. "총괄재난관리자"란 해당 초고층 건축물등의 재난 및 안전관리 업무를 총괄하는 자를 말한다.
8. (생 략)

제12조(총괄재난관리자의 지정 등) ① 초고층 건축물등의 관리주체는 다음 각 호의 업무를 총괄·관리하기 위하여 총괄재난관리자를 지정하여야 한다. 다만, 총괄재난관리자는 다른 법령에 따른 안전관리자를 겸직할 수 없다.

1. ~ 12. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

⑤ 총괄재난관리자의 자격, 등록, 업무정지의 절차, 그 밖에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

초고층재난관리법 시행규칙

제2조(총괄재난관리자의 업무 및 자격) ① (생 략)

② 법 제12조제1항에 따른 총괄재난관리자(이하 "총괄재난관리자"라 한다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이어야 한다.

1. 「건축사법」에 따른 건축사와 「국가기술자격법」에 따른 건축·기계·전기·토목 또는 안전관리 분야 기술사
2. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표 4 제1호에 따라 특급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 선임될 수 있는 자격을 갖춘 사람
3. 「국가기술자격법」에 따른 건축·기계·전기·토목 또는 안전관리 분야 기사로서 재난 및 안전관리에 관한 실무경력이 5년 이상인 사람
4. 「국가기술자격법」에 따른 건축·기계·전기·토목 또는 안전관리 분야 산업기사로서 재난 및 안전관리에 관한 실무경력이 7년 이상인 사람
5. 「주택법」에 따른 주택관리사로서 재난 및 안전관리에 관한 실무경력이 5년 이상인 사람

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0304, 24-0503, 24-0504

행정안전부 – 육상골재 채취 허가 등을 받아 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항에 따른 개발행위의 허가가 의제되는 경우 그 개발행위의 허가가 재해영향평가 협의 대상사업에 해당되는지 여부(「자연재해대책법 시행령」 별표 1 등 관련)

01 질의요지

「자연재해대책법 시행령」 제6조제1항 및 별표 1에서는 재해영향평가등[263]의 협의 대상 행정계획 및 개발사업의 범위와 협의 시기를 정하면서, 같은 별표 제2호에서 재해영향평가의 협의 대상 개발사업으로 같은 호 가목1)에서는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제56조[264]에 따른 '개발행위의 허가'를, 같은 호 사목3)에서는 「골재채취법」 제22조에 따른 '골재채취(하천골재[265]만 해당함)'를 규정하고 있고, 같은 호 비고란 제1호에서는 재해영향평가 협의 대상 개발사업 범위를 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터(국토계획법 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모[266]를 초과하는 경우로 한정함) 이상인 경우 등으로 규정하고 있으며, 같은 호 비고란 제4호에서는 '다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업으로서 개발사업의 대상 규모가 같은 비고 제1호 및 제3호에 따른 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위에 해당하는 경우에 재해영향평가 협의를 하여야 한다'고 규정하고 있는 한편,

「골재채취법」 제22조제1항 본문에서는 골재[267]를 채취하려는 자는 관할 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다고 규정하면서, 같은 법 제23조제1항제1호에서는 골재채취의 허가를 받은 경우에는 국토계획법 제56조제1항제2호 및 제3호에 따른 토지의 형질변경 및 토석의 채취허가(이하 "이 사안 개발행위허가"라 함)를 받은 것으로 본다고 규정하고 있는바,

263) 「자연재해대책법」 제2조제4호의 재해영향성검토 및 같은 조 제5호의 재해영향평가를 말하며(「자연재해대책법」 제4조제1항 및 같은 법 시행령 제3조제1항 참조), 이하 같음

264) 국토계획법 제56조제1항제4호 및 제5호는 제외하며, 이하 같음.

265) 「골재채취법 시행령」 제2조제1항제1호의 하천골재를 말함

266) 주거지역·상업지역·자연녹지지역·생산녹지지역은 1만제곱미터, 공업지역·관리지역·농림지역은 3만제곱미터, 보전녹지지역·자연환경보전지역은 5천제곱미터임(국토계획법 시행령 제55조제1항 참조).

267) 「골재채취법」 제2조제1호에 따른 "골재"를 말하며, 이하 같음.

「골재채취법」 제22조에 따라 바다골재, 산림골재, 육상골재[268](이하 "육상골재등"이라 함)의 채취 허가를 받아 같은 법 제23조제1항제1호에 따라 이 사안 개발행위허가를 받은 것으로 의제되는 경우로서 해당 개발행위허가의 규모가 국토계획법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우, 의제되는 이 사안 개발행위허가에 대하여 재해영향평가 협의를 하여야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 의제되는 이 사안 개발행위허가에 대하여 재해영향평가 협의를 하여야 합니다.

03 이유

먼저 「자연재해대책법 시행령」 별표 1의 규정 체계를 살펴보면, 같은 별표 제2호사목3) 및 같은 호 비고란 제1호에서 「골재채취법」 제22조에 따른 골재채취[269] 허가 대상 부지면적이 5천제곱미터 이상인 경우를 재해영향평가 협의를 하여야 하는 대상 개발사업(이하 "재해영향평가 협의대상사업"이라 함)으로 규정하고 있고, 이와는 별도로 같은 호 가목1) 및 같은 호 비고란 제1호 괄호에서는 '국토계획법 제56조에 따른 개발행위의 허가'가 같은 법 시행령 제55조에 따른 용도지역별 개발행위허가 규모를 초과하는 경우를 재해영향평가 협의대상사업으로 규정하고 있으며, 같은 호 비고란 제4호에서는 다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업의 경우에도 해당 개발사업의 대상 규모가 같은 비고란 '제1호'에 따른 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위에 해당하는 경우에는 재해영향평가 협의를 하여야 한다고 규정하고 있는바, 주된 개발사업인 「골재채취법」 제22조에 따른 육상골재등의 채취 허가가 재해영향평가 협의대상사업에 해당되지 않더라도 해당 채취 허가에 '의제'되는 이 사안 개발행위허가에 대해서는 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호가목1), 같은 호 비고란 제1호 및 제4호에 따라 재해영향평가 협의 대상사업에 해당하는지 여부를 별도로 판단[270]하여 그 대상 부지면적이 '국토계획법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발

268) 「골재채취법 시행령」 제2조제1항제4호의 바다골재, 같은 항 제5호의 산림골재 및 같은 항 제6호의 육상골재를 말함
269) 하천골재만 해당하며, 이하 같음
270) 법제처 2016. 5. 24. 회신 16-0047 해석례 참조

행위허가 규모를 초과하는 경우'에는 해당 개발행위허가에 대한 재해영향평가 협의를 하여야 한다고 해석하는 것이 규정의 문언에 부합한다고 할 것입니다.

그리고 「자연재해대책법」은 태풍, 홍수 등 자연현상으로 인한 재난으로부터 국토를 보존하고 국민의 생명·신체 및 재산과 주요 기간시설을 보호하기 위하여 자연재해의 예방·복구 및 그 밖의 대책에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 재해영향평가는 자연재해에 영향을 미치는 개발사업으로 인한 재해 유발 요인을 조사·예측·평가하고 이에 대한 대책을 마련하는 것이고(제2조제5호), 재해영향평가 협의 제도(제4조)는 각종 개발사업의 계획수립단계부터 사전 심의기능을 강화하여 무분별한 개발을 억제하고 재해 발생요인을 사전에 차단하기 위해 도입된 제도[271]로서 같은 법 시행령 별표 1 제2호 비고란 제4호에서 다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 일정 규모 이상의 개발사업에 대해서도 재해영향평가 협의대상사업으로 규정한 것은 일정 규모 이상의 개발사업이 의제되는 경우에도 예외 없이 해당 개발사업이 자연재해에 미치는 영향을 검토하여 재해 발생 가능성을 최소화하려는 취지인바[272], 그 개발사업이 개별 법령에 따라 직접 허가 등을 받은 경우인지 또는 허가 등을 받은 것으로 의제되는 경우인지와는 관계없이 일정 규모 이상의 개발사업이라면 재해영향평가 협의대상사업에 해당하는 것으로 해석하는 것이 재해영향평가 협의 제도의 취지에 비추어 볼 때 타당하다고 할 것입니다.

또한 구 「자연재해대책법 시행령」[273] 별표 1 제2호 비고란 제4호에서는 직접 인·허가 등을 받는 개발사업의 경우와는 달리 의제되는 개발사업에 대한 협의 대상 규모 기준을 일률적으로 '15만제곱미터 이상'으로 규정하여 운영하고 있다가, 동일한 개발사업이라면 인·허가 등을 의제받는지 여부와는 무관하게 자연재해에 미치는 영향은 동일하여 인·허가 등의 의제 여부에 따라 재해영향평가 협의 대상 규모 기준을 달리 적용할 필요가 없다는 차원에서[274] 2014년 3월 11일 대통령령 제25248호로 일부개정된 「자연재해대책법 시행령」에서 인·허가 등을 받은 것으로 의제되는 개발사업의 경우에도 직접 인·허가 등을 받는 경우와 마찬가지로 '같은 비고란 제1호의 사업별 부지면적 기준'에 따라 협의 대상 여부를 판단하도록 해당 규정을 개정한 것인바, 육상골재등 채취 허가에 의제되는 이 사안 개발행위허가가 같은 영 별표 1 제2호 비고란 제1호에 따른 개발행위허가 규모 기준을 초과하는 경우에는 해당 개발행위

271) 2005. 1. 27. 법률 제7359호로 전부개정된 「자연재해대책법」 개정이유서 및 2004. 7. 2. 의안번호 제170119호로 발의된 자연재해대책법개정법률안에 대한 국회 행정자치위원회 심사보고서 참조

272) 2008. 9. 26. 대통령령 제21044호로 일부개정되어 2008. 9. 28. 시행된 자연재해대책법시행령 일부개정령안 조문별 제·개정이유서 및 법제처 2017. 7. 24. 회신 17-0215 해석례 참조

273) 2014. 3. 11. 대통령령 제25248호로 일부개정되기 전의 것을 말함

274) 2014. 3. 11. 대통령령 제25248호로 일부개정된 「자연재해대책법 시행령」 조문별 제·개정이유서 참조

허가에 대한 재해영향평가 협의를 별도로 거쳐야 한다고 보는 것이 관련 규정의 입법연혁에 부합하는 해석입니다.

따라서 이 사안의 경우, 의제되는 이 사안 개발행위허가에 대하여 재해영향평가 협의를 하여야 합니다.



관계법령

골재채취법

제22조(골재채취의 허가) ① 골재를 채취하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 시장·군수 또는 구청장{「배타적 경제수역 및 대륙붕에 관한 법률」 제2조에 따른 배타적 경제수역(이하 "배타적 경제수역"이라 한다)에서의 골재채취의 경우에는 국토교통부장관을 말하며, 제34조에 따른 골재채취단지(배타적 경제수역에서 지정된 골재채취단지는 제외한다)에서의 골재채취의 경우에는 시·도지사를 말한다. 이하 이 조, 제23조부터 제25조까지, 제29조부터 제31조까지, 제33조 및 제47조의2에서 같다}의 허가를 받아야 한다. 〈단서 생략〉

② ~ ⑥ (생 략)

제23조(다른 법률과의 관계) ① 골재채취의 허가를 받은 경우에는 다음 각 호의 허가나 승인을 받은 것으로 본다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조제1항제2호 및 제3호에 따른 토지의 형질변경 및 토석의 채취허가
2. ~ 10. (생 략)

② (생 략)

골재채취법 시행령

제2조(정의) ① 이 영에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "하천골재"라 함은 「하천법」 제2조제2호에 따른 하천구역에서 채취하는 골재로서 수중골재와 하상골재를 말한다.
2. "수중골재"라 함은 수중장비에 의하여 하천구역의 수면 밑에서 채취하는 골재를 말한다.
3. "하상골재"라 함은 하천구역에서 채취하는 골재중 제2호 외의 것을 말한다.
4. "바다골재"라 함은 바다 밑에서 채취하는 골재를 말한다.
5. "산림골재"라 함은 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 산림 안에서 채취하는 골재를 말한다.
6. "육상골재"라 함은 제1호 내지 제5호 외의 골재를 말한다.

② (생 략)

자연재해대책법 시행령

[별표 1]

재해영향평가등의 협의 대상 행정계획 및 개발사업의 범위 및 협의 시기

(제6조제1항 관련)

1. (생 략)

2. 개발사업

구분	대상 개발사업	협의 시기
가. 국토·지역 계획 및 도시의 개발	1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조(제1항제4호 및 제5호는 제외한다)에 따른 개발행위의 허가	개발행위 허가 전
	2) ~ 21) (생 략)	
나. ~ 바. (생 략)		
사. 산지개발 및 골재채취	1)·2) (생 략)	개발행위 허가 전
	3) 「골재채취법」 제22조에 따른 골재채취(하천골재만 해당함)	허가 전
	4) ~ 10) (생 략)	
아. (생 략)		

비고

1. 위 표의 개발사업 중 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위는 개별 법령에서 정하는 바에 따라 허가·승인 등을 하려는 개발사업의 부지면적이 5천제곱미터(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제56조에 따른 개발행위의 허가의 경우에는 같은 법 시행령 제55조제1항에 따른 용도지역별 개발행위허가의 규모를 초과하는 경우로 한정하며, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조에 따른 공장설립 승인의 경우에는 1만제곱미터) 이상이거나 길이가 2킬로미터(「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제9조에 따른 임도 설치의 경우에는 4킬로미터) 이상인 경우로 한다. 다만, 개발사업 부지의 전부가 법 제12조에 따른 자연재해위험개선지구 또는 법 제25조의3에 따른 해일위험지구에 포함되는 경우에는 모든 대상 개발사업에 대하여 재해영향평가 협의를 하여야 한다.
2.·3. (생 략)
4. 다른 법령에 따라 승인 등을 받은 것으로 의제되는 사업으로서 개발사업의 대상 규모가 비고 제1호 및 제3호에 따른 재해영향평가 협의를 하여야 하는 개발사업의 범위에 해당하는 경우에는 재해영향평가 협의를 하여야 한다.

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0344

민원인 – 청원주가 국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰에게 「청원경찰법 시행령」 별표 1에 따른 봉급보다 상향된 봉급을 지급할 수 있는지(「청원경찰법 시행령」 별표 1 등 관련)

01 질의요지

「청원경찰법」 제6조제1항제1호에서는 청원주는 청원경찰에게 지급할 봉급과 각종 수당을 부담하도록 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 국가기관 또는 지방자치단체(이하 "국가기관등"이라 함)에 근무하는 청원경찰의 보수는 각 호의 구분에 따라 같은 재직기간에 해당하는 경찰공무원의 보수를 감안하여 대통령령으로 정하도록 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제9조제1항에서는 국가기관등에 근무하는 청원경찰의 봉급은 별표 1과 같다고 규정하고 있고, 같은 영 별표 1에서는 재직기간 및 호봉에 따른 월별 봉급액을 규정하고 있는바,

청원주는 국가기관등에 근무하는 청원경찰에게 「청원경찰법 시행령」 별표 1에 따른 봉급보다 상향된 봉급을 지급할 수 있는지?

02 회답

청원주는 국가기관등에 근무하는 청원경찰에게 「청원경찰법 시행령」 별표 1에 따른 봉급보다 상향된 봉급을 지급할 수 없습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데, 「청원경찰법」 제6조제2항에서 국가기관등에 근무하는 청원경찰의 보수는 각 호의 구분에 따라 같은 재직기간에 해당하는 경찰공무원의 보수를 감안하여 '대통령령으로 정한다'고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제9조제1항에서는 국가기관등에 근무하는 청원경찰의 봉급은 '별표 1과 같다'고

규정하면서 같은 영 별표 1에서 국가기관등에 근무하는 청원경찰의 봉급표를 정하여 청원경찰의 재직기간별로 호봉에 따라 매월 지급하는 봉급액을 구체적으로 규정하고 있는바, 「청원경찰법」 제6조제2항에 따라 같은 법 시행령 제9조제1항 및 별표 1에서는 국가기관등에 근무하는 청원경찰의 봉급을 직접 규정하고 있고, 청원경찰법령에서 국가기관등에 근무하는 청원경찰의 봉급에 대해서 청원주와 청원경찰 간 협의로 같은 영 별표 1과 다르게 봉급을 정할 수 있는 예외 규정을 두고 있지도 않으므로, 문언상 국가기관등에 근무하는 청원경찰에게 「청원경찰법 시행령」 별표 1과 다르게 봉급을 지급할 수 없다고 할 것입니다.

그리고 「청원경찰법」 제6조제3항에서는 청원주의 봉급·수당의 최저부담기준액(국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰의 봉급·수당은 제외함)은 경찰청장이 정하여 고시한다고 규정하고 있어, 국가기관등에 근무하는 청원경찰의 봉급·수당은 그 최저부담기준액을 경찰청장이 정하여 고시하는 대상에서 제외하고 있고, 이에 따라 같은 법 시행령 제9조에서는 국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰의 봉급을 별표 1과 같이 규정하고, 같은 영 제10조에서는 국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰 외의 청원경찰의 봉급 등은 「청원경찰법」 제6조제3항에 따라 경찰청장이 고시한 최저부담기준액 이상으로 지급하도록 하여, 국가기관등에서 근무하고 있는 청원경찰과 국가기관등에서 근무하고 있는 청원경찰 외의 청원경찰의 보수를 구분하여 규정하고 있는바, 국가기관등에서 근무하고 있는 청원경찰의 봉급에 대해서는 「청원경찰법 시행령」 별표 1에서 정한 금액을 최저부담기준액으로 본다는 등의 명시적 규정이 없는 이상 「청원경찰법 시행령」 별표 1에서 정한 금액을 지급하는 것으로 해석하는 것이 청원경찰법령체계에 부합하는 해석입니다.

아울러 「청원경찰법」 제3조에 따르면 청원경찰은 청원주와 경찰서장의 감독을 받아 그 경비구역만의 경비를 목적으로 「경찰관 직무집행법」에 따른 경찰관의 직무를 수행하는 자로서, 특히 국가기관등에 근무하는 청원경찰은 비록 공무원은 아니지만 다른 청원경찰들과는 달리 임용권자가 행정기관의 장이고, 국가기관등에서 보수를 받으며(제6조), 휴직 및 명예퇴직에 대해서는 「국가공무원법」 제71조부터 제73조까지 및 제74조의2를 준용하도록 하고 있는(제10조의7)[275] 등 국가기관등에 근무하는 청원경찰에 적용되는 임용, 직무, 복무의 내용 등을 종합하면 업무의 공공성, 업무수행의 특수성으로 인하여 그 근무관계는 사법상의 고용관계의 성격 및 공법상 근무관계의 성격을 복합적으로 가지고 있는바[276], 「청원경찰법」에서 국가기관등에 근무하는 청원경찰의 봉급에 대해서는 같은 재직기간에 해당하는 경찰공무원의 보수를 감안하여 대통령령으로 정하도록 위임한 것이고, 그 위임에

275) 법제처 2018. 6. 12. 회신 18-0205 해석례 참조

276) 헌법재판소 2010. 2. 25. 선고 2008헌바160 결정례 참조

따라「청원경찰법 시행령」별표 1에서 그 봉급액을 규정하고 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 청원주는 국가기관등에 근무하는 청원경찰에게「청원경찰법 시행령」별표 1에 따른 봉급보다 상향된 봉급을 지급할 수 없습니다.

관계법령

청원경찰법

제6조(청원경찰경비) ① 청원주는 다음 각 호의 청원경찰경비를 부담하여야 한다.

1. 청원경찰에게 지급할 봉급과 각종 수당
2. ~ 4. (생 략)

② 국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰의 보수는 다음 각 호의 구분에 따라 같은 재직기간에 해당하는 경찰공무원의 보수를 감안하여 대통령령으로 정한다.

1. 재직기간 15년 미만: 순경
2. 재직기간 15년 이상 23년 미만: 경장
3. 재직기간 23년 이상 30년 미만: 경사
4. 재직기간 30년 이상: 경위

③ (생 략)

청원경찰법 시행령

제9조(국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰의 보수) ① 법 제6조제2항에 따른 국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰의 봉급은 별표 1과 같다.

②·③ (생 략)

[별표 1]

국가기관 또는 지방자치단체에 근무하는 청원경찰의 봉급표

(제9조제1항 관련)

(월 지급액, 단위: 원)

재직기간 / 호봉	15년 미만	15년 이상 23년 미만	23년 이상 30년 미만	30년 이상
1	1,877,000	–	–	–
2	1,914,800	–	–	–
3~30	(생 략)			
31	3,629,500	3,846,100	4,265,400	4,554,500

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0421, 24-0664, 24-0665

민원인 – 소방안전관리대상물의 관계인이 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제25조에 따라 관리업자로 하여금 일부 소방안전관리업무를 대행하게 한 경우 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자를 선임할 의무가 있는지 여부 등(「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조제3항 등 관련)

01 질의요지

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(이하 "화재예방법"이라 함) 제25조제1항에서는 소방안전관리대상물 중 연면적 등이 일정규모 미만인 대통령령으로 정하는 소방안전관리대상물(이하 "중소규모소방안전관리대상물"이라 함)의 관계인은 같은 법 제24조제1항에도 불구하고 관리업자[277]로 하여금 같은 조 제5항에 따른 소방안전관리업무 중 대통령령으로 정하는 업무를 대행하게 할 수 있으며, 이 경우 같은 법 제24조제3항에 따라 선임된 소방안전관리자는 관리업자의 대행업무 수행을 감독하고 대행업무 외의 소방안전관리업무는 직접 수행하여야 한다고 규정하고 있는바,

화재예방법 제24조제1항 후단에 따라 소방안전관리자의 업무에 대하여 보조가 필요한 대통령령으로 정하는 소방안전관리대상물이면서 중소규모소방안전관리대상물에 해당하는 의무관리대상 공동주택[278](이하 "이 사안 공동주택"이라 함)과 관련하여,

가. 이 사안 공동주택의 관계인[279]은 화재예방법 제25조제1항에 따라 관리업자로 하여금 일부 소방안전관리업무를 대행하게 한 경우 같은 법 제24조제1항 및 제3항에 따라 소방안전관리자와 소방안전관리보조자를 선임하여야 하는지?

나. 이 사안 공동주택의 관리주체가 입주자대표회의의 동의를 받아 관리업무의 하나인 소방안전관리업무의 일부를 관리업자로 하여금 대행하게 하는 경우, 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 제1호에 따라 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자를 공동주택관리기구의 기술인력으로 갖추지 않을 수 있는지?[280]

277) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제29조제1항에 따른 소방시설관리업의 등록을 한 자를 말하며(화재예방법 제24조제3항), 이하 같음

278) 「공동주택관리법」 제2조제1항제2호에 따른 의무관리대상 공동주택을 말하며, 이하 같음

279) 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자를 말하며(화재예방법 제2조제2항 및 「소방기본법」 제2조제3호 참조), 이하 같음

02 회답

가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 화재예방법 제24조제1항 및 제3항에 따라 소방안전관리자와 소방안전관리보조자를 선임하여야 합니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 제1호에 따라 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자를 공동주택관리기구의 기술인력으로 갖추어야 합니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

먼저 화재예방법에서 규정하고 있는 소방안전관리자에 관해 살펴보면, 화재예방법 제25조제1항 전단에서는 중소규모소방안전관리대상물의 관계인은 같은 법 제24조제1항에도 불구하고 관리업자로 하여금 같은 법 제24조제5항에 따른 소방안전관리업무 중 대통령령으로 정하는 업무를 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제28조제2항에서는 같은 법 제24조제5항제1호부터 제9호까지에서 규정하고 있는 소방안전관리업무 중 관리업자가 대행할 수 있는 업무를 '같은 항 제3호에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리'와 '같은 항 제4호에 따른 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리'로 규정하고 있으며, 같은 법 제25조제1항 후단에서는 같은 법 제24조제3항에 따라 선임된 소방안전관리자는 관리업자의 대행업무 수행을 감독하고 대행업무 외의 소방안전관리업무는 직접 수행하여야 한다고 규정하고 있는바, 이 사안 공동주택의 관계인이 같은 법 제25조제1항에 따라 관리업자로 하여금 소방안전관리업무를 대행하게 하더라도 그 대행의 범위는 같은 법 제24조제5항제3호 및 제4호의 업무로 한정되므로, ①관리업자의 대행업무 수행을 감독하고 ②같은 법 제24조제5항 각 호의 업무 중 같은 항 제3호·제4호의 업무를 제외한 나머지 소방안전관리업무를 직접 수행할 '소방안전관리자'를 별도로 선임해야 한다고 보는

280) '화재예방법 제24조에 따라 소방안전관리대상물의 관계인이 선임해야 하는 소방안전관리자와 소방안전관리보조자'가 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 제1호의 기술인력에 포함됨을 전제함

것이 같은 법 제25조 및 같은 법 시행령 제28조 등의 문언에 부합하는 해석입니다.

다음으로 소방안전관리보조자에 관한 규정을 살펴보면, 화재예방법 제24조제1항 후단에서는 소방안전관리자의 업무에 대하여 보조가 필요한 대통령령으로 정하는 소방안전관리대상물(이하 "보조자선임필요소방안전관리대상물"이라 함)의 경우에는 소방안전관리자 외에 소방안전관리보조자를 추가로 선임하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 별표 5에서는 보조자선임필요소방안전관리대상물의 범위와 소방안전관리보조자의 선임 대상별 자격 및 인원기준에 대해 구체적으로 규정하고 있으며, 화재예방법령에서 '관리업자로 하여금 소방안전관리업무를 대행하게 한 경우에는 소방안전관리보조자를 선임하지 않을 수 있다'는 등의 내용을 별도로 규정하고 있지도 않은바, 보조자선임필요소방안전관리대상물에 해당하는 이 사안 공동주택의 관계인은 관리업자에게 일부 소방안전관리업무를 대행시킨 경우에도 소방안전관리보조자를 선임할 의무가 있다고 할 것입니다.

그렇다면 화재예방법 제24조제1항에서 '소방안전관리대상물의 관계인은 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람을 소방안전관리자로 선임하여야 한다는 내용'(전단) 및 '보조자선임필요소방안전관리대상물의 경우에는 소방안전관리자 외에 소방안전관리보조자를 추가로 선임하여야 한다는 내용'(후단)을 규정하면서, 같은 조 제3항에서 '제1항에도 불구하고 중소규모소방안전관리대상물의 관계인은 소방안전관리업무를 대행하는 관리업자를 감독할 수 있는 사람을 지정하여 소방안전관리자로 선임할 수 있다'고 규정한 것은, 중소규모소방안전관리대상물의 관계인의 경우 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람을 같은 법 제24조제5항제1호부터 제9호까지의 소방안전관리업무를 수행하기 위한 소방안전관리자로 선임(같은 법 제24조제1항)하는 대신, '같은 법 제24조제5항제3호·제4호의 소방안전관리업무를 대행하는 관리업자를 감독할 수 있는 사람'을 업무대행 감독 및 같은 법 제24조제5항 각 호의 소방안전관리업무 중 관리업자에게 대행시키지 않은 나머지 업무를 수행하도록 하기 위하여 소방안전관리자로 선임(같은 법 제24조제3항)할 수 있도록 한 것이지, 관리업자에게 일부 소방안전관리업무를 대행하도록 한 경우에 대해 중소규모소방안전관리대상물 관계인의 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자 선임 의무를 면제하려는 취지는 아니라고 할 것입니다.

또한 입법연혁적으로도, 구 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(2014년 1월 7일 법률 제12207호로 일부개정되기 전의 것을 말함) 제20조제3항에서는 소방안전관리대상물의 관계인은 관리업자에게 소방안전관리 업무를 대행하게 할 수 있고, 이 경우 소방안전관리 업무 대행자를 감독할 수 있는 자를 소방안전관리자(1명)로 선임할 수 있도록

규정하고 있었으나, 소방안전관리업무의 성질상 관계인 또는 소방안전관리자가 직접 수행하여야 하는 업무도 대행업체에 떠넘기는 사례가 발생하고, 소방안전관리대상물별로 선임된 1명의 소방안전관리자만으로는 실제 화재발생 시 소방안전관리자가 부재하여 체계적으로 대응하지 못하는 등의 문제가 발생함에 따라[281], 2014년 1월 7일 법률 제12207호로 같은 법을 일부개정하면서 화재 등 재난 발생 시 자체 대응능력을 강화하기 위해 규모가 큰 소방안전관리대상물 등의 관계인에게 소방안전관리자뿐만 아니라 '소방안전관리보조자'를 선임하도록 하고[282](제20조제2항), 소방안전관리대상물 중 '일정 규모 이하의 것'에 대해서 소방안전관리업무 중 성질상 대행이 가능한 업무만 관리업자 등으로 하여금 대행하게 하도록 한 것(제20조제3항)이 현행 화재예방법 제24조 및 제25조로 이어지고 있는 것인바, 소방안전을 강화하고자 한 화재예방법령의 입법취지를 고려할 때에도, 관리업자에게 소방 관련 시설 관리업무와 같은 일부 소방안전관리업무를 대행하게 한 경우라고 하여 이 사안 공동주택의 관계인에게 화재예방법 제24조제1항 및 제3항에 따라 소방안전관리자와 소방안전관리보조자를 선임할 의무가 없다고 보기는 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 화재예방법 제24조제1항 및 제3항에 따라 소방안전관리자와 소방안전관리보조자를 선임하여야 합니다.

나. 질의 나에 대해

「공동주택관리법 시행령」 별표 1 제1호에서는 공동주택관리기구의 기술인력 기준을 정하면서, 관리주체가 입주자대표회의의 동의를 받아 관리업무의 일부를 해당 법령에서 인정하는 전문용역업체에 용역하는 경우 해당 기술인력을 갖추지 않을 수 있도록 기술인력의 예외를 규정하고 있는데, 이 사안 공동주택의 관리주체가 입주자대표회의의 동의를 받아 관리업자로 하여금 일부 소방안전관리업무를 대행하게 하는 경우 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자를 공동주택관리기구의 기술인력으로 갖추지 않을 수 있는지 여부에 대해 명시적으로 규정하고 있지는 않습니다.

먼저 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 제1호에서는 공동주택관리기구가 갖추어야 하는 기술인력에 대한 예외에 관해 "해당 법령에서 인정하는 전문용역업체"에 용역하는 경우 "해당

281) 2013. 5. 31. 의안번호 제1905229호로 발의(정부)된 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 안전행정위원회 심사보고서 및 2012. 11. 14. 의안번호 제1902564호로 발의(의원)된 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 안전행정위원회 심사보고서 참조

282) 구 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(2014. 1. 7. 법률 제12207호로 일부개정되어 2014. 7. 8. 시행된 것) 개정이유 참조

기술인력"을 갖추지 않을 수 있다고 규정하고 있어, 별도의 전문용역업체에 소방·전기 안전 등의 관리업무 일부를 맡기기만 하면 그 분야의 기술인력 전부를 갖추지 않아도 된다는 것이 아니라, 문언상 개별 법령에서 전문성을 갖춘 업체로 하여금 '특정 기술인력이 수행하는 업무를 대신할 수 있도록 인정하고 있는 부분만큼' 그에 해당하는 기술인력만 갖추지 않을 수 있도록 규정한 것으로 해석하는 것이 타당합니다.

그런데 화재예방법 제24조 및 제25조에서는 소방시설관리업의 등록을 한 자, 즉 관리업자로 하여금 화재예방법 제24조제5항제1호부터 제9호까지의 소방안전관리업무 중 같은 항 제3호 및 제4호에 따른 시설 관리 업무만 대행하게 할 수 있도록 하고 그 외의 나머지 소방안전관리업무는 소방안전관리자가 직접 수행하도록 하고 있는바, 화재발생 시 초기대응(같은 항 제8호) 등의 소방안전관리업무의 경우에는 관리업자가 이를 대행할 수 없고 '소방안전관리자'와 이를 보조하는 '소방안전관리보조자'가 이를 직접 수행해야 하므로, 이 사안 공동주택의 관리주체가 입주자대표회의의 동의를 받아 관리업자에게 일부 소방안전관리업무를 대행하게 한다고 하더라도 화재예방법 제24조제1항 및 제3항에 따라 소방안전관리대상물의 관계인이 선임해야 하는 소방안전관리자와 소방안전관리보조자를 공동주택관리기구의 기술인력으로 갖추지 않을 수 있다고 보기는 어렵습니다.

그리고 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 제1호나목에서 공동주택관리기구가 관계 법령에 따라 갖추어야 할 기준 인원 이상의 기술자를 갖추도록 한 것은, 전기, 가스 및 소화 설비 등 건축설비의 종류에 따라 유지·보수 및 관리에 전문적인 기술이 요구되어 개별법에서 특정 인력을 선임하도록 규정한 경우 해당 법령에 따른 기준 인원 이상의 인력을 필수적으로 갖추어 공동주택을 전문적이고 안전하게 관리하도록 하려는 취지인바[283], 같은 호에서 규정하고 있는 기술인력의 예외 규정 역시 공동주택을 전문적이고 안전하게 관리하고자 하는 입법목적을 충분히 달성할 수 있는 방향으로 해석해야 할 것인데, 만약 이 사안 공동주택의 관리주체가 입주자대표회의의 동의를 받아 관리업자로 하여금 일부 소방안전관리업무를 대행하게 하는 경우 화재예방법에 따른 소방안전관리자와 소방안전관리보조자를 공동주택 관리기구의 기술인력으로 갖추지 않을 수 있다고 본다면, 관리업자가 대행하지 않는 소방안전관리업무 부분에 대한 기술인력 공백이 발생할 수 있어 그 입법취지에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 제1호에 따라 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자를 공동주택관리기구의 기술인력으로 갖추어야 합니다.

283) 법제처 2020. 10. 6. 회신 20-0420 해석례 참조

법령정비 권고사항

화재예방법 등 개별법령에서 특정 기술인력이 수행하는 업무의 일부만 전문용역업체에 용역할 수 있도록 규정한 경우 그 기술인력을 갖추어야 하는지 여부를 공동주택관리법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



관계법령

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률

제24조(특정소방대상물의 소방안전관리) ① 특정소방대상물 중 전문적인 안전관리가 요구되는 대통령령으로 정하는 특정소방대상물(이하 "소방안전관리대상물"이라 한다)의 관계인은 소방안전관리업무를 수행하기 위하여 제30조제1항에 따른 소방안전관리자 자격증을 발급받은 사람을 소방안전관리자로 선임하여야 한다. 이 경우 소방안전관리자의 업무에 대하여 보조가 필요한 대통령령으로 정하는 소방안전관리대상물의 경우에는 소방안전관리자 외에 소방안전관리보조자를 추가로 선임하여야 한다.

② (생 략)

③ 제1항에도 불구하고 제25조제1항에 따른 소방안전관리대상물의 관계인은 소방안전관리업무를 대행하는 관리업자(「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제29조제1항에 따른 소방시설관리업의 등록을 한 자를 말한다. 이하 "관리업자"라 한다)를 감독할 수 있는 사람을 지정하여 소방안전 관리자로 선임할 수 있다. 이 경우 소방안전관리자로 선임된 자는 선임된 날부터 3개월 이내에 제34조에 따른 교육을 받아야 한다.

④ (생 략)

⑤ 특정소방대상물(소방안전관리대상물은 제외한다)의 관계인과 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 다만, 제1호·제2호·제5호 및 제7호의 업무는 소방안전관리대상물의 경우에만 해당한다.

1. 제36조에 따른 피난계획에 관한 사항과 대통령령으로 정하는 사항이 포함된 소방계획서의 작성 및 시행
2. 자위소방대(自衛消防隊) 및 초기대응체계의 구성, 운영 및 교육
3. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리
4. 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리
5. 제37조에 따른 소방훈련 및 교육
6. 화기(火氣) 취급의 감독
7. 행정안전부령으로 정하는 바에 따른 소방안전관리에 관한 업무수행에 관한 기록·유지(제3호·제4호 및 제6호의 업무를 말한다)
8. 화재발생 시 초기대응

9. 그 밖에 소방안전관리에 필요한 업무
⑥ (생 략)

제25조(소방안전관리업무의 대행) ① 소방안전관리대상물 중 연면적 등이 일정규모 미만인 대통령령으로 정하는 소방안전관리대상물의 관계인은 제24조제1항에도 불구하고 관리업자로 하여금 같은 조 제5항에 따른 소방안전관리업무 중 대통령령으로 정하는 업무를 대행하게 할 수 있다. 이 경우 제24조제3항에 따라 선임된 소방안전관리자는 관리업자의 대행업무 수행을 감독하고 대행업무 외의 소방안전관리업무는 직접 수행하여야 한다.
②·③ (생 략)

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령

제28조(소방안전관리 업무의 대행 대상 및 업무) ① 법 제25조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 소방안전관리대상물"이란 다음 각 호의 소방안전관리대상물을 말한다.
1. 별표 4 제2호가목3)에 따른 지상층의 층수가 11층 이상인 1급 소방안전관리대상물(연면적 1만5천제곱미터 이상인 특정소방대상물과 아파트는 제외한다)
2. 별표 4 제3호에 따른 2급 소방안전관리대상물
3. 별표 4 제4호에 따른 3급 소방안전관리대상물

② 법 제25조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 법 제24조제5항제3호에 따른 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리
2. 법 제24조제5항제4호에 따른 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 관리

공동주택관리법 시행령

제6조(공동주택관리기구의 구성·운영) ① 법 제9조제1항에 따라 공동주택관리기구는 별표 1에 따른 기술인력 및 장비를 갖추어야 한다.
② (생 략)

[별표 1]

공동주택관리기구의 기술인력 및 장비기준(제4조제1항 및 제6조제1항 관련)

구 분	기 준
1. 기술인력	다음 각 호의 기술인력. 다만, 관리주체가 입주자대표회의의 동의를 받아 관리업무의 일부를 해당 법령에서 인정하는 전문용역업체에 용역하는 경우에는 해당 기술인력을 갖추지 않을 수 있다. 가. 승강기가 설치된 공동주택인 경우에는 「승강기 안전관리법 시행령」 제28조에 따른 승강기 자체검사자격을 갖추고 있는 사람 1명 이상 나. 해당 공동주택의 건축설비의 종류 및 규모 등에 따라 「전기안전관리법」, 「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」, 「에너지이용 합리화법」, 「소방기본법」, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 「대기환경보전법」 등 관계 법령에 따라 갖추어야 할 기준 인원 이상의 기술자

2. 장비	가. ~ 다. (생 략)

비고

1. 관리사무소장과 기술인력 상호간에는 겸직할 수 없다.
2. 기술인력 상호간에는 겸직할 수 없다. 다만, 입주자대표회의가 제14조제1항에 따른 방법으로 다음 각 목의 겸직을 허용한 경우에는 그러하지 아니하다.
   가. 해당 법령에서 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격(이하 "국가기술자격"이라 한다)의 취득을 선임요건으로 정하고 있는 기술인력과 국가기술자격을 취득하지 않아도 선임할 수 있는 기술인력의 겸직
   나. 해당 법령에서 국가기술자격을 취득하지 않아도 선임할 수 있는 기술인력 상호간의 겸직

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0541, 24-0607, 24-0608

민원인 – 소하천관리청이 수립한 소하천정비시행계획에 따라 소하천관리청이 직접 소하천에 인공구조물을 설치하려는 경우 소하천 점용허가를 별도로 받아야 하는지 여부(「소하천정비법」 제14조제1항 등 관련)

01 질의요지

「소하천정비법」 제8조제1항 및 제2항에서는 관리청[284]은 소하천등[285] 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획을 수립하여 이를 공고하도록 규정하고 있는 한편, 같은 법 제14조제1항제4호에서는 소하천등(소하천 예정지는 제외함)에서 '그 밖의 인공구조물(이하 "인공구조물"이라 함)의 신축·개축 또는 변경' 행위를 하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 관리청의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있는바,

관리청이 수립·공고한 소하천정비시행계획에 따라 관리청이 직접 소하천에 인공구조물을 신축·개축 또는 변경하려는 경우[286], 「소하천정비법」 제14조제1항제4호에 따라 소하천의 점용허가를 별도로 받아야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 관리청은 소하천 점용허가를 별도로 받지 않아도 됩니다.

03 이유

먼저 「소하천정비법」 제14조제1항 본문에서는 소하천등에서 '다음 각 호의 어느 하나에

284) 「소하천정비법」 제3조제6항에 따라 소하천등의 지정, 정비와 유지관리 업무를 관장하는 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장을 말하며, 이하 같음.

285) 「소하천정비법」 제2조제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 소하천, 소하천구역, 소하천시설 및 같은 법 제4조에 따른 소하천 예정지를 말하며(「소하천정비법」 제3조의2제1항 참조), 이하 같음.

286) 「소하천정비법 시행령」 제11조제1호에 따른 허가 면제 사유 중 '인공구조물을 임시로 설치하는 경우'가 아님을 전제함.

해당하는 행위를 하려는 자'는 관리청의 허가를 받도록 규정하고 있는데, 소하천정비법령에서 '자(者)'라는 용어를 사용한 규정들을 살펴보면, 같은 법 제10조에서는 '관리청이 아닌 자'는 관리청의 허가를 받아 소하천등 정비를 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제18조에서는 관리청은 소하천등 정비를 위하여 필요한 경우(제1호) 등에는 같은 법 제14조에 따른 점용·사용 허가를 받은 자에 대하여 같은 법 제17조에 따른 처분을 하거나 필요한 조치를 명할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제22조제1항에서는 관리청은 같은 법 제14조에 따른 소하천등의 점용·사용 허가를 받은 자로부터 점용료 등을 징수할 수 있다고 규정하고 있는 등 소하천정비법령에서는 관리청을 개별 규정에 따라 이루어지는 행정 처분 등의 주체로, '자'를 그 행정 처분 등을 받는 상대방으로 하여 '관리청'과 '자'를 서로 구분하여 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 같은 법 제14조제1항 본문에서 규정하고 있는 '다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자'에 소하천 점용 등에 대한 허가권자인 '관리청'이 포함되는 것으로 해석하기는 어렵습니다.

그리고 「소하천정비법」 제10조제1항 본문에서는 '관리청이 아닌 자(국가나 지방자치단체를 제외함)'가 소하천등 정비를 할 때 관리청의 허가를 받도록 규정하고 있는 것에 반해, 같은 법 제5조제2항에서는 국가나 지방자치단체가 같은 법에 따라 관리청의 허가를 받아야 하는 행위를 수반하는 사업을 시행하려는 때 미리 관리청과 '협의'하도록 규정하면서, 같은 법 제14조제4항에서는 같은 법 제5조제1항·제2항에 따라 관리청과 미리 협의한 경우에는 그 협의된 범위에서 같은 법 제14조제1항의 허가 관련 규정을 적용하지 않도록 규정하고 있는바, 이는 사업을 수행하는 주체가 국가 또는 지방자치단체인 경우에는 그 사업에 수반되는 행위의 공익적 성격을 고려하여 '협의'라는 별도의 절차를 거치도록 하면서 관리청의 점용허가를 면제하고 있는 것으로 보이고, 이러한 소하천 점용허가와 관련한 절차상의 예외는 사업수행자 또는 계획수립자가 갖는 공익성의 측면에서 인정되는 것인데[287], 관리청이 수립한 소하천정비시행계획에 따라 직접 인공구조물을 신축·개축·변경하는 것도 공익적 목적으로 수행하는 소하천등의 정비사업에 따라 행해진다는 점을 고려하면, 이러한 경우까지 「소하천정비법」 제14조제1항에 따른 소하천 점용허가를 별도로 받아야 하는 사항으로 보아 '국가나 지방자치단체'가 소하천등과 관계된 사업을 시행하는 경우보다 더 엄격한 절차를 거쳐야 한다고 해석하는 것은 소하천정비법령의 규정 체계 및 소하천 점용허가의 예외를 둔 취지에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

또한 소하천의 점용은 소하천에 대한 일반사용과는 달리 소하천의 특정 부분을 유형적·

287) 법제처 2015. 11. 9. 회신 15-0601 해석례 참조

고정적으로 특정한 목적을 위해 사용하는 특별사용을 의미하는 것으로서[288], 소하천 점용허가는 특정인에게 소하천에 대한 공물사용권을 설정[289]하여 주는 처분에 해당하여 「행정절차법」의 적용 대상이 되는데, 「행정절차법」에서는 행정에 관한 의사를 결정하여 표시하는 국가 또는 지방자치단체의 기관 등인 '행정청'(같은 법 제2조제1호)과 행정청의 처분에 대하여 직접 그 상대가 되는 당사자인 '당사자등'(같은 법 제2조제4호)을 구분하여 별도로 정의하고 있고, 같은 법 제9조에서 이러한 행정절차의 '당사자등'이 될 수 있는 자를 자연인(제1호), 법인, 법인이 아닌 사단 또는 재단(제2호), 그 밖에 다른 법령등에 따라 권리·의무의 주체가 될 수 있는 자(제3호)로 규정하고 있는 등 행정절차법령에서 특정 처분의 주체로서의 '행정청'을 해당 처분의 상대가 되는 '당사자등'에 원칙적으로 포함하고 있지 않은 점에 비추어 볼 때에도, 다른 특별한 규정이 없는 한 「소하천정비법」 제14조제1항에 따른 소하천의 점용허가와 관련하여 '행정청'에 해당하는 관리청이 그 허가의 직접 상대방으로서의 '당사자'의 지위까지 가질 수 있다고 해석하기는 어렵습니다.

아울러 행정청의 '처분'이란 특정 사항에 대하여 법규에 의한 권리의 설정 또는 의무의 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 직접 발생하게 되는 등 국민의 권리의무와 관계가 있는 행위를 말하는 것으로, 행정청의 내부적인 의사결정 등과 같이 상대방 또는 관계자들의 법률상 지위에 직접 법률적 변동을 일으키지 않는 행위는 처분에 해당하지 않는데[290], 이 사안과 같이 행위자와 허가권자가 '관리청'으로 동일한 경우라면 그 소하천의 점용에 관한 사항은 관리청 내부의 의사결정 절차로 이루어지게 되는 것이지 점용허가라는 대외적인 효력이 발생하는[291] 처분 절차를 거쳐야 하는 것으로 볼 수 없다는 점, 「소하천정비법」 제14조제1항의 위임에 따라 소하천 점용 등의 허가를 신청하려는 경우에는 같은 법 시행규칙 제10조 및 별지 제11호서식에 따라야 하는데, 같은 서식 신청인란에서는 인적사항으로 '신청인의 성명(법인인 경우는 그 명칭 및 대표자의 성명)'과 '생년월일(법인인 경우 법인등록번호)'을 기재하도록 규정하고 있을 뿐, 관리청을 포함한 국가나 지방자치단체의 행정기관이 '신청자'일 경우까지를 예정하고 있지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 관리청은 소하천 점용허가를 별도로 받지 않아도 됩니다.

---

288) 대법원 1991. 4. 9. 선고 90누8855 판결례 및 대법원 2004. 10. 15. 선고 2002다68485 판결례 참조

289) 대법원 1990. 2. 13. 선고 90누23022 판결례 참조

290) 대법원 2011. 4. 21. 선고 2010무111 전원합의체 판결례 참조

291) 대법원 1967. 11. 21. 선고 67누129 판결례 참조

관계법령

소하천정비법

제3조(소하천의 지정 및 관리청) ① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 "관리청"이라 한다)이 관장한다.

제8조(소하천정비시행계획의 수립) ① 관리청은 중기계획에 따라 소하천등 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획(이하 "시행계획"이라 한다)을 수립하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 소하천등 정비를 시행하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 관리청은 시행계획을 수립한 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ⑥ (생 략)

제14조(소하천등의 점용 등) ① 소하천등(소하천 예정지는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 유수(流水)의 점용
2. 토지의 점용
3. 소하천시설의 점용·신축·개축·변경 또는 제거
4. 그 밖의 인공구조물의 신축·개축 또는 변경
5. 토지의 굴착·성토(盛土) 또는 절토(切土), 그 밖에 토지의 형상 변경
6. 토석(土石)·모래·자갈·죽목(竹木), 그 밖의 소하천등 산출물의 채취
7. 그 밖에 소하천등의 형상과 기능에 지장을 줄 수 있는 행위

② ~ ⑧ (생 략)

질의제목 10 ▶ 안건번호 24-0548

민원인 – 도급계약을 갱신한 경우가 경비업의 허가를 받은 법인이 신고해야 하는 사유 중 하나인 '특수경비업무를 개시하거나 종료한 때'에 해당되는지 여부(「경비업법」 제4조제3항제5호 등 관련)

01 질의요지

「경비업법」 제4조제3항제5호에서는 같은 조 제1항의 규정에 의하여 경비업[292]의 허가를 받은 법인(이하 "경비업자"라 함)이 특수경비업무[293]를 개시하거나 종료한 때에 시·도 경찰청장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제5조제4항에서는 같은 법 제4조제3항제5호의 규정에 의한 특수경비업무의 개시 또는 종료의 신고는 별지 제7호 서식에 의한다고 규정하고 있으며, 같은 서식에 따른 신고서 기재 사항에는 도급내역(도급기간, 도급액, 경비원의 수) 및 경비업무의 기간(개시일, 종료일) 등이 있는바,

특수경비업무를 수행하는 경비업자(이하 "특수경비업자"라 함)가 「경비업법」 제4조제3항제5호에 따라 특수경비업무 개시 신고를 한 후 동일한 시설에 대해 기간의 단절 없이 도급계약이 갱신되는 경우, 특수경비업무 종료 및 개시 신고를 하여야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 특수경비업자는 특수경비업무 종료 및 개시 신고를 하여야 합니다.

03 이유

「경비업법」 제4조제3항제5호에서는 경비업자가 '특수경비업무를 개시하거나 종료한

292) 시설경비업무, 호송경비업무, 신변보호업무, 기계경비업무, 특수경비업무(이하 "경비업무"라 함)의 전부 또는 일부를 도급받아 행하는 영업을 말하며(「경비업법」 제2조제1호 참조), 이하 같음

293) 공항(항공기를 포함함) 등 대통령령이 정하는 국가중요시설의 경비 및 도난·화재 등 위험발생을 방지하는 업무를 말하며(「경비업법」 제2조제1호마목 참조), 이하 같음

때'에 시·도경찰청장에게 신고하여야 한다고 규정하면서, 특수경비업무의 '개시'와 '종료'의 의미에 대해서는 구체적으로 규정하고 있지 않은바, 특수경비업자가 같은 법 제4조제3항제5호에 따라 특수경비업무 개시 신고를 한 후 동일한 시설에 대해 기간의 단절 없이 도급계약이 갱신되는 경우 특수경비업무 종료 및 개시 신고를 하여야 하는지 여부는 경비업법령의 전체적인 체계, 해당 규정의 입법 취지 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 합니다.

먼저 「경비업법」 제2조제1호에 따르면 "경비업"이란 경비업무의 전부 또는 일부를 도급받아 행하는 영업을 말하는 것으로, 특수경비업자는 도급인과의 도급계약에 따라 특수경비업무를 수행하게 되는바, 특수경비업무의 개시 및 종료도 도급계약으로 정한 도급기간 내에서 이루어지게 되므로 특수경비업무의 개시·종료 시기는 도급기간과 사실상 동일하거나 불가분의 관계에 있다고 할 수 있고, 통상적으로 '계약의 갱신'이란 법률관계의 존속 기간이 끝났을 때 그 기간을 연장하는 일을 의미하는데[294], 특수경비업자가 같은 법 제4조제3항제5호에 따라 특수경비업무 개시 신고를 한 후 도급계약이 기간의 단절 없이 갱신되는 경우 당초의 도급기간이 만료되는 동시에 새로운 도급기간이 시작되는 것으로 볼 수 있으므로, 개시 신고를 한 특수경비업무 역시 갱신 전 도급기간의 만료로 '종료'한 뒤 도급계약 갱신으로 다시 '개시'되는 것이라 할 것입니다.

그리고 특수경비제도는 공항 등 국가중요시설에 대한 경비업무의 과학화·전문화 등 경비기술향상을 도모하기 위하여 2001년 4월 7일 법률 제6467호로 전부개정된 「경비업법」 제2조제1호마목으로 경비업무의 유형 중 하나로 '특수경비업무'를 신설하면서 도입된 제도로서,[295] 국가중요시설에 어떤 특수경비업자가 배치되어 근무하고 있는지를 파악할 수 있도록 같은 법 제4조제3항제5호로 특수경비업무의 도급개시·종료 신고 의무를 함께 신설하여 유사 시 시설주와 특수경비업자 및 경찰 간의 유기적인 협조체제를 구축하고 국가중요시설 경비를 효율적으로 지도·감독하려는 것인바,[296] 특수경비업자가 특수경비업무 개시 신고를 한 후 기간의 단절 없이 도급계약이 갱신되었다면 시·도경찰청에서 그 도급계약의 갱신 사실을 알 수 있도록 해당 특수경비업자가 특수경비업무의 개시 및 종료 신고를 해야 한다고 해석하는 것이 입법 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

또한 「경비업법 시행규칙」 제5조제4항에 따르면 「경비업법」 제4조제3항제5호의 규정에 의한 특수경비업무의 개시 또는 종료의 신고는 별지 제7호서식에 의하게 되는데, 같은

294) 국립국어원 표준국어대사전 참조

295) 2001. 4. 7. 법률 제6467호로 전부개정된 「경비업법」 개정이유 참조

296) 2000. 11. 21. 의안번호 제160366호로 발의된 경비업법개정법률안에 대한 국회 행정자치위원회 심사보고서 참조

서식에서 신고서 기재 사항으로 '경비업무를 수행하는 시설명' 및 '도급기간' 등을 포함시켜 해당 특수경비업자가 어떠한 시설에서 언제까지 특수경비업무를 수행하게 되는지를 시·도경찰청장이 미리 파악할 수 있도록 하고 있는바, 특수경비업자가 특수경비업무 개시 신고를 한 후 도급계약이 갱신되었다면 시·도경찰청에서 '새로운 도급기간'을 알 수 있도록 해당 특수경비업자가 이를 신고할 의무가 있다고 보는 것이 경비업법령의 규정 체계에 비추어 볼 때 합리적인 해석입니다.

아울러 공항, 항만, 원자력발전소 등 국가중요시설은 전문적인 인력에 의한 철저한 경비가 요구되고, 특수경비업무를 수행하는 특수경비원[297]은 관할경찰관서장의 사전승인이 있으면 무기(권총 및 소총) 휴대도 가능[298]하여 특수경비업무 전반에 대한 체계적인 관리·감독의 필요성이 크므로 특수경비업무 개시 및 종료 신고를 통해 엄격한 관리가 필요하다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 특수경비업자는 특수경비업무 종료 및 개시 신고를 하여야 합니다.

법령정비 권고사항

특수경비업자가 「경비업법」 제4조제3항제5호에 따라 특수경비업무 개시 신고를 한 후 동일한 시설에 대해 기간의 단절 없이 도급계약이 갱신되는 경우 특수경비업무 종료 및 개시 신고를 하여야 하는지 여부를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

경비업법

제4조(경비업의 허가) ①·② (생 략)

③ 제1항의 규정에 의하여 경비업의 허가를 받은 법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 시·도경찰청장에게 신고하여야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 특수경비업무를 개시하거나 종료한 때

297) 「경비업법」 제2조제3호나목 참조

298) 「경비업법」 제14조 및 같은 법 시행령 제20조 참조

6. (생 략)
④ 제1항 및 제3항의 규정에 의한 허가 또는 신고의 절차, 신고의 기한 등 허가 및 신고에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

경비업법 시행령

제5조(폐업 또는 휴업 등의 신고) ① ~ ④ (생 략)
⑤ 법 제4조제3항제2호부터 제6호까지의 규정에 따른 신고는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

경비업법 시행규칙

제5조(폐업 또는 휴업 등의 신고) ① ~ ③ (생 략)
④ 법 제4조제3항제5호의 규정에 의한 특수경비업무의 개시 또는 종료의 신고는 별지 제7호서식에 의한다.

질의제목 11 ▶ 안건번호 24-0803

소방청 – 소화기를 제조하거나 수입하려는 경우 그 소화기의 형상·구조·재질·성분 여부와 관계없이 형식승인 대상에 해당되는지 여부(「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항 등 관련)

01 질의요지

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 "소방시설법"이라 함) 제37조제1항 본문에서는 대통령령으로 정하는 소방용품을 제조하거나 수입하려는 자는 소방청장의 형식승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제46조에서는 대통령령으로 정하는 소방용품이란 별표 3의 소방용품을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 영 별표 3 제1호가목에서는 소방용품의 종류 중 하나로 같은 영 별표 1 제1호가목의 소화기구를 규정하고 있으며, 같은 영 별표 1 제1호가목1)에서는 소화기구의 종류 중 하나로 '소화기'를 규정하고 있는바,

소방시설법 시행령 별표 1 제1호가목1)에 따른 '소화기'에 해당하는 소방용품을 제조하거나 수입하려는 경우, 그 소화기의 형상·구조·재질·성분 여부와 관계없이 소방시설법 제37조제1항에 따라 형식승인 대상에 해당하는지?[299]

02 회답

소방시설법 시행령 별표 1 제1호가목1)에 따른 '소화기'에 해당하는 소방용품을 제조하거나 수입하려는 경우, 그 소화기의 형상·구조·재질·성분 여부와 관계없이 소방시설법 제37조제1항에 따라 형식승인 대상에 해당합니다.

299) 소방시설법 제37조제1항 단서에 따라 형식승인 대상에서 제외되는 '연구개발 목적으로 제조하거나 수입하는 소방용품'이 아님을 전제로 함

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것[300]인바, 소방시설법 제37조제1항 본문에서는 대통령령으로 정하는 소방용품을 제조하거나 수입하려는 자는 소방청장의 형식승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제46조 및 별표 3에서는 형식승인의 대상이 되는 소방용품의 종류를 규정하면서, 같은 표 제1호가목에서는 같은 영 별표 1 제1호가목의 '소화기구'를 규정하고 있으며, 같은 영 별표 1 제1호가목1)에서는 '소화기구'의 종류 중 하나로 '소화기'를 규정하고 있는바, 문언상 '소화기'는 형식승인의 대상이 되는 소방용품에 해당한다고 할 것이고, 소화기를 연구개발 목적으로 제조하거나 수입하는 경우[301] 외에는 소방시설법령에서 소화기의 형상·구조·재질·성분 여부에 따라 형식승인 대상으로 적용하지 않을 수 있도록 하는 명시적인 예외규정을 두고 있지도 않으므로, '소화기'라면 그 형상·구조·재질·성분 여부와 관계없이 형식승인 대상 소방용품에 해당되어 그 '소화기'를 제조하거나 수입하려는 자는 소방청장의 형식승인을 받아야 할 것입니다.

그리고 소방시설법은 소방용품 성능관리에 필요한 사항 등을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전과 복리 증진에 이바지함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제37조에 따른 형식승인 제도는 1997년 3월 7일 법률 제5294호로 일부개정된 「소방법」에서 소방용품 제조업에 대한 허가제 및 방염처리업에 대한 면허제를 폐지하면서 소방안전에 필요한 규제를 보완하기 위하여 도입되어 현재까지 유지되어 온 소방용품 품질관리제도의 하나로, 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 안전기기인 소방용품이 유사시에 그 성능이 제대로 발휘될 수 있도록 하기 위하여 제품의 제조 및 수입 단계에서부터 안전성 및 기능성이 확보되도록 하려는 취지[302]인바, 특정 물품이 소방시설법령상의 소방용품으로 분류되는 '소화기'에 해당한다면, 그 형상·구조·재질·성분 여부와 관계없이 형식승인 대상으로 보아 해당 소화기의 안전성 및 기능성을 제조 및 수입 단계에서부터 충분히 확보하여 국민의 생명 및 재산이 최대한 보호될 수 있도록 하는 것이 소방용품에 대한 형식승인 제도를 두고 있는 소방시설법령의 입법 취지에 부합합니다.

---

300) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

301) 소방시설법 제37조제1항 단서 참조

302) 법제처 2010. 11. 5. 회신 10-0315 해석례 참조

또한 소방시설법 제37조제5항에서는 소방용품의 형상·구조·재질·성분·성능 등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 등에 필요한 사항은 소방청장이 정하여 고시한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」[303] 제2조제1호에서는 '소화기'를 물이나 소화약제를 압력에 의하여 방사하는 기구로서 사람이 조작하여 소화하는 것을 말한다고 정의하고 있어, 형상·구조·재질 등을 '소화기'에 해당하는지 여부를 판단하는 기준으로 삼고 있지 않은 점, 같은 고시에서 소화기로서 형식승인을 받기 위하여 갖추어야 할 구체적인 기술기준으로 정하고 있는 일반 구조(제3조), 능력 단위(제4조), 조작기구(제6조), 소화약제(제8조), 소화기 본체용기(제11조), 안전장치(제22조) 등의 규정에서도 소화기마다 그 형상·구조·재질·성분 등의 차이가 있을 수 있다는 전제하에 특정 소화기가 갖는 형상·구조·재질·성분 등이 소방청장이 정한 기술기준에 적합한지를 확인·평가하도록 규정하고 있는 점에 비추어 보면, 특정 소화기의 형상·구조· 재질·성분 여부에 따라 형식승인 기술기준 적합여부에 대한 확인방법이나 그 평가결과 등이 달라질 수는 있으나, 형식승인을 받아야 하는 소화기의 대상 범위 자체가 달라질 수 있다고 보기는 어렵습니다.

아울러 소방시설법 제37조제8항에서는 소방청장은 소방용품의 작동기능, 제조방법, 부품 등이 같은 조 제5항에 따라 소방청장이 고시하는 형식승인 및 제품검사의 기술기준에서 정하고 있는 방법이 아닌 새로운 기술이 적용된 제품의 경우에는 관련 전문가의 평가를 거쳐 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 같은 조 제4항에 따른 방법 및 절차와 다른 방법 및 절차로 형식승인을 할 수 있으며, 외국의 공인기관으로부터 인정받은 신기술 제품은 형식승인을 위한 시험 중 일부를 생략하여 형식승인을 할 수 있다고 규정하고 있는 등 신기술이 적용된 소화기의 형상·구조·재질·성분이 기존의 소화기와 달라 현행 소방시설법령에서 정하고 있는 기술기준으로 형식승인이 어려운 경우에도 행정안전부령으로 정하는 다른 방법 및 절차를 거쳐 형식승인을 할 수 있도록 특례를 규정하고 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 소방시설법 시행령 별표 1 제1호가목1)에 따른 '소화기'에 해당하는 소방용품을 제조하거나 수입하려는 경우, 그 소화기의 형상·구조·재질·성분 여부와 관계없이 같은 법 제37조제1항에 따라 형식승인 대상에 해당합니다.

303) 소방청고시 제2024-39호

관계법령

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률

제37조(소방용품의 형식승인 등) ① 대통령령으로 정하는 소방용품을 제조하거나 수입하려는 자는 소방청장의 형식승인을 받아야 한다. 다만, 연구개발 목적으로 제조하거나 수입하는 소방용품은 그러하지 아니하다.

②·③ (생 략)

④ 제1항에 따른 형식승인의 방법·절차 등과 제3항에 따른 제품검사의 구분·방법·순서·합격표시 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

⑤ 소방용품의 형상·구조·재질·성분·성능 등(이하 "형상등"이라 한다)의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 등에 필요한 사항은 소방청장이 정하여 고시한다.

⑥ 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소방용품을 판매하거나 판매 목적으로 진열하거나 소방시설공사에 사용할 수 없다.

1. 형식승인을 받지 아니한 것

2.·3. (생 략)

⑦ 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장은 제6항을 위반한 소방용품에 대하여는 그 제조자·수입자·판매자 또는 시공자에게 수거·폐기 또는 교체 등 행정안전부령으로 정하는 필요한 조치를 명할 수 있다.

⑧ 소방청장은 소방용품의 작동기능, 제조방법, 부품 등이 제5항에 따라 소방청장이 고시하는 형식승인 및 제품검사의 기술기준에서 정하고 있는 방법이 아닌 새로운 기술이 적용된 제품의 경우에는 관련 전문가의 평가를 거쳐 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 제4항에 따른 방법 및 절차와 다른 방법 및 절차로 형식승인을 할 수 있으며, 외국의 공인기관으로부터 인정받은 신기술 제품은 형식승인을 위한 시험 중 일부를 생략하여 형식승인을 할 수 있다.

⑨ ~ ⑪ (생 략)

소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령

제3조(소방시설) 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 별표 1의 설비를 말한다.

제46조(형식승인 대상 소방용품) 법 제37조제1항 본문에서 "대통령령으로 정하는 소방용품"이란 별표 3의 소방용품(같은 표 제1호나목의 자동소화장치 중 상업용 주방자동소화장치는 제외한다)을 말한다.

[별표 1]

소방시설(제3조 관련)

1. 소화설비: 물 또는 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화하는 기계·기구 또는 설비로서 다음 각 목의 것
   가. 소화기구
      1) 소화기
      2) 간이소화용구: 에어로졸식 소화용구, 투척용 소화용구, 소공간용 소화용구 및 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구
      3) 자동확산소화기
   나 ~ 바. (생 략)
2. ~ 5. (생 략)

[별표 3]

소방용품(제6조 관련)

1. 소화설비를 구성하는 제품 또는 기기
   가. 별표 1 제1호가목의 소화기구(소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구는 제외한다)
   나. 별표 1 제1호나목의 자동소화장치
   다. 소화설비를 구성하는 소화전, 관창(菅槍), 소방호스, 스프링클러헤드, 기동용 수압개폐장치, 유수제어밸브 및 가스관선택밸브
2. ~ 5. (생 략)

질의제목 12 ▶ 안건번호 24-0903

민원인 - 「청원경찰법」 제10조의6제3호단서에 따른 청원경찰의 당연 퇴직 시점(「청원경찰법」 제10조의6제3호 등 관련)

01 질의요지

「청원경찰법」 제10조의6 각 호 외의 부분에서는 청원경찰이 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 당연 퇴직된다고 규정하고 있고, 같은 조 제3호 본문에서는 "나이가 60세가 되었을 때[304]"를 규정하면서, 같은 호 단서에서는 "다만, 그 날이 1월부터 6월 사이에 있으면 6월 30일에, 7월부터 12월 사이에 있으면 12월 31일에 각각 당연 퇴직된다"고 규정하고 있는바,

「청원경찰법」 제10조의6제3호 단서에 따른 "그 날"은 60세가 되는 해의 생일을 의미하는지 아니면 61세가 되는 해의 생일의 전날을 의미하는 것인지?

02 회답

「청원경찰법」 제10조의6제3호 단서에 따른 "그 날"은 60세가 되는 해의 생일을 의미합니다.

03 이유

「청원경찰법」 제10조의6에서는 청원경찰이 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 당연 퇴직된다고 규정하고 있고, 같은 조 제3호 본문에서는 "나이가 60세가 되었을 때"를 규정하고 있으며, 같은 호에 단서를 두어 "다만, 그 날이 1월부터 6월 사이에 있으면 6월 30일에, 7월부터 12월 사이에 있으면 12월 31일에 각각 당연 퇴직된다"고 규정하고 있어,

304) 「청원경찰법」에서 나이에 관하여 특별한 규정을 두고 있지 않으므로, 「행정기본법」 제7조의2에 따라 만 나이로 계산함

청원경찰은 "나이가 60세가 된 날"에 따라 당연 퇴직일이 결정되는바, 이 사안에서는 「청원경찰법」 제10조의6제3호에 따른 나이가 60세가 된 날이 60세가 되는 해의 생일을 의미하는 것인지, 아니면 61세가 되는 해의 생일의 전날을 의미하는 것인지가 문제됩니다.

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것[305]인데, 「청원경찰법」 제10조의6제3호에서 청원경찰은 나이가 60세가 되었을 때에 당연 퇴직된다고 규정하고 있고, 「행정기본법」 제7조의2에서는 행정에 관한 나이 계산을 "만(滿) 나이"로 계산하도록 일반 원칙과 기준을 명확하게 규정하고 있는바, 연령은 출생일부터 현재까지 살아온 기간으로서 매년 생일을 기준으로 1년 단위로 산정[306]되는 것이므로 60세는 60번째 생일을 기준으로 하여 산정하게 되는 것이고, "되었을 때"란 어떤 때나 시기, 상태에 이르렀다[307]는 것을 의미하는 것인바, 나이가 60세가 된 날은 60세가 되는 해의 생일을 의미하는 것이 문언상 분명합니다.

그리고 종전에는 청원경찰의 당연 퇴직 연령을 "59세에 달한 때"로 규정하던 것을 구 청원경찰법(2010년 2월 4일 법률 제10013호로 일부개정된 것을 말함)에서 "60세가 되었을 때"로 개정하여 청원경찰의 당연 퇴직연령을 59세에서 60세로 상향 조정하면서, 어려운 한자어 투의 표현인 "달한 때"를 쉬운 우리말인 "되었을 때"로 함께 정비하였는데, "달한 때"나 "되었을 때" 모두 일정한 정도에 이르다는 것을 의미[308]하는 것이고, 개정의 취지가 당연 퇴직연령을 59세에서 60세로 상향 조정하려는 것일 뿐 당연 퇴직연령의 산정 방식에 관하여 종전과 달리 규정하려는 취지로 보기는 어려운바, "나이가 60세가 된 날"은 60세가 되는 해의 생일을 의미[309]하는 것으로 해석해야 할 것입니다.

따라서 「청원경찰법」 제10조의6제3호 단서에 따른 "그 날"은 60세가 되는 해의 생일을 의미합니다.

---

305) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
306) 법제처 2006. 1. 27. 회신 05-0157 해석례 참조
307) 국립국어원 표준국어대사전 참조
308) 국립국어원 표준국어대사전 참조
309) 법제처 2006. 1. 27. 회신 05-0157 해석례 참조

관계법령

청원경찰법

제10조의6(당연 퇴직) 청원경찰이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 당연 퇴직된다.

1. 제5조제2항에 따른 임용결격사유에 해당될 때. 다만, 「국가공무원법」 제33조제2호는 파산선고를 받은 사람으로서 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 신청기한 내에 면책신청을 하지 아니하였거나 면책불허가 결정 또는 면책 취소가 확정된 경우만 해당하고, 「국가공무원법」 제33조제5호는 「형법」 제129조부터 제132조까지, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조, 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호 및 직무와 관련하여 「형법」 제355조 또는 제356조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당한다.
2. 제10조의5에 따라 청원경찰의 배치가 폐지되었을 때
3. 나이가 60세가 되었을 때. 다만, 그 날이 1월부터 6월 사이에 있으면 6월 30일에, 7월부터 12월 사이에 있으면 12월 31일에 각각 당연 퇴직된다.

CHAPTER

06

농림축산·산림·해양수산

제1절 농림축산
제2절 산림
제3절 해양수산

제1절 농림축산

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-1022

민원인 – 농업진흥지역 등이 아닌 농림지역에 설치된 농어업인 주택으로 「농어촌정비법」 제2조 제16호라목에 따른 농어촌민박사업을 경영할 수 있는지 여부(「농어촌정비법」 제86조 등 관련)

01 질의요지

「농어촌정비법」 제86조제2항에서는 농어촌민박사업을 경영하려는 자는 신고자가 거주하는 「건축법」 제2조제2항제1호에 따른 단독주택(제3호), 신고자가 직접 소유하고 있는 단독주택(제4호) 등의 요건을 모두 갖추어야 한다고 규정하고 있는 한편,

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함)제76조제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제71조제1항제20호 및 별표 21에서는 용도지역 중 농림지역[1] 안에서 건축할 수 있는 건축물을 규정하면서 같은 표 제1호가목에서 '「건축법 시행령」 별표 1 제1호의 단독주택으로서 현저한 자연훼손을 가져오지 아니하는 범위 안에서 건축하는 농어가주택(「농지법」 제32조제1항제3호에 따른 농업인 주택 및 어업인 주택을 말하며, 이하 같음)'을 규정하고 있는바,

'「농지법」에 따른 농업진흥지역, 「산지관리법」에 따른 보전산지 또는 「초지법」에 따른 초지'가 아닌 농림지역(이하 "농업진흥지역등이 아닌 농림지역"이라 함)에 설치된 「농지법」 제32조제1항제3호에 따른 농업인 주택 및 어업인 주택(이하 "농어업인 주택"이라 함)의 일부를 활용하여 「농어촌정비법」 제2조제16호라목에 따른 농어촌민박사업(이하 "농어촌민박사업"이라 함)을 경영[2]할 수 있는지?[3]

---

1) 국토계획법 제6조제3호에 따른 농림지역을 말하며, 이하 같음.

2) 「농지법 시행령」 제29조제4항 각 호에 따른 농어업인 주택의 요건 및 「농어촌정비법」 제86조제2항 각 호에 따른 농어촌민박사업을 경영하려는 자가 갖추어야 하는 요건을 계속 갖춘 채 경영하는 것을 전제로 함.

02 회답

이 사안의 경우, 농업진흥지역등이 아닌 농림지역에 설치된 농어업인 주택의 일부를 활용하여 농어촌민박사업을 경영할 수 있습니다.

03 이유

규제의 대상 등은 그 근거가 되는 법령에 구체적이고 명확하게 규정되어야 하고 법률에 근거하지 아니한 규제로 국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과할 수 없다고 할 것입니다.[4)]

그런데 국토계획법 제76조에서는 용도지역에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한에 관한 사항은 대통령령으로 정하도록 하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제71조제1항제20호 및 별표 21에서는 농림지역 안에서 건축이 가능한 건축물 중 하나로 '「건축법 시행령」 별표 1 제1호의 단독주택으로서 현저한 자연훼손을 가져오지 아니하는 범위 안에서 건축하는 농어가주택'을 규정하면서, 그 농어가주택을 '「농지법」 제32조제1항제3호에 따른 농어업인 주택'으로 규정하고 있는바, 농림지역 안에서 「농지법」 제32조제1항제3호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제29조제4항 각 호의 요건을 모두 갖추어 건축된 농어업인 주택이라면 농림지역의 용도에 적합한 건축행위를 한 것이고, 국토계획법령에서는 이와 같이 농림지역 안에 적법하게 건축된 농어업인 주택의 요건과 용도를 계속 유지하면서 그 일부를 이용하여 추가로 「농어촌정비법」에 따라 농어촌민박사업을 경영하는 것을 금지하는 등의 행위제한에 관한 규정을 두고 있지 않습니다.

그리고 「농어촌정비법」에 따른 농어촌민박사업은 농어촌지역 또는 준농어촌지역의 주민이 소유 및 거주하고 있는 주택을 이용하여 농어촌 소득을 늘릴 목적으로 투숙객에게 숙박·취사시설·조식 등을 제공하는 사업(제2조제16호라목)으로서, 같은 법 제86조제2항에서는 농어촌민박사업을 경영하려는 자가 갖추어야 하는 요건으로 농어촌지역 또는 준농어촌지역의 주민일 것(제1호), 농어촌지역 또는 준농어촌지역의 관할 시·군·구에 6개월 이상 계속하여 거주하고 있을 것[5)](제2호), 신고자가 거주하는 「건축법」 제2조제2항제1호에 따른 단독

3) 「농지법」, 「산지관리법」, 「초지법」, 국토계획법을 제외한 다른 법령에 농어촌민박사업에 관한 제한이 없는 것을 전제함.
4) 「행정규제기본법」 제4조 참조
5) 농어촌민박사업에 이용되고 있는 주택을 상속받은 자는 제외함.

주택(제3호), 신고자가 직접 소유하고 있는 단독주택(제4호)을 규정하고 있을 뿐, 같은 법 제86조제2항제3호 및 제4호에 따른 단독주택의 범위에서 '농어업인 주택'을 명시적으로 배제하고 있지 않은바, 농업진흥지역등이 아닌 농림지역에 설치된 농어업인 주택으로서, 농지법령에 따른 농어업인 주택으로서의 요건을 갖춘 주택의 일부만을 이용하여 농어촌민박사업을 경영하는 것이 국토계획법령, 농지법령 또는 농어촌정비법령에 따라 금지된다고 보기는 어렵습니다.

또한 「농어촌정비법」은 농업생산기반, 농어촌 생활환경, 농어촌 관광휴양자원 및 한계농지 등을 종합적·체계적으로 정비·개발하여 농수산업의 경쟁력을 높이고 농어촌 생활환경 개선을 촉진함으로써 환경친화적이고 현대적인 농어촌 건설과 국가의 균형발전에 이바지하는 것을 목적(제1조)으로 제정된 법률로서, 같은 법 제2조제16호라목에서는 농어촌민박사업을 '농어촌 또는 준농어촌 지역의 주민이 소유 및 거주하고 있는 주택을 이용'하여 농어촌 소득을 늘릴 목적으로 투숙객에게 숙박 등을 제공하는 것으로 정의하고 있는 점에 비추어볼 때, 농업진흥지역등이 아닌 농림지역에 적법하게 설치된 농어업인 주택의 일부를 이용하여 농지법령에 따른 농어업인 주택으로서의 요건을 유지하면서 농어촌민박사업을 하는 것이 그 제도의 취지에 반한다거나, 농어업인의 주거생활 영위를 위해 설치하는 농어업인 주택의 본래 목적에 반드시 배치된다고 볼 수는 없다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 농업진흥지역등이 아닌 농림지역에 설치된 농어업인 주택의 일부를 활용하여 농어촌민박사업을 경영할 수 있습니다.

관계법령

농어촌정비법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같아.

1. ~ 15. (생 략)

16. "농어촌 관광휴양사업"이란 다음 각 목의 사업을 말한다.

가. ~ 다. (생 략)

라. 농어촌민박사업: 농어촌지역 또는 준농어촌지역의 주민이 소유 및 거주하고 있는 주택을 이용하여 농어촌 소득을 늘릴 목적으로 투숙객에게 숙박·취사시설·조식 등을 제공하는 사업

17.·18. (생 략)

제86조(농어촌민박사업자의 신고) ① (생 략)

② 농어촌민박사업을 경영하려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 농어촌지역 또는 준농어촌지역의 주민일 것
2. 농어촌지역 또는 준농어촌지역의 관할 시·군·구에 6개월 이상 계속하여 거주하고 있을 것(농어촌민박사업에 이용되고 있는 주택을 상속받은 자는 제외한다)
3. 신고자가 거주하는 「건축법」 제2조제2항제1호에 따른 단독주택(같은 법 시행령 별표 1에 따른 단독주택과 다가구주택을 말한다. 이하 같다)
4. 신고자가 직접 소유하고 있는 단독주택

③ ~ ⑨ (생 략)

농지법 시행령

제29조(농업진흥구역에서 할 수 있는 행위) ① ~ ③ (생 략)

④ 법 제32조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 농업인 주택, 어업인 주택"이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 건축물 및 시설물을 말한다. (단서 생략)

1. 농업인 또는 어업인(「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제3호에 따른 어업인을 말한다. 이하 같다) 1명 이상으로 구성되는 농업·임업·축산업 또는 어업을 영위하는 세대로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 세대의 세대주가 설치하는 것일 것
   가. 해당 세대의 농업·임업·축산업 또는 어업에 따른 수입액이 연간 총수입액의 2분의 1을 초과하는 세대
   나. 해당 세대원의 노동력의 2분의 1 이상으로 농업·임업·축산업 또는 어업을 영위하는 세대
2. 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 세대의 세대원이 장기간 독립된 주거생활을 영위할 수 있는 구조로 된 건축물(「지방세법 시행령」 제28조에 따른 별장 또는 고급주택을 제외한다) 및 해당 건축물에 부속한 창고·축사 등 농업·임업·축산업 또는 어업을 영위하는데 필요한 시설로서 그 부지의 총면적이 1세대 당 660제곱미터 이하일 것
3. 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 세대의 농업·임업·축산업 또는 어업의 경영의 근거가 되는 농지·산림·축사 또는 어장 등이 있는 시(구를 두지 아니한 시를 말하며, 도농복합형태의 시에 있어서는 동지역에 한한다)·구(도농복합형태의 시의 구에 있어서는 동지역에 한한다)·읍·면(이하 "시·구·읍·면"이라 한다) 또는 이에 연접한 시·구·읍·면 지역에 설치하는 것일 것

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령

제71조(용도지역안에서의 건축제한) ①법 제76조제1항에 따른 용도지역안에서의 건축물의 용도·종류 및 규모 등의 제한(이하 "건축제한"이라 한다)은 다음 각호와 같다.

1. ~ 19. (생 략)
20. 농림지역안에서 건축할 수 있는 건축물 : 별표 21에 규정된 건축물
21. (생 략)

②·③ (생 략)

[별표 21]

농림지역안에서 건축할 수 있는 건축물(제71조제1항제20호관련)

1. 건축할 수 있는 건축물
   가. 「건축법 시행령」 별표 1 제1호의 단독주택으로서 현저한 자연훼손을 가져오지 아니하는 범위 안에서 건축하는 농어가주택(「농지법」 제32조제1항제3호에 따른 농업인 주택 및 어업인 주택을 말한다. 이하 같다)
   나. 「건축법 시행령」 별표 1 제3호사목(공중화장실, 대피소, 그 밖에 이와 비슷한 것만 해당한다) 및 아목에 따른 제1종 근린생활시설
   다. ~ 바. (생 략)
2. 도시·군계획조례가 정하는 바에 의하여 건축할 수 있는 건축물
   가. ~ 거. (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-1083

민원인 - 농지 소유자의 배우자가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우에도 농지 소유자가 소유하고 있는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 있는지 여부(「농지법 시행령」 제24조제1항제5호 등)

01 질의요지

「농지법」 제23조제1항 각 호 외의 부분에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 항 제3호에서는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 있는 경우의 하나로 '질병, 징집, 취학, 선거에 따른 공직취임, 그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 인하여 일시적으로 농업경영에 종사하지 아니하게 된 자가 소유하고 있는 농지를 임대하거나 무상사용하게 하는 경우'를 규정하고 있으며, 같은 호의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제24조제1항제5호에서는 '임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우'를 「농지법」 제23조제1항제3호의 "그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유"로 규정하고 있는바,

'농지 소유자의 배우자[6]'가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우에도 「농지법」 제23조제1항제3호 및 같은 법 시행령 제24조제1항제5호에 따라 농지 소유자가 소유하고 있는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 있는지?[7]

02 회답

'농지 소유자의 배우자'가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우에는 「농지법」 제23조제1항제3호 및 같은 법 시행령 제24조제1항제5호에 따라 농지 소유자가 소유하고 있는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 없습니다.

---

6) 농지 소유자가 아님을 전제함.

7) '농지 소유자의 배우자'가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만이라는 점 외에 해당 농지의 소유자에게 「농지법」 제23조제1항제3호에 따른 질병, 징집, 취학, 선거에 따른 공직취임, 그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 없는 경우를 전제함.

03 이유

먼저 「농지법」 제6조에 따르면 농지는 원칙적으로 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못하는 한편, 같은 법 제23조제1항제3호에서는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 있는 경우 중 하나로 '질병, 징집, 취학, 선거에 따른 공직취임, 그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유'로 인하여 일시적으로 농업경영에 종사하지 아니하게 된 자가 소유하고 있는 농지를 임대하거나 무상사용하게 하는 경우를 규정하고 있는데, 이 때 농지 소유자가 농업경영에 종사하지 아니하게 되는 사유로 열거하고 있는 '질병, 징집, 취학, 선거에 따른 공직취임'은 모두 해당 농지 소유자 본인에게 발생한 사유를 의미한다고 할 것인바, '그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유'도 특별한 규정이 없는 한 농지 소유자 본인에게 발생한 사유로 한정된다고 보아야 할 것입니다.

그런데 「농지법 시행령」 제24조제1항제5호에서는 「농지법」 제23조제1항제3호의 "그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유"를 "임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우"로 규정하고 있을 뿐, '농지 소유자의 배우자'가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우도 포함되는 것으로 규정하고 있지 않은바, '농지 소유자의 배우자'가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우는 「농지법」 제23조제1항제3호 및 같은 법 시행령 제24조제1항제5호에 포함되지 않는다고 보는 것이 그 문언 및 체계에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

그리고 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것이고[8], 「농지법」에서는 농지는 공공복리에 적합하게 관리되어야 하고 농지에 관한 권리의 행사에는 필요한 제한과 의무가 따르며 농지는 농업 생산성을 높이는 방향으로 소유·이용되어야 하고 투기의 대상이 되어서는 안 된다는 것을 기본 이념(제3조)으로 규정하면서, 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 원칙적으로 농지를 소유하지 못하도록 하고(제6조), 농지의 임대나 무상사용도 원칙적으로 금지(제23조)하는 등 농지가 농업경영 목적 외로 사용되지 않도록 엄격히 제한하고 있는바[9], 농지의 임대 및 무상사용 금지 원칙에 대한 예외 사유에 해당하는 같은 법 시행령 제24조제1항제5호에 '농지 소유자' 본인이 아닌 그 배우자가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우까지 포함되는 것으로 확장해석하는 것은 예외규정의 엄격해석 원칙 및 「농지법」의 기본이념에 비추어 타당하지 않습니다.

---

8) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 및 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조

9) 1994. 11. 1. 의안번호 제140850호로 발의된 농지법 제정안 국회 농림수산위원회 심사보고서 참조

더욱이 「농지법 시행령」 제24조제1항제5호는 2020년 8월 11일 대통령령 제30925호로 구 「농지법 시행령」이 일부개정될 당시 신설된 규정으로, 개정 당시 입법자료에서는 「농지법 시행령」 제24조제1항제5호를 '모자건강의 보호'를 위해 '농지 소유자'가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우에는 예외적으로 농지의 임대·무상사용을 허용하기 위한 것임을 명시[10]하고 있는바, 같은 호는 '농지 소유자 본인'과 그 자녀의 건강 보호를 위해 '임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 농지 소유자 본인'이 일시적으로 농업경영에 종사하지 아니할 수 있도록 하기 위한 규정으로서, 농지 소유자의 배우자가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우는 같은 호에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 그 입법취지에 부합합니다.

따라서 '농지 소유자의 배우자'가 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우에는 「농지법」 제23조제1항제3호 및 같은 법 시행령 제24조제1항제5호에 따라 농지 소유자가 소유하고 있는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 없습니다.

관계법령

농지법

제23조(농지의 임대차 또는 사용대차) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 없다.

1.·2. (생 략)

3. 질병, 징집, 취학, 선거에 따른 공직취임, 그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유로 인하여 일시적으로 농업경영에 종사하지 아니하게 된 자가 소유하고 있는 농지를 임대하거나 무상사용하게 하는 경우

4. ~ 9. (생 략)

②·③ (생 략)

농지법 시행령

제24조(농지의 임대차 또는 사용대차) ① 법 제23조제1항제3호에서 "그 밖에 대통령령으로 정하는 부득이한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 임신 중이거나 분만 후 6개월 미만인 경우

②·③ (생 략)

10) 2020. 8. 11. 대통령령 제30925호로 일부개정된 농지법 시행령 일부개정령 개정이유 참조

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0247

민원인 – 「농지법 시행령」 제28조제1항제1호다목 후단의 '농업진흥지역 안의 토지의 면적'은 해제하려는 농업진흥지역 안의 농지의 면적 뿐만 아니라 농지가 아닌 토지의 면적도 포함하여 산정해야 하는지 여부(「농지법 시행령」 제28조제1항 등 관련)

01 질의요지

「농지법」 제31조제1항 본문에서는 시·도지사[11]는 대통령령으로 정하는 사유가 있으면 농업진흥지역[12] 또는 용도구역을 변경하거나 해제할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제28조제1항제1호다목에서는 농업진흥지역을 해제할 수 있는 경우의 하나로 "해당 지역의 여건변화로 농업진흥지역의 지정요건에 적합하지 않게 된 경우"를 규정(전단)하면서, "이 경우 그 농업진흥지역 안의 토지의 면적이 3만제곱미터 이하인 경우로 한정한다"고 규정(후단)하고 있는바,

「농지법 시행령」 제28조제1항제1호다목 후단에 따라 '농업진흥지역 안의 토지의 면적'이 3만제곱미터 이하인지를 판단하는 경우, 해제하려는 농업진흥지역 안의 농지[13]의 면적뿐만 아니라 농지가 아닌 토지의 면적도 포함하여 산정해야 하는지?

02 회답

「농지법 시행령」 제28조제1항제1호다목 후단에 따라 '농업진흥지역 안의 토지의 면적'이 3만제곱미터 이하인지를 판단하는 경우, 해제하려는 농업진흥지역 안의 농지의 면적뿐만 아니라 농지가 아닌 토지의 면적도 포함하여 산정해야 합니다.

---

11) 특별시장·광역시장 또는 도지사를 말하며(「농지법」 제14조제3항 참조), 이하 같음.

12) 「농지법」 제28조제1항에 따른 농업진흥지역를 말하며, 이하 같음.

13) 「농지법」 제2조제1항에 따른 농지를 말하며, 이하 같음.

03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미를 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[14], 「농지법」 제2조에서는 같은 법에서 사용하는 용어의 뜻을 규정하면서, 제1호에서 "농지"를 '같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 토지'를 말한다고 정의하고 있는 점을 고려하면, 농지법령에 규정된 "농지"와 "토지"는 서로 구분되는 개념이라 할 것인바, 같은 법 시행령 제28조제1항다목 후단에서 같은 목 전단에 따라 농업진흥지역을 해제할 수 있는 경우를 농업진흥지역 안의 '농지'의 면적이 아닌, '토지'의 면적이 3만제곱미터 이하인 경우로 규정하고 있는 이상, 같은 목 후단의 요건을 충족하기 위해서는 해제하려는 농업진흥지역 안의 전체 토지 중 농지에 해당하는 토지의 면적뿐만 아니라 농지가 아닌 토지의 면적도 포함하여 3만제곱미터 이하여야 한다는 점은 그 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 「농지법」은 농지를 효율적으로 이용하고 관리하여 농업인의 경영 안정과 농업 생산성 향상을 바탕으로 농업 경쟁력을 강화하고 국토 환경 보전에 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제28조제1항에서는 농지를 효율적으로 이용·보전함으로써 농업의 생산성을 향상시키기 위해[15] 농업진흥지역을 지정한다고 규정하고 있고, 같은 법 제32조제1항 및 제2항에서는 농업진흥지역의 농업진흥구역과 농업보호구역 내 '토지이용행위'를 엄격하게 규제하고 있으며, 같은 법 제31조제1항 단서에서는 농업진흥지역의 변경 또는 해제의 사유가 없어진 경우에는 원래의 농업진흥지역으로 환원해야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 「농지법」의 입법목적, 농업진흥지역 지정취지와 해제사유가 소멸된 농업진흥지역의 환원 규정에 비추어 볼 때, 같은 법 시행령 제28조제1항제1호에서 규정하고 있는 농업진흥지역의 해제 사유는 엄격하게 해석해야 할 것[16]이므로, 농업진흥지역의 해제 사유로서 면적에 관한 요건인 "농업진흥지역 안의 토지의 면적이 3만제곱미터 이하인 경우"를 그 문언의 범위를 벗어나 농업진흥지역 안의 전체 토지의 면적이 아닌, 그 중 농지에 해당하는 토지의 면적이 3만제곱미터 이하인 경우로 한정하여 해석함으로써, 「농지법 시행령」 제28조제1항제1호다목에 따라 해제될 수 있는 농업진흥지역의 범위를 확대하는 것은 타당하지 않습니다.

---

14) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

15) 1990. 4. 7. 법률 제4228호로 제정되어 같은 날 시행된 「농어촌발전특별조치법」 제정이유 참조

16) 법제처 2022. 3. 18. 회신 21-0829 해석례 참조

또한 「농지법 시행령」 제28조제5항의 위임에 따라 농업진흥지역의 지정·변경·해제에 필요한 세부 기준 및 절차 등을 규정하고 있는 「농업진흥지역관리규정」(농림축산식품부훈령 제504호) 제10조제2항 단서 및 별표 6에서는 「농지법 시행령」 제28조제1항제1호다목에 따른 농업진흥지역 해제 승인요청 시 작성하는 '토지조서'는 '토지의 지목에 상관없이 농업진흥지역 구획선 안의 모든 토지'를 대상으로 작성하도록 규정하고 있고, '농업진흥지역 해제승인 요청서'의 토지편입현황의 경우에도 '농지'와 '비농지'를 더하여 합계를 산정하도록 규정하고 있는바, 「농지법 시행령」 제28조제1항제1호다목 후단의 '농업진흥지역 안의 토지의 면적'은 해제하려는 농업진흥지역 구획선 안에 위치한 모든 토지, 즉 농지인 토지와 농지가 아닌 토지(비농지)의 면적을 더하여 산정해야 한다고 보는 것이 관련 규정의 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

따라서 「농지법 시행령」 제28조제1항제1호다목 후단에 따라 '농업진흥지역 안의 토지의 면적'이 3만제곱미터 이하인지를 판단하는 경우, 해제하려는 농업진흥지역 안의 농지의 면적뿐만 아니라 농지가 아닌 토지의 면적도 포함하여 산정해야 합니다.

관계법령

농지법

제31조(농업진흥지역 등의 변경과 해제) ① 시·도지사는 대통령령으로 정하는 사유가 있으면 농업진흥지역 또는 용도구역을 변경하거나 해제할 수 있다. 다만, 그 사유가 없어진 경우에는 원래의 농업진흥지역 또는 용도구역으로 환원하여야 한다.

② (생 략)

농지법 시행령

제28조(농업진흥지역 등의 변경·해제) ① 법 제31조제1항 본문에 따라 시·도지사가 농업진흥지역 또는 용도구역을 변경 또는 해제할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우로서 농업진흥지역을 해제하는 경우

   가.·나. (생 략)

   다. 해당 지역의 여건변화로 농업진흥지역의 지정요건에 적합하지 않게 된 경우. 이 경우 그 농업진흥지역 안의 토지의 면적이 3만제곱미터 이하인 경우로 한정한다.

2.·3. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0258

민원인 – 농지전용변경허가를 신청하는 경우 「농지법」 제56조제2호 및 같은 법 시행령 제74조제1항 제2호에 따라 수수료를 납부해야 하는지 여부(「농지법」 제56조 등 관련)

01 질의요지

「농지법」 제34조제1항에서는 농지를 전용하려는 자는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 농림축산식품부장관의 허가를 받도록 하면서(전단), 허가받은 농지의 면적 또는 경계 등 중요사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다고 규정하고 있고(후단), 같은 법 제56조제2호에서는 같은 법 제34조에 따른 허가를 신청하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내도록 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제74조제1항제2호에서는 같은 법 제34조에 따른 농지전용허가의 신청에 대한 수수료 금액을 규정하고 있는바,

「농지법」 제34조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 중요사항을 변경하려는 허가(이하 “농지전용변경허가”라 함)를 신청하는 자는 같은 법 제56조제2호 및 같은 법 시행령 제74조제1항제2호에 따라 수수료를 내야 하는지?

02 회답

농지전용변경허가를 신청하는 자는 「농지법」 제56조제2호 및 같은 법 시행령 제74조제1항 제2호에 따라 수수료를 내야 합니다.

03 이유

「농지법」 제34조제1항 각 호 외의 부분 전단에서는 농지를 전용하려는 자는 농림축산식품부장관의 허가를 받도록 규정하고 있고, 같은 항 각 호 외의 부분 후단에서는 허가받은

농지의 면적 또는 경계 등 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다고 하여 그 변경허가에 대해 규정하고 있으며, 같은 법 제56조제2호에서는 '제34조에 따른 허가'를 신청하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야한다고 규정하면서 그 위임에 따른 같은 법 시행령 제74조제1항제2호에서는 '법 제34조에 따른 농지전용허가'의 신청을 규정하고 있는바, 같은 법 시행령 제74조제1항제2호에서 규정하고 있는 '법 제34조에 따른 농지전용허가'에 같은 법 제34조제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 '농지전용허가' 뿐만 아니라 후단에 따른 '농지전용변경허가'가 포함되어 농지전용변경허가의 경우에도 수수료를 내야하는지 여부가 문제됩니다.

먼저 수수료 납부의 근거 규정인 「농지법」 제56조제2호에서는 수수료 납부 대상을 '제34조에 따른 허가'라고 규정하고 있는데, 같은 법 제34조제1항 각 호 외의 부분에서는 전단에 농지전용허가를, 후단에 농지전용변경허가를 함께 규정하고 있고, '제34조에 따른 허가'에서 '농지전용변경허가'를 제외한다고 명시적으로 규정하고 있지 않으므로, 문언상 해당 '허가'는 농지전용허가와 농지전용변경허가를 모두 포함하는 것으로 해석해야 하고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제74조제1항에서는 농지전용허가와 농지전용변경허가 모두에 대한 수수료 납부의 대상과 금액을 정하고 있는 것이라고 보아야 할 것입니다.

또한 「농지법」에서는 '법 제34조제1항에 따른 농지전용허가'를 받은 경우 농지를 소유할 수 있도록 하고 있고(제6조제2항제7호), '제34조제1항에 따라 농지전용허가를 받는 자'는 농지보전부담금을 내도록 하고 있는(제38조제1항제1호) 등 법률에서 전반적으로 '허가'와 '변경허가'를 구분하지 않고 제34조제1항에 따른 '농지전용허가'로만 규정하고 있는바[17], 이처럼 「농지법」에서 '법 제34조제1항에 따른 농지전용허가'를 사용하고 있는 조문의 체계에 비추어보면, '농지전용허가'에는 농지전용변경허가에 대해 별도로 명시하고 있지 않더라도 같은 조 제1항 전단의 '농지전용허가'와 같은 항 후단의 '농지전용변경허가'가 모두 포함된다고 보는 것이 「농지법」의 규정과 체계에도 부합하는 해석입니다.

그리고 '수수료'란 행정기관의 서비스 제공에 대한 반대급부를 의미하는 것으로서 그 이익을 얻는 특정인에 대하여 부과·징수한다는 점에서 개별적·구체적인 대가성이 있는데[18], 농지전용허가의 경우 관할 시장등이 농지법령에 따른 요건을 갖추었는지를 심사한 후 그 요건에 부합한 경우 허가하는 점에서 이에 대한 수수료도 그 행정업무 수행에 대한 대가라고

17) 농지관리위원회의 자문 사항(법 제37조의3제1항제2호), 농지전용허가의 취소 및 그 사유를 규정(법 제39조제1항)하면서 변경허가에 대한 자문이나 취소는 별도로 정하고 있지 않고 있고, 용도변경의 승인(제40조제1항제1호)·농지의 지목변경의 제한(제41조제1호)·원상회복의 대상(제42조제1항제1호)으로도 제34조(제1항)에 따른 농지전용허가만을 규정하고 있음

18) 2023 법령입안 심사기준 p.465 참조

할 것이고, 농지전용변경허가의 경우에도 「농지법 시행령」 제32조 및 제33조 등[19]에 따라 농지전용허가의 요건과 절차 등이 원칙적으로 동일하게 규정되어 있으므로 농지전용허가를 하는 경우에 따라야 하는 허가기준과 일련의 행정절차를 다시 거쳐 행해지는 점을 고려하면, 「농지법 시행령」 제74조제1항제2호에 따라 농지전용변경허가에 대해서도 그에 대한 수수료를 납부하도록 해석하는 것이 행정서비스의 대가라는 성격을 지닌 수수료의 특성에도 부합합니다.

한편 「농지법 시행령」 제74조제1항제2호에서 '농지전용허가'의 신청에 대해 수수료를 내야 한다고 규정하고 있을 뿐, 농지전용변경허가의 신청에 대해 수수료를 내야한다고 규정하고 있지 않으므로 수수료를 내야 하는 대상은 「농지법」 제34조제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 농지전용허가에 한정된다는 의견이 있으나, 농지전용허가의 신청 방법 및 서류에 관해 규정하고 있는 같은 법 시행규칙 제26조제1항에서는 농지전용허가신청서는 별지 제14호서식에 의한다고 규정하고 있고, 같은 규칙 별지 제14호서식에서는 농지전용허가 및 농지전용변경허가 신청서를 함께 규정하면서, 허가신청에 대한 수수료에 대해 '같은 법 시행령 제74조에 따름'으로만 규정하고 있어 그 수수료 부과 대상인 농지전용허가와 농지전용변경허가를 구분하여 규정하고 있지 않은바, 농지전용허가와 농지전용변경허가를 구분하여 농지전용변경허가의 경우 수수료를 면제한다고 명시적으로 규정하지 않은 이상, 농지전용변경허가에 대해서도 수수료를 면제할 의사가 없다고 보는 것이 농지법령의 체계 및 취지에 부합하는 해석이므로, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 농지전용변경허가를 신청하는 자는 「농지법」 제56조제2호 및 같은 법 시행령 제74조제1항제2호에 따라 수수료를 내야 합니다.

관계법령

농지법

제34조(농지의 전용허가·협의) ①농지를 전용하려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농림축산식품부장관의 허가(다른 법률에 따라 농지전용허가가 의제되는 협의를 포함한다. 이하 같다)를 받아야 한다. 허가받은 농지의 면적 또는 경계 등 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

19) 「농지법 시행령」 제32조(농지전용허가의 신청), 제33조(농지전용허가의 심사) 및 같은 법 시행규칙 제26조(농지전용허가의 신청), 제28조(농지전용심사의견서 등) 참조

1. ~ 4. (생 략)
② (생 략)

제56조(수수료) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다.
1. 제8조에 따라 농지취득자격증명 발급을 신청하는 자
2. 제34조나 제36조에 따른 허가를 신청하는 자
3. 제35조나 제43조에 따라 농지전용을 신고하는 자
4. 제40조에 따라 용도변경의 승인을 신청하는 자
5. 제50조에 따라 농지대장 등본 교부를 신청하거나 자경증명 발급을 신청하는 자

농지법 시행령

제74조(수수료) ① 법 제56조에 따른 수수료는 다음 각 호와 같다.
1. 법 제8조에 따른 농지취득자격증명의 신청: 1천원
2. 법 제34조에 따른 농지전용허가의 신청 및 법 제43조에 따른 농지전용의 신고: 다음 각 목의 구분에 따른 금액
   가. 허가신청농지의 면적이 3천500제곱미터 이하인 경우에는 2만원
   나. 허가신청농지의 면적이 3천500제곱미터를 초과할 경우에는 2만원에 그 초과면적 350제곱미터 마다 2천원을 가산한 금액
3. ~ 6. (생 략)
② (생 략)

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0314

민원인 - 농업진흥구역에서 공장인 농수산물의 가공·처리시설의 부지 안에 종업원을 위하여 사용하는 용도의 기숙사를 설치할 수 있는지(「농지법」 제32조제1항 등 관련)

01 질의요지

「농지법」 제32조제1항 본문에서는 농업진흥구역에서는 농업 생산 또는 농지 개량과 직접적으로 관련된 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 외의 토지이용행위를 할 수 없다고 규정하면서, 같은 항 단서에서 대통령령으로 정하는 농수산물[20]의 가공·처리 시설의 설치(제1호) 등 각 호의 토지이용행위는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제29조제2항제1호에서는 일정한 요건[21]을 모두 갖춘 농수산물의 가공·처리시설(「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 또는 같은 별표 제17호에 따른 공장에 해당하는 시설을 말하며, 그 시설에서 생산된 제품을 판매하는 시설을 포함한다)을 규정하고 있는 한편,

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 "산업집적법"이라 함) 제2조제1호 및 같은 법 시행령 제2조제2항제2호에서는 제조업을 하는 경우 종업원의 복지후생을 위하여 해당 공장부지 안에 설치하는 부대시설로서 산업통상자원부령으로 정하는 것을 공장의 범위에 포함되는 것으로 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제2조제6호의2에서는 부대시설 중 하나로 "기숙사"를 규정하고 있는바,

농업진흥구역에서 공장[22]인 농수산물의 가공·처리시설의 부지 안에 종업원을 위하여 사용하는 용도로 해당 농수산물의 가공·처리시설과 별도의 건축물인 기숙사[23](이하 "이 사안의 기숙사"라 함)를 설치할 수 있는지?

---

20) 농산물·임산물·축산물·수산물을 말하며, 이하 같음(「농지법」 제32조제1항제1호 참조).

21) 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호 각 목의 요건을 말함

22) 농수산물의 가공·처리시설이 ①「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 공장에 해당하는 시설인 경우로서, ②「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 따른 공장설립승인(제13조제1항), 공장설립완료신고(제15조제1항), 공장등록대장에 등록(제16조제1항)한 공장인 경우를 전제함(「농지법 시행령」 제29조제2항제1호 각 목 외의 부분 및 법제처 2014. 3. 25. 회신 14-0048 해석례 참조).

23) 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사를 말하며, 같은 목 2)에 따른 "임대형기숙사"가 아닌 것을 전제함.

02 회답

농업진흥구역에서 이 사안의 기숙사를 설치할 수 없습니다.

03 이유

먼저 농업진흥구역에 설치할 수 있는 농수산물의 가공·처리시설에 대해 규정하고 있는 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호의 문언을 살펴보면, 같은 호 각 목 외의 부분에서는 농수산물의 가공·처리시설을 「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 "공장"에 해당하는 시설로 규정하고 있고, 같은 표 제17호에서는 "공장"을 물품의 제조·가공 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 '다른 시설 등[24]으로 따로 분류되지 아니한 것'으로 규정하고 있는데, 같은 표 제2호라목에서는 공동주택인 '기숙사'를 별도로 분류하여 규정하고 있는바, 건축법령상 기숙사는 「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 공장에 해당하지 않으므로, 이 사안의 기숙사는 「농지법 시행령」 제29조제2항제1호에 따라 농업진흥구역에 설치할 수 없다고 할 것입니다.

그리고 「농지법」 제32조제1항 본문에서는 농업진흥구역에서 대통령령으로 정하는 행위 외의 토지이용행위를 할 수 없도록 하면서, 같은 항 단서에서 예외적으로 대통령령으로 정하는 농수산물의 가공·처리 시설의 설치(제1호) 등이 가능하도록 규정하고 있는데, 이처럼 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 그 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것이므로[25], 「농지법」 제32조제1항 각 호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제29조제2항부터 제7항까지에 따라 농업진흥구역에서 예외적으로 허용되는 토지이용행위는 한정적·열거적인 것으로 보아야 할 것인바[26], 같은 법 시행령 제29조제2항제1호에 따라 농업진흥구역에서는 대통령령으로 정하는 농수산물의 가공·처리시설의 설치를 예외적으로 허용하면서 해당 시설에 포함되어 함께 건축할 수 있는 시설로 그 시설에서 생산된 제품을 '판매하는 시설'만을 규정하고 있고, 종업원의 복지후생을 위한 기숙사 시설은 별도로 규정하고 있지 않으므로, 이 사안의 기숙사는 농업진흥구역에서 설치할 수 없는 것으로

24) 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 자원순환 관련 시설 등을 말함
25) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조
26) 법제처 2022. 8. 19. 회신 22-0461 해석례 참조

해석하는 것이 법령의 규정 체계 및 취지에 부합하는 해석입니다.

한편 산업집적법 제2조제1호, 같은 법 시행령 제2조제2항제2호 및 같은 법 시행규칙 제2조제6호의2에 따라 공장부지 안에 설치하는 부대시설인 기숙사는 공장의 범위에 포함되는 것으로 규정하고 있으므로, 농업진흥구역에서도 공장의 부대시설로서 기숙사를 설치할 수 있다는 의견이 있으나, 「건축법」은 건축물의 안전·기능·환경 및 미관 향상 등을 목적으로 하고 있고, 산업집적법은 산업 집적의 활성화 및 공장의 원활한 설립 지원 등을 목적으로 하고 있어 각각 입법목적·취지 및 규율대상 등을 달리하는 법률로써[27], 산업집적법령상 농수산물의 가공·처리시설인 공장의 부지 안에 설치하는 기숙사가 공장의 부대시설로서 공장의 범위에 포함된다고 하더라도, 건축법령상 기숙사는 「건축법 시행령」 별표 1 제17호에 따른 공장과는 별개의 용도인 건축물이므로, 「농지법」 제32조제1항 및 같은 법 시행령 제29조제2항제1호에 따라 이 사안의 기숙사는 농업진흥구역에 설치할 수 없다고 보아야 할 것인바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 농업진흥구역에서 이 사안의 기숙사를 설치할 수 없습니다.

관계법령

농지법

제32조(용도구역에서의 행위 제한) ① 농업진흥구역에서는 농업 생산 또는 농지 개량과 직접적으로 관련된 행위로서 대통령령으로 정하는 행위 외의 토지이용행위를 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 토지이용행위는 그러하지 아니하다.

1. 대통령령으로 정하는 농수산물(농산물·임산물·축산물·수산물을 말한다. 이하 같다)의 가공·처리 시설의 설치 및 농수산업(농업·임업·축산업·수산업을 말한다. 이하 같다) 관련 시험·연구 시설의 설치
2. ~ 9. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

농지법 시행령

제29조(농업진흥구역에서 할 수 있는 행위) ① (생 략)

② 법 제32조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 농수산물(농산물·임산물·축산물·수산물을 말한다. 이하 같다)의 가공·처리 시설 및 농수산업(농업·임업·축산업·수산업을 말한다. 이하 같다)

27) 법제처 2013. 1. 28. 회신 12-0689 해석례 참조

관련 시험·연구 시설"이란 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 농수산물의 가공·처리 시설(「건축법 시행령」 별표 1 제4호너목에 따른 제조업소 또는 같은 표 제17호에 따른 공장에 해당하는 시설을 말하며, 그 시설에서 생산된 제품을 판매하는 시설을 포함한다)
   가. 국내에서 생산된 농수산물(「농업·농촌 및 식품산업 기본법 시행령」 제5조제1항 및 제2항에 따른 농수산물을 말하며, 임산물 중 목재와 그 가공품 및 토석은 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 및 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 농수산가공품을 주된 원료로 하여 가공하거나 건조·절단 등 처리를 거쳐 식품을 생산하기 위한 시설일 것
   나. 농업진흥구역 안의 부지 면적이 1만5천제곱미터[미곡의 건조·선별·보관 및 가공시설(이하 "미곡종합처리장"이라 한다)의 경우에는 3만제곱미터] 미만인 시설(판매시설이 포함된 시설의 경우에는 그 판매시설의 면적이 전체 시설 면적의 100분의 20 미만인 시설에 한정한다)일 것
2.·3. (생 략)

③ ~ ⑦ (생 략)

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0410

교육부 – 「초·중등교육법」에 따른 사립학교가 시험지 등의 용도로 농지를 취득하려는 경우 해당 사립학교를 관할하는 교육감을 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에 따른 추천의 주체인 소관 중앙행정기관의 장으로 볼 수 있는지 여부(「농지법 시행규칙」 제6조제1항 등 관련)

01 질의요지

「농지법」 제6조제1항에서는 농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다고 규정하면서, 같은 조 제2항제2호 및 같은 법 시행규칙 제6조제1항에 따르면 같은 법 제6조제1항에도 불구하고 「초·중등교육법」에 따른 학교 등이 그 목적사업을 수행하기 위하여 필요한 시험지·연구지·실습지 등(이하 "시험지등"이라 함)으로 쓰기 위하여 농지를 취득하려는 경우에는 소관 중앙행정기관의 장(소관 사무에 관한 권한을 위임받은 자를 포함함)의 추천을 거쳐 농지소재지를 관할하는 특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 "시·도지사"라 함)의 농지취득인정을 받으면 농지를 취득하여 소유할 수 있도록 규정하고 있는 한편,

「초·중등교육법」 제3조에서는 초·중등교육을 실시하기 위한 학교[28]를 설립주체에 따라 국립·공립·사립학교로 구분하면서 같은 법 제6조에서 국립학교는 교육부장관의 지도·감독을 받으며, 공립·사립 학교는 교육감의 지도·감독을 받는다고 규정하고 있는바,

「초·중등교육법」에 따른 사립학교가 그 목적사업을 수행하기 위하여 필요한 시험지등으로 쓰기 위하여 농지를 취득하려는 경우, 해당 사립학교를 관할하는 교육감을 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에 따른 추천의 주체인 소관 중앙행정기관의 장[29]으로 볼 수 있는지?

28) 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교(초·중등 초등학교, 중학교·고등공민학교, 고등학교·고등기술학교, 특수학교, 각종학교)를 말하며, 이하 같음.

29) 사립학교가 농지를 취득하려는 경우 소관 중앙행정기관의 장의 추천에 관하여 법령에서 교육부장관이 교육감에게 권한을 위임한 경우가 아님을 전제로 함.

02 회답

이 사안의 경우, 해당 사립학교를 관할하는 교육감을 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에 따른 추천의 주체인 소관 중앙행정기관의 장으로 볼 수 없습니다.

03 이유

먼저 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에서는 「초·중등교육법」에 따른 학교 등이 시험지 등으로 농지를 취득하려는 경우에는 소관 '중앙행정기관의 장'의 추천을 거쳐 농지소재지를 관할하는 시·도지사의 농지취득인정을 받아야 한다고 규정하고 있는데, 국가행정기관의 설치·조직과 직무범위를 규정한 「정부조직법」 제2조제2항에서 '중앙행정기관'은 이 법에 따라 설치된 부·처·청과 같은 항 각 호의 행정기관으로 하되, 중앙행정기관은 이 법 및 같은 항 각 호의 법률에 따르지 아니하고는 설치할 수 없다고 규정하고 있는 한편, 지방자치단체의 교육·학예에 관한 사무를 관장하는 기관의 설치와 그 조직 등에 관한 사항을 규정한 「지방교육자치에 관한 법률」(이하 "교육자치법"이라 함) 제18조제1항에서는 시·도의 교육·학예에 관한 사무의 집행기관으로 시·도에 교육감을 둔다고 규정하고 있는바, "중앙행정기관의 장"은 「정부조직법」 제2조제2항에 따라 설치된 국가행정기관의 장을 의미하는 것으로서 지방자치단체의 교육·학예에 관한 사무의 집행기관의 장인 "교육감"과는 구분되는 별개의 주체이므로 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에 따른 "중앙행정기관의 장"에 "교육감"은 포함되지 않는 것이 문언상 명확합니다.

그리고 「농지법」 제6조제1항에서는 경자유전의 원칙을 규정하고 있고, 같은 조 제2항 제2호에서는 그 원칙의 예외로서 「초·중등교육법」에 따른 학교 등이 농지를 취득하는 경우를 규정하면서 그 취득 절차로 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에서 소관 중앙행정기관의 장의 추천을 규정하고 있는바, 이처럼 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 그 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있는데[30], 농지법령에서 해당 추천권의 주체에 대하여 사립학교가 농지를 취득하려는 경우에는 '교육감'을 '소관 중앙행정기관의 장'으로 한다는 명시적 규정을 두고 있지 않은 이상, 중앙행정기관의 장과

30) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 참조.

구분되는 교육감을 "중앙행정기관의 장"으로 보는 것은 문언의 의미를 지나치게 확대하여 해석하는 것으로 타당하지 않습니다.

또한 행정청의 권한은 「정부조직법」을 비롯한 각 개별법에서 정한 범위에서 행사되어야 하고, 이와 같은 행정권한 법정주의 원칙상 행위 주체에 대해서는 문언에 따라 엄격하게 해석하여야 하며, 법률에 규정되어 있지 아니한 사항을 유추·확장하여 해석하여서는 안 된다고 할 것인데[31], 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에서 농지취득인정의 주체에 대해서 "농지소재지를 관할하는 시·도지사"라고 규정한 것과는 달리 추천의 주체에 대해서는 "소관 중앙행정기관의 장"으로 규정하고 있을 뿐 "해당 사립학교를 관할하는 시·도 교육감"이라고 명시하지 않고 있는바, 교육감의 추천 권한에 관한 명확한 근거 규정 없이 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에 따른 추천의 주체를 교육감으로 해석하기는 어렵습니다.

아울러 교육인적자원부장관의 권한 중 교육감에게 위임하는 사항을 규정하고 있던 구 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」[32] 제26조제1항에서는 제30호를 신설하여 "「초·중등교육법」에 의하여 설치된 학교의 「농지법」 제6조제2항제2호 및 동법 시행규칙 제5조제1항의 규정에 의한 농지취득을 위한 추천" 권한을 교육감에게 위임한다고 명시적으로 규정하고 있었는데, 이후 2010년 1월 6일 대통령령 제21978호로 전부개정된 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」에서 해당 조항이 삭제되었는바, 이러한 권한의 위임에 관한 연혁에 비추어보면 당초 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에 따른 농지취득을 위한 추천 권한은 교육부장관에게 있는 것이고, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 등 다른 법령에서 교육부장관의 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에 따른 추천 권한을 교육감에게 위임한다는 명시적 규정이 없다면 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에 따른 "소관 중앙행정기관의 장"에 교육감이 포함된다고 해석하여 농지취득을 위한 추천을 할 수 있다고 보기는 어렵다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 사립학교를 관할하는 교육감을 「농지법 시행규칙」 제6조제1항에 따른 추천의 주체인 소관 중앙행정기관의 장으로 볼 수 없습니다.

31) 법제처 2012. 8. 29. 회신 12-0417 해석례 참조.

32) 2003. 1. 20. 대통령령 제17892호로 일부개정된 것을 말함

관계법령

농지법

제6조(농지 소유 제한) ① 농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다.
② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 농지를 소유할 수 있다. 다만, 소유 농지는 농업경영에 이용되도록 하여야 한다(제2호 및 제3호는 제외한다).
1. (생 략)
2. 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교, 농림축산식품부령으로 정하는 공공단체·농업연구기관·농업생산자단체 또는 종묘나 그 밖의 농업 기자재 생산자가 그 목적사업을 수행하기 위하여 필요한 시험지·연구지·실습지·종묘생산지 또는 과수 인공수분용 꽃가루 생산지로 쓰기 위하여 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 농지를 취득하여 소유하는 경우
3. ~ 10. (생 략)
③ (생 략)
④ 이 법에서 허용된 경우 외에는 농지 소유에 관한 특례를 정할 수 없다.

농지법 시행규칙

제6조(시험지·연구지·실습지 등으로 쓰일 농지의 취득인정) ①「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 학교 또는 제5조에 따른 공공단체 등이 법 제6조제2항제2호에 따라 시험지·연구지·실습지·종묘생산지 또는 과수 인공수분용 꽃가루 생산지로 농지를 취득하려는 경우에는 소관 중앙행정기관의 장(소관 사무에 관한 권한을 위임받은 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 추천을 거쳐 농지소재지를 관할하는 특별시장·광역시장 또는 도지사(이하 "시·도지사"라 한다)의 농지취득 인정을 받아야 한다.
② ~ ⑥ (생 략)

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0525

민원인 – 농업인이나 농업생산자단체가 아닌 자가 농업회사법인을 설립할 수 있는지 여부(「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제19조제2항 등 관련)

01 질의요지

「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」(이하 "농어업경영체법"이라 함) 제19조에서는 농업의 경영이나 농산물의 유통·가공·판매를 기업적으로 하려는 자나 농업인의 농작업을 대행하거나 농어촌 관광휴양사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농업회사법인을 설립할 수 있다고 규정하면서(제1항), 농업회사법인을 설립할 수 있는 자는 농업인과 농업생산자단체로 하되, 농업인이나 농업생산자단체가 아닌 자도 대통령령으로 정하는 비율 또는 금액의 범위에서 농업회사법인에 출자할 수 있다고 규정하고 있고(제2항), 같은 법 시행령 제17조제1항에서는 농업인 및 농업생산자단체는 같은 법 제19조제1항에 따라 주식회사(제3호) 등에 해당하는 농업회사법인을 설립할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

농어업경영체법 제19조제11항에서는 농업회사법인에 관하여 같은 법에서 규정한 사항 외에는 「상법」 중 회사에 관한 규정을 준용한다고 규정하고 있는바,

농업인이나 농업생산자단체가 아닌 자(이하 "비농업인"이라 함)는 농어업경영체법 제19조에 따라 발기인으로서 주식회사인 농업회사법인을 설립할 수 있는지?

02 회답

비농업인은 농어업경영체법 제19조에 따라 발기인으로서 주식회사인 농업회사법인을 설립할 수 없습니다.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[33], 농어업경영체법 제19조제2항에서는 농업회사법인을 설립할 수 있는 자는 농업인과 농업생산자단체로 하되, 비농업인도 대통령령으로 정하는 비율 또는 금액의 범위에서 농업회사법인에 출자할 수 있다고 규정하고 있는바, 일반적으로 '설립'이란 "기관이나 조직체 따위를 만들어 일으킴"을, '출자'란 "자금을 내는 일"을 의미하여[34] '설립'과 '출자'의 의미가 서로 다르고, 농어업경영체법 제19조에서는 "농업회사법인을 설립할 수 있는 자"와 "농업회사법인에 출자할 수 있는 자"를 구분하여 규정하고 있으며, 발기인은 「상법」 제288조에 따라 주식회사를 설립함에 있어 정관을 작성하는 등 주식회사의 설립사무를 담당하는 자라는 점[35] 등을 종합적으로 고려하면, 농어업경영체법 제19조제2항에서 "농업회사법인을 설립할 수 있는 자"를 "농업인과 농업생산자단체"로 규정하고 있는 것은 주식회사인 농업회사법인을 설립할 수 있는 자, 즉 설립사무를 담당하는 발기인이 "농업인과 농업생산자단체"인 것을 의미하므로 비농업인이 주식회사의 설립사무를 담당하는 자인 발기인으로서 주식회사인 농업회사법인을 설립할 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 농어업경영체법은 농어업, 농어촌을 지속적으로 발전시키고 농어업 경영주체의 경쟁력을 강화하려는 취지에서 제정된 법률로서[36], 같은 법 제19조에 따른 농업회사법인은 농업·농촌의 공익기능 증진과 소득안정을 위한 공익직접지불제도[37] 등 각종 지원제도의 대상이 되고, 농업회사법인의 식량작물재배업소득 등에 대하여 법인세가 면제되며[38], 농업회사법인이 영농에 사용하기 위하여 법인설립등기일부터 2년 이내에 취득하는 농지 등에 대해서 취득세가 감면되는 등[39] 세제 혜택의 대상이 되므로 이러한 농업회사법인의 설립요건은 엄격하게 해석해야 할 것[40]인바, 농어업경영체법 제19조제2항에서 규정하고 있는 "농업인과 농업생산자단체" 외에 비농업인까지 포함하여 발기인으로서 주식회사인

33) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
34) 국립국어원 표준국어대사전 참조
35) 법제처 2008. 9. 16. 08-0231 해석례 및 정찬형, 제26판 상법강의(상), p.664 참조
36) 2009. 4. 1. 법률 제9620호로 제정된 농어업경영체법 제정이유 참조
37) 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제2조제1호, 제5조 및 제6조 참조
38) 「조세특례제한법」 제68조제1항 참조
39) 「지방세특례제한법」 제11조제1항 및 제2항 참조
40) 대법원 2008. 2. 14. 선고 2007두21242 판결례 참조

농업회사법인을 설립할 수 있다고 보기는 어렵습니다.

또한 통상적으로 법인의 발기인은 법인을 설립할 때 법인의 권리·의무의 근간이 되는 정관을 작성하고[41] 자본금의 규모와 구조 등 자본적 기초가 되는 사항[42]을 정하는 등 법인의 기본적 운영방향을 결정하게 되므로 농업 효율성 향상과 규모화를 달성하려는 농업회사법인제도의 취지[43]에 따라 농업회사법인의 발기인은 한정적으로 해석할 필요가 있고, 농업회사법인 제도의 취지와 달리 사업범위를 일탈하여 사업을 추진하는 농업회사법인 등이 발생함에 따라 이에 대한 효과적인 관리·감독을 위하여[44] 농어업경영체법에서는 법인의 주된 사무소 관할 시장·군수·구청장은 주주의 인적사항, 주소 및 출자현황 등에 대한 조사를 실시하고(제20조의2 제1항), 조사 결과 비농업인이 보유한 출자지분이 법정출자한도를 초과하는 경우 시정을 명할 수 있으며(제20조의2제8항제2호), 비농업인이 보유한 출자지분이 법정출자한도를 초과한 후 1년 이상이 경과한 경우에 시장·군수·구청장은 농업회사법인에 대하여 법원에 해산을 청구할 수 있도록 규정(제20조의3제2항제2호)하는 등 비농업인의 출자지분을 엄격히 관리하도록 규정하고 있는바, 이러한 농어업경영체법령의 체계 및 취지에 비추어 봤을 때 농어업경영체법 제19조제2항에서 농업회사법인을 설립할 수 있는 자로 규정하고 있는 "농업인과 농업생산자단체" 외에 비농업인까지 포함하여 발기인으로서 주식회사인 농업회사법인을 설립할 수 있다고 해석하는 것은 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 비농업인은 농어업경영체법 제19조에 따라 발기인으로서 주식회사인 농업회사법인을 설립할 수 없습니다.

관계법령

농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률

제19조(농업회사법인 및 어업회사법인의 설립신고 등) ① 농업의 경영이나 농산물의 유통·가공·판매를 기업적으로 하려는 자나 농업인의 농작업을 대행하거나 농어촌 관광휴양사업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 농업회사법인(農業會社法人)을 설립할 수 있다.

41) 「상법」 제289조 참조

42) 「상법」 제289조, 제301조 등 참조

43) 대법원 2023. 8. 18. 자 2023마5602 결정례 참조

44) 2013. 9. 3. 의안번호 제1906660호로 발의된 농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 심사보고서(대안반영폐기) 참조

② 농업회사법인을 설립할 수 있는 자는 농업인과 농업생산자단체로 하되, 농업인이나 농업생산자단체가 아닌 자도 대통령령으로 정하는 비율 또는 금액의 범위에서 농업회사법인에 출자할 수 있다.
③ ~ ⑪ (생 략)

농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률 시행령

제17조(농업회사법인 및 어업회사법인의 설립 유형) ① 농업인 및 농업생산자단체는 법 제19조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 농업회사법인(이하 "농업회사법인"이라 한다)을 설립할 수 있다.
1. 합명회사
2. 합자회사
2의2. 유한책임회사
3. 주식회사
4. 유한회사
② (생 략)

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0577

민원인 – 「농지법」 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지를 같은 법 제23조제1항제6호에 따라 한국농어촌공사에 위탁하지 않고 제3자에게 무상사용하게 할 수 있는지(「농지법」 제23조제1항제6호 등 관련)

01 질의요지

「농지법」 제23조제1항 각 호 외의 부분에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 없다고 규정하면서, 같은 항 제6호에서 같은 법 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지를 한국농어촌공사나 그 밖에 대통령령으로 정하는 자[45]에게 위탁하여 임대하거나 무상사용하게 하는 경우를 규정하고 있는바,

「농지법」 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지를 같은 법 제23조제1항제6호에 따라 한국농어촌공사에 위탁하지 않고 제3자에게 무상사용하게 할 수 있는지?

02 회답

「농지법」 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지를 같은 법 제23조제1항제6호에 따라 한국농어촌공사에 위탁하지 않고 제3자에게 무상사용하게 할 수 없습니다.

03 이유

법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미를 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에

45) 「농지법 시행령」 등 관련 대통령령에서는 '그 밖에 대통령령으로 정하는 자'에 대해 규정하고 있지 않음

없다고 할 것인데[46], 「농지법」 제6조제1항에서는 원칙적으로 "농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다"고 규정하면서 같은 조 제3항에서 "법 제23조제1항제1호부터 제6호까지의 규정에 따라 농지를 임대하거나 무상사용하게 하는 경우에는 제6조제1항 또는 제2항에도 불구하고 임대하거나 무상사용하게 하는 기간 동안 농지를 계속 소유할 수 있다"고 그 예외를 규정하고 있으며, 같은 법 제23조제1항 각 호 외의 부분에서는 "같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 없다"고 규정하면서 그 예외 사유 중 하나로 같은 항 제6호에서 "법 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지를 한국농어촌공사에 위탁하여 임대하거나 무상사용하게 하는 경우"라고 규정하고 있는바, 같은 법 제23조제1항제6호에서 해당 농지를 "임대"하는 경우와 "무상사용"하게 하는 경우에 대하여 그 위탁 대상이나 요건을 달리 정하고 있지 않으므로 두 경우 모두 한국농어촌공사에 위탁해야 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 있는 예외사유에 해당하는 것이 문언상 분명합니다.

그리고 「농지법」 제3조제1항에서는 농지에 관한 기본 이념으로 농지는 공공복리에 적합하게 관리되어야 하고 농지에 관한 권리의 행사에는 필요한 제한과 의무가 따른다고 규정하고 있고, 같은 법 제6조 및 제23조제1항에서는 농지는 원칙적으로 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못하게 하면서 제23조제1항제1호부터 제6호까지의 사유에 해당하는 예외적인 경우에만 농지를 소유하면서 그 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 있도록 하고 있으므로, 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 있는 제23조제1항 각 호의 사유를 해석함에 있어서는 엄격하고 제한적으로 해석해야 할 것[47]인바, 같은 법 제23조제1항제6호의 경우 한국농어촌공사에 위탁해야 한다는 것은 같은 법 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지의 임대나 무상사용을 허용하기 위한 요건으로서 임대뿐만 아니라 무상사용의 경우에도 해당 요건을 갖춰야 한다고 보아야 하고, 같은 법 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지를 한국농어촌공사에 위탁하여 무상사용하게 하는 경우에만 같은 법 제23조제1항제6호에 따라 농지를 무상사용하게 할 수 있는 경우에 해당한다고 엄격히 해석하는 것이 농업경영을 하는 자만 농지를 소유하도록 한 「농지법」의 원칙과 예외규정의 엄격해석 원칙에 비추어 타당하다고 할 것입니다.

아울러 구 「농지법」[48] 제23조제1항제6호에서는 "제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지"를 한국농어촌공사에 위탁하여 임대하거나 무상사용하게 하는 경우라고 규정하고

46) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

47) 법제처 2020. 7. 13. 회신 20-0172 해석례, 법제처 2021. 5. 12. 회신 21-0147 해석례 참조

48) 2023. 8. 16. 법률 제19639호로 일부개정되기 전의 것을 말함

있던 것을 2023년 8월 16일 법률 제19639호로 「농지법」을 일부개정하면서 같은 법 제23조제1항제6호에서 "제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지"를 한국농어촌공사에 위탁하여 임대하거나 무상사용하게 하는 경우로 개정하였는데, 그 취지는 한국농어촌공사의 농지임대수탁제도 등이 농지 투기수단으로 활용되는 것을 방지하기 위해 3년 이상 소유한 농지에 한해 임대차 또는 사용대차[49]가 가능하도록 하기 위한 것으로 설명하고 있어[50] 한국농어촌공사에 위탁하는 경우에만 사용대차가 가능한 것으로 전제하고 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「농지법」 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지를 같은 법 제23조제1항제6호에 따라 한국농어촌공사에 위탁하지 않고 제3자에게 무상사용하게 할 수 없습니다.

관계법령

농지법

제6조(농지 소유 제한) ① 농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다.
② (생 략)
③ 제23조제1항제1호부터 제6호까지의 규정에 따라 농지를 임대하거나 무상사용하게 하는 경우에는 제1항 또는 제2항에도 불구하고 임대하거나 무상사용하게 하는 기간 동안 농지를 계속 소유할 수 있다.
④ 이 법에서 허용된 경우 외에는 농지 소유에 관한 특례를 정할 수 없다.

제23조(농지의 임대차 또는 사용대차) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 농지를 임대하거나 무상사용하게 할 수 없다.
1. ~ 5의2. (생 략)
6. 제6조제1항에 따라 개인이 소유하고 있는 농지 중 3년 이상 소유한 농지를 한국농어촌공사나 그 밖에 대통령령으로 정하는 자에게 위탁하여 임대하거나 무상사용하게 하는 경우
7. ~ 9. (생 략)
② 제1항에도 불구하고 농지를 임차하거나 사용대차한 임차인 또는 사용대차인이 그 농지를 정당한 사유 없이 농업경영에 사용하지 아니할 때에는 시장·군수·구청장이 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 임대차 또는 사용대차의 종료를 명할 수 있다.

49) 「농지법」 제23조는 조제목을 '농지의 임대차 또는 사용대차'라고 하고 있고, 사용대차란 당사자 일방이 상대방에게 무상으로 사용, 수익하게 하기 위한 것(「민법」 제609조)인바, 「농지법」 제23조에서 임대차에 대해서는 '임대', 사용대차에 대해서는 '무상사용'이라는 용어를 사용하고 있음

50) 2022. 10. 31. 의안번호 2118000호로 발의된 농지법 일부개정법률안 주요내용 참조

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0628, 24-0940

경상남도 – 「개간촉진법」 제23조제1항에 따라 특별개간허가를 받은 경우, 그 권리의 양도에 관한 허가 및 준공인가 권한 등은 누구에게 있는지[「개간촉진법」(1967. 1. 16. 법률 제1872호로 폐지되기 전의 것을 말함) 제23조제1항 등 관련]

01 질의요지

「개간촉진법」(1967. 1. 16. 법률 제1872호로 폐지되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제23조제1항에서는 농림부장관은 개간허가신청을 수리하였을 경우에는 그 능력을 심사하여 개간을 허가한다고 규정하고 있고, 같은 법 제27조에서는 특별개간허가 권리의 양도, 상속, 자격, 준공인가 및 취소에 관하여는 같은 법 제11조 내지 제13조의 규정을 준용한다고 규정하고 있으며, 「개간촉진법 시행령」(1967. 4. 10. 대통령령 제2988호로 폐지되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제45조에서는 개간허가를 받은 자가 사업계획의 일부를 변경하려는 경우에는 허가관청의 허가를 받아 변경실시할 수 있다고 규정하고 있고,

1967년 1월 16일 법률 제1872호로 「개간촉진법」이 폐지되면서 「농경지조성법」(1967. 1. 16. 법률 제1872호로 제정된 것을 말하며, 이하 같음)이 제정되었고, 같은 법 부칙 제3항 단서에서는 "다만, 「개간촉진법」 제14조 내지 제19조, 제21조 내지 제26조 및 제28조의3의 규정에 의한 사항에 관하여는 종전의 예에 의한다"고 규정하고 있으며, 「농경지조성법」 제17조 및 제18조에서는 개간허가 권리의 양도와 준공인가를 규정하고 있고, 「농경지조성법 시행령」(1967. 4. 10. 대통령령 제2988호로 제정된 것을 말하며, 이하 같음) 제31조에서는 수허가자가 사업계획의 일부를 변경하려는 경우에는 허가관청의 허가를 받아 변경실시할 수 있다고 규정하고 있으며,

1975년 4월 11일 법률 제2767호로 「농경지조성법」이 폐지되면서 「농지확대개발촉진법」(1975. 4. 11. 법률 제2767호로 제정된 것을 말하며, 이하 같음)이 제정되었고, 같은 법 부칙 제3항 단서에서는 "다만, 「농경지조성법」 제16조 내지 제23조 및 제29조와 동법 부칙 제3항 단서의 규정에 의한 사항에 관하여는 종전의 예에 의한다"고 규정하고 있는 한편,

1977년 2월 10일 대통령령 제8441호로 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」(1977.

2. 10. 대통령령 제8441호로 일부개정된 것을 말하며, 이하 "구 행정위임위탁규정"이라 함)이 개정되면서 같은 영 제20조제15항제78호에서 서울특별시장·부산시장 또는 도지사에게 위임하는 농수산부장관의 권한으로 "「농지확대개발촉진법」 부칙 제3항의 규정에 의하여 종전의 예에 의하게 된 「농경지조성법」 제16조 내지 제23조 및 제29조와 동법 부칙 제3항의 단서규정에 의한 권한"이 신설되었고,

1994년 12월 22일 법률 제4823호로 「농지확대개발촉진법」이 폐지되면서 「농어촌정비법」(1994. 12. 22. 법률 제4823호로 제정된 것을 말하며, 이하 "구 「농어촌정비법」"이라 함)이 제정되었고, 같은 법 부칙 제5조제1항에서는 "이 법 시행당시 종전의 「농지확대개발촉진법」에 의하여 시행중인 농지개발사업과 동법 제32조·제33조·제35조·제36조·제45조 및 동법 부칙 제3항 단서의 규정에 의한 사항에 관하여는 종전의 규정에 의한다"고 규정하고 있는바,

가. 「개간촉진법」 제23조제1항에 따라 특별개간허가를 받은 경우, 그 권리의 양도에 관한 허가 및 준공인가는 도지사에게 받아야 하는지, 아니면 농림축산식품부장관에게 받아야 하는지[51]?

나. 「개간촉진법」 제23조제1항에 따라 특별개간허가를 받은 경우, 사업계획의 변경허가는 도지사에게 받아야 하는지, 아니면 농림축산식품부장관에게 받아야 하는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

「개간촉진법」 제23조제1항에 따라 특별개간허가를 받은 경우, 그 권리의 양도에 관한 허가 및 준공인가는 도지사에게 받아야 합니다.

나. 질의 나에 대해

「개간촉진법」 제23조제1항에 따라 특별개간허가를 받은 경우, 사업계획의 변경허가는 도지사에게 받아야 합니다.

51) 「개간촉진법」 제23조제1항에 따른 특별개간허가가 현재까지 유효하고, 농경지조성법 제2조제5항에 따른 허가관청 및 「농어촌정비법」 제9조제8항에 따른 농업생산기반 정비사업 시행계획 변경승인권자는 도지사인 경우를 전제로 함

03 이유

가. 질의 가 및 나의 공통사항

「개간촉진법」에서는 특별개간허가와 개간허가를 구분하여 규정하면서, 그중 특별개간에 대하여 같은 법 제21조 및 제22조에서는 같은 법 제6조에 따라 고시된 개간예정지 이외의 미간지로서 일반개간예정지로 적합하지 않은 30정보[52] 이상의 1단지를 개간하려는 자는 사업계획서를 작성하여 농림부장관에게 개간예정지결정신청을 하도록 규정하고 있고, 개간예정지결정신청이 수리되어 개간예정지로 고시된 경우 농림부장관에게 개간허가를 신청할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제23조에서는 농림부장관은 개간허가신청을 수리하였을 경우에는 그 능력을 심사하여 적당하다고 인정될 때에는 개간을 허가한다고 규정하고 있고, 같은 법 제27조에서는 특별개간허가를 받은 자에 대한 권리의 양도, 상속, 자격, 준공인가 및 취소에 관하여 같은 법 제11조 및 제13조의 규정을 준용하도록 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제45조에서는 개간허가를 받은 자에 대한 사업계획 변경허가 권한은 당해 허가관청에 있다고 규정하고 있는바, 「개간촉진법」에 따르면 특별개간허가 권한은 농림부장관에게 있다고 할 것입니다.

1967년 1월 16일 법률 제1872호로 「개간촉진법」이 폐지되면서 제정된 「농경지조성법」에서는 특별개간사업에 관한 사항은 규정하지 않고, 「농경지조성법」 부칙 제3항 단서에서 「개간촉진법」 제14조 내지 제19조, 제21조 내지 제26조 및 제28조의3의 규정에 의한 사항에 관하여는 종전의 예에 의한다고 규정하고 있으며, 「농경지조성법」 제17조 및 제18조에서는 각각 개간허가 권리의 양도와 준공인가 권한이 허가관청[53]에 있다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제31조에서는 개간허가를 받은 자에 대한 사업계획 변경허가 권한은 당해 허가관청에 있다고 규정하고 있는바, 「농경지조성법」에 따르면 같은 법 부칙 제3항에 따라 특별개간허가 권한은 농림부장관에게 있고, 특별개간허가 권리의 양도, 준공인가 및 사업계획 변경에 대해서는 명시적인 규정을 두고 있지 않습니다.

1975년 4월 11일 법률 제2767호로 「농경지조성법」이 폐지되면서 제정된 「농지확대개발촉진법」 부칙 제3항 단서에서는 「농경지조성법」 제16조 내지 제23조 및 제29조와 동법 부칙 제3항 단서의 규정에 의한 사항에 관하여는 종전의 예에 의한다고 규정하여 특별개간허가 권한은 「농경지조성법」과 동일하게 농수산부장관에게 있다고 할 것이고, 1977년 2월 10일

52) 땅 넓이의 단위로 1정보는 3,000평으로 약 9,917.4㎡에 해당함(국립국어원 표준국어대사전 참조)
53) 「농경지조성법」 제2조제5항 참조

대통령령 제8441호로 구 행정위임위탁규정이 개정되면서 제20조제15항제78호에서는 농수산부장관이 "「농지확대개발촉진법」 부칙 제3항의 규정에 의하여 종전의 예에 의하게 된 「농경지조성법」 제16조 내지 제23조 및 제29조와 동법 부칙 제3항의 단서규정에 의한 권한"을 도지사 등[54]에게 위임하고 있는바, 구 행정위임위탁규정 시행으로 특별개간허가 권한은 도지사에게 위임되었습니다.

그리고 1994년 12월 22일 법률 제4823호로 「농지확대개발촉진법」이 폐지되면서 제정된 구 「농어촌정비법」에서는 개간사업을 농업생산기반정비사업[55]으로 개편하였고, 구 「농어촌정비법」 부칙 제5조제1항에서는 「농지확대개발촉진법」 제32조·제33조·제35조·제36조·제45조 및 동법 부칙 제3항 단서의 규정에 의한 사항에 관하여는 종전의 규정에 의한다고 규정하여 「농지확대개발촉진법」 부칙 제3항 단서의 내용을 유지하고 있으며, 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제32조제1항제1호에서도 "법률 제4823호 농어촌정비법 부칙 제5조제1항에 따라 종전의 규정에 따르게 된 법률 제2767호 농지확대개발촉진법 제32조, 제33조, 제36조 및 같은 법 부칙 제3항 단서에 따른 권한"은 농림축산식품부장관이 시·도지사[56]에게 위임하도록 규정하여 구 행정위임위탁규정 제20조제15항제78호의 내용이 유지되고 있는바, 특별개간허가 권한은 도지사에게 있다고 할 것입니다.

나. 질의 가에 대해

「개간촉진법」을 대체한 「농경지조성법」에서는 특별개간사업에 관한 사항은 규정하지 않고, 「농경지조성법」 부칙 제3항 단서에서 특별개간허가 권리의 양도에 관한 허가 및 준공인가(「개간촉진법」 제27조)는 제외하고 특별개간허가(「개간촉진법」 제23조)만 종전의 예에 의하도록 경과조치를 두었으며, 「농지확대개발촉진법」 부칙 제3항 단서에서도 그 내용은 유지되어 특별개간허가와 관련된 권한은 농수산부장관이 갖는다고 할 것인데, 구 행정위임위탁규정 제20조제15항제78호에서 농수산부장관은 「농경지조성법」 부칙 제3항의 단서 규정의 권한을 도지사 등에게 위임하고 있고, 그 내용은 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제32조제1항제1호에서도 유지되고 있어 구 행정위임위탁규정의 시행으로 특별개간허가 권한은 도지사에게 위임된 것인바, 허가 권한과 부수되는 권한 중 일부만을 위임하면 관련 업무의 처리 권한자가 각각 달라 행정상 혼란이 발생할 수 있어[57] 일반적으로

54) 서울특별시장·부산시장 또는 도지사를 말함

55) 구 농어촌정비법 제2조제3호에 따른 농업생산기반정비사업을 말함

56) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사를 말함

57) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.502 참조

허가권한과 허가에 부수되는 권한의 주체는 일원화되는 점, 특별개간허가는 「개간촉진법」 이후 없어졌으므로 도지사에게 위임된 사항은 신규 허가가 아니라 허가에 부수되는 권한 일체로 볼 수 있는 점을 고려할 때, 「개간촉진법」 제23조에 따른 특별개간허가를 받은 경우 그 권리의 양도에 관한 허가 및 준공인가 권한은 도지사에게 있다고 보는 것이 타당합니다.

그리고 「개간촉진법」이 폐지되고 「농경지조성법」이 제정되면서 개간허가, 그 허가의 양도 및 준공인가 권한(「농경지조성법」 제13조, 제17조, 제18조)은 「농경지조성법」 제2조제5항에 따른 허가관청으로 일원화되었고, 여기서 허가관청은 서울특별시·부산시 또는 도가 개간사업을 하는 경우에만 농림부장관의 권한으로 규정하고 그 외에는 모두 시·도지사 또는 시장·군수로 규정하고 있으며, 「농지확대개발촉진법」에서는 개간허가, 그 허가의 양도 및 준공인가 권한(「농지확대개발촉진법」 제24조, 제25조, 제29조)은 농수산부장관이 갖고 있으나, 같은 법 제61조 및 같은 법 시행령 제37조제1항제3호·제4호에서 그 권한을 도지사에게 위임하고 있는바, 이러한 입법연혁에 따르면 농지 개간사업 업무의 효율적인 운영을 위해 개간허가와 관련된 권한 일체를 지방자치단체의 장에게 모두 위임하고 있다고 보는 것이 규정의 취지에도 부합합니다.

아울러 만약 「농경지조성법」 부칙 제3항의 경과조치에서 특별개간허가 권리의 양도에 관한 허가 및 준공인가(「개간촉진법」 제27조)를 규정하고 있지 않아 해당 부칙 제3항이 적용되지 않는다고 하더라도, 「농경지조성법」 제17조 및 제18조에서는 각각 개간허가 권리의 양도와 준공인가 권한이 허가관청에 있다고 규정하고 있고, 이 사안에서 허가관청은 「농경지조성법」 제2조제5항에 따라 도지사인데, 이후 「농지확대개발촉진법」 부칙 제3항 단서에서는 「농경지조성법」 제17조 및 제18조에 의한 사항은 종전의 예에 의하도록 규정하고 있고, 구 「농어촌정비법」 부칙 제5조제1항의 경과조치에서도 그 내용은 유지되었는바, 이 경우에도 특별개간허가 권리의 양도에 관한 허가 및 준공인가 권한은 도지사에게 있다고 보아야 한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「개간촉진법」 제23조제1항에 따라 특별개간허가를 받은 경우, 그 권리의 양도에 관한 허가 및 준공인가는 도지사에게 받아야 합니다.

다. 질의 나에 대해

「개간촉진법 시행령」 제45조에서는 개간허가를 받은 자가 사업계획의 일부를 변경하려는 경우에는 당해 허가관청의 허가를 받아 허가의 취지에 배치되지 않는 범위 내에서 이를 변경실시할 수 있다고 규정하고 있고, 「개간촉진법 시행령」을 대체한 「농경지조성법 시행령」

제31조에서는 「개간촉진법 시행령」과 동일하게 개간사업의 사업계획 변경허가에 대해서 규정하고 있으나, 「농경지조성법 시행령」 부칙에서는 「개간촉진법 시행령」 제45조에 따른 사업계획 변경허가에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않으며, 「농경지조성법」을 대체한 농지확대개발촉진법령에서는 사업계획 변경에 관한 사항을 규정하고 있지 않고, 「농경지조성법 시행령」 제31조에 따른 사업계획 변경허가에 대해서는 별도의 부칙을 규정하고 있지 않았으나, 「개간촉진법」 이후 특별개간허가 권한은 「농경지조성법」 및 「농지확대개발촉진법」 부칙에 따라 농수산부장관이 갖는다고 할 것입니다.

그런데 구 행정위임위탁규정이 개정됨에 따라 같은 영 제20조제15항제78호에서 농수산부장관은 특별개간허가 권한을 도지사 등에게 위임하고 있고, 그 내용은 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제32조제1항제1호에서도 유지되고 있어, 구 행정위임위탁규정의 시행으로 특별개간허가 권한은 도지사에게 위임된 것인바, 허가 권한과 부수되는 권한 중 일부만을 위임하면 관련 업무의 처리 권한자가 각각 달라 행정상 혼란이 발생할 수 있어 일반적으로 이미 허가받은 사항을 일부 변경하려는 경우 그 변경허가권한은 허가권자에게 있다고 할 것[58]이므로, 이 사안의 경우 사업계획의 변경허가는 도지사에게 받아야 한다고 할 것입니다.

그리고 「개간촉진법」이 폐지되고 「농경지조성법」이 제정되면서 개간허가, 그 허가의 양도 및 준공인가 권한(「농경지조성법」 제13조, 제17조, 제18조)은 「농경지조성법」 제2조제5항에 따른 허가관청으로 일원화되었고, 여기서 허가관청은 서울특별시·부산시 또는 도가 개간사업을 하는 경우에만 농림부장관의 권한으로 규정하고 그 외에는 모두 시·도지사 또는 시장·군수로 규정하고 있으며, 「농지확대개발촉진법」에서는 개간허가, 그 허가의 양도 및 준공인가 권한(「농지확대개발촉진법」 제24조, 제25조, 제29조)은 농수산부장관으로 규정하고 있으나, 같은 법 제61조 및 같은 법 시행령 제37조제1항제3호·제4호에서 그 권한을 도지사 등에게 위임하고 있는바, 이러한 입법연혁에 비추어 보면, 농지 개간사업 업무의 효율적인 운영을 위해 개간허가와 관련된 권한 일체를 지방자치단체의 장에게 모두 위임하고 있다고 보는 것이 규정의 취지에도 부합합니다.

아울러 현행 「농어촌정비법」에서는 종전의 개간사업이 포함된 농업생산기반 정비사업[59]에 대해서 같은 법 제9조에서는 농업생산기반 정비사업 시행자는 농업생산기반 정비사업 시행계획을 세워야 하고(제2항), 농업생산기반 정비사업 시행자는 농업생산기반 정비사업 시행계획을 수립하여 농림축산식품부장관에게 승인을 신청해야 하며(제6항), 승인받은 농업

58) 법제처 2021. 8. 24. 회신 21-0278 해석례 참조, 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.502 참조

59) 「농어촌정비법」 제2조제5호에 따른 농어촌생산기반 정비사업을 말하며, 이하 같음

생산기반 정비사업 시행계획을 변경하려는 경우에는 농림축산식품부장관 또는 시·도지사[60]의 승인을 받아야 하는데(제8항), 같은 법 제109조제1항 및 같은 법 시행령 제86조제1항제3호에서는 농림축산식품부장관의 같은 법 제9조제7항부터 제9항까지의 규정에 따른 농업생산기반 정비사업 시행계획의 승인 및 변경승인 권한[61]을 시·도지사에게 위임하고 있는바, 현행 농어촌정비법령에 따르더라도 이 사안의 경우 사업계획의 변경허가는 도지사에게 받아야 한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「개간촉진법」 제23조제1항에 따라 특별개간허가를 받은 경우, 사업계획의 변경허가는 도지사에게 받아야 합니다.

관계법령

개간촉진법(1963. 12. 16. 법률 제1532호로 일부개정되어 1963. 12. 16. 시행된 것)

제11조(허가의 양도, 상속, 자격) ① 개간허가를 받은 자는 서울특별시장·부산시장 또는 도지사의 허가를 받아 그 권리를 양도할 수 있다.
②·③ (생 략)

제12조(개간준공 인가) ① 제10조제2항의 규정에 의하여 개간허가를 받은 자가 공사를 준공하였을 경우에는 준공기일로부터 1월내에 서울특별시장·부산시장 또는 도지사에게 준공인가신청서를 제출하여야 한다.
② 전항에 신청서를 수리한 서울특별시장·부산시장 또는 도지사는 지체없이 준공검사를 실시하여 소정의 개간이 완료되었을 때에는 준공인가를 하여야 한다.

제23조(특별개간허가) ① 농림부장관은 전조제1항의 규정에 의한 개간허가신청을 수리하였을 경우에는 그 능력을 심사하여 적당하다고 인정될 때에는 다음 순위에 의하여 개간을 허가한다.
1. ~ 3. (생 략)
② ~ ⑤ (생 략)

제27조(특별개간허가의 양도, 상속, 자격, 준공인가, 취소) 제23조의 규정에 의하여 개간허가를 받은 자에 권리의 양도, 상속, 자격, 준공인가 및 취소에 관하여는 제11조 내지 제13조의 규정을 준용한다.

개간촉진법 시행령(1964. 11. 10. 대통령령 제1980호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것)

제45조(용도 및 계획변경) 개간허가를 받은 자가 부득이한 사유로 인하여 개간의 용도 및 사업계획의 일부를 변경하고자 할 경우에는 당해허가관청의 허가를 받아 허가의 취지에 배치되지 아니하는 범위내에서 이를 변경실시할 수 있다.

60) 광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사를 말함

61) 「농어촌정비법 시행규칙」 제57조에 해당하는 사항은 농림축산식품부장관의 승인을 받아야 하나, 이 사안의 경우는 「농어촌정비법 시행규칙」 제57조에 해당하지 않는 것을 전제로 함

농경지조성법(1967. 1. 16. 법률 제1872호로 제정되어 1967. 3. 18. 시행된 것)

제17조(허가의 양도·상속·자격) ① 개간허가를 받은 자는 허가관청의 허가 없이 타인에게 그 권리를 양도할 수 없다.

② 전항의 규정에 의한 허가관청의 허가는 개간허가를 받은 자가 개간할 능력을 상실하였거나 기타 불가피하다고 인정할 만한 특별한 사유가 있을 경우에 한하여야 한다.

③ (생 략)

제18조(개간준공인가) ① 제13조의 규정에 의하여 개간허가를 받은 자가 공사를 준공한 때에는 준공일로부터 30일이내에 허가관청에 준공인가신청서를 제출하여야 한다.

② 전항의 신청서를 수리한 허가관청은 지체 없이 준공검사를 실시하고, 소정의 개간이 완료된 때에는 준공인가를 하여야 한다.

법률 제1872호 농경지조성법 부칙

③ (경과조치) 개간촉진법에 의하여 행하여진 처분은 이 법에 의한 처분으로 본다. 다만, 개간촉진법 제14조 내지 제19조, 제21조 내지 제26조 및 제28조의3의 규정에 의한 사항에 관하여는 종전의 예에 의한다.

농경지조성법 시행령(1967. 4. 10. 대통령령 제2988호로 제정되어 같은 날 시행된 것)

제31조(용도 및 계획변경) 수허가자가 부득이한 사유로 인하여 개간의 용도 또는 사업계획의 일부를 변경하고자 할 경우에는 허가의 취지에 배치되지 아니하는 범위안에서 당해 허가관청의 허가를 받아 이를 변경실시할 수 있다.

대통령령 제2988호 농경지조성법 시행령 부칙

① (시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다.

② (폐지법령) 개간촉진법시행령은 이를 폐지한다.

법률 제2767호 농지확대개발촉진법 부칙

③ (경과조치) 이 법 시행당시 농경지조성법에 의하여 행하여진 처분은 이 법에 의한 처분으로 본다. 다만, 농경지조성법 제16조 내지 제23조 및 제29조와 동법 부칙 제3항 단서의 규정에 의한 사항에 관하여는 종전의 예에 의한다.

대통령령 제7699호 농지확대개발촉진법 시행령 부칙

이 영은 공포한 날로부터 시행한다.

행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정(1977. 2. 10. 대통령령 제8441호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것)

제20조 (농수산부소관) ① ~ ⑭ (생 략)

⑮ 농수산부장관은 다음의 권한을 서울특별시장 부산시장 또는 도지사에게 위임한다.

1. ~ 77. (생 략)

78. 농지확대개발촉진법 부칙 제3항의 규정에 의하여 종전의 예에 의하게 된 농경지조성법 제16조 내지 제23조 및 제29조와 동법 부칙 제3항의 단서규정에 의한 권한

79. ~ 98. (생 략)

법률 제4823호 농어촌정비법 부칙

제5조(농지확대개발촉진법 폐지에 따른 경과조치) ① 이 법 시행당시 종전의 농지확대개발촉진법에 의하여 시행중인 농지개발사업과 동법 제32조·제33조·제35조·제36조·제45조 및 동법 부칙 제3항 단서의 규정에 의한 사항에 관하여는 종전의 규정에 의한다.

②·③ (생 략)

질의제목 10 ▶ 안건번호 24-0783

민원인 – 개발제한구역 안의 농지에 대해 「농지법」 제63조에 따른 이행강제금을 부과하는 경우, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 제41조의2제2항제3호에 따라 그 부과를 유예할 수 있는지(「농지법」 제63조 등 관련)

01 질의요지

「농지법」 제63조제1항에서는 시장[62]·군수 또는 구청장은 같은 법 제11조제1항[63]에 따라 처분명령을 받은 후 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 지정기간까지 그 처분명령을 이행하지 아니한 자(제1호) 등 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 해당 농지의 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등이 감정평가한 감정가격 또는 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조에 따른 개별공시지가 중 더 높은 가액의 100분의 25에 해당하는 이행강제금을 부과한다고 규정하고 있는 한편,

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 "개발제한구역법"이라 함) 제30조의2제1항에서는 시장·군수·구청장은 같은 법 제30조제1항에 따른 시정명령을 받은 후 그 시정기간 내에 그 시정명령의 이행을 하지 아니한 자에 대하여 같은 법 제30조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액의 범위에서 이행강제금을 부과한다고 규정하고 있고, 같은 조 제9항에서는 같은 조 제1항에 따른 이행강제금의 부과기준이나 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 개발제한구역법 시행령 제41조의2제2항에서는 이행강제금 부과·징수 대상자 중 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 그 각 호에서 정하는 시기까지 이행강제금의 부과를 유예하거나 같은 영 별표 5에 따른 이행강제금의 가중기준을 적용하지 않을 수 있다고 규정하고 있는바,

개발제한구역 안의 농지에 대해 「농지법」 제63조에 따른 이행강제금을 부과하는 경우, 개발제한구역법 시행령 제41조의2제2항제3호에 따라 그 부과를 유예할 수 있는지?

62) 구를 두지 아니한 시의 시장을 말하며, 이하 「농지법」 제63조에서 같음

63) 제12조제2항에 따른 경우를 포함함

02 회답

개발제한구역 안의 농지에 대해 「농지법」 제63조에 따른 이행강제금을 부과하는 경우, 개발제한구역법 시행령 제41조의2제2항제3호에 따라 그 부과를 유예할 수 없습니다.

03 이유

입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 경우에는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 한 어떤 행위가 둘 이상의 법률의 요건에 모두 해당한다면 둘 이상의 법률이 모두 적용된다고 할 것인바[64], 개발제한구역법은 개발제한구역의 지정과 개발제한구역에서의 행위 제한 등에 관한 사항을 정함으로써 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률이고, 「농지법」은 농지의 소유·이용 및 보전 등에 필요한 사항을 정함으로써 농업 경쟁력 강화 및 국토 환경 보전을 목적(제1조)으로 하는 법률이며, 개발제한구역법령에 따른 "개발제한구역"은 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되어 도시·군관리계획으로 지정 또는 변경이 결정된 구역[65]을 말하고, 「농지법」에 따른 "농지"는 법적 지목(地目)을 불문하고 실제로 농작물 경작지로 이용되는 토지 등(제2조제1호)으로서 투기의 대상이 되지 않도록 공공복리에 적합하게 관리되어야 하는(제3조) 토지인바, 양 법은 서로 입법목적이나 규정사항을 달리하므로 일반적으로 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용되는 관계에 있다고 볼 수 없습니다.

그리고 개발제한구역법 제30조제1항에서는 같은 법 제12조제1항 단서 등에 따른 허가를 받지 않고 건축 및 용도변경 등의 행위를 하는 경우 등에 대해 공사의 중지 또는 건축물·공작물 등의 철거 등의 "시정명령"을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제30조의2제1항에서는 이러한 시정명령을 이행하지 아니한 자에 대해 이행강제금을 부과하도록 규정하고 있는 한편, 「농지법」 제11조제1항에서는 같은 법 제10조에 따라 농업경영에 이용하지 않는 농지를 일정한 기간 내 처분하도록 한 처분의무 기간에 농지를 처분하지 않는 경우 등에 해당하는 농지소유자에게 6개월 이내에 그 농지를 "처분할 것을 명"할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 법 제42조제1항에서는 같은 법 제34조제1항에 따른 농지전용허가를 받지 않고 농지를 전용한

64) 대법원 2010. 9. 9. 선고 2008두22631 판결례 참조
65) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제38조 참조

경우 등에 해당하면 그 행위를 한 자에게 기간을 정하여 “원상회복을 명”할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제63조제1항에서는 같은 법 제11조에 따른 “처분명령” 또는 같은 법 제42조에 따른 “원상회복 명령”을 받은 후 이러한 명령을 이행하지 않은 자에 대해 이행강제금을 부과하도록 규정하고 있는바, 이러한 양 법의 규정들을 종합해보면, 각각의 법률에서 규정하고 있는 시정명령 등의 불이행에 따라 이행강제금이 부과되는 것으로서, 개발제한구역법에 따라 부과되는 이행강제금과 「농지법」에 따라 부과되는 이행강제금은 서로 별개의 이행강제금이라 할 것이고, 이는 동일한 구역의 토지라 하더라도 해당 토지에서 각각의 법률에 따른 시정명령 등을 받고 이를 이행하지 않은 경우라면 개발제한구역법과 「농지법」에 따른 이행강제금이 각각 부과되는 것[66]이므로, 개발제한구역법에 따른 이행강제금 부과 규정과 「농지법」에 따른 이행강제금 부과 규정 또한 어느 것이 우선하여 배타적으로 적용되는 관계에 있다고 볼 수 없습니다.

나아가 이러한 체계는 이행강제금 부과의 유예 등에 관한 예외규정에 대해서도 동일하게 적용되는 것으로, 개발제한구역법 시행령 제41조의2제2항에서는 이행강제금의 부과를 유예하거나 이행강제금의 가중기준을 적용하지 않을 수 있는 경우를 각 호로 규정하면서 같은 항 제3호에서는 정비사업을 시행하는 자의 경우 해당 정비사업이 완료되는 시기까지로 규정하고 있는데, 이러한 규정은 개발제한구역법에 따라 부과되는 이행강제금에 한정하여 적용되는 것이지 「농지법」에 따라 부과되는 이행강제금이 포함된다고 볼 수는 없고, 마찬가지로 「농지법」에 따른 이행강제금은 「농지법」에 따라 부과되는 것으로서 그 부과의 유예 또한 「농지법」에서 정한 바에 의하여야 할 것인데, 「농지법」에서는 이행강제금 부과를 유예할 수 있는 사유로 개발제한구역법에 따라 정비사업을 시행하는 경우 등을 별도로 명시하고 있지 않은바, 정비사업에 포함된 토지라는 이유로 「농지법」에 따른 이행강제금도 개발제한구역법령에 따라 유예할 수는 없다고 할 것입니다.

따라서 개발제한구역 안의 농지에 대해 「농지법」 제63조에 따른 이행강제금을 부과하는 경우, 개발제한구역법 시행령 제41조의2제2항제3호에 따라 그 부과를 유예할 수 없습니다.

66) 법제처 2021. 4. 9. 회신 21-0023 해석례 참조

관계법령

농지법

제63조(이행강제금) ① 시장(구를 두지 아니한 시의 시장을 말한다. 이하 이 조에서 같다)·군수 또는 구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 해당 농지의 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가법인등이 감정평가한 감정가격 또는 「부동산 가격공시에 관한 법률」 제10조에 따른 개별공시지가(해당 토지의 개별공시지가가 없는 경우에는 같은 법 제8조에 따른 표준지공시지가를 기준으로 산정한 금액을 말한다) 중 더 높은 가액의 100분의 25에 해당하는 이행강제금을 부과한다.

1. 제11조제1항(제12조제2항에 따른 경우를 포함한다)에 따라 처분명령을 받은 후 제11조제2항에 따라 매수를 청구하여 협의 중인 경우 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 지정기간까지 그 처분명령을 이행하지 아니한 자
2. 제42조에 따른 원상회복 명령을 받은 후 그 기간 내에 원상회복 명령을 이행하지 아니하여 시장·군수·구청장이 그 원상회복 명령의 이행에 필요한 상당한 기간을 정하였음에도 그 기한까지 원상회복을 아니한 자

② ~ ⑧ (생 략)

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법

제30조의2(이행강제금) ① 시장·군수·구청장은 제30조제1항에 따른 시정명령을 받은 후 그 시정기간 내에 그 시정명령의 이행을 하지 아니한 자에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액의 범위에서 이행강제금을 부과한다.

1. ~ 2. (생 략)

② ~ ⑧ (생 략)

⑨ 제1항에 따른 이행강제금의 부과기준이나 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령

제41조의2(이행강제금의 산정·부과) ① 법 제30조의2제1항에 따른 이행강제금의 산정기준은 별표 5와 같다.

② 제1항에 따른 이행강제금 부과·징수 대상자 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대해서는 그 각 호에서 정하는 시기까지 이행강제금의 부과를 유예하거나 별표 5에 따른 이행강제금의 가중기준을 적용하지 않을 수 있다.

1. 공익사업의 시행을 위하여 법 제4조제1항에 따라 개발제한구역의 해제에 관한 도시·군관리계획이 입안된 경우 해당 해제대상지역의 이행강제금 부과·징수 대상자: 개발제한구역의 해제에 관한 도시·군관리계획 결정을 고시한 시기까지
2. 해제대상지역으로 이전할 자: 입주시기나 완료시기를 고려하여 그 이전이 가능한 시기까지
3. 정비사업을 시행하는 자: 해당 정비사업이 완료되는 시기까지

③ ~ ⑥ (생 략)

제2절 산림

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0644

민원인 – 산지에서의 지역 등 지정 또는 결정에 관한 협의기준인 '해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율'의 의미(「산지관리법 시행령」 별표 2 등 관련)

01 질의요지

「산지관리법 시행령」 제7조제2항 본문에서는 산림청장등[67]은 「산지관리법」 제8조제1항에 따라 관계 행정기관의 장으로부터 산지에서의 지역등[68]의 지정 또는 결정에 관한 협의를 요청받았을 때에는 해당 산지에 대하여 현지조사를 실시한 후 같은 영 별표 2의 기준에 따라 협의요청사항을 검토하고 의견을 통보해야 한다고 규정하고 있고, 같은 표 제13호 각 목 외의 부분 본문에서는 협의기준의 하나로 '지역등으로 지정·결정하려는 산지의 면적이 30만제곱미터 이상인 경우로서 해당 산지를 전용 또는 일시사용하려는 경우에는 해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율은 매년 산림청장이 발표하는 임업통계연보상의 해당 시·군·구의 산지면적에 대한 보전산지의 면적비율(보전산지의 면적 비율이 100분의 50 이하인 경우에는 100분의 50을 말하며, 이하 같음)을 초과해서는 아니 된다'고 규정하고 있는바,

「산지관리법 시행령」 별표 2 제13호 각 목 외의 부분 본문에 따라 '해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율'이 협의기준에 적합한지를 판단할 때, '해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율'은 '전체 사업계획부지의 면적'에 대한 보전산지의 면적비율로 산정하는지, 아니면 '전체 사업계획부지 중 산지의 면적'에 대한 보전산지의 면적비율로 산정하는지?[69]

67) 산림청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하며, 이하 같음.

68) 다른 법률에 따라 특정 목적으로 보전 또는 이용하기 위한 지역·지구 및 구역 등을 말하며(「산지관리법 시행령」 제4조제1항 각 호 외의 부분 참조), 이하 같음

69) 사업계획부지에 보전산지, 보전산지 외의 산지 및 산지 외의 토지가 모두 포함된 경우를 전제로 함.

02 회답

「산지관리법 시행령」 별표 2 제13호 각 목 외의 부분 본문에 따라 '해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율'이 협의기준에 적합한지를 판단할 때 '해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율'은 '전체 사업계획부지의 면적'에 대한 보전산지의 면적비율로 산정합니다.

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석 방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[70], 「산지관리법」 제8조에서는 관계 행정기관의 장은 다른 법률에 따라 산지를 특정 용도로 이용하기 위하여 지역등으로 지정하거나 결정하려면 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등과 미리 협의해야 한다고 규정하면서(제1항), 그 협의의 기준을 대통령령으로 위임함에 따라(제3항), 같은 법 시행령 별표 2 제13호 각 목 외의 부분 본문에서는 산지에서의 지역등의 지정·결정에 관한 협의기준의 하나로 '지역등으로 지정·결정하려는 산지의 면적이 30만제곱미터 이상인 경우로서 해당 산지를 전용 또는 일시사용하려는 경우에는 "해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율"은 매년 산림청장이 발표하는 임업통계연보상의 해당 시·군·구의 산지면적에 대한 보전산지의 면적비율을 초과해서는 아니 된다'고 규정하고 있는바, 이 때 "해당 사업계획부지"는 같은 법 제8조에서 산림청장등과 협의해야 하는 것으로 규정하고 있는 '다른 법률에 따라 산지를 특정 용도로 이용하기 위한 지역등의 지정·결정'의 대상이 되는 개발사업 등의 사업계획부지를 의미하는 것으로, 이 사안의 경우 해당 규정에서 '사업계획부지에 대한 보전산지 면적비율'을 산정할 때 산지에 해당하지 않는 토지를 제외하도록 명시적으로 규정하고 있지 않은 이상, 그 사업계획에 포함된 모든 부지를 의미하는 것으로 해석됩니다.

그리고 산지에서의 지역등 지정에 관한 산림청장등과의 협의 제도의 입법연혁을 살펴보면, 2007년 1월 26일 법률 제8283호로 구 「산지관리법」을 일부개정할 당시 같은 법 제8조 제1항에 따른 산림청장과의 협의 대상 지역등 지정의 범위를 산지 중 '보전산지'에서의 지역등 지정에서 전체 '산지'에서의 지역등 지정으로 확대한 것은 사전협의 없이 산지에 지역등을

70) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

지정할 경우 산지전용허가기준을 충족하지 못하는 산지가 해당 구역 등에 포함될 수 있고 이 경우 전용허가가 불가능하게 되어 구역 지정에도 불구하고 개발을 할 수 없게 되는 문제가 발생할 우려 등을 개선하기 위하여 미리 산림청장과 협의를 거치도록 한 것[71]이고, 2008년 7월 24일 대통령령 제20936호로 구 「산지관리법 시행령」을 일부개정하여 보전산지 비율이 높은 지방자치단체의 지역등 지정을 원활하게 하려는 목적으로 같은 영 별표 2 제13호에 따른 사업계획부지에 편입되는 보전산지 면적비율의 상한을 '사업계획부지 총면적의 100분의 50'에서 '해당 시·군·구의 산지 면적 대비 보전산지의 면적비율[72]'로 완화하였는바, 「산지관리법 시행령」 별표 2 제13호 각 목 외의 부분 본문의 "해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율"을 산정하는 경우 그 문언과 달리 이를 '해당 사업계획부지 중 산지 면적 대비 보전산지 면적비율'로 축소해석하여 지역등 지정·결정을 위한 협의기준이 강화되는 방향으로 해석하는 것은 개발과 보전의 조화를 이루고 합리적인 산지 관리를 도모하기 위해 개정되어 온 산지관리법령의 입법연혁에도 부합하지 않습니다.

한편 「산지관리법 시행령」 별표 2 제13호 각 목 외의 부분 본문에 따른 '해당 사업계획부지'를 '산지' 및 '산지 외 토지'로 구성되는 전체 사업계획부지로 보아 '산지 및 산지 외 토지를 포함하는 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율'이 해당 시·군·구의 '산지면적에 대한 보전산지의 면적비율' 이하일 것을 협의기준으로 보게 되면, 경우에 따라서는 지역등 지정·결정으로 인하여 시·군·구의 산지에 대한 보전산지 면적비율이 줄어드는 결과가 발생할 수 있으므로, 보전산지 면적비율이 줄어드는 것을 방지하기 위해서라도 '해당 사업계획부지 중 산지에 대한 보전산지의 면적비율'을 기준으로 "해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율"을 산정해야 한다는 의견이 있습니다.

그러나 「산지관리법 시행령」 별표 2에서는 산지에서의 지역등 지정·결정 협의기준으로 제13호의 면적비율 기준 외에도 '보전산지는 특정 용도로 이용하려는 지역등의 지정·결정의 목적에 필요한 최소한의 면적'으로 할 것(제1호), 보전산지에 대하여 산지의 보전과 유사한 목적으로 지역등을 지정·결정하려는 경우에는 '그 지정·결정의 범위가 최소화'되도록 할 것(제4호) 등의 기준을 추가적으로 마련하고 있고, 산림청장등은 지역등 지정·결정에 관한 협의 시 이러한 기준을 종합적으로 고려하도록 하고 있는 점에 비추어 볼 때, 시·군·구의 보전산지 면적비율 축소 등에 대한 우려만으로 같은 표 제13호에 규정된 "해당 사업계획부지"의 의미를 임의로 축소해석할 수는 없다고 할 것이므로, 그러한 의견은 의견은 타당하지 않습니다.

---

71) 2006. 5. 11. 의안번호 제174385호로 발의된 산지관리법 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 농림해양수산위원회 검토보고서 참고

72) 보전산지 면적비율이 100분의 50 미만인 경우에는 100분의 50

따라서 「산지관리법 시행령」 별표 2 제13호 각 목 외의 부분 본문에 따라 '해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율'이 협의기준에 적합한지를 판단할 때 '해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율'은 '전체 사업계획부지의 면적'에 대한 보전산지의 면적비율로 산정합니다.

관계법령

산지관리법 시행령

제7조(산지에서의 지역등의 지정·결정에 관한 협의 통보) (생 략)

② 산림청장등은 법 제8조제1항에 따라 관계 행정기관의 장으로부터 산지에서의 지역등의 지정 또는 결정에 관한 협의를 요청받았을 때에는 해당 산지에 대하여 현지조사를 실시한 후 별표 2의 기준에 따라 협의요청사항을 검토하고 의견을 통보하여야 한다. 다만, 산림청장등은 관계 행정기관의 장이 법 제18조의2제1항에 따른 산지전용타당성조사를 받은 경우에는 현지조사를 실시하지 아니하고 검토할 수 있다.

③ ~ ⑤ (생 략)

[별표 2]

산지에서의 지역 등의 협의기준(제7조제2항 관련)

1. ~ 12. (생 략)

13. 지역등으로 지정·결정하려는 산지의 면적이 30만제곱미터 이상인 경우로서 해당 산지를 전용 또는 일시사용하려는 경우에는 해당 사업계획부지에 대한 보전산지의 면적비율은 매년 산림청장이 발표하는 임업통계연보상의 해당 시·군·구의 산지면적에 대한 보전산지의 면적비율(보전산지의 면적 비율이 100분의 50 이하인 경우에는 100분의 50)을 초과하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
   가. 스키장, 집단묘지(공설묘지 및 법인묘지에 한정한다), 대중형 골프장, 송·배선 철탑 또는 풍력발전시설을 설치하기 위한 경우
   나. 지역등으로 지정하여 전용하려는 산지의 평균 입목축적이 산림기본통계상 해당 시·군·구의 평균 입목축적 이하인 지역에 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지 또는 「관광진흥법」 제2조제7호에 따른 관광단지를 조성하는 경우
   다. 지역등으로 지정하여 전용하려는 산지의 평균경사도가 15도 미만이고 평균입목축적(산불발생·솎아베기 또는 인위적인 벌채를 실시한 후 5년이 지나지 아니한 때에는 그 산불발생·솎아베기 또는 벌채전의 입목축적으로 환산하여 적용한다)이 산림기본통계상 해당 시·군·구의 평균입목축적의 75퍼센트 미만인 경우에는 해당 사업계획부지의 100분의 10의 범위에서 보전산지를 추가하여 편입할 수 있다.

14. (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-1164

민원인 – 산지에 개인묘지를 설치하려는 경우 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가를 별도로 받아야 하는지 여부(「산지관리법」 제14조 등 관련)

01 질의요지

「산지관리법」 제14조제1항 본문에서는 산지전용을 하려는 자는 그 용도를 정하여 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등[73]의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 같다고 규정하고 있는 한편,

「장사 등에 관한 법률」(이하 "장사법"이라 함) 제14조제2항 전단에서는 개인묘지[74]를 설치한 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 묘지를 설치한 후 30일 이내에 해당 묘지를 관할하는 시장등[75]에게 신고(이하 "사후신고"라 함)해야 한다고 규정하고 있는바,

산지[76]에 개인묘지를 설치하려는 경우 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가를 별도로 받아야 하는지, 아니면 장사법 제14조제2항 전단에 따른 개인묘지 설치 사후신고만 하면 되는지?[77]

02 회답

산지에 개인묘지를 설치하려는 경우 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가를 별도로 받아야 합니다.

---

73) 산림청장, 시·도지사 또는 시장(특별자치도 또는 특별자치시의 경우는 특별자치도지사 또는 특별자치시장을 말함)·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함)을 말하며(「산지관리법」 제3조의2제7항 및 제3조의5제3항 참조), 이하 같음.

74) 장사법 제14조제1항제1호에 따른 개인묘지를 말하며, 이하 같음.

75) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함)을 말하며(장사법 제5조제2항 및 제8조제1항 참조), 이하 같음.

76) 「산지관리법」 제2조제1호에 따른 산지를 말하며, 이하 같음.

77) 장사법 제16조제1항제1호에 따른 개인자연장지를 설치하려는 경우가 아니며, 전제함.

03 이유

입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 사항에 대해 각각 그 기준을 규정하고 있는 경우 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 그 사항에 관하여는 각 법률에 따른 기준을 모두 충족해야 할 것입니다.[78]

그런데 「산지관리법」은 산지를 합리적으로 보전하고 이용하여 임업의 발전과 산림의 다양한 공익기능의 증진을 도모함으로써 국민경제의 건전한 발전과 국토환경의 보전에 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률인 반면, 장사법은 장사(葬事)의 방법과 장사시설의 설치·조성 및 관리 등에 관한 사항을 정하여 보건위생상의 위해(危害)를 방지하고, 국토의 효율적 이용과 공공복리 증진에 이바지하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 두 법은 입법목적을 달리하고 두 법 중 어느 법이 다른 법에 대해 우선적 효력을 가진다거나 어느 법에서 다른 법의 적용을 배제한다는 규정도 없습니다.

그리고 「산지관리법」 제2조제2호에서는 "산지전용"이란 산지를 조림, 숲 가꾸기, 입목의 벌채·굴취(가목), 토석 등 임산물의 채취(나목), 대통령령으로 정하는 임산물의 재배(다목) 또는 산지일시사용(라목)에 해당하는 용도 외로 사용하거나 이를 위하여 산지의 형질을 변경하는 것을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제14조제1항 본문에서는 산지전용을 하려는 자는 허가를 받아야 한다고 규정하고 있는데, 장사법 제14조제2항 전단에서는 개인묘지의 설치를 사후신고 대상으로 규정하면서, 산지에 개인묘지를 설치하는 경우 「산지관리법」에 따른 산지전용허가를 받지 않아도 된다거나 개인묘지 설치 사후신고로 산지전용허가가 의제된다는 등의 규정을 두고 있지도 않은바, 산지에서 「산지관리법」 제2조제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도에 해당하지 않는 개인묘지 설치 행위를 하려는 경우 같은 법 제14조제1항 본문에 따라 산지전용 허가를 별도로 받아야 할 것입니다.

따라서 산지에 개인묘지를 설치하려는 경우 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가를 별도로 받아야 합니다.

78) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례 참조

관계법령

산지관리법

제14조(산지전용허가) ① 산지전용을 하려는 자는 그 용도를 정하여 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 같다. (단서 생략)

② ~ ⑤ (생 략)

장사 등에 관한 법률

제14조(사설묘지의 설치 등) ① 국가, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 아닌 자는 다음 각 호의 구분에 따른 묘지(이하 "사설묘지"라 한다)를 설치·관리할 수 있다.

1. 개인묘지 : 1기의 분묘 또는 해당 분묘에 매장된 자와 배우자 관계였던 자의 분묘를 같은 구역 안에 설치하는 묘지

2. ~ 4. (생 략)

② 개인묘지를 설치한 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 묘지를 설치한 후 30일 이내에 해당 묘지를 관할하는 시장등에게 신고하여야 한다. (후단 생략)

③ ~ ⑨ (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 23-1175

민원인 – 「건설산업기본법」에 따른 조경식재·시설물공사업의 기술인력으로 이미 등록된 사람을 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 숲길 조성·관리사업의 기술인력으로 중복하여 인정할 수 있는지 여부(「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제24조 등 관련)

01 질의요지

「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」(이하 "산림자원법"이라 함) 제24조제1항 각 호 외의 부분에서는 산림사업을 하려는 자는 같은 항 각 호의 요건을 모두 갖추어 산림사업의 종류별로 등록을 신청해야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 제2호에서는 그 등록 요건 중 하나로 "기술수준과 자본금 등 대통령령으로 정하는 요건"을 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제25조 및 별표 2 제7호에서는 숲길 조성·관리를 위하여 시행하는 사업(이하 "숲길 조성·관리사업"이라 함)을 할 수 있는 법인의 등록기준 중 기술수준으로 기술중급 이상인 산림공학기술자 또는 기술중급 이상인 녹지조경기술자 1명 이상 등 일정한 자격 소지자를 둘 것을 인력 요건으로 정하면서, 같은 표 비고 제3호에서는 같은 표에서 인력이란 '상시 근무'하는 사람을 말한다고 규정하고 있는바,

「건설산업기본법」 제10조, 같은 법 시행령 제13조 및 별표 2 제2호마목에 따라 조경식재·시설물공사업의 기술인력으로 등록된 사람(이하 "조경식재·시설물공사업 기술인력"이라 함)을 산림자원법 시행령 별표 2 제7호에 따라 숲길 조성·관리사업의 등록을 위해 요구되는 기술수준을 충족하기 위한 인력으로 중복하여 인정할 수 있는지?

02 회답

조경식재·시설물공사업 기술인력을 산림자원법 시행령 별표 2 제7호에 따라 숲길 조성·관리사업의 등록을 위해 요구되는 기술수준을 충족하기 위한 인력으로 중복하여 인정할 수 없습니다.

03 이유

산림자원법 시행령 별표 2에서는 숲길 조성·관리사업 등 산림사업을 할 수 있는 법인의 등록기준 중 '기술수준'으로 일정한 자격을 가진 인력을 갖출 것을 요구하면서, 비고란 제3호에서 같은 표에서의 "인력"이란 상시 근무하는 사람을 말한다고 규정하고 있고, 「건설산업기본법 시행령」 별표 2에서는 조경식재·시설물공사업 등 건설업의 등록기준 중 '기술능력'으로 일정한 자격을 가진 인력을 갖출 것을 요구하면서, 같은 표 비고 제1호가목에서 기술인력에 해당하는 사람은 '상시 근무'(다른 사업을 영위하는 경우에는 상시 근무에 지장이 없는 경우로 한정함)하는 사람이어야 한다고 규정하고 있는바, 산림자원법령에 따른 숲길 조성·관리사업과 건설산업기본법령에 따른 조경식재·시설물공사업 모두 등록에 필요한 기술인력이 '상시 근무'하는 사람일 것을 요구하고 있는데, '상시 근무'하는 사람이란 통상적으로 정해진 근무시간 중에는 계속 근무하는 사람을 의미하고[79], 통상 근로자는 1일 8시간 근무하는 점에 비추어 볼 때[80], 하나의 업종에 상시 근무하는 인력으로 등록된 사람이 통상적으로 정해진 근무 시간 중에 다른 업종에도 '상시 근무'할 수 있다고 보기는 어려우므로, 조경식재·시설물공사업 기술인력은 산림자원법령에 따른 숲길 조성·관리사업의 기술수준을 충족하기 위한 상시 근무 인력으로서의 요건을 갖추었다고 볼 수는 없습니다.

그리고 산림자원법 시행령 별표 2의 비고에서는 같은 표에 따른 산림사업의 종류로 이미 등록한 법인이 다른 종류의 산림사업 등록을 추가로 신청하는 경우(제1호), 둘 이상의 산림사업의 종류로 동시에 등록을 신청하는 경우(제2호) 또는 「산림보호법」 제21조의9제1항에 따라 등록한 나무병원이 둘 이상의 산림사업의 종류로 산림사업법인을 등록하려는 경우(제2호의3)에는 등록하려는 산림사업의 종류에 같은 종류 및 등급의 기술자가 요구되는 경우 해당 기술자를 이미 갖춘 것으로 본다고 명시적으로 규정하고 있는 반면, 「건설산업기본법」에 따라 조경식재·시설물공사업 등록을 한 법인이 산림사업 등록을 추가로 신청하는 경우에 대해서는 기술수준으로 요구되는 인력의 중복인정 여부 등을 별도로 규정하고 있지 않은바, 조경식재·시설물공사업 기술인력을 숲길 조성·관리사업의 등록을 위해 요구되는 인력으로 인정할 수는 없다고 보는 것이 산림자원법 시행령 별표 2의 규정체계에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

또한 산림자원법에서 산림사업법인 등록제도를 둔 취지는 산림사업의 부실시공을 방지하고 산림사업 전반에 걸쳐 시장 질서를 확립함으로써 공정한 경쟁을 통한 발전과 관련

79) 법제처 2022. 10. 28. 회신 22-0258 해석례 참조

80) 서울고등법원 2021. 12. 24. 선고 2021누48764 판결례 참조

기술향상을 도모하기 위한 것으로서[81], 같은 법 시행령 제25조 및 별표 2에서 산림사업별로 정하고 있는 일정 인원 수 이상의 기술인력을 갖춘 경우에만 산림사업을 영위할 수 있는 최소한의 기술능력을 갖춘 것으로 인정된다고 할 것이므로[82], 명문의 근거 없이 조경식재·시설물공사업 기술인력을 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 중복하여 등록할 수 있다고 해석하는 것은 산림자원법령에 따른 산림사업법인 등록제도의 목적 및 취지에도 부합하지 않습니다.

더욱이 건설산업기본법령에서는 부실공사를 방지하고 국민의 건강과 생명, 재산을 보호하기 위하여 건설업의 등록기준으로 일정한 기술능력·자본금·시설 및 장비 등을 규정하면서[83], 건설업 내의 세부 업종간은 물론 다른 업종과 중복되는 기술인력을 인정하려는 경우에는 그 인정 여부 및 기준을 명시하여 규정하고 있는바, 이에 따라 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 이미 등록된 사람을 건설산업기본법령에 따른 조경공사업의 기술인력으로 중복하여 등록할 수 없는 점[84]에 비추어 보면, 반대로 조경공사업의 기술인력으로 이미 등록된 사람을 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 중복하여 등록할 수도 없다고 보아야 하고, 건설산업기본법령에 따른 조경식재·시설물공사업 기술인력에 대해서도 이와 달리 볼 만한 규정을 두고 있지 않으므로, 조경식재·시설물공사업 기술인력을 숲길 조성· 관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 중복하여 등록할 수 없다고 보는 것이 건설산업 기본법령과 산림자원법령의 내용과 체계에 부합하는 조화로운 해석이라고 할 것입니다.

따라서 조경식재·시설물공사업 기술인력을 산림자원법 시행령 별표 2 제7호에 따라 숲길 조성·관리사업의 등록을 위해 요구되는 기술수준을 충족하기 위한 인력으로 중복하여 인정할 수 없습니다.

81) 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제정(2005. 8. 4. 법률 제7678호로 제정된 것) 당시 국회 농림해양수산위원회 검토보고서 참조

82) 법제처 2024. 2. 19. 회신 23-0835 해석례 참조

83) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013두12386 판결례 참조

84) 법제처 2024. 2. 19. 회신 23-0835 해석례 참조

관계법령

산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률

제24조(산림사업법인의 등록) ① 산림사업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 대통령령으로 정하는 산림사업의 종류별로 시·도지사에게 등록을 신청하여야 한다. 등록한 사항 중 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경한 경우에는 농림축산식품부령으로 정하는 기간 안에 변경등록을 신청하여야 한다.

1. 「민법」에 따른 법인 또는 「협동조합 기본법」 제2조에 따른 협동조합 및 협동조합연합회
2. 기술수준과 자본금 등 대통령령으로 정하는 요건

② ~ ⑦ (생 략)

산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령

제25조(산림사업법인의 등록기준) 법 제24조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 요건"이란 별표 2의 등록기준을 말한다.

[별표 2]

산림사업을 할 수 있는 법인의 등록기준(제25조 관련)

산림사업의 종류	산림사업의 범위	자격요건		
		기술수준	자본금	시설
1. ~ 6.	(생 략)			사무실
7. 숲길 조성·관리	숲길 조성·관리	다음의 모두에 해당하는 인력요건 1) 기술중급 이상인 산림공학기술자 또는 기술중급 이상인 녹지조경기술자 1명 이상 2) 기술초급 이상인 산림공학기술자 또는 기술초급 이상인 녹지조경기술자 2명 이상	3억원 이상	

비고

1. ~ 2의3. (생 략)
3. 이 표에서 "인력"이란 상시 근무하는 사람을 말하며, 법, 「국가기술자격법」 등 자격 관련 법령에 따라 그 자격이 정지된 사람은 제외한다.
4.·5. (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0012

민원인 – 「농어촌정비법」 제83조제2항에 따른 관광농원의 사업계획에 포함되는 영농체험시설 부지 중 임업용산지에 해당하는 부지에서 개발사업계획에 따라 「산지관리법」 제2조제2호다목의 임산물을 재배하려는 경우가 같은 법 제14조에 따른 산지전용허가 대상인지 여부(「산지관리법」 제14조 등 관련)

01 질의요지

「산지관리법」 제14조제1항 본문에서는 산지전용을 하려는 자는 그 용도를 정하여 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등[85]의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 같다고 규정하고 있는 한편,

「농어촌정비법」 제83조제2항 전단에서는 관광농원을 개발하려는 자는 사업계획(이하 "개발사업계획"이라 함)을 세워 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있는바,

관광농원사업[86]을 경영하기 위해 관광농원을 개발하려는 경우로서, 그 개발사업계획에 포함되는 영농 체험시설[87] 부지 중 임업용산지[88]에 해당하는 부지에서 개발사업계획에 따라 「산지관리법」 제2조제2호다목에 따른 '대통령령으로 정하는 임산물'(이하 "임산물"이라 함)을 재배[89]하려는 경우가 같은 법 제14조에 따른 산지전용허가 대상에 해당하는지?

85) 산림청장, 시·도지사 또는 시장(특별자치도 또는 특별자치시의 경우는 특별자치도지사 또는 특별자치시장을 말함)·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함)을 말하며(「산지관리법」 제3조의2제7항 및 제3조의5제3항 참조), 이하 같음.

86) 「농어촌정비법」 제2조제16호나목에 따른 관광농원사업(농어촌의 자연자원과 농림수산 생산기반을 이용하여 지역특산물 판매시설, 영농 체험시설, 체육시설, 휴양시설, 숙박시설, 음식 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 이에 딸린 시설을 갖추어 이용하게 하는 사업)을 말하며, 이하 같음.

87) 「농어촌정비법 시행규칙」 별표 3 제2호에 따른 영농 체험시설을 말하며, 이하 같음.

88) 「산지관리법」 제4조제1항제1호가목에 따른 임업용산지를 말하며, 이하 같음.

89) 성토(흙쌓기) 또는 절토(땅깎기) 등을 통하여 지표면으로부터 높이 또는 깊이 50센티미터 이상 형질변경을 수반하는 경우와 시설물의 설치를 수반하는 경우가 아님을 전제함.

02 회답

관광농원사업을 경영하기 위해 관광농원을 개발하려는 경우, 그 개발사업계획에 포함되는 영농 체험시설 부지 중 임업용산지에 해당하는 부지에서 개발사업계획에 따라 임산물을 재배하려는 경우는 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가 대상에 해당합니다.

03 이유

「산지관리법」 제2조제2호에서는 "산지전용"이란 산지를 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 '용도' 외로 사용하거나 이를 위하여 산지의 형질을 변경하는 것을 말한다고 정의하고 있고, 같은 호 다목에서는 산지전용에 해당하지 않는 용도의 하나로 '임산물의 재배'를 규정하고 있으며, 같은 법 제14조제1항 본문에서는 "산지전용"을 하려는 자는 그 용도를 정하여 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 같다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 「농어촌정비법」 제83조제2항 전단에 따라 관광농원을 개발하려는 경우, '그 개발사업계획 부지에 포함된 산지에서 개발사업계획에 따라 임산물을 재배하는 것'이 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가의 대상이 되는 "산지전용"에 해당하는지가 문제됩니다.

먼저 「산지관리법」은 산지를 합리적으로 보전하고 이용하여 임업의 발전과 산림의 다양한 공익기능의 증진을 도모함으로써 국민경제의 건전한 발전과 국토환경의 보전에 이바지함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법에서는 산지를 그 본래 용도 외의 용도로 사용하는 '산지전용' 행위를 엄격히 제한하고 있는데, 이 사안에서 임업용산지를 포함하는 부지를 개발하여 경영하려는 관광농원사업은 '농어촌의 자연자원과 농림수산 생산기반을 이용하여 영농 체험시설을 제공하는 사업(「농어촌정비법」 제2조제16호나목 참조)'으로서, 그 개발사업계획에 따른 '영농 체험시설' 부지에 포함된 임업용산지에서 그 개발사업계획에 따라 임산물을 재배하는 것은 해당 산지를 온전히 '임산물을 재배하는 용도'로 사용하는 것이 아니라, 영농 체험시설을 제공하는 관광농원사업의 일부로서 사용하는 것으로서, 「산지관리법」 제2조제2호에 따른 "산지전용"에 해당한다고 할 것입니다.

그리고 「산지관리법」 제18조제5항 본문 및 같은 법 시행령 제20조제6항에 따라 산지전용 시 공통으로 적용되는 허가기준을 규정하고 있는 같은 법 시행령 별표 4 제1호를 살펴보면,

같은 호 마목에서 '사업계획 및 산지전용면적이 적정하고 산지전용방법이 자연경관 및 산림훼손을 최소화하고 산지전용 후의 복구에 지장을 줄 우려가 없을 것'을 규정하면서, 같은 목 9)에서는 그 세부기준으로 '사업계획부지 안에 원형으로 존치되거나 조성되는 산림 또는 녹지에 대하여 적정한 관리계획이 수립될 것'을 규정하고 있는바, 산림이 원형 그대로 존치되거나 새롭게 산림이 조성되는 경우라도 '사업계획부지 안에 포함되는 경우'에는 산지전용허가 대상이 된다고 할 것이므로, 관광농원 개발사업계획에 따라 영농 체험시설 부지 안에 포함되는 '산지'에서 임산물을 재배하려는 경우라도 '산지전용허가' 대상으로 보아야 하고, '산지전용허가' 대상에서 제외하려는 경우에는 관광농원 개발사업 부지에 편입되지 않도록 해야 한다고 보는 것이 산지전용허가 관련 규정체계에 부합하는 해석입니다.

또한 「산지관리법」 제12조제1항에서는 '임업용산지'에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하기 위하여 산지전용 또는 산지일시사용을 하는 경우를 제외하고는 산지전용 또는 산지일시사용을 할 수 없다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서는 '농림어업용 생산·이용·가공시설 및 농어촌휴양시설로서 대통령령으로 정하는 시설의 설치'를 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조제5항제2호에서는 '「농어촌정비법」 제82조 및 같은 법 제83조에 따라 개발되는 3만 제곱미터 미만의 농어촌 관광휴양단지 및 관광농원'을 규정하고 있는바, 이는 산지에서 이루어지는 「농어촌정비법」 제83조에 따른 '관광농원 개발사업'이 산지전용허가의 대상임을 전제로 하여 예외적으로 보전산지인 임업용산지에서도 산지전용허가를 받아 일정한 규모 이하로 관광농원을 설치할 수 있도록 허용하려는 것인 점에 비추어 볼 때에도, 이 사안과 같이 관광농원 개발사업계획에 따른 영농 체험시설 부지의 일부인 임업용산지에서 임산물을 재배하려는 경우는 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가의 대상이라고 보아야 합니다.

따라서 관광농원사업을 경영하기 위해 관광농원을 개발하려는 경우, 그 개발사업계획에 포함되는 영농 체험시설 부지 중 임업용산지에 해당하는 부지에서 개발사업계획에 따라 임산물을 재배하려는 경우는 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가 대상에 해당합니다.

관계법령

산지관리법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. (생 략)
2. "산지전용"(山地轉用)이란 산지를 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도 외로 사용하거나 이를 위하여 산지의 형질을 변경하는 것을 말한다.
   가.·나. (생 략)
   다. 대통령령으로 정하는 임산물의 재배[성토(흙쌓기) 또는 절토(땅깎기) 등을 통하여 지표면으로부터 높이 또는 깊이 50센티미터 이상 형질변경을 수반하는 경우와 시설물의 설치를 수반하는 경우는 제외한다]
   라. 산지일시사용
3. ~ 6. (생 략)

제14조(산지전용허가) ① 산지전용을 하려는 자는 그 용도를 정하여 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 같다. 다만, 농림축산식품부령으로 정하는 사항으로서 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 산림청장 등에게 신고로 갈음할 수 있다

② ~ ⑤ (생 략)

농어촌정비법

제83조(관광농원의 개발) ① (생 략)

② 관광농원을 개발하려는 자는 사업계획을 세워 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장의 승인을 받아야 한다. 승인을 받은 사항 중 대통령령으로 정하는 중요한 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

농어촌정비법 시행규칙

제47조(농어촌 관광휴양사업의 규모 및 시설기준) 법 제81조제2항에 따른 농어촌 관광휴양사업의 규모 및 시설기준은 별표 3과 같다.

[별표 3]

농어촌 관광휴양사업의 규모 및 시설기준(제47조 관련)

1. (생 략)
2. 시설기준

구분	시설의 종류	시설기준
농어촌관광휴양단지 사업	(생 략)	(생 략)
관광농원 사업	영농체험시설 (기본시설)	○ 식량작물·특용작물·약용작물·채소·과수·화훼·유실수·버섯 등이 입식된 농장, 저수지·조류사육장·초지·축사·양어장·유리하우스(비닐하우스를 포함한다)·분재원 등 농수산물 생산을 위한 토지와 시설(자연림·자연초지 또는 야생화 등의 자생지는 제외한다) 면적이 2천제곱미터 이상이면서 관광농원 개발 승인 면적의 100분의 20 이상일 것
	(생 략)	(생 략)
농어촌 민박사업	(생 략)	(생 략)

※ 비고: "기본시설"이란 농어촌 관광휴양사업 사업시행자가 반드시 설치해야 하는 시설을 말한다.

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0091

민원인 – 한국광해광업공단이 산업통상자원부장관의 위탁을 받아 시행하는 광해방지사업을 위하여 보전국유림을 사용하고자 하는 경우가 국가 또는 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 국유림을 사용하고자 하는 경우에 해당하는지 여부(「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」 제21조제1항제1호 등 관련)

01 질의요지

「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」(이하 "국유림법"이라 함) 제21조제1항 본문에서는 산림청장은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 보전국유림의 사용을 허가하거나 준보전국유림을 대부할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 보전국유림에 대한 사용허가는 국가 또는 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 사용하고자 하는 경우(제1호) 등에 한정하여 할 수 있다고 규정하고 있는 한편, 같은 법 제23조제1항 본문에서는 산림청장은 같은 법 제21조제1항에 따라 국유림의 대부 또는 사용허가(이하 "대부등"이라 함)를 하는 경우에는 대부료 또는 사용료(이하 "대부료등"이라 함)를 징수하도록 규정하면서, 같은 조 제3항제1호에서는 같은 조 제1항에도 불구하고 "같은 법 제21조제1항제1호·제4호 및 제5호에 해당하는 경우"에는 대부료등의 전부 또는 일부를 징수하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바,

「한국광해광업공단법」에 따라 설립된 한국광해광업공단이 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」(이하 "광산피해방지법"이라 함) 제12조제2항제1호에 따라 산업통상자원부장관의 위탁을 받아 시행하는 광해방지사업[90]을 위하여 보전국유림을 사용하고자 하는 경우가 국유림법 제23조제3항제1호에 따라 산림청장이 그 대부료등의 전부 또는 일부를 징수하지 아니할 수 있는 사유인 같은 법 제21조제1항제1호의 "국가 또는 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 사용하고자 하는 경우"에 해당하는지?

90) 광산피해의 예방 및 원상회복을 위해 시행하는 사업을 말하며(광산피해방지법 제2조제5호 참조), 이하 같음(광해방지사업의 범위는 같은 법 제11조에 따르는 것을 전제함)

02 회답

이 사안의 경우, 국유림법 제23조제3항제1호에 따라 산림청장이 그 대부료등의 전부 또는 일부를 징수하지 아니할 수 있는 사유인 같은 법 제21조제1항제1호의 "국가 또는 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 사용하고자 하는 경우"에 해당하지 않습니다.

03 이유

먼저 국유림법 제21조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 산림청장은 보전국유림에 대한 사용허가는 국가 또는 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 사용하고자 하는 경우(제1호) 등 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정하여 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제23조제1항에 따라 산림청장은 대부료등을 원칙적으로 징수하여야 함에도 불구하고, 같은 조 제3항에서는 같은 법 제21조제1항제1호에 해당하는 경우(제1호) 등에 있어서는 예외적으로 대부료등의 전부 또는 일부를 징수하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바, 이와 같이 보전국유림에 대한 사용허가는 같은 법 제21조제1항 각 호에 해당하는 경우에만 한정하여 인정하고 있고, 그 대부료등의 감면도 같은 법 제23조제3항에 따라 예외적으로 인정하고 있는 국유림법의 규정 체계에 비추어 보면, 대부료등의 감면 사유인 같은 법 제21조제1항제1호의 사유에 대해서는 제한적으로 해석할 필요[91]가 있다고 할 것입니다.

그런데 국유림법 제21조제1항제1호에서는 보전국유림의 사용허가가 가능한 사유를 "국가 또는 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 사용하고자 하는 경우"로 규정하여 그 사용 주체를 '국가나 지방자치단체'로 제한하고 있는바, 한국광해광업공단은 「한국광해광업공단법」에 따라 설립된 공법인으로서, 광산피해방지법 제12조 등에 따라 산업통상자원부장관으로부터 권한을 위탁받아 광해방지사업을 시행하는 경우라 하더라도 이는 한국광해광업공단이 광해방지사업에 관하여 국가에 부여한 법률상 권한을 위탁받은 범위에서 행사할 수 있다는 것이지, 해당 위탁 규정을 근거로 한국광해광업공단이 국가의 지위를 갖게 된다고 보기는 어려우므로[92], 이 사안과 같이 한국광해광업공단이 산업통상자원부장관으로부터 위탁받아 시행하는 광해방지사업을 위해 보전국유림을 사용하는 경우는 국유림법 제21조제1항제1호의 "국가 또는 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 사용하고자 하는 경우"에 해당하는 것으로 볼 수 없습니다.

91) 법제처 2020. 5. 11. 회신 19-0684 해석례 참조

92) 서울행정법원 2016. 8. 18. 선고 2015구합78861 판결례 참조

그리고 국유림법 제23조제1항 본문 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제21조제1항 각 호의 규정을 종합하면, 국유림에 대한 대부등의 사유에 따라 그 국유림에 적용되게 되는 대부료등의 요율이 달라지므로, 같은 법 제21조제1항 각 호에서 규정하고 있는 보전국유림의 사용허가 사유는 규정간 상호 중복되지 않게 해석·적용하는 것이 타당하다 할 것인데[93], 같은 항 제12호에서는 보전국유림의 사용허가 사유로 '광산피해방지법 제2조제5호에 따른 광해방지사업의 시행을 위하여 사용하려는 경우'를 별도로 규정하고 있고, 해당 규정은 보전국유림을 광해방지사업의 시행 목적으로 사용하려는 경우에도 보전국유림에 대한 사용허가를 할 수 있도록 하여 광해방지사업의 원활한 추진을 도모하고자 신설된 것인바[94], 이러한 입법 연혁과 취지에 비추어보면 이 사안과 같이 광해방지사업을 위하여 보전국유림을 사용하고자 하는 경우는 같은 법 제21조제1항제12호의 사용허가 사유에 해당한다고 보는 것이 합리적이고, 이에 더하여 같은 항 제1호의 사유에도 중복하여 해당한다고 해석하는 것은 보전국유림의 사용허가 사유별로 그 대부료등의 요율을 달리 규정한 국유림법의 규정 체계를 고려하면 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 국유림법 제23조제3항제1호에 따라 산림청장이 그 대부료등의 전부 또는 일부를 징수하지 아니할 수 있는 사유인 같은 법 제21조제1항제1호의 "국가 또는 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 사용하고자 하는 경우"에 해당하지 않습니다.

관계법령

국유림의 경영 및 관리에 관한 법률

제21조(국유림의 대부등) ① 산림청장은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 보전국유림의 사용을 허가하거나 준보전국유림을 대부할 수 있다. 다만, 보전국유림에 대한 사용허가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정하여 할 수 있다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 공용 또는 공공용으로 사용하고자 하는 경우
2. ~ 11. (생 략)
12. 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 광해방지사업의 시행을 위하여 사용하려는 경우

②·③ (생 략)

93) 법제처 2020. 5. 11. 회신 19-0684 해석례 참조

94) 2020. 2. 18. 법률 제17008호로 일부개정되어 같은 날 시행된 국유림법 개정이유 및 주요내용 참조

제23조(대부료 등) ①·② (생 략)

③ 산림청장은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 대부료등의 전부 또는 일부를 징수하지 아니할 수 있다.

1. 제21조제1항제1호·제4호 및 제5호에 해당하는 경우
2. 천재지변 등으로 인하여 대부등을 받은 목적사업의 소득이 없다고 인정되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우

한국광해광업공단법

제1조(목적) 이 법은 한국광해광업공단을 설립하여 광산피해를 적정하게 관리하고 광물자원산업을 육성·지원함으로써 광산지역의 경제활성화와 광물자원의 안정적 수급을 도모하여 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(법인격) 한국광해광업공단(이하 "공단"이라 한다)은 법인으로 한다.

제8조(사업) ① 공단은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」 제11조에 따른 광해방지사업
2. ~ 18. (생 략)

② (생 략)

광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률

제12조(광해방지사업의 시행) ① 광해방지사업은 광해방지의무자가 직접 시행한다. 다만, 기술능력부족 등 대통령령이 정하는 사유로 인하여 광해방지의무자가 직접 시행할 수 없는 경우에는 산업통상자원부장관이 시행한다.

② 제1항의 규정에 따라 산업통상자원부장관이 광해방지사업을 시행하는 경우에는 그 사업의 효율적인 추진을 위하여 다음 각 호의 자에게 그 사업의 전부 또는 일부를 위탁할 수 있다. 다만, 제2호라목의 광해방지에 관한 연구·기술개발사업의 경우에는 개발사업의 성격에 따라 제2호의 전문광해방지사업자가 아닌 관련 학계 및 연구기관에 이를 위탁할 수 있다.

1. 「한국광해광업공단법」에 따른 한국광해광업공단(이하 "공단"이라 한다)
2. (생 략)

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0209

민원인 – 산지전용허가 처분의 권리·의무를 승계하도록 하는 「산지관리법」 제51조제1항의 "이 법에 따른 변경신고 등"의 범위(「산지관리법」 제51조제1항 등 관련)

01 질의요지

「산지관리법」 제51조제1항에서는 산지의 소유자가 같은 법 제37조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 받거나 신고 등을 한 후 매매·양도·경매 등으로 그 소유권이 변경된 경우에는 그 산지의 매수인·양수인 등 변경된 산지소유자(제1호)가 "이 법에 따른 변경신고 등"을 통하여 권리·의무를 승계하는 것으로 규정하고 있고, 같은 법 제37조제1항제1호에서는 "제14조에 따른 산지전용허가"를 규정하고 있는바,

「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가를 받은 산지의 소유자 A가 매매를 통해 해당 산지의 소유권을 B에게 이전한 이후, 같은 조 제1항 단서 및 같은 법 시행규칙 제10조제4항제1호에 따른 산지전용허가를 받은 자의 명의변경에 관한 변경신고(이하 "산지전용허가 명의변경 신고"라 함)를 하지 않은 상태에서 종전 소유자 A가 같은 법 제17조제2항에 따라 해당 산지전용허가에 대한 '산지전용기간의 연장 허가(이하 "산지전용기간 연장허가"라 함)'를 받은 경우[95], 그 '산지전용기간의 연장허가'가 같은 법 제51조제1항 각 호 외의 부분의 "이 법에 따른 변경신고 등"에 해당하여 산지전용허가에 관한 A의 권리 · 의무가 B에게 승계되는지?

02 회답

이 사안의 경우 '산지전용기간의 연장허가'는 「산지관리법」 제51조제1항 각 호 외의 부분의 "이 법에 따른 변경신고 등"에 해당하지 않아, 산지전용허가에 관한 A의 권리·의무가 B에게 승계되지 않습니다.

95) 산지의 소유권변경사유(매도)가 발생한 날부터 60일 이내(「산지관리법」 제51조제2항 참조)에 산지전용기간 연장허가를 신청하면서, 산지전용허가의 명의변경에 관한 신청 없이 「산지관리법 시행규칙」 별지 제8호서식(산지전용기간 연장허가 신청서)의 신청인란에는 A를, 산지소유자란에는 B를 각각 기재하고, B로부터 발급받은 해당 산지의 사용·수익권을 증명할 수 있는 서류를 함께 제출한 경우를 전제로 함.

03 이유

먼저 「산지관리법」 제51조제1항에 따르면, 산지의 소유자가 같은 법 제14조에 따른 산지전용허가(같은 법 제37조제1항제1호)를 받은 후 매매로 그 소유권이 변경된 경우 변경된 산지소유자는 “이 법에 따른 변경신고 등”을 통하여 산지전용허가를 받은 자의 권리·의무를 승계하는데, 같은 법 제14조제1항 본문에서는 산지전용을 하려는 경우 및 허가받은 사항을 변경하려는 경우 산림청장등[96]의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 단서 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제10조제4항제1호에서는 산지전용허가를 받은 자의 명의변경은 신고로 갈음할 수 있도록 규정하고 있으며, 같은 법 제14조제2항에서는 같은 조 제1항 단서에 따른 변경신고를 받은 날부터 25일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지해야 한다고 규정하여 산지전용허가 명의변경신고를 ‘수리를 요하는 신고’로 규정하고 있고, 산림청장등은 산지전용허가 명의변경신고가 있는 때에는 「산지관리법 시행령」 제15조에 따라 변경신고 대상 산지의 현지조사 및 신청내용의 허가기준 적합여부 심사(제2항 본문)와 해당 변경신고서 및 첨부서류를 바탕으로 명의변경의 적정성을 검토한 이후 변경신고를 수리하는 것이 타당하다고 인정되는 경우 그 변경신고를 수리(제3항)해야 하는 점에 비추어 보면, 산지전용허가를 받은 자의 명의를 변경하려면, 산지전용허가 명의변경신고를 반드시 거쳐야 한다고 보는 것이 산지관리법령의 체계에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

그리고 산지관리법령에서는 「산지관리법」 제14조제1항 단서에 따른 산지전용허가의 변경신고와 산지전용기간 연장허가의 요건 및 절차 등을 별개의 조문에서 규정하면서, 변경신고를 하려는 경우에는 같은 법 시행규칙 별지 제7호서식의 ‘산지전용변경신고서’를, 연장허가 신청을 하려는 경우에는 같은 규칙 별지 제8호서식의 ‘산지전용기간연장허가신청서’를 제출하도록 하는 등 산지전용허가 명의변경신고와 산지전용기간 연장허가 신청을 서로 구분하고 있고, 산지전용기간 연장허가를 통해 산지전용허가에 관한 권리·의무가 승계되도록 하는 규정을 두고 있지도 않으므로, 같은 법 제51조제1항의 “이 법에 따른 변경신고 등”에 ‘산지전용기간 연장허가’까지 포함된다고 볼 수는 없습니다.

더욱이 「산지관리법」 제14조 및 같은 법 시행규칙 제10조제2항제1호다목에서는 산지전용허가의 요건으로 산지전용을 하려는 자가 전용하려는 산지를 반드시 소유하고 있을 것을 요구하고 있지 아니하고, 같은 규칙 제10조제4항제1호 및 제5호에서도 ‘산지전용허가를 받은

96) 산림청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함)을 말하며(「산지관리법」 제3조의5제3항 참조), 이하 같음.

자의 명의변경'과 '산지전용허가를 받은 산지의 소유권 등의 변경'을 각각 별도의 산지전용허가 변경신고 대상으로 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 산지전용허가를 받은 산지의 소유자 A가 산지의 소유권을 B에게 이전한 이후 산지전용허가 명의변경신고를 하지 않은 상태에서 산지전용기간 연장허가를 받은 경우에는 그 산지전용기간연장허가신청서에 산지소유자를 B로 기재하였다는 이유만으로 '산지전용허가의 명의변경'에 관한 사항을 포함하여 허가를 받은 것으로 볼 수 없으므로, '산지전용기간 연장허가'를 통해 산지전용허가에 대한 종전 산지소유자 A의 권리·의무가 변경된 산지소유자 B에게 승계된다고 보기는 어렵습니다.

아울러 「산지관리법」 제51조제1항의 입법연혁을 살펴보면, 2017년 4월 18일 법률 제14773호로 일부개정되기 전의 「산지관리법」(이하 "구 「산지관리법」"이라 함) 제14조제1항 단서 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제10조제4항제1호에서 '산지의 소유권이 변경되는 경우 등 산지전용허가를 받은 자가 변경될 경우 명의변경을 위한 변경신고를 통해 기존 산지전용허가를 받은 자의 권리의무를 승계하도록 변경신고 절차'를 두고 있었음[97]에도 불구하고, 권리·의무의 승계에 관하여 규정하고 있던 구 「산지관리법」 제51조에서는 이러한 변경신고 등을 통해 권리·의무가 승계된다는 점을 명시적으로 규정하고 있지 않아 명의변경을 위한 변경신고를 하지 않은 경우에도 권리·의무가 승계된다는 정부유권해석[98]에 따라[99] 2017년 4월 18일 법률 제14773호로 「산지관리법」을 일부개정하여 현행 제51조제1항과 같이 '변경신고 등'을 통하여 권리·의무가 승계되도록 명확하게 규정한 것인바[100], 「산지관리법」 제51조제1항의 "이 법에 따른 변경신고 등"의 범위는 '산지전용허가 명의변경신고' 등과 같이 권리·의무를 승계하게 할 목적으로 이루어지는 "변경신고 등"으로 한정된다고 보아야 하고, 산지전용허가 기간 이내에 목적사업을 완료하지 못하여 그 기간을 연장하기 위해 받는 '산지전용기간 연장허가'는 "변경신고 등"의 범위에 포함되지 않는다고 보는 것이 해당 규정의 입법연혁과 취지에 부합한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우 '산지전용기간의 연장허가'는 「산지관리법」 제51조제1항 각 호 외의 부분의 "이 법에 따른 변경신고 등"에 해당하지 않아, 산지전용허가에 관한 A의 권리·의무가 B에게 승계되지 않습니다.

---

97) 2016. 12. 14. 의안번호 제2004374호로 발의된 산지관리법 일부개정법률안에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 심사보고서 참조

98) 법제처 2015. 7. 21. 회신 15-0276 해석례 참조

99) 2016. 12. 14. 의안번호 제2004374호로 발의된 산지관리법 일부개정법률안에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 심사보고서 및 2016. 12. 14. 의안번호 제2004374호로 발의된 산지관리법 일부개정법률안에 대한 제350회국회(임시회) 농림축산식품해양수산위원회회의록(소위제1차) 참조

100) 2017. 4. 18. 법률 제14773호로 일부개정되어 같은 날 시행된 「산지관리법」 개정이유 참조

관계법령

산지관리법

제14조(산지전용허가) ① 산지전용을 하려는 자는 그 용도를 정하여 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 같다. 다만, 농림축산식품부령으로 정하는 사항으로서 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 산림청장 등에게 신고로 갈음할 수 있다.

② ~ ⑤ (생 략)

제17조(산지전용허가 등의 기간) ① (생 략)

② 제14조에 따른 산지전용허가를 받거나 제15조에 따른 산지전용신고를 한 자가 제1항에 따른 산지전용기간 이내에 전용하려는 목적사업을 완료하지 못하여 그 기간을 연장할 필요가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 산림청장등으로부터 산지전용기간의 연장 허가를 받거나 산림청장 또는 시장·군수·구청장에게 산지전용기간의 변경신고를 하여야 한다.

③·④ (생 략)

제51조(권리·의무의 승계 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 이 법에 따른 변경신고 등을 통하여 제37조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 받거나 신고 등을 한 자의 권리·의무를 승계한다.

1. 산지의 소유자가 제37조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 받거나 신고 등을 한 후 매매·양도·경매 등으로 그 소유권이 변경된 경우: 그 산지의 매수인·양수인 등 변경된 산지소유자
2. (생 략)

②·③ (생 략)

산지관리법 시행규칙

제10조(산지전용허가의 신청 등) ① ~ ③ (생 략)

④ 법 제14조제1항 단서에서 "농림축산식품부령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 산지전용허가를 받은 자의 명의변경
2. ~ 4. (생 략)
5. 산지전용허가를 받은 산지의 소유권 또는 사용·수익권의 변경

⑤ ~ ⑦ (생 략)

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0475

산림청 – 산지전용허가·신고지 또는 산지일시사용허가·신고지에서 생산되는 소나무류 중 감염목등에 대하여 재선충병 방제를 위한 경우 「소나무재선충병 방제특별법」 제10조제2항제3호에 따라 반출금지구역 안에서 이동이 허용되는지(「소나무재선충병 방제특별법」 제10조제2항 등 관련)

01 질의요지

「소나무재선충병 방제특별법」(이하 "재선충방제법"이라 함) 제10조제1항에서는 반출금지구역[101]에서는 소나무류[102]의 이동을 금지한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에도 불구하고 소나무류를 이동할 수 있는 사유로서 같은 법 제11조에 따른 재선충병 방제를 위한 감염목등[103]인 원목의 이동 등 대통령령으로 정하는 경우(제3호), 산지전용허가·신고지 또는 산지일시사용허가·신고지에서 생산되는 소나무류를 해당 허가·신고지 내에서 이동하는 경우(제5호)등을 규정하고 있는바,

산지전용허가·신고지 또는 산지일시사용허가·신고지(이하 "산지전용허가지등"이라 함)에서 생산되는 소나무류 중 감염목등(이하 "이 사안 감염목등"이라 함)은 재선충병 방제를 위한 경우 반출금지구역의 범위 안에서는 재선충방제법 제10조제2항제3호에 따라 산지전용허가지등 밖으로 이동이 허용되는지, 아니면 반출금지구역의 범위 안에서도 같은 항 제5호에 따라 산지전용허가지등 안에서만 이동이 허용되는지?[104]

101) 시장(특별자치시 및 특별자치도의 경우는 특별자치시장 및 특별자치도지사를 말함)·군수·구청장이 재선충병의 방제 및 확산방지를 위하여 발생지역과 발생지역으로부터 5킬로미터 이내의 범위로 일정거리 이내인 지역에 대하여는 행정동·리 단위로 지정한 소나무류반출금지구역을 말하며(재선충방제법 제9조제1항 참조), 이하 "반출금지구역"이라 함

102) 소나무, 해송, 잣나무와 그 밖에 산림청장이 재선충병에 감염되는 것으로 인정하여 고시하는 수종을 말하며(재선충방제법 제2조제2호 참조), 이하 같음

103) 감염목(재선충방제법 제2조제4호 참조) 또는 감염우려목(재선충방제법 제2조제3호 참조)을 말하며(재선충방제법 제3조제1항 참조), 이하 같음

104) 산지전용허가·신고 또는 산지일시사용허가·신고 후 반출금지구역이 지정된 경우로서 반출금지구역의 범위 안에 산지전용허가지등이 위치한 경우를 전제함

02 회답

이 사안 감염목등은 재선충병 방제를 위한 경우 반출금지구역의 범위 안에서는 재선충방제법 제10조제2항제3호에 따라 산지전용허가지등 밖으로 이동이 허용됩니다.

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[105], 재선충방제법 제10조 제1항에서는 반출금지구역에서는 소나무류의 이동을 금지한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항제3호에서는 같은 조 제1항에도 불구하고 같은 법 제11조에 따른 재선충병 방제를 위한 "감염목등인 원목의 이동 등 대통령령으로 정하는 경우"는 소나무류를 이동할 수 있다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조의6제1항에서는 "감염목등인 원목의 이동 등 대통령령으로 정하는 경우"란 산림청장이 정하여 고시하는 기간 동안 훈증, 파쇄, 소각, 건조, 그 밖에 산림청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 방제를 하기 위하여 감염목등인 원목을 같은 법 제9조제1항에 따라 지정된 소나무류반출금지구역(해당 발생지역이 포함된 소나무류반출금지구역에 한정함) 안에서 이동하는 경우를 말한다고 규정하고 있는바, 같은 법 제10조제2항제3호에 따라 예외적으로 반출금지구역에서 소나무류를 이동할 수 있는 경우 중 하나인 '재선충병 방제를 위한 감염목등인 원목을 이동하려는 경우'에는 그 원목이 생산되는 지역이 산지전용허가지등인지 여부와 관계없이 '반출금지구역 안'에서는 소나무류를 이동할 수 있다고 해석하는 것이 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 재선충방제법 제10조의 입법연혁을 살펴보면, 방제사업을 효과적이고 신속하게 추진하기 위하여[106] 재선충방제법이 제정될 당시에는 반출금지구역에서 감염목등인 원목의 이동을 금지한다고만 규정(제10조제1항제3호)하여 피해지역의 소나무 이동을 제한하던 것을 2006년 9월 27일 법률 제7993호로 일부개정된 재선충방제법에서는 재선충병 확산을 막기 위해서는 감염목등인 원목의 이동을 제한하는 것이 바람직하나, 파쇄·소각 등 방제사업을 위해 불가피한 경우에는 이동을 허용하도록 같은 호의 내용을 개정하였는바[107], 이러한

105) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

106) 2005. 2. 2. 의안번호 171332호로 발의된 소나무재선충병 방제특별법안에 대한 국회 농림해양수산위원회 검토보고서 참조

입법연혁을 고려하면, 방제사업을 신속하게 추진하기 위한 목적으로 반출금지구역 안에서는 소나무류의 이동을 제한하는 것을 원칙으로 하되, 감염목등에 대한 방제사업을 위해 불가피한 경우 반출금지구역 안에서 소나무류의 이동을 예외적으로 허용하도록 하려는 것이므로 산지전용허가지등에서 생산되는 소나무류 중 감염목등에 대하여 재선충방제법 제10조제2항제3호에 따른 재선충병 방제를 위한 경우 해당 산지전용허가지등 밖이라도 반출금지구역 안에서는 이동이 가능하다고 해석하는 것이 타당합니다.

또한 재선충방제법 제10조제2항에서는 반출금지구역에서 소나무류의 이동금지에 대한 예외를 각 호로 규정하고 있는데, 같은 항 각 호에서 반출금지구역 안에서 소나무류를 이동할 수 있는 경우를 개별적으로 각각 열거하고 있어, 각 호의 규정 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 반출금지구역 안에서 소나무류를 이동할 수 있다고 해석하는 것이 타당하고, 그렇지 않고 만약 재선충방제법 제10조제2항 각 호의 모든 요건이 동시에 충족되어야 반출금지구역 안에서 소나무류를 이동할 수 있다고 본다면, 같은 항 제1호에 따라 관계 공무원이 재선충이 죽은 것을 확인한 경우 또는 같은 항 제4호나목에 따라 산지일시사용신고를 하여 생산된 것으로 다른 예방조치를 하여 재선충병의 감염이 없다는 시·도 산림환경 관련 연구기관의 장의 확인증을 받은 경우에도 같은 항 제5호에 따라 해당 산지전용허가지등 내에서만 이동할 수 있게 되므로, 반출금지구역 안에서도 이동할 수 있는 범위를 추가로 제한 받게 되는 결과가 초래되는바, 원칙적으로 반출금지구역 안에서 소나무류의 이동을 금지하되 예외적인 경우 반출금지구역 안에서는 소나무류의 이동을 허용하려는 같은 법 제10조의 입법 취지에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 이 사안 감염목등은 재선충병 방제를 위한 경우 반출금지구역의 범위 안에서는 재선충방제법 제10조제2항제3호에 따라 산지전용허가지등 밖으로 이동이 허용됩니다.

법령정비 권고의견

재선충방제법 제10조제2항에 따라 반출금지구역 안에서 소나무류를 이동할 수 있는 경우 중 산지전용허가지등에서 생산되는 소나무류의 이동(제5호)에 대해 같은 항 제3호와의 적용 관계를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

107) 2006. 1. 27. 의안번호 173820호로 발의된 소나무재선충병 방제특별법 일부개정법률안에 대한 국회 농림해양수산위원회 검토보고서 참조

관계법령

소나무재선충병 방제특별법

제9조(반출금지구역 지정·해제) ①시장·군수·구청장은 재선충병의 방제 및 확산방지를 위하여 발생지역과 발생지역으로부터 5킬로미터 이내의 범위로 대통령령으로 정하는 일정거리 이내인 지역에 대하여는 「지방자치법」 제7조제4항에 따른 행정동·리 단위로 소나무류반출금지구역(이하 "반출금지구역"이라 한다)으로 지정하여야 한다.

② 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지정사유가 소멸되었다고 인정되는 경우에는 반출금지구역 지정을 해제할 수 있다.

③ ~ ④ (생 략)

제10조(소나무류의 이동제한 등) ① 반출금지구역에서는 소나무류의 이동을 금지한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 소나무류를 이동할 수 있다.

1. 제11조제4항에 따른 훈증 등 산림청장이 별도로 정하는 처리 방식으로 방제하여 관계 공무원이 재선충이 죽은 것을 확인한 경우
2. 제11조제4항에 따른 파쇄 등 산림청장이 별도로 정하는 처리방식으로 방제하여 이동하는 경우
3. 제11조에 따른 재선충병 방제를 위한 감염목등인 원목의 이동 등 대통령령으로 정하는 경우
4. (생 략)
5. 산지전용허가·신고지 또는 산지일시사용허가·신고지에서 생산되는 소나무류를 해당 허가·신고지 내에서 이동하는 경우

③ ~ ④ (생 략)

소나무재선충병 방제특별법 시행령

제3조의6(감염목 등의 이동) ① 법 제10조제2항제3호에서 "감염목등인 원목의 이동 등 대통령령으로 정하는 경우"란 산림청장이 정하여 고시하는 기간 동안 훈증, 파쇄, 소각, 건조, 그 밖에 산림청장이 정하여 고시하는 방법에 따라 방제를 하기 위하여 감염목 또는 재선충병 감염우려목(이하 "감염목등"이라 한다)인 원목을 법 제9조제1항에 따라 지정된 소나무류반출금지구역(해당 발생지역이 포함된 소나무류 반출금지구역에 한정한다) 안에서 이동하는 경우를 말한다.

② (생 략)

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0690

산림청 – 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제4조제1호의 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 요건의 의미(「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제4조제1호 등 관련)

01 질의요지

「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」(이하 "임업직불제법"이라 한다) 제8조제1항에서는 임산물생산업 직접지불금[108]의 지급대상이 될 수 있는 자는 같은 법 제7조에 따른 임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지(이하 "지급대상 산지"라 한다)에서 임산물생산업에 종사하는 임업인등[109]으로서 농림축산식품부령으로 정하는 요건에 해당하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제4조에서는 임산물생산업 직접지불금 지급대상이 될 수 있는 자는 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 규정하면서, 같은 조 제1호에서는 임업직불제법 제17조제2항에 따른 등록신청연도(이하 "등록신청연도"라 함)의 직전 1년 이상 계속하여 지급대상 산지에서 연간 60일 이상 임산물생산업에 종사한 임업인등으로서 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로 규정하고 있는바,

임업직불제법 시행규칙 제4조제1호의 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 요건인 "등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여 지급대상 산지에서 임산물생산업에 종사"는 등록신청연도의 직전 1년 이상 종사하고 등록신청연도에도 임산물생산업 직접지불금 지급대상자로 확정될 때까지 계속하여 종사하는 것을 의미하는지, 아니면 등록신청연도의 직전 1년 이상만 계속하여 종사하는 것을 의미하는지?

108) 임업직불제법 제6조제1항에 따른 임산물생산업 직접지불금을 말하며, 이하 같음

109) 임업직불제법 제2조제3호에 따른 임업인등을 말하며, 이하 같음

02 회답

임업직불제법 시행규칙 제4조제1호의 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 요건인 "등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여 종사"는 등록신청연도의 직전 1년 이상 종사하고 등록신청연도에도 임산물생산업 직접지불금 지급대상자로 확정될 때까지 계속하여 종사하는 것을 의미합니다.

03 이유

임업직불제법 제8조제1항에서는 임산물생산업 직접지불금의 지급대상이 될 수 있는 자는 지급대상 산지에서 임산물생산업에 종사하는 임업인등으로서 농림축산식품부령으로 정하는 요건에 해당하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제4조제1호에서는 임산물생산업 직접지불금의 지급대상이 될 수 있는 자 중 하나로 등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여 지급대상 산지에서 연간 60일 이상 임산물생산업에 종사한 임업인등으로서 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 규정하고 있으며, 같은 호 각 목에서는 임산물생산업에 이용되는 산지의 면적과 임산물생산업을 통해 수확한 임산물의 연간 판매금액을 규정하고 있으므로, 관련 규정을 종합하면 임업직불제법 제8조제1항 및 같은 법 시행규칙 제4조제1호에 해당하는 지급대상자는 임업인등으로서 ① 등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여 지급대상 산지에서 임산물생산업에 종사할 것(종사 기간), ② 연간 60일 이상 종사할 것(종사 일수), ③ 산지의 면적과 연간 판매금액을 준수할 것의 요건을 모두 갖추어야 하는데, 임업·산림 공익직접지불사업에 관한 시행지침[110]에서는 종사에 관한 요건을 구체화하여 "등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여"의 종사 기간은 임업직불제법 제5조제1항의 공익직접지불금[111]의 적용대상인 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」(이하 "농어업경영체법"이라 함) 제4조제1호에 따라 농업경영 관련 정보 등(이하 "임업경영정보"이라 함)을 등록한 것을 기준으로 인정하고, "연간 60일 이상"의 종사 일수는 수기 또는 스마트영림일지로 임산물생산업 활동이나 임업기자재 구입 등의 실제 활동을 증명한 것으로 인정하는바, 이 사안에서는 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 요건 중 하나인 "등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여 종사"의 종사 기간 요건을 언제까지 유지하여야 하는지가 문제됩니다.

110) 2024년도 임업·산림 공익직접지불사업 시행지침 p16 참조

111) 공익직접지불제도(임업직불제법 제4조 참조)에 따른 직접지불금을 말하며(임업직불제법 제17조제1항 참조), 이하 같음

법령에서 특정 용어의 의미가 불명확한 경우에는 그 법령의 규정 내용과 입법 취지, 다른 법률과의 관계, 사회에서 일반적으로 통용되는 의미 등을 종합적으로 고려하여 해석해야 할 것인데[112], 임업직불제법 제4조에 따른 공익직접지불제도는 임업·산림의 공익기능 증진과 임업인등의 소득안정을 위하여 매년 일정한 자격을 갖추고 준수사항을 이행한 임업인등에게 직접지불금을 지급하는 제도[113]로, 공익직접지불금을 지급받으려는 자는 매년 공익직접지불금 지급대상자 요건을 충족하여야 하고, 임업직불제법 제11조에 따라 산지의 형상(形狀) 및 기능을 유지하고 농약 및 화학 비료를 대통령령으로 정하는 기준에 따라 사용하는 등의 의무를 이행하여야 하는데, 이러한 준수사항의 위반횟수 산정은 같은 법 시행령 별표 4 제1호나목에 따르면 등록신청연도의 직전 연도 10월 1일부터 등록신청연도 9월 30일까지의 기간을 기준으로 판단하는바, 임업직불제법의 공익직접지불금은 매년 지급대상자 요건과 준수사항 이행 여부 등을 등록신청연도 9월 30일까지 점검하는 것을 토대로 산정하게 되므로, 그 시기까지 임산물생산업에 종사함으로써 공익기능을 제공하는 임업인등에게 소득보전을 위해서 보조금을 지원하는 제도[114]로 보아야 할 것입니다.

그렇다면 임업직불제법 제5조제1항에 따라 임산물생산업 직접지불금을 신청할 수 있는 자는 임업경영정보를 등록한 임업인등이어야 하므로, 임산물생산업 직접지불금 지급대상자로 확정되는 시기까지 임업경영정보 등록자의 지위를 유지하여야 하는데, "등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여 종사"한다는 것은 임업경영정보 등록자의 지위를 계속하여 유지하여야 한다는 것을 의미한다고 볼 수 있고, "등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여 종사"의 종사 기간 요건은 "계속성"과 "종사"를 전제하고 있는데, 계속성이 유지되어야 하는 기간의 시기(始期)는 등록신청연도의 직전 1년으로 정하면서 종기(終期)는 정하고 있지 않은바, 공익기능을 제공하는 임업인등을 위한 소득보전이라는 공익직접직불제도의 취지에 비추어 보면, 임산물생산업 직접지불금의 지급대상이 될 수 있는 자는 등록신청연도의 직전 1년 이상 종사하고 임산물생산업 직접지불금 지급대상자로 확정되는 때까지 계속하여 지급대상 산지에서 임산물생산업에 종사하여야 한다고 보는 것이 합리적인 해석입니다.

그리고 임산물생산업 직접지불금 지급 결정 체계를 살펴보면, 임업직불제법 제17조 및 제18조에서는 임산물생산업 직접지불금을 지급받으려는 자는 산지 소재지 관할 읍장·면장 또는 동장(이하 "읍장등"이라 함)에게 등록을 신청하여야 하고, 읍장등은 등록기준에 맞는지를 확인하기 위하여 현지조사 등 필요한 조사를 하며, 산림청장은 지급대상자로 인정되면

112) 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0572 해석례 참조

113) 2022. 5. 31. 산림청 보도자료, 2022. 6. 22. 산림청 보도자료 참조

114) 2022. 5. 24. 산림청 보도자료 참조

지급대상자로 등록하도록 규정하고 있고, 같은 법 제20조 및 제22조에서는 산림청장은 등록사항에 관한 사실이나 같은 법 제11조에 따른 준수사항 이행 여부 확인 등을 위하여 실태조사를 한 후 지급 여부를 결정하도록 규정하고 있는바, 임산물생산업 직접지불금 등록 신청 시에 지급대상자 요건을 갖추었다고 반드시 지급되는 것이 아니고 등록 이후에도 등록사항에 관한 사실이나 준수사항 이행 여부 등을 조사·확인하여 임산물생산업 직접지불금 지급 여부와 액수 등이 정해지므로, 이 사안의 경우 지급대상자는 등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여 임산물생산업 직접지불금 지급대상자로 확정되는 시기까지 지급대상 산지에서 임산물생산업에 종사하여야 한다고 보는 것이 임업직불제법령의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

아울러 임업직불제법은 농업과 수산업 분야는 공익직접지불제도를 이미 시행하여 농업·농촌 및 수산업·어촌의 공익기능 증진을 장려하고 있는 것과 비교하여 임업 분야는 임업·산림의 공익 기능에 대한 지속가능성을 담보하기 어려워 임업·산림 공익기능 증진 직접지불제도를 도입하여 임업·산림의 공익기능을 제고하고 임업인의 소득 안정을 도모하기 위해 제정된 법률로서[115], 임업직불제법 시행규칙 제4조는 부정수급을 막고 실제 임산물생산업에 종사하는 임업인등에게 임산물생산업 직접지불금이 지급되도록 요건을 구체화한 것인바[116], 이러한 입법취지에 비추어 볼 때, 임업·산림의 공익기능 제고 및 임업인의 소득 안정 도모라는 입법목적을 훼손하지 않는 범위에서 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 요건은 엄격하게 해석해야 한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 임업직불제법 시행규칙 제4조제1호의 임산물생산업 직접지불금 지급대상자 요건인 "등록신청연도의 직전 1년 이상 계속하여 종사"는 등록신청연도의 직전 1년 이상 종사하고 등록신청연도에도 임산물생산업 직접지불금 지급대상자로 확정될 때까지 계속하여 종사하는 것을 의미합니다.

법령정비 권고사항

임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지에서 임산물생산업에 종사한 임업인등으로서 종사한 기간의 요건을 임업직불제법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

115) 2021. 11. 30. 법률 제18535호로 제정된 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제정이유 및 주요내용 참조

116) 2022. 9. 30. 농림축산식품부령 제548호로 제정된 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 조문별 제정이유서 참조

관계법령

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률

제8조(임산물생산업 직접지불금 지급대상자) ① 임산물생산업 직접지불금의 지급대상이 될 수 있는 자는 제7조에 따른 임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지에서 임산물생산업에 종사하는 임업인 등으로서 농림축산식품부령으로 정하는 요건에 해당하여야 한다.

②·③ (생 략)

임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙

제4조(임산물생산업 직접지불금 지급대상자) 법 제8조제1항에 따라 임산물생산업 직접지불금(법 제6조제1항에 따른 임산물생산업 직접지불금을 말한다. 이하 같다)의 지급대상이 될 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

1. 법 제17조제2항에 따른 등록신청 연도의 직전 1년 이상 계속하여 법 제7조에 따른 임산물생산업 직접지불금 지급대상 산지에서 연간 60일 이상 임산물생산업에 종사한 임업인등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
   가. 임산물생산업에 이용되는 산지의 면적이 1천제곱미터 이상이고, 임산물생산업을 통해 수확한 임산물의 연간 판매금액이 120만원 이상인 임업인(「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」에 따른 임업인을 말한다. 이하 같다)
   나. 임산물생산업에 이용되는 산지의 면적이 5만제곱미터 이상이고, 임산물생산업을 통해 수확한 임산물의 연간 판매금액이 4천5백만원 이상인 농업법인(「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농업법인을 말한다. 이하 같다)
2. (생 략)

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0840

민원인 – 「산지관리법」 제25조제1항에 따른 토석채취허가 사무의 성격(「산지관리법」 제25조제1항 등 관련)

01 질의요지

「산지관리법」 제25조제1항 본문에서는 국유림이 아닌 산림의 산지에서 토석을 채취하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 "시장등"이라 함)에게 토석채취허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제32조에 따르면 토석채취허가를 받으려는 자는 신청서에 농림축산식품부령이 정하는 서류를 첨부하여 시장등에게 제출하여야 하고(제1항), 시장등은 토석채취허가 신청을 받은 때에는 토석채취허가 대상 산지에 대하여 현지조사를 실시하여, 그 신청내용이 같은 법 제28조에 따른 토석채취허가기준에 적합한지 여부를 검토한 후 토석채취의 타당성에 관하여 지방산지관리위원회의 심의를 거쳐야 하며(제2항), 시장등은 그 심사한 결과 토석채취허가를 하는 것이 타당하다고 인정되는 경우에는 허가 구역 및 별표 8 제4호에 따른 완충구역의 경계를 표시하게 하고 같은 법 제38조제1항에 따른 복구비를 미리 예치하게 한 후 토석채취허가증을 신청인에게 발급하도록 규정(제3항)하고 있는바,

「산지관리법」 제25조제1항에 따른 토석채취허가 사무는 지방자치단체의 사무(이하 "자치사무"라 함)인지, 아니면 국가사무로서 지방자치단체의 장이 위임받은 사무(이하 "기관위임사무"라 함)인지?

02 회답

「산지관리법」 제25조제1항에 따른 토석채취허가 사무는 자치사무에 해당합니다.

03 이유

먼저 지방자치단체의 장이 처리하고 있는 사무가 자치사무인지 아니면 기관위임사무인지를 판단함에 있어서는 그에 관한 법규의 규정 형식과 취지를 우선 고려하여야 할 것이지만, 그 외에도 그 사무의 성질이 전국적으로 통일적인 처리가 요구되는 사무인지 여부나 그에 관한 경비부담과 최종적인 책임귀속의 주체 등도 아울러 고려하여 판단하여야 할 것입니다[117].

「산지관리법」 제25조제1항에서는 국유림이 아닌 산림의 산지에서 토석을 채취하려는 자는 토석채취 면적이 10만제곱미터 이상인 경우에는 시·도지사에게, 10만제곱미터 미만인 경우에는 시장·군수·구청장에게 허가를 받도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제32조제2항에서는 시장등은 토석채취허가 대상 산지에 대하여 현지조사를 실시하고, 그 신청내용이 같은 법 제28조에 따른 토석채취허가기준에 적합한지 여부를 검토한 후 토석채취의 타당성에 관하여 지방산지관리위원회[118]의 심의를 거쳐야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제32조제3항에서는 시장등은 토석채취허가를 하는 것이 타당하다고 인정되는 경우에는 허가 구역 및 별표 8 제4호에 따른 완충구역의 경계를 표시하게 하고 같은 법 제38조제1항에 따른 복구비를 미리 예치하게 한 후 토석채취허가증을 신청인에게 발급하도록 규정하고 있는바, 이러한 토석채취허가에 관한 규정 및 체계에 비추어 보면, 시장등은 토석채취허가 대상 산지에 대해 현지조사를 실시하고 같은 법 제28조에 따른 토석채취허가기준에 적합한지 여부를 검토하는 등 토석채취허가 전반에 관한 사무를 주도적으로 수행하고 있습니다.

그리고 토석채취허가와 관련된 산지관리법령의 입법연혁을 살펴보면, 구 「산지관리법」(2010년 5월 31일 법률 제10331호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제25조에서는 산림청장에게 토석채취허가를 받도록 규정하고 있었고, 구 「산지관리법 시행령」(2010년 12월 7일 대통령령 제22513호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제32조에서는 산림청장이 현지조사를 하고 토석채취의 타당성에 관하여 중앙산지관리위원회[119]의 심의를 거치도록 규정하고 있었으며, 구 「산지관리법」 제52조 및 같은 법 시행령 제52조에서는 같은 법 제25조에 따른 토석채취허가 권한을 토석채취면적이 10만 제곱미터 미만인 경우에는 시장·군수·구청장에게, 10만 제곱미터 이상 20만 제곱미터 미만인 경우에는 시·도지사에게 위임하고 있었는데, 토석채취허가 사무가 지방자치단체에 위임되어 운영됨에 따라 지방자치

117) 대법원 2009. 6. 11. 선고 2008도6530 판결례 및 법제처 2016. 1. 18. 회신 15-0724 해석례 참조

118) 산지의 이용 및 보전에 관한 사항을 심의하기 위하여 시·도에 설치한 지방산지관리위원회를 말하며(「산지관리법」 제22조제2항 참조), 이하 같음

119) 산림청에 설치한 중앙산지관리위원회를 말하며(「산지관리법」 제22조제1항 참조), 이하 같음

단체의 자율권이 제한되는 등 효율적인 업무추진이 어렵다는 문제가 있어, 구「산지관리법」 및 같은 법 시행령을 개정하여 구「산지관리법」 제25조에 따른 토석채취허가 사무가 포함된 산지관리사무를 지방자치단체에 이양함으로써[120], 지방자치단체의 자율성과 책임성을 높이고, 사무의 효율적 운영으로 주민에게 편의를 제공하도록 한 것인바[121], 이러한 입법연혁과 개정취지, 관련 규정의 체계를 종합적으로 고려하면,「산지관리법」 제25조제1항에 따른 토석채취허가 사무는 허가권자인 시장등이 산지관리법령상 허가 기준 및 절차 등에 따라 지역적 특성 및 실정을 반영하여 허가권자의 권한과 책임 아래 수행하는 자치사무라고 보아야 할 것입니다.

아울러「산지관리법」 제25조제1항에 따른 토석채취허가를 신청하는 자는 같은 법 제50조, 같은 법 시행령 제51조제1항 및 별표 9 제4호에 따라 허가를 신청하는 산지면적이 1만제곱미터 이하인 경우에는 2만원, 1만제곱미터를 초과하는 경우에는 2만원에 1천제곱미터를 초과할 때마다 2천원을 가산한 금액을 수수료로 내야 하는데, 납부된 토석채취허가 수수료는 해당 지방자치단체의 세입이 되고 그 귀속주체는 시장등이 된다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서「산지관리법」 제25조제1항에 따른 토석채취허가 사무는 자치사무에 해당합니다.

관계법령

산지관리법

제25조(토석채취허가 등) ① 국유림이 아닌 산림의 산지에서 토석을 채취(가공하거나 산지 이외로 반출하는 경우를 포함한다)하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 구분에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 토석채취허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 같다. 다만, 농림축산식품부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하는 것으로 갈음할 수 있다.

1. 토석채취 면적이 10만제곱미터 이상인 경우: 시·도지사의 허가
2. 토석채취 면적이 10만제곱미터 미만인 경우: 시장·군수·구청장의 허가

② ~ ⑧ (생 략)

120) 2009. 11. 16. 의안번호 제1806582호로 발의된 산지관리법 일부개정법률안에 대한 국회 농림수산식품위원회 검토보고서 참조

121) 2010. 5. 31. 법률 제10331호로 일부개정된「산지관리법」 개정이유 및 주요내용 참조

산지관리법 시행령

제32조(토석채취허가의 절차 및 심사 등) ① 법 제25조제1항에 따라 토석채취허가 또는 변경허가를 받거나 변경신고를 하려는 자는 신청서에 농림축산식품부령이 정하는 서류를 첨부하여 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 토석채취허가 또는 변경허가의 신청을 받거나 변경신고가 있는 때에는 토석채취허가·변경허가 또는 변경신고 대상 산지에 대하여 현지조사를 실시하고, 그 신청내용이 법 제28조에 따른 토석채취허가기준에 적합한지 여부를 검토한 후 토석채취의 타당성에 관하여 지방산지관리위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 지방산지관리위원회의 심의를 거치지 않는다.

1. ~ 7. (생 략)

③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 심사한 결과 토석채취허가 또는 변경허가를 하거나 변경신고를 수리하는 것이 타당하다고 인정되는 경우에는 허가·변경허가 또는 변경신고 구역 및 별표 8 제4호에 따른 완충구역의 경계를 표시하게 하고 법 제38조제1항에 따른 복구비를 미리 예치하게 한 후 농림축산식품부령으로 정하는 토석채취허가증을 신청인에게 발급하거나 변경신고를 수리하여야 한다.

④ ~ ⑦ (생 략)

제3절 해양수산

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0925

전북특별자치도 – 한정마을어업면허의 면허기간 만료 전 관계 행정기관의 장과 면허기간 추가 부여에 협의하거나 승인을 받은 경우 다시 새로운 면허신청을 해야 하는지 여부(「수산업법」 제15조 등 관련)

01 질의요지

「수산업법」 제15조제1항에서는 시장[122]·군수·구청장[123]은 공익상 면허어업이 제한되는 사유[124]에 해당되어 어업이 제한된 구역이나 어업면허가 취소된 수면에서 어업을 하려는 자에게는 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아 따로 면허기간 등을 정하여 같은 법 제7조에 따른 어업면허(이하 "한정어업면허"라 함)를 할 수 있다고 규정하고 있는데,

「수산업법」 제15조제1항에 따라 한정마을어업면허[125]를 받은 자[126]가 면허기간 만료 이후에도 마을어업을 계속하려는 경우, 「수산업법」 제7조에 따라 다시 새로운 면허신청을 하는 대신 그 면허기간 만료 전 면허기간 추가 부여[127] 신청을 하고 그에 대해 시장·군수·구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아 면허기간을 추가로 부여하는 것이 가능한지?

---

122) 특별자치도의 경우에는 특별자치도지사를 말하며, 이하 같음.

123) 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음.

124) 「수산업법」 제33조제1항제1호부터 제6호까지 또는 제34조제6호(같은 법 제33조제1항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 경우만 해당함)에 해당하는 경우를 말하며, 이하 같음.

125) 「수산업법」 제8조에 따른 마을어업에 대한 한정어업면허를 말하며, 이하 같음

126) 공익사업으로 일반어업면허(「수산업법」 제7조에 따른 어업면허 중 한정어업면허를 제외한 어업면허를 말하며, 이하 같음)가 취소된 수면(「수산업법」 제33조제1항제6호에 해당되어 같은 법 제34조제6호에 따라 어업면허가 취소된 수면을 말하며, 이하 같음)에서 면허신청을 하여 한정마을어업면허를 받은 자로 한정하며, 이하 같음

127) 한정마을어업면허의 유효기간 만료 전 관계 행정기관의 장과 면허기간을 추가로 부여하는 데 협의하거나 승인을 받아 기간을 따로 정하여 면허기간을 추가로 부여하는 것을 말하며, 일반어업면허의 연장과 마찬가지로 총 추가 부여기간은 10년을 초과하지 않는 경우를 전제로 함.

02 회답

이 사안의 경우, 「수산업법」 제7조에 따라 다시 새로운 면허신청을 하는 대신 그 면허기간 만료 전 면허기간 추가 부여 신청을 하고 그에 대해 시장·군수·구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아 면허기간을 추가로 부여하는 것도 가능합니다.

03 이유

「수산업법」 제7조제1항에서는 정치망어업(제1호)이나 마을어업(제2호)을 하려는 자는 시장·군수·구청장의 면허를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제14조에서는 같은 법 제7조에 따른 어업면허의 유효기간은 10년으로 한다고 규정(제1항 본문)하면서, 공익상 면허어업이 제한되는 사유 등이 있는 경우 외에는 어업권자의 신청에 따라 면허기간이 끝난 날부터 10년의 범위에서 유효기간의 연장을 허가해야 한다고 규정(제2항 전단)하고 있는 한편, 같은 법 제15조제1항에서는 시장·군수·구청장은 공익상 면허어업이 제한되는 사유에 해당되어 어업이 제한된 구역이나 어업면허가 취소된 수면에서 어업을 하려는 자에게는 "관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아 따로 면허기간 등을 정하여 제7조에 따른 어업면허"를 할 수 있다고 규정하면서, 같은 법 제15조제2항에서는 그 한정어업면허에 관한 사항은 같은 법 제16조제2항[128], 제19조제1항 각 호[129] 및 제88조제1항[130]을 적용하지 않는다고 규정하고 있을 뿐, 그 면허기간의 연장 가능 여부 또는 연장 절차 등에 관해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안에서는 같은 법 제15조제1항에 따라 한정마을어업면허를 받은 자가 그 면허기간이 만료되기 전에 면허기간 추가 부여 신청을 하고, 그에 대해 시장·군수·구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받은 경우(이하 "협의한 경우"라 함)에도 면허기간 만료 이후 마을어업을 계속하려면 다시 새로운 면허신청을 해야 하는지 여부가 문제됩니다.

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은

128) 어업권의 물권적 성질
129) 어업권의 이전·분할 또는 변경
130) 어업권 제한 등에 따른 손실보상

법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 해야 하는바[131], 「수산업법」 제15조제1항에 따라 한정마을어업면허를 받은 자가 그 면허기간이 만료되기 전에 면허기간 추가 부여 신청을 하고, 그에 대해 관계 행정기관의 장과 협의한 경우 새로운 면허신청 없이 면허기간을 추가로 부여할 수 있는지 여부를 판단하기 위해서는 같은 항에 따른 어업면허의 법적 성격, 해당 조문의 입법 취지 및 다른 조문과의 관계 등을 종합적으로 살펴보아야 합니다.

먼저 「수산업법」 제15조제1항에서는 시장·군수·구청장은 공익상 면허어업이 제한되는 사유에 해당되어 어업이 제한된 구역이나 어업면허가 취소된 수면에서 어업을 하려는 자에게는 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아 따로 면허기간 등을 정하여 한정어업면허를 "할 수 있다"고 규정하고 있고, 그 내용에 있어서도 공익상 사유로 어업이 제한되는 수면에서 일정기간 어업을 할 수 있도록 하는 처분이라는 점에서 한정어업면허는 일반어업면허와 같이 특정인에게 일정기간 동안 권리나 이익을 부여하는 행정행위로서 재량행위이라고 할 것인바, 그 면허의 기준을 정하는 것 역시 행정청의 재량에 속하는 것이므로[132], 수산업법령에서 한정어업면허의 '면허기간 추가 부여'에 관한 별도의 규정을 두지 않았더라도 면허기간을 추가 부여하는 것이 법령에 합치되지 않거나 객관적으로 합리적이라고 볼 수 없어 재량권을 남용한 것이라고 볼만한 사정이 없는 한, 시장·군수·구청장은 「수산업법」 제15조제1항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받는 등 한정마을어업면허의 요건과 절차를 준수하는 범위 내에서라면 당초 한정마을어업면허의 '면허기간을 정하여' 면허를 할 수 있는 것과 같이 그 '면허기간을 추가로 부여'하는 것도 가능하다고 보아야 합니다.

더욱이 「수산업법」에서 한정어업면허제도를 마련한 취지는 어업인의 소득증대 및 불편 해소를 위해 공익사업으로 어업이 제한된 구역이나 어업면허가 취소된 수면이라 하더라도 공익사업의 추진을 저해하지 않는 범위에서 어업 활동을 가능하게 하려는 것인바[133], 이 사안과 같이 공익사업으로 일반어업면허가 취소된 수면에서 한정마을어업면허를 한 후 제반 사정을 고려하여 당초 부여한 면허기간이 만료된 이후에도 해당 수면에서 일정기간 계속하여 어업활동을 하는 것이 공익사업의 시행을 저해하지 않는 것으로 관계 행정기관의 장과 협의한 경우라면, 다시 새로운 면허신청을 하지 않아도 한정마을어업면허의 면허기간을 변경하는 의미에서 면허기간을 추가로 부여할 수 있다고 보는 것이 한정어업면허제도의 취지에도 부합합니다.

---

131) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

132) 법제처 2012. 2. 3. 회신 11-0776 해석례 참조

133) 1995. 12. 30. 법률 제5131호로 일부개정되어 1996. 12. 31. 시행된 수산업법중개정법률안에 대한 국회 농림수산위원회 심사보고서 참조

아울러 구「수산업법」[134] 제8조에서는 면허어업의 종류로 양식어업을 포함하여 정하면서 면허의 유효기간(제14조)과 한정어업면허(제15조)에 관하여 현행「수산업법」과 유사하게 규정하고 있었는데, 2019년 8월 27일 법률 제16568호로「양식산업발전법」이 제정되어 양식어업에 관한 사항이 같은 법에서 규율되면서, 한정양식업면허에 대하여는 같은 법 제18조제2항에서 명시적으로 같은 법 제17조제2항에 따른 양식업면허의 유효기간의 연장 규정을 적용하지 않도록 규정하고 있는데 반해,「수산업법」에서는 이러한 적용 배제 규정을 신설하지 않았다는 점을 고려할 때에도 한정어업면허에 대해서는 그 면허 취지에 반하지 않는 범위에서 면허기간의 추가 부여가 가능하다고 해석하는 것이 합리적이라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우,「수산업법」 제7조에 따라 다시 새로운 면허신청을 하는 대신 그 면허기간 만료 전 면허기간 추가 부여 신청을 하고 그에 대해 시장·군수·구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아 면허기간을 추가로 부여하는 것도 가능합니다.

법령정비 권고사항

한정어업면허기간 추가 부여의 방법 및 절차 등을 수산업법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

수산업법

제7조(면허어업) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 어업을 하려는 자는 시장·군수·구청장의 면허를 받아야 한다.

1. 정치망어업(定置網漁業): 일정한 수면을 구획하여 대통령령으로 정하는 어구를 일정한 장소에 설치하여 수산동물을 포획하는 어업
2. 마을어업: 일정한 지역에 거주하는 어업인이 해안에 연접(連接)한 일정 수심 이내의 수면을 구획하여 패류·해조류 또는 정착성(定着性) 수산동물을 관리·조성하여 포획·채취하는 어업

② 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 어업면허를 할 때에는 개발계획의 범위에서 하여야 한다.

③·④ (생 략)

134) 2019. 8. 27. 법률 제16568호로 일부개정되어 2020. 8. 28. 시행되기 전의 것을 말함

제15조(면허제한구역 등에 대한 한정어업면허) ① 시장·군수·구청장은 제33조제1항제1호부터 제6호까지 또는 제34조제6호(제33조제1항제1호부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에만 해당한다)에 해당되어 어업이 제한된 구역이나 어업면허가 취소된 수면에서 어업을 하려는 자에게는 관계 행정기관의 장과 협의하거나 승인을 받아 따로 면허기간 등을 정하여 제7조에 따른 어업면허(이하 "한정어업면허"라 한다)를 할 수 있다.

② 한정어업면허에 관한 사항은 제16조제2항, 제19조제1항 각 호 및 제88조제1항을 적용하지 아니한다.

③ (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-1114

전북특별자치도 부안군 – 낚시어선업자는 낚시어선업 신고의 요건 중 하나인 어업허가를 신고 시에만 갖추고 있으면 되는지, 아니면 신고가 유효한 기간 동안 계속하여 갖추고 있어야 하는지 여부(「낚시관리 및 육성법」 제25조 등 관련)

01 질의요지

「낚시 관리 및 육성법」(이하 "낚시관리법"이라 함) 제25조제1항 전단에서는 낚시어선업[135]을 하려는 자는 낚시어선[136]의 대상·규모·선령·설비·안전성 검사, 선장의 자격, 전문교육 이수 등 대통령령으로 정하는 요건(이하 "신고요건"이라 함)을 갖추어 어선번호, 어선의 명칭 등 대통령령으로 정하는 사항(이하 "신고사항"이라 함)에 관한 낚시어선업의 신고서를 작성하여 해당 낚시어선의 선적항을 관할하는 시장·군수·구청장[137]에게 신고(이하 "낚시어선업신고"라 함)해야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제16조제1항제1호에서는 "낚시어선이 「수산업법」 또는 「내수면어업법」에 따라 어업허가를 받은 어선으로서 총톤수 10톤 미만의 동력어선일 것"을 신고요건의 하나로 규정하고 있는바,

낚시어선업자[138]는 신고요건 중 하나인 '낚시어선이 「수산업법」에 따라 어업허가를 받은 어선일 것'의 요건을 낚시어선업신고 시에만 갖추고 있으면 되는지, 아니면 낚시어선업신고가 유효한 기간 동안 계속 갖추고 있어야 하는지?

02 회답

낚시어선업자는 신고요건 중 하나인 '낚시어선이 「수산업법」에 따라 어업허가를 받은

135) 낚시인을 낚시어선에 승선시켜 낚시터로 안내하거나 그 어선에서 낚시를 할 수 있도록 하는 영업을 말하며(낚시관리법 제2조제6호 참조), 이하 같음.

136) 「어선법」에 따라 등록된 어선으로서 낚시어선업에 쓰이는 어선을 말하며(낚시관리법 제2조제7호 참조), 이하 같음.

137) 특별자치도지사·특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말하며, 서울특별시의 관할구역에 있는 한강의 경우에는 한강관리에 관한 업무를 관장하는 기관의 장을 말함)을 말하며, 이하 같음.

138) 낚시관리법 제25조에 따라 신고하고 낚시어선업을 경영하는 자로서(낚시관리법 제2조제8호 참조), 「수산업법」에 따라 어업허가를 받은 어선으로 낚시어선업신고를 한 경우를 전제함.

어선일 것'의 요건을 낚시어선업신고가 유효한 기간 동안 계속 갖추고 있어야 합니다.

03 이유

낚시관리법 제25조제1항 전단에서는 낚시어선업을 하려는 자는 신고요건을 갖추어 신고사항에 관한 낚시어선업의 신고서를 작성하여 해당 낚시어선의 선적항을 관할하는 시장·군수·구청장에게 신고해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 그 신고한 내용이 신고요건에 적합하면 낚시어선업 신고확인증을 발급해야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제16조제1항제1호에서는 낚시어선업 신고요건의 하나로 '낚시어선이 「수산업법」에 따라 어업허가를 받은 어선'으로서 총톤수 10톤 미만의 동력어선일 것을 규정하고 있는데, 낚시관리법 제2조제6호에 따르면, "낚시어선업"이란 낚시인을 '낚시어선'에 승선시켜 낚시터로 안내하거나 그 '낚시어선'에서 낚시를 할 수 있도록 하는 영업으로서, 같은 법 시행령 제16조제1항제1호에서 규정하고 있는 '낚시어선이 「수산업법」에 따라 어업허가를 받은 어선'일 것이라는 요건은 낚시어선업의 신고 시 뿐만 아니라, 신고한 낚시어선업이 유효하게 유지되는 동안 계속하여 충족해야 하는 요건으로 보아야 할 것입니다.

더욱이 낚시관리법 제38조제1항제6호에서는 시장·군수·구청장은 '낚시어선업자가 신고요건을 충족하지 못하게 된 경우' 영업의 폐쇄를 명하거나 3개월 이내의 기간을 정하여 그 영업의 정지를 명할 수 있다고 규정하고 있고, 그 세부적인 행정처분의 기준을 정하고 있는 같은 법 시행규칙 별표 2 제2호다목6)에서는 낚시어선업의 신고요건을 충족하지 못하게 된 경우에 대해서는 3회 위반 시 영업폐쇄 명령을 하도록 규정하고 있으며, 낚시관리법 제38조제2항에서는 영업의 폐쇄명령을 받은 자는 그 영업이 폐쇄된 날부터 2년이 지나지 아니하면 낚시어선업신고를 할 수 없다고 규정하는 등 신고요건을 충족하지 못하게 된 낚시어선업자에 대해서는 그 영업을 계속할 수 없도록 규제하고 있는바, 낚시어선업자는 낚시어선업의 신고 시 뿐만 아니라 그 후 낚시어선업신고가 유효한 기간 동안에는 계속하여 '「수산업법」에 따른 어업허가를 받은 총톤수 10톤 미만의 동력어선'을 낚시어선으로 갖추고 있어야 한다고 보는 것이 낚시관리법령의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

또한 낚시관리법은 낚시로 인한 수산자원 남획과 환경오염 및 낚시인의 안전사고 등을 방지하기 위하여 낚시어선업의 신고제도 등을 정하여 낚시 관련 제도를 체계화하고 낚시를 건전한 국민레저 활동으로 육성하여 농어촌의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 기여하기 위해 제정된 법률로서[139], 같은 법 제25조제1항 전단 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령

제16조제1항에서 낚시어선업을 하려는 자에 대해 일정한 신고요건을 갖추도록 규정하고 있는 것은 낚시어선 이용객이 급증하고 낚시로 인한 연근해어업 어획량이 감소하는 상황에서 무분별한 낚시어선업 진입 방지를 통하여 수산자원을 보호[140]하려는 취지라 할 것인데, 「수산업법」 제57조제1항에서는 수산자원의 상태, 현재 그 어업을 경영하는 자의 수, 그 밖의 자연적·사회적 조건 등을 고려하여 어업허가의 정수를 정할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 법 제58조제1항에서는 해양수산부장관은 수산자원의 지속적인 이용과 어업조정을 위하여 필요하면 같은 법 제40조에 따라 어업의 허가를 받은 어선에 대하여 선복량(船腹量)을 제한할 수 있도록 규정하고 있는바, 낚시관리법 시행령 제16조제1항제1호에서 낚시어선업의 신고요건 중 하나로 그 낚시어선을 '「수산업법」에 따라 어업허가를 받은 어선'으로 제한하고 있는 것은 해당 어선의 경우 같은 법에 따라 그 정수와 선복량의 통제가 가능하기 때문이라고 할 것이므로, 낚시어선업자는 낚시관리법 시행령 제16조제1항제1호의 요건을 계속 갖추어 낚시어선업을 영위해야 한다고 보는 것이 '수산자원의 보호'를 위해 낚시어선업의 신고요건을 엄격히 제한하고 있는 낚시관리법령의 입법취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 낚시어선업자는 신고요건 중 하나인 '낚시어선이 「수산업법」에 따라 어업허가를 받은 어선일 것'의 요건을 낚시어선업신고가 유효한 기간 동안 계속 갖추고 있어야 합니다.



관계법령

낚시 관리 및 육성법

제25조(낚시어선업의 신고) ① 낚시어선업을 하려는 자는 낚시어선의 대상·규모·선령·설비·안전성 검사, 선장의 자격, 전문교육 이수 등 대통령령으로 정하는 요건(이하 "신고요건"이라 한다)을 갖추어 어선번호, 어선의 명칭 등 대통령령으로 정하는 사항(이하 "신고사항"이라 한다)에 관한 낚시어선업의 신고서를 작성하여 해당 낚시어선의 선적항(船籍港)을 관할하는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 어선번호, 어선의 명칭 등 대통령령으로 정하는 중요한 신고사항을 변경하려는 때에도 같다.
② 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 신고한 내용이 신고요건에 적합하면 신고인에게 낚시어선업 신고확인증을 발급하여야 한다.
③ 제1항에 따른 낚시어선업 신고의 유효기간은 제48조에 따라 가입한 보험이나 공제의 계약기간으로 하되, 3년을 초과할 수 없다.
④ (생 략)

139) 2011. 3. 9. 법률 제10458호로 제정되어 2012. 9. 10. 시행된 낚시 관리 및 육성법 제정이유 참조
140) 헌법재판소 2021. 12. 23. 선고 2019헌마475 결정례 참조

제38조(영업의 폐쇄 등) ① 시장·군수·구청장은 낚시어선업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 영업의 폐쇄를 명하거나 3개월 이내의 기간을 정하여 그 영업의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제4호까지에 해당하는 경우에는 영업의 폐쇄를 명하여야 한다.

1 ~ 5. (생 략)

6. 제25조에 따른 낚시어선업의 신고요건을 충족하지 못하게 된 경우

7. ~ 10. (생 략)

② 제1항에 따라 영업의 폐쇄명령을 받은 자는 그 영업이 폐쇄된 날부터 2년이 지나지 아니하면 낚시어선업의 신고를 할 수 없다.

③ (생 략)

낚시 관리 및 육성법 시행령

제16조(낚시어선업의 신고요건 등) ① 법 제25조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 요건"이란 다음 각 호의 요건 모두를 말한다.

1. 낚시어선이 「수산업법」 또는 「내수면어업법」에 따라 어업허가를 받은 어선으로서 총톤수 10톤 미만의 동력어선일 것
2. 낚시어선이 선령(船齡) 20년 이하인 목선(木船)이거나 선령 25년 이하인 강선(鋼船)·합성수지선·알루미늄선일 것
3. 낚시어선에 별표 4에 따른 설비를 갖출 것
4. 법 제25조의2제1항 본문에 따른 낚시어선의 안전성 검사를 받았을 것
5. 낚시어선의 선장은 다음 각 목에 따른 요건을 모두 갖출 것

가. 「선박직원법」 제4조제2항제6호에 따른 소형선박 조종사 면허 또는 그 상위등급의 해기사 면허를 받았을 것

나. 「선박직원법」 제2조제6호에 따른 승무경력이 2년 이상이거나 120일 이상의 선박 출입항 기록을 보유할 것

6. 법 제47조제2항에 따른 전문교육을 이수할 것(최초로 낚시어선업을 신고하는 경우로 한정한다)

②·③ (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0511, 24-0688

민원인 - 선적항이 지정된 어선은 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제3조에 따라 무역항의 수상구역등에서의 선박 입항·출항에 관하여 같은 법의 적용이 제외되는지 여부(「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제3조 등 관련)

01 질의요지

「어선법」 제13조제1항 전단에서는 어선의 소유자나 해양수산부령으로 정하는 선박의 소유자는 그 어선이나 선박이 주로 입항·출항하는 항구 및 포구(이하 "선적항"이라 함)를 관할하는 시장·군수·구청장에게 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 어선원부에 어선의 등록을 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 선적항의 지정과 제한 등에 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다고 규정하고 있는 한편,

「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」(이하 "선박입출항법"이라 함) 제3조에서는 무역항의 수상구역등[141]에서의 선박 입항·출항에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 따른다고 규정하고 있는바,

「어선법」 제13조제1항 및 제4항이 선박입출항법 제3조에 따른 "다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우"에 해당하여 선적항이 지정된 어선은 무역항의 수상구역등에서의 선박 입항·출항에 관하여 선박입출항법의 적용이 제외되는지?

02 회답

「어선법」 제13조제1항 및 제4항은 선박입출항법 제3조에 따른 "다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우"에 해당하지 않아 선적항이 지정된 어선은 무역항의 수상구역등에서의 선박 입항·출항에 관하여 선박입출항법의 적용이 제외되지 않습니다.

141) 무역항의 수상구역과 「항만법」 제2조제5호가목1)의 수역시설 중 수상구역 밖의 수역시설로서 관리청이 지정·고시한 것을 말하며(선박입출항법 제2조제2호), 이하 같음

03 이유

선박입출항법 제3조에서는 무역항의 수상구역등에서의 선박 입항·출항에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 따른다고 규정하고 있는데, 이와 같은 규정은 하나의 법령에서 규율하려는 사항이 다른 법령에서 규율하고 있는 것과 중복되거나 상호 연관되어 있는 경우 다른 법령과의 관계를 명확하게 규정하여 다른 법령과의 상충을 피하고 법령 상호 간의 조화를 도모하려는 것으로서,[142] 어떤 규정이 선박입출항법 제3조에 따른 "다른 법률에 특별한 규정"이 있는 경우에 해당하여 선박입출항법의 적용을 배제하기 위해서는 그 특별한 규정이 '법률'이어야 하고, 나아가 그 규정하는 대상이 중복되거나 상호 연관되어 있으면서, 그 내용은 규정하는 대상에 대하여 선박입출항법과 달리 규정하고 있는 경우여야 할 것입니다.[143]

먼저 「어선법」은 어선의 효율적인 관리와 안전성을 확보하고 어선의 성능 향상을 도모함으로써 어업생산력의 증진과 수산업의 발전에 이바지하기 위해 어선의 등록 등에 관하여 규정하는 것을 목적(제1조)으로 하는 '법률'로서, 같은 법 제13조제1항 전단에서는 어선의 소유자는 선적항을 관할하는 시장·군수·구청장에게 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 어선원부에 어선의 등록을 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제21조제1항 본문에서 같은 법 제13조제1항에 따라 어선의 등록을 하려는 자는 별지 제27호서식에 따른 어선등록신청서를 제출하여야 한다고 규정하면서 어선등록신청서에 어선이 주로 입항·출항하는 항구 및 포구인 선적항을 기재하도록 하고 있으며, 같은 법 제13조제4항에서 선적항의 지정과 제한 등에 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제22조제1항에서 같은 법 제13조제4항에 따라 선적항을 정하고자 할 때에는 원칙적으로 해당 어선이 항행할 수 있는 수면을 접한 그 소유자의 주소지인 시·구·읍·면에 소재하는 항·포구를 기준으로 하여 정하도록 하면서, 예외적으로 어선의 소유자의 주소지가 어선이 항행할 수 있는 수면을 접한 시·구·읍·면이 아닌 경우(제2호) 등에 해당하는 경우에는 어선의 소유자가 지정하는 항·포구를 선적항으로 정할 수 있다고 규정하고 있는바, 같은 법 제13조제1항 및 제4항에서는 어선의 효율적인 관리와 안전성 확보를 위하여 '어선의 등록 및 선적항의 지정'에 대한 사항을 규정하고 있습니다.

그런데 선박입출항법은 무역항의 수상구역 등에서 선박의 입항·출항에 대한 지원과

142) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p. 77 참조

143) 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007두2555 판결례, 법제처 2022. 12. 19. 회신 22-0907 해석례 등 참조

선박운항의 안전 및 질서 유지에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 선박에 대한 통제를 강화하여 선박의 안전운항 여건을 확보하고 안보 위해 요소를 제거하는 등 효율적이고 안전한 선박의 입항 및 출항을 도모하기 위해 제정[144]되었는바, 이 법은 선박의 입항·출항 및 정박(제2장), 항로 및 항법(제3장), 위험물의 관리(제6장), 수로의 보전(제7장) 등 선박의 안전운항과 안보 위해 요소 제거를 주요 내용으로 하고 있으며, 어선의 등록이나 선적항 지정에 대한 규정은 두고 있지 않습니다.

이와 같이 「어선법」과 선박입출항법은 입법목적과 취지가 서로 다른 법률로서, 선박입출항법에서는 「어선법」 제13조제1항 및 제4항에서 규정하고 있는 어선의 등록 및 선적항 지정에 관한 사항을 규정하고 있지 않으므로, 「어선법」 제13조제1항 및 제4항에서 규정하는 내용이 선박입출항법과 서로 중복되거나 상호 연관되어 있다고 볼 수 없고, 나아가 그 규정 내용이 선박입출항법과 달리 규정하고 있는 경우에도 해당하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 「어선법」 제13조제1항 및 제4항은 선박입출항법 제3조에 따른 "다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우"에 해당하지 않아 선적항이 지정된 어선은 무역항의 수상구역등에서의 선박 입항·출항에 관하여 선박입출항법의 적용이 제외되지 않습니다.



관계법령

선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률

제3조(다른 법률과의 관계) 무역항의 수상구역등에서의 선박 입항·출항에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에 따른다.

어선법

제13조(어선의 등기와 등록) ① 어선의 소유자나 해양수산부령으로 정하는 선박의 소유자는 그 어선이나 선박이 주로 입항·출항하는 항구 및 포구(이하 "선적항"이라 한다)를 관할하는 시장·군수·구청장에게 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 어선원부에 어선의 등록을 하여야 한다. 이 경우 「선박등기법」 제2조에 해당하는 어선은 선박등기를 한 후에 어선의 등록을 하여야 한다.
② 제1항에 따른 등록을 하지 아니한 어선은 어선으로 사용할 수 없다.
③ 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 등록을 한 어선에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 증서 등을 발급하여야 한다.

144) 2015. 2. 3. 법률 제13186호로 제정된 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제정이유 참조

1. 총톤수 20톤 이상인 어선 : 선박국적증서
2. 총톤수 20톤 미만인 어선(총톤수 5톤 미만의 무동력어선은 제외한다) : 선적증서
3. 총톤수 5톤 미만인 무동력어선 : 등록필증

④ 선적항의 지정과 제한 등에 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.

어선법 시행규칙

제21조(등록의 신청등) ① 법 제13조제1항에 따라 어선의 등록을 하려는 자는 별지 제27호서식에 따른 어선등록신청서·어선변경등록신청서 또는 어업변경허가신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 제22조제1항에 따른 선적항을 관할하는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다. 다만, 어선의 건조허가 또는 건조발주허가를 한 시장·군수·구청장에게 등록을 신청하는 경우에는 제1호에 따른 어선건조허가서 또는 어선건조발주허가서를 첨부하지 아니한다.

1. ~ 7. (생 략)

②·③ (생 략)

제22조(선적항의 지정등) ① 법 제13조제4항에 따라 선적항을 정하고자 할 때에는 해당 어선 또는 선박이 항행할 수 있는 수면을 접한 그 소유자의 주소지인 시·구(자치구에 한한다. 이하 같다)·읍·면에 소재하는 항·포구를 기준으로 하여 정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 어선 또는 선박의 소유자가 지정하는 항·포구를 선적항으로 정할 수 있다.

1. 국내에 주소가 없는 어선의 소유자가 국내에 선적항을 정하는 경우
2. 어선의 소유자의 주소지가 어선이 항행할 수 있는 수면을 접한 시·구·읍·면이 아닌 경우
3. 삭제
4. 그 밖의 부득이한 사유로 어선의 소유자의 주소지 외의 항·포구를 선적항으로 지정하고자 하는 경우

② ~ ④ (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0517

해양수산부 – 준공된 항만시설인 항로·정박지 등을 유지하기 위한 준설이 「항만법」 제9조제4항 단서의 적용대상인지 여부(「항만법」 제9조제4항 등 관련)

01 질의요지

「항만법」 제9조제2항 본문에서는 "관리청[145]이 아닌 자가 항만개발사업[146]을 시행하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 항만개발사업계획을 작성하여 관리청의 허가를 받아야 한다"고 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문에서는 "관리청은 제2항 본문에 따른 허가의 신청을 받은 날부터 20일 이내에 허가 여부를 신청인에게 통지하여야 한다"고 규정하면서, 같은 조 제4항 단서에서는 "다만, 항만시설의 유지·보수에 관한 항만개발사업의 경우에는 14일 이내에 통지하여야 한다"고 규정하고 있는바,

준공된 항만시설[147]인 항로·정박지 등을 유지하기 위한 준설(이하 "유지준설"이라 함)이 「항만법」 제9조제4항 단서의 적용대상인지?

02 회답

유지준설은 「항만법」 제9조제4항 단서의 적용대상에 포함됩니다.

145) 항만의 개발 및 관리에 관한 행정업무를 수행하는 「항만법」 제2조제6호 각 목의 구분에 따른 행정관청을 말하며(「항만법」 제2조제6호 참조), 이하 같음

146) 항만시설(항만구역 밖에 설치하려는 「항만법」 제2조제5호 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설로서 장래에 해양수산부장관이 항만시설로 지정·고시할 예정인 시설을 포함함)의 신설·개축·보강·유지·보수(補修) 및 준설 등을 하는 사업을 말하며(「항만법」 제2조제7호 참조), 이하 같음

147) 「항만법」 제12조에 따라 준공된 항만시설로서 항만구역 안에 있는 항만시설임을 전제로 함

03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 할 것입니다[148].

먼저 「항만법」 제9조제4항 본문에서는 "관리청은 제2항 본문에 따른 허가의 신청을 받은 날부터 20일 이내에 허가 여부를 신청인에게 통지하여야 한다"고 규정하면서, 같은 조 제4항 단서에서는 "다만, 항만시설의 유지·보수에 관한 항만개발사업의 경우에는 14일 이내에 통지하여야 한다"고 규정하고 있어 같은 항 단서의 적용대상이 되기 위해서는 "항만시설의 유지·보수에 관한 항만개발사업"에 해당하면 될 것인데, 유지준설은 준공된 '항만시설'인 항로·정박지 등을 '유지'하기 위한 목적에서 준설을 하는 것이므로, "항만시설의 유지에 관한 항만개발사업"에 해당하여 같은 항 단서의 적용대상이라고 할 것이고, 같은 항에서는 항만개발사업에 '준설'이 포함되는 경우 같은 항 본문을 적용하도록 하거나 같은 항 단서의 적용대상에서 제외하도록 하는 명시적인 규정을 두고 있지 않은바, 유지준설에 '준설'이 포함된다고 하더라도 "항만시설의 유지에 관한 항만개발사업"에 해당한다면 같은 항 단서의 적용대상에 포함된다고 보는 것이 관련 규정의 체계에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

또한 항만개발사업 허가 신청에 대한 관리청의 통지 의무를 규정하고 있는 「항만법」 제9조제4항은 국민생활 및 기업활동과 밀접하게 관련되어 있는 인허가 민원의 처리절차를 법령에서 명확하게 규정하여 관련 민원의 투명하고 신속한 처리와 일선 행정기관의 적극 행정을 유도하기 위하여 2017년 10월 31일 법률 제15010호로 「항만법」을 일부개정하면서 신설된 것으로서[149], 당초 발의된 항만법 일부개정법률안에서는 모든 항만개발사업에 대한 허가 여부를 '14일 이내'에 통지하도록 규정하고 있었으나[150], 국회 심사과정에서 단순 유지·보수 공사가 아닌 '본공사'나 '새로운 공사'에 대해서는 '20일 이내'에 허가 여부를 통지하도록 수정되어 현행과 같이 규정된 것인바[151], 이러한 입법과정을 고려하면 「항만법」

148) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

149) 2017. 10. 31. 법률 제15010호로 일부개정된 「항만법」 개정이유 참조

150) 2016. 12. 28. 의안번호 제2004664호로 발의된 항만법 일부개정법률안 참조

151) 2016. 12. 28. 의안번호 제2004664호로 발의된 항만법 일부개정법률안에 대한 제354회 국회 법제사법위원회회의록 (법안심사제2소위원회, 2017. 9. 21. 개최) 참조

제9조제4항은 '14일 이내'에 허가 여부를 통지하기 어려운 본공사 등에 해당하는 항만개발사업의 경우에 관리청이 '20일 이내'에 통지할 수 있도록 하되, 항만시설의 유지·보수에 관한 항만개발사업의 경우에는 '14일 이내'에 통지하도록 하여 신속한 허가 절차의 진행이 가능하도록 해석하는 것이 해당 규정의 입법취지에 부합한다고 할 것이고, 그렇다면 유지준설의 경우에는 '항만시설의 유지·보수에 관한 항만개발사업'에 해당한다는 점에서 「항만법」 제9조제4항 단서의 적용대상에 포함된다고 보는 것이 타당하다고 할 것입니다.

따라서 유지준설은 「항만법」 제9조제4항 단서의 적용대상에 포함됩니다.

법령정비 권고사항

준공된 항만시설인 항로·정박지 등을 유지하기 위한 준설이 「항만법」 제9조제4항 단서의 적용대상에 포함된다는 점을 명확히 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

항만법

제9조(항만개발사업의 시행자 등) ① (생 략)
② 관리청이 아닌 자가 항만개발사업을 시행하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 항만개발사업계획을 작성하여 관리청의 허가를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 항만개발사업은 그러하지 아니하다.
1.·2. (생 략)
③ (생 략)
④ 관리청은 제2항 본문에 따른 허가의 신청을 받은 날부터 20일 이내에 허가 여부를 신청인에게 통지하여야 한다. 다만, 항만시설의 유지·보수에 관한 항만개발사업의 경우에는 14일 이내에 통지하여야 한다.
⑤ 관리청이 제4항에서 정한 기간 내에 허가 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장 여부를 신청인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 허가를 한 것으로 본다.
⑥ ~ ⑧ (생 략)

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0684

부산광역시 – 「항만법」이 전부개정된 경우 구 「항만법」 부칙 제6조가 계속 적용되는 것으로 볼 수 있는지 여부(법률 제12545호 항만법 일부개정법률 부칙 제6조 등 관련)

01 질의요지

구 「항만법」(2014년 3월 24일 법률 제12545호로 일부개정되어 2014년 9월 25일 시행된 것을 말하며, 이하 "구 항만법"이라 함)에서는 제64조의6을 신설하여 항만재개발사업시행자(이하 "사업시행자"라 함)는 항만재개발사업으로 발생하는 개발이익을 100분의 25의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도로 사용하도록 규정하면서, 같은 법 부칙 제6조에서는 제64조의6의 개정규정은 이 법 시행 후 사업시행자로 지정받은 경우부터 적용한다고 적용례를 두고 있었고,

2020년 1월 29일 법률 제16902호로 「항만법」(이하 "전부개정 항만법"이라 함)을 전부개정하고, 「항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률」(2020년 1월 29일 법률 제16904호로 제정된 것을 말하며, 이하 "항만재개발법"이라 함)을 제정하여, 구 항만법에서 규정하고 있던 항만재개발사업에 관한 사항을 이관하면서, 항만재개발법 제39조에서 구 항만법 제64조의6의 내용을 그대로 규정하되, 항만재개발법 제39조제1항에 제3호를 신설하여 "해당 사업구역의 「중소기업창업 지원법」 제2조제7호에 따른 창업보육센터 등 항만물류 산업의 일자리 창출을 위한 시설의 설치비용에의 충당"을 추가하여 규정하는 한편,

전부개정 항만법 부칙 제12조에서 처분 등에 관한 일반적 경과조치로서 "이 법 시행 당시 종전의 「항만법」에 따른 행정기관의 행위나 행정기관에 대한 행위는 그에 해당하는 이 법에 따른 행정기관의 행위나 행정기관에 대한 행위로 본다"고 규정하면서 구 항만법 부칙 제6조와 관련된 별도의 경과조치나 적용례를 두지 않았고, 항만재개발법 부칙 제3조에서도 전부개정 항만법 부칙 제12조와 같은 내용의 처분 등에 관한 일반적 경과조치를 규정하면서 구 항만법 부칙 제6조와 관련된 별도의 경과조치나 적용례를 두지 않은바,

구 항만법 시행일(2014년 9월 25일) 전에 사업시행자로 지정받아 구 항만법 부칙 제6조에 따라 개발이익의 재투자 의무가 없던 사업시행자[152]가 항만재개발법 제39조에 따른 개발이익을 재투자해야 하는 사업시행자에 해당하는지?

02 회답

구 항만법 시행일(2014년 9월 25일) 전에 사업시행자로 지정받아 구 항만법 부칙 제6조에 따라 개발이익의 재투자 의무가 없던 사업시행자는 항만재개발법 제39조에 따른 개발이익을 재투자해야 하는 사업시행자에 해당하지 않습니다.

03 이유

2020년 1월 29일 법률 제16902호로 「항만법」을 전부개정하면서, 종전의 「항만법」(2020년 1월 29일 법률 제16902호로 전부개정되기 전의 것을 말함)에서 규율하고 있던 항만재개발사업에 관한 사항은 전부개정 항만법이 아니라 별도로 항만재개발법을 제정하여 규율하게 되었는데, 이처럼 법령을 전부개정하는 경우 원칙적으로 종전 부칙을 모두 검토하여 현재까지 유효한 부칙에 대해 개별적인 경과조치 규정을 두되, 보충적으로 누락될 수 있는 종전 부칙의 효력을 인정하기 위해 "종전 부칙의 적용범위에 관한 경과조치"를 규정할 수 있으나[153], 전부개정 항만법 부칙 및 항만재개발법 부칙에서는 구 항만법 부칙 제6조의 효력에 대해 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안에서는 구 항만법 시행일(2014년 9월 25일) 전에 사업시행자로 지정받아 구 항만법 부칙 제6조에 따라 개발이익의 재투자 의무가 없던 사업시행자가 전부개정 항만법 및 항만재개발법 시행 이후에도 구 항만법 부칙 제6조의 효력이 실효되지 않고 계속 적용된다고 보아 항만재개발법 제39조에 따른 개발이익을 재투자해야 하는 사업시행자에 해당하지 않는지 여부가 문제됩니다.

법령을 전부개정하는 경우에는 법령의 내용 전부를 새로 고쳐 쓰므로 종전의 본칙은 물론 부칙 규정도 모두 소멸한다고 보는 것이 원칙이나, 그 경우에도 종전 경과규정의 입법 경위와 취지, 개정 전후 법령의 전반적인 체계나 내용 등에 비추어 신법의 효력발생 이후에도 종전의 경과규정을 계속 적용하는 것이 입법자의 의사에 부합하고, 그 결과가 수범자인 국민에게 예측할 수 없는 부담을 지우는 것이 아니라면 별도의 규정이 없더라도 종전의 경과규정이 실효되지 않고 계속 적용된다고 해석할 수 있습니다[154].

---

152) 2014년 9월 25일 전에 사업시행자로 지정받아 현재까지 항만재개발사업을 진행 중인 경우로서 항만재개발사업의 개발이익 재투자에 대해서 전부개정 항만법 및 항만재개발법 시행 당시 종전의 「항만법」(법률 제16902호로 전부개정되기 전의 것을 말함)에 따른 행정기관의 행위나 행정기관에 대한 행위가 없는 것을 전제로 함

153) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.708, 709 참조

먼저 구 항만법에서는 항만재개발사업의 공익성과 건전성을 확보하기 위해 같은 법에 제64조의6(개발이익의 재투자)을 신설하여 항만재개발사업을 통해 개발이익이 발생하는 경우 사업시행자는 그 개발이익의 100분의 25 이내의 범위에서 해당 사업구역의 분양가격이나 임대료 인하, 기반시설 설치비용에 충당하는 등의 용도로 사용하도록 하면서, 같은 법 부칙 제6조에서 이에 대한 적용례를 두어 제64조의6의 개정 규정은 같은 법 시행 후 사업시행자로 지정받는 경우부터 적용하도록 규정하고 있는바[155], 이러한 적용례를 둔 취지는 구 항만법 시행 전에 사업시행자로 지정받은 경우에는 같은 법 제64조의6이 적용되지 않도록 하여 종전 사업시행자의 기득권 및 신뢰를 법적으로 보호하려는 것으로 보이고, 이후 「항만법」을 전부개정하면서 항만재개발법을 제정하는 과정에서도 구 항만법 부칙 제6조에 따른 종전 사업시행자에 대한 신뢰보호를 변경할만한 특별한 사유가 있었다고 보기는 어렵습니다.

그리고 전부개정 항만법과 항만재개발법의 입법 연혁을 살펴보면, 항만재개발사업에 관한 사항은 구 항만법 제6장에서 규정하고 있었는데, 항만재개발사업의 추진 및 지원체계를 강화하고 항만재개발 정책을 효율적으로 수행하기 위하여 항만재개발사업에 관한 조문을 분리하여 별도로 제정된 항만재개발법에 해당 내용을 이관하고[156], 항만재개발사업에 관한 사항을 제외한 항만의 개발, 항만의 관리와 사용, 항만배후단지 등 항만의 지정·개발·관리 및 사용에 관한 사항은 전부개정 항만법에서 규정하게 된 것인바, 이에 따라 항만재개발법 제39조에서 규정하고 있는 개발이익의 재투자에 관한 사항도 구 항만법 제64조의6에서 규정하고 있던 내용을 항만재개발법에 그대로 이관하면서, 같은 법 제39조제1항에 제3호를 신설하여 개발이익 재투자 용도에 창업보육센터 등 항만물류 산업의 일자리 창출을 위한 시설을 추가하여 규정함으로써 개발이익을 재투자할 수 있는 시설의 범위만을 확대한 것인데[157], 이러한 입법 취지 및 해당 규정의 내용을 종합적으로 고려하면, 구 항만법의 일부개정 이후 「항만법」을 전부개정하고 항만재개발법을 제정하는 과정에서 항만재개발법 제39조에서 규정하고 있는 항만재개발사업의 개발이익 재투자 제도의 본질적인 사항에 대해서는 변경이 이루어지지 않았고, 그러한 변경을 하려는 입법의도가 있었던 것으로 보이지 않으므로, 구 항만법 시행일 전에 사업시행자로 지정받아 구 항만법 부칙 제6조에 따라 개발이익의 재투자 의무가 없던 사업시행자의 경우에는 전부개정 항만법 및 항만재개발법 시행 이후에도 구 항만법 부칙 제6조의 효력이 실효되지 않고 계속 적용된다고 보는 것이 타당할 것입니다.

---

154) 대법원 2013. 3. 28. 선고 2012재두299 판결례 참조

155) 2014. 3. 24. 법률 제12545호로 일부개정되어 2014. 9. 25. 시행된 「항만법」 개정이유 및 주요내용 참조

156) 2019. 1. 13. 의안번호 2018017호로 발의된 항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률안에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 검토보고서 참조

157) 2020. 1. 29. 법률 제16904호로 제정된 「항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률」 조문별 제정이유서 참조

아울러 전부개정 항만법 및 항만재개발법이 시행됨에 따라 구 항만법 부칙 제6조의 효력이 상실된다고 본다면, 구 항만법 시행일인 2014년 9월 25일 전에 사업시행자로 지정되어 개발이익 재투자 대상이 아니었던 사업시행자는 약 6년이 경과한 전부개정 항만법 및 항만재개발법의 시행일(2020년 7월 30일)에 개발이익 재투자 대상이 되는 결과가 초래될 수 있는바, 이 경우 해당 사업시행자에게 예측할 수 없는 부담이 발생하게 되어 구 항만법 부칙 제6조에 대한 해당 사업시행자의 신뢰를 소급하여 침해할 여지가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 구 항만법 시행일(2014년 9월 25일) 전에 사업시행자로 지정받아 구 항만법 부칙 제6조에 따라 개발이익의 재투자 의무가 없던 사업시행자는 항만재개발법 제39조에 따른 개발이익을 재투자해야 하는 사업시행자에 해당하지 않습니다.

관계법령

항만법(2014. 3. 24. 법률 제12545호로 일부개정되어 2014. 9. 25. 시행된 것)

제64조의6(개발이익의 재투자) ① 사업시행자는 항만재개발사업으로 발생하는 개발이익을 100분의 25의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도로 사용하여야 한다.

1. 해당 사업구역의 항만시설용지 등의 분양가격이나 임대료의 인하
2. 해당 사업구역의 기반시설이나 공공시설의 설치비용에의 충당

② 사업시행자는 제1항에 따른 개발이익의 재투자가 차질 없이 이루어질 수 있도록 그 발생된 개발이익을 구분하여 회계처리하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ (생 략)

법률 제12545호 항만법 일부개정법률 부칙

제6조(개발이익의 재투자에 관한 적용례) 제64조의6의 개정규정은 이 법 시행 후 사업시행자로 지정받는 경우부터 적용한다.

법률 제16902호 항만법 전부개정법률 부칙

제12조(처분 등에 관한 일반적 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 「항만법」에 따른 행정기관의 행위나 행정기관에 대한 행위는 그에 해당하는 이 법에 따른 행정기관의 행위나 행정기관에 대한 행위로 본다.

항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률(2020. 1. 29. 법률 제16904호로 제정되어 2020. 7. 30. 시행된 것)

제39조(개발이익의 재투자) ① 사업시행자는 항만재개발사업으로 발생하는 개발이익을 100분의 25의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도로 사용하여야 한다.

1. 해당 사업구역의 항만시설용지 등의 분양가격이나 임대료의 인하
2. 해당 사업구역의 기반시설이나 공공시설의 설치비용에의 충당
3. 해당 사업구역의 「중소기업창업 지원법」 제2조제7호에 따른 창업보육센터 등 항만물류 산업의 일자리 창출을 위한 시설의 설치비용에의 충당

② 사업시행자는 제1항에 따른 개발이익의 재투자가 차질 없이 이루어질 수 있도록 그 발생된 개발이익을 구분하여 회계처리하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ (생 략)

법률 제16904호 항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률 부칙

제3조(처분 등에 관한 일반적 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 「항만법」(법률 제16902호로 전부개정되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)에 따른 행정기관의 행위나 행정기관에 대한 행위는 그에 해당하는 이 법에 따른 행정기관의 행위나 행정기관에 대한 행위로 본다.

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0713, 24-0777

강릉시 – 국가관리무역항의 항만구역 밖에 항만시설이 위치한 구역이 국가관리무역항의 항만구역에 포함되는지 등(「항만법」 제3조제1항 등 관련)

01 질의요지

「항만법」 제2조제4호에서는 "항만구역"이란 항만[158]의 수상구역과 육상구역을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5호에서는 "항만시설"을 기본시설, 기능시설, 지원시설 등 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 말한다고 하면서(전단), 항로[가목1)], 하역시설[나목2)] 등의 시설이 항만구역 밖에 있는 경우에는 해양수산부장관이 지정·고시하는 시설로 한정한다(후단)고 규정하고 있는 한편,

「항만법」 제3조제1항에서는 항만은 무역항(제1호)과 연안항(제2호)으로 구분하되, 그 명칭·위치 및 구역은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조제1항 및 별표 1에서는 경인항(제1호가목), 동해·묵호항(제1호퍼목) 등 항만의 구분·명칭과 해당 항만의 위치 및 수상·육상구역을 세부적으로 규정하고 있으며, 같은 법 제3조제2항에서는 무역항은 체계적이고 효율적인 관리·운영을 위하여 수출입 화물량, 개발계획 및 지역균형발전 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가관리무역항(제1호)과 지방관리무역항(제2호)으로 세분할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 국가관리무역항을 국내외 육상·해상운송망의 거점으로서 광역권의 배후화물을 처리하거나 주요 기간산업 지원 등으로 국가의 이해에 중대한 관계를 가지는 항만으로 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조제2항 및 별표 2 제1호에서는 경인항, 동해·묵호항 등 총 14개의 항만을 국가관리무역항으로 규정하고 있는바,

가. 「항만법」 제3조제1항에 따른 항만의 명칭·위치 및 구역은 같은 법 시행령 별표 1에 규정된 것으로 한정되는지?

나. 「항만법」 제3조제2항 및 같은 법 시행령 제3조제2항, 별표 2 제1호에 따른 국가관리

158) "항만"이란 선박의 출입, 사람의 승선·하선, 화물의 하역·보관 및 처리, 해양친수활동 등을 위한 시설과 화물의 조립·가공·포장·제조 등 부가가치 창출을 위한 시설이 갖추어진 곳을 말하며(「항만법」 제2조제1호 참조), 이하 같음

무역항의 항만구역 밖에 있는 항만시설로서 「항만법」 제2조제5호 각 목 외의 부분 후단에 따라 해양수산부장관이 지정·고시[159]한 항만시설(이하 "이 사안 항만시설"이라 함)이 위치한 구역[160]은 국가관리무역항의 항만구역에 포함되는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

「항만법」 제3조제1항에 따른 항만의 명칭·위치 및 구역은 같은 법 시행령 별표 1에 규정된 것으로 한정됩니다.

나. 질의 나에 대해

이 사안 항만시설이 위치한 구역은 국가관리무역항의 항만구역에 포함되지 않습니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[161], 「항만법」 제3조제1항에서는 항만은 무역항(제1호)과 연안항(제2호)으로 구분한다고 규정하여 법률에서는 항만 구분의 대략적인 사항을 정하면서, "그 명칭·위치 및 구역은 대통령령으로 정한다"고 규정하여 항만의 명칭·위치 및 구역의 세부적인 사항은 하위법령에서 정하도록 위임하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조제1항 및 별표 1 제1호에서는 무역항에 속하는 경인항(가목), 동해·묵호항(퍼목) 등의 명칭과 해당 항만의 위치, 수상·육상구역을, 같은 표 제2호에서는 연안항에 속하는 용기포항(가목), 연평도항(나목) 등의 명칭과 해당

159) 「항만법 시행령」 제93조제1항제1호에 따라 「항만법」 제2조제5호 각 목 외의 부분 후단에 따른 항만시설의 지정·고시 권한은 지방해양수산청장에게 위임되어 있음

160) 「항만법」 제2조제5호 각 목 외의 부분 후단에 따른 해양수산부장관의 지정·고시에서 항만구역 밖 항만시설의 경계(항만구역, 지정구역, 항계선 등)로 고시된 부분을 말함

161) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

항만의 위치, 수상·육상구역을 세부적으로 정하고 있는바, 「항만법」 제3조제1항에 따른 항만의 명칭·위치 및 구역은 같은 법 시행령 별표 1에 규정된 것으로 한정된다는 것이 문언상 분명합니다.

한편 「항만법 시행령」 별표 1 제1호 및 제2호의 육상구역란에서는 각각 "해양수산부장관이 관할 시·도지사와 협의한 후 중앙항만정책심의회의 심의를 거쳐 지정·고시한 구역"을 항만의 육상구역으로 규정하고 있어, 항만의 명칭·위치 및 구역을 대통령령인 「항만법 시행령」이 아닌, 부령이나 고시 등 행정규칙으로도 정할 수 있다는 의견이 있으나, 「항만법」 제3조제1항에서는 항만의 명칭·위치 및 구역은 대통령령으로 정하도록 명확하게 위임하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 별표 1에서 항만의 "육상구역"을 해양수산부장관이 지정하여 고시한 구역으로 규정한 것이지, 부령이나 행정규칙에서 별표 1과 달리 항만명을 정하거나 항만의 위치, 구역을 정할 수 있도록 허용한 것은 아니므로, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 「항만법」 제3조제1항에 따른 항만의 명칭·위치 및 구역은 같은 법 시행령 별표 1에 규정된 것으로 한정됩니다.

나. 질의 나에 대해

먼저 「항만법」 제3조제1항에서는 항만은 무역항과 연안항으로 구분하되, 그 명칭·위치 및 구역은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 국내외 육상·해상운송망의 거점으로서 광역권의 배후화물을 처리하거나 주요 기간산업 지원 등으로 국가의 이해에 중대한 관계를 가지는 항만을 "국가관리무역항"으로 규정(제1호)하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조제1항 및 별표 1 제1호에서는 무역항의 명칭과 해당 항만의 위치와 수상·육상구역을, 같은 법 시행령 제3조제2항 및 별표 2 제1호에서는 국가관리무역항으로 경인항, 인천항, 동해·묵호항 등 총 14개의 무역항을 각각 규정하고 있는바, 이를 종합해 보면 「항만법」 제3조제2항제1호에 따른 "국가관리무역항"의 공간적 범위인 "항만구역"은 같은 법 시행령 별표 2 제1호에서 정하고 있는 총 14개의 국가관리구역항의 항만구역, 즉 시행령 별표 1 제1호에서 정하고 있는 수상구역 및 육상구역만으로 한정되는 것이 문언 및 규정의 체계상 분명합니다.

그렇다면 「항만법」 제2조제5호 각 목 외의 부분 후단에 따라 해양수산부장관이 지정·고시한 이 사안 항만시설이 위치한 구역은 같은 법 시행령 별표 1 제1호에서 규정하고 있는 국가관리무역항의 항만구역 밖에 위치하고 있으므로, 국가관리무역항의 항만구역에 해당하지

않는다고 해석하는 것이 문언 및 해당 법령의 규정 체계에 부합한다고 할 것입니다.

그리고 「항만법」 제2조제5호에서는 "항만시설"을 기본시설(가목), 기능시설(나목), 지원시설(다목) 등으로 규정하여 항만구역 안에 있는 시설을 세분화하여 정하되, 항만구역 밖에서도 안전한 선박의 출입이나 화물의 하역 등을 위하여 선착장, 하역시설 등을 설치할 필요성이 있는 점을 고려하여 이러한 시설이 항만구역 밖에 있는 경우에는 해양수산부장관이 지정·고시하는 시설에 한정하여 항만시설로 정할 수 있도록 하고 있어, "항만시설"은 항만구역 안뿐만 아니라 항만구역 밖에도 위치할 수 있다는 것을 전제하고 있는데, 이는 항만구역 밖에 있는 시설 중 해양수산부장관이 지정·고시하는 시설을 항만시설에 포함시켜 「항만법」에 따라 관리(제41조에 따른 항만시설 사용허가 등)하려는 것이지, 항만의 공간적 범위인 항만구역 자체를 확장하려는 취지로 볼 수는 없다고 할 것이고, "항만시설이 위치한 구역"이 같은 법 제2조제5호에 따른 "항만구역"과 동일한 개념이라고 보기도 어렵다고 할 것입니다.

따라서 이 사안 항만시설이 위치한 구역은 국가관리무역항의 항만구역에 포함되지 않습니다.

관계법령

항만법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "항만"이란 선박의 출입, 사람의 승선·하선, 화물의 하역·보관 및 처리, 해양친수활동 등을 위한 시설과 화물의 조립·가공·포장·제조 등 부가가치 창출을 위한 시설이 갖추어진 곳을 말한다.
2. "무역항"이란 국민경제와 공공의 이해(利害)에 밀접한 관계가 있고, 주로 외항선이 입항·출항하는 항만으로서 제3조제1항에 따라 대통령령으로 정하는 항만을 말한다.
3. (생 략)
4. "항만구역"이란 항만의 수상구역과 육상구역을 말한다.
5. "항만시설"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설을 말한다. 이 경우 다음 각 목의 시설이 항만구역 밖에 있는 경우에는 해양수산부장관이 지정·고시하는 시설로 한정한다.
   가. 기본시설
      1) 항로, 정박지, 소형선 정박지, 선회장(旋回場) 등 수역시설(水域施設)
      2) ~ 4) (생 략)
   나. ~ 바. (생 략)
6. ~ 15. (생 략)

제3조(항만의 구분 및 명칭·위치·구역 등) ① 항만은 다음 각 호의 항(港)으로 구분하되, 그 명칭·위치 및 구역은 대통령령으로 정한다.

1. 무역항
2. 연안항

② 무역항은 체계적이고 효율적인 관리·운영을 위하여 수출입 화물량, 개발계획 및 지역균형발전 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 항으로 세분할 수 있다.

1. 국가관리무역항: 국내외 육상·해상운송망의 거점으로서 광역권의 배후화물을 처리하거나 주요 기간산업 지원 등으로 국가의 이해에 중대한 관계를 가지는 항만
2. 지방관리무역항: 지역별 육상·해상운송망의 거점으로서 지역산업에 필요한 화물처리를 주목적으로 하는 항만

③·④ (생 략)

항만법 시행령

제3조(항만의 명칭 등) ① 법 제3조제1항에 따른 항만의 구분·명칭·위치 및 구역은 별표 1과 같다.

② 법 제3조제2항에 따른 국가관리무역항과 지방관리무역항은 별표 2와 같다.

③ (생 략)

제93조(권한의 위임) ① 해양수산부장관은 법 제104조제1항에 따라 법 제3조제2항제1호 및 같은 조 제3항제1호의 국가관리무역항 및 국가관리연안항에 관한 다음 각 호의 권한을 지방해양수산청장에게 위임한다.

1. 법 제2조제5호 각 목 외의 부분 후단에 따른 항만시설의 지정·고시
2. ~50. (생 략)

② (생 략)

[별표 1]

항만의 구분·명칭·위치 및 구역(제3조제1항 관련)

1. 무역항

항만명	위치	수상구역	육상구역
가. ~ 터.	(생 략)	(생 략)	
퍼. 동해·묵호항	강원특별자치도 동해시	동해시 냉천 동단에서 북위 37도 31분 10.29초, 동경 129도 8분 31.55초 지점과 북위 37도 31분 20.00초, 동경 129도 8분 43.79초 지점과 북위 37도 31분 19.71초, 동경 129도 12분 03.74초 지점과 북위 37도 28분 54.00초, 동경 129도 12분 03.35초 지점 및 동해항 남쪽 호안 끝단을 순차적으로 연결한 선 안의 해면과 어달동 오도 동방 북위 37도 33분 22.13초, 동경 129도 07분 16.75초 지점에서 진방위 90도로 1,350미터 지점과, 북위 37도 32분 10.13초, 동경 129도	해양수산부장관이 관할 시·도지사와 협의한 후 중앙항만정책심의회의 심의를 거쳐 지정·고시한 구역

허. ~ 도.	(생 략)	06분 53.75초 지점에서 진방위 90도로 1,900미터 지점을 각각 연결한 선 안의 해면 (생 략)	

2. 연안항 (생 략)

[별표 2]

국가관리무역항과 지방관리무역항의 구분(제3조제2항 관련)

구분	항만명
1. 국가관리무역항 (14개)	경인항, 인천항, 평택·당진항, 대산항, 장항항, 군산항, 목포항, 여수항, 광양항, 마산항, 부산항, 울산항, 포항항, 동해·묵호항
2. 지방관리무역항 (17개)	서울항, 태안항, 보령항, 완도항, 하동항, 삼천포항, 통영항, 장승포항, 옥포항, 고현항, 진해항, 호산항, 삼척항, 옥계항, 속초항, 제주항, 서귀포항

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0890, 24-0979

해양경찰청 - 「도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 「연안사고 예방에 관한 법률」 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우 같은 조에 따른 연안체험활동 안전수칙을 준수해야 하는지 등(「연안사고 예방에 관한 법률」 제11조 등 관련)

01 질의요지

「연안사고 예방에 관한 법률」(이하 "연안사고예방법"이라 함) 제4조에서는 연안사고 예방에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다고 규정하면서, 같은 법 제11조제2항에서 연안체험활동에 참가하려는 자(이하 "연안체험활동 참가자"라 함)를 모집하여 연안체험 프로그램을 운영하려는 자(이하 "연안체험활동 운영자"라 함)는 연안체험활동 안전수칙을 준수하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제11조의2제1항에서는 연안체험활동 운영자 및 같은 법 제11조제1항제1호의 안전관리요원(이하 "안전관리요원"이라 함)은 연안체험활동의 안전에 관하여 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 해양경찰청장이 실시하는 안전교육을 받아야 한다고 규정하고 있는 한편,

「도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률」(이하 "도농교류법"이라 함) 제4조에서는 이 법에 따른 도시와 농어촌의 교류를 촉진하기 위한 사업에 관하여는 다른 법률의 규정에도 불구하고 이 법을 우선 적용한다고 규정하면서, 같은 법 제7조제2항에서는 농어촌체험·휴양마을사업자[162]는 그 이용자들의 안전과 위생을 위하여 이용자에게 건강상 위해요인이 발생하지 아니하도록 영업 관련 시설 및 설비의 위생적이고 안전한 관리(제1호) 등의 사항을 지켜야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 시장·군수등[163]은 농어촌체험·휴양마을을 이용하는 사람들의 안전 및 위생 관리를 위하여 농어촌체험·휴양마을사업자에게 농림축산식품부령 또는 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 안전·위생교육을 하여야 한다고 규정하고 있는바,

162) 도농교류법 제5조에 따라 농어촌체험·휴양마을사업을 운영하는 자로 지정을 받은 마을협의회 또는 어촌계를 말하며(도농교류법 제2조제6호 참조), 이하 같음

163) 특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함)을 말하며(도농교류법 제5조제1항 참조), 이하 같음

가. 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우 같은 조에 따른 연안체험활동 안전수칙을 준수해야 하는지?

나. 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우 같은 법 제11조의2에 따른 연안체험활동 안전교육을 받아야 하는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우 같은 조에 따른 연안체험활동 안전수칙을 준수해야 합니다.

나. 질의 나에 대해

도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우 같은 법 제11조의2에 따른 연안체험활동 안전교육을 받아야 합니다.

03 이유

가. 질의 가에 대해

먼저 입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 경우에는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 어떤 행위가 둘 이상의 법률의 요건에 모두 해당한다면 둘 이상의 법률이 모두 적용된다고 할 것입니다[164].

164) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례, 대법원 2010. 9. 9 선고 2008두22631 판결례 참조

이와 관련하여 연안사고예방법은 연안해역에서 발생하는 연안사고의 예방에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전을 도모(제1조)하려는 법률로서 같은 법 제11조제1항에서는 해양경찰청장은 안전관리요원의 자격과 배치기준, 안전장비의 종류와 배치기준 등의 내용이 포함된 연안체험활동 안전수칙을 정하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 별표 1에서는 연안체험활동 안전수칙에 정하여야 할 사항으로 구명조끼 착용에 관한 사항 및 연안사고 발생 시 응급처치에 관한 사항 등을, 같은 규칙 별표 2에서는 안전관리요원의 자격과 배치기준(제1호 및 제2호)으로 인명구조요원 등 1명 이상의 안전관리요원을 두고 연안체험활동 참가자 10명 당 안전관리요원 1명 이상을 추가로 배치할 것 등을, 안전장비의 종류와 배치기준(제3호)으로 탑승정원이 연안체험활동 참가자 인원의 100퍼센트 이상인 비상구조선 등을 갖출 것 등을 규정하고 있습니다.

반면 도농교류법은 도시와 농어촌 간의 교류를 촉진하여 농어촌의 사회·경제적 활력을 증진시키고 도시민의 농어촌생활에 대한 체험과 휴양 수요를 충족시킴으로써 도시와 농어촌의 균형 발전과 국민의 삶의 질을 향상(제1조)시키려는 법률로서, 같은 법 제2조제5호에서 마을협의회 또는 어촌계가 마을의 자연환경, 전통문화 등 부존자원을 활용하여 도시민에게 생활체험·휴양공간 프로그램을 제공하고 지역 농림수산물 등을 판매하거나 숙박 또는 음식 등의 서비스를 제공하는 업을 농어촌체험·휴양마을사업으로 정의하고 있고, 같은 법 제7조제2항에서는 농어촌체험·휴양마을사업자가 이용자들의 안전과 위생을 위하여 준수하여야 하는 사항을 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 별표 1에서는 마을공동시설의 경우 안전성을 필요로 하는 체험이 행하여질 경우 체험객의 안전을 위한 안전표지 및 안전경고물을 설치하고 사전안전교육을 실시하도록 하는 등 안전시설기준(제2호) 등을 규정하고 있습니다.

이와 같이 연안사고예방법과 도농교류법은 그 입법목적이 다르고, 연안사고예방법에서는 도농교류법에서 정하고 있지 않은 연안체험활동과 직접적으로 관련된 구체적인 안전수칙을 정하고 있는 반면, 도농교류법에서는 연안체험활동보다 범위가 넓은 농어촌체험·휴양마을사업에 관하여 주로 건강상 위해요인을 방지하기 위한 영업 관련 시설의 위생적이고 안전한 관리 등 일반적인 내용을 규정하고 있어서 그 규율 사항도 다른바, 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우 도농교류법과 연안사고예방법의 관련 규정이 모두 적용된다고 보아야 할 것입니다.

한편 도농교류법 제4조에서 이 법에 따른 도시와 농어촌의 교류를 촉진하기 위한 사업에 관하여는 다른 법률의 규정에도 불구하고 이 법을 우선 적용한다고 규정하고 있으나, 이는 도농교류법에서 도시와 농어촌 교류를 촉진하기 위하여 규정한 사항이 다른 법률에서 규정한 내용과 다르다면 도농교류법의 규정을 우선 적용한다는 의미일 뿐, 같은 법에서 규정하지 아니한 모든 사안에 대해서까지도 다른 법률의 규정이 배제된다는 의미는 아니라고 할 것인바[165], 연안체험활동 참가자의 안전 확보를 위해서는 자격을 갖춘 안전관리요원의 적절한 배치와 안전장비 구비가 필요[166]하여 연안사고예방법 제11조, 같은 법 시행규칙 별표 1 및 별표 2에서 연안체험활동 시 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위한 구체적인 안전수칙을 규정하고 있는 것인데, 도농교류법 제7조제2항 및 같은 법 시행규칙 별표 1에서는 주로 지상에 위치하는 폐교와 마을공동시설의 소방시설 및 안전표지 설치 등에 대해 규정하고 있으므로, 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우에도 도농교류법 제4조를 근거로 연안사고예방법 제11조의 적용이 배제되는 것으로 보기는 어렵습니다.

아울러 연안사고예방법은 연안 위험요소에 대한 체계적 관리가 이루어지지 않아 다수의 인명사고가 발생하는 등 해양사고의 대부분을 차지하는 연안사고가 매년 증가함에 따라 연안에서 발생하는 인명사고를 사전에 예방하기 위해 제정[167]되었는바, 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 도농교류법에 따른 지도·점검 등을 받아 운영하는 연안체험 프로그램이라고 하더라도 연안사고의 위험과 사고 예방을 위한 안전수칙 준수의 필요성은 동일하게 인정된다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우 같은 조에 따른 연안체험활동 안전수칙을 준수해야 합니다.

나. 질의 나에 대해

먼저 입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 경우에는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 어떤 행위가 둘 이상의 법률의 요건에 모두 해당한다면 둘 이상의 법률이 모두 적용된다고 할 것입니다.

---

165) 법제처 2016. 11. 23. 회신 16-0529 해석례 참조

166) 2013. 11. 6. 의안번호 1907585호로 발의된 연안사고예방에 관한 법률안에 대한 국회 농림축산식품해양수산위원회 검토보고서 참조

167) 2014. 5. 21. 법률 제12657호로 제정되어 2014. 8. 22. 시행된 연안사고예방법 제정이유 참조

이와 관련하여 연안사고예방법은 연안해역에서 발생하는 연안사고의 예방에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전을 도모(제1조)하려는 법률로서, 같은 법 제11조의2제1항에서는 연안체험활동 운영자 및 안전관리요원은 연안체험활동의 안전에 관하여 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 해양경찰청장이 실시하는 안전교육을 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제6조의2제1항 및 별표 3에서는 연안체험활동 운영자 및 안전관리요원이 이수해야 하는 안전교육 내용 및 교육시간을 정하면서, 체험활동의 종류별로 수상안전 수칙, 관련 법령 등, 응급처치, 인명구조를 내용으로 하는 교육을 일정 시간 이상 신규 종사일 전 6개월 이내에 1회 이상 이수하도록 하는 등의 내용을 규정하고 있습니다.

반면 도농교류법은 도시와 농어촌 간의 교류를 촉진하여 농어촌의 사회·경제적 활력을 증진시키고 도시민의 농어촌생활에 대한 체험과 휴양 수요를 충족시킴으로써 도시와 농어촌의 균형 발전과 국민의 삶의 질을 향상(제1조)시키려는 법률로서, 같은 법 제2조제5호에서 마을협의회 또는 어촌계가 마을의 자연환경, 전통문화 등 부존자원을 활용하여 도시민에게 생활체험·휴양공간 프로그램을 제공하고 지역 농림수산물 등을 판매하거나 숙박 또는 음식 등의 서비스를 제공하는 업을 농어촌체험·휴양마을사업으로 정의하고 있고, 같은 법 제7조제4항에서는 시장·군수등은 농어촌체험·휴양마을을 이용하는 사람들의 안전 및 위생관리를 위하여 농어촌체험·휴양마을사업자에게 안전·위생교육을 하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제5조제1항에서는 같은 법 제7조제4항에 따른 안전·위생교육은 농어촌체험·휴양마을사업자로 지정받은 마을협의회 또는 어촌계의 대표자나 그 대표자가 지정하는 안전위생책임자를 대상으로 시장·군수등이 연 4시간으로 실시하여야 하며, 이 경우 시장·군수등은 교육 목적 및 교육 대상자별로 적절한 교재를 만들어 교육대상자에게 제공하여야 한다고 규정하고 있습니다.

이와 같이 연안사고예방법과 도농교류법은 그 입법목적이 다르고, 연안사고예방법에서는 도농교류법과 달리 연안체험활동 운영자는 물론 직접 연안체험 프로그램에 배치되어 안전관리 업무를 수행하는 안전관리요원도 교육대상자로 규정하여 연안체험활동 안전관리에 필수적인 응급처치 등의 교육 내용을 구체적으로 정하고 있는 반면, 도농교류법에서는 연안체험활동보다 범위가 넓은 농어촌체험·휴양마을사업과 관련하여 농어촌체험·휴양마을사업자로 지정받은 마을협의회 또는 어촌계의 대표자나 그 대표자가 지정하는 안전위생책임자를 대상자로 시장·군수등이 적절한 교재를 만들어 제공해야 한다고 규정하고 있을 뿐 구체적인 내용은 정하고 있지 않은바, 교육의 대상자 및 내용이 서로 다르므로, 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험

프로그램을 운영하는 경우에는 도농교류법과 연안사고예방법의 관련 규정이 모두 적용된다고 보아야 할 것입니다.

한편 도농교류법 제4조에서 이 법에 따른 도시와 농어촌의 교류를 촉진하기 위한 사업에 관하여는 다른 법률의 규정에도 불구하고 이 법을 우선 적용한다고 규정하고 있으나, 이는 같은 법에서 도시와 농어촌 교류를 촉진하기 위하여 규정한 사항이 다른 법률에서 규정한 내용과 다르다면 도농교류법의 규정을 우선 적용한다는 의미일 뿐, 같은 법에서 규정하지 아니한 모든 사안에 대해서까지도 다른 법률의 규정이 배제된다는 의미는 아니라고 할 것인바[168], 연안사고예방법령에서는 연안체험 프로그램에 배치되어 직접 안전관리를 하는 안전관리요원도 안전교육의 대상자로 하고 있고, 연안체험활동 시 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위해 필요한 안전교육의 내용도 구체적으로 정하고 있는데 반해, 도농교류법령에서는 마을협의회 또는 어촌계의 대표자 등을 교육 대상자로 하여, 안전·위생교육에 대하여 시장·군수등이 적절한 교재를 만들어 제공하도록 하고 있는 등 두 법령에서 교육의 대상자나 내용에 대하여 서로 규정하고 있는 것이 다르므로, 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우 도농교류법 제4조를 근거로 연안사고예방법 제11조의2의 적용이 배제된다고 보기는 어렵습니다.

아울러 연안사고예방법은 연안 위험요소에 대한 체계적 관리가 이루어지지 않아 다수의 인명사고가 발생하는 등 해양사고의 대부분을 차지하는 연안사고가 매년 증가함에 따라 연안에서 발생하는 인명사고를 사전에 예방하기 위해 제정되었는바, 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 같은 법에 따른 관리·점검 등을 받아 운영하는 연안체험 프로그램이라고 하더라도 연안사고의 위험과 사고 예방을 위한 연안체험활동 안전교육의 필요성은 동일하게 인정된다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 도농교류법 제2조제6호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업자가 연안사고예방법 제11조에 따른 연안체험 프로그램을 운영하는 경우 같은 법 제11조의2에 따른 연안체험활동 안전교육을 받아야 합니다.

168) 법제처 2016. 11. 23. 회신 16-0529 해석례 참조

관계법령

연안사고 예방에 관한 법률

제4조(다른 법률과의 관계) 연안사고 예방에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

제11조(연안체험활동 안전수칙) ① 해양경찰청장은 연안체험활동 중 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 연안체험활동 안전수칙(이하 "안전수칙"이라 한다)을 정하여야 한다.

1. 안전관리요원의 자격과 배치기준
2. 안전장비의 종류와 배치기준
3. 그 밖에 해양수산부령으로 정하는 사항

② 연안체험활동에 참가하려는 자(이하 "연안체험활동 참가자"라 한다)를 모집하여 연안체험 프로그램을 운영하려는 자(이하 "연안체험활동 운영자"라 한다)는 안전수칙을 준수하여야 한다.

④ 제1항에 따른 안전관리요원의 자격과 배치기준, 안전장비의 종류와 배치기준 등에 필요한 사항은 해양수산부령으로 정한다.

제11조의2(연안체험활동 안전교육) ① 연안체험활동 운영자 및 제11조제1항제1호의 안전관리요원은 연안체험활동의 안전에 관하여 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 해양경찰청장이 실시하는 안전교육을 받아야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률

제4조(다른 법률과의 관계) 이 법에 따른 도시와 농어촌의 교류를 촉진하기 위한 사업에 관하여는 다른 법률의 규정에도 불구하고 이 법을 우선 적용한다.

제7조(농어촌체험·휴양마을사업의 관리 등) ① 제5조에 따라 농어촌체험·휴양마을사업자를 지정한 시장·군수등은 농어촌체험·휴양마을사업의 발전과 활성화를 위해 성실히 노력하고, 농어촌체험·휴양마을사업이 원활히 운영되도록 지도·점검 및 관리를 하여야 한다.

② 농어촌체험·휴양마을사업자는 그 이용자들의 안전과 위생을 위하여 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

1. 이용자에게 건강상 위해요인이 발생하지 아니하도록 영업 관련 시설 및 설비의 위생적이고 안전한 관리
2. 그 밖에 공중이용시설에서의 소방시설 설치 기준 등 농림축산식품부령 또는 해양수산부령으로 정하는 사항의 준수

③ 시장·군수등은 농어촌체험·휴양마을사업이 제2항에 따른 안전·위생기준에 맞지 아니하게 설치·운영되거나 그 밖의 지정요건 등에 맞지 아니하면 농어촌체험·휴양마을사업자의 대표자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 개선명령을 할 수 있다.

④ 시장·군수등은 농어촌체험·휴양마을을 이용하는 사람들의 안전 및 위생 관리를 위하여 농어촌체험·휴양마을사업자에게 농림축산식품부령 또는 해양수산부령으로 정하는 바에 따라 안전·위생교육을 하여야 한다.



보건복지·식품의약품

제1절 보건복지
제2절 식품의약품

제1절 보건복지

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-0913

민원인 – 「의료법」 제17조제3항에 따른 진단서의 범위(「의료법」 제17조제3항 등 관련)

01 질의요지

「의료법」 제17조제3항에서는 '의사·치과의사 또는 한의사는 자신이 진찰하거나 검안(檢案)한 자에 대한 진단서·검안서 또는 증명서 교부를 요구받은 때에는 정당한 사유 없이 거부하지 못한다'고 규정하고 있는바, 같은 항에 따라 의사·치과의사 또는 한의사가 정당한 사유 없이 교부를 거부하지 못하는 '진단서'에 「병역법 시행규칙」 별지 제106호서식의 병무용진단서가 포함되는지?

02 회답

「의료법」 제17조제3항에 따라 의사·치과의사 또는 한의사가 정당한 사유 없이 교부를 거부하지 못하는 '진단서'에는 「병역법 시행규칙」 별지 제106호서식의 병무용진단서는 포함되지 않습니다.

03 이유

먼저 「의료법」 제17조제3항에서는 '의사·치과의사 또는 한의사는 자신이 진찰하거나 검안한 자에 대한 진단서·검안서 또는 증명서 교부를 요구받은 때에는 정당한 사유 없이 거부하지 못한다'고 규정하면서, 같은 조 제5항에서는 '같은 조 제1항부터 제4항까지의

규정에 따른 진단서, 증명서의 서식·기재사항, 그 밖에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다'고 규정하고 있는데, 그 위임받은 사항을 정한 「의료법 시행규칙」에서는 의사·치과의사 또는 한의사가 발급하는 진단서를 유형별로 ① 일반적인 '진단서(제9조제1항 및 별지 제5호의2서식)', ② 질병의 원인이 상해로 인한 것인 경우에 교부하는 '상해진단서(제9조제2항 및 별지 제5호의3서식)' 및 ③ 사망자에 대하여 교부하는 '사망진단서'(제10조 및 별지 제6호 서식)'로 구분하여 각각 그 서식과 기재사항을 정하고 있는바, 이러한 진단서·상해진단서·사망진단서가 같은 법 제17조제3항에 따른 '진단서'에 해당한다는 점은 명확합니다.

그런데 「병역법 시행규칙」 별지 제106호서식의 병무용진단서(이하 "병무용진단서"라 함)는 같은 규칙에 따라 사회복무요원의 분할복무(제41조의2제1항제1호), 병역의무이행일의 연기(제87조제1항제1호), 병역준비역의 병역면제(제93조제1항제1호), 현역병입영 대상자 등의 병역처분변경(제95조제1항제1호) 등과 같은 병역의무와 관련된 각종 신청 시 제출해야 하는 서류로서, 의료법령에 따라 의사·치과의사 또는 한의사가 직접 진찰한 환자에 대해 교부하는 '진단서·상해진단서·사망진단서'와는 그 근거 법령과 제출용도가 구분되는 별개의 서류이고, 「병역법 시행규칙」 별지 제106호서식에서는 병무용진단서에 '현재까지의 치료경과', '현재까지의 일상적 생활 상태와 운동능력', '치료 후 심신장애에 관한 의견', '병명을 진단한 검사항목' 등을 작성하도록 규정하여, 「의료법 시행규칙」에 따른 '진단서·상해진단서·사망진단서'와는 그 기재사항에 있어서 차이가 있는바, '의사·치과의사 또는 한의사'가 진찰하여 교부하는 것이라는 이유로 병무용진단서가 「의료법」 제17조제3항에 따라 정당한 사유 없이 교부를 거부하지 못하는 '진단서'에 포함된다고 보기는 어렵습니다.

더욱이 어떠한 행위에 대하여 형벌이 부과되는 경우 관련 규정의 해석은 엄격해야 하고, 명문규정의 의미를 당사자에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석하는 것은 죄형법정주의 원칙에 어긋나는 것으로서 허용되지 않는다고 할 것인데[1], 「의료법」 제90조에서는 같은 법 제17조제3항을 위반한 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하여 정당한 사유 없이 '진단서' 교부를 거부한 자에 대한 벌칙을 규정하고 있는바, 같은 법 제17조제3항에 따라 정당한 사유 없이 교부를 거부하지 못하는 '진단서'에 병무용진단서까지 포함된다고 보는 것은 명문의 규정이 없음에도 불구하고 형벌 부과와 관련된 규정을 유추·확장 해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

따라서 「의료법」 제17조제3항에 따라 의사·치과의사 또는 한의사가 정당한 사유 없이 교부를 거부하지 못하는 '진단서'에는 병무용진단서는 포함되지 않습니다.

---

1) 대법원 2005. 11. 24. 선고 2002도4758 판결례 참조

관계법령

의료법

제17조(진단서 등) ① 의료업에 종사하고 직접 진찰하거나 검안(檢案)한 의사[이하 이 항에서는 검안서에 한하여 검시(檢屍)업무를 담당하는 국가기관에 종사하는 의사를 포함한다], 치과의사, 한의사가 아니면 진단서·검안서·증명서를 작성하여 환자(환자가 사망하거나 의식이 없는 경우에는 직계존속·비속, 배우자 또는 배우자의 직계존속을 말하며, 환자가 사망하거나 의식이 없는 경우로서 환자의 직계존속·비속, 배우자 및 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에는 형제자매를 말한다) 또는 「형사소송법」 제222조제1항에 따라 검시(檢屍)를 하는 지방검찰청검사(검안서에 한한다)에게 교부하지 못한다. (단서 생략)

② (생 략)

③ 의사·치과의사 또는 한의사는 자신이 진찰하거나 검안한 자에 대한 진단서·검안서 또는 증명서 교부를 요구받은 때에는 정당한 사유 없이 거부하지 못한다.

④ (생략)

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 진단서, 증명서의 서식·기재사항, 그 밖에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

병역법 시행령

제168조(의료시설의 지정 등) ① 지방병무청장(병무지청장을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 병역판정신체검사, 병역준비역의 병역면제 처분 및 병역처분변경 등에 참조할 수 있는 병무용진단서 발급의료기관을 지정할 수 있다.

②·③ (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 23-1050

전북특별자치도 진안군 – 「장애인복지법」 제63조제2항에 따른 “장애인복지단체”의 범위(「장애인복지법」 제63조제2항 등 관련)

01 질의요지

「장애인복지법」 제63조제1항에서는 국가와 지방자치단체는 장애인의 복지를 향상하고 자립을 돕기 위하여 장애인복지단체를 보호·육성하도록 노력해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 같은 조 제1항에 따른 단체의 사업·활동 또는 운영이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「비영리민간단체 지원법」 제4조제1항에서는 같은 법이 정한 지원을 받고자 하는 비영리민간단체는 그의 주된 공익활동을 주관하는 중앙행정기관의 장, 시·도지사[2]나 「지방자치법」 제198조제2항제1호에 따른 인구 100만 이상 대도시(이하 “특례시”라 함)의 장에게 등록을 신청해야 하며, 등록신청을 받은 중앙행정기관의 장, 시·도지사나 특례시의 장은 그 등록을 수리해야 한다고 규정하고 있는바,

「비영리민간단체 지원법」 제4조제1항에 따라 등록된 비영리민간단체(이하 “등록비영리민간단체”라 함) 중 「장애인복지법」 제63조제2항에 따라 지방자치단체가 그 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있는 장애인복지단체는 ‘법인’으로 한정되는지?

02 회답

등록비영리민간단체 중 「장애인복지법」 제63조제2항에 따라 지방자치단체가 그 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있는 장애인복지단체는 ‘법인’으로 한정되지 않습니다.

2) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사를 말하며, 이하 같음.

03 이유

「장애인복지법」 제63조에서는 국가와 지방자치단체는 장애인의 복지를 향상하고 자립을 돕기 위하여 장애인복지단체를 보호·육성하도록 노력해야 한다고 규정(제1항)하면서, 예산의 범위 안에서 장애인복지단체의 사업·활동 또는 운영이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다고 규정(제2항)하고 있는데, "장애인복지단체"의 의미나 범위에 대해서는 장애복지법령에서 별도로 규정하고 있지 않습니다.

그런데 '단체'는 통상적으로 '같은 목적을 달성하기 위하여 모인 사람들의 일정한 조직체' 또는 '여러 사람이 모여서 이루어진 집단' 등을 의미[3]하므로, 설립등기를 함으로써 성립되어 법적 권리·의무의 주체가 되는 '법인'[4]으로 한정되는 개념이라 볼 수 없는 한편, 「장애인복지법」에는 "비영리법인" 등의 용어를 사용하여 그 규율 대상을 '법인'으로 한정하고 있는 규정이 존재하는 점(제59조의11제4항), 같은 법 제63조에서 "장애인복지단체"에 해당하기 위한 요건을 별도로 정하거나 '법인'의 형태로 설립된 단체만 "장애인복지단체"에 해당하는 것으로 명시하고 있지 않은 점 등을 종합하면, '등록비영리민간단체 중 법인이 아닌 비영리민간단체'가 법인이 아니라는 이유만으로 「장애인복지법」 제63조에 따른 "장애인복지단체"에 해당하지 않는다고 보기는 어렵습니다.

그리고 2015년 12월 29일 법률 제13663호로 「장애인복지법」을 일부개정하면서 같은 법 제63조제2항을 개정하여 종전에는 장애인복지단체의 '사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비'만을 보조 대상 경비로 규정하고 있던 것을 현행과 같이 '운영에 필요한 경비'까지 보조할 수 있도록 하였는바, 이는 2014년 5월 28일 법률 제12687호로 「지방재정법」이 일부개정되면서 같은 법에 제32조의2가 신설되어 법령에 명시적인 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없게 됨에 따라 지방자치단체가 장애인복지단체에 운영비를 교부할 수 있는 법적 근거를 명문화하여 장애인복지단체의 안정적인 운영을 지원하려는 취지[5]라 할 것인데, 등록비영리민간단체는 공익활동을 수행하는 것을 주된 목적으로 하여 '법인이 아닌 단체일 경우에는 대표자 또는 관리인이 있을 것'(제6호) 등 「비영리민간단체 지원법」 제2조 각 호의 요건을 갖추어 그 주된 공익활동을 주관하는 중앙행정기관의 장, 시·도지사나 특례시의 장에게 등록한 단체로서, 법인이 아닌 등록비영리

3) 국립국어원 표준국어대사전 참조

4) 「민법」 제33조 참조

5) 법제처 2020. 5. 28. 회신 20-0094 해석례 및 2015. 8. 28. 의안번호 제1916626호로 발의된 장애인복지법 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 보건복지위원회 심사보고서 참조

민간단체의 경우에도 장애인의 복지를 향상하고 자립을 돕기 위한 공익활동을 활발히 수행하는 등 그 안정적인 운영을 지원함으로써 장애인 복지 증진을 도모할 필요성이 있는 경우가 있을 수 있으므로, 등록비영리민간단체가 법인이 아닌 경우에는 「장애인복지법」 제63조제2항에 따른 "장애인복지단체"에서 당연히 제외된다고 보는 것은 관련 규정의 취지에 부합한다고 보기 어렵습니다.

아울러 「장애인복지법」 제63조제2항에서는 국가와 지방자치단체가 '예산의 범위 안에서' 장애인복지단체의 운영에 필요한 경비의 '전부 또는 일부를 보조할 수 있다'고 규정하고 있는바, 지방자치단체는 '등록비영리민간단체 중 법인이 아닌 비영리민간단체'에 대하여 해당 지방자치단체의 재정 상황, 등록비영리민간단체의 활동 실적 및 계획, 장애인 복지 향상에 대한 기여도, 운영비 교부의 필요성 등을 종합적으로 고려하여 보조 여부 및 수준을 결정할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 등록비영리민간단체 중 「장애인복지법」 제63조제2항에 따라 지방자치단체가 그 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있는 장애인복지단체는 '법인'으로 한정되지 않습니다.

관계법령

지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률

제6조(지방보조금의 예산 편성 및 운영) ① (생 략)
② 지방자치단체의 장은 법령에 명시적 근거가 있는 경우 외에는 지방보조금을 운영비로 교부할 수 없다. 이 경우 운영비로 사용할 수 있는 경비의 종목은 대통령령으로 정한다.
③ (생 략)

장애인복지법

제63조(단체의 보호·육성) ① 국가와 지방자치단체는 장애인의 복지를 향상하고 자립을 돕기 위하여 장애인복지단체를 보호·육성하도록 노력하여야 한다.
② 국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업·활동 또는 운영이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.

비영리민간단체 지원법

제2조(정의) 이 법에 있어서 "비영리민간단체"라 함은 영리가 아닌 공익활동을 수행하는 것을 주된 목적으로 하는 민간단체로서 다음 각호의 요건을 갖춘 단체를 말한다.

1. 사업의 직접 수혜자가 불특정 다수일 것
2. 구성원 상호간에 이익분배를 하지 아니할 것
3. 사실상 특정정당 또는 선출직 후보를 지지·지원 또는 반대할 것을 주된 목적으로 하거나, 특정 종교의 교리전파를 주된 목적으로 설립·운영되지 아니할 것
4. 상시 구성원수가 100인 이상일 것
5. 최근 1년 이상 공익활동실적이 있을 것
6. 법인이 아닌 단체일 경우에는 대표자 또는 관리인이 있을 것

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0003

민원인 – 응급환자의 이송을 목적사업으로 하여 설립된 비영리법인의 구급차 등의 사용 범위(「응급의료에 관한 법률」 제44조제1항 및 제45조제1항 등 관련)

01 질의요지

「응급의료에 관한 법률」(이하 "응급의료법"이라 함) 제44조제1항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 외에는 구급차등[6]을 운용할 수 없다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서는 구급차등을 운용할 수 있는 자로 '응급환자의 이송을 목적사업으로 하여 보건복지부장관의 설립허가를 받은 비영리법인(이하 "응급환자이송목적비영리법인"이라 함)'을 규정하고 있는 한편,

응급의료법 제45조제1항에서는 구급차등은 '응급환자 이송'(제1호), '응급의료를 위한 혈액, 진단용 검사대상물 및 진료용 장비 등의 운반'(제2호), '응급의료를 위한 응급의료종사자의 운송'(제3호), '사고 등으로 현장에서 사망하거나 진료를 받다가 사망한 사람의 의료기관 등으로의 이송'(제4호) 및 '그 밖에 보건복지부령으로 정하는 용도'(제5호) 외의 용도로는 사용할 수 없다고 규정하고 있는바,

응급환자이송목적비영리법인[7]이 응급의료법 제45조제1항제2호부터 제5호까지의 용도로 구급차등을 사용하는 것이 금지되는지?[8]

02 회답

응급환자이송목적비영리법인은 응급의료법 제45조제1항제2호부터 제5호까지의 용도로 구급차등을 사용하는 것이 금지되지 않습니다.

---

6) 응급의료법 제2조제6호에 따른 "구급차등"을 말하며, 이하 같음.

7) 응급의료법 제44조제1항제1호부터 제4호까지에 따른 구급차등의 운용자에는 해당하지 않는 것으로 전제함.

8) 응급환자이송목적비영리법인의 정관 등에 '응급의료법 제45조제1항제2호부터 제5호까지의 용도로 구급차등을 사용하는 것이 금지된다'는 내용이 별도로 기재되지 않은 경우임을 전제함.

03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[9], 구급차등의 사용이 금지되는 용도에 관하여 규정하고 있는 응급의료법 제45조제1항에서는 "구급차등은 다음 각 호의 용도 외에는 사용할 수 없다"고 규정하고 있을 뿐, 구급차등의 운용 주체에 따라 구급차등의 사용 용도를 달리 정하고 있지 않은바, 같은 항의 문언상 응급환자이송목적비영리법인에서 운용하는 구급차등은 같은 항 각 호의 용도 외로 사용하는 것이 금지될 뿐, 같은 항 제2호부터 제5호까지의 용도로 구급차등을 사용하는 것이 금지된다고 볼 수는 없습니다.

그리고 응급의료법 제45조제1항에서는 구급차등을 응급환자 이송(제1호), 응급의료를 위한 혈액·진료용 장비의 운반(제2호), 응급의료를 위한 응급의료종사자의 운송(제3호), 구급차등의 이용이 불가피한 척추장애환자의 이송(제5호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제37조제2호) 등의 한정된 용도로 사용할 수 있도록 함으로써 응급환자의 이송 뿐만 아니라 응급의료를 위한 혈액 운반 등 구급차등으로 이송이 필요한 환자 또는 의료자원의 신속하고 안전한 이동이 필요한 경우 등에도 구급차등을 사용할 수 있도록 허용한 것으로 보이는바, 응급환자이송목적비영리법인 역시 '응급환자 이송' 뿐만 아니라 같은 법 제45조제1항제2호부터 제5호까지 열거된 용도로도 구급차등을 사용할 수 있다고 보는 것이 같은 조의 규정체계 및 취지에도 부합합니다.

아울러 ① 응급의료법 제44조제2항에서는 '의료기관은 구급차등의 운용을 같은 법에 따라 응급환자이송업의 허가를 받은 자(이하 "이송업자"라 함) 또는 응급환자이송목적비영리법인에 위탁할 수 있다'고 규정하여 이송업자와 응급환자이송목적비영리법인이 운용하는 구급차등의 사용 범위에 차이가 있는 것으로 전제하고 있지 않다는 점, ② 응급환자이송목적비영리법인도 응급의료법령에 따른 구급차의 형태, 표시, 내부장치 등에 관한 기준(법 제46조), 구급차등에 갖추어야 하는 의료장비 및 구급의약품 등의 기준(법 제47조), 구급차등 출동 시 응급구조사 등의 탑승의무(법 제48조) 등을 준수할 의무가 있다는 점, ③ "응급의료"란 응급환자가 발생한 때부터 생명의 위험에서 회복되거나 심신상의 중대한 위해가 제거되기까지의 과정에서 응급환자를 위하여 하는 상담·구조·이송·응급처치 및 진료 등의 조치를 말하는 것(같은 법 제2조제2호)으로서, '응급환자'의 발생을 전제하고 있는바, 응급의료를 위한 혈액 등의 운반, 응급의료를 위한 응급의료종사자의 운송(같은 법 제45조제1항제2호

9) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

및 제3호) 등도 '응급환자'를 위한 행위라는 점에서 응급환자이송목적비영리법인의 설립 목적인 '응급환자 이송'(같은 항 제1호)과 연관된 업무로 볼 측면이 있다고 할 것인 점 등도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 응급환자이송목적비영리법인은 응급의료법 제45조제1항제2호부터 제5호까지의 용도로 구급차등을 사용하는 것이 금지되지 않습니다.



관계법령

응급의료에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 5. (생 략)
6. "구급차등"이란 응급환자의 이송 등 응급의료의 목적에 이용되는 자동차, 선박 및 항공기 등의 이송수단을 말한다.
7. (생 략)
8. "응급환자이송업"이란 구급차등을 이용하여 응급환자 등을 이송하는 업(業)을 말한다.

제44조(구급차등의 운용자) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 외에는 구급차등을 운용할 수 없다.

1. 국가 또는 지방자치단체
2. 「의료법」 제3조에 따른 의료기관
3. 다른 법령에 따라 구급차등을 둘 수 있는 자
4. 이 법에 따라 응급환자이송업(이하 "이송업"이라 한다)의 허가를 받은 자
5. 응급환자의 이송을 목적사업으로 하여 보건복지부장관의 설립허가를 받은 비영리법인

②·③ (생 략)

제45조(다른 용도에의 사용 금지) ① 구급차등은 다음 각 호의 용도 외에는 사용할 수 없다.

1. 응급환자 이송
2. 응급의료를 위한 혈액, 진단용 검사대상물 및 진료용 장비 등의 운반
3. 응급의료를 위한 응급의료종사자의 운송
4. 사고 등으로 현장에서 사망하거나 진료를 받다가 사망한 사람을 의료기관 등에 이송
5. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 용도

②·③ (생 략)

응급의료에 관한 법률 시행규칙

제37조(구급차등의 용도) 법 제45조제1항제5호에서 "보건복지부령으로 정하는 용도"란 다음 각 호의 용도를 말한다.

1. 「지역보건법」 제2조제1호에 따른 지역보건의료기관에서 행하는 보건사업의 수행에 필요한 업무
2. 구급차등의 이용이 불가피한 척추장애환자 또는 거동이 불편한 환자의 이송
3. 다수인이 모이는 행사 등에서 발생되는 응급환자 이송을 위한 대기

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0048

민원인 – 「의료법」 제3조에 따른 의료기관의 구급차등 운용신고 수리 시 운용지역을 제한할 수 있는지 여부(「응급의료에 관한 법률」 제51조 등 관련)

01 질의요지

「응급의료에 관한 법률」(이하 "응급의료법"이라 함) 제44조제1항에서는 「의료법」 제3조에 따른 의료기관(이하 "의료기관"이라 함)(제2호), 이송업[10]의 허가를 받은 자(제4호) 등에 해당하는 자 외에는 구급차등[11]을 운용할 수 없도록 규정하고 있고, 응급의료법 제44조의2 제2항 및 제3항에서는 의료기관과 이송업의 허가를 받은 자 등이 구급차등을 운용하고자 할 때에는 해당 구급차등을 관계 법령에 따라 등록한 후 지체 없이 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장[12]에게 신고해야 하고, 시장·군수·구청장은 그 내용을 검토하여 같은 법에 적합하면 신고를 수리해야 한다고 규정하고 있는 한편,

응급의료법 제51조제1항 전단에서는 이송업을 하려는 자는 보건복지부와 국토교통부의 공동부령으로 정하는 시설 등을 갖추어 관할 시·도지사[13]의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 시·도지사는 같은 조 제1항에 따라 허가(이하 "이송업 허가"라 함)를 하는 경우에는 시설의 규모 등을 고려하여 영업지역을 제한하여 허가할 수 있다고 규정하고 있는바,

응급의료법 제44조의2제3항에 따라 시장·군수·구청장이 같은 조 제2항에 따른 의료기관의 구급차등의 운용에 관한 신고(이하 "구급차등 운용신고"라 함)를 수리할 때 같은 법 제51조제2항을 준용하여 구급차등의 운용지역을 제한할 수 있는지?[14]

---

10) 구급차등을 이용하여 응급환자 등을 이송하는 업(業)인 응급환자이송업을 말하며(응급의료법 제2조제8호 및 제44조제1항제4호 참조), 이하 같음.

11) 응급환자의 이송 등 응급의료의 목적에 이용되는 자동차, 선박 및 항공기 등의 이송수단을 말하며(응급의료법 제2조제6호 참조), 이하 같음.

12) 자치구의 구청장을 말하며(응급의료법 제12조제2항 참조), 이하 같음

13) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 말하며(응급의료법 제12조제2항 참조), 이하 같음.

14) ① 의료기관이 이송업을 하는 경우 및 ② 응급의료법 제44조제2항에 따라 같은 조 제1항제4호에 따른 이송업의 허가를 받은 자 또는 같은 조 제1항제5호에 따른 비영리법인에 구급차등의 운용을 위탁하지 않은 경우를 전제함.

02 회답

이 사안의 경우, 응급의료법 제44조의2제3항에 따라 시장·군수·구청장이 의료기관의 구급차등 운용신고를 수리할 때 같은 법 제51조제2항을 준용하여 구급차등의 운용지역을 제한할 수 없습니다.

03 이유

먼저 응급의료법 제44조의2제2항에서는 의료기관(제2호)과 이송업의 허가를 받은 자(제4호) 등이 구급차등을 운용하고자 할 때에는 해당 구급차등을 관계 법령에 따라 등록한 후 지체 없이 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 시장·군수·구청장은 구급차등 운용신고를 받은 경우 "그 내용을 검토하여 같은 법에 적합하면 신고를 수리해야 한다"고 규정하고 있을 뿐, 응급의료법령에서는 구급차등 운용신고 시 그 운용지역을 한정하여 신고하도록 하거나[15] 시장·군수·구청장이 구급차등 운용신고를 수리할 때 운용지역을 제한할 수 있는 규정을 두고 있지 않습니다.

그리고 "준용"이란 특정 조문을 그와 성질이 유사한 규율 대상에 대해 그 성질에 따라 다소 수정하여 적용하는 입법기술로서 특별한 사정이 없는 한 준용 규정을 명시적으로 둔 경우에만 준용이 가능하다 할 것[16]이고, 구급차등 운용신고 수리 시 구급차등의 운용지역을 제한하는 것은 구급차등을 운용하려는 자의 자유를 제한하는 것으로서 법률에 근거를 두어야 할 것인데, 응급의료법에서는 '이송업 허가' 시 영업지역을 제한하여 허가할 수 있도록 규정한 같은 법 제51조제2항을 구급차등 운용신고 수리에 대하여 준용하는 규정을 두고 있지 않으므로, 같은 법 제44조의2제3항에 따라 시장·군수·구청장이 의료기관의 구급차등 운용신고를 수리할 때 같은 법 제51조제2항을 준용하여 운용지역을 제한할 수 없다는 점은 분명합니다.

또한 응급의료법 제44조의2제2항에서는 '의료기관(제2호), 이송업 허가를 받은 자(제4호) 등 구급차등을 운용하고자 하는 자'에 대해 구급차등 운용신고 의무를 부여하고 있는데, 같은 법 제51조제2항에 따른 영업지역의 제한은 '구급차등을 운용하고자 하는 이송업자'가 그

15) 응급의료법 시행규칙 제36조의2제1항 및 별지 제15호의5서식 등

16) 법제처 2021. 5. 21. 회신 21-0049 해석례, 법제처 2023. 9. 12. 23-0714 해석례 참조

'이송업의 허가를 받을 때' 적용되는 규정으로서, 1994년 1월 7일 법률 제4730호로 「응급의료에관한법률」이 제정될 당시부터 현재까지 응급의료법에서는 '구급차등을 이용하여 응급환자 등을 이송하는 이송업'의 지역적 범위 등을 제한할 수 있는 근거[17]를 두어 왔을 뿐, '구급차등을 운용하고자 하는 자'에 대해 그 운용지역을 제한할 수 있는 규정을 둔 적은 없다는 점에 비추어 보더라도, 의료기관의 구급차등 운용신고의 수리 시에는 응급의료법 제51조제2항을 준용하여 구급차등의 운용지역을 제한할 수 없다고 보는 것이 같은 법의 규정체계 및 입법연혁에도 부합하는 해석입니다.

따라서 이 사안의 경우, 응급의료법 제44조의2제3항에 따라 시장·군수·구청장이 의료기관의 구급차등 운용신고를 수리할 때 같은 법 제51조제2항을 준용하여 구급차등의 운용지역을 제한할 수 없습니다.

관계법령

응급의료에 관한 법률

제44조(구급차등의 운용자) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 외에는 구급차등을 운용할 수 없다.

1. 국가 또는 지방자치단체
2. 「의료법」 제3조에 따른 의료기관
3. 다른 법령에 따라 구급차등을 둘 수 있는 자
4. 이 법에 따라 응급환자이송업(이하 "이송업"이라 한다)의 허가를 받은 자
5. 응급환자의 이송을 목적사업으로 하여 보건복지부장관의 설립허가를 받은 비영리법인

② 의료기관은 구급차등의 운용을 제1항제4호에 따른 이송업의 허가를 받은 자(이하 "이송업자"라 한다) 또는 제1항제5호에 따른 비영리법인에 위탁할 수 있다.

③ 제2항에 따라 구급차등의 운용을 위탁한 의료기관과 그 위탁을 받은 자는 보건복지부령으로 정하는 구급차등의 위탁에 대한 기준 및 절차를 지켜야 한다.

제44조의2(구급차등의 운용신고 등) ① 제44조제1항제1호의 국가 또는 지방자치단체가 구급차등을 운용하고자 할 때에는 해당 구급차등을 관계 법령에 따라 등록한 후 지체 없이 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다. 그 통보 후 보건복지부령으로 정하는 중요사항을 변경할 때에도 같다.

② 제44조제1항제2호부터 제5호까지에 해당하는 자가 구급차등을 운용하고자 할 때에는 해당

17) 1994. 1. 7. 법률 제4730호로 제정되어 1995. 1. 1. 시행된 「응급의료에관한법률」 제40조제4항에서는 이송업 허가를 할 때에 필요한 조건을 붙일 수 있다고 규정하였고, 2000. 7. 1. 법률 제6147호로 「응급의료에관한법률」을 전부개정하면서 현행과 같이 이송업의 허가를 할 때 영업지역을 제한하여 허가할 수 있도록 규정함.

구급차등을 관계 법령에 따라 등록한 후 지체 없이 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 그 신고 후 보건복지부령으로 정하는 중요 사항을 변경할 때에도 같다.

③ 시장·군수·구청장은 제2항에 따른 신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다.

제51조(이송업의 허가 등) ① 이송업을 하려는 자는 보건복지부와 국토교통부의 공동부령으로 정하는 시설 등을 갖추어 관할 시·도지사의 허가를 받아야 한다. 이 경우 둘 이상의 시·도에서 영업을 하려는 경우에는 해당 시·도별로 시·도지사의 허가를 받아야 한다.

② 시·도지사는 제1항에 따라 허가를 하는 경우에는 시설의 규모 등을 고려하여 영업지역을 제한하여 허가할 수 있다.

③ ~ ⑦ (생 략)

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0250

민원인 – 「재난적의료비 지원에 관한 법률 시행령」 제7조제1항제2호가목의 "「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호라목에 따른 희귀난치성질환자등으로서 본인일부부담금의 경감을 인정받은 사람"의 범위(「재난적의료비 지원에 관한 법률 시행령」 제7조제1항 등 관련)

01 질의요지

「재난적의료비 지원에 관한 법률」(이하 "재난적의료비지원법"이라 함) 제9조제1항에서는 "재난적의료비[18]에 대한 지원은 국내에 거주하는 국민으로서 소득 및 의료비 부담 수준 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 사람(이하 "지원대상자"라 함)에 대하여 실시한다"고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제7조제1항제2호가목에서는 재난적의료비를 부담하는 사람으로서 "「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호라목에 따른 희귀난치성질환자등[19]으로서 본인일부부담금[20]의 경감을 인정받은 사람"을 지원대상자 중 하나로 규정하고 있는바,

재난적의료비지원법 시행령 제7조제1항제2호가목에 따른 지원대상자에 「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호마목에 따라 본인일부부담금의 부담률 및 부담액을 적용받은 중증질환자도 포함되는지?

02 회답

재난적의료비지원법 시행령 제7조제1항제2호가목에 따른 지원대상자에 「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호마목에 따라 본인일부부담금의 부담률 및 부담액을 적용받은 중증질환자는 포함되지 않습니다.

18) 재난적의료비지원법 제2조제3호에 따른 재난적의료비를 말하며, 이하 같음

19) 보건복지부장관이 정하여 고시하는 희귀난치성질환 또는 중증질환(이하 "희귀난치성질환등"이라 함)을 가진 사람, 희귀난치성질환등 외의 질환으로 6개월 이상 치료를 받고 있거나 6개월 이상 치료가 필요한 사람 또는 18세 미만의 아동을 말하며(「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호라목 참조), 이하 같음.

20) 「국민건강보험법」 제44조제1항 전단에 따른 본인일부부담금을 말하며, 이하 같음.

03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미를 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[21], 재난적의료비지원법 시행령 제7조제1항제2호가목에서는 재난적의료비의 지원대상자를 "「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호라목에 따른 희귀난치성질환자등으로서 본인일부부담금의 경감을 인정받은 사람"으로 규정하고 있고, 「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호라목 전단에서는 희귀난치성질환자등로서 본인일부부담금의 경감을 인정받기 위한 일정한 소득 기준 등과 본인일부부담금의 경감 인정 신청을 규정하고 있으며, 같은 목 1)부터 10)까지에서는 경감을 인정받은 경우에 적용받는 본인일부부담금의 부담률 및 부담액을 규정하고 있고, 같은 호 마목에서는 "라목에 해당하는 사람에 대한 요양급여는 제외한다"고 규정함으로써 같은 호 라목의 적용을 받은 경우에는 같은 호 마목의 적용을 받지 않도록 규정하고 있는바, 재난적의료비지원법 시행령 제7조제1항제2호가목의 "「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호라목에 따른 희귀난치성질환자등으로서 본인일부부담금의 경감을 인정받은 사람"이란 '「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호라목에 따라 본인일부부담금의 경감 인정 신청을 하여 그 경감을 인정받은 희귀난치성질환자등'을 말하고, 같은 호 마목에 따라 본인일부부담금의 부담률 및 부담액을 적용받은 중증질환자는 포함되지 않는다는 점이 문언상 명백합니다.

그리고 본인일부부담금의 부담률 및 부담액에 관한 국민건강보험법령의 규정체계를 살펴보면, 「국민건강보험법 시행령」 별표 2 중 제3호라목에서만 '본인일부부담금의 경감'에 관하여 규정하고 있고, 이에 따라 같은 법 시행규칙 제14조(본인부담액 경감 인정)·제15조(본인부담액 경감 대상자의 기준) 및 제17조(본인부담액 경감 적용 시기)에서도 같은 법 시행령 '별표 2 제3호라목'에 따른 본인부담액 경감 인정의 절차, 대상자 기준 및 경감 적용 시기 등을 규정하고 있는바, 이러한 국민건강보험법령의 규정체계에 비추어 볼 때, 같은 법 시행령 별표 2 제3호라목 및 같은 법 시행규칙 제14조·제15조·제17조에 따라 본인일부부담금의 경감을 인정받지 않고, 같은 법 시행령 별표 2 제3호마목에 따라 본인일부부담금의 부담률 및 부담액을 적용받은 중증질환자는 '본인일부부담금의 경감을 인정받은 사람'에 포함된다고 보기는 어려우므로, 해당 중증질환자는 재난적의료비지원법 시행령 제7조제1항제2호가목에 따른 지원대상자에 포함되지 않는다고 해석하는 것이 국민건강보험법령의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

---

21) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

아울러 재난적의료비지원법은 '소득수준'에 비하여 과도한 의료비 지출로 경제적 어려움을 겪는 국민들에게 의료비의 일부를 지원하여 의료이용의 접근성을 높임으로써 사회보장을 증진하고 국민건강 보호에 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제9조제1항에서 재난적의료비에 대한 지원은 국내에 거주하는 국민으로서 '소득 및 의료비 부담수준' 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 사람에 대하여 실시한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제7조제1항 각 호에서도 재난적의료비의 지원대상자를 '소득수준' 등을 고려하여 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자, 같은 조 제10호에 따른 차상위계층에 해당하는 사람 등으로 규정하고 있는바, 이러한 재난적의료비지원법의 목적과 재난적의료비 지원대상자의 규정체계를 종합해 볼 때, 재난적의료비지원법 시행령 제7조제1항제2호가목에 따른 지원대상자 또한 '소득수준'을 고려하여야 할 것인데, 「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호라목과 마목을 살펴보면, 같은 호 라목 전단에서는 희귀난치성질환자등의 소득수준을 본인일부부담금의 경감 인정 신청을 위한 기준으로 규정하고 있는 것과 달리, 같은 호 마목에서는 중증질환자의 '소득수준'과 관계없이 본인일부부담금의 부담률 및 부담액을 규정하고 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 재난적의료비지원법 시행령 제7조제1항제2호가목에 따른 지원대상자에 「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호마목에 따라 본인일부부담금의 부담률 및 부담액을 적용받은 중증질환자는 포함되지 않습니다.



관계법령

재난적의료비 지원에 관한 법률 시행령

제7조(지원대상자) ① 법 제9조제1항에서 "대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 사람"이란 재난적의료비를 부담하는 사람으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
   가. 「국민건강보험법 시행령」 별표 2 제3호라목에 따른 희귀난치성질환자등으로서 본인일부부담금의 경감을 인정받은 사람
   나. ~ 라. (생 략)
3. 그 밖에 소득, 재산 등을 고려하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 기준에 해당하는 사람

② (생 략)

국민건강보험법 시행령

[별표 2]

본인일부부담금의 부담률 및 부담액

(제19조제1항 관련)

1.·2. (생 략)

3. 제1호와 제2호에도 불구하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 각 목에서 정하는 금액을 부담한다. (단서 생략)

가. ~ 다. (생 략)

라. 보건복지부장관이 정하여 고시하는 희귀난치성질환 또는 중증질환(이하 "희귀난치성질환등"이라 한다)을 가진 사람, 희귀난치성질환등 외의 질환으로 6개월 이상 치료를 받고 있거나 6개월 이상 치료가 필요한 사람 또는 18세 미만의 아동(이하 "희귀난치성질환자등"이라 한다) 중 희귀난치성질환자등이 속한 세대(배우자를 포함한다)의 소득 및 재산을 더하여 계산한 가액(이하 "소득인정액"이라 한다)이 「국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 기준 중위소득의 100분의 50 이하이고, 희귀난치성질환자등의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자(이하 "부양의무자"라 한다)가 없거나 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 사람으로서 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 공단의 본인일부부담금 경감 인정 신청(이하 "경감인정신청"이라 한다)을 하여 그 경감 인정을 받은 사람 또는 희귀난치성질환자등 중 본인일부부담금의 경감이 필요하다고 보건복지부장관이 정하는 사람으로서 경감인정신청을 한 사람에 대한 요양급여의 경우에는 다음의 구분에 따라 계산한 금액. 이 경우 소득인정액 산정의 기준이 되는 세대의 범위, 소득 및 재산의 범위, 소득인정액 산정방법 등 소득인정액의 산정에 필요한 사항 및 부양의무자가 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 경우의 구체적인 기준은 보건복지부령으로 정한다.

1) ~ 10) (생 략)

마. 보건복지부장관이 정하여 고시하는 중증질환자에 대하여 보건복지부장관이 정하는 요양급여(라목에 해당하는 사람에 대한 요양급여는 제외한다)의 경우에는 요양급여비용 총액의 100분의 5에 입원기간 중 식대의 100분의 50을 더한 금액

바. ~ 너. (생 략)

4.·5. (생 략)

질의제목 6 ▶ 안건번호 24-0277

민원인 – 「의료법 시행규칙」 제36조제4항에 따른 “각급 의료기관은 제1항에 따른 환자를 요양병원으로 옮긴 경우”의 의미(「의료법 시행규칙」 제36조제4항 등 관련)

01 질의요지

「의료법」 제36조 각 호 외의 부분 및 같은 조 제3호에서는 같은 법 제33조제2항 및 제8항에 따라 의료기관을 개설하는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 의료기관 및 요양병원의 운영 기준에 관한 사항을 지켜야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제36조제1항에서는 요양병원[22]의 입원 대상은 노인성 질환자(제1호) 등에 해당하는 자로서 주로 요양이 필요한 자로 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서는 각급 의료기관은 같은 조 제1항에 따른 환자(이하 “요양병원입원대상환자”라 함)를 요양병원으로 옮긴 경우에는 환자 이송과 동시에 진료기록 사본 등을 그 요양병원에 송부해야 한다고 규정하고 있는바,

요양병원입원대상환자가 의료기관에서 퇴원한 후 스스로 요양병원을 선택하여 입원한 경우[23]가 「의료법 시행규칙」 제36조제4항에 따른 ‘각급 의료기관이 요양병원입원대상환자를 요양병원으로 옮긴 경우’에 해당하여 진료기록 사본 등을 그 요양병원에 송부해야 하는지?

02 회답

이 사안의 경우, 「의료법 시행규칙」 제36조제4항에 따른 ‘각급 의료기관이 요양병원입원대상환자를 요양병원으로 옮긴 경우’에 해당하지 않아 진료기록 사본 등을 그 요양병원에 송부하지 않아도 됩니다.

22) 「의료법」 제3조제2항제3호라목에 따른 요양병원을 말하며, 이하 같음.

23) 환자 측에서 이송수단을 섭외하여 요양병원으로 이동한 경우를 전제함.

03 이유

먼저 「의료법 시행규칙」 제36조제4항에서는 각급 의료기관은 요양병원입원대상환자를 요양병원으로 옮긴 경우에는 환자 이송과 동시에 진료기록 사본 등을 그 요양병원에 송부해야 한다고 규정하여 요양병원입원대상환자를 요양병원으로 옮기는 행위의 주체를 '각급 의료기관'으로 명시하고 있고, '옮기다'의 사전적 의미는 그 대상을 어떤 곳에서 다른 곳으로 자리를 바꾸게 한다[24]는 의미인 점에 비추어 볼 때, 같은 항의 "각급 의료기관은 제1항에 따른 환자를 요양병원으로 옮긴 경우"란 각급 의료기관이 주체가 되어 요양병원입원대상환자를 요양병원으로 이송한 경우를 의미함이 문언상 명확한바, 이 사안과 같이 요양병원입원대상환자가 의료기관에서 퇴원한 후 스스로 요양병원을 선택하여 입원한 경우는 의료기관이 주체가 되어 요양병원입원대상환자를 이송했다고 보기 어려우므로 "각급 의료기관은 제1항에 따른 환자를 요양병원으로 옮긴 경우"에 해당한다고 보기 어렵습니다.

그리고 「의료법」 제21조제2항에서는 의료인 등은 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내주는 등 내용을 확인할 수 있게 하여서는 아니 된다고 규정하면서, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제2항에도 불구하고 환자가 아닌 사람이 환자에 관한 기록을 열람하게 하는 등 그 내용을 확인할 수 있는 경우를 제한적으로 열거하고 있고, 같은 법 제21조의2제1항에서는 의료인 또는 의료기관의 장은 다른 의료인 또는 의료기관의 장으로부터 진료기록의 내용 확인이나 진료기록의 사본 등을 송부 또는 전송할 것을 요청받은 경우 해당 환자나 환자 보호자의 동의를 받아 그 요청에 응하여야 한다고 규정하면서(본문), 해당 환자의 의식이 없거나 응급환자인 경우 또는 환자의 보호자가 없어 동의를 받을 수 없는 경우에만 환자나 환자 보호자의 동의 없이 송부 또는 전송할 수 있도록 규정하고 있으며(단서), 같은 법 제88조제1호 및 제90조에서는 이를 위반한 자는 징역 또는 벌금에 처하도록 규정하여 환자의 동의 없이 진료기록 사본 등을 타인에게 제공하거나 송부하는 것을 엄격히 제한하고 있는 점에 비추어 볼 때, 같은 법 시행규칙 제36조제4항에 따라 진료기록 사본 등을 요양병원에 송부해야 하는 경우인 '각급 의료기관이 요양병원입원대상환자를 요양병원으로 옮긴 경우'는 그 문언대로 '각급 의료기관이 요양병원입원대상환자를 요양병원으로 직접 이송한 경우'로 한정하여 해석해야 합니다.

또한 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안

24) 국립국어원 표준국어대사전 참조

된다고 할 것인바,[25] 의료기관이「의료법 시행규칙」제36조제4항에 따른 진료기록 사본 등 송부의무를 위반한 경우에는「의료법」제36조를 위반한 경우에 해당하여 같은 법 제63조제1항에 따른 시정명령이나 같은 법 제64조제1항제9호에 따른 개설허가 취소 등의 행정처분이 부과될 수 있다는 점을 고려하면, 같은 법 시행규칙 제36조제4항을 확장해석하여 요양병원입원대상환자가 의료기관에서 퇴원하고 스스로 요양병원을 선택하여 입원한 경우까지 진료기록 사본 등을 그 요양병원에 송부할 의무가 있다고 보는 것은 타당하지 않습니다.

아울러「의료법 시행규칙」제36조제4항 중 "각급 의료기관은 제1항에 따른 환자를 요양병원으로 옮긴 경우"를 요양병원입원대상환자가 의료기관에서 퇴원하고 스스로 요양병원을 선택하여 입원한 경우까지 확대하여 적용할 경우, 의료기관의 입장에서 환자가 해당 의료기관 퇴원 후 요양병원에 입원하는지 여부나 입원하는 요양병원이 어디인지를 알 수 없음에도 같은 항에 따른 진료기록 사본 등 송부의무를 지게 되는 불합리한 결과가 초래될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우,「의료법 시행규칙」제36조제4항에 따른 '각급 의료기관이 요양병원입원대상환자를 요양병원으로 옮긴 경우'에 해당하지 않아 진료기록 사본 등을 그 요양병원에 송부하지 않아도 됩니다.

관계법령

의료법

제36조(준수사항) 제33조제2항 및 제8항에 따라 의료기관을 개설하는 자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.
1. 의료기관의 종류에 따른 시설기준 및 규격에 관한 사항
2. 의료기관의 안전관리시설 기준에 관한 사항
3. 의료기관 및 요양병원의 운영 기준에 관한 사항
4. ~ 13. (생 략)

의료법 시행규칙

제36조(요양병원의 운영) ① 법 제36조제3호에 따른 요양병원의 입원 대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 주로 요양이 필요한 자로 한다.

25) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

1. 노인성 질환자
2. 만성질환자
3. 외과적 수술 후 또는 상해 후 회복기간에 있는 자

②·③ (생 략)

④ 각급 의료기관은 제1항에 따른 환자를 요양병원으로 옮긴 경우에는 환자 이송과 동시에 진료기록 사본 등을 그 요양병원에 송부하여야 한다.

⑤ ~ ⑦ (생 략)

질의제목 7 ▶ 안건번호 24-0325, 24-0563

민원인 - 「노인복지법 시행규칙」 별표 9 제1호나목에 따른 "시설 연면적"의 범위(「노인복지법 시행규칙」 별표 9 제1호나목 등 관련)

01 질의요지

「노인복지법」 제38조제1항에서 재가노인복지시설은 방문요양서비스, 주·야간보호서비스, 단기보호서비스, 방문목욕서비스 등의 서비스 중 어느 하나 이상의 서비스를 제공함을 목적으로 하는 시설을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제39조제4항에서는 재가노인복지시설의 시설기준 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제29조제1항에서는 같은 법 제39조에 따른 재가노인복지시설의 시설기준은 별표 9와 같다고 규정하면서, 같은 별표 제1호나목에서는 주·야간보호, 단기보호를 제공하는 시설의 규모를 "시설 연면적" 90제곱미터 이상으로 규정하고 있는바,

건축물의 하나의 층에 주·야간보호를 제공하는 시설 또는 단기보호를 제공하는 시설을 설치하려는 경우[26], '그 층에 위치한 해당 시설 외부에 있는 건축물의 복도 등[27]'(이하 "이 사안 복도등"이라 함)의 바닥면적은 「노인복지법 시행규칙」 별표 9 제1호나목에 따른 "시설 연면적"에 포함되는지?

02 회답

이 사안 복도등의 바닥면적은 「노인복지법 시행규칙」 별표 9 제1호나목에 따른 "시설 연면적"에 포함되지 않습니다.

---

26) 해당 층에는 주·야간보호를 제공하는 시설 또는 단기보호를 제공하는 시설만이 설치되는 경우를 전제함.

27) 재가노인복지시설이 있는 층에 위치한 해당 시설 외부에 있는 복도나 계단 등 해당 시설을 이용하지 않는 사람도 자유롭게 통행할 수 있는 부분을 말하며, 이하 같음.

03 이유

「노인복지법」 제38조제1항에서는 재가노인복지시설은 방문요양서비스, 주·야간보호서비스, 단기보호서비스, 방문목욕서비스, 그 밖의 서비스 중 어느 하나 이상의 서비스를 제공함을 목적으로 하는 시설을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제39조제4항에서는 재가노인복지시설의 시설기준 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 「노인복지법 시행규칙」 별표 9 제1호에서는 재가노인복지시설의 시설의 규모를 규정하면서, 방문요양, 방문목욕 및 방문간호를 제공하는 시설(가목), 재가노인지원서비스를 제공(다목)하는 경우에는 "시설전용면적"이 일정 규모 이상을 갖추도록 규정하고 있고, 주·야간보호, 단기보호를 제공하는 시설(나목)은 "시설 연면적"이 90제곱미터 이상으로 규정하고 있는바, 이러한 "시설 연면적"에 이 사안 복도등의 바닥면적이 포함되는지 판단하기 위해서는 해당 규정의 문언 외에도 재가노인복지시설의 성격, 그 시설기준 규정의 체계 등을 종합적으로 고려하여 조화롭게 해석할 필요가 있습니다.

먼저 ①「노인복지법 시행규칙」 별표 9 제1호나목 본문에서는 주·야간보호를 제공하는 시설 또는 단기보호를 제공하는 시설의 규모와 관련한 시설기준으로 "시설 연면적" 90제곱미터 이상으로 규정하면서, 이용정원이 6명 이상인 경우에는 1명당 6.6제곱미터 이상의 생활실 또는 침실 공간을 추가로 확보하도록 하고 있고, 같은 목 단서에서는 "주·야간보호시설 안"에 치매전담실을 두는 경우에는 치매전담실 1실당 이용정원을 25명 이하로 하여야 한다고 규정하고 있는 점, ② 같은 별표 제2호나목에서는 주·야간보호서비스를 제공하는 시설이 갖추어야 하는 시설로 생활실, 사무실, 의료 및 간호사실, 프로그램실, 물리치료실, 식당 및 조리실, 화장실, 세면장 및 목욕실, 세탁장 및 건조장 등의 전용부분만 정하고 있고, 복도, 비상구, 계단 등에 대해서는 따로 정하지 않고 있으며, 단기보호서비스를 제공하는 시설이 갖추어야 하는 시설로도 침실, 사무실, 의료 및 간호사실, 프로그램실, 물리치료실, 식당 및 조리실, 화장실, 세면장 및 목욕실, 세탁장 및 건조장 등의 전용부분만 정하고 복도, 비상구, 계단 등에 대해서는 따로 정하지 않고 있는 점에 비추어보면, 같은 별표 제1호나목에서는 시설 내부의 전용공간을 대상으로 하여 면적 또는 이용정원에 대한 시설기준을 정하고 있는 것으로 보이는바, 같은 목 본문에서 주·야간보호를 제공하는 시설 또는 단기보호를 제공하는 시설의 시설기준으로 규정하고 있는 "시설 연면적"은 해당 시설 내의 전용공간의 면적을 의미하는 것이고 시설 외의 복도 등의 면적은 이에 포함되지 않는 것으로 보는 것이 문언에 충실한 해석입니다.

또한「노인복지법 시행규칙」별표 9 제1호나목에서 규정하고 있는 주·야간보호서비스를 제공하는 시설은 심신이 허약한 노인과 장애노인을 주간 또는 야간 동안 보호시설에 입소시켜 편의를 제공하는 서비스를 제공하는 시설이고, 단기보호서비스를 제공하는 시설은 일시적으로 보호가 필요한 심신이 허약한 노인과 장애노인을 보호시설에 단기간 입소시켜 보호하는 서비스를 제공하는 시설[28]로서 해당 시설은 모두 재가노인이 '입소'하는 시설이므로 그 시설 내부에는 생활실, 화장실, 프로그램실 등 입소한 재가노인의 생활 및 활동이 원활하게 이루어질 수 있는 충분한 공간을 확보해야 할 필요성이 있는바,「노인복지법 시행규칙」별표 9 제1호나목에 따른 "시설 연면적"은 '시설전용면적(연면적 기준)'으로 해석하는 것이 같은 목에 해당하는 시설의 성격과 목적에 부합한다고 할 것입니다.

그리고「노인복지법」은 노인의 적절한 치료·요양으로 심신의 건강을 유지하고, 노후의 생활안정을 위하여 필요한 조치를 강구함으로써 노인의 보건복지증진에 기여함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서,「노인복지법 시행규칙」별표 9 제2호나목에서는 주·야간보호, 단기보호를 제공하는 시설의 규모는 이용자가 쾌적한 일상생활을 하는데 적합하도록 하고, 5개 이상의 필수시설을 갖추도록 규정하는 등 적정 기준 이상의 시설을 갖춘 재가노인복지시설들을 통하여 서비스를 제공하여 노인들의 보건복지를 증진하려는 목적인바, 만약 같은 별표 제1호나목에 따른 "시설 연면적"에 이 사안 복도등의 바닥면적이 포함되는 것으로 본다면, 시설 내부의 면적 비중이 낮고 이 사안 복도등의 바닥면적 비중이 높게 구성되는 경우에도 시설 내부 면적과 이 사안 복도등의 바닥면적의 합이 90제곱미터 이상이기만 하면 해당 시설의 규모와 관련한 시설기준인 "시설 연면적 90제곱미터 이상"을 충족하게 되는 결과를 초래할 수 있으므로, 이러한 해석은 같은 별표 제1호나목에서 주·야간보호, 단기보호를 제공하는 시설의 기준을 정하고 있는 취지, 나아가 노인의 보건복지증진에 기여하려는 법률의 목적에 부합하는 것으로 보기 어렵습니다.

아울러「노인복지법 시행규칙」별표 9 제1호에서는 방문요양, 방문목욕 및 방문간호를 제공하는 시설(가목) 및 재가노인지원서비스를 제공하는 시설(다목)의 규모에 대한 기준으로 "시설전용면적"이 일정 규모 이상일 것으로 규정하고 있는데, 같은 별표 제1호가목 및 다목에 해당하는 재가노인복지시설은 재가노인이 입소하여 생활하는 시설이 아니므로 사무실, 상담실 등 특정 목적으로 사용되는 소규모 공간을 갖추도록 하면서, 해당 목적으로 사용되는 공간을 일정 규모 이상 확보해야 하는 점을 명확히 하기 위하여 시설기준 면적을 '전용면적'으로 규정한 것으로도 볼 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

28)「노인복지법」제38조제1항 참조

따라서 이 사안 복도등의 바닥면적은「노인복지법 시행규칙」별표 9 제1호나목에 따른 "시설 연면적"에 포함되지 않습니다.

법령정비 권고의견

주·야간보호, 단기보호를 제공하는 시설의 규모를 정한「노인복지법 시행규칙」별표 9 제1호나목에 따른 "시설 연면적"의 의미를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

노인복지법

제39조(재가노인복지시설의 설치) ① ~ ③ (생 략)

④ 재가노인복지시설의 시설, 인력 및 운영에 관한 기준과 설치신고 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

노인복지법 시행규칙

제29조(재가노인복지시설의 시설기준등) ①법 제39조의 규정에 의한 재가노인복지시설의 시설기준 및 직원배치기준은 별표 9와 같다.

② (생 략)

[별표 9]

재가노인복지시설의 시설기준 및 직원배치기준(제29조제1항 관련)

1. 시설의 규모
   가. 방문요양, 방문목욕 및 방문간호를 제공하는 시설: 시설전용면적 16.5제곱미터 이상(연면적 기준)
   나. 주·야간보호, 단기보호를 제공하는 시설: 시설 연면적 90제곱미터 이상(이용정원이 6명 이상인 경우에는 1명당 6.6제곱미터 이상의 생활실 또는 침실 공간을 추가로 확보하여야 함). 다만, 주·야간보호시설 안에 치매전담실을 두는 경우에는 치매전담실 1실당 이용정원을 25명 이하로 하여야 한다.
   다. 재가노인지원서비스: 시설전용면적 33제곱미터 이상(연면적 기준)
   라. 복지용구를 제공하거나 대여하는 시설: 복지용구 진열·체험 공간 23.1제곱미터 이상 및 복지용구 세정·소독·수선 공간 56.2제곱미터 이상
2. ~ 6. (생 략)

질의제목 8 ▶ 안건번호 24-0558, 24-0685

민원인 – 시설주등이 공공건물 등을 증축 또는 용도변경하는 경우 시설주관기관이 편의시설 설치계획으로 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제8조제1항 및 같은 법 시행령 별표 2에 따른 편의시설의 종류 및 설치기준을 완화하여 별도로 정할 수 있는지(「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제12조 등 관련)

01 질의요지

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(이하 "장애인등편의법"이라 함) 제8조제1항에서는 대상시설[29]별로 설치하여야 하는 편의시설[30]의 종류는 대상시설의 규모, 용도 등을 고려하여 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제4조에서는 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류 및 그 설치기준은 별표 2와 같다고 규정하고 있으며, 같은 법 제9조에서는 시설주등[31]은 대상시설을 설치하거나 대통령령으로 정하는 주요 부분을 변경(용도변경을 포함함)할 때에는 장애인등이 대상시설을 항상 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설을 제8조에 따른 설치기준에 적합하게 설치하고 유지·관리하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제5조제3호 본문에서는 대통령령으로 정하는 주요 부분을 변경할 때란 별표 1의 공공건물 및 공중이용시설과 공동주택을 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경할 때를 말한다고 규정하고 있는 한편,

장애인등편의법 제12조제1항에서는 시설주관기관[32]은 편의시설 설치를 촉진하기 위하여 소관 대상시설에 대한 편의시설 설치계획(이하 "편의시설 설치계획"이라 함)을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있는바,

29) 편의시설을 설치하여야 하는 대상을 말하며(장애인등편의법 제7조 참조), 이하 같음

30) 장애인등이 일상생활에서 이동하거나 시설을 이용할 때 편리하게 하고, 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위한 시설과 설비를 말하며(장애인등편의법 제2조제2호), 이하 같음

31) 시설주와 대상시설의 설치를 위하여 「건축법」 등 관계 법령에 따른 허가나 처분(「건축법」 제29조에 따른 협의를 포함함)을 신청하는 등 절차를 진행 중인 자를 말하며(장애인등편의법 제2조제3호 및 제3조 참조), 이하 같음

32) 편의시설의 설치와 운영에 관하여 지도하고 감독하는 중앙행정기관의 장과 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사, 시장·군수·자치구의 구청장 및 교육감을 말하며(장애인등편의법 제2조제4호 참조), 이하 같음.

시설주등이 공공건물 및 공중이용시설[33]과 공동주택(이하 "공공건물등"이라 함)을 설치하는 경우가 아니라 증축 또는 용도변경하는 경우, 시설주관기관이 편의시설 설치계획으로 장애인등편의법 시행령 별표 2에 따른 편의시설의 종류 및 설치기준(이하 "편의시설의 종류 및 설치기준"이라 함)을 완화하여 별도로 정할 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 시설주관기관이 편의시설 설치계획으로 편의시설의 종류 및 설치기준을 완화하여 별도로 정할 수 없습니다.

03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[34], 먼저 공공건물등을 설치하는 경우가 아니라 '증축 또는 용도변경'하는 경우 편의시설 설치기준을 완화할 수 있는지 살펴보면, 장애인등편의법 제9조에서는 시설주등은 대상시설을 '설치'하거나 대통령령으로 정하는 주요 부분을 '변경'할 때에는 그 편의시설을 제8조에 따른 설치기준에 적합하게 설치하고 유지·관리하여야 한다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 영 제5조제3호 본문에서 "대통령령으로 정하는 주요 부분을 변경할 때"란 공공건물등을 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경할 때를 말한다고 규정하고 있는바, 시설주등은 공공건물등을 증축 또는 용도변경할 때에도 이를 설치할 때와 마찬가지로 편의시설의 종류 및 설치기준에 따라 편의시설을 설치해야 할 의무가 있고, 장애인등편의법령에서는 편의시설의 종류 및 설치기준과 관련하여 공공건물등의 증축 또는 용도변경 시에 이를 완화하여 별도로 정할 수 있도록 하는 규정도 두고 있지 않으므로, 문언상 공공건물등을 증축 또는 용도변경하는 경우에도 편의시설의 종류 및 설치기준을 완화하여 별도로 정할 수는 없습니다.

다음으로 시설주관기관이 '편의시설 설치계획'으로 편의시설의 종류 및 설치기준을 완화

33) 장애인등편의법 시행령 별표 1 비고로 정하는 공중이용시설은 아닌 경우를 전제함(장애인등편의법 시행령 제5조제3호 단서 참조)

34) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

하여 별도로 정할 수 있는지 살펴보면, 장애인등편의법 제7조에 따르면 편의시설 설치계획은 편의시설 설치를 촉진하기 위하여 소관 대상시설에 대해 수립하는 계획으로서(제1항), 편의시설 설치계획에는 대상시설의 설치실태 및 정비계획, 건축·대수선·용도변경 등에 따른 편의시설 설치계획, 대상시설 및 편의시설 설치 기준에 관한 홍보 등의 내용을 포함하도록 규정하고 있는데(제2항), 편의시설 설치계획으로 편의시설의 종류 및 설치기준을 완화하여 별도로 정할 수 있도록 하는 내용은 규정하고 있지 않으므로, 편의시설 설치계획으로 편의시설의 종류 및 설치기준을 완화하여 별도로 정할 수는 없다고 할 것입니다.

또한 장애인등편의법 제15조제1항에서 시설주등은 '세부기준에 적합한 편의시설을 설치하기가 구조적으로 곤란한 경우(제1호)', '세부기준에 적합하게 편의시설을 설치하면 안전관리에 중대한 위험을 초래할 우려가 있는 경우(제2호)' 등으로서 '같은 법 제8조제2항에 따른 세부기준'에 적합한 편의시설을 설치하기가 곤란하거나 불합리할 때에는 그 세부기준을 완화한 별도의 기준을 정하고 시설주관기관의 승인을 받아 이에 따라 편의시설을 설치할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 공공건물등의 증축 또는 용도변경하는 경우 편의시설 설치기준의 완화에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이러한 규정들을 종합적으로 고려하면 시설주등이 공공건물등을 설치하는 경우가 아니라 증축 또는 용도변경하는 경우에 시설주관기관이 편의시설 설치계획으로 편의시설의 종류 및 설치기준을 완화하여 별도로 정할 수 없다고 보는 것이 같은 법의 문언 및 규정체계에 부합하는 해석입니다.

더욱이 장애인등편의법은 장애인·노인·임산부 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용하고 정보에 접근할 수 있도록 보장함으로써 이들의 사회활동 참여와 복지 증진에 이바지(제1조)하기 위하여 제정된 법률로서, 같은 법에서는 장애인등은 인간으로서의 존엄과 가치 및 행복을 추구할 권리를 보장받기 위해 장애인등이 아닌 사람들이 이용하는 시설과 설비를 동등하게 이용하고 정보에 자유롭게 접근할 수 있는 권리를 가진다(제4조)고 규정하면서, 이러한 권리를 보장하기 위해 장애인등이 이용할 가능성이 열려 있는 공공건물등과 같은 대상시설을 설치하거나 증축 등을 할 때 장애인등이 대상시설을 항상 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설을 같은 법 제8조에 따른 설치기준에 적합하게 설치하고 유지·관리할 의무를 시설주등에게 부여(제7조부터 제9조까지)하고 있는 것인바[35], 이러한 취지에 비추어보면 시설주등이 대상시설에 편의시설을 설치할 때 의무적으로 준수해야 할 편의시설의 종류 및 설치기준을 명확한 법적 근거 없이 완화하거나 예외를 인정할 수는 없다고 보아야 합니다.

35) 1997. 4. 10. 법률 제5332호로 제정되어 1998. 4. 11. 시행된 장애인·노인·임산부등의편의증진보장에관한법률 제정이유 참조

따라서 이 사안의 경우, 시설주관기관이 편의시설 설치계획으로 편의시설의 종류 및 설치기준을 완화하여 별도로 정할 수 없습니다.

관계법령

장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률

제8조(편의시설의 설치기준) ① 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류는 대상시설의 규모, 용도 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

② 편의시설의 구조와 재질 등에 관한 세부기준은 보건복지부령으로 정한다. 이 경우 편의시설의 종류별 안내 내용과 안내 표시 디자인 기준을 함께 정하여야 한다.

제9조(시설주등의 의무) 시설주등은 대상시설을 설치하거나 대통령령으로 정하는 주요 부분을 변경(용도변경을 포함한다)할 때에는 장애인등이 대상시설을 항상 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설을 제8조에 따른 설치기준에 적합하게 설치하고, 유지·관리하여야 한다.

제12조(설치계획의 수립·시행 및 보고) ① 시설주관기관은 편의시설 설치를 촉진하기 위하여 소관 대상시설에 대한 편의시설 설치계획을 수립·시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 편의시설 설치계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 대상시설의 편의시설 설치실태 및 정비계획
2. 대상시설의 건축·대수선(大修繕)·용도변경 등에 따른 편의시설 설치계획
3. 대상시설 및 편의시설 설치 기준에 관한 홍보
4. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 사항

③ 시설주관기관은 제1항에 따른 편의시설 설치계획과 시행 실적을 대통령령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관에게 제출하여야 한다.

④ 보건복지부장관은 제3항에 따라 제출된 계획 등을 종합하여 제12조의2에 따른 편의증진심의회의 심의를 거쳐 편의시설 설치에 관한 국가종합계획을 수립하여야 한다.

장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령

제4조(편의시설의 종류) 법 제8조제1항의 규정에 의하여 대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류 및 그 설치기준은 별표 2와 같다.

제5조(대상시설의 변경) 법 제9조에서 "대통령령으로 정하는 주요 부분을 변경(용도변경을 포함한다)할 때"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때를 말한다.

2. (생 략)
3. 별표 1의 공공건물 및 공중이용시설과 공동주택을 증축·개축·재축·이전·대수선 또는 용도변경할 때. 다만, 별표 1 비고로 정하는 공중이용시설의 경우에는 건축물이 있는 대지에 별개의 건축물로 증축할 때, 건축물 전부를 개축할 때와 건축물을 재축할 때로 한정한다.

질의제목 9 ▶ 안건번호 24-0606, 24-0733

민원인 – 「사회복지사업법」 제33조제1항에 따른 시·군·구협의회를 별개의 사회복지법인으로 설립하지 않고 중앙협의회의 지회로 둘 수 있는지 등(「사회복지사업법」 제33조제2항 등 관련)

01 질의요지

「사회복지사업법」 제33조제1항에서는 "사회복지에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 전국 단위의 한국사회복지협의회(이하 "중앙협의회"라 함)와 시·도 단위의 시·도 사회복지협의회(이하 "시·도협의회"라 함)를 두며, 필요한 경우에는 시[36]·군·구[37] 단위의 시·군·구 사회복지협의회(이하 "시·군·구협의회"라 함)를 둘 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 중앙협의회, 시·도협의회 및 시·군·구협의회는 이 법에 따른 사회복지법인으로 하도록 규정하고 있는바,

가. 「사회복지사업법」 제33조제1항에 따른 시·군·구협의회를 별개의 사회복지법인으로 설립하지 않고 중앙협의회의 지회로 둘 수 있는지?

나. 「사회복지사업법」 제33조제1항에 따른 시·군·구협의회를 별개의 사회복지법인으로 설립하지 않고 시·도협의회의 지회로 둘 수 있는지?

02 회답

가. 질의 가에 대해

「사회복지사업법」 제33조제1항에 따른 시·군·구협의회를 별개의 사회복지법인으로 설립하지 않고 중앙협의회의 지회로 둘 수 없습니다.

---

36) 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따른 행정시를 포함하며(「사회복지사업법」 제33조제1항 참조), 이하 같음

37) 자치구를 말하며(「사회복지사업법」 제33조제1항 참조), 이하 같음

나. 질의 나에 대해

「사회복지사업법」 제33조제1항에 따른 시·군·구협의회를 별개의 사회복지법인으로 설립하지 않고 시·도협의회의 지회로 둘 수 없습니다.

03 이유

가. 질의 가와 나의 공통사항

「사회복지사업법」 제16조제1항에서는 "사회복지법인을 설립하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·도지사의 허가를 받아야 한다"고 규정하면서, 같은 조 제2항에서 "제1항에 따라 허가를 받은 자는 법인의 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 하여야 한다"고 규정하고 있고, 같은 법 제33조제1항 각 호 외의 부분에서는 "사회복지에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 중앙협의회와 시·도협의회를 두며 필요한 경우에는 시·군·구협의회를 둘 수 있다"고 규정하면서, 같은 조 제2항에서 중앙협의회, 시·도협의회 및 시·군·구협의회는 이 법에 따른 설립등기를 함으로써 성립하는 사회복지법인으로 하도록 규정하고 있는 반면, 「사회복지사업법」에서는 중앙협의회나 시·도협의회의 '지회'에 대해서는 규정하지 않고 있는데, 지회(支會)는 일반적으로 어떤 법인의 하부조직[38][39]이므로 사회복지법인의 특정 지역 사업을 관장하기 위한 내부조직으로서 별도의 법인격은 없는 것으로 보입니다.

나. 질의 가에 대해

그렇다면 「사회복지사업법」 제33조제2항에서 "시·군·구협의회는 이 법에 따른 사회복지법인"으로 하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제14조 및 제15조에서는 시·군·구협의회는 임원으로 대표이사·이사·감사를 두면서 이사로 구성된 이사회를 두도록 규정하고 있는 반면, 시·군·구협의회를 중앙협의회의 지회나 내부조직으로 둘 수 있도록 하는 예외를 규정하고 있지 않은바, 시·군·구협의회도 중앙협의회 및 시·도협의회와 같이 이 법에 따른 사회복지법인으로 해야 할 것이므로, 같은 법 제33조제1항에 따른 시·군·구협의회를 '중앙협의회의 지회'로 둘 수는 없는 것이 문언상 분명합니다.

---

38) 대법원 2018. 9. 13. 선고 2018다231031 판결례 참조

39) 참고로 사회복지 관련 법령인 「사회복지공동모금회법」에서는 사회복지법인인 모금회에 지역단위의 사회복지공동모금사업을 관장하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 단위 사회복지공동모금지회를 둔다고 규정(제14조제1항)하고 있는바, 지회를 모금회의 내부조직으로 두도록 하면서 별도의 법인격 여부에 대해서는 규정하고 있지 않음.

그리고 「사회복지사업법」 제33조제1항 및 제2항에서 규정하고 있는 '시·군·구협의회를 둘 수 있고[40], 시·군·구협의회를 이 법에 따른 사회복지법인으로 한다'는 내용은 2003년 7월 30일 법률 제6960호로 「사회복지사업법」이 일부개정되면서 신설된 것인데, 해당 규정은 사회복지서비스는 작은 지역사회단위로 하여 제공하는 것이 수요파악·자원동원 및 서비스 전달 등에 있어서 이점을 가질 수 있으므로 시·군·구 사회복지의 증진을 위하여 전국 혹은 시·도와 별개로 시·군·구에 사회복지협의회를 둘 필요가 있고, 특히 당시 시·군·구에 시·도협의회의 지회 형태로 설치하여 시·군·구협의회에 해당하는 기능을 수행하고 있었으나 사회복지협의회의 설립 촉진 및 대외관계와 사업수행상의 편의를 위해 지회가 아닌 별개의 '독립된 사회복지법인'으로 해야 할 필요가 있다는 점을 고려하여 신설된 것[41]이므로, 시·군·구협의회를 별개의 사회복지법인으로 설립하지 않고 중앙협의회의의 지회로 둘 수는 없다고 보는 것이 「사회복지사업법」 제33조의 개정연혁이나 취지에도 부합한다고 할 것입니다.

따라서 「사회복지사업법」 제33조제1항에 따른 시·군·구협의회를 별개의 사회복지법인으로 설립하지 않고 중앙협의회의 지회로 둘 수 없습니다.

다. 질의 나에 대해

그렇다면 「사회복지사업법」 제33조제2항에서 "시·군·구협의회는 이 법에 따른 사회복지법인"으로 하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제14조 및 제15조에서는 시·군·구협의회는 임원으로 대표이사·이사·감사를 두면서 이사로 구성된 이사회를 두도록 규정하고 있는 반면, 시·군·구협의회를 시·도협의회의 지회나 내부조직으로 둘 수 있도록 하는 예외를 규정하고 있지 않은바, 시·군·구협의회도 중앙협의회 및 시·도협의회와 같이 이 법에 따른 사회복지법인으로 해야 할 것이므로, 같은 법 제33조제1항에 따른 시·군·구협의회를 '시·도협의회의 지회'로 둘 수는 없는 것이 문언상 분명합니다.

그리고 「사회복지사업법」 제33조제1항 및 제2항에서 규정하고 있는 '시·군·구협의회를 둘 수 있고, 시·군·구협의회를 이 법에 따른 사회복지법인으로 한다'는 내용은 2003년 7월 30일 법률 제6960호로 「사회복지사업법」이 일부개정되면서 신설된 것인데, 해당 규정은 사회복지서비스는 작은 지역사회단위로 하여 제공하는 것이 수요파악·자원동원 및 서비스 전달 등에 있어서 이점을 가질 수 있으므로 시·군·구 사회복지의 증진을 위하여 전국 혹은 시·도와 별개로 시·군·구에 사회복지협의회를 둘 필요가 있고, 특히 당시 시·군·구에

40) 2024년 1. 2. 법률 제19893호로 일부개정되어 2025. 1. 3. 시행 예정인 「사회복지사업법」 제33조제1항에서는 '시·군·구협의회를 둔다'고 개정되었으며, 이하 같음

41) 2003. 3. 17. 의안번호 제162145호로 발의된 사회복지사업법중개정법률안에 대한 국회 보건복지위원회 심사보고서 참조

시·도협의회의 지회 형태로 설치하여 시·군·구협의회에 해당하는 기능을 수행하고 있었으나 사회복지협의회의 설립 촉진 및 대외관계와 사업수행상의 편의를 위해 지회가 아닌 별개의 '독립된 사회복지법인'으로 해야 할 필요가 있다는 점을 고려하여 신설된 것이므로, 시·군·구협의회를 별개의 사회복지법인으로 설립하지 않고 시·도협의회의 지회로 둘 수는 없다고 보는 것이 「사회복지사업법」 제33조의 개정연혁이나 취지에도 부합한다고 할 것입니다.

따라서 「사회복지사업법」 제33조제1항에 따른 시·군·구협의회를 별개의 사회복지법인으로 설립하지 않고 시·도협의회의 지회로 둘 수 없습니다.

관계법령

사회복지사업법

제33조(사회복지협의회) ① 사회복지에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 전국 단위의 한국사회복지협의회(이하 "중앙협의회"라 한다)와 시·도 단위의 시·도 사회복지협의회(이하 "시·도협의회"라 한다)를 두며, 필요한 경우에는 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 단위의 시·군·구 사회복지협의회(이하 "시·군·구협의회"라 한다)를 둘 수 있다.

1. ~ 4. (생 략)

② 중앙협의회, 시·도협의회 및 시·군·구협의회는 이 법에 따른 사회복지법인으로 하되, 제23조제1항은 적용하지 아니한다.

③ (생 략)

④ 중앙협의회, 시·도협의회 및 시·군·구협의회의 조직과 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

사회복지사업법 시행령

제14조(임원) ① 중앙협의회, 시·도협의회 및 시·군·구협의회(이하 "각 협의회"라 한다)는 임원으로 대표이사 1인을 포함한 15인 이상 30인 이하(시·군·구협의회의 경우에는 10인 이상 30인 이하)의 이사와 감사 2인을 둔다.

② 이사와 감사의 임기는 3년으로 하되, 각각 연임할 수 있다.

③ 임원의 선출방법과 그 자격요건에 관하여 필요한 사항은 정관으로 정한다.

제15조(이사회) ① 각 협의회에 이사로 구성되는 이사회를 둔다.

② 이사회는 정관이 정하는 바에 따라 각 협의회의 업무에 관한 중요사항을 심의·의결한다.

③ 대표이사는 이사회를 소집하고, 그 의장이 된다.

④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑤ 이사회의 운영에 관하여 필요한 사항은 정관으로 정한다.

질의제목 10 ▶ 안건번호 24-0654

보건복지부 – 「공중위생관리법 시행규칙」 제3조제1항제1호의2에 따른 영업시설 및 설비의 사용에 관한 권리를 확보하였음을 증명하는 서류 제출의무자의 범위(「공중위생관리법 시행규칙」 제3조제1항제1호의2 관련)

01 질의요지

「공중위생관리법」 제3조제1항에서는 공중위생영업을 하고자 하는 자는 공중위생영업의 종류별로 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비를 갖추고 시장·군수·구청장[42]에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제6항에서는 신고의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제3조제1항제1호의2에서는 같은 법 제3조제1항에 따라 공중위생영업의 신고를 하려는 자가 신고서[43]에 첨부해야 하는 서류로 '영업시설 및 설비의 사용에 관한 권리를 확보하였음을 증명하는 서류(이하 "사용권확보증명서류"라 함), 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제3조에 따른 공용부분에서 사건·사고 등 발생 시 영업자의 배상책임을 담보하는 보험증서 또는 영업자의 배상책임 부담에 관한 공증서류(이하 "배상책임담보서류"라 함)'를 규정하면서 마지막 부분에 괄호를 두어 '건물의 일부를 대상으로 숙박업 영업신고를 하는 경우[44]에만 해당한다'고 규정하고 있는바,

「공중위생관리법 시행규칙」 제3조제1항제1호의2에 따른 사용권확보증명서류는 건물의 일부를 대상으로 숙박업 영업신고를 하는 경우에만 제출하는지, 아니면 모든 업종의 공중위생영업 신고를 하는 경우에 제출해야 하는지?

42) 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음

43) 전자문서로 된 신고서를 포함하며, 이하 같음

44) 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 적용을 받는 경우를 말하며, 이하 같음

02 회답

「공중위생관리법 시행규칙」 제3조제1항제1호의2에 따른 사용권확보증명서류는 건물의 일부를 대상으로 숙박업 영업신고를 하는 경우에만 제출합니다.

03 이유

「공중위생관리법 시행규칙」 제3조제1항제1호의2에서는 "영업시설 및 설비의 사용에 관한 권리를 확보하였음을 증명하는 서류, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제3조에 따른 공용부분에서 사건·사고 등 발생 시 영업자의 배상책임을 담보하는 보험증서 또는 영업자의 배상책임 부담에 관한 공증서류[건물의 일부를 대상으로 숙박업 영업신고를 하는 경우(「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 적용을 받는 경우를 말하며, 이하 같다)에만 해당한다]"라고 규정하여, 하나의 호에서 두 가지 첨부서류(사용권확보증명서류 및 배상책임담보서류)를 열거하면서 마지막 부분에만 대괄호를 두고 있는데, 해당 대괄호의 내용이 배상책임담보서류에만 적용되는 것인지, 사용권확보증명서류와 배상책임담보서류 모두에 적용되는 것인지 문언상 명확하지 않으므로 사용권확보증명서류를 제출해야 하는 경우를 판단하기 위해서는 해당 규정의 입법 취지와 목적 등을 함께 고려할 필요가 있습니다.

먼저 사용권확보증명서류를 첨부하도록 한 「공중위생관리법 시행규칙」 제3조제1항제1호의2는 2020년 8월 28일 보건복지부령 제745호로 일부개정된 「공중위생관리법 시행규칙」에서 신설된 규정인데, 개정 당시의 입법자료[45]에 따르면 그 개정 취지는 건물의 일부를 대상으로 하는 숙박업 영업신고에 필요한 절차와 시설·설비 기준 등을 정하려는 것으로서, 보건복지부령 제745호 공중위생관리법 시행규칙 일부개정령의 주요내용에서는 "건물의 일부를 대상으로 숙박업 영업신고를 하려는 자는 영업시설 및 설비의 사용에 관한 권리를 증명하는 서류 등을 시장·군수·구청장에게 제출하도록 하고"라고 설명하고 있는 점을 고려하면 「공중위생관리법 시행규칙」 제3조제1항제1호의2는 건물의 일부를 대상으로 숙박업 영업신고를 하는 경우에만 사용권확보증명서류를 제출하도록 하려는 취지임이 분명합니다.

또한 「공중위생관리법 시행규칙」 제3조제1항제1호에서는 모든 공중위생영업의 신고를

45) 2020. 8. 28. 보건복지부령 제745호 공중위생관리법 시행규칙 일부개정령 개정이유 및 주요내용 참조

하려는 자는 공중위생영업의 종류별 시설 및 설비기준에 적합한 시설을 갖춘 후 신고서에 영업시설 및 설비개요서를 첨부하여 제출하도록 규정하고 있는데, 사용권확보증명서류의 경우 같은 항 제1호에서 영업시설 및 설비개요서와 함께 열거하여 규정하지 않고, 같은 항 제1호의2에서 별도로 배상책임담보서류와 함께 규정하면서 마지막 부분에 괄호를 두어 서류를 제출하는 경우를 한정하고 있는바, 같은 조 제1항 각 호와 제2항 각 호에서 공중위생영업 신고 시 첨부서류 등을 열거하면서 특정한 경우에만 제출하면 되는 서류의 경우에는 해당 호의 마지막 부분에 괄호를 두어 해당 서류를 제출해야 하는 경우를 한정하는 규정 방식을 취하고 있는 것에 비추어보면, 같은 규칙 제3조제1항제1호의2에서는 건물의 일부를 대상으로 하는 숙박업 영업신고의 경우에만 제출하면 되는 서류로서 사용권확보증명서류를 배상책임담보서류와 함께 규정한 것으로 보아야 할 것입니다.

따라서 「공중위생관리법 시행규칙」 제3조제1항제1호의2에 따른 사용권확보증명서류는 건물의 일부를 대상으로 숙박업 영업신고를 하는 경우에만 제출합니다.

법령정비 권고의견

건물의 일부를 대상으로 하는 숙박업 외의 공중위생영업 신고를 하는 경우에도 사용권확보증명서류를 제출받을 정책적 필요성이 있다면, 다른 공중위생영업 신고를 하는 경우에도 사용권확보증명서류를 제출받을 수 있도록 명확히 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

공중위생관리법

제3조(공중위생영업의 신고 및 폐업신고) ①공중위생영업을 하고자 하는 자는 공중위생영업의 종류별로 보건복지부령이 정하는 시설 및 설비를 갖추고 시장·군수·구청장(자치구의 구청장에 한한다. 이하 같다)에게 신고하여야 한다. 보건복지부령이 정하는 중요사항을 변경하고자 하는 때에도 또한 같다.

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ 제1항부터 제3항까지에 따른 신고의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

공중위생관리법 시행규칙

제3조(공중위생영업의 신고) ①법 제3조제1항에 따라 공중위생영업의 신고를 하려는 자는 제2조에 따른 공중위생영업의 종류별 시설 및 설비기준에 적합한 시설을 갖춘 후 별지 제1호서식의 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 제출해야 한다.

1. 영업시설 및 설비개요서

1의2. 영업시설 및 설비의 사용에 관한 권리를 확보하였음을 증명하는 서류, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제3조에 따른 공용부분에서 사건·사고 등 발생 시 영업자의 배상책임을 담보하는 보험증서 또는 영업자의 배상책임 부담에 관한 공증서류[건물의 일부를 대상으로 숙박업 영업신고를 하는 경우(「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 적용을 받는 경우를 말하며, 이하 같다)에만 해당한다]

2. ~ 5. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

질의제목 11 ▶ 안건번호 24-0679

인천광역시 – 입체적 도시·군계획시설결정으로 공공시설을 설치한 경우로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제65조에 따라 해당 공공시설이 관리청에 무상귀속되는 경우, 관리청은 그 공공시설이 설치되는 토지에 대해 반드시 소유권을 확보해야 하는지(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제65조 등 관련)

01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제43조제2항에서는 효율적인 토지이용을 위해 도시·군계획시설이 위치하는 공간의 일부를 구획하여 도시·군계획시설을 결정(이하 "입체적 도시·군계획시설결정"이라 함)할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제99조 전단에서는 도시·군계획시설사업에 의해 새로 공공시설을 설치한 경우에는 같은 법 제65조를 준용한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제65조제1항 및 제2항에서는 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청(이하 "관리청"이라 함)에 무상으로 귀속된다고 규정하고 있고, 국토계획법 제43조제2항의 위임에 따라 마련된 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」(이하 "도시계획시설규칙"이라 함) 제4조제2항에서는 입체적 도시·군계획시설결정에 따라 도시·군계획시설을 설치하고자 하는 때에는 미리 토지소유자, 토지에 관한 소유권외의 권리를 가진 자 및 그 토지에 있는 물건에 관하여 소유권 그 밖의 권리를 가진 자(이하 "토지소유자등"이라 함)와 구분지상권의 설정 또는 이전 등을 위한 협의를 하여야 한다고 규정하고 있는바,

국토계획법 제43조제2항에 따라 입체적 도시·군계획시설결정으로 공공시설을 설치하는 경우로서 같은 법 제99조에 따라 준용되는 같은 법 제65조에 따라 해당 공공시설이 관리청에 무상으로 귀속되는 경우, 관리청은 그 공공시설이 설치되는 토지에 대해 반드시 소유권을 확보해야 하는지, 아니면 구분지상권만을 설정 또는 이전받으면 되는지?[46]

46) 사업시행자가 토지소유자에 해당하여 토지에 대한 소유권을 가지고 있는 경우임을 전제함

02 회답

이 사안의 경우, 공공시설을 무상귀속 받는 관리청은 해당 공공시설이 설치되는 토지에 대해 반드시 소유권을 확보해야 하는 것은 아니고, 구분지상권만을 설정 또는 이전받으면 됩니다.

03 이유

먼저 국토계획법 제43조제2항에서는 효율적인 토지이용을 위해 입체적 도시·군계획시설 결정을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문에서는 이러한 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치의 기준 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 도시계획시설규칙 제4조제2항에서는 입체적 도시·군계획시설결정에 의해 도시·군계획시설을 설치하고자 하는 때에는 미리 토지소유자등과 구분지상권의 설정 또는 이전 등을 위한 협의를 하여야 한다고 규정하고 있는바, 도시계획시설규칙에 따르면 입체적 도시·군계획시설결정에 따라 도시·군계획시설을 설치하는 경우에는 구분지상권만을 설정 또는 이전한 경우에도 그 시설의 설치가 가능하다고 할 것입니다.

그리고 국토계획법 제46조에서는 도시·군계획시설을 공중·수중·수상 또는 지하에 설치하는 경우 그 높이나 깊이의 기준과 그 설치로 인해 토지나 건물의 소유권 행사에 제한을 받는 자에 대한 보상 등에 관해서는 따로 법률로 정한다고 규정하고 있고, 이에 따라 「도로법」 제28조, 「도시철도법」 제12조, 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 제12조의3, 「수도법」 제60조의3, 「전기사업법」 제89조의2, 「하수도법」 제10조의3 등에서는 도로, 철도, 수도, 전기, 하수도 등 각각의 시설을 설치하려는 자는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 토지 등의 소유자 또는 그 권리자와 토지의 지하부분 사용에 관한 협의가 성립된 경우에는 구분지상권을 설정하거나 이전하여야 한다고 규정하면서, 토지의 지하부분 사용에 관한 구분지상권의 등기절차를 대법원규칙으로 정하도록 규정하고 있으며, 구분지상권의 존속기간은 「민법」 제280조 또는 제281조에도 불구하고 해당 시설이 존속하는 날까지로 한다고 규정하고 있는 등 해당 시설이 설치되는 토지의 구분지상권 설정·이전 의무 및 존속기간에 관한 사항 등을 법률에 명시적으로 규정하고 있는바, 입체적 도시·군계획시설 결정으로 설치하는 공공시설이 위와 같은 법률에서 규정하고 있는 도로, 철도, 수도 등의 시설에 해당한다면 이러한 개별 법률의 규정에 따라 관리청은 그 시설이 설치되는 토지에 대해 구분지상권을 확보하면 되는 것인데, 이처럼 국토계획법 제46조 및 관련 법령의 체계를

고려하면, 도로, 철도, 수도 등의 시설에 해당하지 않는 경우라 하더라도 마찬가지로 그 시설이 설치되는 토지에 구분지상권을 설정 또는 이전받으면 그 시설을 설치할 수 있다고 해석하는 것이 관련 법령의 체계에 부합한다고 할 것입니다.

또한 입체적 도시·군계획시설결정은 한정된 도시 내의 토지자원을 효율적으로 활용하고 도시시설의 확보비용을 절감하기 위해 도입된 제도[47]로서, 2000년 8월 18일 건설교통부령 제257호로 전부개정된 「도시계획시설기준에관한규칙」에서는 제4조(입체적 도시계획시설결정)를 신설하여 관련 내용을 최초로 규정하였고, 해당 규정의 내용이 현행 국토계획법 제43조제2항 및 도시계획시설규칙 제4조로 규정된 것인데, 입체적 도시·군계획시설결정으로 도시·군계획시설을 설치하는 경우에는 민간의 토지를 수용하는 등 토지 소유권을 확보하는 방식이 아닌 해당 토지에 대한 구분지상권만을 설정 또는 이전하는 방식을 활용함으로써 도시·군계획시설이 위치하는 부분 외의 공간은 그 도시·군계획시설이 아닌 용도로 자유롭게 활용할 수 있도록 하여 토지소유자등의 재산권을 보호하고 도시기능의 합리성을 증진함으로써 토지의 효율적인 활용을 도모[48]하려는 해당 규정의 입법 취지에 비추어 볼 때, 입체적 도시·군계획시설결정으로 설치되는 공공시설에 대해서는 같은 법 제65조 및 제99조에 따라 공공시설이 무상귀속되는 경우에도 이러한 입법 취지를 고려하여 관리청은 해당 공공시설이 설치되는 토지의 구분지상권만을 설정 또는 이전받으면 된다고 해석하는 것이 합리적이라 할 것입니다.

한편 국토계획법 제65조 및 제99조에 따라 무상귀속 받은 공공시설을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리하기 위해서는 관리청은 해당 공공시설 및 토지 모두에 대한 독점적·배타적 권리(소유권)를 확보해야 할 필요성이 있다는 의견이 있으나, 같은 법 제65조는 공공시설을 효율적으로 유지·관리하기 위해 해당 공공시설의 소유권을 바로 관리청으로 귀속되도록 하는 규정[49]으로서, 이는 국민의 기본권인 재산권과 관련되어 있다는 점에서 해당 규정에 따른 무상귀속은 행정목적을 달성할 수 있는 필요최소한의 범위 내에서만 이루어지도록 해석해야할 것인바, 입체적 도시·군계획시설결정으로 공공시설을 설치하는 경우에는 관리청은 새로 설치되는 '공공시설'의 소유권을 확보하여 그 공공시설의 관리·사용·수익·처분 등에 관한 권리를 행사하고, 해당 공공시설이 설치되는 '토지'에 대해서는 구분지상권만을 설정 또는 이전받아 그 공공시설이 위치한 공간(지하 등)에 대한 유지·관리를 하면 충분한 것이지, 공공

47) 건설교통부, 입체도시계획의 활성화 방안 연구(2001), p.9 참조

48) 2000. 8. 18. 건설교통부령 제257호로 전부개정되어 같은 날 시행된 「도시계획시설기준에관한규칙」 개정이유 및 주요골자 참조

49) 법제처 2024. 7. 2. 회신 24-0408 해석례, 헌법재판소 2016. 12. 29. 결정 2015헌바333 결정례 참조

이외의 용도의 시설로 활용할 수 있는 '토지' 부분의 소유권을 확보하여 토지 전체의 재산권 행사를 제한하면서까지 그 토지의 관리·사용·수익·처분 등에 관한 권리를 행사할 필요성은 크지 않다는 점에서, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 공공시설을 무상귀속 받는 관리청은 해당 공공시설이 설치되는 토지에 대해 반드시 소유권을 확보해야 하는 것은 아니고, 구분지상권만을 설정 또는 이전받으면 됩니다.

관계법령

국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제43조(도시·군계획시설의 설치·관리) ① (생 략)

② 효율적인 토지이용을 위하여 둘 이상의 도시·군계획시설을 같은 토지에 함께 결정하거나 도시·군계획시설이 위치하는 공간의 일부를 구획하여 도시·군계획시설을 결정할 수 있다.

③ 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치의 기준 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정하고, 그 세부사항은 국토교통부령으로 정하는 범위에서 시·도의 조례로 정할 수 있다. 다만, 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

④ (생 략)

제65조(개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속) ① 개발행위허가(다른 법률에 따라 개발행위허가가 의제되는 협의를 거친 인가·허가·승인 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.

② 개발행위허가를 받은 자가 행정청이 아닌 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 설치한 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 개발행위로 용도가 폐지되는 공공시설은 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치한 공공시설의 설치비용에 상당하는 범위에서 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 양도할 수 있다.

③ ~ ⑨ (생 략)

제99조(공공시설 등의 귀속) 도시·군계획시설사업에 의하여 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 제65조를 준용한다. 이 경우 제65조제5항 중 "준공검사를 마친 때"는 "준공검사를 마친 때(시행자가 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장인 경우에는 제98조제4항에 따른 공사완료 공고를 한 때를 말한다)"로 보고, 같은 조 제7항 중 "제62조제1항에 따른 준공검사를 받았음을 증명하는 서면"은 "제98조제3항에 따른 준공검사증명서(시행자가 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장인 경우에는 같은 조 제4항에 따른 공사완료 공고를 하였음을 증명하는 서면을 말한다)"로 본다.

도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙

제4조(입체적 도시·군계획시설결정) ① 도시·군계획시설이 위치하는 지역의 적정하고 합리적인 토지이용을 촉진하기 위하여 필요한 경우에는 도시·군계획시설이 위치하는 공간의 일부만을 구획하여 도시·군계획시설결정을 할 수 있다. 이 경우 당해 도시·군계획시설의 보전, 장래의 확장가능성, 주변의 도시·군계획시설 등을 고려하여 필요한 공간이 충분히 확보되도록 하여야 한다.
② 제1항의 규정에 의하여 도시·군계획시설을 설치하고자 하는 때에는 미리 토지소유자, 토지에 관한 소유권외의 권리를 가진 자 및 그 토지에 있는 물건에 관하여 소유권 그 밖의 권리를 가진 자와 구분지상권의 설정 또는 이전 등을 위한 협의를 하여야 한다.
③·④ (생 략)

질의제목 12 ▶ 안건번호 24-0682

보건복지부- 의사가 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제50조제1항에 따른 응급입원 동의를 하기 위해서는 반드시 대면 진단을 거쳐야 하는지(「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제50조제1항 등 관련)

01 질의요지

「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」(이하 "정신건강복지법"이라 함) 제50조제1항에서는 정신질환자로 추정되는 사람으로서 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 큰 사람(이하 "응급입원대상자"라 함)을 발견한 사람은 그 상황이 매우 급박하여 같은 법 제41조부터 제44조까지의 규정에 따른 입원등[50]을 시킬 시간적 여유가 없을 때에는 의사와 경찰관의 동의를 받아 정신의료기관에 그 사람에 대한 응급입원을 의뢰할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제68조제1항에서는 누구든지 같은 법 제50조에 따른 응급입원의 경우를 제외하고는 정신건강의학과전문의의 대면 진단에 의하지 아니하고 정신질환자를 정신의료기관등에 입원등을 시키거나 입원등의 기간을 연장할 수 없다고 규정하고 있는바,

의사가 정신건강복지법 제50조제1항에 따른 응급입원의 동의를 하기 위하여 반드시 응급입원대상자에 대한 대면 진단을 거쳐야 하는지?

02 회답

의사가 정신건강복지법 제50조제1항에 따른 응급입원의 동의를 하기 위하여 반드시 응급입원대상자에 대한 대면 진단을 거쳐야 하는 것은 아닙니다.

50) 입원 또는 입소를 말하며(정신건강복지법 제2조제5항 참조), 이하 같음

03 이유

먼저 정신건강복지법 제50조제1항의 문언을 살펴보면 응급입원대상자를 발견한 사람은 의사와 경찰관의 동의를 받아 정신의료기관에 그 사람에 대한 응급입원을 의뢰할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 의사가 같은 항에 따른 동의를 하기 위하여 반드시 응급입원대상자에 대해 대면 진단을 하여야 한다는 등의 규정은 두고 있지 않고, '동의'는 '의사나 의견을 같이 함' 또는 '다른 사람의 행위를 승인하거나 시인함'의 의미로서[51] 그 자체로 대면 진단을 포함하는 의미로 보기도 어렵다는 점에 비추어 볼 때, 의사가 정신건강복지법 제50조제1항에 따른 응급입원의 동의를 하기 위해 반드시 대면 진단을 거쳐야만 하는 것은 아니라고 보는 것이 같은 항의 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 정신건강복지법에서는 응급입원대상자 본인과 그 주변인을 신속하게 보호하기 위하여 응급입원의 경우에는 다른 입원등과 달리 예외적으로 정신건강의학과전문의의 사전 대면 진단 없이도 입원등이 가능[52]하도록(제50조 및 제68조제1항) 하면서, 응급입원을 시킨 정신의료기관의 장은 지체 없이 정신건강의학과전문의에게 그 응급입원한 사람의 증상을 진단하게 하도록(제50조제4항) 규정하고 있는데, 만약 정신건강복지법 제50조제1항에 따른 동의를 하기 위하여 반드시 의사의 대면 진단을 거쳐야만 하는 것으로 본다면 응급입원의 경우에도 의사의 사전 대면 진단이 있어야만 가능한 것과 마찬가지의 결과가 되는바, 정신건강복지법 제50조 및 제68조제1항에 따른 응급입원 제도의 체계 및 취지를 고려하면, 의사가 정신건강복지법 제50조제1항에 따른 응급입원의 동의를 하기 위해서는 반드시 대면 진단을 거쳐야만 하는 것은 아니라고 할 것입니다.

아울러 ① 정신건강복지법 제50조에 따르면 응급입원의 경우 그 기간이 공휴일을 제외하고 3일 이내(제3항)로 길지 않고, 응급입원 후 지체 없이 정신건강의학과전문의에게 증상을 진단하게 하고 있으며(제4항), 정신건강의학과전문의의 진단 결과 그 사람이 계속하여 입원할 필요가 없다고 인정된 경우에는 즉시 퇴원시키도록 하고(제5항) 있고, 이를 위반하여 즉시 퇴원을 시키지 않은 자는 같은 법 제86조제5호에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 하여 응급입원에 대한 엄격한 관리와 통제를 위한 수단이 마련되어 있는 점, ② 정신건강복지법에서도 제19조제4항제5호, 제68조제1항 등에서는 명시적으로 '대면 진단'이라는 용어를 사용하여, 대면 진단이 필요한 경우에는 이를 명확히 규정하고 있는데

51) 국립국어원 표준국어대사전 참조

52) 대법원 2021. 5. 7. 선고 2018도14546 판결례 참조

반해, 같은 법 제50조제1항에 따른 응급입원의 경우에는 그와 같이 규정하고 있지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 의사가 정신건강복지법 제50조제1항에 따른 응급입원 동의를 하기 위하여 반드시 응급입원대상자에 대한 대면 진단을 거쳐야 하는 것은 아닙니다.



관계법령

정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률

제50조(응급입원) ① 정신질환자로 추정되는 사람으로서 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 큰 사람을 발견한 사람은 그 상황이 매우 급박하여 제41조부터 제44조까지의 규정에 따른 입원등을 시킬 시간적 여유가 없을 때에는 의사와 경찰관의 동의를 받아 정신의료기관에 그 사람에 대한 응급입원을 의뢰할 수 있다.

② 제1항에 따라 입원을 의뢰할 때에는 이에 동의한 경찰관 또는 구급대원은 정신의료기관까지 그 사람을 호송한다.

③ 정신의료기관의 장은 제1항에 따라 응급입원이 의뢰된 사람을 3일(공휴일은 제외한다) 이내의 기간 동안 응급입원을 시킬 수 있다.

④ 제3항에 따라 응급입원을 시킨 정신의료기관의 장은 지체 없이 정신건강의학과전문의에게 그 응급입원한 사람의 증상을 진단하게 하여야 한다.

⑤ 정신의료기관의 장은 제4항에 따른 정신건강의학과전문의의 진단 결과 그 사람이 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 있는 정신질환자로서 계속하여 입원할 필요가 있다고 인정된 경우에는 제41조부터 제44조까지의 규정에 따라 입원을 할 수 있도록 필요한 조치를 하고, 계속하여 입원할 필요가 없다고 인정된 경우에는 즉시 퇴원시켜야 한다.

⑥ 정신의료기관의 장은 제3항에 따른 응급입원을 시켰을 때에는 그 사람의 보호의무자 또는 보호를 하고 있는 사람에게 입원이 필요한 사유·기간 및 장소를 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.

제68조(입원등의 금지 등) ① 누구든지 제50조에 따른 응급입원의 경우를 제외하고는 정신건강의학과전문의의 대면 진단에 의하지 아니하고 정신질환자를 정신의료기관등에 입원등을 시키거나 입원등의 기간을 연장할 수 없다.

② (생 략)

질의제목 13 ▶ 안건번호 24-0712

보건복지부 – 「의료법」 제21조제1항 및 제3항에 따라 환자 등이 환자에 관한 기록을 열람하는 경우, 의료기관 개설자는 같은 법 제45조제2항 및 제3항을 근거로 환자 등에게 열람에 대한 비용을 징수할 수 있는지 여부(「의료법」 제21조제1항 등 관련)

01 질의요지

「의료법」 제45조제2항에서는 의료기관 개설자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 의료기관이 환자로부터 징수하는 제증명수수료의 비용을 게시하도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 의료기관 개설자는 같은 조 제2항에서 게시한 금액을 초과하여 징수할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 법 제45조의3에서는 보건복지부장관은 같은 법 제45조의2 제2항에 따른 현황조사·분석의 결과를 고려하여 제증명수수료의 항목 및 금액에 관한 기준을 정하여 고시하도록 규정하고 있는 한편,

「의료법」 제21조제1항에서는 환자는 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자(이하 "의료인등"이라 함)에게 본인에 관한 기록의 열람 또는 그 사본의 발급 등 내용의 확인을 요청할 수 있다고 규정하면서(전단), 이 경우 의료인등은 정당한 사유가 없으면 이를 거부하여서는 안 된다고 규정하고 있고(후단), 같은 조 제3항 본문에서는 의료인등은 환자의 배우자 등이 환자 본인의 동의서와 친족관계임을 나타내는 증명서 등을 첨부하여 요청하는 경우 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하면 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 교부하는 등 그 내용을 확인할 수 있게 하여야 한다고 규정하고 있는바,

환자 등이 「의료법」 제21조제1항 및 제3항에 따라 환자에 관한 기록을 열람하는 경우, 의료기관 개설자는 같은 법 제45조제2항 및 제3항을 근거로 환자 등에게 열람에 대한 비용을 징수할 수 있는지[53]?

53) 의료기관 개설자가 「의료법」 제45조제2항 및 제3항을 근거로 환자에 관한 기록의 열람에 대해서 비용을 징수할 수 있는지 여부만을 해석 대상으로 하는 것을 전제함

02 회답

이 사안의 경우, 의료기관 개설자는 「의료법」 제45조제2항 및 제3항을 근거로 환자에 관한 기록의 열람에 대해서 비용을 징수할 수 없습니다.

03 이유

먼저 「의료법」 제45조제2항 및 제3항에서는 의료기관 개설자는 의료기관이 환자로부터 징수하는 제증명수수료의 비용을 게시하도록 하고, 그 게시한 금액을 초과하여 징수할 수 없도록 규정하면서, 같은 법 제45조의3에서는 보건복지부장관은 제증명수수료의 항목 및 금액에 관한 기준을 정하여 고시하도록 규정하고 있어, 의료법령에서는 환자에 관한 기록에 대해서 의료기관 개설자가 환자 등으로부터 징수할 수 있는 비용으로 "제증명수수료"를 규정하고 있는데, "제증명서"란 진료기록부 사본, 진단서 등 의료기관이 환자의 요청에 따라 발급하는 일체의 서류로서, "제증명수수료"는 이러한 제증명서 발급에 따라 징수하는 수수료를 의미합니다.[54]

그런데 「의료법」 제21조제1항 및 제3항에서는 환자 등이 환자에 관한 기록의 열람을 요청하면 의료인등은 이를 열람하게 하도록 규정하고 있고, 일반적으로 "열람"은 책이나 문서 따위를 죽 훑어보거나 조사하면서 보는 것을 의미하는 것으로서[55], 같은 법 제21조에 따른 환자에 관한 기록의 열람은 환자 등의 요청에 의하여 해당 기록을 보는 것이므로, 진단서·진료확인서 등의 발급과 같은 제증명서 발급과는 차이가 있다고 할 것인바, 환자에 관한 기록의 열람을 제증명서 발급과 동일하게 보아, 제증명수수료에 관한 규정인 「의료법」 제45조제2항 및 제3항을 근거로 환자에 관한 기록의 열람에 대해 비용을 징수할 수 있다고 보기는 어렵습니다.

그리고 「의료법」 제38조의2제8항에서는 의료기관의 개설자는 보건복지부장관이 정하는 범위에서 같은 조 제2항에 따라 촬영한 영상정보의 열람 등에 소용되는 비용을 열람 등을 요청한 자에게 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 「수술실 폐쇄회로 텔레비전 설치·운영 기준」[56]에서는 열람 등에 소용되는 비용을 실비의 범위에서 열람 등을 요청한 자에게 청구할

54) 2016. 7. 8. 의안번호 제2000776호로 발의된 의료법 일부개정법률안에 대한 국회 보건복지위원회 검토보고서 및 「의료법 시행규칙」 제42조의2제3항 등 참조

55) 표준대국어사전 참조

56) 수술실 폐쇄회로 텔레비전 설치·운영 기준(2023. 8., 보건복지부 보건의료정책과) p.15 참조

수 있다고 규정하고 있어, 의료법령에서도 필요한 경우에는 자료의 열람에 대해서 비용을 청구할 수 있도록 근거 규정을 마련하고 있는바, 이러한 규정 체계에 비추어 보더라도 환자에 관한 기록의 열람에 대한 비용의 징수에 대해 명확히 규정하고 있지 않은 「의료법」 제45조제2항 및 제3항을 근거로는 의료기관 개설자가 그 열람에 대해서 비용을 청구할 수 없다고 보는 것이 합리적인 해석입니다.

또한 「의료법」 제45조제2항 및 같은 법 시행규칙 제42조의2제3항에 따라 의료기관 개설자는 진료기록부 사본·진단서 등 제증명수수료의 비용을 접수창구 등 환자 및 환자의 보호자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하도록 하고 있고, 같은 법 제45조제3항에서는 의료기관 개설자가 그 게시한 금액을 초과하여 징수할 수 없도록 규정하고 있으며, 이를 위반하는 경우에는 시정명령(제63조제1항)의 대상이 되고, 그 시정명령을 이행하지 않으면 업무정지(제64조제1항제6호)까지 명할 수 있는데, 이러한 제재처분의 근거 규정은 엄격하게 해석하여야 할 것인바, 「의료법」 제45조에 따라 게시 의무 및 초과 징수 금지 의무가 있는 제증명수수료의 범위에 명문의 규정 없이 환자에 관한 기록의 열람에 대한 비용이 포함된다고 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 의료기관 개설자는 「의료법」 제45조제2항 및 제3항을 근거로 환자에 관한 기록의 열람에 대해서 비용을 징수할 수 없습니다.

법령정비 권고사항

의료기관 개설자가 환자에 관한 기록의 열람을 요청한 자에게 열람에 대한 비용을 징수하는 근거를 명시적으로 규정할 필요성이 있다면 「의료법」 제45조 등 관련 규정에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

관계법령

의료법

제21조(기록 열람 등) ① 환자는 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자에게 본인에 관한 기록(추가기재·수정된 경우 추가기재·수정된 기록 및 추가기재·수정 전의 원본을 모두 포함한다. 이하 같다)의 전부 또는 일부에 대하여 열람 또는 그 사본의 발급 등 내용의 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 정당한 사유가 없으면 이를 거부하여서는 아니 된다.

② 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내주는 등 내용을 확인할 수 있게 하여서는 아니 된다.

③ 제2항에도 불구하고 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 교부하는 등 그 내용을 확인할 수 있게 하여야 한다. 다만, 의사·치과의사 또는 한의사가 환자의 진료를 위하여 불가피하다고 인정한 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 19. (생 략)

제45조(비급여 진료비용 등의 고지) ① 의료기관 개설자는 「국민건강보험법」 제41조제4항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 「의료급여법」 제7조제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 사항의 비용(이하 "비급여 진료비용"이라 한다)을 환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고지하여야 한다.

② 의료기관 개설자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 의료기관이 환자로부터 징수하는 제증명수수료의 비용을 게시하여야 한다.

③ 의료기관 개설자는 제1항 및 제2항에서 고지·게시한 금액을 초과하여 징수할 수 없다.

제45조의3(제증명수수료의 기준 고시) 보건복지부장관은 제45조의2제2항에 따른 현황조사·분석의 결과를 고려하여 제증명수수료의 항목 및 금액에 관한 기준을 정하여 고시하여야 한다.

질의제목 14 ▶ 안건번호 24-0828

인천광역시 연수구 – 보장기관은 「국민기초생활 보장법」 제16조제2항제1호에 따라 지역자활센터에 대하여 “지역자활센터의 설립·운영 비용”과 “같은 조 제1항 각 호의 사업수행 비용”을 모두 지원할 수 있는지(「국민기초생활 보장법」 제16조제2항 등 관련)

01 질의요지

「국민기초생활 보장법」(이하 “기초생활보장법”이라 함) 제16조제1항에서는 보장기관[57]은 수급자 및 차상위자의 자활 촉진에 필요한 같은 항 각 호의 사업을 수행하게 하기 위하여 사회복지법인, 사회적협동조합 등 비영리법인과 단체의 신청을 받아 지역자활센터로 지정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 보장기관은 같은 조 제1항에 따라 지정을 받은 지역자활센터에 대하여 같은 조 제2항 각 호의 지원을 할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 같은 조 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부를 규정하고 있는바,

보장기관은 기초생활보장법 제16조제2항제1호에 따라 지역자활센터에 대하여 “지역자활센터의 설립·운영 비용”과 “같은 조 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부”를 모두 지원할 수 있는지, 아니면 하나만 지원할 수 있는지?

02 회답

보장기관은 기초생활보장법 제16조제2항제1호에 따라 지역자활센터에 대하여 “지역자활센터의 설립·운영 비용”과 “같은 조 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부”를 모두 지원할 수 있습니다.

57) 기초생활보장법에 따른 급여를 실시하는 국가 또는 지방자치단체를 말하며(기초생활보장법 제2조제4호 참조), 이하 같음

03 이유

먼저 기초생활보장법 제16조제2항에서는 보장기관은 지역자활센터에 대하여 같은 항 각 호의 지원을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 항 제1호에서는 "지역자활센터의 설립·운영 비용" 또는 "제1항 각 호의 사업수행비용의 전부 또는 일부"를 규정하고 있는바, 같은 법 제16조제2항제1호에서는 지역자활센터에 대한 지원 사항이 "또는"으로 연결되어 있고, 일반적으로 "또는"은 어느 것을 선택해도 될 때를 의미[58]하므로, 보장기관은 두 가지 지원 사항 중 어느 하나를 선택하여 지원하거나 두 가지 모두를 지원할 수 있다는 취지이지, 두 가지 지원 사항을 모두 지원할 수는 없고 어느 하나만을 지원해야 한다는 취지로 볼 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 기초생활보장법 제16조제2항에서는 보장기관은 지역자활센터에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 각 호로 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 같은 조 제1항 각 호의 사업수행비용의 전부 또는 일부(제1호), 국유·공유 재산의 무상임대(제2호), 보장기관이 실시하는 사업의 우선 위탁(제3호)을 각각 규정하고 있는데, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분에서 "다음 각 호의 지원"이라는 문언을 사용하여 같은 항 각 호에 해당하는 사항을 모두 지원할 수 있도록 규정하고 있는바, 이러한 규정체계에 비추어 보면, 보장기관은 같은 조 제2항 각 호의 지원 사항 모두를 개별적으로 판단하여 지원할 수 있다고 할 것이고, 마찬가지로 같은 항 제1호의 지원 사항의 경우에도 지원 사항 모두에 대해 개별적으로 판단하여 지원할 수 있다고 보는 것이 규정체계에 부합하는 해석입니다.

또한 기초생활보장법 제16조에 따르면 보장기관은 수급자 및 차상위자의 자활 촉진에 필요한 자활의욕 고취를 위한 교육, 자활을 위한 정보제공이나 상담, 직업교육 등을 사업을 수행하게 하기 위하여 지역자활센터를 지정하여 운영하고 있고(제1항), 보장기관은 지역자활센터에 대하여 정기적으로 사업실적 및 운영실태를 평가하고 수급자의 자활촉진을 달성하지 못하는 지역자활센터에 대하여 그 지정을 취소할 수 있으며(제3항), 같은 법 시행규칙 제29조제3항에서는 보건복지부장관은 같은 법 제16조제3항에 따른 평가결과를 지역자활센터의 보조금 등의 지원에 반영할 수 있다고 규정하고 있는데, 이를 종합하여 보면 기초생활보장법령에서는 지역자활센터를 통해 수급자 및 차상위자의 자활 촉진을 위한 각종 사업을 수행할 수 있도록 하기 위하여 보장기관이 지역자활센터의 설립 및 운영에 필요한 비용 등을 지원할 수 있도록 하면서, 지역자활센터를 운영한 사업실적 및 운영실태를 정기적으로

58) 법제처 알기 쉬운 법령 정비기준(2023) p. 150

평가하고 그 결과에 따라 지역자활센터의 지정을 취소하거나 지역자활센터의 보조금 등 지원에 반영할 수 있도록 하고 있는바, 수급자 등의 자활 촉진에 필요한 사항을 효율적으로 지원하기 위하여 지역자활센터를 둔 취지를 고려하면, 보장기관이 지역자활센터에 지원하는 사항인 같은 법 제16조제2항제1호의 지원 사항도 폭넓게 인정하여 지역자활센터의 안정적 운영을 도모할 필요가 있으므로, 그 지원 필요성에 따라 어느 하나를 선택하거나 모두를 선택하여 지원할 수 있다고 보는 것이 타당합니다.

따라서 보장기관은 기초생활보장법 제16조제2항제1호에 따라 지역자활센터에 대하여 "지역자활센터의 설립·운영 비용"과 "같은 조 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부"를 모두 지원할 수 있습니다.

관계법령

국민기초생활 보장법

제16조(지역자활센터 등) ① 보장기관은 수급자 및 차상위자의 자활 촉진에 필요한 다음 각 호의 사업을 수행하게 하기 위하여 사회복지법인, 사회적협동조합 등 비영리법인과 단체(이하 이 조에서 "법인등"이라 한다)를 법인등의 신청을 받아 지역자활센터로 지정할 수 있다. 이 경우 보장기관은 법인등의 지역사회복지사업 및 자활지원사업 수행능력·경험 등을 고려하여야 한다.

1. 자활의욕 고취를 위한 교육
2. 자활을 위한 정보제공, 상담, 직업교육 및 취업알선
3. 생업을 위한 자금융자 알선
4. 자영창업 지원 및 기술·경영 지도
5. 제18조에 따른 자활기업의 설립·운영 지원
6. 그 밖에 자활을 위한 각종 사업

② 보장기관은 제1항에 따라 지정을 받은 지역자활센터에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부
2. 국유·공유 재산의 무상임대
3. 보장기관이 실시하는 사업의 우선 위탁

③ ~ ⑤ (생 략)

제2절 식품의약품

질의제목 1 ▶ 안건번호 23-1079, 24-0176

식품의약품안전처 – 행정처분의 대상이 되는 '둘 이상의 위반행위가 적발된 경우'의 의미(「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 등 관련)

01 질의요지

「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 및 제2호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"는 '위반행위의 종류와 관계없이 둘 이상'의 위반행위가 적발된 경우를 의미하는지, 아니면 '종류가 서로 다른 둘 이상'의 위반행위가 적발된 경우를 의미하는지?

02 회답

「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 및 제2호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"는 위반행위의 종류와 관계없이 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우를 의미합니다.

03 이유

「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 각 목 외의 부분에서는 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 '가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분'한다고 규정하고 있고, 같은 표 Ⅰ 제2호 각 목 외의 부분에서도 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 그 위반행위가 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지에 해당하는 경우에는 각각의 영업정지와

품목 또는 품목류 제조정지 처분기간을 '같은 표 Ⅰ 제1호에 따라 산정'한 후 같은 표 Ⅰ 제2호 각 목의 구분에 따라 처분한다고 규정하고 있는데, 이러한 일반기준이 없는 경우에는 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우 각 위반행위마다 그 처분기준에 따른 처분을 각각 하는 것이 원칙이라고 할 것이나[59], 각각의 위반행위에 따른 처분을 모두 적용하게 되면 영업자에게 과도한 처분이 될 수 있어 이를 방지하기 위해[60] 여러 위반행위 중 가장 무거운 처분기준은 그대로 적용하되, 나머지 처분기준은 각각 그 2분의 1만을 반영하도록 하는 등 완화된 일반기준을 마련한 것입니다.

또한「식품위생법 시행규칙」별표 23 Ⅰ 제1호 각 목 외의 부분 및 제2호 각 목 외의 부분의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"를 종류가 서로 다른 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로 한정하여 해석하면, 같은 위반행위가 둘 이상 적발된 경우에 대해서는 위반행위의 수만큼 행정처분기준이 각각 온전히 적용되어 영업자에 대한 과도한 처분을 방지하기 위하여 일반기준을 마련한 취지에 부합하지 않을 뿐 아니라, 복수의 위반행위를 한 경우 위반행위의 종류가 같다는 이유만으로 서로 다른 종류의 위반행위를 한 경우보다 불리한 결과를 초래하여 위반행위에 따른 제재의 형평성 문제가 발생할 수 있습니다.

아울러「식품위생법 시행규칙」별표 23 Ⅰ 제5호에서는 위반행위의 차수에 따른 행정처분의 기준을 "같은 위반행위"를 한 경우에 적용한다고 규정하여 명시적으로 위반행위의 종류가 같은 경우로 한정한 반면, 같은 표 Ⅰ 제1호 및 제2호에서는 위반행위의 종류를 구분하지 않은 채 "둘 이상의 위반행위"가 적발된 경우라고 규정하고 있을 뿐 "둘 이상의 서로 다른 위반행위"가 적발된 경우라고 한정하고 있지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편「식품위생법 시행규칙」별표 23 Ⅰ 제1호 각 목 외의 부분에서는 "가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다"고 규정하고 있는데, 개별 행정처분기준이 정지처분인 같은 위반행위의 경우에는 정지처분 기간도 각각 동일하하여 '가장 중한 정지처분'이 존재하지 않으므로, 해당 규정은 종류가 서로 다른 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우에만 적용하는 것으로 해석해야 한다는 의견이 있으나, 같은 표 Ⅱ의 개별기준을 살펴보면, 종류가 서로 다른 위반행위라 하더라도 그 정지처분 기간이 서로 동일한 경우가 있다는 점에 비추어 볼 때, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서「식품위생법 시행규칙」별표 23 Ⅰ 제1호 및 제2호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"는 위반행위의 종류와 관계없이 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우를 의미합니다.

---

59) 법제처 2017. 3. 15. 회신 16-0642 해석례 참조

60) 법제처 2020. 11. 5. 회신 20-0166 해석례 참조

관계법령

식품위생법 시행규칙

[별표 23]

행정처분 기준(제89조 관련)

Ⅰ. 일반기준

1. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다.
   가.·나. (생 략)
2. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 그 위반행위가 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지에 해당하는 경우에는 각각의 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지 처분기간을 제1호에 따라 산정한 후 다음 각 목의 구분에 따라 처분한다.
   가. ~ 라. (생 략)
3. ~ 19. (생 략)

Ⅱ.·Ⅲ. (생 략)

질의제목 2 ▶ 안건번호 24-0015

식품의약품안전처 – 하나의 행위가 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 및 「식품위생법」의 위반 행위에 모두 해당되는 경우 행정처분의 적용 법령(「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제4조 및 「식품위생법」 제44조 등 관련)

01 질의요지

「식품 등의 표시 · 광고에 관한 법률」(이하 "식품표시광고법"이라 함) 제4조제1항에서는 식품등[61]에는 각 호의 구분에 따른 사항을 표시하도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 제1항에 따른 표시가 없는 식품등은 판매할 목적으로 영업에 사용해서는 아니 된다고 규정하면서, 같은 법 제16조제3항제1호 및 같은 조 제5항의 위임에 따른 같은 법 시행규칙 별표 7 Ⅱ. 개별기준 제4호가목1)가)에서 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 "시장·군수·구청장등"이라 함)은 같은 법 제2조제11호나목에 따른 영업자인 「식품위생법 시행령」 제21조제8호의 식품접객업자(이하 "식품접객업자"라 함)가 같은 법 제4조제3항을 위반한 경우로서 식품·축산물·식품첨가물(수입품을 포함함)에 대한 표시사항 전부를 표시하지 않은 것을 사용한 경우 영업정지 1개월과 해당 제품 폐기(1차 위반) 등을 규정하고 있는 한편,

「식품위생법」 제44조제1항제8호 및 같은 법 시행규칙 별표 17 제7호나목에서 식품접객업자와 그 종업원의 준수사항으로 식품표시광고법 제4조 등에 따른 표시사항을 모두 표시하지 않은 축산물 등은 음식물의 조리에 사용하여서는 아니 된다고 규정하면서, 같은 법 제75조제1항제13호 및 같은 조 제5항의 위임에 따른 같은 법 시행규칙 별표 23 Ⅱ. 개별기준 제3호(식품접객업)의 표 제10호가목4)에서 식품의약품안전처장 또는 시장·군수·구청장등은 식품접객업자가 법 제44조제1항을 위반한 경우로서 별표 17 제7호나목을 위반한 경우 영업정지 15일(1차 위반) 등을 규정하고 있는바,

식품접객업자 중 「식품위생법 시행령」 제21조제8호나목에 따른 일반음식점영업을 하는 자(이하 "일반음식점영업자"라 함)[62]가 식품표시광고법 제4조제1항에 따른 표시사항 전부를

61) 식품표시광고법 제2조제7호에 따른 "식품, 식품첨가물, 기구, 용기 · 포장, 건강기능식품, 축산물"을 말하며, 이하 같음

62) 「식품위생법」 제37조제4항 및 같은 법 시행령 제25조제1항제8호에 따라 시장·군수·구청장등에게 일반음식점영업 신고를 한 경우를 대상으로 함

표시하지 않은 축산물을 음식물의 조리에 사용하여 영업한 경우, 식품표시광고법 시행규칙 별표 7 Ⅱ. 개별기준 제4호가목1)가)에 따른 행정처분 기준만 적용하면 되는지, 아니면 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅱ. 개별기준 제3호 (식품접객업)의 표 제10호가목4)에 따른 행정처분 기준도 함께 적용할 수 있는지?

02 회답

이 사안의 경우, 식품표시광고법 시행규칙 별표 7 Ⅱ. 개별기준 제4호가목1)가)에 따른 행정처분 기준만 적용하면 됩니다.

03 이유

식품접객업자의 준수사항 위반에 대한 행정처분의 기준을 정하고 있는 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅱ. 개별기준 제3호 (식품접객업)의 표 제10호가목에서는 '식품접객업자의 준수사항(별표 17 제7호자목·파목·머목 및 별도의 개별 처분기준이 있는 경우는 제외한다)의 위반으로서' 1)부터 12)까지를 위반한 경우에 대한 행정처분 기준을 규정하고 있는데, 괄호에서 "별도의 개별 처분기준이 있는 경우"를 같은 목의 위반사항에서 제외하고 있는바, 이 사안에서 식품표시광고법 시행규칙 별표 7 Ⅱ. 개별기준 제4호가목1)가)에서 규정하고 있는 행정처분의 기준이 "별도의 개별 처분기준이 있는 경우"에 해당하는 것인지를 검토할 필요가 있습니다.

먼저 식품위생법령에서는 괄호 앞부분의 "별표 17 제7호자목·파목·머목" 부분은 조항을 특정하여 명시하면서 이와 달리 괄호 뒷부분에서는 "별도로 개별 처분기준이 있는 경우"라고만 하여 그 대상을 포괄적으로 규정하고 있을 뿐 별도의 개별 처분기준이 있는 법령을 식품위생법령으로 한정하고 있지 않은 점, 별도의 개별 처분기준이 있는 법령을 특정하거나 예시하지 않고 포괄적으로 규정한 것은 식품위생 등과 관련된 다른 법령에서 별도의 개별 처분기준이 규정될 수 있어 이를 사전에 조정하려는 취지라고 볼 수 있는 점 등을 고려할 때, 해당 규정은 식품위생법령 뿐만 아니라 다른 법령에 따른 개별 처분기준이 있는 경우에도 식품위생법령의 행정처분 기준 적용대상에서 제외하려는 것으로 해석하는 것이 합리적입니다.

그리고 식품접객업자 등의 준수사항을 규정하고 있는 「식품위생법 시행규칙」 별표 17

제7호의 입법연혁을 살펴보면, 구 「식품위생법 시행규칙」[63] 별표 17 제7호나목에서는 식품접객업자 등의 준수사항으로 '구 「축산물 위생관리법」[64] 제6조제1항에 따른 표시 사항을 모두 표시하지 않은 축산물은 음식물의 조리에 사용하여서는 아니 된다'고 규정하고 있어, 구 「식품위생법 시행규칙」 별표 17 제7호나목의 위반에 따른 행정처분의 대상은 "식품접객업자"였던 반면, 당시 구 「축산물 위생관리법」 제6조제1항에 따른 축산물의 표시기준의 적용대상은 같은 법 제21조제1항에 따른 식육즉석판매가공업자 등의 영업자로서 같은 법 제6조제1항의 위반에 따른 행정처분의 대상은 "식육즉석판매가공업자 등[65]"이었던바, 구 식품위생법령 및 구 축산물 위생관리법령의 의무를 위반한 경우 행정처분의 대상은 각 법률에 따라 서로 다르게 규정되어 있었습니다.

그런데 2018년 3월 13일 법률 제15483호로 식품표시광고법을 제정하여 같은 법 제4조의 식품등의 표시기준에 구 「식품위생법」[66] 제10조 및 구 「축산물 위생관리법」 제6조에 따른 표시기준을 통합하여 이관하면서, 식품표시광고법 시행규칙 별표 7 Ⅱ. 개별기준 제4호 가목1)가)에서 "식품접객업자"가 표시사항 전부를 표시하지 않은 축산물을 사용한 경우에 대한 행정처분기준을 마련하였고, 동시에 '구 「축산물 위생관리법」 제6조'에 따른 축산물의 표시기준이 삭제됨에 따라 구 「식품위생법 시행규칙」 별표 17 제17호나목 중 "「축산물 위생관리법」 제6조제1항"을 "식품표시광고법 제4조"로 개정하여 현행과 같이 규정된 것인바, 이러한 입법연혁 및 규정체계를 고려할 때, 식품표시광고법령에 "식품접객업자가 식품표시광고법 제4조제1항에 따른 표시사항을 위반한 축산물을 사용한 경우"에 대한 행정처분기준을 신설한 이후에도 계속 동일한 행위에 대해 식품표시광고법령 뿐만 아니라 식품위생법령에 따라서도 행정처분 규정을 적용하도록 하려는 입법의도가 있는 것으로 보기는 어렵습니다.

또한 식품표시광고법은 「식품위생법」, 「건강기능식품에 관한 법률」 및 「축산물 위생관리법」에 분산되어 있는 식품등의 표시·광고에 관한 규정을 통합하는 동시에 식품등의 표시·광고에 관한 주요 내용을 법률로 규정함으로써 식품·건강기능식품·축산물·수입식품 등의 관련 영업자들이 표시·광고 규제의 주요 내용을 쉽게 파악할 수 있도록 하기 위하여 제정된 법률[67]로서, 이러한 제정 취지를 고려하여 식품표시광고법 제3조에서는 식품등의 표시 또는 광고에 관하여 다른 법률에 우선하여 같은 법을 적용하도록 규정하고 있는바,

63) 2019. 4. 25. 총리령 제1535호로 타법개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음

64) 2018. 3. 13. 법률 제15487호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음

65) 구 「축산물 위생관리법」 제27조제1항제1호 및 같은 조 제6항의 위임에 따라 규정된 같은 법 시행규칙 별표 11 제2호라목 식육즉석판매가공업 제3호가목 등 참조

66) 2018. 3. 13. 법률 제15484호로 일부개정되기 전의 것을 말함

67) 2019. 3. 14. 법률 제15483호로 제정된 식품표시광고법 관련 국회 보건복지위원회 전문위원 검토보고서 참조

식품등의 표시와 관련한 하나의 행위에 대하여 식품표시광고법 제4조제3항과 「식품위생법」 제44조제1항제8호의 두 개의 법령이 적용되는 이 사안의 경우 식품표시광고법 제3조에 따라 같은 법이 우선 적용되어 식품표시광고법에 따른 행정처분 기준만 적용하도록 하는 것이 「식품위생법」에서 식품등의 표시·광고에 관한 규정을 별도로 분리하여 관련 영업자들이 표시·광고 규제의 주요 내용 및 제재처분의 기준을 쉽게 파악할 수 있도록 개편한 「식품위생법」과 식품표시광고법의 입법취지에도 부합하는 해석입니다.

따라서 이 사안의 경우, 식품표시광고법 시행규칙 별표 7 Ⅱ. 개별기준 제4호가목1)가)에 따른 행정처분 기준만 적용하면 됩니다.

법령정비 권고사항

식품접객업자가 식품표시광고법 제4조에 따른 표시사항 전부를 표시하지 않은 축산물을 음식물의 조리에 사용하여 영업한 경우 식품표시광고법령과 식품위생법령에 따른 행정처분 기준의 적용에 대해 해석상 혼란이 발생하지 않도록 관련 규정을 정비할 필요가 있습니다.

관계법령

식품 등의 표시·광고에 관한 법률

제3조(다른 법률과의 관계) 식품등의 표시 또는 광고에 관하여 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다.
제4조(표시의 기준) ① 식품등에는 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 표시하여야 한다. 다만, 총리령으로 정하는 경우에는 그 일부만을 표시할 수 있다.
1. 식품, 식품첨가물 또는 축산물
가. 제품명, 내용량 및 원재료명
나. 영업소 명칭 및 소재지
다. 소비자 안전을 위한 주의사항
라. 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한
마. 그 밖에 소비자에게 해당 식품, 식품첨가물 또는 축산물에 관한 정보를 제공하기 위하여 필요한 사항으로서 총리령으로 정하는 사항
2.·3. (생 략)
② (생 략)
③ 제1항에 따른 표시가 없거나 제2항에 따른 표시방법을 위반한 식품등은 판매하거나 판매할 목적으로 제조·가공·소분[(小分): 완제품을 나누어 유통을 목적으로 재포장하는 것을 말한다. 이하

같다]·수입·포장·보관·진열 또는 운반하거나 영업에 사용해서는 아니 된다.

식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙

■ 식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙 [별표 7]

행정처분 기준(제16조 관련)

Ⅰ. 일반기준

Ⅱ. 개별기준

1. ~ 3. (생 략)

4. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호의 식품접객업

위반사항	근거 법조문	행정처분 기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
가. 법 제4조제3항을 위반한 경우 1) 식품·축산물·식품첨가물(수입품을 포함한다)에 대한 표시사항을 위반한 경우로서 가) 표시사항 전부를 표시하지 않은 것을 사용한 경우 나) (생 략) 2) (생 략)	법 제14조부터 제16조까지	영업정지 1개월과 해당 제품 폐기	영업정지 2개월과 해당 제품 폐기	영업정지 3개월과 해당 제품 폐기

식품위생법

제44조(영업자 등의 준수사항) ① 제36조제1항 각 호의 영업을 하는 자 중 대통령령으로 정하는 영업자와 그 종업원은 영업의 위생관리와 질서유지, 국민의 보건위생 증진을 위하여 영업의 종류에 따라 다음 각 호에 해당하는 사항을 지켜야 한다.

1. ~ 7. (생 략)

8. 그 밖에 영업의 원료관리, 제조공정 및 위생관리와 질서유지, 국민의 보건위생 증진 등을 위하여 총리령으로 정하는 사항

② ~ ④ (생 략)

식품위생법 시행규칙

제57조(식품접객영업자 등의 준수사항 등) 법 제44조제1항에 따라 식품접객영업자 등이 지켜야 할 준수사항은 별표 17과 같다.

■ 식품위생법 시행규칙 [별표 17]

식품접객업영업자 등의 준수사항(제57조 관련)

~ 6. (생 략)
7. 식품접객업자(위탁급식영업자는 제외한다)와 그 종업원의 준수사항
 가. (생 략)
 나. 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제4조 및 제5조에 따른 표시사항을 모두 표시하지 않은 축산물, 「축산물 위생관리법」 제7조제1항을 위반하여 허가받지 않은 작업장에서 도축·집유·가공·포장 또는 보관된 축산물, 같은 법 제12조제1항·제2항에 따른 검사를 받지 않은 축산물, 같은 법 제22조에 따른 영업 허가를 받지 아니한 자가 도축·집유·가공·포장 또는 보관된 축산물 또는 같은 법 제33조제1항에 따른 축산물 또는 실험 등의 용도로 사용한 동물은 음식물의 조리에 사용하여서는 아니 된다.
 다. ~ 모. (생 략)
8. (생 략)

■ 식품위생법 시행규칙 [별표 23]

행정처분 기준(제89조 관련)

Ⅰ. 일반기준
Ⅱ. 개별기준
 1.·2. (생 략)
 3. 식품접객업
  영 제21조제8호의 식품접객업을 말한다.

위반사항	근거 법령	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
10. 법 제44조제1항을 위반한 경우 가. 식품접객업자의 준수사항(별표 17 제7호 자목·파목·머목 및 별도의 개별 처분기준이 있는 경우는 제외한다)의 위반으로서	법 제71조 및 법 제75조			영업정지 3개월과 해당 제품 폐기
1) ~ 3) (생 략)				
4) 별표 17 제7호나목 및 타목3)·4), 하목, 어목, 저목 또는 처목을 위반한 경우		영업정지 15일	영업정지 1개월	영업정지 3개월

 4. (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0281

식품의약품안전처 – '위반행위에 대하여 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간 중'에 '같은 위반행위가 둘 이상 적발'된 경우 행정처분의 일반기준 적용(「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제4호 등 관련)

01 질의요지

「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호에서는 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다"고 규정하고 있고, 같은 표 Ⅰ 제4호에서는 "위반행위에 대하여 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간 중에 반복하여 같은 사항을 위반하는 경우에는 그 위반횟수마다 행정처분 기준의 2분의 1씩 더하여 처분한다"고 규정하고 있는바,

영업정지에만 해당하는 위반행위 A1이 적발되어 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간 중에 반복하여 같은 사항을 위반한 위반행위로서 각각 다른 날 발생한 A2·A3이 동시에 적발[68]된 경우, 위반행위 A2·A3에 대하여 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 및 제4호 중 제4호만 적용되는지?[69]

02 회답

이 사안의 경우, 위반행위 A2·A3에 대하여 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 및 제4호 중 제4호만 적용됩니다.

---

68) 위반행위 A1이 적발된 이후에 다른 날 위반행위 A2·A3가 각각 발생하여 동시에 적발된 경우로서, A2·A3가 각각 새로운 위반행위임을 전제로 함.

69) 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제4호가 적용되는 경우 A2·A3에 대한 행정처분은 A1에 대한 행정처분에 A2·A3의 행정처분 기준의 2분의 1씩만 더하여 처분하는 것을 전제로 함.

03 이유

먼저 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제4호에서는 '위반행위에 대하여 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간 중에 반복하여 같은 사항을 위반하는 경우'에는 그 위반횟수마다 행정처분 기준의 2분의 1씩 더하여 처분한다고 규정하고 있고, 이 사안은 영업정지에만 해당하는 위반행위 A1이 적발되어 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간 중에 반복하여 같은 사항을 위반한 위반행위 A2와 위반행위 A3이 발생하여 적발된 경우인바, 이 사안 위반행위에 대한 행정처분에 대해 같은 표 Ⅰ 제4호의 일반기준이 적용된다는 점은 그 문언상 분명합니다.

그리고 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ의 일반기준을 살펴보면, 제1호부터 제3호까지에서는 '둘 이상의 위반행위'가 적발된 경우에 대하여 규정하고 있고, 제4호·제5호에서는 '행정처분을 하기 위한 절차가 진행되거나 완료된 이후에 동일한 위반행위가 반복'하여 적발되는 경우에 대하여 규정하고 있으므로, 같은 표 Ⅰ 제1호부터 제3호까지의 기준은 위반행위를 적발하여 그에 대한 행정처분 절차가 시작되기 전까지 적용되는 일반기준인 반면, 같은 표 Ⅰ 제4호·제5호의 기준은 행정처분 절차가 시작된 이후에 적용되는 일반기준이라고 보는 것이 같은 표 I의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

그렇다면 이 사안에서 위반행위 A2·A3가 동시에 적발된 것 그 자체는 '둘 이상의 위반행위가 적발'된 경우에 해당한다고 하더라도, 이는 종전에 이미 A1이 적발되어 같은 위반행위에 대한 행정처분 절차가 진행되는 기간 중에 반복하여 같은 사항을 위반한 경우로서, 행정처분 절차가 진행되기 전까지만 적용되는 같은 표 Ⅰ 제1호가 아닌 제4호가 적용된다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 위반행위 A2·A3에 대하여 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 및 제4호 중 제4호만 적용됩니다.

관계법령

식품위생법 시행규칙

[별표 23]

행정처분 기준(제89조 관련)

Ⅰ. 일반기준

1. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다.
   가.·나. (생 략)
2.·3. (생 략)
4. 위반행위에 대하여 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간 중에 반복하여 같은 사항을 위반하는 경우에는 그 위반횟수마다 행정처분 기준의 2분의 1씩 더하여 처분한다.
   가. ~ 라. (생 략)
5. ~ 19. (생 략)

Ⅱ.·Ⅲ (생 략)

질의제목 4 ▶ 안건번호 24-0349

민원인 – 위생용품제조업 신고 시 창고를 별도로 갖추지 않아도 되는 경우의 범위(「위생용품 관리법 시행규칙」 별표 1 등 관련)

01 질의요지

「위생용품 관리법」 제3조제1항 전단에서는 위생용품제조업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 기준에 따른 시설을 갖추고 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장[70](이하 "시장등"이라 함)에게 신고해야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 별표 1 제2호다목1)다)(5)에서는 위생용품제조업의 '창고 등의 시설' 기준으로서 원료와 제품을 위생적으로 보관·관리할 수 있는 창고를 갖추어야 하되, 위생용품제조업자가 「식품위생법 시행령」 제21조제3호에 따른 식품첨가물제조업(이하 "식품첨가물제조업"이라 함)을 함께 운영하면서 해당 영업소의 창고 등 시설을 공동으로 이용하는 경우에는 창고를 갖추지 않을 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「식품위생법」 제36조제1항제1호에서는 식품첨가물의 제조업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 기준에 맞는 시설을 갖추어야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「식품위생법 시행규칙」 별표 14 제3호 본문에 따라 식품첨가물제조업의 시설기준에 준용되는 식품제조·가공업의 시설기준 중 같은 표 제1호바목1)나)에서는 '창고 등의 시설' 기준으로서 같은 영업자가 같은 나)의 (1)부터 (4)까지의 어느 하나에 해당하는 영업을 하면서 해당 영업소의 창고 등 시설을 공동으로 이용하는 경우에는 창고를 갖추지 않을 수 있다고 규정하고 있는데, 그 (1)부터 (4)까지에는 「위생용품 관리법」에 따른 위생용품제조업이 규정되어 있지 아니한바,

위생용품제조업을 하려는 자가 식품첨가물제조업을 운영하고 있는 경우로서 식품첨가물제조업 영업소의 창고[71]를 위생용품제조업의 창고로 공동으로 이용[72]하려는 경우, 위생용품제조업의 창고를 별도로 갖추지 않아도 위생용품제조업의 시설기준을 갖춘 것으로 볼 수 있는지?

---

70) 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음

71) 「식품위생법」에 따른 시설기준에 적합한 경우를 전제로 함

72) 위생용품제조업과 식품첨가물제조업에 사용되는 원료 또는 제품 간에 교차 오염의 우려가 없는 것을 전제로 함

02 회답

이 사안의 경우, 위생용품제조업의 창고를 별도로 갖추지 않아도 위생용품제조업의 시설기준을 갖춘 것으로 볼 수 있습니다.

03 이유

먼저 「위생용품 관리법」 제3조제1항 전단에서는 위생용품제조업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 기준에 따른 시설을 갖추고 시장등에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제2조 및 별표 1 제2호다목1)의 본문에서는 위생용품제조업의 시설기준으로서 원료와 제품을 위생적으로 보관·관리할 수 있는 창고를 갖추어야 한다고 규정하면서, 같은 1)의 단서에서 "다음의 가)부터 다)까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 창고를 갖추지 않을 수 있다"고 규정하고 있으며, 같은 1)의 다)에서는 창고를 갖추지 않을 수 있는 경우로서 '위생용품제조업자가 다음의 (1)부터 (5)까지의 규정 중 어느 하나에 해당하는 영업을 함께 운영하면서 해당 영업소의 창고 등 시설을 공동으로 이용하는 경우'를 규정하고 있고, 같은 다)의 (5)에서는 "「식품위생법 시행령」 제21조제1호·제3호에 따른 식품제조·가공업 또는 식품첨가물제조업"을 규정하고 있는바, 위생용품제조업을 하려는 자가 식품첨가물제조업을 함께 운영하면서 식품첨가물제조업 영업소의 창고를 위생용품제조업의 창고로 공동으로 이용하려는 경우에는 위생용품제조업의 창고를 별도로 갖추지 않을 수 있다는 것이 위생용품 관리법령의 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 위생용품제조업의 창고를 갖추지 않을 수 있는 요건 중 하나인 「위생용품 관리법 시행규칙」 별표 1 제2호다목1)다)는 2022년 3월 30일 같은 규칙이 총리령 제1802호로 일부개정되면서 신설되었는데, 같은 다)에서는 위생용품제조업자가 의약품, 화장품, 식품첨가물 제조업 등 같은 다)의 (1)부터 (5)까지 중 어느 하나에 해당하는 영업을 함께 운영하면서 해당 영업소의 창고 등 시설을 공동으로 이용하는 경우 위생용품제조업을 위한 별도의 창고를 갖추지 않을 수 있도록 규정하고 있는바, 이는 위생용품제조업의 시설 기준을 완화하여[73] 중복 시설투자에 따른 영업자의 비용 부담을 완화하고, 창업을 활성화하기 위한 것[74]으로서, 이 사안과 같이 위생용품제조업을 하려는 자가 식품첨가물제조업을 운영하고 있는 경우로서

73) 2022. 3. 30. 총리령 제1802호로 일부개정된 「위생용품 관리법 시행규칙」 개정이유 참조

74) 2022. 3. 30. 총리령 제1802호로 일부개정된 「위생용품 관리법 시행규칙」 조문별 제개정이유서 참조

식품첨가물제조업 영업소의 창고를 위생용품제조업의 창고로 공동으로 이용하려는 경우, 위생용품제조업의 창고를 별도로 갖추지 않더라도 위생용품제조업의 시설기준을 갖춘 것으로 보는 것이 입법취지에도 부합한다고 할 것입니다.

아울러 ① 이 사안과 같이 식품첨가물제조업 창고를 갖춘 영업자가 위생용품제조업을 위한 별도의 창고를 갖추지 않고 식품첨가물제조업 창고를 공동으로 이용하려는 경우에 대하여 위생용품제조업의 시설기준을 갖춘 것으로 볼 수 없다고 해석한다면, 식품첨가물제조업 영업소의 창고를 공동으로 이용하는 경우 위생용품제조업의 창고는 갖추지 않을 수 있다고 규정한 「위생용품 관리법 시행규칙」 별표 1 제2호다목1)다)(5)는 사실상 적용할 수 있는 경우가 없어 규정 실익이 없게 된다는 점, ② 「위생용품 관리법」 제3조제1항에 따른 시설기준을 위반한 경우에는 같은 법 제17조제1항제1호에 따른 영업정지나 영업소 폐쇄, 같은 법 제32조제1호에 따른 형벌부과의 대상이 되는바, 형벌법규의 해석은 엄격하여야 하고 명문 규정의 의미를 당사자에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 않는다는 점[75]도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 위생용품제조업의 창고를 별도로 갖추지 않아도 위생용품제조업의 시설기준을 갖춘 것으로 볼 수 있습니다.

법령정비 권고사항

위생용품 관리법령 및 식품위생법령에서 창고를 갖추지 않을 수 있는 요건을 서로 다르게 규정하고 있어 해석상 혼란이 발생할 수 있으므로, 양 법령의 통일적 규정이 필요한지 여부와 통일적 규정을 두는 경우 공동으로 이용하는 창고에 대한 위생기준이 추가로 필요한지 여부를 검토하여 각각의 법령에서 창고 공동 이용에 대한 규정을 명확히 할 필요가 있습니다.

75) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90도1516 전원합의체 판결례 등 참조

관계법령

위생용품 관리법

제3조(영업의 신고) ① 위생용품제조업 또는 위생물수건처리업을 하려는 자는 총리령으로 정하는 기준에 따른 시설을 갖추고 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 총리령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② ~ ④ (생 략)

⑤ 제1항 또는 제2항에 따른 신고의 내용, 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

위생용품 관리법 시행규칙

제2조(영업의 종류별 시설기준) ① 「위생용품 관리법」(이하 "법"이라 한다) 제3조제1항 전단 및 같은 조 제2항 전단에서 "총리령으로 정하는 기준"이란 별표 1을 말한다.

②·③ (생 략)

[별표 1]

영업의 종류별 시설기준(제2조 관련)

1. (생 략)
2. 위생용품제조업 및 위생물수건처리업의 시설기준
   가.·나. (생 략)
   다. 창고 등의 시설
      1) 원료와 제품을 위생적으로 보관·관리할 수 있는 창고를 갖추어야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 창고를 갖추지 않을 수 있다.
         가)·나) (생 략)
         다) 위생용품제조업자 또는 위생물수건처리업자가 다음의 어느 하나에 해당하는 영업을 함께 운영하면서 해당 영업소의 창고 등 시설을 공동으로 이용하는 경우
            (1) ~ (4) (생 략)
            (5) 「식품위생법 시행령」 제21조제1호·제3호에 따른 식품제조·가공업 또는 식품첨가물 제조업
      2) (생 략)
   라. ~ 바. (생 략)
3. (생 략)

질의제목 5 ▶ 안건번호 24-0652, 24-0797, 24-0798

식품의약품안전처 – 다른 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우 등에 대한 행정처분의 일반기준 적용(「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제3호 등 관련)

01 질의요지

「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호에서는 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다고 규정하고 있고, 같은 표 Ⅰ 제2호에서는 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 그 위반행위가 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지에 해당하는 경우에는 각각의 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지 처분기간을 제1호에 따라 산정한 후 같은 호 각 목의 구분에 따라 처분한다고 규정하고 있으며, 같은 표 Ⅰ 제3호에서는 같은 날 제조한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항(「식품위생법」 제7조제4항 위반행위의 경우에는 식품등의 기준과 규격에 따른 같은 기준 및 규격의 항목을 위반한 것을 말함)이 적발된 경우에는 같은 위반행위로 본다고 규정하고 있는바,

① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항[76]이 둘 이상 적발된 경우[77]가 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 및 제2호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”에 해당하는지?

02 회답

① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우는 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 및 제2호의 “둘 이상의 위반행위가 적발된 경우”에 해당합니다.

---

76) 「식품위생법」 제7조제4항 위반행위의 경우에는 식품등의 기준과 규격에 따른 같은 기준 및 규격의 항목을 위반한 것을 말하며, 이하 같음

77) 다른 날 제조한 다른 품목, 다른 날 제조한 같은 품목 또는 같은 날 제조한 다른 품목에 대한 둘 이상의 “같은 위반사항”을 행정청이 “하나의 위반사항”으로 보아 1건만 적발할 수 있는지 여부는 별론으로 함

03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[78], 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제3호에서는 "같은 날 제조한 같은 품목"에 대하여 같은 위반사항이 적발된 경우에는 "같은 위반행위"로 본다고 규정하고 있고, 이는 "같은 날 제조한 같은 품목"에 대하여 같은 위반사항이 복수의 제품에서 발생한 경우에도 "하나의 위반행위"로 보아 영업정지, 품목 또는 품목류 제조정지 처분기간을 가중하지 않도록 하여 과도한 제재를 방지하기 위한 취지의 규정인바[79], 같은 호의 문언에 대한 반대해석상 "같은 날 제조한 같은 품목"이 아닌 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우에는 "하나의 위반행위"로 보기 어렵다고 할 것이므로, 이 사안과 같이 ① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우는 하나의 위반행위가 아니라 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우에 해당한다고 할 것입니다.

또한 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ의 일반기준의 규정체계를 살펴보면, 제1호부터 제3호까지는 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"에 대한 행정처분 일반기준을 규정하고 있는 것이고[80], 그중 제3호는 적발된 둘 이상의 위반행위를 예외적으로 하나의 위반행위로 간주하는 경우를 규정하고 있는 것인데, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 엄격하게 해석할 필요가 있으며[81], 이에 따라 제3호의 적용대상이 아니라면 원칙적으로 제1호 및 제2호의 적용대상이 된다고 할 것인데, 같은 표 Ⅰ 제1호 및 제2호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"란 위반행위의 종류와 관계없이 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우를 의미하는바[82], 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우에도 같은 표 Ⅰ 제1호 및 제2호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"에 해당 한다는 점에 비추어 보면, 이 사안과 같이 ① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우는 같은 표 Ⅰ 제1호 및 제2호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"에 해당한다고 보는 것이 같은 표

78) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
79) 법제처 2015. 2. 17. 회신 15-0016 해석례 참조
80) 법제처 2024. 4. 24. 회신 24-0281 해석례 참조
81) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조
82) 법제처 2024. 3. 20. 회신 23-1079 해석례 참조

I. 일반기준의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

한편 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제3호에 따른 같은 날 제조한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항이 적발된 경우에 해당하지 않는다는 이유만으로 이 사안의 경우를 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"로 보아 위반행위의 수만큼 행정처분을 한다면, 영업자에 과도한 처분이 될 수 있으므로, 같은 위반사항의 경우에는 이를 하나의 위반행위로 보아야 한다는 의견이 있으나, 행청처분은 그 실효성을 확보하기 위해서 위반행위가 둘 이상이라면 각각의 위반행위에 대해 제재처분을 내릴 필요가 있다고 할 것이고, 그 위반행위의 위반사항이 동일하다고 하여 이를 달리 볼 것은 아니라는 점[83]을 고려하면, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 ① 다른 날 제조한 다른 품목, ② 다른 날 제조한 같은 품목 또는 ③ 같은 날 제조한 다른 품목에 대하여 같은 위반사항이 둘 이상 적발된 경우는 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 및 제2호의 "둘 이상의 위반행위가 적발된 경우"에 해당합니다.

관계법령

식품위생법 시행규칙

제89조(행정처분의 기준) 법 제71조, 법 제72조, 법 제74조부터 법 제76조까지 및 법 제80조에 따른 행정처분의 기준은 별표 23과 같다.

[별표 23]

행정처분 기준(제89조 관련)

Ⅰ. 일반기준

1. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 위반행위가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가장 중한 정지처분 기간에 나머지 각각의 정지처분 기간의 2분의 1을 더하여 처분한다.
   가.·나. (생 략)
2. 둘 이상의 위반행위가 적발된 경우로서 그 위반행위가 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지에 해당하는 경우에는 각각의 영업정지와 품목 또는 품목류 제조정지 처분기간을 제1호에 따라 산정한 후 다음 각 목의 구분에 따라 처분한다.
   가. ~ 라. (생 략)

83) 법제처 2018. 1. 16. 회신 17-0655 해석례 참조

3. 같은 날 제조한 같은 품목에 대하여 같은 위반사항(법 제7조제4항 위반행위의 경우에는 식품등의 기준과 규격에 따른 같은 기준 및 규격의 항목을 위반한 것을 말한다)이 적발된 경우에는 같은 위반행위로 본다.
4. ~ 19. (생 략)

Ⅱ.·Ⅲ. (생 략)

2024
법령해석 사례집 (상)

편집·발행 법제처 법령해석총괄과
전화 : 044-200-6706
팩스 : 044-200-6970
주소 : 30102
세종특별자치시 도움5로 20,
정부세종청사 법제처(7-1동)

홈 페 이 지 www.moleg.go.kr

인 쇄 일 2025년 6월

발 행 일 2025년 6월

제 작·인 쇄 한결엠 02-6952-0551 www.hgm6952.com

중증장애인생산품생산시설
사회적협동조합
사회적기업